

JEFFERSON CARÚS GUEDES

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

XI

ARTIGOS 719 AO 770

LUIZ GUILHERME MARINONI

DIRETOR

SÉRGIO CRUZ ARENHART

DANIEL MITIDIERO

COORDENADORES



THOMSON REUTERS

REVISTA DOS
TRIBUNAIS™

2019 - 11 - 26

Comentários ao CPC - v. XI - Marinoni - Ed. 2018

SOBRE O AUTOR

Sobre o Autor

Doutor em Direito das Relações Sociais, com tese sobre a Igualdade e Desigualdade no Processo Civil, pela PUC-SP (2008). Mestre no mesmo Programa de Direito (2001). Especialista em Processo Civil pela PUC-RS (1996). Graduação em Direito pela Universidade da Região de Campanha/URCAMP – Bagé-RS (1993).

Professor do UniCEUB na Graduação, Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado. Publicou pela Editora Revista dos Tribunais: *Princípio da Oralidade* (2003) e *Igualdade e Desigualdade* (2014); atualizou em coautoria 4 tomos do *Tratado de Direito Privado* de Pontes de Miranda (2012), dentre outras obras.

Advogado e Consultor Jurídico em Brasília. Advogado da União (AGU), 2000-2018, exerceu funções de Procurador-Geral da União, Procurador-Chefe Nacional do INSS, Consultor Jurídico do Ministério da Previdência Social, Diretor da Escola da AGU e Vice-Presidente Jurídico dos Correios.

© desta edição [2018]

Agradecimentos

Há quase 20 anos, nos idos de 1998, em Umuarama-PR, acompanhei a visita de um jovem processualista da Capital paranaense ao interior, à UNIPAR, para palestra em Semana Jurídica. *Naquele então* conversamos Luiz Guilherme Marinoni e eu pela primeira vez e, depois disso, nos cruzamos outras tantas ocasiões, às vezes com seus fiéis companheiros de estudos e projetos, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, às vezes em Brasília ou outros lugares em lançamentos de livros, congressos etc.

Um desses reencontros recentes foi patrocinado pela Prof. Betina Günther Silva, em meados de 2014, que os levou à reunião de nosso Grupo de Pesquisa = "*ISO*" *Desigualdade e Justiça Processual*, no UniCEUB, em Brasília, permitiu-nos mais uma reaproximação e o posterior convite para participar dos *Comentários ao Código de Processo Civil*, agora publicado pela Revista dos Tribunais.

Convidado, aceitei de imediato, sob a condição de irretratabilidade.

Planejei demasiadamente; como *suele* ser. Na execução, muito me debati e debati com colegas advogados, professores, alunos do Doutorado, Mestrado e Graduação do UniCEUB e de outras instituições.

Devo inumeráveis agradecimentos a todos:

Principio e destaco o empenho de Reno Gomes Lopes (IESB), Thiago Garcia Costa, Marcelo Tadeu de Assunção Sobrinho, Leonardo Arêba Pinto, Déborah Said Silva, Flavia Harckbart de Oliveira (IESB) e Carla Guedes Barroso.

Aos atentos revisores críticos, Mestres e/ou mestrandos e doutorandos do UniCEUB: Mario Jorge Panno de Mattos, Bruna Barbieri Waquin, Ricardo Rocha Leite, Breno Zoehler Santa Helena, José Amilton Torquato e Marcos Antonio Tavares Martins.

Finalizo pelos outros alunos os do Doutorado e Mestrado do UniCEUB: Thiago Aguiar de Pádua, Fabio Luiz Bragança Ferreira, Lucas de Castro Rivas, Ana Caroline Pereira Lima e Sergio Ricardo Cruz, que não faltaram a nenhum debate.

Ainda aos colegas da Advocacia-Geral da União – AGU – na Consultoria Jurídica do Ministério dos Transportes [Portos e Aviação] e aos Professores da Graduação e do PPG – Mestrado e Doutorado do UniCEUB.

Agradeço também...

Aos amigos Joaquim Portes de Cerqueira Cesar, Mauro Luciano Hauschild, Otavio Luiz Rodrigues Jr. (USP) e Carlos José Guimarães (UERJ) pela rica convivência na advocacia privada ou pública e no magistério, pela fidalguia e pela atenção aos 'seus'.

Ao Juca – José Carlos Teixeira Giorgis –, sempre e em cada livro, pelo carinhoso estímulo (desde os idos de 1980 na URCamp, em Bagé-RS) e pela incomum capacidade de "escrever muitos livros na cabeça" e tirá-los vários no papel.

Apresentação

Desde a formação da ciência jurídica como a conhecemos, a prática do direito orientou-se pela doutrina formada em torno de textos dotados de autoridade – primeiro com a *Glosa* e logo em seguida com os *Comentários*. Esse hábito de argumentar invocando a *communis opinio doctorum* é particularmente tão arraigado na tradição luso-brasileira que a glosa de Accursio e opinião de Bartolus constituíam fonte subsidiária do direito nas Ordenações Afonsinas e Manuelinas, tendo inclusive mantido esse mesmo patamar nas Ordenações Filipinas – com a única diferença de que a glosa de Accursio e a opinião de Bartolus não poderiam ser contrárias à *communis opinio doctorum* para então figurarem como fonte do direito.

Nesse cenário, em que se refletem as mais fundas raízes da cultura jurídica brasileira, é natural que os *Comentários* tenham tido grande proeminência na conformação da prática do direito brasileiro. Especialmente no campo do processo civil, não só o Código de 1939 despertou a atenção para a redação de textos com intenção sistemática, mas também o Código de 1973 experimentou idêntico interesse.

Atenta à tradição – e ao mesmo tempo ciente de seu compromisso em renová-la à luz das necessidades atuais – a Editora Revista dos Tribunais/Thomson Reuters organizou não só duas coleções de *Comentários ao Código de 1973* (a primeira organizada por Sérgio Bermudes e a segunda por Ovídio Baptista da Silva), mas igualmente se preocupou em convidar-nos para coordenar estes *Comentários*, os primeiros a constituírem uma coleção completa entregue à cultura jurídica nacional a respeito do Código de 2015. A fim de que o seu conteúdo pudesse espelhar os diferentes fios que se entrelaçam para dar sustentação ao processo civil brasileiro, a coleção é composta de autores do mais alto nível de formação acadêmica, atuantes em diferentes segmentos da prática jurídica e pertencentes a todos os quadrantes do nosso país.

Estes *Comentários* estão voltados a todos aqueles que trabalham diariamente com o Código de Processo Civil. É por essa razão que é uma grande alegria apresentar esta coleção de *Comentários ao Código de Processo Civil de 2015*, ao mesmo tempo em que agradecemos a confiança depositada pela Editora em nosso trabalho, pelos nossos coautores em nossa capacidade de levar adiante o projeto e pelo público interessado em torná-los seus instrumentos de trabalho. Enredar-se na tradição a fim de torná-la sempre viva e comprometida com a prática do direito é motivo de enorme felicidade para nós – ainda mais quando o seu objeto é o processo civil, ramo das leis mais rente à vida, sem o qual a tutela dos direitos não passa de uma mal-acabada impressão.

Luiz Guilherme Marinoni

Sérgio Cruz Arenhart

Daniel Mitidiero

SUMÁRIO

Breve ensaio inicial sobre a Jurisdição Voluntária brasileira atual

1. Uma tradição que se mantém
2. Definições ou conceitos de Jurisdição Voluntária
3. Características e critérios de distinção entre jurisdição voluntária e contenciosa
4. Funções da Jurisdição Voluntária
5. Jurisdição, ação, processo e procedimento na Jurisdição Voluntária
6. Sujeitos processuais imparciais, sujeitos parciais ou interessados e terceiros
7. Funções Essenciais à Justiça e a jurisdição voluntária atual
8. Direito material e suas áreas, diversidade e classificações na Jurisdição Voluntária

CAPÍTULO XV - Dos Procedimentos de Jurisdição Voluntária

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ÍNDICE ALFABÉTICO-REMISSIVO

Comentários ao CPC - v. XI - Marinoni - Ed. 2018

1. BREVE ENSAIO INICIAL SOBRE A JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA BRASILEIRA ATUAL

1. Breve Ensaio Inicial sobre a Jurisdição Voluntária Brasileira Atual

Este Breve Ensaio Inicial situa a atual Jurisdição Voluntária no cenário de apresentação do novo processo civil brasileiro, marcado cada vez mais pela influência do Direito Constitucional e pela nova concepção contemporânea de processo civil num Estado Constitucional, como meio de proteção a direitos fundamentais, com a criação de técnicas adequadas à tutela de direitos, ampliação da tutela específica, adaptabilidade dos procedimentos, ampliação dos poderes do juiz, busca de consensualidade de técnicas autocompositivas, reconhecimento da disponibilidade regrada de interesses públicos, autorização de negócios processuais, ampliação da força das decisões e aceitação das técnicas de precedentes, entre outras.

1. Uma tradição que se mantém

A jurisdição voluntária na história jurídica ocidental remonta à tradição latina e ao Direito Romano.¹ Sua expressão no Direito Romano foi pequena em seus diversos períodos, considerada a obra central de Vittorio Scialoja, que ao longo todo o livro refere apenas duas vezes a essa espécie jurisdicional.² Nos períodos intermédios do direito processual manteve-se a jurisdição voluntária na Europa continental, passando ao Direito Comum Medieval, ao Direito Romano-Canônico e aos direitos locais nacionais que a esses sucederam.³

Os países de tradição romano germânica ou *civil law* (Europa Continental e América do Sul) nos últimos dois séculos têm preservado, com espaço variável, esta atividade jurisdicional ou modalidade de ‘intervenção estatal judicial nos negócios e interesses privados’, segundo características culturais e tradições também locais. Não é possível traçar um padrão geral ou mesmo regional, sendo integralmente oscilantes os critérios que fazem pender ora para um dos lados, ora para outro; ora prestigiando, ora enfraquecendo essa atividade jurisdicional.

Países de tradição do *common law* também possuem atividades judiciais que podem ser classificadas como jurisdição voluntária ou não contenciosa.

O Brasil, desde as leis processuais portuguesas e as leis propriamente nacionais trazem referências às matérias hoje identificadas como jurisdição voluntária, como agora o CPC/2015, e antes, o CPC/1973,⁴ CPC/1939,⁵ CPCs Estaduais,⁶ Regulamento/22.11.1861, Regulamento 737/1850,⁷ Regulamento/15.03.1842, Regulamento/15.03.1842,⁸ Ordenações Filipinas/ 1603,⁹ Ordenações Manuelinas/1521,¹⁰ Ordenações Afonsinas/1446.¹¹

As atividades afetas atualmente, à jurisdição voluntária, o são por circunstâncias externas ao direito processual e sofrem como antes uma *oscilação triangular*, segundo cada momento histórico, entre as alternativas: a) judicial; b) extrajudicial notaria;¹² ou c) extrajudicial administrativa. Essa instabilidade que já foi observada por Eduardo J. Couture,¹³ não atende a critérios estáveis ou coerentes, variando conforme o interesse político-legislativo predominante de cada época. Há também influência das concepções dominantes para fazer oscilar entre jurisdição contenciosa e voluntária, segundo a existência [ou inexistência] de direitos subjetivos.¹⁴

Estes são os perfis da jurisdição voluntária nas três codificações processuais civis gerais do Brasil, 1939, 1973 e 2015. No CPC/2015 preserva-se a dignidade da jurisdição voluntária, por duas

razões: na medida em que se mantêm os procedimentos anteriores (ou se incrementam alguns); e na medida em que se amplia seu escopo, incorporando matérias consensuais de Direito de Família, por exemplo, ou, especialmente, quando se atribui, como outrora já se reconheceu em escala menor, a conciliação,¹⁵ efetivada pelo pedido de “homologação de autocomposição extrajudicial, de qualquer natureza ou valor” (art. 725, inc. VIII) processar-se-á pela jurisdição voluntária por ser matéria a ela afeta. A consideração da conciliação como jurisdição voluntária já é fenômeno um pouco diverso do anterior, pois engloba a autocomposição judicial e fora proposta pela doutrina desde a década de 1960.¹⁶

Neste período a doutrina processual brasileira dedicou atenção a essa espécie jurisdicional, técnica processual e modalidade procedimental pelas *monografias* e *comentários*, a começar pelas obras dos pioneiros José Frederico Marques (1952)¹⁷ e de Alfredo de Araújo Lopes da Costa (1961); pela obra intermédia de Edson Prata (1979) e a dissertação de Jorge Araken Faria da Silva (1989) e; mais recentemente, as obras de José Maria Rosa Tesheiner (1992), João Paulo Lucena (1996), Leonardo Greco (2003) e Cristina Ferraz (2008). Dentre os *Comentários ao Código de Processo Civil* de 1973, destacaram-se José Olympio de Castro Filho (1976), Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (1977), Edson Prata (1978), Alcides de Mendonça Lima (1982) e João Paulo Lucena (1999).¹⁸

1.1 CPC/2015 e as premissas da Jurisdição Voluntária

O novo CPC conservou a mesma linha das demais codificações do século XX no Brasil, sejam os códigos estaduais e, depois, o CPC/1939, ainda que de modo assistemático, e o CPC/1973, de modo mais ordenado, mantiveram os procedimentos de jurisdição voluntária inseridos no Código de Processo Civil em certa e própria ordem. Sem poder tocar diretamente aos demais procedimentos de jurisdição voluntária dispersos pela legislação esparsa, a eles presta-se o CPC apenas como um guia geral, na medida em que vige a regra que toda a jurisdição cível, além da trabalhista, eleitoral e administrativa (art. 15) a ele se submete.

1.2 As reiteradas premissas do CPC/2015 para a Jurisdição Voluntária

Como será reiterado em várias passagens à frente, segundo a interpretação tradicional da doutrina identificam-se “três ordens distintas de normas procedimentais” regentes da Jurisdição Voluntária, todas presentes tanto no CPC/1973 como no CPC/2015.¹⁹ Tais ordens possuem uma relação de generalidade e especialidade, relacionadas a “três categorias de procedimentos especiais de jurisdição voluntária”, fazendo enfraquecerem-se ou ganharem força, gerando certo ônus interpretativo quanto à aplicação de uma ou mais ordens normativas; esse ônus interpretativo em parte já foi resolvido mas outros advirão do CPC/2015.

As “três ordens distintas de normas procedimentais” são: [X] Parte Geral (arts. 1.º-317), as normas do Livro I da Parte Especial do CPC/2015 (arts. 318-538), Livro II, *Execução* (arts. 771-928) e Livro III, *Recursos e ações* (arts. 929-993) da Parte Especial; [Y] as normas gerais contidas nas Disposições Gerais da Seção I da Jurisdição Voluntária (arts. 719-724), procedimento de jurisdição voluntária 'comum' ou geral²⁰ adotado pela doutrina;²¹ [Z] as normas próprias de cada procedimento especial de Jurisdição Voluntária que contenha disciplina individual.

Identificam-se também “três categorias de procedimentos especiais de jurisdição voluntária”: (a) procedimentos especiais de jurisdição voluntária típicos do CPC (arts. 726-770); (b) procedimentos do rol não taxativo do CPC (art. 725) e; (c) procedimentos especiais de jurisdição voluntária esparsos de leis especiais. Cada uma destas categorias, ao seu modo, submete-se a cada uma daquelas “ordens distintas de normas procedimentais”. Assim:

[X] Parte Geral do CPC (arts. 1.º-317), as normas do Livro I da Parte Especial (arts. 318-538), Livro II, *Execução* (arts. 771-928) e Livro III, *Recursos e ações* (arts. 929-993), aplicam-se às três categorias procedimentais especiais, em escala menor quando os procedimentos típicos do CPC (arts. 726-770) contiverem regras distintivas das gerais do CPC (a) (b) (c);²²

[Y] as normas gerais contidas nas Disposições Gerais da Seção I da Jurisdição Voluntária (arts.

719-724), aplicam-se aos procedimentos típicos do CPC (arts. 726-770), conforme o par. único do art. 725 [a]; aplicam-se integralmente também aos procedimentos do rol não taxativo do art. 725, por “não estabelecer procedimento especial”, conforme o art. 719 [b]; e, subsidiariamente, ou no que couber, aos procedimentos esparsos de leis especiais integrantes da jurisdição civil [c];²³

[Z] a norma própria de cada procedimento especial de Jurisdição Voluntária, presente no CPC/2015 ou em lei esparsa, que contenha disciplina individual aplica-se exclusivamente a tais procedimentos típicos [c].

Disso decorre a confirmação de premissas orientadoras anteriores e a definição de novas premissas, conforme serão a seguir expostas. Ver a respeito, Cândido Rangel Dinamarco.²⁴

1.2.1 Novas premissas decorrentes das esferas normativas

Essas ordens normativas distintas estão intrinsecamente interligadas e representam em seu conjunto o complexo de regras que se impõe sobre os procedimentos especiais de jurisdição voluntária, em maior ou menor intensidade, de forma direta ou indireta, de forma excludente ou ponderada, conforme ver-se-á a seguir.

1.2.1.1 Premissas decorrentes da parte geral do CPC/2015

O Processo civil num Estado Constitucional deve ser visto em toda a sua função e atividade como meio de proteção a direitos fundamentais, que adquirem a força normativa contida na Constituição, vinculando a todos os Poderes, pelas leis criadas pelo Legislativo, os atos do Executivo e decisões do Judiciário. Assim, “são indispensáveis normas de caráter processual para viabilizar a tutela específica da norma de proteção, ou melhor, normas processuais que outorguem à jurisdição o poder de prestar a tutela judicial capaz de fazer valer o desejo de tutela contido na norma de proteção.”²⁵

Com este sentido o CPC/2015 refaz a sua parte introdutória descrevendo princípios constitucionais processuais, como normas fundamentais, Livro I (arts. 1.º-12) e na Parte Geral traz inúmeras inovações, com ampliação dos poderes do juiz, rigor no dever de fundamentação das decisões judiciais, modelo de cooperação entre juiz e partes, nova configuração das intervenções de terceiros, ampliação da tutela específica, criação de técnicas adequadas à tutela de direitos, oferta e estímulo a técnicas consensuais em um sistema multiportas, adaptabilidade dos procedimentos, abertura a negócios processuais, técnicas probatórias preventivas, reconhecimento da disponibilidade regrada de interesses públicos, reorganização da fase de cumprimento e execução, redução de alguns recursos, ampliação da força das decisões e aceitação das técnicas de precedentes.

Todas essas características se impõem à jurisdição voluntária, em maior ou menor medida, conforme sejam coerentes com a finalidade desta espécie jurisdicional.

De igual modo, os Livros II a VI, que tratam sucessivamente de função jurisdicional, sujeitos do processo, atos processuais, tutela provisória, e formação, suspensão e extinção do processo igualmente se aplicam à jurisdição voluntária, embora possam ter certo temperamento e adequação terminológica, em vista da moderada contenciosidade destes procedimentos. Exemplo desse temperamento é o Livro II, *Dos Sujeitos do Processo*, quando descreve partes em sentido amplo, não se refere aos *interessados* da jurisdição voluntária, mas estende no art. 77 os deveres a “todos aqueles que de qualquer forma participem do processo”; por certo são deveres dos interessados da jurisdição voluntária a exposição de fatos conforme a verdade (art. 77, inc. I), I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento (art. 77, inc. II), não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito (art. 77, inc. III), cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, (art. 77, inc. IV), não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou *direito litigioso* (art. 77, inc. VI).

Dentre as partes que não se pode deixar de tratar está a *tutela provisória* (arts. 294 a 311),

aplicável na jurisdição voluntária, seja nas modalidades da *tutela da evidência* (art. 311), de menor utilização (art. 311, incs. I e III), como da *tutela de urgência* (arts. 300 a 310), nas duas modalidades de tutela cautelar (art. 300), ou de tutela antecipada (arts. 300, § 3.º a art. 302).

Assim, observadas as peculiaridades na natureza da jurisdição voluntária, aplicar-se-ão a ela em escala e grau próprios as disposições da Parte Geral do CPC/2015.

1.2.1.2 Premissas decorrentes da parte especial do CPC/2015

A Parte Especial do CPC/2015 contém as normas do Livro I (318-770), *Processo de Conhecimento e Execução de Sentença*, Livro II, *Execução* (arts. 771-928) e Livro III, *Processos nos Tribunais e Meios de impugnação (Recursos e ações)* (arts. 929-993). De modo próprio neste CPC/2015 os Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa e de Jurisdição Voluntária estão contidos dentro do Processo de Conhecimento (Livro I da Parte Especial) por serem propriamente parte deste *processo de declaração*, embora possa em muitos casos conter decisões com outras eficácias, constitutivas, condenatórias, mandamentais e mesmo executivas *lato sensu*.

De igual modo, as disposições de cada um desses três Livros, conforme a compatibilidade, aplicar-se-ão ou não à jurisdição voluntária. Exemplos de não aplicação estão nas regras de alguns procedimentos de jurisdição contenciosa, que muito próprios e voltados a direitos materiais específicos (posse, consignação, prestação de contas etc.) não terão curso e aproveitamento aos procedimentos de jurisdição voluntária. Exemplo inverso está no procedimento de inventário, que arrolado como procedimento de jurisdição contenciosa, muitas vezes se reveste exatamente das características da jurisdição voluntária, admitindo, inclusive, a partir da Lei 11.441/2007, a realização extrajudicial, simplificada de transmissão dos bens quando não exista testamento ou interesse de incapazes.

O que define a aplicabilidade é a compatibilidade da norma à índole da jurisdição voluntária, a adaptabilidade às características gerais, que exige em cada caso a apreciação específica.

1.2.1.3 Premissas decorrentes das disposições gerais dos arts 719 a 724 do CPC

As premissas contidas na *Parte Geral* regente do procedimento geral da jurisdição voluntária do CPC/2015 na estrutura do *Capítulo* ao dispor em uma *Seção I*, inicial, que trata das *Disposições Gerais*, mantém a mesma ordem do CPC/1973. Preserva-se a quantidade e o conteúdo próximo de dispositivos que tratam desta parte inicial do *Capítulo*, com dispositivos da seção inicial com conteúdo equivalente (art. 726 ao art. 770), senão idênticos, àqueles do CPC/1973. Essas regras, como dito acima, aplicam-se integralmente também aos procedimentos do rol não taxativo do art. 725, por “não estabelecer procedimento especial”, conforme o art. 719; e, subsidiariamente, ou no que couber, aos procedimentos esparsos de leis especiais integrantes da jurisdição civil.

1.2.1.4 Premissas decorrentes das disposições gerais dos arts. 726 a 770 do CPC/2015

Os procedimentos específicos dos arts. 726-770 se regem, em maior ou menor intensidade por suas próprias regras, sem descuidar das regras contidas nos dispositivos da premissa anterior (arts. 719-724). De modo próprio, também, podem interferir para além de suas especificidades, especialmente se contiverem 'técnicas processuais diferenciadas' (art. 327, § 2.º, parte final) e possam ser emprestadas, de modo flexível, a procedimentos que cumulem mais de um pedido compatível.²⁶

1.2.1.5 Premissas decorrentes do art. 725 do CPC/2015

O rol do art. 725 (art. 1112 do CPC/1973) considerado como exemplificativo por grande parte da doutrina, assim se confirma, com as inclusões agora feitas (incs. VII e VIII), que bem-vindas vêm carregadas de sentido, especialmente aquela do inc. VIII do art. 725. Amplia-se o rol de procedimentos não descritos como típicos e codificados (arts. 726-770) de jurisdição voluntária para incluir, por exemplo, a expedição de alvará judicial e a homologação de autocomposição, agora reconhecidos como procedimentos que devem também seguir a jurisdição voluntária. Houve assim uma ampliação material e nominal de procedimentos.

A premissa central que daqui se destaca é de que as características próprias dos procedimentos, previstos ou não no rol do art. 725, permitem a classificação como jurisdição voluntária daqueles procedimentos que em si contenham a natureza.

1.2.1.6 Premissa decorrentes do inc. VIII do art. 725 do CPC e a nova dignidade material de homologação da conciliação

Outro aspecto importante é aquele que pode ser destacado como um novo campo de atuação da jurisdição voluntária, que permite a “homologação de autocomposição extrajudicial, de qualquer natureza ou valor” (art. 725, inc. VIII), após a inclusão no rol das hipóteses do referido artigo. Como premissa, gera uma questão de difícil solução, a esta altura, correspondente, a saber-se se em todas as situações em que a ação chega ao fim pela conciliação das partes entender-se-á como jurisdição voluntária ou somente nas hipóteses em que iniciado o procedimento como um pedido de homologação, terá ele a classificação como jurisdição voluntária. Dentre os reflexos concretos ou práticos dessa divergência pode estar a recorribilidade ou não da decisão homologatória e a possibilidade de desconstituição por ação anulatória de ato das partes ou rescisória de decisão judicial.

1.2.1.7 Premissa decorrentes dos procedimentos de Jurisdição Voluntária contidos nas leis esparsas ou extravagantes

Uma evidente alteração está relacionada à redução dos dispositivos que tratam da jurisdição voluntária, antes em quantidade superior a uma centena; e agora reduzidos a meia centena. A técnica utilizada foi da aglutinação de disposições em um único artigo, mais que a supressão de disposições. Assim, pouco ou nada se altera em conteúdo.

Número indefinido de procedimentos da legislação extravagantes Jurisdição Voluntária, além daqueles contidos no CPC/2015 contém regramentos que se guiam pelas premissas próprias, sem influenciar os procedimentos contidos no CPC, mas deixando-se influenciar especialmente pelas *Disposições Gerais*, arts. 719-724 do CPC/2015, como forma de atuar função jurisdicional estatal e como técnica procedimental.

2. Contornos teóricos, natureza jurídica características e critérios distintivos da técnica de Jurisdição Voluntária

Três são as abordagens as serem feitas neste *item* e se referem ao conceito atual da Jurisdição Voluntária, em toda a complexidade trazida pelo CPC/2015; à natureza jurídica da Jurisdição Voluntária, ponto de sucessivas e históricas divergências; e às características e critérios distintivos da técnica da Jurisdição Voluntária.

Tais pontos terão apenas revisão, pois foram suficientes a entusiasmar a produção de obras monográficas inteiras no Brasil e em outros países.

2.1 Definições ou conceitos de Jurisdição Voluntária

Há atividade jurisdicional na jurisdição voluntária, segundo Pontes de Miranda,²⁷ opinião que contraria a maioria dos processualistas brasileiros e estrangeiros.

Há muito se define a jurisdição voluntária, em decorrência de larga tradição alemã e italiana antecedente, como *administração pública de interesses privados* ou *administração pública de direito privado*. Especialmente no Brasil, pela influência da obra pioneira de Alfredo de Araújo Lopes da Costa, *A Administração Pública e a ordem jurídica privada* (Jurisdição Voluntária), seguiu-se predominantemente esta concepção,²⁸ segundo a mesma posição, colhida de Guido Zanobini,²⁹ classificação que ainda se mantém forte e bem amparada.³⁰

Contudo, ela merece uma apreciação mais abrangente.

Cândido Rangel Dinamarco e Bruno Carrilho Lopes definem a jurisdição voluntária como: “(a) não consiste em dirimir diretamente conflitos entre as partes, (b) conseqüentemente, não são

julgadas pretensões antagônicas, (c) destina-se a dar tutela a uma das partes, ou ambas, sem se colocar para o juiz uma escolha entre tutelar uma delas ou a outra, (d) é invariavelmente exercida por juízes integrantes do Poder Judiciário e (e) deve sempre ser exercida pelo juiz com inteira imparcialidade.”³¹

De modo equivalente e mais amplo o processo civil, pelo CPC/2015, estabelece que “Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos” (art. 3.º, § 2.º) e “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.” (art. 3.º, § 3.º). O mesmo CPC/2015 ainda reitera outras trinta e cinco vezes a expressão *conciliação*, outras trinta e nove vezes a expressão *mediação*, oito vezes a expressão *solução* ou *composição consensual*, a *delimitação consensual* de questões de fato e direito, *perícia consensual*, além de hipóteses consensuais próprias da jurisdição voluntária.

Não se trata, evidentemente, de uma onda que amplia a jurisdição voluntária, mas de fadiga e incapacidade do processo e da jurisdição contenciosa em solucionar todas controvérsias que acorrem ao Judiciário e de busca ou estímulo aos meios consensuais, intraprocessuais ou extraprocessuais. Inova, parcialmente, o CPC/2015 ao trazer para a jurisdição voluntária a “homologação de autocomposição extrajudicial, de qualquer natureza ou valor” (art. 725, inc. VIII).

2.2 A Natureza jurídica da Jurisdição voluntária

Eduardo Couture, como dito acima, afirmava que: “a jurisdição voluntária pertenceu nos primeiros tempos aos *notários* e com o andar do tempo foi passando aos órgãos do Poder Judicial. Nada impede que passem amanhã para a administração e ainda que voltem a sua fonte de origem (...).”³² Essa oscilação pode estar relacionada à política legislativa de judicialização e desjudicialização ou de desformalização de controvérsias.

Embora Giuseppe Andriolli tenha dito, referindo-se ao CPC italiano de 1942, que a questão relativa à natureza jurídica da jurisdição voluntária já tivesse perdido grande parte de seu valor, constituindo-se em muitos casos como um “luxo teórico”, mantêm-se vivas as históricas e severas divergências que entre as correntes que se polarizam no debate sobre este ponto.³³ Também, e por consequência disso, discute-se sobre a existência de atividade jurisdicional, a existência de conflituosidade, a existência de partes.³⁴

2.2.1 A Natureza jurídica administrativa ou (não jurisdicional)³⁵

Atividade administrativa ou jurisdicional. Consideram-na atividade administrativa ou *amministrazione pubblica del diritto privato* na Itália,³⁶ no Brasil José Frederico Marques denomina de judiciário-administrativa.³⁷

Arruda Alvim afirma a jurisdição voluntária não é própria e verdadeiramente jurisdição.³⁸

José Ignácio Botelho de Mesquita acredita que a “distinção no fato de que a jurisdição contenciosa busca a realização da ordem jurídica, enquanto à jurisdição voluntária cumpre atuar ordens de diversa natureza, como a ordem política, a ordem econômica, e a ordem social, tomada está no seu sentido mais amplo, compreendendo os valores da educação, cultura, saúde, segurança, família, previdência e assistência social.”³⁹

2.2.2 A Natureza jurídica jurisdicional

Nesse ponto, sustenta Humberto Theodoro Júnior que a função qualificada como “jurisdição voluntária” é aquela (a cargo do Judiciário) “não necessária constitucionalmente”, distinta da que corresponde a resolução de situações conflituosas. Assim, jurisdição voluntária distingue-se da contenciosa por algumas características principais, quais sejam, “na voluntária não há ação, mas pedido; não há processo, mas apenas procedimento; não há partes, mas interessados, promovedor e promovido; não produz coisa julgada, nem há lide”. O juiz se apresenta na condição de

representante do Poder Judiciário como verdadeiro administrador, pelo que a função jurisdicional na espécie voluntária se aproxima de outra função estatal, “como tal da executiva ou administrativa”.⁴⁰ Marcos Afonso Borges discordava dessa corrente majoritária.⁴¹

Pontes de Miranda já se opunha a esta interpretação.⁴² Depois disso, entre outros, Ovídio Baptista da Silva e Fabio Gomes sintetizam a divergência a quatro pontos.⁴³

Afirma Fernando Henrique Mendes de Almeida que “daí resulta que a atividade administrativa atípica realizada no cenário judicial do amigável sofre a resistência de ser reconhecida como o que é. Tal resistência, sob os nomes de ‘graciosa’ ou ‘voluntária’ ou de ‘partes *in volentes*’, é clássica. Tal resistência, sob os nomes de ‘graciosa’ ou ‘voluntária’ ou de ‘partes *in volentes*’, é clássica. Por isto, a atipicidade, ora caracterizada e à qual damos o nome de objetiva, deflui de se pretender que as partes, na ‘jurisdição graciosa’, vão a juízo porque a lei lhes impõe, mas, dependem de jurisdição, ainda que não sejam respectivamente autor e réu. É de se esclarecer, no entanto, que este entendimento não pertence aos escritores processualistas (...)”.⁴⁴

Essa é também a posição de Flavio Luiz Yarshell que a atuação concreta da lei fica submetida a critérios de “conveniência” e “oportunidade”, ao ponto de se dizer majoritariamente que “não é autêntica jurisdição”, mas atividade de caráter (“meramente”) administrativo. Concluindo que há uma “atipicidade de função” na jurisdição voluntária.⁴⁵

2.2.3 A Natureza jurídica autônoma

Numa classificação diversa, Elio Fazzalari considera a jurisdição voluntária como categoria autônoma,⁴⁶ corrente que teve sempre menor prestígio, mas pode ser uma alternativa ao binômio que a poucos satisfaz (jurisdição contenciosa x jurisdição voluntária).

3. Características e critérios de distinção entre jurisdição voluntária e contenciosa

São correlatas todas as características que serão apontadas como marcantes na jurisdição voluntária,⁴⁷ embora se tenha sempre advertido na doutrina portuguesa e brasileira que não são seguras as linhas divisórias nas classificações que separam um e outro grupo de procedimentos. Ainda assim Edson Prata lista com base em Stein-Jonas e Shönke cerca de trinta e oito diferenças.⁴⁸ Aqui se tem espaço para mencionar somente algumas delas, sempre suscetíveis de relativização.

3.1 Inexistência de litígio, lide ou conflito e presença de controvérsia

Somente a difícil distinção entre *litígio*, *lide*, *conflituosidade* e *controvérsia* podem fazer-se admitir que em alguns procedimentos especiais de jurisdição voluntária ocorra certa fração ou tom de contraditório, de redução dos poderes do juiz e de ampliação da atividade dos interessados.

A doutrina, tradicionalmente, afirma inexistir lide ou conflito na jurisdição voluntária, sendo esta uma de suas mais marcantes características. Francesco Carnelutti dizia que o conflito pode não ser estranho à jurisdição voluntária.⁴⁹ Ramiro Podetti considera que o argumento da inexistência de conflito não é válido, uma vez que há outras situações em que o processo judicial atua, sem que exista propriamente conflito, ou nas quais há baixa conflituosidade, casos em que a função jurisdicional atua para a proteção contra o menoscabo e a lesão ao direito.⁵⁰

Fernando Luso Soares, crítico à unificação das categorias da ação penal e ação civil, distingue, como Francesco Carnelutti, litígio e controvérsia, de outro lado e com outro fim, José Carlos Teixeira Giorgis, expõe o panorama das correntes italianas e nacionais da *teoria do processo* propondo a lide como uma categoria comum a ambas as áreas.⁵¹

Para José Frederico Marques *lide* e *litígio* são conceitos sinônimos, usados indistintamente no CPC/1973,⁵² assim como no CPC/2015; não os identificando a jurisdição voluntária, ao que chame de “processo sem lide”.⁵³ Em trabalho mais extenso e detalhado, Uziel Santana dos Santos, é capaz de distinguir os conceitos; para este autor *litígio* é “pressuposto processual de natureza fáctico-causal-sociológica e, em assim sendo, um conceito de referibilidade extrínseca”, ao passo que *lide*

é “um suposto processual – conditio *sine qua non* do processo – de natureza jurídico-processual *stricto sensu* e, em assim sendo, um conceito de referibilidade intrínseca, portanto, endoprocessual”.⁵⁴

A noção de *lide*, para a maioria, está associada à litígio e a conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida; a noção de *conflituosidade*, decorre ou é representada pelo *conflito* ou *conflituosidade* que expressa no processo o *conflito* social antecedente.

A noção de *controvérsia* ou *controversão* está associada à divergências de menor intensidade, que não geram lide em sentido processual, mas podem se ver atraídos ao procedimento jurisdicional (voluntário) em busca de chancela estatal ou por decorrência de exigência legal.

A noção de *litígio* está associada à contraposição de interesses resistidos poderá implicar a lesão, a exclusão de outro interesse ou sua recíproca incompatibilidade.⁵⁵ A lide, o litígio ou o conflito franco justificam a conversão do procedimento de jurisdição voluntária em procedimento jurisdição contenciosa; a controvérsia ou controversão não justificam a conversão do procedimento de jurisdição voluntária em procedimento jurisdição contenciosa.

Niceto Alcalá-Zamora y Castillo distingue classes de procedimentos de jurisdição voluntária em que em uma das classes há predominância de efeitos constitutivos e em outros autênticos provimentos declaratórios e condenatórios, com eficácia de coisa julgada a atingir as pessoas que intervieram no procedimento.⁵⁶

Arruda Alvim, Humberto Theodoro Júnior e Antonio Carlos Marcato negam a presença de processo, de contenciosidade e de pretensão.⁵⁷ Edson Prata menciona dissensões na doutrina sobre esses pontos.⁵⁸

Especialmente no nosso direito processual civil atual em que há o dever do juiz “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais” (art. 139, inc. V), não se pode imaginar a jurisdição e o processo como atuação exclusiva para o julgamento do mérito, em caráter substitutivo, mas também nessas hipóteses há resolução de mérito, quando as partes transacionam, por exemplo (art. 487, inc. III, b).

3.2 Inexistência de processo e presença de procedimento

A simplificação da jurisdição voluntária é identificada desde o Direito Romano clássico, pois enquanto à jurisdição contenciosa era reservada inicialmente o *Comitium*, parte do *Forum* era destinada a atos e reuniões, e posteriormente às *auditorias*, com locais elevados onde sentava o juiz (*sella curulis*) para *iudicare pro tribunale*; já para os atos de jurisdição voluntária não adotavam a mesma pompa e podiam ser dados sem o assento elevado, *iudicare de plano*.⁵⁹

Essa postura simplicadora persiste, como se pode constar da baixa densidade normativa das regras da jurisdição voluntária, que possui, por exemplo, apenas seis dispositivos como disposições gerais (arts. 719 a 724), embora as demais *ordens normativas* do próprio CPC/2015 sirvam, evidentemente, como regras supletivas. Adroaldo Furtado Fabrício alerta que se evita a expressão processo na jurisdição voluntária de forma deliberada.⁶⁰

Muitos autores não identificam a presença de processo, mas apenas de procedimentos.⁶¹ Essa *aprocessualidade* observada em outros sistemas,⁶² é de difícil justificação pois embora possa se identificar procedimento sem processo, “não existe processo sem procedimento.”⁶³

3.3 Inexistência ou atenuação do contraditório e pleno contraditório

Muitas vezes se justificou a inexistência de contraditório na jurisdição voluntária, associada à inexistência de lide, de contestação, de revelia, dentre outros efeitos.⁶⁴ Nenhum destes característicos hoje é genericamente identificável na jurisdição voluntária, não se prestando mais às generalizações.

Essa justificativa não tem mais a extensão que se pretendia, seja pela genérica constitucionalização do Direito Processo Civil, seja pela especial atenção dada ao contraditório (e à ampla defesa) na CF/1988 e no CPC/2015.⁶⁵ Nelson Nery Junior destaca que “o princípio do contraditório atua sempre no processo civil, sendo indiferente tratar-se de processo desenvolvido por meio de procedimento de jurisdição contenciosa ou de jurisdição voluntária”.⁶⁶

J.J. Calmon de Passos com sua peculiar irreverência já observara, tratando dos procedimentos especiais que “chama-se de contraditório a essa exigência de bilateralidade”.⁶⁷

As novas disposições do CPC/2015, arts. 9.^o⁶⁸ e 10,⁶⁹ que generalizam o contraditório e afastam a possibilidade de decisão surpresa no processo civil brasileiro, trazem para um novo patamar essa garantia constitucional (CF/1988, art. 5.^o, inc. LV),⁷⁰ estendida em 1988 ao processo civil e processo administrativo, visto que a CF/1969 o impunha apenas ao processo penal. Assim como a nova lei processual federal, a lei federal do processo administrativo, Lei 9.784/1999,⁷¹ igualmente já o assegurava.

A inexistência de contraditório ou a existência de níveis diversificados de oferta da garantia nos diversos procedimentos cíveis de jurisdição voluntária é uma das formas de reconhecer e compreender a variedade de direitos e interesses materiais envolvidos, a função ou funções estatais predispostas nesta modalidade processual e a complexidade classificatória deste campo procedimental, que se identifica com os procedimentos especiais contenciosos e, em alguma medida, se contrapõem ao procedimento comum.

Antes disso, em uma vista geral, em atenção ao dever de igualmente a todos tratar no processo civil (art. 7.^o),⁷² na distribuição de oportunidades, riscos e expectativas,⁷³ corresponde ao juiz o dever de tratar igualmente às partes (igualdade intraprocessual).⁷⁴ Mas, do mesmo modo, existe a dever de que tenham quaisquer participantes, de quaisquer processos e procedimentos, em quaisquer fases, as mesmas oportunidades e tratamento, os mesmos riscos e expectativas, mesmo entre processos diversos, num tratamento ou igualdade na justiça processual (igualdade extraprocessual).

Edson Prata, inicialmente e com certa timidez, e Leonardo Greco, com mais clareza, dentre outros autores é um dos que destaca a importância do contraditório na jurisdição voluntária.⁷⁵ Se há um contraditório mínimo, agora garantido por regras constitucionais incorporadas ao CPC/2015, não mais se pode tratar como um simples procedimento. Elio Fazzalari distinguiu o procedimento como o processo em contraditório, em sua estrutura dialética, com a participação nos atos processuais preparatórios daqueles sujeitos que são destinatários do ato final do processo.⁷⁶

3.4 Inexistência de partes em sentido processual e existência de interessados, promovente e promovido

Embora boa parte da doutrina não reconheça na Jurisdição Voluntária e na maior parte de seus procedimentos especiais a presença ou a existência de verdadeiras partes, seja por não se tratar de um processo de “partes” em sentido próprio, que pedem uma contra a outra,⁷⁷ seja pela inexistência evidente de uma contradição, a terminologia é variável nas modalidades deste CPC/2015, embora nela se identifique a expressão *parte* e mesmo a expressão *autor*.⁷⁸

Há uma evidente preferência pela expressão *interessado* mais congruente com a maior parte dos procedimentos especiais mantidos no CPC/2015. Pode-se argumentar que não se deveria, por apreço à técnica e rigor linguístico, atribuir usualmente o nome de *partes*, mas de *interessados*, os quais podem ser chamados, apenas para fins de distinção quanto a quem se refere, de promovente (aquele que promove o pedido) e promovido (aquele em face do qual o pedido é formulado) ou, respectivamente, requerente e requerido ou ainda demandante e demandado. A praxe forense, seja pela atuação dos advogados e mesmo dos magistrados e seus auxiliares, não observa com rigor a terminologia considerada adequada.

Afirma-se, preponderantemente, até hoje que “não existem partes – há interessados,”⁷⁹ e a

atividade se dá *inter volentes*”⁸⁰. Essa é uma larga tradição chancelada por Edson Prata, Humberto Theodoro Júnior e Arruda Alvim que afirmam inexistir partes na jurisdição voluntária.⁸¹

Eduardo J. Couture argumentava que existem partes, mas não em sentido estrito;⁸² ao passo que Pontes de Miranda era categórico, ao dizer que *existem partes em sentido próprio* e enfrentava as correntes contrárias bradando tratar-se de “verdadeiro absurdo” dizer que não existem partes na jurisdição voluntária.⁸³ Sergio Gilberto Porto identifica também a presença de partes.⁸⁴

3.5 A inexistência de atividade substitutiva, finalidade ou utilidade

José Frederico Marques observa que “não se pode enxergar uma atividade substitutiva por parte do juiz, visto que este, no exercício de suas funções, integra o negócio jurídico privado (homologando-o, autorizando-o, aprovando-o etc.), mas não se coloca no lugar da pessoa interessada na realização do ato jurídico.”⁸⁵ Essa posição, segundo Araken de Assis destaca o absurdo considerar não tratar-se de jurisdição, apenas para evitar contrariedade à nota central do conceito de jurisdição dado por Giuseppe Chiovenda, que é a substitutividade.⁸⁶

Celso Neves pontua “que essa atividade implique tutela jurídica, é indubitoso. Entretanto, sua função é eminentemente constitutiva apresenta uma particularidade que a arreda do plano *jurissatisfativo*: o não ser nem secundária, sem substitutiva. (...) Constitui, portanto, a resultante de tutela *juristegrativa*, absolutamente diversa da atividade *jurisdicional* e *jurissatisfativa*. E porque obrigatória, não é voluntária”.⁸⁷

Pode ser identificada também a atividade estatal e sua finalidade, por avaliação inversa, pois se fosse atribuída aos funcionários estatais do Poder Executivo a apreciação ou validação dos atos hoje conferidos à jurisdição voluntária, ou mesmo que se atribuísse aos notários e seus cartórios privados, não se excluiria da apreciação judicial secundária, caso houvesse ameaça ou lesão a direito (CF, art. 5.º, inc. XXXV).⁸⁸ Neste sentido, ao atribuir-se diretamente ao Poder Judiciário tais atividades e funções, evita-se a revisibilidade encadeada por órgãos paraestatais e estatais.

Essa posição que nega o caráter jurisdicional e substitutivo à jurisdição voluntária é muito comum na doutrina brasileira.⁸⁹

3.6 Existência ou inexistência de imparcialidade do juiz

Ao contrário de alguns, Elio Fazzalari afirma que na jurisdição voluntária o juiz atuando de modo *parcialíssimo*.⁹⁰ Segundo Ali José Venturini Villaroel as razões parcialidade do autor italiano se devem ao fato de ter o juiz de zelar por interesses que lhes são diretamente confiados.⁹¹ Contrariando, aparecem posições de Cristina Ferraz ou de Cândido Rangel Dinamarco e Bruno Carrilho Lopes que caracterizam a jurisdição voluntária como aquela que é “sempre ser exercida pelo juiz com inteira imparcialidade.”⁹²

Não se pode generalizar a toda a jurisdição voluntária a posição do juiz que se distancia e se aproxima das partes. A multiplicidade de procedimentos e a ambígua reunião de interesses dos mais diversificados faz, cada vez mais, criar campos em que o juiz atua com imparcialidade (interdição) e outros com parcialidade (herança jacente, coisas vagas, bens de ausentes) e, ainda, outros em que atua com certa indiferença pendular (notificações, interpelações e protestos).

De modo geral, no processo civil, é possível associar a parcialidade e imparcialidade a uma moderada ou excessiva intervenção do juiz na produção da prova e na definição do objeto processual,⁹³ considerada em parte social e ideologicamente justificada⁹⁴ ou considerada como um teor injustificado pela necessidade de participação de todos os sujeitos no processo.⁹⁵

3.7 Inexistência de sentença de mérito e de coisa julgada

Tradicionalmente há muito se rejeita na jurisdição voluntária, quase majoritariamente, a inexistência de *sentença de mérito* e de *coisa julgada*: tudo, sempre, como consequência lógica da inexistência de partes, da inexistência de lide, inexistência de conflito franco, inexistência de

efetivo contraditório, inexistência de decisão adjudicatória (substitutiva), inexistência de sentença sobre o mérito e, por fim, inexistência de coisa julgada suscetível de rescisão. Assim, pode-se dividir a compreensão do mesmo fenômeno:

a) inexistência de *sentença de mérito*: embora exista um pedido;⁹⁶

b) inexistência de *coisa julgada*: embora se revista da eficácia natural dos atos estatais, coisa julgada formal, sem ter os efeitos imutáveis da coisa julgada.⁹⁷

Essa tendência dominante quanto à existência de sentença de mérito tem declinado, perdendo força desde alguns anos⁹⁸ e tantos outros posteriormente.

Essa tendência dominante quanto à existência de coisa julgada começa a se inclinar e há autores que já a reconhecem na jurisdição voluntária. Fredie Didier Jr. é um deles, argumentando que “a homologação judicial confere às partes algo além daquilo que se pode obter pelo procedimento cartorário: a indiscutibilidade da decisão, a coisa julgada. O negócio jurídico é processualizado (inserido no processo) e, após a homologação judicial, somente pode ser desconstituído por ação rescisória (...), como reflexo da rescisão da sentença homologatória”.⁹⁹ Mas há outros que levantam dúvidas.¹⁰⁰

4. Funções da Jurisdição Voluntária

Sob o aspecto funcional a Jurisdição Voluntária também tem multivariada funcionalidade, tão diversa como a variedade de procedimentos reunidos nesta categoria jurisdicional. Segundo Nicola Picardi, enquanto a jurisdição (contenciosa) é função constitucionalmente necessária, a jurisdição voluntária constitui-se como função constitucionalmente desnecessária, porquanto tal atividade possa, mas não deva, ser atribuída ao juiz.¹⁰¹ Essa concepção não pode mais ter curso equivalente no Brasil, considerado que o Preâmbulo da Constituição estabelece que *somos* “sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias.” O art. 5.º, inc. XXXV, estabelece que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, o que não impede também a competência para a pacificação dos litígios ou o reconhecimento (homologação) da paz obtida pela autocomposição. Ainda se estabelece a criação dos juizados especiais para matérias de direito público e direito privado, ancorados na conciliação.¹⁰²

4.1 Jurisdição sem função de solução de controvérsias

A doutrina tradicional como Celso Neves, não identifica atividade “jurisdicional e juris-satisfativa - é o dever de tutela jurídica que compete ao Estado, desde que monopolizou os instrumentos de realização da Justiça. Não só dessas duas espécies de atividade que se atribui aos órgãos do Poder Judiciário, mas abrangente, também, da atividade ‘juris-integrativa’, a eles igualmente entregue, para o aperfeiçoamento de atos e negócios jurídicos que versem sobre direitos indisponíveis, a que, impropriamente, se tem atribuído a denominação de jurisdição voluntária, não obstante se reconheça que, nela, nem há jurisdição, nem impera a vontade.”¹⁰³

Parte da doutrina hoje admite a existência de atividade jurisdicional na jurisdição voluntária.¹⁰⁴ “Os procedimentos especiais de jurisdição voluntária são procedimentos em que não há litígio entre os interessados na obtenção da tutela jurisdicional. Na jurisdição voluntária há jurisdição (...).”¹⁰⁵ embora não se possa dizer que a simples confiança ao juiz transforme todas essas atividades em jurisdicionais.¹⁰⁶

Essa postura positiva é minoritária, mas crescente. Grande parte da doutrina europeia, sul-americana¹⁰⁷ e brasileira¹⁰⁸ nega a existência de atividade jurisdicional na jurisdição voluntária. Galeno Lacerda manteve essa posição e argumentava que somente ocorria a atividade jurisdicional quando do julgamento de questão e, por conseguinte, na jurisdição voluntária, se o juiz não julga, e sim diz o direito, não se pode ver jurisdicionalidade nos atos aí emanados.¹⁰⁹

Cândido Rangel Dinamarco mantém posição peculiar, relativizando a diferença entre as

funções e atividades dos poderes, para reconhecer similaridade entre Jurisdição e Administração.¹¹⁰

Admitem a existência de atividade jurisdicional na jurisdição voluntária parte da doutrina europeia,¹¹¹ sul-americana¹¹² e brasileira.¹¹³ Araken de Assis chega a considerar antiga e desatualizada a posição que não reconhece o caráter jurisdicional na atividade,¹¹⁴ com amparo nas posições de Gian Antonio Micheli, Salvatore Satta e Piero Pajardi.

A atividade do juiz pode ter fins proveitosos diferentes da composição de lides;¹¹⁵ não há como aceitar que a jurisdição deva se preocupar somente com a solução de conflitos;¹¹⁶ sua função não é exclusiva de solução de controvérsias;¹¹⁷ na prevenção de lides.¹¹⁸ Se surge a controvérsia expressa e clara, deve ser enviado o processo à jurisdição contenciosa,¹¹⁹ conversão ou “remetido às vias ordinárias”, como nas hipóteses de inventário que se inicia consensual e no qual, depois, exsurge a divergência.¹²⁰

4.2 Função de proteção de interesses privados especiais ou restrição à autonomia privada

Um dos evidentes objetos da jurisdição voluntária é a proteção de interesses privados especiais;¹²¹ compostos por uma variedade de situações de relevância pública, que impõem à autoridade a assunção do encargo da gestão, valorização e cuidados de interesses qualificados;¹²² referindo-se ao resguardo de bens reputados de alta relevância social.¹²³ Elio Fazzalari diz que a denominação é indiferente, “mera questão de nome”, chamar a categoria como administração pública de direito privado ou como jurisdição voluntária, embora o peso da tradição tenha feito vencer a jurisdição voluntária.¹²⁴

Arruda Alvim chega a afirmar que, “no fundo, a jurisdição voluntária importa uma limitação à autonomia privada”,¹²⁵ o que é em grande medida verdadeiro, vez que, conforme a época e a ideologia legislativa, reduz-se ou se amplia essa incidência no campo do Direito Privado. As oscilações modernas e contemporâneas possuem razões diversas daquelas históricas e tradicionais; o Estado contemporâneo e o constitucionalismo moderno possuem razões muito mais complexas de intervenção no mundo econômico que aquelas razões originais de atração dos negócios privados para a jurisdição voluntária. Ana Prata identifica a autonomia privada não mais à propriedade, mas ao negócio jurídico e à transformação que este “ganha autonomia e relevo conceitual ligada à concepção jurídica do liberalismo econômico, (...) e vai sofrendo uma desvalorização que acompanha a transformação deste último conceito”.¹²⁶ A autora aponta critérios mais recentes e justificadores dessa intervenção.

Há casos de impossibilidade de obtenção do mesmo resultado senão pela jurisdição voluntária e seus procedimentos, que pode, em parte, coincidir com as ‘ações constitutivas necessárias’,¹²⁷ tais como a interdição, a tomada de decisão apoiada, a alteração do regime de bens do casamento, a autorização para cremação em casos de morte violenta etc. Essas exigências retiram ou tornam ambígua a expressão ‘voluntária’ dessa modalidade de procedimentos especiais.

Salvo as raras exceções agora possíveis de conciliação de interesses públicos pelo inc. VIII do art. 725 e outras que envolvam interesses patrimoniais da Administração Pública sobre bens remanescentes (Herança Jacente, Coisas Vagas e Bens de Ausentes), trata-se na jurisdição voluntária, quase sempre, de interesses puramente privados.

Disso se conclui pela presença de certas características aparentemente paradoxais, como: *presença predominante de interesses e direitos privados, presença rara de interesses e direitos públicos, normas de “ordem pública” visando certos interesses sociais e interesses coletivos.*

4.3 Função homologatória e solução consensual ou conciliação de controvérsias

Tradicionalmente se reconhece a jurisdição voluntária como atividade jurisdicional sem função de solução de controvérsias.

Na doutrina brasileira tradicional, Moacyr Amaral Santos definia o ato como: “tentar a

conciliação é tentar a consecução de um acordo entre as partes, compondo total ou parcialmente a lide. No sistema processual civil brasileiro, conciliação é uma atividade do juiz e das partes, disciplinada pela lei (...), na qual aquele funciona como mediador, e é, também, o resultado dessa atividade, consistente na composição da lide por acordo das partes. Difere da transação, da conciliação amigável ou da reconciliação, porque pressupõe a autoridade do juiz e um procedimento do qual resulta um ato (ato de conciliação) com valor de sentença (...).¹²⁸

Essa distinção não possui mais sentido, na medida em que se ampliam os deveres do juiz com relação à conciliação, que a ele se incorporam conciliadores e mediadores, que mais direitos ou interesses são incorporados ao rol dos que admitem composição e, por fim, na medida em que a conciliação se integra a atividade jurisdicional voluntária, sem que se considere tal sentença como puramente homologatória.

4.3.1 A conciliação como ato de jurisdição voluntária

O conceito de conciliação é entendido no âmbito processual como a forma consensual de pôr fim ao conflito (material ou processual), por meios diversos, tais como a desistência, a renúncia, o reconhecimento do direito ou a transação; pode se dar de forma *preventiva* (ou *pré-processual*) e *sucessiva* (ou *endoprocessual*), conforme o momento de sua realização; pode também se dar no ambiente jurisdicional ou administrativo.

J.J. Calmon de Passos, nos *Comentários ao Código de Processo Civil* de 1973, define a conciliação ato das partes como “uma das modalidades de se pôr fim ao processo mediante a solução que lhe dão as próprias partes, apenas cumprindo ao juiz acolhê-la. Caracteriza-se por implicar na participação do magistrado. Com ela pode-se tanto lograr uma transação, quanto o reconhecimento ou a renúncia.”¹²⁹ Essa proposição é mais consentânea com as atuais e especialmente com as trazidas há pouco pelo CPC/2015.

Para Eduardo Couture, conciliação é o gênero e a transação é espécie. Sempre que se transige se concilia; nem sempre que se concilia se transige.¹³⁰ Mais adiante define: “Cuando dentro de nuestro régimen se habla de la necesidad de la conciliación, como requisito previo al proceso, no solo se tiene en cuenta la posibilidad de la transacción: deben entrar, también, en la cuenta del legislador, el desistimiento y el allanamiento. Son numerosos los casos de la vida forense, en los cuales el demandado se allana y paga en el acto de la conciliación; y no son, tampoco, casos de laboratorio, aquellos en los cuales el actor, enterado en el acto de la conciliación de las defensas que le opondrá el demandado, prefiere ahorrarse el juicio a tener que seguirlo en condiciones desventajosas.”¹³¹ Alfredo de Araújo Lopes da Costa ia no mesmo sentido.¹³²

Questão central e de difícil solução é saber se todos os atos de conciliação, independentemente do momento de realização e da intensidade da participação do órgão jurisdicional, são atos de jurisdição voluntária.¹³³

4.3.2 Solução consensual ou conciliação de controvérsias envolvendo interesses privados

Mantém-se, prioritariamente, como meio de acerto de interesses privados, preponderantemente, mas não exclusivamente.

Já era discutível a exclusividade do envolvimento de interesses ou direitos privados na jurisdição voluntária; Elio Fazzalari refere a tendência italiana que acrescentou à terminologia tradicional de *jurisdição voluntária* a posterior, atraente, mas genérica de *administração pública de direito privado*, criticada pelos autores alemães, por tratar também de interesses públicos.¹³⁴

4.3.3 Solução consensual ou conciliação de controvérsias envolvendo interesses públicos especiais transigíveis e disponíveis

A questão que agora se apresenta é outra e está relacionada à *transigibilidade*¹³⁵ de interesses públicos, à *transigibilidade e disponibilidade de valor limitado* desses interesses e à *transigibilidade e disponibilidade de valor não limitado* na Administração Pública. Se, se pode tratar os interesses

públicos ou da Administração Pública com transigíveis ou disponíveis, não se pode excluir de plano, possam eles ser tratados na jurisdição voluntária, após a inclusão no rol dos procedimentos de jurisdição voluntária da “homologação de autocomposição extrajudicial, de qualquer natureza ou valor” (art. 725, inc. VIII).

Desde a década de 1990 vêm se ampliando as possibilidades de transação na Administração Pública com sucessivas normas especialmente federais, que autorizam de forma limitada a conciliação e transação¹³⁶ e depois, as que autorizam de forma ampla a conciliação e transação,¹³⁷ a admitem a arbitragem¹³⁸ e a mediação¹³⁹ para a solução de conflitos da Administração e outras técnicas antes admitidas apenas para resolução de disputas patrimoniais privados.

Todas as *portas* do *Sistema Multiportas* idealizado politicamente como alternativa legislativa à crise da multilitigação - chamados também de *meios alternativos de solução de conflitos*, ou *equivalentes jurisdicionais*, tais como a *mediação*, *arbitragem*, *transação* e *espécies negociais inovadoras*

José Ignácio Botelho de Mesquita, crítico contundente dos juizados especiais, já considerava que a figura do juiz desses órgãos é “criado e cevado nos moldes da jurisdição voluntária,” mais afeito “em decidir do modo que mais adequado lhes parecesse às suas tendências políticas e socioculturais”.¹⁴⁰

Por isso, os *Juizados Especiais Cíveis*, limitados à sua competência de 40 salários mínimos, os *Juizados Especiais Federais* limitados à competência de 60 salários mínimos, e os *Juizados Especiais da Fazenda Pública*, limitados à competência estabelecida pela lei local, passam a ser espaço de atuação da jurisdição como predisse o professor da USP, mas não mais sob um olhar de censura e de crítica.

Homologação de acordos extrajudiciais, fruto de transação prevista em lei, ganham a partir de agora um novo espaço de chancela e validade, ao passo que dão à jurisdição voluntária uma nova dignidade.

Tratando da transação penal como jurisdição voluntária, Rogério Pacheco Alves identifica a natureza conciliação cível na “própria Lei 9.099/1995, tratando dos Juizados Especiais Cíveis, serviu-se da jurisdição voluntária como forma de alcançar a conciliação entre os interessados, ao estabelecer no art. 57: “Art. 57. O acordo extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, poderá ser homologado, no juízo competente, independentemente de termo, valendo a sentença como título executivo judicial”.¹⁴¹

5. Jurisdição, ação, processo e procedimento na Jurisdição Voluntária

Jurisdição ação, defesa e processo são categorias que devem ser compreendidas no âmbito do Estado Democrático de Direito.¹⁴²

5.1 Jurisdição e Jurisdição Voluntária

A jurisdição possui concepções variadas,¹⁴³ conforme os autores e sua afiliação a correntes definidoras da função do processo. Athos Gusmão Carneiro a define como “o poder (e o dever) de declarar a lei que incidiu e aplicá-la, coativa e contenciosamente, aos casos concretos.”¹⁴⁴ Ainda, em conceitos aproximados, diz-se que é “[...] função do Estado, destinada à solução imperativa de conflitos e exercida mediante a atuação da vontade do direito em casos concretos [...] substitutiva das atividades dos sujeitos envolvidos no conflito, a quem a ordem jurídica proíbe atos generalizados de autodefesa”¹⁴⁵ ou, para outros autores, o ato jurisdicional deve [...] atender a dois pressupostos básicos: a) o ato jurisdicional é praticado pela autoridade estatal, no caso o Juiz, que o realiza por dever de função, ou seja, o Juiz, ao aplicar a lei ao caso concreto, pratica essa atividade como finalidade específica de seu agis [...]; b) o outro componente essencial do ato jurisdicional é a condição de terceiro imparcial em que se encontra o Juiz com relação ao interesse sobre o qual recai a sua atividade.¹⁴⁶

5.2 Ação e Jurisdição Voluntária

Pontes de Miranda criticava ostensivamente os processualistas que não identificavam a categoria processual da *ação* na jurisdição voluntária.¹⁴⁷ Na mesma linha é possível identificar-se segundo Uziel Santos a *jurisdicionalidade*, a *lide*, o *pedido*, o *mérito* e mesmo as '*partes interessadas*'; ainda que não se encontre *litígio*.¹⁴⁸

5.3 Processo e procedimento na Jurisdição Voluntária

Processo civil é definido por Giuseppe Chiovenda como “o conjunto de atos coordenados para a finalidade de atuação da vontade concreta da lei (em relação a um bem que se apresenta como garantido por ela) por parte dos órgãos da jurisdição ordinária”.¹⁴⁹ Eduardo Couture, ao tratar da ciência do processo enquanto técnica assevera que “as formas [processuais] surgem dessas regras técnicas. Seu conteúdo constitui-se numa ciência. As regras técnicas são somente meios para a realização de um fim.” O fim do processo, para este autor, é resolver o conflito de interesses.¹⁵⁰ Arruda Alvim mantém uma posição que se inclina ao objetivismo, ao convergir com o autor uruguaio, e destacar que o “processo é um instrumento de técnica jurídica, cujo escopo principal é a aplicação da lei a um caso controvertido, não solucionado extraprocessualmente, e cuja solução é pedida pelo autor.” É meio para conseguir um fim, segundo o reiterado axioma.¹⁵¹

Procedimento é o “meio pelo qual se exterioriza o processo, coordenação dos atos que se sucedem”, enquanto o *processo* “são os atos que lhe dão corpo (ao procedimento) e as relações entre eles (atos) e as relações entre seus sujeitos”.¹⁵² A noção de *processo* é teleológica (finalística), ao passo que a noção de *procedimento* é instrumental, intercalar e formal. Pode-se ainda entender o *processo* como o “complexo de atividades que se desenvolvem tendo por finalidade a provisão jurisdicional. É uma unidade, um todo, é uma direção no movimento”, representado pelo *procedimento*, que é o “modo de mover e forma em que é movido o ato”.¹⁵³ O *procedimento*, embora intrinsecamente coligado ao *processo*, é a revelação exterior deste último.

Procedimento é, por conseguinte, a exposição de feições, ordem e forma, velocidades e marchas, intensidade e profundidade na realização de atos. Mas há posições contemporâneas, como a de Elio Fazzalari, que define o *procedimento* como o *processo em contraditório*, em sua estrutura dialética, com a participação nos atos processuais preparatórios daqueles sujeitos que são destinatários do ato final do processo,¹⁵⁴ visão que não deve ser afastada na jurisdição voluntária, mas que possui versão mais plana ou de baixa contenciosidade.

Tais conceitos ganham nova concepção a partir da CF/1988¹⁵⁵ e organização a partir do CPC/2015.

5.4 As fases procedimentais no CPC/2015 e sua compatibilização com a jurisdição voluntária

A nova estrutura procedimental do CPC/2015 e a intersecção das “três ordens distintas de normas procedimentais” referentes à Parte Geral (art. 1.º-317), Livro I da Parte Especial (arts. 318-538), Livro II, *Execução* (arts. 771-928) e Livro III, *Recursos e ações* (arts. 929-993) da Parte Especial; e Disposições Gerais da Seção I da Jurisdição Voluntária (arts. 719-724), procedimento de jurisdição voluntária 'comum' ou geral, que exigem uma nova revisão da estrutura de fases procedimentais de modo convergente com as peculiaridades conceituais finalísticas da jurisdição voluntária.

Aqui cabe apenas uma vista breve, que deve ser repassada em revista quando do exame de cada procedimento, como forma de adaptar os procedimentos típicos à nova concepção estrutural hexapartida em fase postulatória, fase organizatória e de saneamento, fase instrutória, fase decisória, fase de cumprimento e fase recursal ou impugnativa.

5.4.1 Fase postulatória no procedimento de jurisdição voluntária

Postular é pedir em juízo por meio de petição inicial (arts. 319-320) dando início a esta fase processual de troca de escritos e que completa no procedimento comum com a resposta do réu,

assim compreendidas a contestação (arts. 335-336), exceções (arts. 337-342) e reconvenção (arts. 343-336). Nos procedimentos especiais de jurisdição voluntária o ato de postular se aproxima daquele ato dos procedimentos contenciosos, mas são mitigadas parte das atitudes do réu, por não existir propriamente tal sujeito processual, embora em algumas espécies possa surgir certo nível de contrariedade e mesmo a citação para impugnação, com procedimento de interdição. Contudo, podem os intervenientes, o Ministério Público ou a Fazenda Pública arguirem exceções processuais (arts. 337-342).

A petição inicial deve atender aos requisitos (art. 287), ou seja, “deve vir acompanhada de procuração, que conterà os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico”, considerando a necessidade de imediata comunicação para a possível emenda e complementação. Os requisitos gerais (art. 319) devem também ser atendidos, tais como: o juízo ao qual é dirigida (inc. I); os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor (inc. II); o fato e os fundamentos jurídicos do pedido (inc. III); o pedido com as suas especificações (inc. IV); o valor da causa (inc. V); as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados (inc. VI); a desnecessidade de realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação, neste caso (inc. VII). Também a petição inicial deve vir acompanhada ou “instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação” (art. 320).

Pela sistemática atual, se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos gerais e documentais (arts. 319-320) ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito (art. 321), pode determinar ao autor que a emende ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias. É dever do juiz, a partir do CPC/2015, indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado (art. 321, 2.^a parte). O indeferimento ocorre se o autor não cumprir a diligência, emendando, corrigindo ou complementando informações necessárias (art. 321, parágrafo único), decisão de extinção sem exame de mérito, recorrível por apelação.

A improcedência liminar (art. 332) pode ocorrer quando o pedido contrariar: enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça (inc. I); acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (inc. II); entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (inc. III) enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local (inc. IV); identificada a decadência ou a prescrição (§ 1.º). A decisão de extinção nestes casos examina o exame de mérito, sendo recorrível por apelação que pode ser reformada pelo juiz prolator em sua retratação a pedido do autor, caso em que prossegue o processo com citação do réu (§ 3.º); não havendo retratação, prossegue o contraditório recursal, com prazo de 15 dias para o réu apresentar contrarrazões de apelação (§ 4.º).

O deferimento permite o prosseguimento com a manifestação de interessados ou do Ministério Público e Fazenda Pública, nos casos em que tais instituições e seus representantes judiciais participam.

As *Disposições Gerais, Seção I do Capítulo XV*, dos Procedimentos de Jurisdição Voluntária estabelecem que “serão citados todos os interessados” para se manifestarem no prazo de 15 dias para (art. 721) fazendo crer-se que a regra é igual e gera o mesmo ônus à do procedimento comum. Mas não se pode imaginar propriamente de atitudes equivalentes às do réu dos procedimentos contenciosos nos procedimentos de jurisdição voluntária; o máximo que se cogita é a *impugnação do interditando* (art. 752), a *contestação de tutor ou curador* ao pedido de remoção (art. 761, parágrafo único) *impugnação* de interessado ou interessados noutros procedimentos sem previsão expressa ou a *manifestação* de contrariedades de terceiros intervenientes e de representantes do Ministério Público ou da Fazenda Pública arguirem exceções processuais (arts. 337-342). Não se poderá cogitar de reconvenção (art. 343), salvo remotamente, como na hipótese da remoção de tutor ou curador em que pode *contrapedir* o reconhecimento de direito correlato (art. 761, parágrafo único). O prazo de 15 dias para manifestação após a citação do interessado (art. 721) será contado, quase sempre, segundo as regras contidas nas inúmeras hipóteses do art. 231¹⁵⁶ e no caso das cartas pelo art. 232.

Revelia ou ausência de resposta e mesmo a ausência de impugnação e seus efeitos devem ser examinadas com outros critérios na jurisdição voluntária (art. 345 e incisos), em razão de nem sempre reproduzirem efeitos idênticos àqueles da jurisdição contenciosa (art. 344). Seja porque a falta de resposta, impugnação ou manifestação (art. 344) não permite que se presumam como verdadeiras as alegações do *autor* ou requerente que formula o pedido, seja porque os interesses são indisponíveis em razão da presença de incapazes (art. 344, inc. II), seja porque os interesses são da fazenda Pública (art. 722), seja porque o juiz não se submete à legalidade estrita, podendo adotar solução mais conveniente e oportuna (art. 723, par. único);¹⁵⁷ diz-se às vezes, "revelia atenuada".¹⁵⁸

A exigência de manifestação dos interessados, promovente e promovido, sobre a conciliação e a realização de audiência para este fim é relativamente improvável, necessitando apenas que se examinem possibilidades remotas em que se possa cogitar de contrariedades, tais como na *impugnação do interditando* (art. 752), na *contestação de tutor ou curador* ao pedido de remoção (art. 761, parágrafo único) ou em outras *impugnações* de interessados em outros procedimentos (art. 721, art. 734, § 1.º, art. 737, art. 741, art. 764, inc. I e art. 769). Nos casos dos procedimentos dissolutórios de casamento e união estável pela jurisdição voluntária é explícita a convergência de interesses (arts. 731-732), dispensando-se a audiência de conciliação ou de mediação.¹⁵⁹ Nos demais casos a mediação é absolutamente improvável, pois não se pode pensar em mediação nas situações em que a jurisdição surge como imposição à intervenção estatal.

5.4.2 Fase organizatória e de saneamento

Sanear e organizar é preparar o processo para o julgamento, desobstruindo e delimitando o objeto a ser provado e decidido. Para isso é necessário resolver as questões processuais pendentes, (art. 357, inc. D); delimitar as questões de fato para a prova e especificar os meios de prova admitidos (art. 357, inc. II); definir a *distribuição* do ônus da prova, observado o art. 373 (art. 357, inc. III);¹⁶⁰ delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito (art. 357, inc. IV); designar, se necessário, a audiência (art. 357, inc. V) nos casos em que não é expressa sua necessidade ou desnecessidade.

É possível à parte ou interessado, discordando do que foi definido, pedir ajustes no saneamento em 5 dias (art. 357, § 1.º); e delimitar questões consensuais de fato e direito para vincular a colheita da prova restrita a certo objeto (art. 357, § 2.º).

Admite-se o saneamento em audiência com a cooperação da *parte*, interessado ou interessados, do Ministério Público e da Fazenda Pública e mesmo de terceiros intervenientes para questões complexas, (art. 357, § 3.º) devendo, neste caso, levarem rol de testemunhas (art. 357, § 5.º); se há testemunhas para serem ouvidas, nos casos em que não é obrigatória a apresentação do rol de testemunhas com a inicial, abre-se prazo de 15 dias para indicar as testemunhas (art. 357, § 4.º); podendo-se o juiz limitar o número de testemunhas (art. 357, § 6.º), quando não há previsão expressa desse limite; prova pericial, se houver, deve observar o art. 465 (art. 357, § 7.º).

5.4.3 Fase instrutória no procedimento de jurisdição voluntária

Instruir é provar e a fase instrutória se destina a colher a prova ou provas que ainda não foram produzidas, que ainda não estão disponíveis ao juízo e aos demais interessados ou intervenientes.

O objeto da prova são os atos e fatos relacionados ao direito posto em debate. Os poderes instrutórios do juiz, tradicionais na história processual brasileiro,¹⁶¹ permitem-lhe "de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito" (art. 370), de forma mais acentuada na jurisdição voluntária, na qual se reconhece maior liberdade e menores limites, inclusive, probatórios.¹⁶² Em vista de não se estar propriamente diante de partes, mas de interessado ou interessados, mantêm-se em certa medida a distribuição do ônus (art. 373), mas sem incidência tão definida e equânime (art. 7.º), como de resto não mais possui no CPC/2015 (art. 373, § 1.º). Se há apenas um interessado, não se pode cogitar de distribuição de ônus, pois salvo exceções, a este incumbe o ônus da prova.

A prova documental deve acompanhar a inicial ou ser produzida quando se abrir novamente essa possibilidade.

A realização da audiência de instrução está relacionada à necessidade de colheita de prova oral, ou seja, oitiva de depoimento pessoal e de testemunhas (arts. 358-368) na qual se pode tentar a conciliação, havendo alguma espécie de controversão, embora rara neste procedimento (art. 359). É dever do juiz neste ato manter a ordem, tratar a todos com urbanidade, registrar eventuais requerimentos (art. 360), e sob sua presidência ouvir os depoimentos em ordem preferencial e não mais obrigatória de peritos, depoimento pessoal e depois testemunhas do autor e testemunhas do réu (art. 361); esta audiência pode ser adiada (art. 362) ou antecipada (art. 363); nela são eventualmente oferecidas alegações finais orais (art. 364) ou escritas se complexas (art. 365) e pode ser prolatada a sentença, caso contrário será dada em 30 dias (art. 366). O registro da audiência é feito em geral por meio escrito, mas pode também audiência pode ser gravada em áudio ou vídeo (art. 367 e parágrafos). Na concepção atual a sentença é o ditado das descrições feitas pelo depoente sobre os fatos, assinada se transcrita em papel e se feita em meio eletrônico, assinada eletronicamente, pelo juiz, pelos advogados, pelas partes, representantes do Ministério Público etc.

5.4.4 Fase decisória no procedimento de jurisdição voluntária

Decidir é examinar o pedido e sentenciar, *sem a resolução do mérito*, por sentença terminativa (art. 485) ou *com a resolução do mérito*, por sentença definitiva (art. 487); a fase decisória situa-se entre a fase instrutória ou probatória e a fase recursal, se houver. A sentença no procedimento de jurisdição voluntária é igualmente “o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento [...]” (art. 203, § 1.º). A oportunidade de prolação da sentença é ordinariamente após a audiência de instrução e julgamento, salvo se antes dela, seja por sua dispensabilidade, inutilidade ou impossibilidade, for possível o julgamento antecipado total do mérito (art. 355) ou o julgamento antecipado parcial do mérito (art. 356).

A sentença é ato final do processo, que põe fim ao procedimento (art. 490), composta pelos elementos essenciais: o relatório, a fundamentação e a decisão (art. 489); que a partir do CPC/2015 deverá atender a requisitos adicionais para ser considerada fundamentada, sob o risco de gerar invalidades ou nulidades se insuficientemente fundamentada (art. 489, § 1.º, incs. I a VI; § 2.º e § 3.º).¹⁶³

5.4.5 Fase de cumprimento e execução no procedimento de jurisdição voluntária

Cumprir é dar efetividade ao provimento contido na decisão ou especialmente na sentença parcial ou final que terão na jurisdição voluntária, segundo as classificações adotada¹⁶⁴ consequências de *cumprimento* e de *execução* diversas da jurisdição contenciosa, embora se possa cogitar de provimentos mandamentais e executivos *lato sensu* assemelhados. As categorias relacionadas ao cumprimento do *dever de pagar* (art. 513, § 1.º) não ocorrem na jurisdição voluntária, a ponto de se necessitar o cumprimento pelo devedor. Embora não ocorra litígio pode haver na sentença eficácias que demandem providências posteriores, pois o ato jurisdicional não é suficiente, dependendo de “atos materiais que podem ser praticados por auxiliares do juízo ou por terceiros”¹⁶⁵ ou pelo interessado ou interessados, promovente e promovido. As técnicas ou eficácias *declaratória* e *constitutiva* são autossuficientes, ao contrário da *condenatória* e de outras que demandem um fazer ou não fazer dos ‘interessados’.

Observando especialmente a classificação de Leonardo Greco e a confrontando com os dispositivos da fase de cumprimento e execução pode-se dizer que quaisquer dos procedimentos: a) receptícios, como notificações, interpelações e protestos; b) probatórios; c) declaratórios; d) constitutivos; e) executórios; e f) exclusivamente tutelares poderão, observadas as suas peculiaridades, comportarem fases posteriores com fins mandamentais e executivos, especialmente.

5.4.6 Fase recursal ou impugnativa no procedimento de jurisdição voluntária

Recorrer é insurgir-se contra decisões judiciais, sejam decisões interlocutórias, sentença ou decisões dadas em tribunais. Na jurisdição voluntária não há restrição à interposição de recursos, sejam aqueles interpostos no 1.º Grau de Jurisdição, no 2.º Grau de Jurisdição ou mesmo os recursos excepcionais nos Tribunais Superiores (STF e STJ). Todo o rol de recursos (art. 994) tem curso nos procedimentos de jurisdição voluntária, desde que preenchidos os requisitos recursais extrínsecos e intrínsecos.

É a apelação (art. 1.009) o recurso da sentença e que caracteriza o duplo grau de jurisdição, definido como “princípio segundo o qual o processo se submete a uma dupla fase do juízo de mérito.”¹⁶⁶ Ato decisório final do procedimento, qualquer que seja, a sentença se sujeita aos mesmos riscos e meios de ser atacada por recurso só transitando em julgado após o exame desses recursos. E como sentença dos procedimentos de jurisdição voluntária, também está sujeita a recurso de apelação (art. 724), obedecendo aos requisitos *intrínsecos*: cabimento, legitimidade e interesse recursal e *extrínsecos*: tempestividade, regularidade formal e preparo.¹⁶⁷ Não há restrições a impugnação por recursos na Jurisdição Voluntária, em que pese referir-se a lei que da sentença caberá apelação (art. 724), sendo impugnáveis por recursos ordinários e excepcionais como o recurso especial.¹⁶⁸

5.5 Sentença, “trânsito em julgado” e desconstituição

5.5.1 Sentença e seu conteúdo, fundamentação e recorribilidade

As sentenças produzem vários efeitos gerais, tais como vinculativo, imperativo, probatório extintivo e consumativo,¹⁶⁹ sendo definida a partir dos arts. 485 e 487 como ato que põe fim ao processo resolvendo ou não o mérito.

Imaginava Eduardo J. Couture que seriam sempre declaratórias, nunca condenatórias ou constitutivas as eficácias das sentenças da jurisdição voluntária.¹⁷⁰ Sabe-se, por outros autores, que o conteúdo, forma, eficácias e efeitos deveriam ser considerados idênticos na jurisdição voluntária e na jurisdição contenciosa.¹⁷¹ As sentenças da jurisdição voluntária deverão ser igualmente fundamentadas de modo a permitir seu controle e impugnação por recursos ou outros meios impugnativos (art. 489, inc. II),¹⁷² não se considerando fundamentadas as sentenças ou outras decisões que deixarem de atender todos os incisos do § 1º desse mesmo dispositivo.

Como dito anteriormente, não há restrições impugnativas por meio de recursos na Jurisdição Voluntária, podendo suas decisões serem atacadas por todos os recursos cíveis ordinários, ainda que a Constituição se refira a causas decididas. Caberá apelação (art. 724) nos demais recursos ordinários e também no recurso especial. Não há também a restrição ao uso de sucedâneos recursais, como o mandado de segurança, nas estreitas vias em que essa ação sumária é admitida contra atos da Administração e, excepcionalmente, contra atos judiciais.

O recurso extraordinário não está aberto à jurisdição voluntária, por entender-se que faltam a esses procedimentos as decisões sobre causas, de acordo com decisões anteriores e posteriores a Constituição de 1988.¹⁷³ Ainda que soe estranho em tempos de restrições de acesso aos recursos excepcionais, repercussão geral e outros filtros é de examinar-se se todos os procedimentos de jurisdição voluntária devem ser excluídos, considerando que se trata de exercício de jurisdição e que alguns procedimentos possuem nítido caráter contraditório, como a interdição, situada em outras legislações como procedimento contencioso.

5.5.2 “Coisa julgada” e seus limites e consequências

Define-se coisa julgada material como “a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”, segundo o art. 502 do CPC/2015, que substitui a expressão *eficácia* pela expressão *autoridade*. Na definição sintética já se encontra objeção, porquanto parte da doutrina não identifique *mérito* nas decisões da jurisdição voluntária, o que os leva a concluir que não há a ocorrência da coisa julgada na jurisdição voluntária.

Sendo por isso o tema da coisa julgada na jurisdição voluntária aquele dos mais debatidos. Há

autores como Eduardo J. Couture que são categóricos em afirmar que a decisão final na jurisdição voluntária não faz coisa julgada.¹⁷⁴ Essa consequência gera outras, com aquela relacionada à “rescindibilidade” dos atos que não produzem coisa julgada. Segundo Alfredo de Araújo Lopes da Costa: “Não há ação rescisória. A ação rescisória é ação contra a coisa julgada. E aqui não há coisa julgada”.¹⁷⁵ A rescindibilidade ou não (art. 966, incs. I a VIII) esteve, está associada à identificação nesses modelos procedimentais não contenciosos de jurisdição, processo, lide, sentença de mérito e coisa julgada material.

Arruda Alvim é também peremptório dizendo não haver coisa julgada na jurisdição voluntária,¹⁷⁶ assim como outros tantos autores que não identificam este instituto processual na jurisdição voluntária. Longe de ser definitiva a consequência, pode depender, como notou Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, da espécie de direito material envolvido,¹⁷⁷ da espécie de provimento requerido e de outros fatores.¹⁷⁸

5.5.3 Ações desconstitutivas de sentença: rescisória ou anulatória

O debate sobre o meio de desconstituir as sentenças da jurisdição voluntária é objeto de histórico confronto na doutrina, tendo se mantido vivo na vigência do CPC/1973 e, certamente, manter-se-á nos próximos tempos.

A bifurcação entre uma e outra hipótese, entre anulabilidade por ação anulatória (art. 966, § 4.º) e rescindibilidade por ação rescisória (art. 966, incs. I a VIII) está e estará associada à identificação ou não, nesses modelos procedimentais *não contenciosos*, de jurisdição, processo, lide, sentença de mérito e coisa julgada material.

Sérgio Rizzi é categórico ao assegurar que “todas as sentenças proferidas em procedimentos de jurisdição voluntária são irrevogáveis. Na jurisdição voluntária não há processo, não há lide, não há sentença de mérito, não há coisa julgada material”.¹⁷⁹ Antes disso, vários doutrinadores cancelavam essa posição negativa à ação rescisória na jurisdição voluntária, tais como José Frederico Marques¹⁸⁰ e outros mais recentes ou, ainda, a inviabilidade das duas ações anulatória e rescisória.¹⁸¹

Este é um peculiar raciocínio totalizante, que parte de uma classificação binária da jurisdição (+/-), dividida em categorias (contenciosa/voluntária), as quais, individualmente, teriam características mais ou menos unitárias, capazes de permitir respostas diretas (sim/não). Desse modo, sendo jurisdição contenciosa, teria suas decisões atacáveis por ação rescisória e, sendo jurisdição voluntária o procedimento, não teria suas decisões atacáveis por ação rescisória.

Alcides de Mendonça Lima, que dedicou os *Comentários* mais minudentes da jurisdição voluntária no CPC/1973, tem posicionamento bifronte, admitindo a rescisória para os casos em que o juiz violar a lei e inadmitindo para os demais casos. Esse posicionamento se consagrou entre uns¹⁸² e outros.

Pontes de Miranda¹⁸³ e José Carlos Barbosa Moreira,¹⁸⁴ dentre outros já consideravam possível a ação rescisória em procedimentos de jurisdição voluntária na vigência do CPC/1973. Admitem abertamente a possibilidade da ação rescisória, a partir do CPC/2015, Fredie Didier Jr. Leonardo Carneiro da Cunha, sob o fundamento que “no procedimento de jurisdição voluntária, há pedido, portanto, mérito. A sentença que o acolhe está a resolver o mérito, encaixando-se na hipótese do art. 487, I, CPC. A sentença de mérito, proferida em procedimento de jurisdição voluntária, torna-se imutável e indiscutível, produzindo coisa julgada. Desse modo, transitada em julgado uma sentença num procedimento de jurisdição voluntária, cabe ação rescisória, com a finalidade de desconstituir a coisa julgada que se produzir, em razão de alguma das hipóteses previstas no art. 966 o CPC.”¹⁸⁵ Neste caso, a interpretação deve ser restrita aos incs. I a VIII, e excluídos o art. 966, § 4.º, que trata da ação anulatória.

Fungibilidade entre ação rescisória (art. 966) e ação anulatória (art. 966, § 4.º) pode tornar menores as consequências práticas do debate teórico que foi acima exposto. Se há fungibilidade entre os dois meios impugnativos – ação anulatória e ação rescisória – pode ser indiferente (ou

quase) uma ou outra consequência. Teresa Arruda Alvim Wambier, José Miguel Garcia Medina e Berenice S. Nogueira Magri admitem a fungibilidade desses meios impugnativos autônomos.¹⁸⁶

Outra coisa é o novo pedido e modificação da sentença, perfeitamente possível diante das alterações fáticas ou jurídicas, como no exemplo da interdição, que pode ser alterada, ampliada ou afastada; da declaração de ausência, que pode ser revogada com o retorno do ausente; com a extinção da união estável, que pode ter seu conteúdo pela reunião dos companheiros. Contudo, foi suprimida a regra do art. 1.111 do CPC/1973 que previa a modificação da sentença após a primeira decisão, por simples pedido da parte, demonstrando a inexistência de coisa julgada em seu sentido material.¹⁸⁷ Ver nesse sentido extensa bibliografia brasileira.¹⁸⁸

5.6 Outros reflexos procedimentais

5.6.1 Dualidade entre “opção” procedimental jurisdicional e extrajudicial notarial

A dualidade ou oferta de opções procedimentais múltiplas era mais rara no direito processual civil brasileiro, mas cada vez mais se amplia com a maturidade cultural ou motivada por interesses econômicos ou mesmo político-legislativos. Vê-se também como decorrente da maior ou menor transcendência e de projeções sociais do ato judicial.¹⁸⁹

A política de dualidade procedimental judicial e extrajudicial contempla a tentativa de deformalização de controvérsias, diante da incapacidade de atendimento pleno das demandas postas ao judiciário e da crise da justiça civil, como apontado há muito por Ada Pellegrini Grinover,¹⁹⁰ agora mais fortemente reconhecida.¹⁹¹

Exemplo de dualidade são os três procedimentos especiais relacionados a *separação, divórcio e dissolução de união estável* (art. 733, § 1.º e § 2.º), que incorporam parcialmente a previsão legal antecedente quanto à possibilidade de procedimento extrajudicial em cartório notarial, desde que “não [exista] nascituro ou filhos incapazes”. Exemplo também se encontra nos procedimentos de comunicações, *interpelações, notificações e protestos* (arts. 726-729), modalidades já contempladas como alternativa extrajudicial.

A simultânea tramitação judicial e extrajudicial não gera “litispendência”, embora a tramitação de procedimentos paralelos indique a falta de interesse processual (judicial).

5.6.2 Adaptabilidade e flexibilização procedimental

Acolhendo a proposição histórica da doutrina italiana, Fernando da Fonseca Gajardoni aprofundou estudo sobre a flexibilização do procedimento, em parte acolhida pelo CPC/2015. Essa técnica permite maior liberdade de formas e o aproveitamento, finalidade, contraditório útil, motivação dentre outros,¹⁹² com sensíveis vantagens que podem ser aproveitadas pelos procedimentos de jurisdição voluntária.

Especialmente o art. 139 permite ao juiz: “promover, a qualquer tempo, a autocomposição (...)” (inc. V), “dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito” (inc. VI) e, “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (...)” (inc. IV) expondo um acervo de meios antes inexistente no processo civil brasileiro,¹⁹³ que conjugado à finalidade da jurisdição voluntária, pode produzir resultados promissores.

5.6.3 Valor da causa

Vem regulado nos arts. 291 a 293 o valor da causa, exigindo-se que seja atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico, imediatamente aferível e correspondente ao proveito, não a coisa ou direito, necessariamente. Deve-se em cada procedimento observar o que será dito.

Do mesmo modo, por tratar-se também de matéria de ordem pública, pode ser corrigido de ofício (art. 292, § 3.º) e se sujeita à impugnação do valor, do modo agora previsto, em preliminar de

contestação (art. 293).

5.6.4 Despesas processuais, honorários advocatícios decorrentes da litigiosidade excepcional e gratuidade da Justiça

Parte da doutrina ainda reluta em admitir a possibilidade de incidência de todas as despesas processuais;¹⁹⁴ embora se reconheça a incidência de custas periciais, segundo o princípio da causalidade.¹⁹⁵ O STJ tem admitido em processos considerados de jurisdição voluntária, em que desponta certa 'litigiosidade', a condenação em custas e honorários: "Nos procedimentos de jurisdição voluntária, em que há litigiosidade, não meros interessados, é cabível a condenação da parte vencida em honorários advocatícios".¹⁹⁶ Incidem, nesses casos, custas e honorários, embora se trate de jurisdição voluntária, igualmente aos demais processos e procedimentos.¹⁹⁷

Nos demais casos, quando há apenas um interessado, as outras despesas processuais (excluídos os honorários) incidem igualmente, em vista da movimentação dos serviços judiciais. Mas, havendo incapacidade de pagamento dessas despesas processuais, é possível a concessão da gratuidade de justiça, tanto a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas processuais (art. 98).¹⁹⁸

6. Sujeitos processuais imparciais, sujeitos parciais ou interessados e terceiros

Sujeitos processuais parciais e sujeitos processuais imparciais são os protagonistas das atividades judiciais, processuais, procedimentais ou puramente administrativas que se desenvolvem no ambiente forense.

6.1 Juiz e a Jurisdição Voluntária

Enrico Tulio Liebman conceituava de modo inverso ao dizer que "ai giudice ordinari sono devolute certe materie che si distinguono per non dar luogo a controversie fra più parti, bensì ad un'attività di assitenza e di controllo ad atti posti in essere dai privati, compiuta a richiesta della parte interessata (...)".¹⁹⁹ Dá-se-lhe certa matéria diversa da matéria típica de sua atividade de decidir conflitos e a sua atuação difere em certo sentido da jurisdição contenciosa.²⁰⁰

O CPC/2015 redimensiona as funções do juiz e seu papel no processo, atribuindo-lhe novos poderes e deveres no processo e procedimentos contenciosos, com reflexos nos procedimentos voluntários. Os exemplos são muitos, tais como: *quanto aos poderes*, os de "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial" (art. 139, inc. IV), "dilatatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova adequando-os às necessidades do conflito" (art. 139, inc. VI), "determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais" (art. 139, inc. IX), quando se deparar com excesso de demandas individuais oficiar aos legitimados para avaliarem a possibilidade de propositura de ação coletiva (art. 139, inc. X); *quanto aos deveres*: fundamentar as decisões judiciais, atendendo a exigências argumentativas antes inexistentes (art. 489, § 1.º, incs. I a VI). Especialmente na jurisdição voluntária o juiz: *quanto aos poderes de controle* em casos como a interpelação e notificação edital (art. 726), nomear curador provisório na interdição (art. 749, parágrafo único), atribuir poderes de curador de bens e da pessoa de forma mais conveniente ao incapaz (art. 757); *quanto deveres*, ouvir o interditando no local em que estiver, quando limitada a locomoção (art. 751, § 1.º), dentre outros.

O ativismo e a autocontenção. Ativismo é expressão polissêmica associada a inúmeras discussões mais afetas ao Direito Constitucional que ao Direito Processual Civil. O sentido aqui utilizado é mais estreito e tem relação com comportamentos processuais do juiz que, no processo civil, viola o conhecido axioma latino *iudex debet judicare secundum allegata et probata a partibus*, identificado com a proibição de o juiz de ir além das alegações das partes e a proibição de o juiz de determinar a realização de provas de ofício, ou, sem requerimento dos interessados.²⁰¹ Neste sentido ativista é juiz que se opõe, comportamentalmente, ao juiz garantista, segundo Juan Montero Aroca.²⁰² Em sentido constitucional é visto "como a uma disfunção no exercício de função jurisdicional, em detrimento, notadamente, da função legislativa", tendo sofrido severo desgaste e

crítica.²⁰³ Se a contrapartida ao ativismo processual civil é o garantismo processual civil, a contrapartida ao ativismo constitucional é a autocontenção constitucional. Assim conceituado, o fenômeno do ativismo constitucional pode ser identificado em qualquer grau de jurisdição, mas tem maior afinidade com a atividade judicante do Supremo Tribunal Federal, sem necessariamente se confundir com a simples ampliação dos poderes do juiz. De outro lado, José Carlos Barbosa Moreira já observou que “a ampliação dos poderes do órgão judicial não tem como contrapartida necessária o amesquinhaamento do papel das partes, nem a eliminação, ou sequer a redução, das garantias a que fazem jus, e tampouco da responsabilidade que sobre elas pesa”.²⁰⁴

A atuação de ofício²⁰⁵ ou a iniciativa do juiz pode ser identificada também como uma “mitigação do princípio da demanda”, às vezes associada a certa expansão dos poderes do juiz. Araken de Assis, em afirmar que o juiz na jurisdição voluntária está adstrito ao pedido da parte ou ao princípio da demanda.²⁰⁶

Os poderes instrutórios e o princípio dispositivo para busca da prova necessária à decisão do mérito têm na jurisdição voluntária uma notória ampliação. Essa ampliação possui tradicionais justificativas lógicas, que se coadunam com o interesse estatal em manter sob o seu exame (Estado) certas *questões da vida privada* abarcadas pela jurisdição voluntária. O juiz da jurisdição voluntária não conhece outra *verdade* que não a *verdade* do interessado²⁰⁷ e, por isso, ganha mais amplos poderes instrutórios; em contrapartida aos estímulos que o processo em contraditório (contencioso) possui e lhe proporciona.

Os poderes instrutórios do juiz são também tradicionais na história processual brasileiro,²⁰⁸ permitem-lhe “de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito” (art. 370), antes vistos com o fim de “instrução do processo” (CPC/1973, art. 130). No tocante aos poderes instrutórios na jurisdição voluntária, em que pese a supressão no CPC/2015,²⁰⁹ nesta também o juiz possui liberdade de instruir, com o fim de poder atender aos fins do processo, ou seja, decidir o “mérito”, sem desatender o “princípio dispositivo” e o “princípio de igualdade de tratamento às partes”,²¹⁰ que devem ser vistos com certa atenuação, porquanto não existam propriamente partes em contradição.

6.2 Interessados ou ‘partes’, litisconsortes e terceiros

Pode-se identificar uma pluralidade de sujeitos, sejam interessados, interessados litisconsortes multitudinários e a presença de terceiros que atuam nestes procedimentos de jurisdição voluntária como cointeressados.

6.2.1 Interessados ou partes

Para a maioria dos processualistas não se pode tratar da existência de partes na jurisdição voluntária, mas há posicionamentos intercalares, no sentido que o conceito de partes é diverso na jurisdição voluntária e um último, minoritário, que insiste na existência de partes em sentido próprio.

O conceito clássico de parte, enquanto sujeitos parciais do processo, está associado ao autor e réu do processo contencioso, sendo o primeiro aquele que, em nome próprio formula o pedido da tutela jurisdicional, com base em sua pretensão, e o segundo aquele contra quem se pede a tutela jurisdicional; em síntese, é aquele que pede e contra quem se pede. A parte pressupõe a contraparte.

A atividade se dá *inter volente*, afirma Enrico Tullio Liebman,²¹¹ seguido por Luiz Guilherme Marinoni Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero que reiteram “não existem partes – há interessados”,²¹² ou, em tom mais moderado Eduardo J. Couture de que “existem partes, mas não em sentido estrito”.²¹³ Opinião comum entre tantos processualistas.²¹⁴

Noutra linha, retorquia Pontes de Miranda ao insistir que “*existem partes em sentido próprio*” e enfrentava essas correntes dizendo tratar-se de “verdadeiro absurdo” dizer que não existem partes na jurisdição voluntária.²¹⁵

6.2.2 “Litisconsórcio” ativo e passivo

Desde muito Luiz Machado Guimarães advertia que “o interesse (em comunhão), se entendido como interesse processual (interesse de agir e de contestar a ação) é elemento genérico e constante no litisconsórcio, insuscetível de caracterizar uma de suas espécies. Incaracterístico, também, por sua amplitude, é o conceito de *conexão* de causas, quando se não determina o elemento conectivo. Por último, a mera afinidade de questões de fato e de direito, só por si e sem o concurso de outros requisitos complementares, não autoriza a formação do litisconsórcio”.²¹⁶

O CPC/2015 tenta agora reorganizar as espécies de litisconsórcio, após sucessivas críticas da doutrina à redação anterior, pondo em melhor plano e organização um instituto de extrema importância para a organização e economia processual, coerência de decisões, nas situações em que: “entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide” (art. 113, inc. I); “entre as causas houver conexão pelo objeto ou pela causa de pedir” (art. 113, inc. II); “ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito” (art. 113, inc. III); permitindo-se que duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente.

É possível o agrupamento de interessados, promovente e promovido, sem que isso caracterize o litisconsórcio, como na jurisdição contenciosa. Observa Augusto Tanger Jardim, em breve ensaio que “havendo mais de um interessado, cogitar-se-ia da formação de litisconsórcio necessário. Contudo, a relação litisconsorcial não se mostra adequada à modalidade de procedimento inerente à jurisdição voluntária. Isso porque, como o próprio nome sugere, o litisconsórcio pressupõe a existência de lide, circunstância que não se faz presente na jurisdição voluntária. Ademais, a formação litisconsorcial sempre se concretiza em um dos polos da demanda, podendo ser tanto ativa, quanto passiva. Na jurisdição voluntária, entretanto, os interessados não ocupam posições antagônicas atuando no feito em nome de interesses não contrapostos”.²¹⁷

Assim, por todas as razões associadas à instrumentalidade, à economia, à coerências decisórias, deve-se permitir o agrupamento dos interesses e dos interessados, como em evidentes hipóteses da interdição, da tutela e curatela, das alienações, das sub-rogações, dos protestos marítimos, da fiscalização de fundações e outros.

6.2.3 Terceiros intervenientes ou cointeressados

Não se prevê expressamente a intervenção de terceiros na jurisdição voluntária, - e nem se poderia cogitar de plano; vez que, a inexistência de parte em sentido estrito, a baixa ou quase inexistência. Conflituosidade de muitos procedimentos típicos pode induzir a pensar-se que não existe a possibilidade destas intervenções. Contudo, seja porque o tratamento da matéria pode conter certa fração de contenciosidade, seja porque pode ocultar aparente desinteresse geral, é possível cogitar-se, em tese, de admitir-se a intervenção de terceiros interessados, promovente e promovido.

Ao estabelecer que “serão citados todos os interessados, bem como intimado o Ministério Público, nos casos do art. 178, para que se manifestem, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias” (art. 721) não indica propriamente a possibilidade ou impossibilidade de admitir-se a participação de terceiros.

A natural ausência de terceiros se deve ao fato de não haver propriamente um *bem da vida em litígio* sobre o qual possa haver interesse de pessoa estranha ao vínculo jurídico, inicialmente apresentado à Jurisdição ou ao Estado-Juiz, mas tão somente interesses receptícios, declaratórios, constitutivos, tutelares e raramente executivos. Logo, tratando-se de procedimentos em que sequer há partes (autor e réu) litigantes, natural que aos riscos não repercutam na esfera jurídica de terceiro a ponto de justificar sua intervenção nos autos judiciais. Evidentemente há procedimentos com maior intensidade conflitiva, como a interdição, a fiscalização de fundações e outros.

A doutrina brasileira já tratou do tema e Ubiratan do Couto Maurício admite a intervenção, contrariando numeroso grupo que não admite.²¹⁸ O conteúdo patrimonial de certos procedimentos (bens de ausentes, herança jacente, testamentos e codicilos) a intervenção na esfera

de vontade (interdição, tutela e curatela) também justifica a possibilidade de chamar-se como o interessado ao processo, aquele que, em outra circunstância, seria um terceiro. Igualmente preocupante, o reconhecimento em outros países da jurisdição voluntária pode representar um risco potencial para os direitos de terceiros.²¹⁹

Nesses casos é de admitir-se, como possível a participação, sem que isso transforme ou converta o procedimento em contencioso. De modo diverso, se o terceiro estabelece o conflito na proteção de direito seu, que vê atingido ou ameaçado, como no caso referido é de admitir-se a conversão.²²⁰

Admitida a participação do terceiro, seja como tal ou como cointeressado, admitir-se-á, também, a sua legitimidade para interpor recursos de terceiros ou de cointeressado, tal como aqueles comuns à primeira instância, agravos e apelação, como os demais afetos aos tribunais superiores.²²¹

A ação de oposição, que adequadamente foi retirada do rol de intervenções de terceiro, exatamente por não ser uma dessas modalidades, figura agora dentre os procedimentos especiais, pois desde sempre foi vista como uma ação interventiva, na qual controverte em “ação facultativa (procedimento) agora posicionada dentre os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa na qual o oponente postula direito ou coisa disputados por outros, em outra ação. Nela o autor (opponente) controverte seu direito às alegações e defesas que autor e réu (opostos) opõem entre si em outra demanda. É demanda sobre o objeto processual de outra demanda, que pode coincidir integralmente (oposição total) ou não (oposição parcial). Não se admite a oposição se o seu objeto for mais amplo que o objeto controvertido na ação original; neste caso somente poderá o interessado propor a ação autônoma, pelo todo ou pelo que excede a ação original.”²²²

Nitidamente desajustada do conceito, da índole e dos objetos tradicionais da jurisdição voluntária, dada a intensa e múltipla litigiosidade que possui a oposição, faz-se também por isso incompatível, por óbvio, com essa espécie procedimental de escassa conflituosidade e ausência de partes.

6.2.4 Auxiliares da Justiça

Não difere na essência a atuação dos auxiliares do juízo na jurisdição voluntária, daquela própria da jurisdição contenciosa. O art. 149 indica que são auxiliares do juízo ou da Justiça: o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias, segundo a organização judiciária de cada Estado ou mesmo da União.

De forma resumida, o escrivão, chefe de secretaria e o oficial de justiça (arts. 150-155) são auxiliares do juízo, aos quais incumbe:

a) escrivão ou ao chefe de secretaria: redigir, na forma legal, os ofícios; mandados; cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao ofício; efetivar as ordens judiciais, como citações e intimações (efetivar, não as executar, pois é atividade atribuída ao Oficial de Justiça); comparecer em audiências,²²³ bem como guardar, sob sua responsabilidade, os autos do processo;²²⁴ emitir certidões de qualquer termo ou ato do processo, ainda que não haja despacho para tanto (observadas as disposições sobre segredo de justiça).²²⁵ São exemplos de sua atuação: a leitura do testamento cerrado, nos termos do art. 735 do CPC/2015; o seu acompanhamento na arrecadação de bens de herança jacente, quando por atos extrajudiciais (art. 740 do CPC/2015) e a redação do auto circunstanciado (v. comentários);

b) oficial de Justiça: realizar as citações; prisões; penhoras; arrestos; atos de rara ocorrência na jurisdição voluntária; executar as ordens do juiz a que estiver subordinado; entregar mandados em cartório, após o seu cumprimento; efetuar avaliações, quando for o caso e certificar, em mandado, proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes (art. 154 do CPC/2015). São exemplos de sua atuação as “citações” dos interessados, conforme exigência do art. 721 do CPC/2015; o arrolamento dos bens de herança jacente (art. 740 do CPC/2015) e avaliação de

bem alheio (v. comentários ao art. 746).

O Perito (arts. 156–158), da mesma forma, é auxiliar da Justiça, porém requisitado apenas quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Diferentemente dos auxiliares anteriormente mencionados, o perito não é um servidor. Trata-se de profissional legalmente habilitado, nomeado pelo juízo, por meio de um cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. O perito poderá, ainda, ser órgão técnico ou científico, desde que devidamente inscrito no cadastro mantido pelo Tribunal (art. 156, § 1.º, do CPC/2015). Está submetido às hipóteses de impedimento e suspeição previstos nos arts. 148 e 467, CPC/2015. Incumbe a ele cumprir, realizar a perícia no prazo designado pelo juízo, empregando suas habilidades (art. 157 do CPC/2015). São exemplos de sua atuação: a avaliação da capacidade do interditando, (art. 753 do CPC/2015) e a elaboração de laudo pericial quando do levantamento da curatela (art. 756, § 2.º, CPC/2015) (v. comentários ao art. 7562);

O Depositário ou Administrador (arts. 159-161), é auxiliar, cuja atribuição consiste em guardar e conservar os bens provenientes de penhora, arresto, sequestro ou arrecadamento, desde que a lei não disponha de outro modo (art. 159). São exemplos de suas atividades: a fiscalização e eventual compra de bem gravado com cláusula de inalienabilidade (v. comentários ao art. 725, inciso II); a guarda e administração de imóvel de incapaz (art. 896) (v. comentários ao art. 730,) e prestação de contas quanto à administração de bens e valores alheios (v. comentários ao art. 735).

O intérprete ou tradutor (arts. 162-164) tem como razão de sua atuação o uso obrigatório da língua portuguesa em todos os atos e termos do processo (art. 192). Necessário, portanto para traduzir documento redigido em língua estrangeira; verter para o português as declarações das partes e das testemunhas que não conhecerem o idioma nacional; interpretar simultaneamente os depoimentos das partes e testemunhas com deficiência auditiva que se comuniquem por meio da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Como os demais auxiliares, se submete aos impedimentos (art. 163). São exemplos de atuação do tradutor, oficial ou não, aquele que traduz os documentos a serem ou já juntados ao processo, como no Ratificação dos Protestos Marítimos e dos Processos Testemunháveis Formados a Bordo (arts. 766 a 770); exemplo de atuação do intérprete pode ser o procedimento de interdição (arts. 747 a 758) ou na tomada de decisão apoiada.

Os conciliadores e mediadores (arts. 165-175) possuem atribuições distintas, incumbindo ao primeiro, nos termos do art. 165, § 2.º, atuar em casos em que não havia vínculo anterior entre as partes, podendo sugerir soluções para o litígio, sendo-lhe vedada a intimidação ou utilização de qualquer meio de constrangimento, a fim de levar as partes a conciliação; já ao segundo incumbe, nos termos do § 3.º do mesmo artigo, auxiliar os interessados, nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, a compreenderem as questões e os interesses em conflito, de forma que possam reestabelecer a comunicação e identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Da mesma forma como os peritos, os auxiliares aqui comentados não são, necessariamente, servidores públicos (art. 167 do CPC/2015). Estão submetidos às hipóteses de impedimento e suspeição, conforme art. 148, inciso II, do CPC/2015. Pode-se citar como exemplo de suas atuações a homologação de acordos em ações onde não exista propriamente um conflito ou nas quais há baixa conflituosidade, tendo em vista o ditame do art. 139 do CPC/2015 (vide item 3.4.1, do *Breve Ensaio Inicial*), como na interdição e na fiscalização e extinção de fundações.

7. Funções Essenciais à Justiça e a jurisdição voluntária atual

Além dos sujeitos “parciais” e do juiz, sujeito “imparcial” da jurisdição voluntária, há nessa atividade jurisdicional o envolvimento de outros entes e instituições, seja em nome próprio ou em representação judicial, tais como o Ministério Público, a Defensoria Pública e Advocacia Pública e a Advocacia privada, conjunto de instituições, órgãos, funções e atividades que a Constituição de 1988 denominou de *Funções Essenciais à Justiça*, arts. 127-135.²²⁶ Para uma análise do trâmite na Assembleia Nacional Constituinte e a formação desta concepção deve-se atentar aos anais que relatam essa evolução.²²⁷

7.1 Ministério Público

A atividade do Ministério Público, no modelo brasileiro atual, tem mais amplitude que nos demais países de tradição romano-germânica e relevo maior que as demais instituições e órgãos denominados como Funções Essenciais à Justiça pela Constituição de 1988 (art. 127 e ss.), com destaque entre suas atribuições a incumbência da “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”.²²⁸ A Lei Complementar 75/1993 reprisa esta mesma incumbência geral (art. 1.º).

Também o CPC/2015 estabelece as hipóteses de atuação (arts. 176-181), especialmente na defesa de interesse público e social (art. 178, inc. I), defesa de interesse de incapaz (art. 178, inc. II), seja no exercício do direito de ação, como parte, em representação, em conformidade com suas atribuições constitucionais (art. 177) ou como fiscal da ordem jurídica (art. 178).

A participação ou a intervenção do Ministério Público na jurisdição voluntária tem sido intensamente debatida, ora vinculada à presença de interesses que mereçam a sua proteção, ora mais estendida, como apontava Pontes de Miranda, que associava essa presença à inafastabilidade do ‘interesse público’, além da presença de interesses privados protegidos (incapazes, estado, tutela, curatela, interdição etc.), gerando nulidade sua ausência quando citado, não tivesse intervindo.²²⁹

Não é terceiro no processo o Ministério Público, é parte ou fiscal da ordem jurídica. Quando, por ventura, atua como parte não necessita de um membro para um fim e outro membro para outro fim; basta um, que além de fiscal represente eventualmente o interessado.²³⁰

Alfredo de Araújo Lopes da Costa que afirmava ser o Ministério Público função acessória, mas indispensável ao Poder Judiciário, afirmava não age na jurisdição voluntária para manter o império da lei, e sim sob a inspiração da oportunidade e conveniência, dos princípios comuns à administração pública e à jurisdição voluntária.²³¹ José Frederico Marques afirmava que o papel do Ministério Público é de fiscalização da atuação dos interessados, promovente e promovido, e do juiz, sendo nulo processo se ausente.²³²

Edson Prata fundamentava a participação na incidência de leis de ordem pública e direitos da personalidade, normalmente indisponíveis, tendo ampliado as atividades no CPC/1973;²³³ de modo similar, Alcides de Mendonça Lima identificava a necessidade de participação, por obrigatória, imprescindível e indeclinável do Ministério Público na jurisdição voluntária;²³⁴ assim como para Nelson Nery Jr.²³⁵

Essa visão única, categórica, linear e genérica não comporta mais aplicação tão ampla, em vista da superexpansão dos poderes do Ministério Público e da necessidade que se concentre em atividades consideradas prioritárias. O CPC/2015, em parte, recua e limita a atuação de modo mais concentrado às áreas de interesse público. Esta é a posição de parte da doutrina, define essa razão pois “(...) tão-somente por se tratar de um feito de procedimento de jurisdição voluntária – sem que estejam presentes hipóteses previstas (...) – não há motivo suficiente a reclamar a nobre intervenção ministerial.”²³⁶ Essa é também a proposição de outros autores, que advogam a proposição de não recepção pela Constituição das normas, que davam ao Ministério Público atribuição de defesa de “interesse eminentemente privado por órgão unicamente encarregado da tutela de interesse público.”²³⁷

O art. 721 do CPC/2015 trata de *intimação* do Ministério Público e não mais de citação, como o art. 1.105 do CPC/1973, que tratava de *citação*, sendo prudente o exame do comentário correspondente a esse artigo.

7.1.1 As hipóteses expressas no CPC/2015

São hipóteses expressas de atuação do Ministério Público: a) art. 720 - prevê a atuação como “parte” ou interessado, provocando a jurisdição por meio de petição inicial; b) art. 721 - prevê a intervenção do órgão como fiscal da lei; c) art. 734, § 1.º - prevê a atuação do Ministério Público, como fiscal, nos procedimentos de alteração de regime de bens (Seção IV do CPC/2015); d) art. 735, § 2.º - prevê a atuação do Ministério Público, como fiscal da lei, nos casos de testamento cerrado e

codicilos (seção V do CPC/2015); e) art. 737, § 2.º - da mesma forma que o anterior, este artigo prevê a intervenção do órgão ministerial como fiscal da lei, quando for requerido por um dos herdeiros, legatários, pelo testamenteiro ou pelo terceiro detentor do testamento, que esteja impossibilitado de entrega-lo a algum dos legitimados, a publicação do testamento particular; f) art. 739, § 1.º, inc. I - nos casos de herança jacente, o Ministério Público intervirá como fiscal da lei, da mesma forma que no art. 740, § 6.º, o qual aduz que não se procederá a arrecadação dos bens da herança jacente, ou se suspenderá, caso, além dos requisitos elencados na primeira parte do parágrafo (aparecimento de herdeiro, cônjuge, companheiro ou testamenteiro notoriamente reconhecido), caso não haja oposição motivada do Ministério Público ou da Fazenda Pública; g) art. 745, § 4.º - embora haja a previsão de citação do Ministério Público neste caso, cumpre destacar que, até a citação, o procedimento está submetido às regras de jurisdição voluntária, porém, havendo contestação por parte dos sucessores provisórios ou definitivos, ou mesmo do próprio ente Ministerial ou da Fazenda, o procedimento será convertido em comum contencioso, conforme parte final do parágrafo.²³⁸ Neste caso, o MP será citado como interessado, nos termos do art. 720, passando a ser parte, caso conteste; h) art. 747, inc. IV c/c art. 748 - neste caso, o MP atuará como “interessado promovedor” (art. 720) nos casos de interdição, porém apenas quando se verificarem as hipóteses previstas no *caput* e incisos do art. 748;²³⁹ i) art. 752, § 1.º - ainda sobre o procedimento de interdição, este artigo prevê, caso o Ministério Público não esteja agindo como “interessado promovente” (requerendo a interdição), a intervenção deste como fiscal da lei; j) art. 756, § 1.º - sendo parte legítima para requerer, como interessado, a interdição, também o é para requerer o levantamento total ou parcial da curatela, caso se verifique a cessação da causa que a determinou, ou se demonstre possuir, o interditado, capacidade parcial para praticar alguns atos da vida civil (§ 4.º do mesmo artigo); k) art. 761 - poderá, ainda, agir como interessado (art. 720) para requerer a remoção de tutor ou de curador, porém, havendo contestação por qualquer destes, observar-se-á o procedimento comum;²⁴⁰ l) art. 764, incs. I e II e art. 765 - no primeiro caso, o Ministério Público intervirá como fiscal da lei (art. 721 c/c 178, I e III) e no segundo como “interessado requerente”, (art. 720). Os dois artigos tratam sobre a organização, fiscalização e extinção das fundações (seção XI), assim, caso o Ministério Público negue previamente, ou exija modificações do estatuto, poderá o interessado, caso não concorde, requerer ao juiz o suprimento de aprovação do Ministério Público (art. 764, I e II), agindo este último como fiscal da lei. No tocante à extinção da fundação (art. 765), o Ministério Público possui legitimidade ativa para ingressar com ação de extinção da fundação, agindo como “interessado requerente”, nos termos do art. 720, sendo que, caso o procedimento não tenha sido provocado por ele, deverá atuar como fiscal da lei, nos termos do art. 721 c/c 178, I e III.²⁴¹

7.1.2 As hipóteses não expressas no CPC/2015

A relação entre as diversas ordens normativas da Jurisdição Voluntária (arts. 719-724), procedimento de jurisdição voluntária 'comum' ou geral, tal como aos procedimentos voluntários típicos do CPC (arts. 726-770) e os procedimentos do rol não taxativo do art. 725, podem atrair a atuação do Ministério Público, assim como aos procedimentos esparsos de leis especiais integrantes da jurisdição civil.

7.1.3 Legitimidade do Ministério Público para atuar como equivalente da Jurisdição Voluntária

Além de atuar largamente na jurisdição voluntária, como parte ou como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público atua como verdadeiro e próprio *equivalente da jurisdição voluntária*.

É certo, como dito no item 5, que se tratam de jurisdição voluntária os atos de homologação previstos na Lei do Juizado Especial de Pequenas Causas (Lei. 7.244/1984, art. 55); Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais (Lei 9.099/1995, art. 57); CPC/1973 (art. 475-N, inc. V, introduzido pela Lei 11.232/2005, revogado) e, agora, reconhecidos expressamente pela situação topografia no inc. VIII do art. 725 do CPC/2015.

Esses atos de natureza jurisdicional (voluntária) podem também há muito ser praticados pelo Ministério Público. Desde a Lei 7.244/1984, art. 55, parágrafo único,²⁴² e antes dela também;²⁴³ e da Lei 9.099/1995, art. 57, parágrafo único.²³³

7.1.4 Legitimidade para atuar como parte e como fiscal da ordem jurídica

²⁴⁴A legitimidade do Ministério Público na jurisdição voluntária, como de resto no processo civil brasileira é ampla, tendo sofrido notável expansão a partir das leis da década de 1980 e na Constituição de 1988, sofrendo a partir da década de 2010 certa acomodação. Neste sentido o CPC/2015 em parte estabiliza essa expansão e até retrai, concentrando a legitimação para os casos da presença do interesse público ou social, do interesse de incapaz e nos litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana (art. 178 e incisos).

A legitimidade de seus membros se estende para a atuação como parte e como fiscal da ordem jurídica, podendo promover a ação ou intervir, assim como interpor recursos sempre associados aos interesses que defendem ou representam.²⁴⁵

7.2 Defensoria Pública

A Defensoria Pública, instituição que galgou status constitucional da Constituição de 1988, como Função Essencial à Justiça²⁴⁶ e na Lei Complementar 80/1993,²⁴⁷ ganhou também destaque especial no CPC/2015.

A doutrina tem posição muito clara sobre os novos deveres sociais e políticos da Defensoria Pública no Estado Democrático de Direito, além dos encargos propriamente processuais²⁴⁸ que atendem às expectativas de acesso à Justiça.²⁴⁹

7.2.1 A hipótese expressa no CPC/2015

O art. 720 apresenta expressamente a possibilidade de representação da parte interessada pela Defensoria Pública. Diferentemente da atuação do Ministério Público e da Advocacia Pública, a Defensoria atuará sempre que a parte for comprovadamente hipossuficiente, nos termos do art. 5.º, LXXIV, da CF/1988 e inciso VIII do art. 4.º da LC 80/1993. A hipossuficiência segue as regras previstas nos arts. 98 e seguintes do CPC/2015, sendo presumida, caso seja deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3.º).

7.3 Advocacia Pública

A Advocacia Pública, instituição que também galgou status constitucional na Constituição de 1988, igualmente como Função Essencial à Justiça,²⁵⁰ e na Lei Complementar 73/1993, que organiza a advocacia estatal federal, além de leis estaduais, distrital e municipais.

Atua em nome alheio, em representação à Fazenda Pública, aos entes da Administração, sejam os entes federativos da Administração direta: União, Estados, Distrito Federal ou Municípios; como em representação judicial e na representação extrajudicial, no assessoramento aos gestores e na consultoria aos entes da Administração indireta: autarquias, fundações, empresas públicas e mesmo das sociedades de economia mista.

Para a conceituação de Fazenda Pública Leonardo Carneiro da Cunha a indica como o Estado em juízo, Poder Público em juízo e mais precisamente a personificação do Estado.²⁵¹

7.3.1 As hipóteses expressas no CPC/2015

São hipóteses de atuação da Advocacia Pública: a) art. 722 – prevê a necessidade de intimação da Fazenda Pública nos casos como o do art. 740, § 6.º, em que a manifestação da Fazenda é necessária para que se proceda - ou não - a arrecadação, ou para esta seja suspensa; b) art. 742, § 1.º - prevê que a Fazenda poderá impedir que se realize a alienação de bens imóveis, proveniente de herança jacente, que estejam hipotecados e cuja dívida tenha vencido e não haja dinheiro para o pagamento, desde que adiante a importância para despesas; c) art. 745, § 4.º - prevê a necessidade de citação da Fazenda para que se manifeste, por meio de contestação, sobre o requerimento do ausente ou de qualquer de seus ascendentes ou descendentes, para reaver os bens concedidos à título de sucessão provisória ou permanente.

7.4 Advocacia

Não há exercício de Poder Jurisdicional, salvo raras exceções, sem a atuação e representação da advocacia ou *defesa técnica*, sendo indispensável a representação por advogado para a administração da Justiça (CF, art. 133). Portanto, nas raras hipóteses de autorização à autodefesa processual civil (ação de alimentos, ação acidentária e procedimentos dos juizados especiais)²⁵² ou concessão de capacidade postulatória direta à parte (*jus postulandi* direto) não terão curso dentre os procedimentos de jurisdição voluntária, embora já se tenha proposto esse caminho.²⁵³

Talvez uma exceção à exceção seja a atuação direta da parte nos juizados especiais (JEC, JEF e JEFP), com a nova aplicação do inc. VIII do art. 725, quando pretenda a parte a “homologação de autocomposição extrajudicial, de qualquer natureza ou valor”, que seguindo a jurisdição voluntária, nos limites destes juizados, poderá dispensar o acompanhamento de advogado (ver *Breve Ensaio Inicial*).

8. Direito material e suas áreas, diversidade e classificações na Jurisdição Voluntária

Existe uma ampla diversidade de procedimentos de jurisdição voluntária que dificultam as classificações porquanto a inclusão ou exclusão de determinado direito material nesse meio processual não obedece a critérios claros ou coerentes. Essa *desordem* permite agrupar na jurisdição voluntária uma verdadeira ‘Arca de Noé’, como nominou Francisco Beceña ou um ‘Labirinto’, como disse Pietro Castro) que dificulta a organização por categorias ou critérios.²⁵⁴

Esse fenômeno da multiplicidade de procedimentos e respectivos provimentos é comum em outros países como Itália,²⁵⁵ Espanha,²⁵⁶ Brasil, onde observa que “difícilmente alcançaria êxito qualquer tentativa de sistematização completa dos motivos determinantes da adoção de procedimento especial.”²⁵⁷ Essa multiplicação está associada ao fim da utopia do “modelo procedimental único,”²⁵⁸ ideal há muito superado.²⁵⁹

Se não estão à mostra os critérios para a inclusão ou exclusão, uma razão está à vista de todos, qual seja: a jurisdição aqui atua para “zelar por algumas situações de direito material que, diante da sua relevância social ou ao ver do legislador, não podem ficar entregues apenas aos particulares envolvidos, ou ainda ser apenas recepcionados por uma autoridade administrativa ou um sujeito privado,”²⁶⁰ ou alguns interesses de ordem pública e remotamente até interesses públicos.

É em razão da natureza do direito material, que se concede ou retira o status de procedimento especial e sua divisão em voluntária ou contenciosa, se dá pela razão simples de conter ou não acentuada conflitualidade.

As classificações feitas pela doutrina indicam um extenso conteúdo material que pode vir contido nos procedimentos de jurisdição voluntária. Eduardo J. Couture, após criticar o destaque dado ao texto de Marciano no Digesto – que define a jurisdição voluntária como os procedimentos judiciais em que não há oposição de partes e nos quais a decisão não causa prejuízo a pessoa conhecida – afasta a existência tanto de jurisdicionalidade como de voluntariedade para acrescentar que na tradição latino-americana, seguindo-se aos espanhóis, agrupa-se sob esta denominação uma vasta diversidade de previsões.²⁶¹ O autor uruguaio classificava os procedimentos de jurisdição voluntária, a partir do conteúdo material em: *medidas de publicidade; atos judiciais de homologação; autorização para a realização de ato; produção de provas; liquidação judicial de impostos; tutela de menores, ausentes e incapazes; intimações e protestos; e administração judicial*.

Referindo-se ao CPC/1973, José Maria Rosa Tesheiner, distribui a matéria entre as tutelas de *pessoas incertas*, de *incapazes*, de *atos da vida privada* e da *prova dos fatos jurídicos* indicando conteúdo dos mais variáveis,²⁶² sem considerar as notificações e interpelações, agora transportadas dos procedimentos cautelares para a jurisdição voluntária. Leonardo Greco, com base no CPC/1973, classifica em *receptícios, probatórios, declaratórios, constitutivos, executórios e exclusivamente tutelares*.

8.1 Civil

A grande área de atuação da jurisdição voluntária é a matéria cível, como se pode ver do rol de procedimentos especiais de jurisdição voluntária previstos no CPC e na legislação esparsa, seja nas áreas de Família, Criança e Adolescente, Contratos, Sucessões etc. Essa afinidade não exclui outras tantas, especialmente áreas não penais que se ajustam a essa atratividade da jurisdição voluntária pela área cível.²⁶³

8.2 Empresarial

A segunda área em importância é a empresarial, aqui compreendidos também o Direito Societário, Direito Marítimo e outros.²⁶⁴ Exemplo tradicional de aplicabilidade é o Regulamento 737/1850, que continha normas específicas de jurisdição voluntária aplicáveis à *Jurisdição Voluntária e Administrativa dos Juizes de Direito do Commercio*, arts. 21 e 22.²⁶⁵

Igualmente o Código Comercial, Lei 566/1850, no Título Único (Da Administração da Justiça nos Negócios e Causas Comerciais), Capítulo I (Dos Tribunais E Juízo Comerciais), Seção I (Dos Tribunais do Comércio), art. 8.º, determina que “Aos Tribunais do Comércio competirá, além das atribuições expressamente declaradas no Código Comercial, aquela jurisdição voluntária inerente à natureza da sua instituição, que for marcada nos Regulamentos do Poder Executivo (art. 27).”

8.3 Trabalhista

Amauri Mascaro do Nascimento, sem tratar da jurisdição voluntária, indica os seus pressupostos ao descrever que a “autocomposição é a técnica de solução dos conflitos coletivos pelas próprias partes, sem emprego de violência, mediante ajustes de vontade”, que pode se dar na “ordem trabalhista, a forma autocompositiva clássica é a convenção coletiva de trabalho, decorrente de negociações coletivas, das quais resultam, mediante o acerto dos interesses, as normas que, instituídas de comum acordo pelos sindicatos e empresas, vigorarão por certo prazo, disciplinando as suas relações e os contratos individuais de trabalho.”²⁶⁶

A jurisdição voluntária da nova “homologação de autocomposição extrajudicial, de qualquer natureza ou valor” (art. 725, inc. VIII) pode ter aplicação ao processo trabalhista, especialmente por não ter sido mencionada na Resolução n. 203/15-03-2016, do TST, que aprovou a Instrução Normativa n. 39/2016, que definiu quais institutos do CPC/2015 são inaplicáveis e inaplicáveis à matéria trabalhista.

Na matéria trabalhista, se considera como jurisdição voluntária o acesso judicial a valores referentes a certas verbas de natureza trabalhistas, depositadas em fundos. Também na matéria de dissídios o Tribunal Superior do Trabalho já identificou interesses ajustáveis à jurisdição voluntária.²⁶⁷

8.4 Penal

A típica contenciosidade do Direito Penal e Processual Penal aparentemente afasta da jurisdição voluntária esses campos jurídicos, sendo essa uma posição tradicional da doutrina até meados da primeira metade do século XX. No processo penal brasileiro essa tendência se mantinha incólume até há pouco.²⁶⁸

Hélio Tornaghi admitia a transação penal com os negócios processuais, ajustáveis à jurisdição voluntária.²⁶⁹

Fernando Luso Soares, tratando do Direito Penal e Processual Penal português tem outra clara posição, admitindo tratarem-se os procedimentos penais de jurisdição voluntária, tal a diferença existente entre o processo civil contencioso e o processo penal que, escudado em uma “aparência de similitudes” e no descuido às fundas diferenças entre um e outro se nega a perceber.²⁷⁰

A criação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, pela Lei n. 9.099/1995, previstos desde a

Constituição de 1988, art. 98, inc. I, ampliou essa perspectiva compositiva ou consensual da justiça penal, com a disponibilidade da ação penal e com a possibilidade da transação penal, com características assemelhadas às da jurisdição voluntária, como certa opcionalidade.

Ampliação mais significativa foi trazida pela Lei 12.850/2014 e a “colaboração premiada”, que institui amplamente o perdão judicial, redução de até 2/3 da pena privativa de liberdade, substituição de penas mais graves por restritivas de direito, nas hipóteses em que o criminoso investigado, acusado ou condenado identifique parceiros e coautores, estruturas organizacionais criminosas, recuperação parcial ou total de produtos do crime, localização de vítimas etc. (art. 4.º, incs. I a IV). Afrânio Silva Jardim prontamente identificou a natureza de jurisdição voluntária e de negócio jurídico de Direito Público na “decisão judicial (não jurisdicional) que a lei exige”²⁷¹ para a concretização dos acordos de delação premiada e a “visão privatista” do Direito Penal. Evidencia-se também o negócio processual com profundos efeitos materiais, sem participação direta do juiz (art. 4.º, § 6.º) nas etapas preparatórias do acordo. A atividade judicial é de natureza homologatória (art. 7.º), embora o juiz possa recusá-la e adequá-la ao caso concreto (art. 4.º, 8.º), apreciar seus termos e eficácia (art. 4.º, 11). Não prevê a lei a forma de desconstituição do ato das partes, embora se possa cogitar que seja atingido pelos defeitos ou vícios comuns aos atos de vontade e negócios, tais como erro ou ignorância, dolo, coação, estado de perigo, estado de coação, fraude etc. (CC/2002, arts. 138-165).

8.5 Eleitoral, Internacional e outras

Por certo as áreas do direito indicadas acima não são as únicas a se afinizarem com a jurisdição voluntária, especialmente pelas características da fraca contenciosidade, presença de interesses públicos etc.

NOTAS DE RODAPÉ

1

A etimologia da palavra voluntária decorre do latim *voluntarius*, -a, -um, derivado de *voluntas*, do verbo *volo*, *velle*, de desejar, de querer.

2

Vittorio Scialoja. *Procedimento Civil Romano*: ejercicio y defensa de los derechos, § 11 e § 12, p. 122 e 125, referindo-se ao período das *legis actiones* e aos *recuperadores*, colegiados compostos por três ou cinco pessoas. O processo civil romano evoluiu em três demarcados períodos, de forma diferenciada e não coincidente com o direito material, assim definidos: a) *Legis actiones* (das origens até 130 a.C.); b) *Per formulas* (do ano de 130 a.C. até 294 d.C.) e c) *Cognitio extraordinaria* (do ano de 294 d.C. até o período Justinianeu).

3

Ver por todos: Jorge Araken Faria da Silva, *Natureza jurídica da Jurisdição Voluntária*, vol. I, tit. II, caps. I e II, p. 48-76. Escrita sob a orientação de José Roberto Franco da Fonseca, reúne nos 4 volumes cerca de 1.000 páginas com mais extenso panorama comparado sobre a jurisdição voluntária já exposto no meio acadêmico brasileiro.

4

Situavam-se no Livro IV, Título II, entre os *procedimentos especiais*, arts. 1103 a 1210, divididos em 11 capítulos correspondentes a cada procedimento ou agrupando procedimentos similares, além de ter preservado como vigentes até 2015 procedimentos de jurisdição voluntária e contenciosa do CPC/1939.

5

Situavam-se no Livro IV, Título XXIV, entre os *processos especiais*, arts. 524 a 654.

6

Editaram-se códigos nos Estados do Rio Grande do Sul (1908), Maranhão (1909), Espírito Santo (1914), Bahia (1915), Rio de Janeiro (1919), Paraná (1920), Piauí (1920), Sergipe (1920), Ceará (1921), Minas Gerais (1922), Rio Grande do Norte (1922), Pernambuco (1924), Distrito Federal (1924), Santa Catarina (1928) e São Paulo (1930). Tais leis estaduais possuíam variada forma de apresentação dos procedimentos de jurisdição voluntária.

7

No Regulamento 737/1850 a Jurisdição Voluntária dos juízes de Direito do Comércio, situava-se nos arts. 21 e 22.

8

Para a compreensão para a dita “pequena demanda” ou “juízo conciliador” ver: José Roberto da Cunha Sales. *Tratado da praxe conciliatoria: Theoria e pratica das conciliações e da pequena demanda*.

9

Situava-se parte da competência das matérias no Livro I, Títulos LXXXVIII, LXXXIX e XC; Livro IV, Títulos LXXX, LXXXIII, LXXXVI, CII, CIII, relacionadas a inventários, órfãos, tutela e curatela, testamentos e codicilos, coisas vagas e jacentes etc.

10

Situava-se parte da competência das matérias no Livro IV, Títulos LXXXVI, entre outros.

11

Situava-se parte da competência das matérias no Livro IV, Títulos LXXXII a LXXXXVIII, entre outros.

12

Ada Pellegrini Grinover. Deformalização do processo e deformalização das controvérsias, *Novas tendências do direito processual*, 2. ed., item 1.5, p. 179-180.

13

Afirmava que: “a jurisdição voluntária pertenceu nos primeiros tempos aos notários e com o andar do tempo foi passando aos órgãos do Poder Judicial. Nada impede que passem amanhã para a administração e ainda que voltem a sua fonte de origem (...)” (Eduardo J. Couture. *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*, item n. 32, p. 53).

14

José Maria Rosa Tesheiner. *Jurisdição voluntária*, item n. 2, p. 53-54.

15

Alfredo de Araújo Lopes da Costa definia a conciliação como “ato pelo qual, com a discreta intervenção de um juiz de jurisdição voluntária ou de um juiz de jurisdição contenciosa, funcionando em sede de jurisdição voluntária, as partes amigavelmente compõem o conflito de interesses que as divide.” Ver: Alfredo de Araújo Lopes da Costa. *A Administração Pública e a ordem jurídica privada*(*Jurisdição Voluntária*), cap. XVI, item n. 284, p. 344.

16

Ver: Alfredo de Araújo Lopes da Costa. *A Administração Pública e a ordem jurídica privada*(*Jurisdição Voluntária*), cap. XVI, item n. 284, p. 344; depois: Ovídio A. Baptista da Silva; Fábio Gomes. *Teoria geral do processo civil*. 2. ed., ponto IV, item n. 3, p. 76-77.

17

Considerada dentre uma centena de obras americanas e europeias, “sin duda la obra de mayor aliento entre las que ahora se mencionam”: Niceto Alcalá-Zamora Y Castillo, Niceto. Eficacia de las providencias de la jurisdicción voluntaria, *Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México*, vol.15, n. 45, item n. 12, p. 526, nota n. 19.

18

Não estão aqui citadas todas as *obras monográficas* e nem todos os *comentários ao CPC*, assim como uma imensa quantidade de artigos publicados em revistas e outras coletâneas, que aprofundaram pontos específicos do Direito Processual Civil que envolve a Jurisdição Voluntária.

19

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*, 2. ed., vol. X, art. 1.103, item n. 3, p. 16.

20

A denominação de Jurisdição Voluntária ‘comum’ ou geral é adotada pela doutrina como forma de distinguir essas ordens normativas diversas, contidas nos arts. 719-724 (comum) daquela dos arts. 726 a 770 (especial), no entanto, não parece adequada, em vista da ambiguidade ou pleonismo linguísticos, pois

haveria *procedimentos especiais de jurisdição voluntária comum* e *procedimentos especiais de jurisdição voluntária especial*.

21

Humberto Theodoro Júnior. *Curso de Direito Processual Civil*, 52. ed., vol. II, item n. 282, p. 480; Fabio Caldas de Araújo, *Curso de Processo Civil: Procedimentos Especiais*. t. III, parte III, cap. I, item n. 5, p. 469.

22

[22] Neste mesmo sentido, referindo-se ao CPC/1973, e justificando a aplicação dos Livros I, II e III, ver: Leonardo Greco. *Jurisdição voluntária moderna*, item n. 2.1, p. 31.

23

Essa estrutura foi introduzida no CPC/1973 e destacada pelo autor do projeto; Alfredo Buzaid. *Linhas fundamentais do sistema do Código de Processo Civil brasileiro. Estudos e pareceres de Direito Processual Civil*, item n. 2.4.2, p. 48.

24

Cândido Rangel Dinamarco. *Fundamentos do Processo Civil Moderno*, 3. ed., vol. I, Cap. XIII, item n. 165, p. 386-387.

25

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *O novo processo civil*, item n. 4.4.9, p. 80-81.

26

Ver nosso: Jefferson Carús Guedes. *Procedimentos especiais a partir do CPC 2015: a ressignificação do confronto entre as técnicas processuais diferenciadas e o atual procedimento comum (flexível e fundível)*. Prelo.

27

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, Disposições Gerais, item n. 2, p. 6.

28

Alfredo de Araújo Lopes da Costa. *A Administração Pública e a ordem jurídica privada* (Jurisdição Voluntária), cap. VII, item n. 31, p. 65; Alfredo Buzaid. *Linhas fundamentais do sistema do Código de Processo Civil brasileiro. Estudos e pareceres de Direito Processual Civil*, item n. 2.4.2, p. 47. Antonio Carlos Marcato. *Procedimentos especiais*, 15. ed., item n. 3, p. 7-8.

29

Guido Zanobini. Sull'amministrazione pubblica di diritto privato, *Rivista di Diritto Pubblico*, n. I, 1918, p. 169.

30

Fernando Henrique Mendes de Almeida. Tipicidade e atipicidade nos atos administrativos. *Revista da Faculdade de Direito*, vol. 60, item n. II.7, p. 170. Nelson Nery Junior. Intervenção do Ministério Público nos procedimentos especiais de jurisdição voluntária. *Revista de Processo*, vol. 46, p. 7-28, item n. 5 (versão eletrônica); Cristina Ferraz. *Jurisdição voluntária no processo civil*, item n. 4.4, p. 121-122.

31

Cândido Rangel Dinamarco; Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes. *Teoria geral do novo processo civil*, item n. 42, p. 81.

32

Eduardo J. Couture. *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*, item, n. 32, p. 53. Nicola Picardi. *Manuale del Processo Civile*, cap. XXV, item n. 210, p. 477.

33

Gian Antonio Micheli. Per una revisione della nozione di giurisdizione volontaria, *Rivista di Diritto Processuale*, vol. 2, n. 1, item n. 1, p. 18.

34

Enrico Tullio Liebman. *Manuale di Diritto Processuale Civile*. vol. 1, Item n. 1-17, p. 28.

35

Eduardo J. Couture. *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*, item n. 32, p. 51-52.

36

Enrico Tullio Liebman. *Manuale di Diritto Processuale Civile*, vol. 1, item n. 1-17, p. 28. Essa é a expressão utilizada por Enrico Tulio Liebman e adotada por processualistas de outros países de tradição romano-germânica; Nicola Picardi. *Manuale del Processo Civile*, cap. XXV, item n. 210, p. 478.

37

José Frederico Marques. *Ensaio sobre a Jurisdição Voluntária*, 1. ed. revista e atualizada, § 22, item 1, p. 241;

38

José Manoel de Arruda Alvim Netto. *Manual de Direito Processual Civil*: parte geral, 7. ed., item n. 57, p. 218.

39

José Ignácio Botelho de Mesquita. *O juizado especial em face das garantias constitucionais*, item n. 11, Disponível em [<http://www.abdpc.org.br>]. Nicola Picardi. *Manuale del Processo Civile*, cap. XXV, item n. 210, p. 477, identifica razões de ordem político-legislativa na atribuição da jurisdição voluntária a um juiz.

40

Humberto Theodoro Júnior. Ainda a polêmica sobre a distinção entre a “jurisdição contenciosa” e a “jurisdição voluntária” espécies de um mesmo gênero ou entidades substancialmente distintas?. *Revista de Processo*, vol. 198/2011, p. 13–50, Ago./2011, Doutrinas Essenciais de Processo Civil, vol. 2, p. 543–579, Out./2011, Item n. 9, subitem “c”, p. 16.

41

Marcos Afonso Borges. Jurisdição. *Revista da Faculdade de Direito da UFG*, item n. 1, p. 25: “Não há dúvida que é jurisdição, e já o demonstramos, é o poder dever do Estado de distribuir justiça, aplicando a lei ao caso concreto.”

42

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, cap. I, item n. 1, p. 7.

43

Ovídio A. Baptista da Silva; Fábio Gomes. *Teoria geral do processo civil*. 2. ed., ponto IV, item n. 3, p. 77-81.

44

Fernando Henrique Mendes de Almeida. Tipicidade e atipicidade nos atos administrativos. *Revista da Faculdade de Direito*, vol. 60, item n. II.7, p. 169.

45

Flavio Luiz Yarshell. *Tutela jurisdicional*, item n. 5.3, p. 135.

46

Elio Fazzalari. *La giurisdizione volontaria: profilo sistematico*, Introduzione, § 2.º, item n. 1, p. 36-37.

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*, 2. ed., art. 1.103, item n. 2, p. 4.

Edson Prata. *Jurisdição voluntária*, tit. II, item n. 6, p. 97. O autor confessa as agruras para classificar o conjunto de procedimentos e os defeitos que resultam dessas tentativas.

Nelson Nery Junior. Intervenção do Ministério Público nos procedimentos especiais de jurisdição voluntária. *Revista de Processo*, vol. 46, p. 7-28, item n. 5 (versão eletrônica). Ali Jose Venturini Villarroel. *Apunte sobre la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en materia de autocomposición procesal y ejecución en sede de jurisdicción voluntaria*, *Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales / Academia de Ciencias Políticas y Sociales*. vol. 70, n. 141, cap. 3, item n. I, p. 216.

J. Ramiro Podetti. Teoría estructural da ciencia del proceso civil, *Teoría y técnica del proceso civil y Teoría estructural de la ciencia del proceso civil*, item n. 8, p. 361.

Fernando Luso Soares. *O processo penal como jurisdição voluntária*: uma introdução crítica ao processo penal, cap. III, item n. 2, p. 55. e José Carlos Teixeira Giorgis. *A lide como categoria comum do processo*, item n. IV, p. 89-114.

José Frederico Marques. *Manual de Direito Processual Civil*, vol. 1, item n. 103, p. 202. Essa é uma opinião comum a muitos processualistas, à maioria pode-se dizer.

José Frederico Marques. *Ensaio sobre a Jurisdição Voluntária*, 1. ed., revista e atualizada, § 22, item 1, p. 241.

Uziel Santana dos Santos. *Litígio e lide*: uma construção, analítico-distintiva, terminológico-conceitual e empírico-crítica, item n. 1.1, p. 32-33. Onde acrescenta que “diferentemente da acepção dada pela dogmática jurídico-processual moderna, que enuncia o Litígio e a Lide como termos processuais de mesma significação conceptual e fenomênica, assentiremos (...) que o Litígio e a Lide são, peremptoriamente, *lato sensu*, elementos terminológico-conceituais de natureza diversa (...)”

Rodolfo Alejandro Aldea Moscoso. *De la autocomposición: una contribución al estudio de la solución de los conflictos jurídicos*, item n. 1, p. 3. Comumente a mesma doutrina destaca que a espontaneidade do sacrifício de um dos litigantes é meramente aparente, pois, na realidade, ela resulta da capitulação da parte que apresenta menos resistência, o que pode ocorrer, até mesmo, em virtude de uma equivocada compreensão acerca de seu direito, item n. 2) B), p. 13. Eliana Pires Rocha. *Conciliação do Direito Processual Civil*, item 1.2.1, p. 10.

56

Niceto Alcalá-Zamora Y Castillo. Eficacia de las providencias de la jurisdicción voluntaria, *Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México*, vol.15, n. 45, item n. 12, p. 533.

57

José Manoel de Arruda Alvim Netto. Manual de Direito Processual Civil: parte geral, 7. ed., item n. 57, p. 221 e p. 223. Arruda Alvim; Humberto Theodoro Júnior. *Curso de Direito Processual Civil*, 52. ed., vol. II, item n. 277, p. 473-474 e item n. 279, p. 477-478; Admite, contudo, a existência de *dissenso*. Antonio Carlos Marcato. *Procedimentos especiais*, 15. ed., item n. 4, p. 10.

58

Edson Prata. *Jurisdição voluntária*, tit. II, item n. 6, p. 101.

59

Vittorio Scialoja. *Procedimento Civil Romano*: ejercicio y defensa de los derechos, § 12, p. 125-126.

60

“Há um trecho do citado Código onde se usa com exclusividade a palavra “procedimento”, sem jamais aludir a “processo” ou “ação”: o Título II do mesmo Livro IV, relativo à chamada jurisdição voluntária ou graciosa. Esse é um indicativo claro de que o legislador optou por uma diferenciação nítida entre os conceitos: com efeito, em se tratando de “processo” sem contraditório e sem partes, embora se haja tomado o partido, por razões históricas, de manter essas figuras paraprocessuais no Código, o mínimo a fazer-se era deixar clara a natureza atípica das mesmas. A inexistência aí de processo autêntico, concebido como *actum tria personarum*, com pressuposto na lide, obriga a admitir que só se trata de procedimento, não processo. Bem por isso, aliás, os textos submetidos àquele Título nunca aludem a partes, mas só a interessados. (Adroaldo Furtado Fabrício. Justificação teórica dos procedimentos especiais)

61

José Frederico Marques. Ensaio sobre a Jurisdição Voluntária, 1. ed. revista e atualizada, § 20, item 1, p. 225; Edson Prata. *Jurisdição voluntária*, tit. II, item n. 6, p. 101.

62

Ali Jose Venturini Villaroel. Apunte sobre la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de

Justicia en materia de autocomposición procesal y ejecución en sede de jurisdicción voluntaria, *Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales / Academia de Ciencias Políticas y Sociales*. vol. 70, n. 141, item n. II-b, p. 217.

63

Fernando da Fonseca Gajardoni. *Flexibilização procedimental*: um novo enfoque para o estudo do procedimento em matéria processual, item n. 2.4.3.2, p. 34-41, especialmente a nota 101, na qual repete a metáfora de Carnelutti, dizendo que processo sem procedimento é a escada sem degraus.

64

Nelson Nery Junior. Intervenção do Ministério Público nos procedimentos especiais de jurisdição voluntária, *Revista de Processo*, vol. 46, p. 7-28, item n. 6 (versão eletrônica).

65

Hermes Zaneti Junior. *Processo Constitucional*: o modelo constitucional do Processo Civil brasileiro, Cap. 4, itens 4-4.3.3, p. 171-201; Felipe Camilo Dall'alba. A ampla defesa vista sob o olhar constitucional processual. *Temas atuais de Direito Público*, itens n. 2-3, p. 253-266, com especial identificação entre contraditório e ampla defesa, integrantes do devido processo legal.

66

Nelson Nery Junior. *Princípios do Processo na Constituição Federal*, 12. ed., sec. IV, item n. 24.4, p. 269-270.

67

José Joaquim Calmon de Passos. Teoria geral dos procedimentos especiais. *Procedimentos especiais cíveis, legislação extravagante*, itens 3-4, p. 2-3. E acrescenta: “Esse itinerário é essencial a todo e qualquer processo jurisdicional, seja qual for o *procedimento* que venha a ser formalizado, quer para a postulação, quer para a instrução, quer para a decisão. Ele é o núcleo rígido do que modernamente se chama de *devido processo legal*, que prefiro denominar, porque mais expressivo, a meu sentir, *devido processo constitucional de produção jurisdicional do direito*.”

68

Art. 9.º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no *caput* não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, II e III; III - à decisão prevista no art. 701.

69

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

70

Art. 5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

71

Art. 2.º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

72

Art. 7.º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz velar pelo efetivo contraditório.

73

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. La igualdad de las partes en el proceso civil, *Revista de Processo*, n. 44, itens n. 2-3, p. 177-178.

74

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de tratamento.

75

Edson Prata. *Jurisdição voluntária*, tít. XI, item n. 3, p. 26. Leonardo Greco. *Jurisdição voluntária moderna*, item n. 2.2, p. 32-34.

76

Elio Fazzalari. *Istituzioni di diritto processuale*, n. II. § 5, p. 82-83 e II. § 6.º, p. 86-87.

77

O conceito da teoria do processo é singelo, mas preciso: “autor é aquele que aduz em juízo uma pretensão (*qui res in iudicium deducit*); e réu, aquele em face de quem aquela pretensão é deduzida (*is contra quem res in iudicium deducitur*)”. Antônio Carlos de Araújo Cintra; Ada Pellegrini Grinover; Cândido Rangel Dinamarco. *Teoria Geral do Processo*, 20. ed., item n. 187, p. 295.

78

O CPC/1973 mencionava a expressão *parte* nos procedimentos de alienação judicial (art. 1.113) e nas notificações e interpelações (art. 872), antes considerados cautelares; a expressão *autor* não aparecia dentre os procedimentos de jurisdição voluntária no CPC/1973, nem mesmo no procedimento de Interdição, que agora a traz (art. 749, CPC/2015), assim como no procedimento de Ratificação dos Protestos Marítimos e dos Processos Testemunháveis Formados a Bordo (arts. 768, 768, § 1.º e 770, parágrafo único).

79

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*, Cap. XV, item n. 1, p. 698.

80

Enrico Tullio Liebman. *Manuale di Diritto Processuale Civile*, vol. 1. Item n. 1-17, p. 28.

81

Edson Prata. *Jurisdição voluntária*, tít. VIII, item n. 1, p. 185; Humberto Theodoro Júnior. *Curso de Direito Processual Civil*, 52. ed., vol. II, item n. 278, p. 475; José Manoel de Arruda Alvim Netto. *Manual de Direito Processual Civil: parte geral*, 7. ed., item n. 57, p. 221 e p. 223.

82

Eduardo J. Couture. *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*, item, n. 30, p. 48. E acrescenta: “Él no es *parte*, en sentido técnico, porque no es *contraparte* de nadie.”

83

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, Disposições Gerais, item n. 2, p. 7-11.

84

Sergio Gilberto Porto. Jurisdição voluntária: atividade administrativa ou jurisdicional, *Revista de Estudos Jurídicos*, p. 85-86.

85

José Frederico Marques. *Ensaio sobre a Jurisdição Voluntária*, 1. ed, revista e atualizada, § 20, item 2, p. 217. A opinião é baseada especialmente na posição de Gian Antonio Micheli.

86

Araken de Assis. O procedimento de dúvida e o princípio de adstrição do juiz ao pedido da parte. *Revista Jurídica*, a. XXXI, vol. 107, item n. 3, p. 37.

87

Celso Neves. *Estrutura fundamental do processo: tutela jurídica processual, ação, processo e procedimento*, item n. 87, p. 45.

88

J. Ramiro Podetti. Teoría estructural da ciencia del proceso civil, *Teoría y técnica del proceso civil y Teoría estructural de la ciencia del proceso civil*, item n. 8, p. 360, notou essa possibilidade de “duplicação de atividades” especialmente se tais atos coubessem ao Poder Executivo.

89

Antonio Carlos Marcato. *Procedimentos especiais*, 15. ed., item n. 4, p. 10.

90

Elio Fazzalari. *La giurisdizione volontaria: profilo sistematico*, cap. 2.º, § 1.º, item n. 1.5, p. 159.

91

Ali Jose Venturini Villaroel. Apunte sobre la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en materia de autocomposición procesal y ejecución en sede de jurisdicción voluntaria, *Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales / Academia de Ciencias Políticas y Sociales*. vol. 70, n. 141, cap. 1.º, item n. V, p. 210.

92

Cristina Ferraz. *Jurisdição voluntária no processo civil*, item n. 3.5.4, p. 66. Cândido Rangel Dinamarco; Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes. Teoria geral do novo processo civil, item n. 42, p. 81.

93

Glauco Gumerato Ramos. Ativismo e garantismo no processo civil: apresentação de debate, *Revista Brasileira de Direito Processual*, n. 70, p. 83-102.

94

Jefferson Carús Guedes. Direito Processual Social Atual: entre o Ativismo Judicial e o Garantismo Processual, *Revista Brasileira de Direito Processual*, n. 82, itens n. 3-4, p. 59-74.

95

Antonio do Passo Cabral. Imparcialidade e imparcialidade: por uma teoria sobre repartição e incompatibilidade de funções nos processos civil e penal. *Teoria do processo: panorama doutrinário mundial*, item n. 1, p. 99-101.

96

Cristina Ferraz. *Jurisdição voluntária no processo civil*, item n. 6.13.1, p. 219.

97

Enrico Tullio Liebman. *Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada*, 2. ed. item n. 34, p. 137 e ss. José Frederico Marques. *Ensaio sobre a Jurisdição Voluntária*, 1. ed., revista e atualizada, § 20, item 2, p. 217. Há autores que negam a existência de coisa julgada em todos os procedimentos contenciosos, ver: Sergio Gilberto Porto. *Jurisdição voluntária: atividade administrativa ou jurisdicional. Revista de Estudos Jurídicos*, p. 85-86. Antonio Carlos Marcato. *Procedimentos especiais*, 15. ed., item n. 4, p. 10.

98

José Maria Rosa Tesheiner. *Jurisdição voluntária*, 1.^a Parte, item n. 3, p. 18.

99

Fredie Didier. Editorial 23. Coisa julgada material em jurisdição voluntária, O exemplo do pedido de homologação de separação/divórcio/partilha consensual.

100

Cristina Ferraz. Reflexões sobre os novos rumos da jurisdição Voluntária, *Procedimentos especiais, tutela provisória e direito transitório*, item n. 3, p. 754.

101

Nicola Picardi. *Manuale del Processo Civile*, cap. XXV, item n. 210, p. 477.

102

“Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. (...) § 1.º Lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal.”

103

Celso Neves. Classificação das ações, *Revista da Faculdade de Direito UFPR*, vol. 18, p. 74.

104

Essa é a posição histórica de Luiz Guilherme Marinoni, identificando a existência de jurisdição sem a presença de conflito. Luiz Guilherme Marinoni. *A jurisdição no Estado Contemporâneo*. Estudos de Direito Processual Civil – Uma homenagem ao Professor Egas Moniz de Aragão.

105

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*, Cap. XV, item n. 1, p. 698. Tereza Arruda Alvim Wambier; Maria Lúcia Lins Conceição; Leonardo Ferres da Silva Ribeiro; Rogério Licastro Torres de Mello. *Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, art. 719, p. 1068.

106

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart. *Curso de Processo Civil*, vol. 1, *Teoria Geral do Processo*, Parte I, item n. 8.1, p. 142. Disso se conclui que podem haver três espécies de atividades confiadas ao juiz: as jurisdicionais com solução de conflito, as jurisdicionais sem solução de conflito e as não jurisdicionais.

107

Eduardo J. Couture. *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*, item, n. 30, p. 49. J. Ramiro Podetti. Teoría estructural da ciencia del proceso civil, *Teoría y técnica del proceso civil y Teoría estructural de la ciencia del proceso civil*, item n. 8, p. 360.

108

Humberto Theodoro Júnior. *Curso de Direito Processual Civil*, 57. ed., vol. I, item n. 72, p. 117; Flavio Luiz Yarshell. *Tutela jurisdiccional*, item n. 5.3, p. 135.

109

Lacerda Galeno. *Comentários ao Código de Processo Civil*, 5. ed., vol. VIII, t. I, item n. 6, p. 12-13 e item n. 8, p. 24.

110

Cândido Rangel Dinamarco. *Fundamentos do Processo Civil Moderno*, 3. ed., vol. I, Cap. XIII, item n. 163, p. 381-382.

111

Nicola Picardi. *Manuale del Processo Civile*, cap. XXV, item n. 210, p. 478.

112

J. Ramiro Podetti. Teoría estructural da ciencia del proceso civil, *Teoría y técnica del proceso civil y Teoría estructural de la ciencia del proceso civil*, item n. 8, p. 360. Ali Jose Venturini Villaroel. *Apunte sobre la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en materia de autocomposición procesal*

y ejecución en sede de jurisdicción voluntaria, *Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales / Academia de Ciencias Políticas y Sociales*. vol. 70, n. 141, cap. 3, item n. I, p. 218.

113

Marcos Afonso Borges. Jurisdição. *Revista da Faculdade de Direito da UFG*, item n. 1, p. 25; entre alguns outros.

114

Araken de Assis. O procedimento de dúvida e o princípio de adstrição do juiz ao pedido da parte. *Revista Jurídica*, a. XXXI, vol. 107, item n. 3, p. 37.

115

Francesco Carnelutti. *Instituciones del Derecho Procesal*, 2. ed., vol. 1, Parte 1.^a, Subtítulo 2.º, item n. 18, p. 44.

116

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart. *Curso de Processo Civil*, vol. 1; *Teoria Geral do Processo*, parte I, item n. 8.1, p. 142.

117

Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias. *Responsabilidade do Estado pela função jurisdicional*, p. 82.

118

Sergio Gilberto Porto. Jurisdição voluntária: atividade administrativa ou jurisdicional, *Revista de Estudos Jurídicos*, p. 85-86.

119

Eduardo J. Couture *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*, item, n. 30, p. 49. Assim: “se esta aparece (controvérsia) se a pretensão do peticionante se opusesse alguém que se considera lesionado por ela, o ato não jurisdicional se transforma em contencioso e, portanto, em jurisdicional”.

120

Cristina Ferraz. *Jurisdição voluntária no processo civil*, item n. 6.22.2, p. 249-250.

121

Enrico Tullio Liebman. *Manuale di Diritto Processuale Civile*. vol. 1, item n. 1-17, p. 28.

122

Nicola Picardi. *Manuale del Processo Civile*, cap. XXV, item n. 210, p. 477.

123

José Manoel de Arruda Alvim Netto. *Manual de Direito Processual Civil*: parte geral, 7. ed., item n. 57, p. 219.

124

Elio Fazzalari. *Istituzioni di diritto processuale*, 7. ed., parte 4.^a, cap. II, § 3, p. 534.

125

José Manoel de Arruda Alvim Netto. *Manual de Direito Processual Civil*: parte geral, 7. ed., item n. 57, p. 219.

126

Ana Prata. *A tutela constitucional da autonomia privada*, item n. 4.2, p. 25.

127

STJ – REsp 1.400.607, julgado por Luis Felipe Salomão, 4.^a Turma, j. 17.05.2018.

128

Moacyr Amaral Santos. *Primeiras linhas do Direito Processual Civil*, vol. 2, item n. 521, p. 288.

129

José Joaquim Calmon de Passos. *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 3, art. 331, item n. 76.8, p. 486.

130

Eduardo J. Couture. *Estudios de Derecho Procesal Civil*, t. 1, item n. 4, p. 230.

131

Idem, p. 232.

132

Alfredo de Araújo Lopes da Costa. *A Administração Pública e a ordem jurídica privada (Jurisdição Voluntária)*, item n. 122-123, p. 169, 171-174.

133

José Frederico Marques. *Ensaio sobre a Jurisdição Voluntária*, 1. ed. revista e atualizada, § 19, item n. 4, p. 222; a opinião do autor tem por base as proposições de Niceto Alcalá Zamora y Castillo. Cristina Ferraz. *Jurisdição voluntária no processo civil*, item n. 6.26, p. 258.

134

Elio Fazzalari. *La giurisdizione volontaria*: profilo sistematico, Introduzione, § 2.º, item n. 1, p. 36-37, especialmente nota n. 40. O autor cita Albert Hänel, *Die Verwaltung des Privatrechts im deutschen Staatsrecht*, I, Leipzig, 1892; e Hermann Bürckner, *Der Privatrechtsgestaltende staatsakt*; Verlag, Leipzig, 1930.

135

Jefferson Carús Guedes. Transigibilidade de interesses públicos: prevenção e abreviação de demandas da Fazenda Pública. *Advocacia de Estado*: questões institucionais para a construção de um Estado de Justiça, p. 243-272.

136

A Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais Cíveis e Criminais) excluiu a Administração Pública dos litígios solucionáveis nesses juizados; Lei 10.259/2001 (Juizados Especiais Federais) e a Lei 12.153/2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública) foram criados especialmente para a solução de conflitos envolvendo a União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

137

A Lei 9.469/1997 prevê desde a sua redação original, e de forma mais ampla por alterações posteriores, a autorização para a realização de acordos ou transações, tanto para prevenir como para terminar litígios, extrajudiciais ou judiciais.

138

A Lei 13.129/2015, que alterou a Lei 9.307/1996, estendeu a arbitragem para a “administração pública direta e indireta (...) para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis”, evidenciando a existência também de interesses disponíveis dentre os interesses públicos.

139

A Lei 13.140/2015 admite o uso da “mediação como meio de solução de controvérsias entre particulares e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública” (art. 1.º). Admitida a autocomposição

140

José Ignácio Botelho de Mesquita. *O juizado especial em face das garantias constitucionais*, Disponível em: [http://www.abdpc.org.br], itens n. 2, 11-12, nos quais afirma que: “É fundamentalmente um juiz, como se dizia dos monarcas de outrora, *a legibus solutus*. É um juiz monárquico, do qual se pode dizer, como diziam do rei as Ordenações, que ‘é lei animada sobre a terra’. É voltado para si mesmo, para aos seus próprios valores que podem, até, eventualmente, mas não necessariamente, coincidir com as exigências da coletividade.”

141

Rogério Pacheco Alves. A transação penal como ato da denominada jurisdição voluntária, *Revista da EMERJ*, vol. 4, n. 13, p. 173.

142

Luiz Guilherme Marinoni. A jurisdição no Estado Contemporâneo. Estudos de Direito Processual Civil – Uma homenagem ao Professor Egas Moniz de Aragão.

143

Ovídio Baptista da Silva; Fábio Gomes. *Teoria Geral do Processo Civil*, item n. I-A, I-B, I-C, p. 62-72. Patricia Miranda Pizzol. *A competência no processo civil*, item n. 1.2.1, p. 32-36. Eduardo Cambi. *Jurisdição civil*, cap. 1-8, p. 17-95.

144

Athos Gusmão Carneiro. *Jurisdição e competência*, item n. 2, p. 5.

145

Cândido Rangel Dinamarco. *Instituições de Direito Processual Civil*, vol. I, item n. 117, p. 305 e 306.

146

Ovídio Baptista da Silva; Fábio Gomes. *Teoria Geral do Processo Civil*, item n. IV.2, p. 75.

147

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, Disposições Gerais, item n. 2, p. 6 e 12. O autor, como em sua tradicional teoria, afirmava que na jurisdição voluntária “há a pretensão à tutela jurídica, há o direito, a pretensão e a ação de direito material e há a ‘ação’ (remédio processual)”.

148

Uziel Santana dos Santos. *Litígio e lide*: uma construção, analítico-distintiva, terminológico-conceptual e empírico-crítica, item n. 1.1, p. 32-36 “Na jurisdição voluntária, não há que se questionar o atributo da jurisdicionalidade, pois apesar de não haver Litígio, há Lide; ou seja, não há um conflito intersubjetivo de

interesses (litígio), mas há um pedido formulado contra o Estado-Juiz, isto é, um mérito (aquilo sobre o que vai se pronunciar e decidir o Estado-Juiz) e partes interessadas. Destarte, com este entendimento, saneamos a problemática dos processos onde não há Litígio entre partes.”

149

Giuseppe Chiovenda. *Instituciones de Derecho Procesal civil*, vol. I, § 2, p. 41.

150

Eduardo J. Couture. *Fundamentos del derecho procesal civil*, item n. 317, p. 484. O autor afirma que a ideia de processo é sempre teleológica, pois só se explica por ter um fim que é dirimir o conflito de interesses submetido ao órgão jurisdicional, fim que deve ser considerado como privado e público. *Fundamentos del derecho procesal civil*, item n. 90, p. 145.

151

Arruda Alvim. *Manual de Direito Processual Civil*, vol. 1, item n. 26, p. 103.

152

Antonio Carlos de Araújo Cintra; Ada Pellegrini Grinover; Cândido R. Dinamarco. *Teoria geral do processo*, n. 169, p. 235.

153

Moacyr Amaral Santos. *Primeiras linhas do direito processual civil*, vol. 2, n. 368, p. 83-84.

154

Elio Fazzalari. *Istituzioni di diritto processuale*, n. II. § 5.º, p. 82-83 e II. § 6.º, p. 86-87.

155

Felipe Camilo Dall'alba. A ampla defesa vista sob o olhar constitucional processual, *Temas atuais de Direito Público*, itens n. 2-3, p. 253-266.

156

Na hipótese remota de ocorrência de audiência ou seções de tentativa de conciliação (art. 335, inc. I) ou na também remota manifestação pelo pedido de cancelamento expresso dos interessados que frustre a possibilidade de realização da audiência (art. 335, inc. II).

157

Nelson Nery Junior. Intervenção do Ministério Público nos procedimentos especiais de jurisdição

voluntária. *Revista de Processo*, vol. 46, p. 7-28, item n. 5 (versão eletrônica); o autor insiste não haver revelia na jurisdição voluntária, posição não unânime, pois há quem atribua a ocorrência de uma “revelia atenuada”. Fabio Caldas de Araújo. *Curso de Processo Civil: Procedimentos Especiais*. t. III, parte III, cap. I, item n. 4.3, p. 465.

158

Maria Lúcia M. C. de Medeiros. *A revelia sob o aspecto da instrumentalidade*, item n. 3.6, p. 168-169. Rita Ganesini. *Revelia no processo civil brasileiro*, item n. 3.3, p. 134. Cristina Ferraz. *Jurisdição voluntária no processo civil*, item n. 6.21.4, p. 240-243. As autoras não admitem a revelia nos procedimentos de jurisdição voluntária, especialmente pela ampliação dos poderes do juiz que tem deveres probatórios.

159

A audiência ou audiências obrigatórias dos procedimentos especiais contenciosos de família (arts. 693-699) não pode ser exigida nestes procedimentos especiais de jurisdição voluntária, mormente se já há a convergência prévia e clara para a dissolução.

160

A *distribuição do ônus da prova* nos procedimentos de jurisdição voluntária se concentra sobre o autor, diante da inexistência de partes em seu sentido próprio e da inexistência, na maior parte destas modalidades, de uma contradição clara e ostensiva entre contendores.

161

No Regulamento 737/1850, norma processual comercial do Império do Brasil — 45 anos antes da Zivilprozessordnung de 1895, austríaca, já havia a possibilidade de o juiz ordenar diligências independentemente do requerimento das partes, art. 230; no CPC de 1939 destacavam-se os arts. 112 e 117, que conferiam poderes do juiz na instrução, após vários Códigos Estaduais; também presentes no art. 130 CPC/1973. Ver: Jefferson Carús Guedes. *Direito Processual Social Atual: entre o Ativismo Judicial e o Garantismo Processual*, *Revista Brasileira de Direito Processual*, n. 82, item n. 2.b, p. 51.

162

O CPC/2015 não reproduziu o teor do art. 1.107 do CPC/1973: “Os interessados podem produzir as provas destinadas a demonstrar as suas alegações; mas ao juiz é lícito investigar livremente os fatos e ordenar de ofício a realização de quaisquer provas.”

163

§ 1.º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; Sem correspondência no CPC/1973. IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar

precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. § 2.º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. § 3.º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

164

José Frederico Marques classificava em a) *atos meramente receptícios*; b) *atos de natureza certificantes*; c) *pronunciamentos judiciais* (José Frederico Marques. *Ensaio sobre a Jurisdição Voluntária*, 1. ed., revista e atualizada, § 19, item n. 4, p. 221-222). Alfredo de Araújo Lopes da Costa classificava em atos: a) *para a criação de pessoas jurídicas*; b) *para suprir ou integrar a capacidade jurídica*; c) *para a formação, documentação ou publicidade do estado já constituído*; d) *tradutores de comércio jurídico* e; e) *conciliação*. (Alfredo de Araújo Lopes da Costa. *A Administração Pública e a ordem jurídica privada (Jurisdição Voluntária)*, item n. 122-123, p. 169, 171-174). José Maria Rosa Tesheiner: a) *tutela pessoas incertas*; b) *tutela de incapazes*; c) *tutela de atos da vida privada* e; d) *tutela da prova dos fatos jurídicos*. (José Maria Rosa Tesheiner. *Jurisdição voluntária*, índice, p. 5-7, ver itens n. 3, 4, 5 e 6). Leonardo Greco, classificava os procedimentos em: a) *receptícios*; b) *probatórios*; c) *declaratórios*; d) *constitutivos*; e) *executórios* e f) *exclusivamente tutelares* (Leonardo Greco. *Jurisdição voluntária moderna*, item n. 1.7, p. 27).

165

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *O novo processo civil*, item n. 7.1.1, p. 367.

166

Piero Zaccardi. Doppio grado o doppia fase del giudizio di merito? Una scelta politica, *Studi in onore di Enrico Tullio Liebman*, vol. III.

167

Ver sobre o tema, por todos: Bruschi, *Apelação civil: teoria geral, procedimento e saneamento de vícios pelo tribunal*, itens n. 3.1-3.2, p. 87-164. Gleydson Kleber de Oliveira. *Apelação no Direito Processual Civil Brasileiro*, itens n. 3.1-3.7, p. 92-169. Flavio Chein Jorge. *Apelação cível: teoria geral e admissibilidade*, itens n. 5.1-5.2, p. 79-208.

168

Fabio Caldas de Araújo, *Curso de Processo Civil: Procedimentos Especiais*. t. III, parte III, cap. I, item n. 2, p. 461, entende que somente a jurisdição contenciosa tem acesso aos recursos extremos do STJ e STF, em vista da inexistência de causa decidida

169

Araken de Assis. *Processo Civil Brasileiro*. Parte Geral: institutos fundamentais, vol. II, t. II, § 335, itens n. 1.651-1.655, p. 1073-1078.

170

Eduardo J. Couture. *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*, item, n. 31, p. 51.

171

Ali Jose Venturini Villaroel. *Apunte sobre la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en materia de autocomposición procesal y ejecución en sede de jurisdicción voluntaria*, *Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales / Academia de Ciencias Políticas y Sociales*. vol. 70, n. 141, cap. 3, item n. II, p. 218.

172

Fabio Caldas de Araújo, *Curso de Processo Civil: Procedimentos Especiais*. t. III, parte III, cap. I, item n. 5, p. 467.

173

“Recurso extraordinário. Dúvida suscitada por Oficial do Registro de Imóveis. Jurisdição voluntária. - O processo de dúvida, de natureza puramente administrativa, não possui o caráter de causa, o que o torna insuscetível de recurso extraordinário. Recurso extraordinário não conhecido.” (RTJ 97/1250, rel. Min. Rafael Mayer)

174

Eduardo J. Couture. *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*, item, n. 31, p. 50.

175

Alfredo de Araújo Lopes da Costa. *A Administração Pública e a ordem jurídica privada (Jurisdição Voluntária)*, item n. 127, p. 159.

176

José Manoel de Arruda Alvim Netto. *Manual de Direito Processual Civil*: parte geral, 7. ed., item n. 57, p. 219.

177

Niceto Alcalá-Zamora Y Castillo. Eficacia de las providencias de la jurisdicción voluntaria, *Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México*, vol. 15, n. 45, item n. 13, p. 532-533.

178

Sobre o tema da coisa julgada, ver: Sergio Gilberto Porto. *Coisa julgada civil*, 3. ed. Eduardo Talamini. *Coisa julgada e sua revisão*.

179

Sérgio Rizzi. *Ação rescisória*, item n. 10, p. 30-31.

180

José Frederico Marques. *Ensaio sobre a Jurisdição Voluntária*, 1. ed., revista e atualizada, § 19, item n. 2, p. 217 e § 29, item 3, p. 312.

181

Cristina Ferraz. *Jurisdição voluntária no processo civil*, item n. 6.13.1, p. 219. Zaiden Garaige Neto. *Ação rescisória: o lento caminhar do direito escrito (...)*, item n. 9.2, p. 210.

182

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. XII, art. 1.109, item n. 17.2, p. 66 (admite coisa julgada e rescisória); *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. XII, art. 1.111, item n. 22-1, p. 80-81 e ss.

183

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Tratado da Ação Rescisória das sentenças e de outras decisões*, 1. ed., atualizada, § 17, item n. (i), p. 174.

184

José Carlos Barbosa Moreira. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 7. ed., vol. 5.

185

Fredie Didier Junior; Leonardo Carneiro Cunha. *Curso de Direito Processual Civil*, 13. ed., vol. 3, cap. 12, item n. 2.13, p. 437. Fredie Didier Junior; Leonardo Carneiro Cunha. Ação rescisória e a ação de invalidação de atos processuais previstas no art. 966, § 4.º, do CPC/2015, *Revista de Processo*, vol. 252, p. 231-241, itens n. 1-5 (versão eletrônica).

186

Teresa Arruda Alvim Wambier; José Miguel Garcia Medina. *O dogma da coisa julgada: hipóteses de relativização*, item n. 6.3, p. 234-239. Berenice Soubhie Nogueira Magri. *Ação Anulatória: art. 486 do CPC*, item n. 8.3, p. 186-190.

187

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. XII, art. 1.111, item n. 22.2, p. 79-81.

188

Flávio Luiz Yarshel. *Ação rescisória: juízos rescindente e rescisório*. Eduardo Talamini. *Coisa julgada e sua revisão*.

189

Eduardo J. Couture. *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*, item, n. 32, p. 53.

190

Ada Pellegrini Grinover. Deformalização do processo e deformalização das controvérsias, *Novas tendências do direito processual*, 2. ed., item n. 1.5, p. 179.

191

Fabio Caldas de Araújo, *Curso de Processo Civil: Procedimentos Especiais*. t. III, parte III, cap. I, item n. 3, p. 462-263.

192

Fernando da Fonseca Gajardoni. *Flexibilização procedimental: um novo enfoque para o estudo do procedimento em matéria processual*, itens 3 e 5, especialmente.

193

Não se pode esquecer, claro, que parte das medidas já existiam, como o dever de conciliar as partes, assim como medidas coercitivas desde a Lei de Alimentos, Lei 5.478/1968, art.19. “O juiz, para instrução da causa ou na execução da sentença ou do acordo, poderá tomar todas as providências necessárias para seu esclarecimento ou para o cumprimento do julgado ou do acordo, inclusive a decretação de prisão do devedor até 60 (sessenta) dias.”; bem como instrumentos como os arts. 273, 287 e 461, reformados, do CPC/1973.

194

Humberto Theodoro Júnior. *Curso de Direito Processual Civil*, 52. ed., vol. II, item n. 281, p. 470-480

195

; Fabio Caldas de Araújo, *Curso de Processo Civil: Procedimentos Especiais*. t. III, parte III, cap. I, item n. 4.5, p. 468-469.

196

(AgRg no Ag 1362095/SP, 4.^a Turma, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10.04.2012, *DJe* 18.04.2012).

197

Precedentes do STJ: REsp n. 77.057-SP, relator Ministro Nilson Naves, *DJ* de 25.03.1996; 25.02.1998. STJ, REsp 1431036/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3.^a Turma, *DJe* 24.04.2018.

198

Diante do requerimento e negativa ou da revogação da gratuidade de justiça, pode-se cogitar o interessado da interposição de agravo de instrumento, justificando a sua incapacidade de pagamento das despesas processuais incidentes, nos moldes do art. 101.

199

Enrico Tullio Liebman. *Manuale di Diritto Processuale Civile*. vol. 1. Item n. I-17, p. 27.

200

Eduardo J. Couture. *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*, item, n. 30, p. 49; Assim: “o ato não jurisdicional se transforma em contencioso e, portanto, em jurisdicional”.

201

Jefferson Carús Guedes. Direito Processual Social Atual: entre o Ativismo Judicial e o Garantismo Processual, *Revista Brasileira de Direito Processual*, n. 82, item n. 3.1, p. 65.

202

Montero Aroca. El proceso civil llamado “social” como instrumento de “justicia” autoritária, in: Montero Aroca (Coord.). *Proceso civil e ideología: un prefacio, una sentencia, dos cartas y quince ensayos*, item n. 10, p. 165.

203

Paulo Gustavo Gonet Branco. Em busca de um conceito fugidio: o ativismo judicial. *As novas faces do ativismo judicial*, p. 389, Também: Thiago Aguiar Pádua. A expressão “ativismo judicial”, como um “cliché constitucional”, deve ser abandonada: uma análise crítica, *Revista Brasileira de Políticas Públicas*, vol. 5, Número Especial, item n 2., p. 137-140; adverte para a inadequação desta denominação.

204

José Carlos Barbosa Moreira. A função social do processo civil moderno e o papel do juiz e das partes na direção e na instrução do processo, *Revista de Processo*, n. 37, item n. 3 (versão eletrônica). José Manoel de Arruda Alvim Netto. *Manual de Direito Processual Civil: parte geral*, 7. ed., item n. 57, p. 220.

205

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*, 2 ed., vol. X, art. 1014, item n. 5, p. 19.

206

Araken de Assis. O procedimento de dúvida e o princípio de adstrição do juiz ao pedido da parte. *Revista Jurídica*, a. XXXI, vol. 107, item n. 10 p. 41.

207

Eduardo J. Couture. *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*, item n. 30, p. 49; E “essa é uma maneira muito relativa de conhecer a verdade”, complementa.

208

No Regulamento 737/1850, norma processual comercial do Império do Brasil – 45 anos antes da Zivilprozessordnung de 1895, austríaca, já havia a possibilidade de o juiz ordenar diligências independentemente do requerimento das partes, art. 230; no CPC de 1939 destacavam-se os arts. 112 e 117, que conferiam poderes do juiz na instrução, após vários Códigos Estaduais; também presentes no art. 130 CPC/1973. Ver: Jefferson Carús Guedes. Direito Processual Social Atual: entre o Ativismo Judicial e o Garantismo Processual, *Revista Brasileira de Direito Processual*, n. 82, item n. 2.b, p. 51.

209

O CPC/2015 não reproduziu o teor do art. 1.107 do CPC/1973: “Os interessados podem produzir as provas destinadas a demonstrar as suas alegações; mas ao juiz é lícito investigar livremente os fatos e ordenar de ofício a realização de quaisquer provas.”

210

Ver também: José Carlos Barbosa Moreira. As bases do Direito Processual, *Temas de Direito Processual*, 1.^a Série, item n. 7, p. 11.

211

Enrico Tullio Liebman. *Manuale di Diritto Processuale Civile*, vol. 1. Item n. 1-17, p. 28.

212

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*, Cap. XV, item n. 1, p. 698.

213

Eduardo J. Couture. *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*, item, n. 30, p. 48. E acrescenta: “Él no es parte,

em sentido técnico, porque no es *contraparte* de nadie.”

214

Alfredo de Araújo Lopes da Costa. *A Administração Pública e a ordem jurídica privada (Jurisdição Voluntária)*, cap. VII, item n. 46, p. 85. Edson Prata. *Jurisdição voluntária*, tít. VIII, item n. 1, p. 185.

215

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, Disposições Gerais, item n. 2, p. 7-11.

216

Luiz Machado Guimarães. As três figuras do litisconsórcio, *Estudos de Direito Processual Civil*, item n. I, p. 201.

217

Augusto Tanger Jardim. Dos Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária (Comentários aos arts. 1003 a 1012), *Revista Páginas de Direito*, ano 7, n. 684, art. 1.105.

218

Ubiratan do Couto Maurício. *Assistência simples no Direito Processual Civil*, item n. 7.5.2, p. 79. Dentre os que cita como apoiadores, conta o Professor Arruda Alvim em parecer mencionado.

219

James E. Pfander; Daniel Birk. Article III Judicial Power, the adverse-party requirement, and Non-Contentious Jurisdiction, *The Yale Law Journal*, Forthcoming; Northwestern Public Law Research Paper, n. 14-13, p. 6.

220

“A decisão proferida em jurisdição voluntária viole direito subjetivo de terceiro ou dos próprios interessados (quando presente erro da estrutura procedimental adotada), pode a sentença ser revista pelo ajuizamento de demanda de jurisdição contenciosa, ainda que não padeça de nenhum vício.” (Edson Prata. A jurisdição voluntária no novo Código de Processo Civil. Juriscível do STF, a. IV, n. 38, fev. de 1976, p. 19; Wilson Gomes de Menezes. Da jurisdição voluntária. In: Revista Forense, vol. 252, a. 71, out./nov./dez, 1975, p. 129.

221

Fredie Didier Junior. *Recurso de terceiro*: juízo de admissibilidade, itens 2.2-2.4, p. 54-254.

222

Jefferson Carús Guedes. (arts. 674-686), *Comentários ao novo Código de Processo Civil*, 2. ed. Org. Antonio do Passo Cabral: Ronaldo Cramer.

223

Não o podendo fazer, deverá designar servidor que o substitua, nos termos do inciso III do art. 152, do CPC/2015.

224

Os autos só poderão deixar o cartório, caso se identifique qualquer das exceções previstas nas alíneas do inciso IV do art. 152, do CPC/2015.

225

Além das atividades descritas, ou escrivão ou chefe de secretaria, poderá realizar os atos meramente ordinatórios, de ofício, e outros determinados pelo juiz titular da vara, nos termos do inciso VI e §1.º do art. 152 do CPC/2015.

226

O Título IV da Constituição Federal, arts. 44 a 135, tratou da Organização dos Poderes, separando o Capítulo I para o Poder Legislativo; o Capítulo II para o Poder Executivo; o Capítulo III para o Poder Judiciário; e isolando desses três capítulos as Funções Essenciais à Justiça, reunidas no Capítulo IV. De forma pedagógica dividiu em três seções, destinando: a Seção I ao Ministério Público; a Seção II à Advocacia Pública (antes EC 19/1998 era AGU); a Seção III à Advocacia (Privada) e à Defensoria Pública.

227

Esses órgãos foram também denominados *Funções Essenciais ao Funcionamento dos Poderes*, durante a Assembleia Constituinte, nos textos prévios ao texto final da Constituição de 1988. Ver: Jefferson Carús Guedes; Mauro Luciano Hauschild; Alexandre Bernardino Costa; et alli., *Nos Limites da história: a construção da Advocacia-Geral da União*, item n. 2, p. 35.

228

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

229

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. XVI, art. 1.105, item n. 1, p. 19. O art. 721 do CPC/2015 trata de intimação do Ministério Público e não mais de citação, como o art. 1.105 do CPC/1973, que tratava de citação.

230

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. XII, art. 1.105, item n. 6.1, p. 46.

231

Alfredo de Araújo Lopes da Costa. *A Administração Pública e a ordem jurídica privada (Jurisdição Voluntária)*, cap. VI, item n. 424, p. 80-82.

232

José Frederico Marques. *Ensaio sobre a Jurisdição Voluntária*, 1. ed., revista e atualizada, § 8.º, item n. 3, p. 105. Também: Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. XII, art. 1.105, item n. 5, p. 46 e item n. 7, p. 47-48.

233

Edson Prata. *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 7, art. 1.105, item n. 1, p. 22. Edson Prata. *Jurisdição voluntária*, tít. VI, item n. 12, p. 176.

234

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. XII, art. 1.105, item n. 4.1, p. 43.

235

Nelson Nery Junior. Intervenção do Ministério Público nos procedimentos especiais de jurisdição voluntária. *Revista de Processo*, vol. 46, p. 7-28, item n. 3 (versão eletrônica).

236

Marcelo Zenkner. *Ministério Público e efetividade do processo civil*, item n. 3.2.4, p. 172.

237

Fernando Antônio Negreiros Lima. *Intervenção do Ministério Público no processo civil brasileiro como custos legis*, item n. 5.3.4, p. 164.

238

Art. 745. (...) § 4.º Regressando o ausente ou algum de seus descendentes ou ascendentes para requerer ao juiz a entrega de bens, serão citados para contestar o pedido os sucessores provisórios ou definitivos, o Ministério Público e o representante da Fazenda Pública, seguindo-se o procedimento comum.

239

Art. 748. O Ministério Público só promoverá interdição em caso de doença mental grave: I - se as pessoas

designadas nos incisos I, II e III do art. 747 não existirem ou não promoverem a interdição; II - se, existindo, forem incapazes as pessoas mencionadas nos incisos I e II do art. 747.

240

Art. 761. Incumbe ao Ministério Público ou a quem tenha legítimo interesse requerer, nos casos previstos em lei, a remoção do tutor ou do curador. Parágrafo único. O tutor ou o curador será citado para contestar a arguição no prazo de 5 (cinco) dias, findo o qual observar-se-á o procedimento comum.

241

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*, art. 764, item n. 6, p. 732; art. 765, item n. 1, p. 733.

242

Art. 55. (...). Parágrafo único - Valerá como título executivo extrajudicial o acordo celebrado pelas partes, por instrumento escrito, referendado pelo órgão competente do Ministério Público.

243

Paulo Salvador Frontini. O Ministério Público no Juizado Espacial das Pequenas Causas, *Juizado especial de pequenas causas (Lei n. 7.244, de 7 de novembro de 1984)*, item n. 19, p. 193, onde identifica, desde a década de 1940, os antecedentes desta função e atividade homologatória de acordos.

244

Art. 57. (...) Parágrafo único. Valerá como título extrajudicial o acordo celebrado pelas partes, por instrumento escrito, referendado pelo órgão competente do Ministério Público.

245

REsp 1418189/RJ, 3.^a Turma rel. Min. Sidney Beneti, j. 10.06.2014, *DJe* 01.07.2014. (...) 5.- “O Ministério Público Estadual é legitimado a, diante da impossibilidade de interpor Recurso Especial, à impetração de Mandado de Segurança, em legitimação extraordinária, para defesa, no interesse da sociedade e da preservação da regularidade registral imobiliária (...)”.

246

A Constituição Federal de 1988, pela Emenda Constitucional n. 80/2014, assim define: Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5.^o desta Constituição Federal.

247

Lei Complementar n. 80/1994 (redação dada pela Lei Complementar 132/2009), que organiza a Defensoria-Geral da União, e estabelece no art. 4.º, inc. XI que é dever institucional “exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades especiais, da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado”.

248

Cleber Francisco Alves. *A justiça para todos: assistência judiciária gratuita nos Estados Unidos, França e Brasil*, item 5.3.2, p, 273-277.

249

Glauco Gumerato Ramos. Realidade e perspectivas da assistência judiciária aos necessitados no Brasil. Cadernos Adenauer 3: *Acesso à Justiça e cidadania* p. 31 e ss.

250

A Advocacia Pública vem assim definida, após a Emenda Constitucional 19/1998: Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

251

Leonardo Carneiro da Cunha. *A Fazenda Pública em juízo*, 13. ed., item n. I.1.1, p. 5-6.

252

Há, ainda, as hipóteses de algumas ações trabalhistas e o procedimento especial criminal de *Habeas Corpus*, que permitem a atuação desacompanhada da parte, sem defesa técnica ou advogado.

253

Caroline Angélica Rabêlo de Souza. Simplificação dos procedimentos de jurisdição voluntária: Inexigibilidade de advogado, *Revista do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região*, vol. 19, n. 8, p. 82. A autora propõe permissão à autodefesa processual, sem advogado, na jurisdição voluntária em geral.

254

Ali Jose Venturini Villarroel. *Apunte sobre la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en materia de autocomposición procesal y ejecución en sede de jurisdicción voluntaria*, *Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales / Academia de Ciencias Políticas y Sociales*. vol. 70, n. 141, cap. 3, item n. II, p. 207.

255

Nicola Picardi. *Manuale del Processo Civile*, cap. XXV, item n. 210, p. 477.

256

Jesús María Gonzalez Garcia. *La proliferación de procesos civiles*, item n. 2, p. 12-17.

257

Adroaldo Furtado Fabrício. *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. VIII, t. III, *Dos procedimentos especiais*, item 3, p. 4; observando os procedimentos contenciosos, observação integralmente válida para os não contenciosos.

258

Jesús María Gonzalez Garcia. *La proliferación de procesos civiles*, item n. 1, p. 1.

259

Moacyr Amaral Santos. *Primeiras Linhas do Processo Civil*, vol. 2, item, n. 373, p. 89. “O ideal seria que aos processos de conhecimento, quaisquer que fossem, se desse um único rito. Entretanto, atendendo a certas peculiaridades de algumas relações jurídicas, os processos que as têm por objeto exigem procedimentos especiais.”

260

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart. *Curso de Processo Civil*, vol. 1, *Teoria Geral do Processo*, Parte I, item n. 8.1, p. 141.

261

Eduardo J. Couture. *Fundamentos del Derecho Procesal*, item n. 29, p. 45-46.

262

José Maria Rosa Tesheiner. *Jurisdição voluntária*, p. 5-7.

263

José Frederico Marques. *Ensaio sobre a Jurisdição Voluntária*, 1. ed., revista e atualizada, § 20-25, p. 225-268.

264

José Frederico Marques. *Ensaio sobre a Jurisdição Voluntária*, 1. ed., revista e atualizada, § 28, itens 11-12, p. 300.

Art.21. Aos Juizes de Direito do Commercio (art. 6.º) competem sem recurso as attribuições seguintes: § 1.º Presidir á nomeação do novo caixa ou gerente das sociedades commerciaes no caso de que trata o art. 309 do Codigo. § 2.º Presidir á nomeação da administração commercial, quando algum negociante que não tenha socios, ou mesmo alguém que não seja commerciante, falleça sem testamento nem herdeiros presentes, e tenha credores commerciantes (art. 310 Codigo). A administração que os credores commerciautes podem requerer e nomear no caso deste paragrapho, sómente tem lugar: N.º 1. Quando não ha testamento; N.º 2. Quando os herdeiros ausentes não têm procurador; N.º 3. Sendo os credores commerciantes matriculados; N.º 4. Sendo a divida commercia, correspondente á metade de todos os creditos, liquida, e constante de titulos authenticos. O sequestro compete ao Juizo de Ausentes, cuja jurisdição cessará logo que se verificarem os requisitos mencionados. § 3.º Processar e julgar a justificação que o capitão do navio deve fazer para tomar dinheiro a risco, e vender mercadoria da carga (arts. 515 e 516 Codigo). § 4.º Nomear depositario para receber os generos, e pagar os fretes devidos quando está ausente o consignatnrio, ou se não apresenta o portador do conhecimento á ordem (art. 528 Codigo). § 5.º Providenciar no caso de naufragio sobre a salvação da gente, navio e carga, e proceder ao inventario, guarda ou venda dos objectos salvados no caso de faltar o capitão ou não apparecer o dono, consignatario ou alguém por elles (art. 732 Codigo). § 6º Autorizar a descarga do navio arribado (art. 746 Codigo). § 7º Abrir, encerrar, numerar e rubricar os livros de apontamentos e protestos de letras (arts. 408 e 410 Codigo). § 8º Proceder aos exames, diligencias, arbitramentos e vistorias no caso de avarias grossas, e dar providencias sobre os effeitos avariados (arts. 772 e seguintes Codigo). § 9º Convocar e ouvir os credores sobre a moratoria (arts. 899 e 900 Codigo). Art. 22. Aos mesmos Juizes competem, nas Provincias em que houver Tribunal do Commercio, e nos termos que ficarem longe ou fóra da residencia delle, as attribuições dos arts. 87, 347 e 463 do Código, e todas as diligencias que os mesmos Tribunaes lhes incumbirem.

Amauri Mascaro Nascimento. *Curso de Direito do Trabalho*, § 99, item n. 1, p. 1412.

TST - Subseção I - Dissídios Individuais. E-RR - 7000-10.2006.5.10.0011. Red. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, j. 26.09.2013, *DEJT*, 18.09.2015.

,José Frederico Marques. *Ensaio sobre a Jurisdição Voluntária*, 1. ed., revista e atualizada, § 23, itens 1-3, p. 248-257. Luiz R. Nuñez Padilla. Chiovenda, jurisdição voluntária e processo penal. *Trabalho e Processo*, São Paulo. n. 7. p. 132-9. dez. 1995.

Rogério Pacheco Alves. A transação penal como ato da denominada jurisdição voluntária, *Revista da EMERJ*, vol. 4, n. 13.

Fernando Luso Soares. *O processo penal como jurisdição voluntária*: uma introdução crítica ao processo penal, cap. III, item n. 2, p. 51.

Afrânio Silva Jardim. Poder Judiciário não deve ser refém de acordos de delação premiada do Ministério Público, *Revista Consultor Jurídico*, 18.10.2015, “2.8. A decisão de homologação do acordo de cooperação premiada tem a natureza de jurisdição voluntária, vale dizer, trata-se de uma decisão judicial (não jurisdicional) que a lei exige para a concretização e eficácia de um determinado negócio jurídico. Aqui, não temos pretensão (no sentido técnico, Carnelutti) e muito menos lide (não há como resistir ao que não existe, pretensão). Assim, a retratação prevista no parágrafo 10 do sempre referido artigo 4.º só terá eficácia se manifestada antes da homologação. O desfazimento do acordo homologado dependerá sempre de uma decisão judicial desconstitutiva.”

Capítulo XV. Dos Procedimentos de Jurisdição Voluntária

Seção I

Disposições gerais

1. Inovações do CPC/2015 na Seção

Não inova o CPC/2015 ao tratar da jurisdição voluntária em um domínio específico. O que aqui se faz na nova lei processual civil é manter o espaço próprio para esta espécie de jurisdição que já estava razoavelmente ordenado no CPC/1939 e fora melhor ordenado sob título específico pelo CPC/1973, fato que rendeu ao autor do Anteprojeto de 1964 o elogio de "inovador", ¹ pois até então, tanto no CPC/1939 como em seus antecessores estaduais, não havia essa forma concentrada e distintiva de reunião em um só título ou capítulo dos procedimentos desta espécie de atividade jurisdicional.

Não inova tampouco o CPC/2015 na estrutura de suas *Disposições Gerais*. Manteve a mesma ordem do CPC/1973, suprimindo apenas a indicação de *especiais* dos procedimentos, mas preservando a quantidade e o conteúdo próximo de dispositivos que tratam desta parte inicial do *Capítulo*. Nas seções seguintes há algumas inovações de extensão, por transposição ou pela reintrodução de procedimentos previstos em 1939. ²

Todos os dispositivos desta seção inicial possuem conteúdo equivalente, senão idêntico, merecendo destaque apenas o art. 725 que amplia o rol de procedimentos não descritos como típicos e codificados de jurisdição voluntária (art. 726 ao art. 770) para incluir, por exemplo, a expedição de alvará judicial e a homologação de autocomposição, agora reconhecidos como procedimentos que devem também seguir a jurisdição voluntária.

O rol do art. 725 (correspondente ao art. 1112 do CPC/1973) sempre foi considerado exemplificativo por grande parte da doutrina, motivo pelo qual os acréscimos feitos pelo CPC/2015 atendem às tendências doutrinárias e jurisprudenciais, bem como as necessidades fático-jurídicas já constatadas no Direito brasileiro. Nesse sentido dá-se especial destaque ao disposto no inc. VIII do art. 725, porquanto trata-se de pedido que, desde sempre, nada possui de contencioso e ainda assim não estava expressamente previsto no CPC/1973.

2. Aspectos materiais da Seção das Disposições Gerais

Como visto anteriormente, as classificações doutrinárias indicam um extenso conteúdo material que pode estar contido nos procedimentos de jurisdição voluntária. São inúmeras as hipóteses em que se pode demandar em juízo pretensões não contenciosas.

Nesse sentido, Eduardo J. Couture afirmava que sob essa denominação está abrigada uma vasta diversidade de previsões e a partir do conteúdo material podem ser divididas em: *medidas de publicidade; atos judiciais de homologação; autorização para a realização de ato; produção de provas; liquidação judicial de impostos; tutela de menores, ausentes e incapazes; intimações e protestos; e administração judicial*. ³

José Frederico Marques inclina-se pela classificação de Giovanni Cristofolini, que identifica três categorias desses procedimentos, são elas: a) atos meramente receptícios, nos quais a atuação do juiz é passiva, como na homologação de emancipações; b) atos de natureza certificantes, como legalização de livros comerciais; c) pronunciamentos judiciais, como nas homologações, conciliação e autorização. ⁴

Alfredo de Araújo Lopes da Costa, ainda na vigência do CPC/1939, considerava a jurisdição voluntária espécie jurisdicional da administração da justiça, na qual estaria contida uma “imensa variedade” de atos. Disso resultava uma diversidade de critérios classificatórios baseados na finalidade, na maior ou menor influência do ato administrativo e na discricionariedade ou não do ato público surgia. Com amparo em Adolf Wach e Giuseppe Chiovenda, Costa classificava tais procedimentos, segundo a finalidade, da seguinte forma: a) *para a criação de pessoas jurídicas* ; b) *para suprir ou integrar a capacidade jurídica* ; c) *para a formação, documentação ou publicidade do estado já constituído* ; d) *tradutores de comércio jurídico* e; e) conciliação.⁵

Para José Maria Rosa Tesheiner, referindo-se ao CPC/1973, a matéria estava distribuída, segundo critérios materiais, entre: a) tutela de *pessoas incertas* ; b) tutela de *incapazes* ; c) tutela de *atos da vida privada* e; d) tutela da *prova dos fatos jurídicos* . Desse modo indicava os mais variáveis conteúdos⁶ , mas sem considerar as notificações e interpelações agora transportadas dos procedimentos cautelares para a jurisdição voluntária.

Leonardo Greco, também em análise ao CPC/1973, classifica os procedimentos em cinco grupos distintos, são eles: a) *receptícios* ; b) *probatórios* ; c) *declaratórios* ; d) *constitutivos* ; e) *executórios* e; f) *exclusivamente tutelares* .⁷ Trata-se, pelo que se pode auferir, de classificação lastreada na finalidade da medida que se pretende obter em juízo.

Todas essas classificações, porque transcendem a vigência das normas e partem sempre de parâmetros distintos de análise – ora baseados em critérios materiais, ora processuais – podem ser transpostas e atualizadas para o CPC/2015 sem maiores problemas.

3. Aspectos processuais e procedimentais gerais da Seção

Segundo interpretação da doutrina, identificam-se “três ordens distintas de normas procedimentais” que regem a Jurisdição Voluntária, todas presentes tanto no CPC/1973 como no CPC/2015. Tais ordens possuem uma relação de generalidade e especialidade, razão pela qual enfraquecem ou ganham força, a depender da categoria de procedimentos especiais que influenciam.

Como resultado material dessa distinção, certos ônus interpretativos surgem, alguns já resolvidos com o amadurecimento da doutrina e da jurisprudência e outros que ainda advirão à medida em que o CPC/2015 for sendo aplicado na regência do processo civil brasileiro. É o que se verá adiante.

Art. 719 . Quando este Código não estabelecer procedimento especial, regem os procedimentos de jurisdição voluntária as disposições constantes desta Seção.

1. Inovações do CPC/2015

Pequenas foram as alterações de redação no CPC/2015, quanto ao dispositivo inicial que trata da regra geral de regência dos procedimentos especiais de jurisdição voluntária. A rigor, em relação ao artigo correspondente, qual seja, o art. 1.103 do CPC/1973, só houve o acréscimo da expressão *procedimentos* antecedendo à expressão ‘jurisdição voluntária’. Mantém-se intacto o conteúdo e a finalidade da regra anterior.

Desse modo, a lei manteve-se silente quanto ao conceito de jurisdição voluntária, ao contrário de outros institutos processuais que são definidos no próprio texto legal. Esse silêncio voluntário se deve à complexidade da questão, que envolve séria divergência doutrinária, hoje menos disputada, mas ainda sem solução e sem vitoriosos.

A redação mantida quase integralmente no CPC/2015 sempre sofreu críticas, desde os primeiros comentários ao CPC/1973, por ser ‘equivoca’. Isso porque sua leitura dá a impressão de que as disposições gerais hoje, contidas nos arts. 720-724 (arts. 1.104-1.111 do CPC/1973) serviram apenas para regulamentar os procedimentos nominados no art. 725 (art. 1.112 do CPC/1973). Contudo, a jurisdição voluntária e todos os seus procedimentos estavam e permanecem submetidos a três ordens distintas de normas procedimentais, são elas: a) as gerais do CPC, notadamente do processo de conhecimento; b) as normas gerais contidas nas Disposições Gerais da Seção I da Jurisdição voluntária e; c) as normas próprias de cada procedimento especial de Jurisdição Voluntária que contenha disciplina específica.⁸

O legislador deixou clara essa submissão geral da jurisdição voluntária às normas do Livro I da Parte Especial do CPC/2015, conforme se extrai do parágrafo único do art. 318, pelo qual previu que o

procedimento comum fosse subsidiariamente aplicado aos procedimentos especiais (dentre os quais se inserem os de jurisdição contenciosa e voluntária) e ao processo de execução.

1.1 Ação e processo em procedimentos de jurisdição voluntária

Ainda que não se identifique lesão, Pontes de Miranda afirma que há ação e processo⁹. Há inclusive variáveis intensidades conflitivas, desde um nível mínimo onde não se deflui nenhuma diversidade de interesses, podendo as partes integrarem os atos iniciais postulatórios em petição conjunta (separação consensual, divórcio consensual, alteração do regime de bens), a algumas de média e até alta contenciosidade (remoção de tutor, extinção de fundações).¹⁰

Arruda Alvim discorda desse posicionamento, negando a presença de processo, de contenciosidade e de pretensão e, por consequência, afirma que inexistem partes.¹¹

1.2 As espécies de procedimentos especiais de jurisdição voluntária

Seria desnecessário dizer que a jurisdição voluntária se submete às regras da Parte Geral do CPC/2015 (arts. 1.º-317), assim como se submete, do mesmo modo, às normas do Livro I da Parte Especial do CPC/2015 (arts. 318-538), notadamente as do *Processo de Conhecimento*, Livros II (Execução) e III (Recursos e ações) da Parte Especial.

Contudo, vale observar que há três categorias de procedimentos especiais de jurisdição voluntária no CPC/2015, quais sejam: a) os específicos dos arts. 726 ao 770; b) aqueles previstos no rol não taxativo do art. 725 e; c) os esparsos contidos em leis especiais. Resta, contudo, estabelecer o modo como cada uma daquelas “ordens distintas de normas procedimentais” se aplica a cada uma dessas três categorias.

De início, já é claro que a disciplina dos arts. 1.º ao 317 (Parte Geral), dos arts. 318 ao 538 (Parte Especial – regras do procedimento comum), dos arts. 771 ao 928 (processo de execução) e dos arts. 929 ao 993 aplicam-se às três categorias procedimentais acima descritas, mas em escala menor quando os procedimentos típicos do CPC/2015 (arts. 726 a 770) contiverem regras específicas distintas.¹²

Já as normas nas Disposições Gerais da Seção I da Jurisdição Voluntária (arts. 719 a 724), aplicam-se aos procedimentos típicos, conforme o parágrafo único do art. 725, bem como aos procedimentos do art. 725 por “não estabelecer procedimento especial”, conforme estabelece o art. 719. Contudo, são aplicadas apenas subsidiariamente, no que couber, aos procedimentos esparsos de leis especiais integrantes da jurisdição civil, porquanto estes possuem regramento próprio em sua lei de regência.

Por fim, os regramentos específicos, logicamente, têm sua aplicação restrita aos procedimentos de que tratam detidamente.

2. Aspectos materiais

O conteúdo material do dispositivo já foi descrito anteriormente (Seção I, item n. 2). Possui estreita relação com todos os demais dispositivos do Capítulo XV, especialmente com o art. 725, que enumera outros procedimentos que também são de jurisdição voluntária.

A amplitude do art. 719 induz ao entendimento de que podem ser processados pela jurisdição voluntária quaisquer pedidos que não estejam listados (art. 725) ou previstos taxativamente (arts. 726 a 770). Sobre isso a jurisprudência já divergiu, ora entendendo que se pode processar pedido que não venha indicado expressamente na lei, ora reconhecendo a taxatividade de suas hipóteses de cabimento.

Todavia, visto o procedimento como instrumental, não se pode negar tratar-se de lista aberta que, como tal, pode ser complementada. Mesmo assim há consistente divergência doutrinária sobre o tema.

Ainda na vigência do CPC/1973, Edson Prata considerava *taxativa* ou *fechada* a relação de procedimentos prevista no revogado art. 1.112, que corresponde ao art. 725 do CPC/2015.¹³ Por outro lado, Pontes de Miranda, José Olympio de Castro Filho e Nelson Nery Junior consideravam não-taxativo ou aberto o rol daquele artigo.¹⁴

Sendo aberto o rol do art. 725 e contrastando-se as inovações do CPC/2015 com as disposições do CC/2002 (art. 840-850), admite-se, por exemplo, a existência de um direito material à transação. Sob a vigência do CPC/1973 não estava prevista expressamente a realização processual desse direito mediante

procedimento não-contencioso. Somente a partir da nova lei é que a homologação de autocomposição extrajudicial passou a ser especificamente admitida em juízo, sob o pálio da jurisdição voluntária (art. 725, inc. VIII).

Nessa ordem de ideias, tem-se que a voluntariedade da homologação de autocomposição extrajudicial não surgiu com a entrada em vigor do CPC/2015 e sua inclusão no rol do art. 725, mas já encontrava respaldo mesmo sob a égide do CPC/1973. Logo, ante a não taxatividade da norma, era defeso ao Estado-juiz negar prestação jurisdicional a pleito dessa natureza.

3. Aspectos processuais e procedimentais

A discussão sobre a taxatividade ou não da lista dos procedimentos especiais de jurisdição voluntária indicados no art. 725 ¹⁵ ganha mais importância à medida em que a atividade judiciária se expande, absorvendo outras tantas questões da vida privada. Por certo as listas são abertas, não comportando a exclusividade e o fechamento típicos de matérias recursal, tributária, penal, sancionatória etc. Sequer a definição daqueles procedimentos descritos nos arts. 726 a 770 do CPC/2015 é exclusiva, na medida em que leis esparsas também descrevem procedimentos especiais de jurisdição voluntária.

Embora grande parte das hipóteses legais alberguem as situações mais comuns, entende-se que a lista de procedimentos especiais indicados no art. 725 (art. 1.112 do CPC/1973) e arts. 726 a 770 não pode ser considerada taxativa, pois há procedimentos típicos de jurisdição voluntária a que o Código não faz referência, assim como: a) outorga judicial de consentimento; b) homologação de casamento nuncupativo (art. 1.540 do CC); c) permissão para casamento de colaterais, legítimos ou ilegítimos, de terceiro grau (Decreto-lei 3.200/1941, arts. 1.º a 3.º), algo de preparatório para habilitação de casamento e outros mais que, inclusive, estão previstos e descritos na legislação especial. ¹⁶

José Olympio de Castro Filho, ao tratar do tema, afirma que a enumeração constante do art. 1.112 não é taxativa, mas exemplificativa, ¹⁷ de forma que os demais pedidos, desde que tradicionalmente ou por suas características se incluam na denominada jurisdição voluntária, estarão submetidos a regra geral do art. 719 (antigo art. 1.103 do CPC/1973), não existindo qualquer razão para que deixem de ser processados como tal e muito menos para que se submetam ao procedimento comum.

O parágrafo único do art. 725 ¹⁸ e o art. 719 ¹⁹ atendem à regra de primazia da lei especial sobre a lei geral. Entendido esse último dispositivo como uma regra geral, os arts. 720 a 724 terão aplicação subsidiária ou secundária nos procedimentos típicos (arts. 726 a 770). Lido em senso contrário, aplica-se o art. 719 de forma integral nas hipóteses em que não há um procedimento especial típico descrito (art. 726 ao art. 770), admitindo-se um procedimento geral ou atípico.

Se há pelo menos três ordens normativas a reger a jurisdição voluntária, a relação entre elas deve observar as regras da Teoria Geral do Direito, de modo que a regra especial prepondere sobre a geral.

4. Atos processuais e negócios processuais

Não se pode excluir da jurisdição voluntária a possibilidade de realização de “negócios processuais” e a “calendarização” admitidas pelos arts. 190 ²⁰ e 191 ²¹ do CPC/2015. A primeira razão é a possibilidade de admitir-se a autocomposição em diversas matérias afetas à jurisdição voluntária. A segunda é a possibilidade de realização de negócios processuais em parte das regras processuais e procedimentais da jurisdição voluntária. ²²

Nem mesmo o art. 723, parágrafo único, segundo o qual o juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar, em cada caso, a solução que considerar mais conveniente ou oportuna, afasta a aplicabilidade dos negócios processuais nos procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Exemplos concretos são a abertura de testamento cerrado e outros (arts. 735-737), os quais serão detidamente estudados mais adiante. ²³

Art. 720 . O procedimento terá início por provocação do interessado, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, cabendo-lhes formular o pedido devidamente instruído com os documentos necessários e com a indicação da providência judicial.

1. Inovações do CPC/2015

Desde o CPC/1973 considerava-se a iniciativa para o processo como ato do interessado ou de seus

representantes e legitimados extraordinários para defesa, ao contrário das concepções anteriores, que viam na “instauração de um processo *ex officio* (...) sinal infalível da jurisdição voluntária”.²⁴

Duas inovações são trazidas pelo CPC/2015: a *primeira* ao atribuir à Defensoria Pública a legitimidade ativa para proposição dos pedidos de jurisdição voluntária, direcionada ao seu público-alvo, ou seja, aos necessitados hipossuficientes (CF, art. 134) e; a *segunda* ao suprimir a expressão “em requerimento dirigido ao juiz”, que continha certa obviedade, porquanto o destinatário do pedido em juízo é, evidentemente, o juiz. Este segundo ponto, relacionado à supressão do trecho considerado repetitivo, é suplementado pelos arts. 319 e 320 do CPC/2015, que indicam os requisitos da petição inicial. O inc. I do art. 319 define a quem deve ser dirigida a inicial – ao juízo – em qualquer espécie de processo, seja na jurisdição contenciosa ou voluntária.

2. Aspectos materiais

Já foi dito que a atividade do Ministério Público, no modelo brasileiro atual, tem mais amplitude que nos demais países de tradição romano-germânica, e relevo maior que as demais instituições e órgãos denominados como Funções Essenciais à Justiça pela Constituição de 1988 (arts. 127 e ss.) com destaque entre suas funções a incumbência da “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”.²⁵ A Lei Complementar 75/1993 reprisa esta mesma incumbência geral (art. 1.º).

Também o CPC/2015 estabelece as hipóteses de atuação (arts. 176-181), especialmente, na defesa de interesse público e social (art. 178, inc. I), defesa de interesse de incapaz (art. 178, inc. II), seja no exercício do direito de ação, como parte, em representação, em conformidade com suas atribuições constitucionais (art. 177) ou como fiscal da ordem jurídica (art. 178).

O Ministério Público não é terceiro, é parte ou fiscal da ordem jurídica.

A participação ou a intervenção do Ministério Público na jurisdição voluntária tem sido intensamente debatida, ora vinculada à presença de interesses que mereçam a sua proteção, ora mais estendida.

Alfredo de Araújo Lopes da Costa que afirmava ser o Ministério Público função acessória, mas indispensável ao Poder Judiciário, não age na jurisdição voluntária para manter o império da lei, e, sim, sob a inspiração da oportunidade e conveniência, princípios comuns à Administração Pública e à jurisdição voluntária.²⁶ José Frederico Marques afirma que o papel do Ministério Público é de fiscalização da atuação dos interessados, promovente e promovido, e do juiz, sendo nulo processo se ausente.²⁷

A doutrina define essa razão, pois “(...) tão-somente por se tratar de um feito de procedimento de jurisdição voluntária – sem que estejam presentes hipóteses previstas (...) – não há motivo suficiente a reclamar a nobre intervenção ministerial”.²⁸

De uma forma ou de outra, fato é que o art. 720 traz a possibilidade de participação do Ministério Público como agente provocador da jurisdição, que, nesse caso específico, atua como substituto processual. Aqui o ente ministerial ingressa em juízo como parte, pleiteando em nome próprio direito alheio. O interesse a ser tutelado pela instituição tem natureza coletiva, assim definida e classificada no parágrafo único do art. 81 do CDC.²⁹

3. Aspectos processuais e procedimentais

O item n. 3 tratará de legitimação ativa e princípio da demanda, da iniciativa do Ministério Público e da representação dos hipossuficientes pela Defensoria Pública. Tratará ainda da petição inicial, dos documentos necessários à propositura da demanda, do princípio dispositivo, da iniciativa do juiz, entre outras questões pertinentes ao trâmite processual.

3.1 Legitimação ativa e princípio da demanda

Essa matéria se desdobra em duas partes: a) a *legitimidade ad causam*, que se relaciona com o interesse de agir; b) a *legitimidade ad processum*, que se relaciona com a representação para se estar em juízo.³⁰ Para que a parte possa ser considerada legítima, ela deve preencher estes dois requisitos.

A legitimidade *ad causam*, na técnica processual, consiste na verificação da existência de necessidade

ou utilidade daquele agente em buscar o judiciário.³¹ Assim, o legitimado deve demonstrar que a providência perquirida se faz necessária ou que lhe será útil, ônus que incumbe, inclusive, ao Ministério Público.³²

Já a legitimação *ad processum* é a capacidade do interessado de representar em juízo. Tome-se como exemplo o incapaz, que, como tal, não pode demandar sozinho em nome próprio, devendo, para tanto, estar representado por um de seus genitores ou por tutor/curador regularmente nomeado. O mesmo ocorre com as pessoas jurídicas, as quais devem ser representantes em juízo pela pessoa natural indicada em seu ato constitutivo.³³

Dessa forma, aquele que requer, por exemplo, a alienação judicial de um imóvel deve demonstrar ser o proprietário do bem ou o representante legal daquele, sob pena de indeferimento da inicial por falta de legitimidade da parte. De igual modo, deverá demonstrar que a tutela pretendida é necessária ou útil, caso contrário seu pleito será prontamente indeferido por falta de interesse de agir.

Conforme dispõe a primeira parte do art. 720, os legitimados ativos para a propositura de procedimentos de jurisdição voluntária (desde que preencham os requisitos anteriormente apontados) são o interessado, o Ministério Público ou a Defensoria Pública. Essa previsão legal atende, perfeitamente, a exigência do art. 2.º,³⁴ o qual determina que o juiz só agirá quando provocado. Assim, via de regra, a iniciativa caberá apenas ao interessado e, por exceção (legitimação extraordinária), ao Ministério Público ou à Defensoria Pública.

Entretanto, em razão de sua estrutura e finalidade, o princípio da demanda é mitigado na jurisdição voluntária,³⁵ de forma que, em alguns casos, a prestação jurisdicional será requerida de ofício pelo juiz.³⁶ Como exemplo, pode-se citar o art. 730 (art. 1.113 do CPC/1973), que autoriza o magistrado, quando não houver acordo entre os interessados sobre o modo como se deve realizar a alienação de bens de fácil deterioração, avariados ou que exigem grandes despesas para sua guarda, aliená-los de ofício em leilão público. Outras hipóteses em que o juiz poderá atuar de ofício estão previstas no art. 738 (art. 1.142 do CPC/1973), no art. 744 (art. 1.160 do CPC/1973), no art. 746, § 2.º (art. 1.171 do CPC/1973), dentre muitas outras.

Dessa forma, embora o princípio da demanda vincule o direito de ação ou, no caso, de “provocação” aqueles indicados no art. 730, há na jurisdição voluntária a possibilidade de que o procedimento seja iniciado *ex officio*, sobretudo, em razão da necessidade urgente de se resguardar determinados direitos ou interesses, que exorbitam a esfera privada e atingem a ordem pública.³⁷

Feitas essas considerações iniciais quanto à legitimidade ativa, bem como sobre a mitigação do princípio da demanda, passa-se à análise individualizada de cada um dos legitimados ativos.

3.1.1 Iniciativa do interessado e princípio da demanda

A iniciativa do interessado é a força motriz do procedimento, porquanto dispõe o art. 2.º do CPC/2015 que “o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. É o que preceitua o princípio da demanda.

Referido princípio, contudo, tem aplicação mitigada na jurisdição voluntária. Assim diz Nelson Nery Junior que “aqui não há lugar para aplicação ampla do princípio da demanda, nem para o princípio dispositivo, podendo ser iniciado o procedimento a requerimento da parte, do Ministério Público ou mesmo *ex officio*”, bem como da Defensoria Pública.³⁸ Araken de Assis, ao afirmar que o juiz na jurisdição voluntária está adstrito ao pedido da parte,³⁹ e também, pode-se dizer, ao princípio da demanda.

O interessado é o titular do direito que se pretende tutelar por meio do procedimento. É aquele diretamente vinculado à natureza da ação e às regras jurídicas atinentes ao direito material.⁴⁰

Sobre um único direito podem recair diversos interesses que merecem respaldo legal e tutela jurisdicional. Todos eles têm de justificar, com maior ou menor grau de necessidade e utilidade, a legitimação ativa para a provocação do Estado-Juiz. É o caso, por exemplo, em que se objetiva a alienação judicial de bem condominial, em que diversas pessoas são proprietárias de coisa sobre a qual recaem ônus reais. Sobre esse patrimônio incidem, além do direito de propriedade, direitos reais de garantia (penhor, hipoteca ou anticrese) a justificar o interesse do credor pignoratício, hipotecário ou anticrético, podendo ainda haver direitos de legítimos possuidores.

Nessa hipótese qualquer desses pode titularizar interesse suficientemente legítimo hábil à propositura de procedimento de jurisdição voluntária. Poderá, assim, diretamente ou mediante representação/assistência processual, demandar em juízo para defesa de seus direitos.

Ademais disso, tem legitimidade o Ministério Público, a Defensoria Pública e, até mesmo, o juiz pode determinar de ofício a instauração do procedimento de jurisdição voluntária. Nesse último caso bem observa Luiz Guilherme Marinoni que se trata de exceção à regra do *nemo iudex sine actore* (art. 2.º do CPC/2015), a exemplo do que acontece nos casos dos arts. 730, 738, 744 e 746 da lei processual vigente.⁴¹

3.1.2 Iniciativa do Ministério Público

O Ministério Público, instituição essencial ao funcionamento da Justiça, é um protagonista de destaque na jurisdição voluntária. Basicamente, a instituição atua em duas frentes no procedimento voluntário: a) como interessado provocante (art. 177), quando, por exemplo, promove a interdição (art. 747, IV e art. 748, I e II); quando requer a remoção do tutor ou curador (art. 761) e; b) como fiscal da lei, em causas em que há interesse de incapazes e em todas as demais causas em que se verifica, seja por sua natureza ou pela qualidade da parte, interesse público (art. 178).⁴²

Outras hipóteses em que o Ministério Público terá legitimidade para provocar o procedimento de jurisdição voluntária são, segundo Nelson Nery, em pedido de nomeação de curador especial para menor (art. 1.692 do CC/2002 c/c art. 720 do CPC/2015), e em ação de remoção de curador especial para o ausente (art. 22 do CC/2002 c/c art. 720 do CPC/2015).⁴³ Luiz Guilherme Marinoni observa a legitimidade do Ministério Público para a declaração de ausência (art. 22 do CC/2002), para instituição e extinção de fundações (art. 764 e 765 do CPC/2015 e arts. 62 e 69 do CC/2002), entre outras.⁴⁴

Sempre que a atuação ministerial na jurisdição voluntária se mostrar necessária, deve ser intimado. Isso ocorre em todos os procedimentos nos quais se verifique alguma das hipóteses do art. 178 (art. 721), sob pena de nulidade nos termos do art. 279, §§ 1.º e 2.º, do CPC/2015.⁴⁵

No CPC/1973 a intimação do Ministério Público era exigida de modo irrestrito em todos os procedimentos de jurisdição voluntária, pouco importando se, no caso, havia ou não interesse de menores, referia-se ou não “ao estado da pessoa”, e até mesmo quando não demonstrado interesse público.⁴⁶ Todavia, como se verá em tópico próprio (v. comentários ao art. 721), o CPC/2015 restringiu os casos de intervenção ministerial nos feitos dessa natureza àquelas hipóteses descritas no art. 178.

Como interessado legitimado ativo, o Ministério Público exercerá, nos casos previstos em lei, os mesmos poderes dos titulares dos direitos em questão, assim como estará submetido aos mesmos ônus que “as partes”, nos termos do art. 177.⁴⁷ Sua atuação como representante, ou substituto, se dará sempre de forma excepcional, cabendo-lhe assentar se deve, ou não, requerer o que for necessário para a assistência de um interesse particular.⁴⁸

Embora o Ministério Público esteja dispensado das exigências quanto à representação processual e postulatória, cumpre ressaltar, mais uma vez, que deve possuir “legítimo interesse” na demanda ou interesse de agir, devendo, portanto, demonstrar a necessidade ou a utilidade da providência judicial requerida em favor do interessado direto.⁴⁹

3.1.3 Intervenção da Defensoria Pública

A Defensoria Pública é instituição essencial ao funcionamento da Justiça, assim definida por expressa disposição constitucional. Nessa linha, dispõe o art. 1.º da Lei Complementar 80/1994 que é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inc. LXXIV do art. 5.º da CF (hipossuficientes).

Não por menos tem legitimidade ativa para provocar procedimento de jurisdição voluntária, nos casos em que admitem suas funções institucionais. Trata-se de inovação do CPC/2015, uma vez que a lei revogada não a contemplava dentre o rol de legitimados para esse fim.

A doutrina tem posição muito clara sobre os novos deveres sociais e políticos da Defensoria Pública no Estado Democrático de Direito, além dos encargos propriamente processuais.⁵⁰

O art. 720 apresenta, expressamente, a possibilidade de representação da parte interessada pela Defensoria Pública. Diferentemente da atuação do Ministério Público e da Advocacia Pública, a Defensoria atuará sempre que a parte for comprovadamente hipossuficiente, como observa Luiz Guilherme Marinoni,⁵¹ nos termos do art. 5.º, LXXIV, da CF/1988 e inc. VIII do art. 4.º da LPC 80/1993. A hipossuficiência segue as regras previstas nos arts. 98 e seguintes do CPC/2015, sendo presumida, caso seja deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3.º).

3.2 Petição inicial, documentos e princípio dispositivo

Repita-se que os procedimentos descritos nessa seção se submetem, também, às regras gerais de processo. Assim, jurisdição será provocada mediante petição inicial, que deverá atender, além dos requisitos estabelecidos no art. 720 (pedido devidamente instruído; documentos necessários e; indicação da providência judicial pretendida), àqueles dos arts. 319 e 320, além das exigências do art. 287.⁵²

A petição atribuirá, inclusive, o valor da causa, de acordo com o proveito pretendido e, caso seja inestimável, será estimado pelo interessado. Além disso, apresentará o requerimento para citação de todos os interessados e para intimação do Ministério Público (art. 721).⁵³

Verificadas irregularidades ou defeitos na inicial, ou mesmo a falta de requerimento, poderá o juiz determinar que o interessado a emende ou complete no prazo de quinze dias, nos termos do art. 321, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único)⁵⁴. Exceção ocorre quando a provocação se dá de ofício pelo juiz, a qual será feita, por óbvio, por meio de portaria ou ato similar e não por petição inicial.⁵⁵

Para Luiz Guilherme Marinoni, os documentos necessários “têm que ser juntados aos autos com a petição inicial”, mas “se o requerente não os ofereceu, tem o juízo que determinar a juntada”, sendo-lhe vedado “indeferir a petição inicial desde logo em face da ausência de juntada de documento necessário”.⁵⁶ Referidos documentos deverão estar necessariamente relacionados ao pedido.⁵⁷

Sobre esse ponto, Edson Prata aduz que: a) no caso de pedido de emancipação, o documento necessário será a certidão de nascimento; b) já naqueles em que há pedido de alienação, locação ou administração de coisa comum, deve-se instruir o procedimento com a escritura e registro do imóvel; por último, ressalta que, além desses, deve-se instruir o procedimento com os documentos normais (cópia do CPF, RG, comprovante de residência etc.).⁵⁸

José Olympio de Castro Filho aponta que, embora se recomende um trabalho técnico, deve-se observar o princípio do máximo aproveitamento da forma, conforme preceitua o art. 188, de maneira que não se permite a extinção do “processo” caso se verifique algum defeito de forma. Excetua, contudo, os casos de extinção por impossibilidade jurídica do pedido; não cabimento de jurisdição voluntária, ou até de contenciosa, bem como por pedido sem apoio ou vedado em lei. Ainda assim, por exemplo, verificada a inadequação do procedimento voluntário ao caso, em razão do pedido estar afeto à jurisdição contenciosa, não se deve extingui-lo, mas apenas determinar sua conversão.⁵⁹

Adverte Edson Prata que “a simplificação excessiva, fora dos ditames legais, acabaria encaminhando-se para o vasto campo das nulidades, com graves prejuízos aos interessados diretos e indiretos. Não se pode compreender, também, um requerimento excessivamente simplificado”⁶⁰, contradizendo o pensamento de Lopes da Costa, o qual afirma que “o requerimento é o mais simples. Basta que o juiz perceba o que o requerente pretende”.⁶¹

Para Luiz Guilherme Marinoni, no tocante à causa de pedir e ao pedido, incumbe ao interessado declinar a razão pela qual inicia o procedimento e providência judicial que postula, a fim de possibilitar adequado controle do órgão jurisdicional sobre a juridicidade da situação substancial e da solução proposta pelo requerente.⁶²

O procedimento seguirá as normas de distribuição, bem como se materializará em *autos*.⁶³ Os interessados poderão formular pedidos em ordem subsidiária, nos termos do art. 326, desde que tal subsidiariedade seja necessária, bem como os de ordem cumulativa, desde que se cumpram todos os requisitos de admissibilidade do § 1.º, do art. 327.⁶⁴

3.3 Outras questões

Outra exigência que se deve cumprir é a presença de um advogado quando a iniciativa for particular. A representação se dará da mesma forma que na jurisdição contenciosa, por meio de procuração

devidamente outorgada por quem tenha poderes para tanto.

Obviamente, os procedimentos de jurisdição voluntária exigem capacidade postulatória para que sejam formulados perante a autoridade jurisdicional. Portanto, deve o interessado se fazer representar por advogado devidamente constituído nos autos. Não apenas o requerente, mas qualquer interessado que pretender se manifestar nos autos deverá se pronunciar por meio de causídico com procuração para tanto.

Os procedimentos de jurisdição voluntária pressupõem trâmite “especialíssimo” e, assim, não se compatibilizam, por exemplo, com o rito dos juizados especiais, nos quais há a possibilidade de o interessado demandar sem procurador constituído. Dada a especialidade desses procedimentos, devem tramitar perante o Juízo comum e não pelos Juizados Especiais, ainda que se atribua à causa valor inferior a sessenta salários mínimos.⁶⁵

3.3.1 Despesas processuais

Como determina o art. 88: “Nos procedimentos de jurisdição voluntária, as despesas serão adiantadas pelo requerente e rateadas entre os interessados”. O ônus é atribuído, portanto, ao promovente, que será reembolsado pelos cointeressados ao final da demanda.

Tendo em vista que na jurisdição voluntária, em regra, não há vencido ou vencedor, mas agentes igualmente interessados, as despesas, em geral, seriam apenas aquelas relacionadas às custas em seu sentido amplo, excluindo-se, portanto, os honorários sucumbenciais. Porém, havendo controvérsia sobre os pontos principais da demanda, que ultrapassem àqueles de ordem secundária, haverá condenação daquele, cuja tese foi “vencida”, ao pagamento total das despesas processuais, que abrangerão, além das custas, os honorários previstos no art. 85. Cita-se, por exemplo: o requerimento de curatela de quem esteja em perfeitas condições mentais. Em tal caso, não seria crível que as despesas processuais, aí incluídas a perícia médica e honorários advocatícios, fossem rateadas. Certo é, pelo bom senso, que o requerente deverá arcar com todas elas.⁶⁶

Bem observa Nelson Nery, que na jurisdição voluntária não se aplica, quanto às custas e aos honorários, o mesmo critério dominante na jurisdição contenciosa, em que ao vencido cabe pagar as custas e os honorários de advogado.⁶⁷ Nesse sentido, já na vigência do CPC/2015, o STJ se pronunciou confirmando tendência anterior de que esta “Corte Superior já proclamou que em procedimento de jurisdição voluntária, a existência de litigiosidade excepciona a regra de não cabimento de condenação em honorários advocatícios”.⁶⁸

Adverte Alcides de Mendonça Lima, que “não se trata, pela condenação imposta ao pagamento das despesas e dos honorários, de transformar o procedimento de jurisdição voluntária em processo de jurisdição contenciosa, pelas profundas decorrências que isso originaria”. A medida se sustenta nos termos do art. 723, parágrafo único, pois o juiz não está, nesta Seção, adstrito à legalidade estrita, podendo adotar a solução que considerar mais conveniente ou oportuna.⁶⁹

Existem, ainda, circunstâncias onde não caberá qualquer adiantamento. É o caso do Ministério Público quando atua como interessado provocante, situação em que as custas serão pagas, ao final, pelo interessado direto, bem como quando o interessado tiver deferida a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 e da Lei 1.060/1950.⁷⁰

3.3.2 Trâmite procedimental e férias forenses

A previsão de continuidade dos trabalhos durante as férias forenses encontra previsão no art. 215, inc. I, no qual se prevê que se processam durante as férias forenses, onde as houver, e não se suspendem pela superveniência delas os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento.

Há quem considere que, quando se tratar de direitos indisponíveis, os quais estão cercados pelo interesse público, justifica-se a urgência da prestação jurisdicional mesmo durante o recesso forense. Cumpre destacar, porém, que a medida não cabe em todos os procedimentos de jurisdição voluntária, mas, somente, naqueles em que se verifique possibilidade de prejuízos pelo adiamento, conforme a parte final do artigo supra.

O art. 174, inc. I, do CPC/1973, utilizava o vocábulo *atos* ao tratar da suspensão, divergindo a doutrina

quanto à extensão do termo a procedimentos, tendo em vista não se tratar de mesma significação, estando os *atos* contidos dentro dos *procedimentos*. Porém, o novo Código de Processo resolveu a divergência ao utilizar no art. 215, inc. I, a expressão *procedimentos*, findando, de vez, a discussão quanto à sua extensão.

Art. 721. Serão citados todos os interessados, bem como intimado o Ministério Público, nos casos do art. 178, para que se manifestem, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

1. Inovações do CPC/2015

Inova o CPC ao corrigir a expressão *citação* substituindo-a por *intimação*, ato próprio de comunicação processual condizente com a natureza da participação do Ministério Público, que não é réu no processo. De fato, existiam críticas reiteradas à impropriedade do termo utilizado pelo CPC/1973.

Intimação, nos termos do art. 269, é ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo, o que se amolda melhor ao caso, já que o ente ministerial não integrará a demanda na qualidade de interessado direto (“parte”), mas, sim, intervirá no procedimento como fiscal da lei, de acordo com o art. 178.

A atribuição dada ao Ministério Público, neste artigo, permanece a mesma da lei revogada, intervindo somente nos casos previsto em lei, não mais indistintamente. Aqui, ser-lhe-ão asseguradas todas as prerrogativas do art. 179, pelo que terá ampla oportunidade e liberdade para se manifestar. Para Alcides de Mendonça Lima, o órgão ministerial deverá ser intimado apenas após a manifestação dos interessados, e não só após as devidas vistas, a fim de que “(...) o agente tenha meios de bem aferir e compreender o problema, se alguma dúvida for suscitada”.⁷¹ Assim, terá ciência de todos os atos do procedimento, podendo produzir provas, requerer medidas processuais pertinentes e recorrer.⁷²

Remanesce a necessidade de citação de todos os interessados, mas suprimiu-se o texto “sob pena de nulidade”. Dessa forma questiona-se: ainda que não citados todos os interessados, o procedimento seguiria sem que, posteriormente, se pudesse arguir nulidade? Entende-se que não. A citação é ato necessário, e indispensável, para a formação da relação jurídica, nos termos do art. 238, de forma que, a despeito das peculiaridades da jurisdição voluntária, o procedimento exige o respeito ao contraditório e à ampla defesa, garantias constitucionais que não podem ser suprimidas.

Assim, devem ser citados todos os interessados, sob pena de nulidade se comprovado o prejuízo, ainda que não haja previsão expressa no dispositivo. Para Luiz Guilherme Marinoni, “o interesse que outorga legitimidade para participação no processo é aquele denotado em função da imediata afetação da esfera jurídica de alguém pela decisão judicial”, mas não há nulidade se a finalidade do ato citatório é alcançada apesar de eventuais violações à forma.⁷³

Portanto, em obediência ao princípio da instrumentalidade das formas, a decretação de nulidade exigirá, sempre, a comprovação do prejuízo sofrido pelo interessado. Logo, não sendo o processo/procedimento um fim em si mesmo, mas, apenas, um meio hábil ao atingimento de um fim maior e mais relevante, não há nulidade sem prejuízo (*pas de nullité sans grief*).

Ressalta-se, porém, que não seria crível, num procedimento onde nem todas as hipóteses estão determinadas no Código, havendo, inclusive, àquelas em que sequer há previsão em lei especial,⁷⁴ que se procedesse a citação pessoal de todos os possíveis interessados. Nestes casos entende-se pelo cabimento de citação por edital. No mesmo raciocínio, a falta de intimação do Ministério Público, nos casos em que se identificar alguma das hipóteses do art. 178, é causa de nulidade.⁷⁵

Inova também o CPC/2015 ao concatenar os conteúdos dos antigos arts. 1.105 e 1.106 CPC/1973. Agora, além de o prazo para atendimento da citação/intimação passar a ser de 15 dias, entendeu o legislador ser mais apropriado chamar de *manifestação* em sentido amplo o ato do interessado e não mais de *resposta*.

2. Aspectos materiais

O art. 721 se correlaciona diretamente com a lei material, na medida em que, para se definir o interessado, é preciso se conhecer o direito sob o qual se funda o procedimento ou que justifica sua instauração. Assim, é preciso, por exemplo, buscar no CC/2002 as disposições sobre capacidade, poder familiar, tutela, curatela e direitos reais para, assim, se definir quem terá interesse na demanda.

Do mesmo modo, para se definir o interesse na intervenção do Ministério Público (hipótese do art. 178 do CPC/2015) e da Defensoria Pública (hipossuficiente) é preciso buscar em suas leis de regência as hipóteses em que poderão e/ou deverão atuar nos autos.

3. Aspectos processuais e procedimentais

Neste item 3 serão tratadas a legitimação passiva, a forma da citação e da intimação dos interessados e do Ministério Público, os prazos procedimentais aplicáveis, as causas de nulidade, intervenção de terceiros, dentre outras questões relevantes para a compreensão dos procedimentos de jurisdição voluntária.

3.1 Legitimação passiva e legitimação processual

A legitimidade passiva será identificada, via de regra, pela própria lei. Pode-se citar como exemplo o teor do art. 741, § 1.º, segundo o qual “verificada a existência de sucessor ou testamenteiro em lugar certo, far-se-á a sua citação, sem prejuízo do edital”. Há também a regra do art. 752 que fixa o prazo de 15 (quinze) dias contados da entrevista para que o interditando impugne o pedido de interdição.⁷⁶

Entretanto, nem todos os procedimentos preveem expressamente quem deverá ser citado. Nesses casos, observar-se-á o princípio geral de “legitimidade da parte” (comentários ao art. 720, item n. 3.1), devendo o juiz apreciá-los preliminarmente, tendo em vista que os efeitos da decisão também repercutirão sobre os requeridos, ainda que não se lhes aplique os efeitos da coisa julgada.⁷⁷

Também na jurisdição voluntária os interessados não de ter legitimação processual para atuar no feito, observadas, quando for o caso, as regras de representação e assistência processuais. Assim, os incapazes, por exemplo, deverão se manifestar em juízo sempre acompanhados de seus tutores ou curadores, bem assim por meio de advogado ou da Defensoria Pública ou ainda por núcleos de prática jurídica, detentores de capacidade postulatória.

De certo, como adverte Alcides de Mendonça Lima, “não se devem inventar interessados”. Caso o juiz, segundo sua experiência e entendimento sobre o pedido, identifique a falta de algum ou de alguns cointeressados, poderá determinar de ofício que sejam citados, porquanto não está adstrito àqueles indicados pelo requerente.⁷⁸

3.1.1 Citação dos interessados

Conforme já observado em linhas anteriores, Alcides de Mendonça Lima, João Paulo Lucena, Humberto Theodoro Júnior e outros juristas de renome defendem que na jurisdição voluntária não há litígio em seu sentido clássico, sendo todos, portanto, interessados e não partes, na acepção de autor e réu.

Inicialmente, há coincidência de objetivos, podendo os citados colaborar com o requerente na obtenção da tutela perquirida.⁷⁹ Assim, diferentemente da jurisdição contenciosa, os interessados não serão citados para se defender, mas, de forma mais ampla, concordar, discordar, confessar, prestar esclarecimentos e, eventualmente, apresentar sua discordância.⁸⁰ Não significa dizer que não haverá possibilidade de *resistência* ao direito perquirido,⁸¹ apenas que, nesses casos, transmutar-se-á da jurisdição voluntária para a contenciosa.

Para Nelson Nery Junior, a citação de que trata o art. 721 não provoca contra o demandado a revelia e seus efeitos, pelo que o ato de comunicação judicial não tem natureza jurídica propriamente de citação. Ainda assim, é meio pelo qual se deve fazer conhecer aos interessados a existência do interesse que se quer protegido, bem como da solução que se busca.⁸²

A relação jurídica processual será formada após a citação de todos os interessados, pessoas físicas ou jurídicas – mantendo-se o entendimento de que será aplicada a nulidade aos atos praticados no procedimento em que se identificar a falta de citação de algum ou alguns interessados –, oportunizando-lhes, assim, o exercício do contraditório.⁸³ A citação seguirá às disposições do art. 238 e seguintes, sendo efetivada via postal, por meio de oficial de justiça ou pela publicação de edital, nos casos em que forem incertos os interessados ou que não se conheça seu paradeiro.⁸⁴

De um modo geral, poderá o requerido se manifestar nos autos de forma ampla, inclusive interpondo os recursos cabíveis e requerendo a produção de todas as provas em direito admitidas, salvo nos casos

específicos em que a dilação probatória e o amplo contraditório forem incompatíveis com o trâmite e a natureza da medida pleiteada, tal como acontece nos protestos, interpelações e notificações judiciais.

Bem observa Luiz Guilherme Marinoni que os interessados são citados para que tenham ciência do processo e para que possam dele participar, mas suas respostas não constituem contestação ou reconvenção, porquanto inadmissíveis no procedimento de jurisdição voluntária. Devem, portanto, ser consideradas simples manifestações a respeito da causa de pedir e do pedido formulado pelo requerente “com o intuito cooperativo”. Por essa mesma razão também afirma que não se operam os efeitos da revelia.⁸⁵

Em todo caso, é vedado aos interessados pretender fim ilícito, bem assim atuar em ofensa à boa-fé processual, caso contrário estarão sujeitos às penalidades legais previstas no próprio CPC/2015 (litigância de má-fé, fraude contra credores, fraude à execução etc.).

3.1.2 A adequada intimação do Ministério Público

O Ministério Público, quando intimado, agirá como fiscal da lei, sendo sua atuação necessária e indispensável. Atuará como auxiliar do juiz no descobrimento da verdade processual (indício de verdade),⁸⁶ podendo anuir ou discordar da tutela requerida e, se for o caso, sugerir diligências ou elaborar soluções diversas àquelas apresentadas pelo juiz, desde que atinjam os mesmos resultados.⁸⁷

O ente ministerial poderá oferecer parecer definitivo ou petições simples, nos quais exporá seu ponto de vista técnico-jurídico ou se resguardará para pronunciamento final diferido, caso esteja aguardando a conclusão de alguma diligência relevante. Mas o Ministério Público, adverte Alcides de Mendonça Lima, não deve se limitar apenas ao conhecimento, omitindo-se como se seu silêncio correspondesse à concordância ao pedido, deixando nos ombros do juiz toda a responsabilidade. Assim, seja anuindo ou discordando, deverá exercer atividade de colaboração efetiva e eficiente na defesa do “interesse público”, conforme preceitua o art. 178.⁸⁸

Sobre a obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público, Luiz Guilherme Marinoni sustenta que o art. 721 deve ser visto sob a perspectiva do art. 178, que prevê as hipóteses em que a participação do ente ministerial é devida. Fora desses casos, entende que sua participação é desnecessária.⁸⁹

Para Nelson Nery “há interesse público de *lege lata* e de *iure conditio* em todos os procedimentos de jurisdição voluntária”, motivo pelo qual o Ministério Público deve intervir em todos os casos, pelo que não lhe é permitido examinar discricionariamente se é ou não caso de intervenção. Assim, sua participação nos autos como fiscal da lei “é obrigatória, imprestável e indeclinável”. Contudo, reconhece que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tende em sentido contrário ao seu entendimento.⁹⁰

Alcides de Mendonça Lima ainda apresenta discussão quanto à necessidade de intervenção ministerial nos casos em que já tomou a iniciativa de promover o procedimento de jurisdição voluntária. Entende que, nos casos em que o Ministério Público se apresenta como “interessado provocante”, é desnecessária sua intervenção como *custos legis*. Isso porque sua atuação dúplice poderia gerar um conflito de opiniões prejudicial ao curso regular do feito. “Se o Ministério já age inicialmente, é evidente que seu representante não está atuando no intuito de parcialidade em favor do beneficiado com a medida e, sim, está procurando solução que atenda à conveniência e à necessidade do interessado direto. Seria bis in idem mandar, no caso, citar (*rectius* – intimar) outro agente, para atuarem os dois”.⁹¹

Pontes de Miranda⁹² e Cândido Rangel Dinamarco⁹³ também indicam a exigência de participação do Ministério Público.

Dessa forma, “se já estiver no feito, é dispensável, logicamente, a cooperação de um outro membro da entidade”, pois o importante, nos termos da lei, é a presença do Ministério Público para que não se cogite a nulidade pela falta. Entende-se ser medida acertada e razoável.

Por derradeiro, cumpre apontar que o órgão ministerial, nos termos do art. 181, será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções.

3.1.2.1 Limites do art. 178

Como dito anteriormente, a lei revogada previa expressamente a “citação” do órgão ministerial, sem que se apresentasse qualquer limitação à sua atuação. Dessa forma, divergia a doutrina quanto à

necessidade de observação das hipóteses previstas no art. 82 do CPC/1973 (correspondente ao atual art. 178 do CPC/2015), entendendo alguns juristas pela intervenção indiscriminada do Ministério Público nos procedimentos de jurisdição voluntária.⁹⁴

Em sentido contrário, João Paulo Lucena assevera não haver qualquer fundamento lógico que justifique, por exemplo, a intervenção do órgão ministerial quando, na extinção de condomínio, alienação judicial, administração ou locação de coisa comum ou venda de quinhão, se verificar trataram-se de interessados capazes, pois a atividade do juiz tem caráter visivelmente fiscalizador e supletivo das deficiências das partes. Conclui o autor que, “apesar de indispensável a citação do Ministério público para todos os procedimentos de jurisdição voluntária, sob pena de nulidade, o seu efetivo ofício fica pendente da existência das hipóteses arroladas no art. 82”.⁹⁵

Cuidou o novo Código de apontar, expressamente, que a intervenção ministerial se dará apenas nos procedimentos em que se verifique alguma das hipóteses previstas no art. 178. O que permite compreender que só haverá intervenção ministerial nos casos em que se verificar discussão sobre direitos indisponíveis ou de incapazes ou interesse público em geral, normatizando-se, assim, o entendimento consolidado pela jurisprudência.⁹⁶

Na prática o Ministério Público avalia cada caso submetido a sua análise e se manifesta sobre a existência ou não de interesse que justifique sua intervenção. Logo, se o procedimento de jurisdição voluntária veicula, por exemplo, direito meramente patrimonial que não envolva interesse público ou de incapaz, como no caso de algumas alienações judiciais, notificações e interpelações, não está obrigado a oficiar nos autos, nem é necessário que o faça.

3.2 Nulidade

Defende-se, conforme anteriormente apresentado, que, embora se tenha retirado do texto a expressão “sob pena de nulidade”, eis que tal aplicação permanece nos casos de inexistência ou precariedade do ato citatório ou intimatório. Porém, cumpre advertir que não será aplicada, em todos os casos, a nulidade total e absoluta.

Os atos serão, via de regra, absolutamente nulos nos casos já citados. Porém, o art. 239, § 1.º, prevê que a citação nula ou inexistente pode ser suprida pelo comparecimento do “réu” ao processo, desde que não se verifique prejuízos ao interessado não citado, devendo o prazo para manifestação ser-lhe restituído integralmente. Não se trata de dar eficácia à citação, mas de supri-la.

Da mesma forma a falta de intimação do Ministério Público, via de regra, trará nulidade absoluta aos atos praticados até o momento em que deveria ter sido intimado. Contudo, nos termos do art. 279, § 2º, caso não se verifique prejuízo, o feito poderá seguir normalmente.

No cotidiano forense, não raras vezes o juiz se esquece de determinar a intimação do ente ministerial, fazendo-o somente às vésperas da sentença ou mesmo após ter sido proferido o julgamento. Intimado, pode o Ministério Público limitar-se a dar ciência dos atos já praticados mesmo da decisão final, sem impugnações, considerando, por exemplo, que o procedimento tramitou regularmente em todos os seus termos. Não havendo prejuízo, não haverá nulidade.

3.3 Prazo do procedimento comum

O prazo para manifestação segue a regra de 15 dias do procedimento comum. Trata-se de intenção específica do legislador em unificar os prazos constantes do CPC/2015.

O termo inicial da contagem do prazo tem início após a juntada do mandado de citação cumprido aos autos, caso seja realizado por oficial de justiça; da juntada do aviso de recebimento, se for pelos correios; e pela devolução da carta precatória ao juízo deprecante. No caso de haver mais de um interessado, da juntada do último mandado cumprido, seguindo, assim, os ditames da parte geral do CPC/2015.⁹⁷

Cumpre ressaltar que se trata de prazo comum aos interessados, não cabendo fixar termo inicial distinto para cada um deles. Aplica-se, porém, a suspensão nos casos do art. 313, I e III.⁹⁸

Ressalta-se que não havia consenso na doutrina quanto à aplicação da dobra do prazo prevista no antigo art. 191 CPC/1973, porém a nova redação do art. 229 não deixa mais dúvidas acerca de seu cabimento: “Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos,

terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independente de requerimento”. Sendo assim, resta incontroversa sua aplicação também nesta Seção.

Já no caso do Ministério Público, não se aplica a contagem do prazo em dobro prevista no *caput* do art. 180, porquanto tem oportunidade diferenciada para manifestação na jurisdição voluntária. É que o art. 720 estabelece prazo específico ao ente ministerial, qual seja, 15 dias, que embora este coincida com a regra geral, aqui atrai a incidência do § 2.º daquele art. 180, o qual dispõe que “não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o Ministério Público”.

3.4 Manifestação dos interessados e do Ministério Público

Devidamente citados os interessados e intimado o Ministério Público, deverão apresentar manifestação no prazo de 15 dias, dizendo se concordam, discordam ou mesmo se apresentam outra solução para o objetivo comum.

Porém, manifestando-se sobre o pedido, incumbirá ao interessado dizer precisamente sobre os fatos apresentados na inicial, com a finalidade de “impedir novas defesas posteriormente”.⁹⁹ Deverá arguir: a) inexistência ou nulidade da citação; b) incompetência absoluta e relativa, bem como impedimento e suspeição; c) inépcia da inicial; d) perempção; e) litispendência; f) conexão; g) incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização; h) carência de ação; i) falta de caução ou outra prestação, que a lei exige como preliminar; j) impugnação ao valor da causa (art. 293); l) falta de documentos necessários (art. 320).¹⁰⁰

Somente depois de arguidas as preliminares é que se poderá atacar a pretensão perquirida pelo interessado direto, o que corresponde à negação no tocante ao mérito em sentido amplo.¹⁰¹

A doutrina diverge quanto à possibilidade de reconvenção. Entende João Paulo Lucena que “não havendo lide e contestação, descabe no procedimento voluntário a reconvenção”.¹⁰² Por outro lado, José Olympio de Castro Filho entende pela admissibilidade da reconvenção, ainda que raramente praticada, quando satisfeitos os pressupostos do art. 343.¹⁰³

Luiz Guilherme Marinoni, já se observou, entende que os interessados são citados para que tenham ciência do processo e para que possam dele participar, mas suas respostas não constituem contestação ou reconvenção, porquanto inadmissíveis no procedimento de jurisdição voluntária. Devem, portanto, ser consideradas simples manifestações a respeito da causa de pedir e do pedido formulado pelo requerente “com o intuito cooperativo”. Por essa mesma razão também afirma que não se operam os efeitos da revelia.¹⁰⁴

O artigo em questão, conforme apontado, inova ao apresentar o termo “querendo”, o que remonta à discussão doutrinária quanto à aplicação da revelia e de seus efeitos nos procedimentos voluntários. Sobre o tema, Pontes de Miranda sustenta a incidência de seus efeitos nos casos em que o interessado, ou interessados, não se manifesta, tomando-se por verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344.

Considera ainda não se tratar de aplicação indiferente, mas que admite ressalvas como aquelas previstas no art. 341, o qual estabelece que o ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Além disso, incide na hipótese o art. 345, segundo o qual a revelia não produz efeitos nos seguintes casos: a) havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação (inc. I); b) o litígio versar sobre direitos indisponíveis (inc. II); c) a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato (inc. III); d) as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos (inc. IV).¹⁰⁵

Já José Olympio de Castro Filho, que reconhece as mesmas exceções anteriormente apontadas, defende o que denomina “revelia atenuada”. Aduz que, por força da própria natureza da jurisdição voluntária, a pena não será aplicada em todo o seu rigor, de forma que o interesse ou a conveniência, que incumbia ao revel defender, não ficará desamparada, pois conforme preceitua o art. 723 poderá o juiz adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna, bem como sempre lhe assistirá o direito de intervir no processo em qualquer fase, nos termos do parágrafo único do art. 346.¹⁰⁶

Contrariando os dois entendimentos, João Paulo Lucena entende que a ausência de manifestação dos

interessados citados não ocasiona a aplicação da confissão ficta. Considerando que não existe lide e que não há resposta dos interessados, o juiz deveria decidir a questão nos termos do art. 723.¹⁰⁷

Tanto João Paulo Lucena quanto José Olympio de Castro Filho fundamentam seu ponto de vista no antigo art. 1.107, não reproduzido no CPC/2015. Esse dispositivo autorizava a utilização do princípio inquisitivo pelo juiz nos procedimentos voluntários, sendo lícito investigar livremente os fatos e ordenar, de ofício, a realização de quaisquer provas.

Assim, ainda que se verifique a atuação *ex officio* do juiz em determinadas situações, eis que não mais prevalece a ampla liberdade investigativa anteriormente outorgada, pelo que se entende inadmissível a atenuação ou mesmo a declaração de inocorrência de revelia e seus efeitos.

No entanto, parece mais razoável reconhecer o descabimento da revelia, ante a inexistência de lide e, conseqüentemente, de contestação na jurisdição voluntária. Assim, é dada total liberdade ao interessado para que, querendo, se manifeste, sem que lhe sejam aplicados os efeitos da confissão ficta ou da revelia atenuada.

Assim, o juiz deve decidir com base nas provas produzidas nos autos, nos termos dos arts. 369 e 371. Portanto, ainda que não se manifeste, incumbe ao interessado citado, caso discorde da tutela requerida, o ônus de apresentar as provas que entenda imprescindíveis ao resguardo de sua pretensão, nos termos do art. 349, ainda que o art. 370 permita ao juiz, de ofício, determinar a produção de provas que julgue necessárias ao caso.

Em relação às provas, por falta de disciplina específica é aplicado ao procedimento voluntário as regras gerais do art. 369 e ss. do CPC/2015, devendo os pedidos serem formulados na petição inicial, no caso daqueles previstos no art. 720, e na manifestação, no caso daqueles previstos no art. 721.

3.5 Intervenção de terceiros

Como os procedimentos de jurisdição voluntária não são vocacionados ao acerto de relação jurídica de direito material, a intervenção de terceiros é, *em regra*, inadmissível. Não se trata de proibição legal expressa, mas de incompatibilidade fático-jurídica, que pode ser desconsiderada, decorrente da natureza do procedimento e do fim a que se destinam as modalidades de intervenção de terceiros.

Esse entendimento se deve ao fato de não haver bem da vida em litígio sobre o qual possa haver interesse de pessoa estranha ao vínculo jurídico inicialmente apresentado ao Estado-Juiz. Logo, tratando-se de procedimento em que sequer há partes (autor e réu) litigantes, natural que a decisão proferida não repercuta na esfera jurídica de terceiro a ponto de justificar sua intervenção nos autos judiciais.

É que na jurisdição voluntária mesmo o contraditório assume feição peculiar, ante a ausência de pretensão resistida e de alegações a serem contestadas. Com menos razão, portanto, hão de permitir a intervenção de terceiros.

Fato é que todo interessado deverá ser cientificado para que, querendo, se manifeste nos autos. De um modo geral, não há terceiros alheios ao processo, mas uma possível pluralidade de interesses a serem observados pelo juiz. Aqui o terceiro assume a qualidade de interessado.

No entanto, foi prevendo hipóteses em que qualquer desses interessados pudesse ser preterido em seu direito de petição, por não ter sido intimado acerca da instauração do procedimento, que a lei previu hipóteses em que a medida concedida em juízo não repercutará na esfera jurídica, aqui sim, do terceiro que permaneceu alheio a relação procedimental. É o caso, por exemplo, das alienações judiciais em jurisdição voluntária, segundo o qual a alienação de bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese será ineficaz em relação ao credor pignoratício, hipotecário ou anticrético não intimado.

Além disso, nada impede que aquele que se considerar terceiro interessado não convidado a integrar a relação jurídica do procedimento impetre mandado de segurança imputando ato coator ao magistrado, nem que demande em ação autônoma, de natureza contenciosa, pela reparação dos danos que tenha sofrido.

Art. 722 . A Fazenda Pública será sempre ouvida nos casos em que tiver interesse.

1. Inovações do CPC/2015

Não houve qualquer alteração na redação do art. 722 do CPC/2015 em relação ao equivalente art. 1.108 do CPC/1973.

2. Aspectos materiais

Como se vê, não inovou o CPC/2015 neste artigo, limitando-se a repetir previsão legal já contida no CPC/1973. Desde a lei anterior há obrigatoriedade de oitiva da Fazenda Pública nos casos em que tiver interesse.

De certo modo, sequer havia necessidade de inclusão desse dispositivo, vez que a regra geral é a de que todos os interessados deverão ser ouvidos. Ao que parece, o legislador quis incluir, expressa e individualmente, a Fazenda Pública no rol dos interessados, objetivando afastar quaisquer dúvidas sobre sua legitimidade, bem assim reafirmar a necessidade de observância do princípio da supremacia e da indisponibilidade do interesse público.

Assim restam vinculados aos termos da lei não apenas os cointeressados e o órgão jurisdicional, mas a própria Fazenda Pública, que está obrigada pela defesa do interesse público.

3. Aspectos processuais e procedimentais

A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial (art. 535) para que manifeste seu interesse, seja ele fiscal ou pecuniário, em ingressar nos procedimentos voluntários, verificando, para tanto, a existência de tributos a serem recolhidos ou fiscalizando o devido recolhimento destes.¹⁰⁸

É, aqui, entendida como entidade fiscal do poder estatal em toda sua plenitude. Desse modo, deve ser estendida a todas as suas entidades (federal; estadual e municipal), bem como, pela finalidade, aos órgãos previdenciários e outros que possuam, igualmente, funções tributárias, a legitimidade para se manifestar.¹⁰⁹

Em Comentários ao CPC/2015, obra coordenada por Antonio do Passo Cabral e Ronaldo Cramer, Bruno Freire e Silva sustenta que a intimação da Fazenda Pública deverá ocorrer nos procedimentos de jurisdição voluntária em que tiver interesse, notadamente quando houver incidência de tributos, como na transmissão de bens, além dos casos que possam importar em arrecadação de bens ao estado.¹¹⁰

A doutrina diverge quanto à natureza de atuação do órgão na jurisdição voluntária. Alcides de Mendonça Lima entende que “a Fazenda, evidentemente, não é referida como promovente ou requerente de providência judicial necessária à constituição de determinado ato jurídico, e, sim, porque é ‘chamada’, desde que interesses fiscais haja no feito para serem atendidos”.¹¹¹ Para o autor, o órgão tem legitimidade para iniciar o procedimento, ficando contida, tal possibilidade, no termo geral “interessado” constante no art. 720. Aduz, ainda, que tal situação está implícita no feito do art. 745, §§ 1.º e 2.º, por ser credora do tributo já vencido, e arts. 738 e 743, § 2.º.¹¹²

Em sentido contrário, posiciona-se Pontes De Miranda, o qual entende que o interesse da Fazenda Pública é aquele relacionado à espécie de “ação”, que não se confunde com o *interesse de agir*, que lhe daria legitimação nos termos dos arts. 720 e 721.¹¹³

José Olympio de Castro Filho aponta que o conteúdo, presente no art. 722, é perfeitamente dispensável, pois, conforme art. 721, todos os interessados devem ser citados,¹¹⁴ não se excluindo, portanto, a Fazenda Pública.¹¹⁵ Ressalta ainda que, ao que parece, o objetivo do artigo é chamar a atenção dos interessados, do Ministério Público e do juiz para o interesse dos Poderes Públicos.¹¹⁶

Em que pesem as discussões quanto à sua legitimação “ativa” ou “passiva”, nos procedimentos voluntários, fato é que deverá ser ouvida sempre que verificado seu interesse. Pode-se citar, como exemplo, os casos em que a Fazenda deverá ser citada: na divisão de bens em separação judicial (art. 626, *caput* e § 4.º), quando deverá ser juntada a certidão ou informação negativa de dívida para com a Fazenda Pública (art. 654), ainda que a existência de dívida não impeça o julgamento da partilha, nos casos em que o pagamento estiver devidamente garantido (parágrafo único do art. 654); juntamente com o Ministério Público na abertura e cumprimento de testamento (art. 735, § 2.º) e para se manifestar sobre a pretensão de cónjuge, herdeiro ou testamenteiro sobre os referidos bens (art. 740, § 6.º).¹¹⁷

Cumprir destacar, porém, que não deve o aplicador da norma se ater apenas aos casos em que haja previsão expressa à intimação da Fazenda Pública, pois são hipóteses meramente enunciativas.¹¹⁸ Dessa

forma, ainda que, com omissão legal, se cogite de possível interesse da Fazenda, deverá haver sua intimação, sob pena de nulidade. ¹¹⁹

Luiz Guilherme Marinoni explica que, para atendimento ao quanto disposto no art. 722, basta a intimação da Fazenda Pública, garantindo-se, assim, a regularidade do procedimento. Não se exige que ela participe efetivamente da demanda, motivo pelo qual de sua inércia após regular intimação presume-se como ausência de interesse. ¹²⁰ Do mesmo entendimento partilham Nelson Nery Junior, ¹²¹ Zulmar Duarte de Oliveira Junior em obra coordenada por Alexandre Freire e organizada por Lenio Luiz Streck e outros, ¹²² bem assim Marcelo Miguel Conrado, em comentário ao CPC/2015 coordenado por José Sebastião Fagundes da Cunha. ¹²³

Quanto ao prazo para manifestação, entende-se cabível o geral de 15 dias, nos termos do art. 721.

3.1 Conceito de Fazenda Pública e sua representação judicial

Para a conceituação de Fazenda Pública, Leonardo Carneiro da Cunha a indica como o Estado em juízo, Poder Público em juízo, e mais precisamente a personificação do Estado. ¹²⁴

Em representação à Fazenda Pública atua a Advocacia Pública, mas em nome alheio, defendendo os entes da Administração, sejam os entes federativos da Administração direta: União, Estados, Distrito Federal ou Municípios; como em representação judicial e na representação extrajudicial, no assessoramento aos gestores e na consultoria aos entes da Administração indireta: autarquias, fundações, empresas públicas e mesmo das sociedades de economia mista.

Art. 723 . O juiz decidirá o pedido no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo único. O juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna.

1. Inovações do CPC/2015

Embora o conteúdo do artigo seja praticamente o mesmo, optou, o legislador, por separar o texto em duas partes, *caput* e parágrafo único. Imagina-se que assim o fez a fim de melhor organizar a estrutura do dispositivo. Observa-se que, no *caput*, o comando legal direciona-se ao juiz, imputando-lhe prazo específico de dez dias para decidir. Já o parágrafo único se relaciona com os poderes do juiz em procedimentos de jurisdição voluntária.

2. Aspectos materiais

Optou-se por expressões transversas para evitar a equidade, complexa definição. O parágrafo único autoriza o juiz a “observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna” ao decidir.

María José Falcón y Tella, em trabalho que pode ser considerado um clássico sobre a equidade, aponta três modos de aplicar a igualdade: tratamento igualitário, tratamento proporcional e tratamento equitativo; sendo o primeiro aquele que considera merecido o trato igual aos iguais, sendo o segundo quando o trato é desigual aos desiguais, na proporção das desigualdades, sendo ambos quantitativos e numéricos, ao passo que o último, tratamento equitativo se ampara em valores e não em quantidades ou medidas. ¹²⁵

Segundo a autora: “O tratamento equitativo vai mais além do tratamento paritário, uniforme, homogeneizador e unitário, mas também vai mais além do tratamento proporcional. (...) Discriminação positiva seria aquela que, apesar de violar o princípio de tratamento igual e inclusive o de tratamento proporcional, não vai contra o tratamento equitativo. Consiste em tratar desigualmente alguém para remediar uma situação inicial de desvantagem, até o ponto de chegar não somente a igualar o desigual, mas a dar prevalência ao polo inicialmente desfavorável”. ¹²⁶

3. Aspectos processuais e procedimentais

O *caput* do dispositivo estabelece prazo específico de 10 dias para que o juiz profira sua decisão sobre o pedido formulado pelo requerente, o qual terá início a partir da conclusão do procedimento para sentença, após finalizada toda a instrução necessária. Trata-se de prazo menor que a regra geral dos

processos contenciosos, resultado da relativa simplicidade dos feitos de jurisdição voluntária.

Contudo, em obra organizada por Alexandre Freire, bem observa Zulmar Duarte de Oliveira Junior que o CPC/2015 não exclui tais procedimentos da ordem cronológica de que trata o art. 12, pelo que por vezes procedimentos facilmente recorríveis terão de ficar à espera de processos de maior complexidade e envergadura e, portanto, demandarão muito mais tempo para que sejam finalmente julgados.¹²⁷

Quanto à regra do parágrafo único, bem observam Guilherme Marinoni e Nelson Nery Junior que se trata da possibilidade de julgamento por equidade, “ao arrepio da legalidade estrita, podendo decidir escorado na conveniência e oportunidade, critérios próprios do poder discricionário, portanto inquisitorial, bem como de acordo com o bem comum”.¹²⁸ A equidade é “verdadeiro poder de criar a norma cabível no caso concreto”¹²⁹ e somente é aplicada nos casos expressamente previstos em lei, tal como admite o art. 723.

Contudo, bem assevera Luiz Guilherme Marinoni que o fato de o juiz não se sujeitar à legalidade estrita “não significa que está isento de seu dever de aplicar o direito e justificar racionalmente a sua decisão”. Por esse motivo, “a motivação é devida, e é a partir dela que se pode aferir a juridicidade da decisão judicial”.¹³⁰

A sentença proferida observará, assim, todos os pressupostos e requisitos aplicáveis ao processo contencioso, conforme disciplina o art. 489¹³¹ do CPC/2015. Afinal, quanto maior a liberdade de decidir do juiz, maior será a necessidade de se declinar todos os motivos que justificaram seu convencimento, de modo a se evitar arbitrariedades e imparcialidades.

Art. 724 . Da sentença caberá apelação.

1. Inovações do CPC/2015

Não há nenhuma inovação na redação do art. 724 do CPC/2015, que corresponde ao art. 1.110 do CPC/1973. A reprodução de dispositivo de lei idêntico afasta certa dúvida sobre a recorribilidade nos procedimentos de jurisdição voluntária.

A apelação já consta do rol dos recursos cíveis (art. 994, CPC/2015) que podem ser interpostos contra a sentença (art. 1009, CPC/2015). É definida pelo § 1.º do art. 203 como o “pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”.

A denominação utilizada (sentença) sempre sofreu inúmeras críticas da doutrina. Conforme anteriormente apontado dentro desta Seção que trata *Das Disposições Gerais*, o ato que põe fim ao procedimento não recebe nomenclatura uniforme, ora chamado propriamente de sentença (art. 724, art. 734, § 3.º, art. 743, § 2.º e 3.º, art. 754, art. 755, *caput* e § 3.º, art. 755, § 3.º, art. 760, § 2.º, art. 770, CPC/2015), ora de providência judicial (art. 720, CPC/2015); ora sendo indicado pelo verbo decidir, correspondente a decisão (art. 723, art. 764, CPC/2015); também por previsões como “confirmará” (art. 737, § 2.º, CPC/2015).

Em que pese essa pluralidade de nomenclaturas, o pronunciamento põe fim à fase cognitiva do procedimento, dando ou não solução à questão suscitada. Decidir é examinar o pedido e sentenciar, *sem a resolução do mérito*, por sentença terminativa (art. 485) ou *com a resolução do mérito*, por sentença definitiva (art. 487).

A sentença no procedimento de jurisdição voluntária é igualmente “o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento (...)” (art. 203, § 1.º), ou seja, é ato final do processo, que põe fim ao procedimento (art. 490), composta pelos seguintes elementos essenciais: o relatório, a fundamentação e a decisão (art. 489); que a partir do CPC/2015 deverá atender a requisitos adicionais para ser considerada fundamentada, sob o risco de gerar invalidades ou nulidades se insuficientemente fundamentada (art. 489, § 1.º, incs. I a VI; § 2.º e § 3.º).¹³²

Embora contenha restrição de conceito relativamente ao procedimento comum, é certo que os procedimentos especiais de jurisdição voluntária ou contenciosa também têm o fim de sua fase de conhecimento por sentença, sendo acertada, portanto, essa denominação ao tipo de decisão proferida ao final do procedimento de jurisdição voluntária.

2. Aspectos materiais

A recorribilidade ou revogabilidade da decisão de jurisdição voluntária decorre da expectativa humana de revisar quaisquer decisões.¹³³

A recorribilidade não retira o caráter não contencioso ou de baixa contenciosidade das decisões da jurisdição voluntária.¹³⁴ Apenas como exemplo e paralelo, a recorribilidade da transação penal nos Juizados Especiais Criminais também não retira o caráter não contencioso da jurisdição voluntária, presente nesse negócio jurídico penal e processual penal.¹³⁵

Niceto Alcalá-Zamora y Castillo aponta para uma variedade de intensidades, tendendo sempre a ser reduzida em relação à jurisdição contenciosa.¹³⁶

3. Aspectos processuais e procedimentais

Desde há muito se debate sobre o cabimento da apelação nos procedimentos de jurisdição voluntária, e as soluções de cada sistema nacional podem seguir um ou outro caminho, permitindo ou não o recurso da sentença.¹³⁷ A recorribilidade das decisões está associada à sucumbência ou ao prejuízo, sem o que não se cogita de recursos contra decisões judiciais. Daí o motivo pelo qual se discute a recorribilidade da sentença proferida em feitos dessa natureza.

Analisando o tema, Luiz Guilherme Marinoni e Nelson Nery Junior são diretos e categóricos ao afirmar que cabe, sim, apelação contra a decisão que põe fim ao procedimento de jurisdição voluntária, inclusive diante do que dispõe o art. 724. Assim, entendem que o recurso seguirá aqui o mesmo regramento aplicável nos processos contenciosos (arts. 1.009-1.014 do CPC/2015).¹³⁸

Talvez toda essa análise deva incidir, na verdade, sobre a configuração do interesse recursal. Afinal, as peculiaridades da jurisdição voluntária não de resultar, não raras vezes, em sentença na qual nenhum cointeressado tenha interesse na interposição de recurso, como é comum nas decisões de deferimento das notificações judiciais, até mesmo pela singeleza do procedimento e pela própria natureza do ato praticado pelo juiz (simples comunicação).

3.1 Sentença, apelação, outros recursos e remessa necessária

Já se viu que a decisão proferida pelo juiz nos procedimentos de jurisdição voluntária, ainda que receba diversas nomenclaturas, será equivalente à sentença, desde que, nos termos do § 1.º do art. 203, CPC/2015, o pronunciamento ponha fim ao procedimento. Assim, corroborando a parte geral do Código, da sentença caberá apelação.

Sendo este o recurso cabível, deve-se observar, portanto, as regras a ele atinentes, quais sejam, aquelas previstas nos arts. 1.009/1.014 do CPC/2015. Deverá ser dirigida ao juízo de primeiro grau (art. 1.010 do CPC/2015), contendo os nomes e a qualificação das partes (inc. I); exposição dos fatos e do direito (inc. II); as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (inc. III) e o pedido de nova decisão (inc. IV).

Seu prazo também obedecerá ao disposto no Capítulo II, do Título II, sendo de 15 dias contados da data da publicação da sentença (art. 1.103, § 5.º, do CPC/2015).

Quanto aos demais recursos admissíveis na via contenciosa, não se constatando regra em contrário, são igualmente cabíveis na jurisdição voluntária. Sobre o tema, Edson Prata, em análise ao CPC/1973, afirmou que “o procedimento ordinário sempre foi fornecedor de subsídios para os demais, inclusive para os de jurisdição voluntária. O art. 1.169, por exemplo, embora trate de procedimento universalmente típico de jurisdição voluntária, o de bens de ausente, dispõe: ‘Serão citados para lhe contestarem o pedido’ e a seguir: ‘havendo contestação, seguir-se-á o procedimento ordinário’”.¹³⁹

O mesmo entendimento há de ser aplicado sob a vigência do CPC/2015. Dessa forma, os agravos, bem como os embargos de declaração tem lugar na jurisdição voluntária. Caberá, ainda, segundo aquele mesmo jurista, Recurso Extraordinário das *decisões* proferidas por outros tribunais, em questões da jurisdição voluntária. Para tanto, ponderou que o art. 541, inc. III, do CPC/1973 (hoje art. 1.029, inc. III, do CPC/2015) utilizou o termo *decisão* em seu sentido amplo.¹⁴⁰

Alcides de Mendonça Lima, nessa mesma linha, também em análise ao CPC/1973, concluiu que, “na

falta de referência expressa, neste Livro e, principalmente, neste Capítulo I, a qualquer outro recurso, quais sejam os relacionados no art. 496 deste Código, não se pode conceber que os outros atos do juiz sejam imunes ao reexame pertinente”.¹⁴¹

Embora, regra geral, não caiba recurso contra despachos, conforme preceitua o art. 1.001, CPC/2015, José Olympio de Castro Filho entende pela possibilidade de interposição de recurso de Agravo de Instrumento contra despachos que manifestem conteúdo decisório, tais como providências ou determinações do magistrado, dentro da jurisdição voluntária, desde que suscetíveis de afetar o interesse perquirido.¹⁴² Como exemplo, cita: “6. ° despacho que, na arrecadação da herança jacente, autoriza a alienação de bens (art. 1.155)”.¹⁴³

Ademais disso, se são passíveis de recursos que admitem reconsideração, nada obsta o exercício do juízo de retratação pelo magistrado, como é o caso do agravo de instrumento. É que, superada a discussão sobre a recorribilidade das decisões em jurisdição voluntária, não há razão para se aplicar aos recursos apenas parte de sua disciplina.

O interesse recursal decorre da sucumbência, aqui analisada em sentido amplo, quer por ter havido julgamento de mérito, quer por ter sido decidida questão incidental. Embora nos procedimentos de jurisdição voluntária a ausência de litígio afaste, de um modo geral, a sucumbência, é possível vislumbrar hipóteses em que o interesse recursal é evidente. É caso, por exemplo, da decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça, a desafiar recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, inc. V).

A despeito dos debates sobre a ocorrência/inocorrência de preclusão e coisa julgada, fato é que o interessado pode pretender que os efeitos da decisão proferida, que se lhe são prejudiciais, sejam imediatamente cessados, tal como se daria no exemplo acima.

Eduardo J. Couture sugere a apreciação a partir da economia processual (desgaste de energia e custos) e do contraste entre alternativas procedimentais ou processuais. O que é mais econômico para chegar-se ao resultado? Permitir-se que a decisão seja revista por recurso ou por uma nova ação judicial?¹⁴⁴

3.2 Efeitos da apelação

A regra do CPC/1973 e também a do CPC/2015 é a de que o recurso de apelação será recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. Contudo, parte da doutrina tende a fazer séria distinção quando o tema é jurisdição voluntária.

Sobre o tema, Alcides de Mendonça Lima pontua que a apelação “somente deva ser [recebida] no [efeito] devolutivo, apesar de não ser inserida na hipótese na segunda parte do art. 520, deste Código [CPC/1973, correspondente ao art. 1.012 do CPC/2015], conforme os respectivos incisos”.¹⁴⁵ Para tanto, sustenta que “pelas peculiaridades da jurisdição voluntária, o efeito suspensivo é implicitamente excluído. Não se trata de conferir ao juiz o poder para *ex vi* do art. 1.109, receber, ou não, em ambos os efeitos, conforme as circunstâncias da causa, por ser solução mais ‘conveniente ou oportuna’. Consideramos que, sempre, a apelação somente pode ser recebida no efeito devolutivo ou, de outro modo, sem efeito suspensivo, caindo assim na exceção”.¹⁴⁶

Dessa forma, conclui que o rol do art. 520 do CPC/1973 (atual § 1.º do art. 1.012 do CPC/2015) é exemplificativo, sem que esgote todas as possibilidades que afastam o efeito suspensivo.

Com o devido respeito ao jurista, e com base na lei processual vigente, é de entender somente nos casos expressos em lei é que a apelação não será recebida em efeito suspensivo. É o que se denota do art. 1.012, *caput e* § 1.º, do CPC/2015 ao dizer que “a apelação terá efeito suspensivo” e que “além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação” nos casos nos incs. I ao VI daquele dispositivo.

Aliás, do inc. VI recai a única hipótese expressamente prevista no CPC/2015 de procedimento de jurisdição voluntária em que a sentença não terá efeito suspensivo, qual seja, no caso de decretação de interdição.

É de se considerar, todavia, o posicionamento adotado por Edson Prata, porquanto pautado em indiscutível razoabilidade. Entende o jurista que “a apelação poderá ser recebida em ambos os efeitos, tudo dependendo da conveniência ou oportunidade, avaliada criteriosamente pelo magistrado”.¹⁴⁷ É

que, como visto, o juiz não está adstrito à legalidade estrita, pelo que a combinação dos arts. 1.012 e 723 do CPC/2015 parece solucionar o problema sem maiores complicações. Assim, poderia o magistrado, segundo a conveniência ou oportunidade, determinar sob quais efeitos a apelação deverá ser recebida.

Além do cabimento da apelação que está consagrado desde o *CPC/1973* (art. 724 do *CPC/2015*), a recorribilidade está associada à sucumbência ou ao prejuízo, sem os quais não se cogita recursos contra decisões judiciais, pela possibilidade de remessa necessária, art. 496 do *CPC/2015*, sendo sucumbente ou condenada a Administração Pública. Para isso devem estar presentes no procedimento especial de jurisdição voluntária algum ou alguns dos entes indicados no *inc. I* do referido dispositivo: a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, observadas, contudo, as limitações quantitativas do § 3º do mesmo artigo, *incs. I, II e III*, além daquelas restritivas de reexame contidas nos incisos do § 4º do mesmo art. 496.

3.3 Preclusão

Na jurisdição voluntária, não se aplica os efeitos da revelia, conforme anteriormente apontado, pelo que também se entende não ser cabível a aplicação dos efeitos da preclusão de forma rígida, como na jurisdição contenciosa.

Quanto ao tema, Alcides de Mendonça Lima conclui que “em princípio, a preclusão se opera ainda que não de forma rígida, como na contenciosa”. A título de exemplo, cita o indeferimento de prova, sem que o interessado agrave de instrumento, em qualquer de suas modalidades. Assim, esclarece que, na jurisdição contenciosa, dificilmente a prova será produzida, embora o juiz possa mandar fazê-lo, de ofício, ainda que à parte não caiba o direito de insistir. Por outro lado, na jurisdição voluntária, dependendo das circunstâncias, o interessado que tenha perdido o prazo poderá tentar a produção, sem que a rigor se possa falar em preclusão. ¹⁴⁸

Aqui, novamente, se invoca a prerrogativa do art. 723, pelo que o juiz poderá reexaminar o assunto sem que se atenha aos efeitos da preclusão. ¹⁴⁹

Cumprе ressaltar, todavia, que as “decisões” de jurisdição voluntária, embora não produzam coisa julgada material, produzem coisa julgada formal. Desse modo, caso tenha transcorrido *in albis* o prazo para interposição do recurso de apelação, poderá ser que ocorra a coisa julgada processual, de forma que não mais será possível rediscutir a matéria nos mesmos autos. Poderá o interessado, contudo, ingressar com novo pedido em procedimento distinto.

3.4 Coisa julgada formal

Dispõe o art. 337, § 4.º, que há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Bem esclarecem Nelson Nery e Guilherme Marinoni que, para que haja o trânsito em julgado impeditivo de nova demanda idêntica, é necessário que a sentença em questão, contra a qual não cabe mais recurso, seja meritória. ¹⁵⁰

Aqui é de se distinguir duas espécies de coisa julgada, quais sejam, a formal e a material. Diz-se formal quando, por decurso ou renúncia do prazo recursal, o interessado perde a faculdade de impugnar a decisão proferida naqueles mesmos autos como consequência da preclusão. Diz-se material quando matéria decidida já não pode mais ser discutida nem nos autos em que proferida a sentença, nem em qualquer outro processo, quer por interesses das partes, quer por vontade do juiz ou qualquer interveniente.

Os procedimentos de jurisdição voluntária fazem coisa julgada formal, mas não fazem coisa julgada material. Era o que previa expressamente o art. 1.111 do *CPC/1973*, segundo o qual a sentença poderia ser modificada, sem prejuízo dos efeitos já produzidos, se ocorrerem circunstâncias supervenientes que justificassem sua alteração, a exemplo de cessação da causa incapacitante que justificou a interdição. Daí decorria, logicamente, a impossibilidade e/ou desnecessidade de ajuizamento de ação rescisória, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal. ¹⁵¹

O *CPC/2015* não reproduziu a regra do revogado art. 1.111. Sobre esse ponto, esclarece Bruno Freire e Silva sendo a jurisdição voluntária consubstanciada em atividade eminentemente administrativa, em que o ato final será de homologação, aprovação ou autorização, consolidou-se o entendimento pela inexistência de coisa julgada material. ¹⁵²

Por esse motivo, sustenta que, sob a vigência do CPC/1973, a doutrina apontava que após o trânsito em julgado formal seria cabível ação anulatória, aplicável à desconstituição dos atos jurídicos em geral, prevista no art. 489 do código revogado. Mesmo com a entrada em vigor da nova lei processual, apesar de inexistir dispositivo semelhante ao art. 1.111, continua-se entendendo pelo cabimento de ação anulatória em tais hipóteses, com respaldo no art. 966, § 4.º, do CPC/2015. ¹⁵³

O jurista ressalta, contudo, que aquele § 4.º deve ser interpretado de forma coerente com todo o ordenamento processual, de modo que se o pronunciamento jurisdicional não se limitar à homologação, mas resolver mérito e transitar em julgado, será cabível a ação rescisória.

Segundo boa parte da doutrina, as decisões da jurisdição voluntária não fazem coisa julgada. ¹⁵⁴ (Ver *Breve Ensaio Inicial*)

Segundo Alfredo de Araújo Lopes da Costa: “Não há ação rescisória. A ação rescisória é ação contra a coisa julgada. E aqui não há coisa julgada”. ¹⁵⁵

O debate sobre o meio de desconstituir as sentenças da jurisdição voluntária é objeto de histórico debate na doutrina, tendo se mantido vivo na vigência do CPC/1973 e, certamente, manter-se-á nos próximos tempos.

A bifurcação entre uma e outra hipótese, entre anulabilidade por ação anulatória (art. 966, § 4.º) e rescindibilidade por ação rescisória (art. 966, incs. I a VIII) esteve, está e estará associada à identificação ou não nesses modelos procedimentais *não contenciosos*, de jurisdição, processo, lide, sentença de mérito e coisa julgada material.

Sérgio Rizzi é categórico: “todas as sentenças proferidas em procedimentos de jurisdição voluntária são irrevogáveis. Na jurisdição voluntária não há processo, não há lide, não há sentença de mérito, não há coisa julgada material”. ¹⁵⁶

Art. 725 . Processar-se-á na forma estabelecida nesta Seção o pedido de:

I – emancipação;

II – sub-rogação;

III – alienação, arrendamento ou oneração de bens de crianças ou adolescentes, de órfãos e de interditos;

IV – alienação, locação e administração da coisa comum;

V – alienação de quinhão em coisa comum;

VI – extinção de usufruto, quando não decorrer da morte do usufrutuário, do termo da sua duração ou da consolidação, e de fideicomisso, quando decorrer de renúncia ou quando ocorrer antes do evento que caracterizar a condição resolutória;

VII – expedição de alvará judicial;

VIII – homologação de autocomposição extrajudicial, de qualquer natureza ou valor.

Parágrafo único. As normas desta Seção aplicam-se, no que couber, aos procedimentos regulados nas seções seguintes.

1. Inovações do CPC/2015

Por certo a mais importante inovação trazida neste dispositivo é a introdução de novas hipóteses de procedimentos, embora não detalhados como os procedimentos típicos do CPC (arts. 726-770), mas sujeitos às “ordens normativas” contidas nas Disposições Gerais da própria Jurisdição Voluntária e nas demais partes do CPC/2015, aplicáveis a estes procedimentos indicados no art. 725, tal como a Parte Geral (arts. 1.º-317), as normas do Livro I da Parte Especial (arts. 318-538), Livro II, Execução (arts. 771-928) e Livro III, Recursos e ações (arts. 929-993).

As novas hipóteses introduzidas são a expedição de alvará judicial (art. 725, inc. VII); e a homologação

de autocomposição extrajudicial, de qualquer natureza ou valor (art. 725, inc. VII).

A primeira delas, expedição de alvará judicial (art. 725, inc. VII), tinha trânsito há muito na praxe forense, seja por analogia ou por modalidade prevista na Lei 6.858/1980, especificamente “para pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares” dos “valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP” (art. 1º).

A segunda delas, homologação de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza ou valor (art. 725, inc. VII), tem ainda maior relevância. Por ela permite-se uma compreensão mais ampla acerca do instituto da *conciliação*, vista, a partir de então, também como um ato de jurisdição voluntária.

Conciliação é a forma consensual de pôr fim a um conflito de interesses, o que se dá por diversos meios, tais como a desistência, a renúncia, o reconhecimento do direito ou a transação. Pode se dar de forma *preventiva* (ou *pré-processual*) e *sucessiva* (ou *endoprocessual*), conforme o momento de sua realização, bem como no ambiente jurisdicional ou administrativo. Agora foi trazida para a jurisdição voluntária, em parte, atendendo ao que já sugerira Alfredo Araújo Lopes da Costa há décadas.¹⁵⁷

Nem todos os atos de *conciliação*, independentemente do momento de realização e da intensidade da participação do órgão jurisdicional, podem ser catalogados como atos de jurisdição voluntária. José Frederico Marques propusera o critério de Alcalá Zamora y Castillo, identificando como jurisdição voluntária o ato de conciliação que antecede ao procedimento¹⁵⁸ que o reconhece ou homologa.

Admitir-se-á agora que ocorram as partes com seu acordo extraprocessual, obtido antes de ingressarem com o pedido de homologação, em que tenham obtido a solução consensual ou conciliação de controvérsias envolvendo interesses privados ou interesses públicos especiais transigíveis e disponíveis. Certamente se admitirá também a suspensão do processo contencioso em curso, para a possível obtenção de solução consensual. Essa possibilidade está relacionada à *transigibilidade*¹⁵⁹ de interesses públicos, à *transigibilidade e disponibilidade de valor limitado* desses interesses e à *transigibilidade e disponibilidade de valor não limitado* da Administração Pública.

Desde a década de 1990 vêm se ampliando as possibilidades de solução alternativa de conflitos na Administração Pública, com sucessivas normas (especialmente federais) que autorizam, de forma limitada, e até mesmo de forma ampla a conciliação, a transação, a arbitragem¹⁶⁰ e a mediação¹⁶¹ para tal finalidade, entre outras técnicas antes admitidas apenas para resolução de disputas patrimoniais entre particulares.

As outras alterações são de redação, especialmente na *alienação, arrendamento ou oneração de bens de crianças ou adolescentes, de órfãos e de interditos* (art. 725, inc. III), na qual a expressão *menores* é substituída pela atual correspondente, a saber, “crianças e adolescentes”. Houve ainda alteração na *extinção de usufruto*, agora restrita aos casos em que “não decorrer da morte do usufrutuário, do termo da sua duração ou da consolidação” no de *fideicomisso*, nos casos em que “decorrer de renúncia ou quando ocorrer antes do evento que caracterizar a condição resolutória” (art. 725, inc. IV).

2. Aspectos materiais dos demais procedimentos especiais de jurisdição voluntária previstos no art. 725

O objeto material destes procedimentos, como dito acima, é dos mais variados, tendo em vista a diversidade das matérias abordadas em cada procedimento. Por esse motivo serão trabalhados individualmente nas linhas que se seguem.

Não há critérios comuns e seguros que permitam agrupar cada uma dessas espécies de procedimentos. Considerando que o rol do art. 725 é não taxativo, torna-se ainda mais difícil identificar as demais situações que se ajustem conceitualmente à jurisdição voluntária para estabelecer regras próprias de agrupamento.

Mantém-se uma clara afinidade e predominância entre situações que envolvem direito privado, nos quais há interesse estatal que restringe a livre atuação da autonomia da vontade ou no qual há interesse de sujeitos especiais que mereçam proteção, tal como menores, absolutamente incapazes, ou outros sujeitos relativamente incapazes. Exceção a este largo campo de direito privado é a possibilidade de conciliação de interesses públicos que admitam transação (art. 725, inc. III).

3. Aspectos processuais e procedimentais

Já foi dito que há “três ordens normativas” que regulamentam os procedimentos de jurisdição voluntária. Uma delas são as normas gerais contidas nos arts. 719-724, que se aplicam tanto aos procedimentos típicos dos arts. 726-770, como aos procedimentos do rol não taxativo art. 725, por “não estabelecer procedimento especial” (art. 719). Aplicam-se também, subsidiariamente ou no que couber, aos procedimentos esparsos de leis especiais integrantes da jurisdição civil.

3.1 O rol exemplificativo do art. 725

De início, repita-se que os procedimentos aqui descritos são exemplificativos, não tendo o legislador esgotado todas as situações da vida que estão submetidas à jurisdição voluntária.¹⁶² Outro argumento que corrobora a não taxatividade do rol do art. 725 é o acréscimo de dois novos procedimentos agora incorporados, quais sejam: *a expedição de alvará judicial* (art. 725, inc. VII) e *a homologação de autocomposição extrajudicial, de qualquer natureza ou valor* (art. 725, inc. VIII).

Exemplos de procedimentos não capitulados nesse artigo são: a) o suprimento judicial ou *outorga uxória*, previsto no art. 74 do CPC/2015 e art. 1.567, *caput*, e par. único, art. 1.648, do CC/2002; b) o consentimento para casamento, previsto nos arts. 1.517 e 1.519 do CC/2002, sendo a competência do juiz da infância e adolescência, quando envolvido algum menor, nos termos do art. 148, parágrafo único, alínea c, do Estatuto da Criança e do Adolescente; c) a homologação de casamento nuncupativo, previsto no art. 1.540 do CC/2002; d) a dispensa de impedimento de parentesco para casamento, previsto no Decreto-lei 3.200/1941, arts. 1.º e 2.º; e) a verificação de gravidez, prevista nos arts. 2.º, 1.779 e 1.901 do CC/2002.¹⁶³

Entendeu o legislador, manter o silêncio em relação aos demais procedimentos não previstos pelo Código de Processo Civil (art. 725), acrescentando apenas duas novas hipóteses, como se observa do quadro acima. Assim, entende-se que as situações não previstas nesse rol, bem como as descritas no artigo ora em análise, estão submetidas às regras gerais descritas nos arts. 719 a 724.

Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni observa que “de um modo geral, o procedimento comum de jurisdição voluntária serve para tutela de posições jurídicas ainda não reconhecidas expressamente pelo legislador infraconstitucional”.¹⁶⁴ Embora se mostre solução acertada, discutem alguns autores e diverge parcela da jurisprudência se os juízes estariam desobrigados de atuar nos casos em que não haja previsão no CPC, por entenderem que os procedimentos de jurisdição voluntária estão ancorados a um sistema *numerus clausus*, sem margem para interpretações ampliativas ou integração por analogia.¹⁶⁵

Sobre o tema, Alcides de Mendonça Lima, em comentários ao CPC/1973, afirmou que, ao tentar simplificar a matéria enumerando alguns procedimentos regulamentados pelo Código Civil e submetendo-os às regras gerais da jurisdição voluntária, bem como disciplinando, de forma autônoma, apenas aqueles previstos nas seções correspondentes (II a XII do Capítulo XV, Parte Especial, Livro I, CPC/2015), o legislador não conseguiu solucionar o problema. Isto porque, procedendo dessa maneira, não se atentou ao fato de que os procedimentos, por diversificados que são, demandam tratamento especial, tanto quanto os considerados autônomos descritos de forma individualizada nas seções seguintes, sendo “impossível dar denominador comum às seis espécies inseridas neste artigo. Isso porque cada uma traz consigo peculiaridades próprias e muito acentuadas, sem que as Disposições Gerais possam servir a todas”.¹⁶⁶

Lima sustenta ainda que o ideal teria sido aperfeiçoar o regime anterior (CPC/1939), sistematizando os vários procedimentos existentes, bem assim melhorar suas redações e suprir as falhas porventura existentes. Conclui dizendo que as Disposições Gerais deveriam ter findado no art. 1.111, e somente depois, além dos atuais capítulos II a XI, deveriam ter sido acrescidos outras regras abrangendo as matérias dos incisos desse artigo.

Segue dizendo que, da maneira como se acha redigido o texto, as lacunas são imensas, ficando sua aplicabilidade ao sabor de interpretações, prejudicando a uniformidade de entendimento pelos juízes e, por via de consequência, a atividade dos advogados, com reflexos nos interesses dos clientes. Nunca se pode ter certeza de qual a solução mais adequada dentro da lei, por falta de diretriz precisa, sendo certo que “a divergência jurisprudencial já se está manifestando sobre algumas questões, exatamente pela ausência de preceito expresso no direito positivo vigente, solvendo-as”. O jurista cita como exemplo “a possibilidade, ou não, da venda de bem imóvel inalienável ser depositada em caderneta de poupança, ou ter de ser, obrigatoriamente, aplicado na compra de outro”.¹⁶⁷

Pelo que se extrai da redação do vigente art. 725, essas sugestões não foram acolhidas pelo legislador no CPC/2015.

3.2 Competência

Tendo em vista não haver previsão expressa quanto à fixação de competência nos procedimentos de jurisdição voluntária, devem ser aplicadas as regras gerais previstas nos arts. 42 a 66 do CPC/2015.

Via de regra, a competência é da Justiça Estadual por meio de suas varas especializadas, de competência cumulativa ou de competência plena, essa última mais comum em municípios menores. Pode ainda ser competente a Justiça Federal, desde que haja interesse da União, como no caso da herança jacente que tem como eventual herdeiro o Município, o Distrito Federal ou a União, nos termos dos arts. 738 a 743 do CPC/2015 e art. 1.822 do CC/2002.

A competência poderá ser absoluta em razão da matéria, a depender da existência de vara especializada, conforme Código de Organização Judiciária ou lei especial de cada Estado. Caso contrário, se a competência da comarca for cumulativa, esta será relativa.

Para Alcides de Mendonça Lima não é possível o ingresso de igual pedido em juízo antes do trânsito em julgado formal, sob pena de litispendência, assim como na jurisdição contenciosa, nos termos do art. 337, § 3.º, do CPC/2015, que poderá ser arguida em “resposta” por qualquer interessado, conforme art. 337, inc. V, do CPC/2015. Ocorrendo conexão ou continência, nos termos dos arts. 55 e 56, o juiz deverá proceder nos termos dos arts. 55, § 1.º e 58, todos do CPC/2015, em razão da competência fixada pelo juízo prevento, nos termos do art. 59, do CPC/2015. ¹⁶⁸

A competência poderá ser, ainda, relativa, como é na maioria dos casos em que os feitos são ajuizados fora das capitais do Estado, porquanto não costumam possuir varas especializadas. Nesses casos, devem ser observadas as regras dos arts. 46 a 50 do CPC/2015, com as devidas adaptações. ¹⁶⁹

Alcides de Mendonça Lima afirma que “na jurisdição voluntária a competência nunca é firmada em razão do valor”, sendo que “somente influi: a) excepcionalmente, a pessoa (União interessada – justiça Federal); b) ‘a matéria’ (havendo vara especializada); c) a ‘situação da coisa’ (referente a imóvel); d) o domicílio (que é típica relativa)”. O autor faz ressalva em relação a este último caso por não haver, nos procedimentos voluntários, a figura do réu, sendo “imprescindível ajustar o alcance da regra a estes feitos”, entendendo o mesmo em relação ao foro da situação da coisa, nos termos do art. 47, § 1.º. Isso porque, na jurisdição voluntária, em regra, o foro do domicílio é o do requerente. ¹⁷⁰

Não sendo o valor da causa um critério válido para a definição de competência, é de se concluir, inicialmente, que os procedimentos de jurisdição voluntária não terão lugar nos juizados especiais. A jurisprudência é farta nesse sentido, embora haja julgados em sentido contrário em hipóteses pontuais.

Nessa linha divergente há, dentre outros precedentes, do órgão pleno do Tribunal Regional da 5.ª Região, no qual a corte firmou o entendimento, por maioria de votos, de que os feitos sujeitos ao procedimento de jurisdição voluntária não estão expressamente excluídos da competência atribuída aos Juizados Especiais Federais Cíveis, tais como as ações arroladas no § 1º do art. 3.º da Lei 10.259/2001 e no parágrafo 2.º do art. 3.º da Lei 9.099/1995, de modo que podem ali ser processados. ¹⁷¹

Apresentadas as regras gerais, cumpre destacar que os critérios para fixação de competência serão melhor explanados no tratamento de cada um dos casos descritos pelo art. 725. Dada a variedade de procedimentos, merecem exame individuado

3.3 Emancipação

Nos termos do art. 1.635, inc. II, do CC/2002, a emancipação é causa extintiva do poder familiar e, conforme art. 5.º, parágrafo único, do mesmo código, é causa aquisitiva, em favor do menor, da capacidade para a prática dos atos da vida civil.

Em determinados casos poderá demandar a apreciação do Judiciário, quando, então, terá lugar o procedimento de emancipação de que trata o art. 725, inc. I, do CPC/2015.

3.3.1 Conceito e características

Na concepção de Clovis Beviláqua, emancipação é a “aquisição da capacidade civil antes da idade

legal”.¹⁷² Assim, admite-se, tradicionalmente, que, mesmo sob a menoridade, seja declarada a capacidade daquele que cumpriu uma ou mais das hipóteses previstas nos incs. do art. 5.º, parágrafo único, do CC/2002, desde que à época possuísse, pelo menos, 16 anos de idade.

Pontes de Miranda critica a utilização do termo emancipação para denominar o ato de suplemento de idade. Em sua obra, autor afirma que “quem emancipa (*emancupo*) põe fora do seu poder, por *mancipatio* . Não pode suplementar idade, porque isso pertence ao Príncipe, ao Estado. (...) O suplemento da idade completa a ‘idade’ do menor para tornar ‘maioridade’. Tal o que diz a expressão (‘suplemento’) e tal o conceito jurídico. É a *venia aetatis* , que nem sempre ocorria com a *emancipatio* ”.¹⁷³

Essa crítica se dá em razão de equívoco legislativo na terminologia utilizada, que não estaria presente apenas no CPC/1973, mas se repetiu na nova lei. O erro consiste, basicamente, em denominar o procedimento para suplemento de idade como “emancipação”, tendo em vista que, segundo os “velhos escritores”, os quais melhor pensavam e analisavam os termos antes de empregá-los de forma “pouco atenta”, a expressão se refere a “ato divestitivo do titular do pátrio poder, que permite continuar a pessoa sob tutela de outrem”, sendo que o ato que suplementa a idade, em verdade, seria a “*venia aetatis* ”.¹⁷⁴

Embora válida a crítica, o termo estabelecido pelo legislador para designar o ato de suplemento é a “emancipação”, que, segundo entendimento majoritário da doutrina, pode-se ser declarada de duas formas: a) por registro em cartório da declaração, por meio de instrumento particular ou público, de vontade dos detentores do poder de família (pai e mãe, ou um dos dois na falta do outro) ou do requerimento ao escrivão, desde que tenha cumprido ao menos um dos requisitos elencados nos incs. II a V do parágrafo único do art. 5.º do CC/2002; b) por sentença.

Adiante se analisará, com maiores detalhes, o cabimento do procedimento especial aqui tratado.

3.3.2 Aspectos materiais do procedimento de emancipação

O CC/2002 estabelece que são incapazes (relativa ou absolutamente) para os atos da vida civil, dentre outras pessoas, os menores de 18 anos (art. 3.º c/c art. 4.º). Diz ainda que a menoridade cessa aos 18 anos (art. 5.º, *caput*) completos, quando então se adquire a capacidade civil plena. Logo, a incapacidade em razão da idade cessa, em regra, com a maioridade.

Apesar dessa regra geral, a lei material previu, como já esclarecido, que a incapacidade por idade poderá cessar antes da maioridade. Isso se dá pela emancipação, no caso dos maiores de 16 anos e menores de 18, e nas seguintes circunstâncias: I) pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos; II) pelo casamento; III) pelo exercício de emprego público efetivo; IV) pela colação de grau em curso de ensino superior; V) pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com dezesseis anos completos tenha economia própria. São essas, portanto, as hipóteses legais disciplinadas pela norma material para emancipação.

Assim, segundo José Olympio de Castro Filho, a homologação do juiz somente é dispensável quando a emancipação decorre do próprio fato em si, como no casamento (cujo instrumento público que faz prova do ato é a certidão de casamento), exercício em cargo público (certidão pública respectiva) ou colação de grau científico em curso superior (o diploma é documento público). Nos demais casos, a dispensa é inadmissível, pois não haveria meio prático de provar o preenchimento dos requisitos legais, como no caso de estabelecimento civil ou comercial (exceto na hipótese de existência de registro na Junta Comercial, onde será possível a prova) ou de economia própria, que exigiria justificação ou comprovação suprida apenas por apreciação do juiz.¹⁷⁵

3.3 Aspectos processuais e procedimentais da emancipação

Nesse tópico serão analisadas as espécies de emancipação, a recorribilidade da decisão do juiz, a possibilidade de produção de provas, o cabimento de recursos, dentre outras questões.

3.3.3.1 Espécies de emancipação

Para João Paulo Lucena a emancipação, conforme sua motivação, poderá ser de três espécies: a) voluntária; b) legal; e c) judicial.

A emancipação voluntária é aquela concedida por meio de escritura pública pelos pais, detentores do poder familiar, ao filho menor de 18 anos e maior de 16. ¹⁷⁶ Está prevista na primeira parte do inc. I do parágrafo único do art. 5.º, do CC/2002.

José Olympio de Castro Filho ressalta que existia, anteriormente, discussão quanto à necessidade de homologação judicial na concessão de emancipação pela espécie voluntária, nos termos do § 2.º art. 16 do Decreto 4.857/1939. Porém, prevaleceu o entendimento jurisprudencial de que, neste caso, não se faz necessária a intervenção judicial, sendo suficiente a manifestação de vontade, que deverá ser externada via escritura pública em cartório de Registro Público, entendimento que encontrou ainda maior respaldo nos arts. 89 a 91 da Lei dos Registros Públicos (Lei 6.015/1973). ¹⁷⁷

Diz-se legal aquela prevista no art. 5.º, parágrafo único, incs. II a V, do CC/2002. O código elegeu tais situações como sendo, por si só, suficientes para se garantir a emancipação, prescindindo de qualquer manifestação de vontade para declaração do efeito ora discutido. A comprovação da subsunção da circunstância fática, a pelo menos uma das hipóteses legais pertinentes, será feita por meio de documentos e/ou testemunhas, com posterior averbação no Registro Civil do emancipando, para que tenha efeito *erga omnis*. ¹⁷⁸

Repitam-se aqui as considerações de José Olympio de Castro Filho, segundo as quais se dispensará a homologação judicial no caso em questão apenas no tocante aos procedimentos em que haja prova “bastante e eficaz”, como, por exemplo, a certidão de casamento, do exercício de cargo público ou de colação de grau científico em curso de nível superior. Será necessária a homologação nos casos em que não houver meio prático de provar o preenchimento dos requisitos legais. ¹⁷⁹

Por fim, a emancipação judicial consta da segunda parte do art. 5.º, parágrafo único, inc. I, do CC/2002. Via de regra, é o próprio tutor que requer o procedimento, a fim de tornar capaz o menor sob sua responsabilidade. Para tanto, necessita da homologação judicial, pois, diferentemente da emancipação voluntária, o tutor não detém poder de família. Nada obsta, contudo, que a ação seja intentada pelo próprio menor. Em todos os casos, será necessário que o emancipando tenha, pelo menos, 16 anos completos.

Está claro, portanto, que no que importa ao estudo dos procedimentos especiais de jurisdição voluntária, apenas se analisará nas linhas seguintes os casos que dependem de decisão do juiz para que a emancipação possa ter validade e ser eficácia.

Nelson Nery enumera outras hipóteses em que o pedido de emancipação deverá ser deduzido em juízo, mediante procedimento de jurisdição voluntária, quais sejam, nos casos de divergência entre os pais sobre a emancipação do filho e para se suprir o consentimento necessário ao casamento. ¹⁸⁰

3.3.3.2 Capacidade processual do menor

Via de regra, o menor não possui capacidade para estar sozinho em juízo (capacidade processual), razão pela qual deve ser assistido por seus pais, tutor ou curador, nos termos do art. 71, do CPC/2015. É possível, ademais, que lhe seja nomeado curador especial quando não tiver representante legal, ou se seus interesses colidirem com os daqueles, nos termos do art. 72, inc. I, do CPC/2015.

Nem o CPC/1973, nem o CPC/2015 trataram da capacidade processual do menor que pretenda sua emancipação. Daí resultam algumas divergências doutrinárias.

Para João Paulo Lucena, a iniciativa poderá partir do menor, caso em que lhe será nomeado tutor *ad hoc* (nomeado) se já não possuir um previamente. ¹⁸¹ Logo, não estaria dispensada a assistência processual para que pudesse ingressar em juízo.

Em sentido contrário, José Olympio de Castro Filho sustenta que o sistema adotado para o processo, em geral, *não funcionará no procedimento de jurisdição voluntária, pois aqui haverá de reconhecer a capacidade processual do menor de 18 anos e maior de 16 anos que desejar a emancipação judicial. A nomeação de curador especial exigiria um procedimento preparatório*, e ainda ficaria ao critério deste iniciar o procedimento de emancipação. Desse modo, defende que a solução seria que o menor pudesse ingressar em juízo como se plenamente capaz fosse. É o que chamamos de “uma capacidade processual *sui generis*, que se justifica por se estar tratando do exercício de um direito-emancipação pela vontade do maior de 16 anos, que poderá estar em juízo, mediante outorga de mandato a advogado (art. 36)”. ¹⁸²

No mesmo sentido é o entendimento de Pontes de Miranda, para quem o menor, desde que tenha alcançado a idade mínima de 16 anos, gozará de capacidade processual.¹⁸³ Assim não haveria que se falar de aplicação dos artigos 8.º e 9.º do CPC/1973, atuais arts. 71 e 72 do CPC/2015, tendo em vista que “a própria lei supõe que haja capacidade processual, porque o que se pede é a declaração da capacidade de direito material”.¹⁸⁴

Alcides de Mendonça Lima também afirma que, mesmo sem norma expressa, mas por uma questão de bom senso, aquela formalidade deverá ser dispensada, pois certamente dificultaria ou impossibilitaria o menor obter a anuência do tutor, com recusa justa ou injusta. Por este motivo, faculta-se que o menor promova a emancipação, mesmo sem consentimento do tutor, que não o assistiu na outorga do mandato profissional”.¹⁸⁵

Por outro lado, Lima nega a possibilidade de o menor, sob poder familiar, requerer sua emancipação, sendo esta atribuição exclusiva dos pais (art. 1.631, do CC/2002). Ocorre que, se o menor acusar o pai ou a mãe de fatos que possam comprometer o poder de família, compete ao juiz, após apresentação de prova contundente, decretar a destituição do poder familiar e nomear-lhe tutor. Após, poderá ser provocada a emancipação judicial pelo menor.¹⁸⁶

Assim, afigura-se mais razoável que, naqueles casos em que o menor requerer sua emancipação judicial, não será necessária a observância da regra geral contida nos arts. 71 e 72, inc. I, do CPC/2015, sendo-lhe reconhecida a capacidade processual *sui generis*, nos termos do art. 70, do CPC/2015.

3.3.3.3 O juízo competente

O juízo competente será o da regra geral dos procedimentos voluntários, qual seja, o do interessado requerente, sendo o foro de sua residência e não o do seu nascimento, no caso.¹⁸⁷

Nelson Nery afirma que para o pedido de emancipação feito pelo pupilo, competente é o foro do domicílio do tutor (art. 76, parágrafo único, CC/2002 c/c art. 147, inc. I, do ECA); para a emancipação pedida por um dos genitores em razão de discordância do consorte, o domicílio do casal (art. 147, inc. I, ECA); nas hipóteses de não serem casados, ou de estarem separados ou divorciados, o foro competente é o daqueles sob cuja guarda o menor se encontra (art. 147, inc. I, ECA); o foro do lugar onde os menores se encontram, nos demais casos (art. 147, inc. II, ECA).¹⁸⁸

Assim, conclui o jurista, as disposições devem servir de parâmetro para a fixação da competência do juízo da família, para os casos que devam por lá ser processados.

3.3.3.4 As provas

De um modo geral, para a concessão da emancipação será necessário: 1) prova da idade mínima; 2) prova de que o menor tem o necessário discernimento para reger sua pessoa e administrar seus bens.¹⁸⁹ No caso, se o requerente for o tutor, estará submetido aos mesmos ônus.

Aqui são cabíveis todas as provas admitidas em direito, embora algumas espécies tenham menor grau de utilidade. O requerente poderá fazer uso de provas documentais, não sendo indispensável a oitiva de testemunhas.¹⁹⁰

Não basta apenas a demonstração de boa conduta ou a exibição do currículo escolar do menor, podendo se valer o requerente, inclusive, de prova pericial.¹⁹¹ Aqui tem lugar exame psicológico, por exemplo, de modo a se aferir a aptidão do menor para gerir sua vida pessoal e exercer livremente todos os atos da vida civil.

3.3.3.5 Impugnação

Deverá ser citado o tutor, bem como intimado o Ministério Público (art. 721 c/c art. 179, ambos do CPC/2015) para que, querendo, se manifestem no prazo de 15 dias. Poderão “impugnar o pedido, alegando a falta de idoneidade do menor e provando-a”, caso em que será aberto novo dia para apresentação de provas do ente ministerial e/ou do tutor.¹⁹²

3.3.3.6 Audiência do menor

Havendo alegações e provas, será ouvido o menor, nos termos do art. 374 do CPC/2015. Afinal, de sua

oitiva podem resultar elementos determinantes para que o juiz firme seu convencimento. De seu depoimento será possível auferir os sinais manifestos de maturidade psíquica e aptidão para a gestão própria, bem assim eventuais interesses escusos pretendidos pelos genitores ou tutores, capazes de prejudicar os interesses do menor.

3.3.3.7 Força eficaz e elemento mandamental da decisão

Decidindo o juiz pela emancipação, os seus efeitos entre tutor e tutelado começam com o trânsito em julgado formal da sentença, que será constitutiva, devendo o juiz comunicá-la, de ofício, ao oficial de registro, se não constar dos autos haver sido efetuado este dentro de oito dias, nos termos do art. 91 da Lei 6.015/1973.¹⁹³ Somente após o registro público da “decisão” em livro especial, bem como da devida anotação no assento de nascimento (art. 108, § 1.º, da Lei 6.015/1973), é que lhe será conferido o efeito *erga omnis*.¹⁹⁴

Dessa forma, se observa a produção de efeitos da sentença em dois momentos: a) quando do trânsito em julgado formal, momento em que a decisão produzirá seus efeitos entre os interessados e; b) após o seu registro em livro especial no Cartório do 1.º ofício ou da 1.ª subdivisão judiciária da comarca, em cujo foro o procedimento foi ajuizado, bem como da averbação no assento de nascimento, momento em que a sentença produzirá seus efeitos perante a sociedade.

A emancipação faz cessar o poder familiar e a condição de pupilo, extinguindo a tutela e a incapacidade do menor.¹⁹⁵

3.3.3.8 Recurso

Da sentença que defere ou indefere o pedido de emancipação cabe apelação, pelo que deverá obedecer as disposições dos art. 1.009 e seguintes do CPC/2015.

3.4 Sub-rogação

Sub-rogar significa substituir ou colocar no lugar; assumir o que era de outrem ou o que estava em outro bem. As sub-rogações podem ser subjetivas (CC/2002, art. 346) ou objetivas (CC/2002, art. 1.146, par. único; art. 1.449; art. 1.455; art. 1.478; art. 1.659, inc. I; art. 1.668, inc. I; art. 1.674, inc. I; art. 1.719 etc.).

Pode decorrer a sub-rogação de lei (limitação) ou de convenção (restrição). No caso da sub-rogação objetiva ou real, o vínculo é transferido de certo bem ou bens que continham gravame para outro ou outros bens, que toma ou tomam o lugar do primeiro. Tal restrição ou diminuição de vantagens interfere na autonomia privada, “emitindo comandos que amesquinham as prerrogativas do domino”,¹⁹⁶ em atenção a outros interesses também privados.

A sub-rogação prevista no CPC/2015, dentre o rol do art. 725, é sub-rogação objetiva ou real, na qual se transfere por autorização judicial o gravame, o vínculo, a objeção negocial que pesava sobre certo bem, para outro. Em geral, a necessidade de sub-rogação decorre da expectativa de superação da restrição contida nas cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e de incomunicabilidade sobre bens, mediante autorização judicial e diante de justa causa que a justifique (CC/2002, art. 1.848, § 2º).¹⁹⁷

3.4.1 Conceito e características

Pontes de Miranda define, precisamente, a sub-rogação da jurisdição voluntária “como o princípio (...) segundo o qual bem ou bens tomam o lugar de outro ou outros, em substituição jurídica, portanto, submetendo-se ao mesmo regime”. Tem como pressuposto para sua ocorrência: 1) a necessidade de que o bem adveniente entre em patrimônio de que o bem saiu; 2) que o patrimônio ou bem estivesse (esteja) sujeito a regime próprio, sem se confundir com a fungibilidade.¹⁹⁸

Trata-se de instituto que restringe “parte dos apanágios ou atributos” inerentes ao direito de propriedade.¹⁹⁹ Conceitua-se, fundamentalmente, como forma de substituição de coisa ou pessoa por, em regra, outra de igual natureza, que suportará as mesmas condições dispostas anteriormente.²⁰⁰ No caso deste inciso, especificamente, trata-se de substituição real, onde o bem adquirido toma o lugar do outro dado em garantia, ou sobre o qual recaiam ônus ou encargos, submetendo-se ao mesmo regime do substituído.²⁰¹

Em geral, decorre de cláusula de inalienabilidade imposta por lei, doador ou testador, que visa

restringir o poder do proprietário, impedindo-o de alienar ou penhorar o bem gravado. Mas não se trata de cláusula absoluta, podendo ser mitigada por ordem judicial autorizadora, que apreciará o pedido sobre os critérios da conveniência e da necessidade da alienação do bem gravado. Ressalta-se que, caso o doador ou testador queira gravar o bem com cláusula de inalienabilidade e, ao mesmo tempo, vedar a sub-rogação, tal ato não terá eficácia, havendo, ainda, a possibilidade de alienação do bem desde que preenchidos os requisitos anteriormente mencionados.²⁰² Tal medida se justifica em razão da “função social da propriedade”, expressa no art. 182, da CF.

A inalienabilidade gera, como consequência lógica, a impenhorabilidade, nos termos do art. 1.911 do CC/2002, haja vista que a penhora visa sempre obstruir a eventual alienação do bem em hasta pública ou em leilão.²⁰³ Outra consequência da cláusula de inalienabilidade, também prevista no artigo mencionado, é a incomunicabilidade, pois, nas palavras de Alcides de Mendonça Lima, “a comunhão de bens é um modo de um cônjuge estar alienado ao outro, incontinenti, celebrado o casamento, seus próprios bens, e, até, reciprocamente”.²⁰⁴ Nesse sentido, inclusive, a Súmula 49 do STF.²⁰⁵

3.4.2 O requisito material de justa causa

O direito de requerer a sub-rogação não confere, de imediato, o direito a obtê-la. A simples vontade do proprietário não é o bastante para a concessão da sub-rogação, sendo necessária a demonstração de dois, ou pelo menos um, dos requisitos: a) a conveniência do interessado e/ou b) a necessidade de sua alienação, os quais são indispensáveis para o deferimento do pedido,²⁰⁶ definidos na lei como justa causa (CC/2002, art. 1.848, § 2.º).

A cláusula protetiva que incide sobre o bem não possui caráter absoluto, podendo o testador ou doador, por convenção, revê-la. A vedação expressa à sub-rogação imposta pelo testador ou doador não é objeção suficiente a impedir a transferência de vínculo de um bem em outro,²⁰⁷ se presente a justa causa justificadora da alteração.

Eis, portanto, a causa de pedir da sub-rogação, a qual se consubstancia no binômio conveniência/necessidade da medida.

3.4.3 Exigência de procedimento de sub-rogação

Não há como, sem o procedimento especial de jurisdição voluntária, obter-se a sub-rogação. Inexiste, como em outras modalidades procedimentais especiais, a alternativa extrajudicial, seja contratual provada ou por escritura chancelada por tabelião.

Bem pontua Luiz Guilherme Marinoni que o titular de direito real sobre bem imóvel que pretende sub-rogar em outro direito as cláusulas que gravam o primeiro deve se valer deste procedimento.²⁰⁸

Exemplo concreto ressaí do *procedimento de dúvida* no qual o Tribunal de Justiça de São Paulo respondeu que “para a transposição dos gravames, não basta a escritura pública, sendo de rigor a prévia ação judicial de sub-rogação de vínculos, prevista no art. 1.112, inc. II, do CPC, onde será aferida, inclusive, a justa causa a que se refere o § 2.º do art. 1.848 do CC”.²⁰⁹

O procedimento de jurisdição voluntária aqui tratado é, assim, condição sem a qual não poderá haver a sub-rogação real de bem gravado com cláusula de inalienabilidade.

3.4.4 Procedimento e suas fases

A nova concepção estrutural *hexapartida* em fase postulatória, fase organizatória e de saneamento, fase instrutória, fase decisória, fase de cumprimento, e fase recursal ou impugnativa pode ser aqui seguida parcialmente.

3.4.4.1 Fase postulatória

Inicialmente, deve-se definir a competência a partir da análise da origem do gravame a ser transferido para outro bem, a fim de que se possa determinar o foro competente. O bem pode ter sido gravado: a) por força de lei ou doação; b) por testamento. Na primeira hipótese, deve-se considerar o foro de domicílio do interessado, ainda que o bem esteja situado em outro Estado. Na segunda, será competente o foro do juízo do inventário onde foi cumprido o testamento.

A petição inicial deverá obedecer aos requisitos do art. 319 do CPC/2015 (art. 282 do CPC/1973), art. 330 do CPC/2015 (art. 295, CPC/1973) e art. 720 CPC/2015 (art. 1.104, CPC/1973), com exceção das peculiaridades deste procedimento, devendo ser citados todos os interessados, inclusive o doador. O proprietário deverá juntar com a petição inicial os documentos de propriedade do bem e o ato de instituição do gravame, fundamentando suas razões para sub-rogação (necessidade e conveniência) a fim de ter o bem sub-rogado. Além disso, deverão ser juntados os documentos do bem que se pretende adquirir ou permutar,²¹⁰ devendo demonstrar, ainda, que seu patrimônio não será diminuído com a transferência do ônus (justa causa).²¹¹

A sub-rogação, em regra, segue o seguinte procedimento. Primeiro se apresenta o pedido ao juízo competente (v. item 5.3), no qual o interessado deverá demonstrar a conveniência e a necessidade da medida, bem como que seu patrimônio não será diminuído com a nova aquisição e consequente transferência do ônus, o que é essencial.²¹²

Após, será procedida a citação dos outros interessados (como o doador e o testamenteiro, sendo este último, porém, totalmente dispensável) e a intimação do Ministério Público. Alcides de Mendonça Lima afirma que o testamenteiro poderá esclarecer a intenção do testador.

Em seguida, passa-se à avaliação dos dois bens, a fim de se determinar, ao menos, a equivalência entre estes.

3.4.4.2 Fase instrutória

Incumbe ao interessado a prova da necessidade da sub-rogação, de sua indispensabilidade, das vantagens do negócio e das conveniências para o proprietário.²¹³ Aqui também são permitidas todas as provas admitidas em direito, sendo geralmente mais úteis as periciais, para avaliação do bem, e documentais, para demonstração da justa causa, já que as circunstâncias fáticas atreladas ao bem que se pretende liberar e ao que se pretende sub-rogar hão de ser, em geral, formalmente registradas em documentos, sobretudo, no caso de imóveis.

Nada impede, contudo, a produção de prova testemunhal, embora sua eficácia probatória, nestes casos, não deva ser tão elevada quanto às demais.

3.4.4.3 Fases organizatória e de saneamento

Já foi dito que sanear e organizar é preparar o processo para o julgamento, desobstruindo e delimitando o objeto a ser provado e decidido. Para isso, é necessário resolver as questões processuais pendentes, (art. 357, inc. I); delimitar as questões de fato para a prova e especificar os meios de prova admitidos (art. 357, inc. II); definir a *distribuição* do ônus da prova, observado o art. 373 (art. 357, inc. III);²¹⁴ delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito (art. 357, inc. IV); designar, se necessário, a audiência (art. 357, inc. V) nos casos em que não é expressa sua necessidade ou desnecessidade.

É possível à parte ou interessado, discordando do que foi definido, pedir ajustes no saneamento em 5 dias (art. 357, § 1.º); e delimitar questões consensuais de fato e direito para vincular a colheita da prova restrita a certo objeto (art. 357, § 2.º).

Admite-se o saneamento em audiência com a cooperação da *parte*, interessado ou interessados, do Ministério Público e da Fazenda Pública e mesmo de terceiros intervenientes para questões complexas, (art. 357, § 3.º) devendo, neste caso, levarem rol de testemunhas (art. 357, § 5.º); se há testemunhas para serem ouvidas, nos casos em que não é obrigatória a apresentação do rol de testemunhas com a inicial, abre-se prazo de 15 dias para indicar as testemunhas (art. 357, § 4.º); podendo-se o juiz limitar o número de testemunhas (art. 357, § 6.º), quando não há previsão expressa desse limite; a prova pericial deve observar o art. 465 (art. 357, § 7.º).

3.4.4.4 Fase decisória, fase de cumprimento e fase recursal

Finda a fase instrutória e saneados os autos, será o feito conclusivo para decisão. A sentença de procedência veicula a autorização para que a sub-rogação seja realizada. Para tanto, será expedido alvará ou mandado direcionado ao Cartório de Registro de Imóveis, a fim de que na matrícula do novo imóvel conste o ônus do originário e que este último seja liberado, nos termos do art. 168, inc. II, da Lei 6.015/1973.

A sentença poderá, ainda, negar o pedido autoral, antes mesmo da avaliação, caso o julgador verifique não ocorrer ao menos um dos requisitos básicos – conveniência e necessidade –, ou que o bem indicado não apresenta, no mínimo, o mesmo valor do outro.²¹⁵ Após a avaliação, será necessária a citação da Fazenda Pública, para fins fiscais.²¹⁶

3.4.5 Outras questões materiais e processuais

Neste tópico serão analisados alguns aspectos práticos específicos que permeiam o procedimento de jurisdição voluntária da sub-rogação. São questões conceituais e disposições materiais que refletem, diretamente, no curso da demanda.

3.4.5.1 Bem sub-rogado e bem sub-rogante

Via de regra, o bem sub-rogado e o sub-rogante devem possuir a mesma natureza, porém, dependendo das circunstâncias, a transferência poderá ocorrer de uma categoria para outra (de imóveis para títulos da dívida pública e vice-versa, por exemplo). Alcides de Mendonça Lima afirma, porém, que nunca de imóvel para móvel, em razão da diferença evidente entre valores, o que causaria prejuízos ao proprietário.²¹⁷

Também não se admite a sub-rogação de bens livres por bens já onerados, mas, sim, que se troquem os bens gravados por outros livres que serão gravados, como bem ressalta Pontes de Miranda.²¹⁸ O autor admite, entretanto, no caso de haver conveniência, sub-rogar um bem gravado por uma causa (razão), por um bem gravado por outra, efetuando-se, por meio de alvará, as trocas das respectivas cláusulas.²¹⁹

Há ainda a possibilidade da venda do bem e aplicação do valor, produto da venda, em caderneta de poupança. Deve-se destacar que isso se dará de forma provisória, pois o objetivo não é sub-rogar o preço, de forma que fique depositado em caderneta de poupança *ad eterno*, mas possibilitar que o proprietário do bem clausulado possa, em razão da necessidade e/ou conveniência, aliená-lo, ainda que não haja, naquele momento, um bem imóvel para sub-rogar.

De fato, nem sempre há oportunidade ou mesmo possibilidade de alienar ou permutar um bem por outro de igual categoria e valor, e nessa condição, conforme acima arguido, não se pode negar prestação jurisdicional ao interessado, apenas pelo fato de não haver bem certo e determinado para se gravar.

3.4.5.2 Autorização para venda

Nesse caso, desde que demonstrada a necessidade e/ou conveniência, deve ser concedida a autorização para venda do imóvel, gravando-se o preço em caderneta de poupança até que se encontre um de igual valor, o qual deverá ter sua matrícula averbada para constar o gravame (inalienabilidade).

Sobre esse ponto, Pontes de Miranda, em comentários ao CPC/1973, afirma que a autorização para a compra e venda é o primeiro passo para a sub-rogação, pois o preço sub-roga-se ao bem desde o momento em que se realiza a compra e venda, havendo, inclusive, a substituição do titular do direito real (proprietário do imóvel). Outro momento, segundo o autor, é o da aquisição do bem que deve substituir o vendido, o qual terá trasladado o gravame a que estava submetido o primeiro. Somente neste momento (aquisição de novo bem e consequente registro do gravame) é que o valor deixa de ser *clausulado*.²²⁰

A finalidade de tal procedimento (gravame do valor depositado em caderneta de poupança) é cumprir a ficção legal da sub-rogação, de forma que somente se efetiva o instituto quando cumprido os dois momentos – quando o outro bem, em regra de mesma categoria, é adquirido e devidamente gravado.

3.4.5.3 O fiscal

O CPC/2015 não sanou dúvida pendente desde a substituição do CPC/1939 pelo CPC/1973, qual seja a necessidade de fiscal para a realização da nova compra.

Ao tratar do assunto, Pontes de Miranda afirma que “no Código de 1939, art. 632, dizia-se que, concedida a autorização e efetuada a venda, o juiz nomearia *fiscal*, que receberia o preço e procederia à compra dos bens, aos quais se transferia o ônus. Tal fiscal ficaria sujeito a responsabilidade e penas do depositário, enquanto não prestasse as contas em juízo. O Código de 1973 não o reproduziu. Às vezes é desnecessária a providência para que se nomeie alguém que receba preço e providencie para a compra. No art. 1.107, 2.^a parte [sem correspondência no novo Código], permite-se ao juiz investigar livremente os

fatos e ordenar de ofício, a realização de quaisquer provas; e pode ele adotar a solução que lhe pareça mais adequada (art. 1.109: ‘mais conveniente ou oportuna’ [art. 723 do CPC/2015])”.²²¹

De outro lado, José Olympio de Castro Filho aduz que “o Código não reproduziu a prescrição antiga, talvez porque, na prática, a experiência mostrou que muitas vezes não foi seguida, e quase sempre resultou ineficaz, já que o fiscal, via de regra o advogado do requerente ou outro advogado da confiança do juiz, se limitava a efetivar a vontade dos interessados sem nada fiscalizar (...)”.²²²

Em que pesem os apontamentos do autor, Alcides de Mendonça Lima, também tratando sobre o CPC/1973, afirma que “apesar das objeções de José Olympio, entendemos indispensável a figura do fiscal, como auxiliar da justiça, para comparecer na escritura de alienação do bem, receber o preço e, se já houver o outro indicado e avaliado [imóvel], utilizar o numerário na sua aquisição; ou, então, se o numerário houver sido depositado, quando aparecer a oportunidade de ser reconstituído o patrimônio do requerente (...)”.²²³

Lima aduz ainda que a única possibilidade de dispensa do fiscal seria quando houvesse permuta de um bem por outro, sem ocorrer, portanto, qualquer pagamento que necessite de fiscalização, ou caso houvesse transferência do ônus para outro bem de propriedade do interessado.²²⁴ Esse ato de fiscalização corresponde na atualidade à atividade do depositário (arts. 159-161). A doutrina, embora em alguns pontos seja divergente, é majoritária ao entender necessária a atuação do fiscal.

Havendo, porém, a nomeação de fiscal, este deverá ser remunerado por meio de Regimento de Custas e não honorários, ainda que nomeado um advogado para o exercício da função, como ressaltado pela doutrina.²²⁵

Tem-se que o fiscal é auxiliar do juiz e, nessa condição, é o depositário judicial, possuindo as mesmas responsabilidades e penas que este. Ocorre, porém, que o depositante (consignatário) não é o juiz, mas, sim, o dono do bem alienado, sendo que as ações de depósito, como resalta Pontes de Miranda, cabem ao interessado (dono do bem alienado) e ao Ministério Público.²²⁶

3.4.5.4 Caso de desapropriação

Outro ponto sobre o qual o CPC/2015 restou silente, assim como fez o CPC/1973, diz respeito à desapropriação, por necessidade ou utilidade pública, de bem gravado com cláusula de inalienabilidade.

José Olympio de Castro Filho destacou que o art. 633 do CPC/1939 determinava que, no caso de desapropriação, a importância da indenização deveria ser aplicada na compra de novo imóvel, ou títulos da dívida pública, os quais deveriam ser gravados com o mesmo ônus previsto no bem desapropriado.²²⁷

Asseverava Pontes de Miranda que, “no caso de indenização, não há ação cujo conteúdo seja a sub-rogação; essa é efeito da sentença [que determina a desapropriação], e só isso”.²²⁸ O procedimento será igual ao da autorização para venda (v. item 5.5.1), inclusive a atuação do fiscal para levantar o preço e efetuar a compra do novo imóvel. As formalidades de registro são feitas por mandado, tanto as de extinção como as de nova gravação.²²⁹

Quanto às competências dos juízos (que desapropria e que mandou gravar o bem), o mesmo autor aponta que, na desapropriação, a competência nem sempre é do juiz que mandou gravar o bem, pois a sub-rogação não passa de efeito da sentença que determinou a desapropriação. Afirma ainda que o juiz da desapropriação, após determinar a venda do imóvel, deve ordenar que se deposite o preço em caderneta de poupança, gravando-o com a cláusula em questão e, quanto ao levantamento do valor e aquisição de novo imóvel, entende que tal juízo já não seria mais competente, cabendo ao juízo do gravame decidir quanto à sub-rogação do preço pelo bem adveniente.

Ao versar sobre a natureza das duas resoluções, Ponte de Miranda esclarece as duas relações jurídicas como: a) o juiz da desapropriação não emite nenhuma declaração de vontade, nem resolve sobre a sub-rogação; b) o juiz do gravame examina, *in casu*, a sub-rogação.²³⁰

Quanto ao valor da indenização, o Poder Público deve oferecer indenização que cubra o valor do imóvel, bem como os encargos processuais da transferência do gravame.²³¹

3.4.5.5 Sinistro

No caso de sinistro, se o bem estiver segurado, nos termos do art. 1.407 do CC/2002, a indenização paga pelo seguro estará submetida aos mesmos efeitos do bem gravado, nos termos do art. 1.409 do CC/2002. Sobre o ponto, Alcides de Mendonça Lima afirma que “o proprietário não pode sofrer desfalque em seu patrimônio, porque o sinistro destruiu o bem gravado. Tanto quanto possível, por conseguinte, o preço da indenização deverá manter o mesmo valor do bem anterior em um novo, embora, às vezes, o preço não seja suficiente. Aí, então, o decréscimo será inevitável”.²³²

3.4.5.6 >Execução por dívida

Conforme anteriormente apontado, a cláusula de inalienabilidade, nos termos do art. 1.911, do CC/2002, implica em impenhorabilidade e incomunicabilidade do bem, sendo essa hipótese analisada apenas em relação a dívidas fiscais, que é exceção à regra.

Executado o bem gravado, o saldo da venda (produto da venda, descontado o valor da dívida) será clausulado, estando vinculado à aquisição de novo bem (parágrafo único do art. 1.911 do CC/2002) que, possivelmente, não será do mesmo valor que o anterior.²³³

3.4.5.7 Sub-rogação em bem de maior valor

A regra geral é a de que o bem adquirido deve ser do mesmo valor que o anterior, sem que se tenha acréscimo ou prejuízo no patrimônio do proprietário.²³⁴ Assim, possuindo valor superior ao antigo, o imóvel adquirido, se divisível (terreno ou unidades autônomas em condomínio), será gravado no correspondente ao anterior, porém, se indivisível, não se poderá permitir a sub-rogação, sob pena de se permitir clausular os próprios bens, o que não é admitido em Direito.²³⁵

3.5 Alienação, arrendamento ou oneração de bens de crianças ou adolescentes, de órfãos e de interditos

Não houve grandes mudanças na redação do inc. III. Em verdade, quanto à possibilidade de alienação, arrendamento ou oneração de *bens dotais*, o CC/2002 já havia extirpado do Direito brasileiro o “pátrio poder” e, por consequência lógica, o conteúdo dos arts. 293 e seguintes do CC/1916, que versavam justamente sobre tais bens (dotais). Assim, não havendo mais direito material sobre o tema, não há que se falar em meio processual para sua persecução.

Já em relação à mudança do termo “menores” para “crianças ou adolescentes”, entende-se que a alteração não buscou trazer modificações substanciais sobre o tema, mas, apenas, adequar a terminologia do CPC/2015 à adotada pelo ECA.

A doutrina sempre criticou a utilização do termo *menores* no lugar de *incapazes*. Pontes de Miranda bem resumia a questão, dizendo que “bens de incapazes diria tudo”.²³⁶ Porém, assim não entendeu o legislador, optando por alterar a redação de outra maneira.

3.5.1 Aspectos materiais dos procedimentos

São três os atos contratuais previstos no inciso, quais sejam, a alienação, o arrendamento e a oneração. A previsão para que esses três tipos de atos contratuais sejam submetidos ao judiciário, a fim de se obter autorização para sua efetivação, é restringir os poderes dos representantes sobre os bens de seus representados (crianças ou adolescentes, órfãos e interditos), com a finalidade de resguardar o interesse destes.²³⁷

A alienação consiste na transferência, de forma gratuita ou onerosa, do domínio ou da propriedade de um bem ou direito. Quando de forma *onerosa*, poderá se dar: 1) pela compra e venda, prevista nos arts. 481 a 504 do CC/2002; 2) pela troca ou permuta, previstos no art. 533 do CC/2002; 3) pela doação mediante encargo ou obrigação, conforme arts. 539 e 553 do CC/2002. Quando de forma *gratuita*, se dará nos termos dos arts. 538 a 564 do CC/2002 (doação não onerosa).²³⁸

O arrendamento é contrato bilateral, oneroso e consensual em que o proprietário ou usufrutuário cede a outrem, por tempo certo ou não, o uso e gozo de coisa não fungível. O termo “arrendamento”, como aponta Alcides de Mendonça Lima, é mais utilizado para contratos de prédio rurais, sendo que, em área urbana, a nomenclatura legal utilizada é locação, que tem previsão nos arts. 565 a 609 do CC/2002. O autor ressalta, ainda, que “o inciso em foco não distingue a natureza do bem a ser ‘arrendado’ e, portanto, poderá ser semovente, móvel ou imóvel, ainda que, habitualmente, seja dessa última classe”.²³⁹

Por fim, a oneração é encargo ou obrigação incidente sobre uma coisa, cumprindo-se destacar que a denominação mais adequada ao termo é gravame. O gravame poderá ser por: 1) hipoteca, sobre os bens descritos no art. 1.473 do CC/2002, usualmente sobre imóveis e excepcionalmente sobre outros bens; 2) penhor, em bens móveis e semoventes, nos termos dos arts. 1.431 a 1.436 do CC/2002, bem como em legislação específica sobre “penhor agrícola”; 3) anticrese, recai sobre frutos e rendimentos, embora raramente utilizada, tem previsão nos arts. 1.506 a 1.510 do CC/2002. É de se salientar que, em relação à *oneração*, caso não seja cumprido o encargo ou obrigação garantida pelo gravame, tal fato poderá ocasionar a alienação forçada do bem pelo credor. ²⁴⁰

3.5.2 Dos aspectos processuais

Assim como no tópico anterior (sub-rogação), o legislador, ao determinar que a alienação, arrendamento ou oneração de bens de crianças ou adolescentes, órfãos e interditos fosse processada segundo as Disposições Gerais da jurisdição voluntária, manteve a omissão do CPC/1973. Isso porque não descreveu como se deveria processar, de forma específica, quaisquer dos pedidos mencionados.

Contudo, como bem ressalta José Olympio de Castro Filho, o juiz não está adstrito aos critérios de legalidade estrita, nos termos do art. 1.109 do CPC/1973, que corresponde ao art. 723, parágrafo único, do CPC/2015, sugerindo, em razão da peculiaridade desses procedimentos, uma série de atos não descritos nas Disposições Gerais. ²⁴¹

A alienação, arrendamento ou oneração de bens de crianças ou adolescentes, de órfãos e de interditos observam procedimentos próprios, conforme previsto nas regras de direito material pertinentes, cuja observância é indispensável para a efetivação da medida. ²⁴² É que as regras gerais de jurisdição voluntária, por óbvio, recebem influência direta do direito material.

Assim como os demais procedimentos submetidos ao regramento geral, este procedimento será iniciado com a distribuição da petição inicial, devendo ser citados todos os interessados, inclusive, se for o caso, o curador especial (art. 1.692 do CC/2002), bem como o Ministério Público, nos termos dos arts. 721 do CPC/2015 e 178, inc. II, do CPC/2015.

Após a citação têm-se duas hipóteses. A primeira é a de que há oposição pelos demais citados e o juiz deve conceder a autorização judicial. A segunda, que algum ou alguns dos interessados se opõem ao deferimento, seja em relação à concessão da autorização judicial, seja quanto às condições desta. Mais rápido e econômico será, primeiro, julgar se deve ser concedida ou não a autorização do juiz, para, num segundo ato, se apurar quais as condições devam ser observadas na venda, ou seja, na hipótese mais frequente, a avaliação”. ²⁴³

Se convencendo o juiz, em princípio, pela concessão da autorização judicial, este deverá determinar as providências destinadas a fixar condições para a venda, arrendamento ou oneração do bem ou bens, inclusive avaliação. ²⁴⁴ Efetivada as diligências e demonstrada a conveniência, necessidade e manifesta vantagem econômica, nos termos dos arts. 1.750 e 1.774, ambos do CC/2002, ou ausência de prejuízo para interessado, o juiz deferirá o pedido, determinando o modo como o ato se completará, ²⁴⁵ caso não haja acordo entre os interessados sobre a forma como a alienação deva se realizar, nos termos do art. 730 do CPC/2015.

Pontes de Miranda, ao comentar o CPC/1973, aduz que se o menor for relativamente incapaz, este necessariamente deverá ser ouvido em audiência, que deverá ser provocada. Porém, quanto ao menor de 16 anos, embora possa ser ouvido apenas para prestar esclarecimentos, não haverá tal necessidade. Entretanto, se há algum parente do menor ou do interdito, que por ele se interesse, tem de ser ouvido. ²⁴⁶

3.5.2.1 Petição inicial

O interessado deverá observar, como nos outros procedimentos, os requisitos expressos no art. 319 do CPC/2015, devendo demonstrar, ainda, a necessidade, conveniência e vantagem econômica da medida requerida, ²⁴⁷ nos termos do art. 1.750 do CC/2002.

Tratando-se de oneração, ressalta Alcides de Mendonça Lima que “cabe ao requerente apresentar, para minucioso estudo, as condições do gravame; modo de poder ser liberado e indicar os recursos financeiros para tal fim”, advertindo tratar-se de demonstração essencial, pois conforme anteriormente apontado, se não houver o adimplemento do gravame, o credor poderá promover a alienação forçada do bem. Caso o risco não seja devidamente analisado, poderá haver dano irreparável para um dos dois

sujeitos: “a) ao interessado, como proprietário, que a lei quer proteger, com a perda do bem pela decorrente alienação forçada; b) ou do credor, se não conseguir receber, vedada a futura alienação para obter os recursos indispensáveis ao adimplemento da obrigação”. ²⁴⁸

Já em relação ao arrendamento ou locação, o contrato deverá ser muito bem esquematizado, a fim de garantir o interesse do proprietário (interessado), exigindo, inclusive, “fiança idônea a favor de terceiro por todas as obrigações assumidas por ele e estabelecidas outras cláusulas que venham a obstar a eventual lesão do requerente dono do bem”. ²⁴⁹

3.5.2.2 Os interessados

As crianças e adolescentes menores de 16 anos serão representadas, nos termos do art. 3º, do CC/2002, por seus pais, ou por um deles na falta do outro (art. 1.690 do CC/2002), ou pelo tutor (art. 1.728 do CC/2002); já os maiores de 16 e menores de 18 anos serão assistidos pelos pais, ou por um deles na falta do outro (art. 1.690 do CC/2002), podendo, ainda, ser assistido por curador especial, conforme art. 1.692 do CC/2002, sendo que, no segundo caso (maiores de 16 e menores de 18 anos), deverão firmar procuração para o advogado o menor e àquele que o assistir. ²⁵⁰

Também os órfãos serão sempre representados ou assistidos por um tutor (art. 1.728, inc. I, do CC/2002), seguindo o mesmo raciocínio acima exposto. Já os interditados serão representados por curador, nos termos dos arts. 747 a 763, ambos do CPC/2015, e art. 1.767 do CC/2002, o qual foi recentemente modificado pela Lei 13.146/2015.

3.5.2.3 Recurso

O Recurso cabível é o de apelação, tanto para a decisão que defere a autorização, quanto para a que indefere, nos termos do art. 724 do CPC/2015.

3.6 Alienação, locação e administração da coisa comum

Este procedimento, embora similar àquele previsto no art. 730 do CPC/2015, com ele não se confunde, tendo em vista que, conforme ressalta Alcides de Mendonça Lima (comentários ao CPC/1973), “aqui se trata de procedimento autônomo, visando a situações sem vínculo com qualquer feito anteriormente já ajuizado; ao passo que, no art. 1.113 ao art. 1.119 [art. 730 do CPC/2015 c/c os arts. 879 a 903, do mesmo Código], são estatuídas normas para processos em curso, (...)”, ²⁵¹ ideia corroborada por Pontes de Miranda. ²⁵²

Como se observa, a redação do inciso permanece a mesma, bem como os problemas antes apontados pela doutrina. Da mesma forma como nos incisos anteriores, o legislador, ao pensar que seu silêncio simplificaria o procedimento, em verdade o obscureceu, deixando a cada intérprete o dever de compreender e aplicar o dispositivo nas complexidades que demanda a espécie, conforme prevê o CC/2002, nos arts. 1.322 e 1.323. ²⁵³

Ressalta Alcides de Mendonça Lima que “esta atividade é segundo o ponto de vista pessoal sem uma diretriz concreta uniforme. Cada objeto provoca uma forma procedimental, alargando-se, assim, as ‘Disposições Gerais’, para adaptá-las mutatis mutandis”. ²⁵⁴ Essa observação tem validade, inclusive, em relação ao CPC/2015, tendo em vista a manutenção da omissão amplamente criticada pela doutrina.

3.6.1 Aspectos materiais do procedimento

Aqui permanecem os apontamentos feitos no tópico anterior (*inc. III*) em relação ao conceito de alienação e de locação (arrendamento), devendo se observar os arts. 481 a 504 do CC/2002 para o primeiro; e os arts. 565 a 609 do CC/2002 para o segundo.

Alcides de Mendonça Lima confirma a similaridade dos conceitos ao apontar que o termo “alienação” foi utilizado a fim de abranger as demais formas de aquisição de propriedade, como a venda e a troca. Do mesmo modo, embora o inc. IV mencione apenas o termo locação, deve-se entender abrangido o “arrendamento” que, na prática, são sinônimos. Porém, a legislação especial atribui o termo a imóvel rural, estando também este submetido ao procedimento. ²⁵⁵

A administração é atribuída a um terceiro ou mesmo um dos condôminos, a fim de que este tome as devidas providências para a manutenção do bem, tendo previsão no art. 1.323 e ss.

A “coisa comum” é a prevista na Seção I do Capítulo VI do CC/2002 – *Condomínio Voluntário* –, previsto no art. 1.314 e ss.

3.6.2 Aspectos processuais do procedimento

No tópico que se segue serão abordados os principais aspectos processuais, tais como as hipóteses de cabimento, os requisitos da petição inicial, a recorribilidade, direito de preferência, entre outros.

3.6.2.1 Natureza do provimento

O provimento jurisdicional pertinente ao procedimento de que trata o inc. IV do art. 725 tem natureza constitutiva. Pontes de Miranda ressalta que sentença constitui título autorizador para a alienação, locação ou administração da coisa comum, pois “se pede ato ou negócio jurídico que a ação vai provocar”. A natureza não se modifica, ainda que o ato do julgador seja apenas para homologar a declaração de vontade das partes.²⁵⁶

3.6.2.2 Cabimento

Só será possível quando se tratar de “coisa comum” e esta for: a) *indivisível* ou cuja divisão comprometa o fim a que se destina (art. 1.322 do CC/2002); e b) por falta de acordo entre os condôminos quanto ao destino do bem comum (art. 1.323 do CC/2002).²⁵⁷

A falta de acordo pode residir: I) na finalidade do ato – se o bem comum deve ser alienado ou locado, por exemplo; ou II) na pessoa com quem o negócio será feito – se com um dos próprios condôminos ou com terceiro; III) na avaliação do preço da venda, do valor da locação, ou das cláusulas deste; IV) na forma de administração.²⁵⁸ Isso porque, se a coisa comum for *divisível*, caberá procedimento próprio, previsto no art. 569, do CPC/2015 – Ação de Divisão e Demarcação de Terras Particulares. Ademais, se há consenso entre os condôminos quanto ao destino do bem, não há porque se buscar o judiciário, a não ser para homologar acordo entre eles firmado, que deverá seguir o procedimento do inc. VIII do art. 725 do CPC/2015.

3.6.2.3 Petição inicial

Além de observar os requisitos do art. 319 do CPC/2015, os interessados deverão instruir os autos com os documentos comprobatórios da propriedade da “coisa comum”,²⁵⁹ bem como da quota parte de cada um deles, se igual ou não. A demonstração da *quota parte* tem a finalidade de, quando da decisão, fixar o valor a ser distribuído a cada um dos interessados, bem como aferir o poder de voto de cada um destes, nos termos do art. 1.325 do CC/2002. Deverá, ainda, indicar a providência pretendida (alienação, locação ou administração da coisa comum), bem como demonstrar a indivisibilidade do bem (ou possibilidade de comprometimento de sua finalidade com a divisão) e a discordância entre os condôminos. Cumpre destacar que, se casado, o interessado deverá juntar a anuência de seu cônjuge, caso a “coisa comum” seja imóvel, nos termos do art. 73 do CPC/2015.

3.6.2.4 O procedimento

A alienação, locação e administração de coisa comum observam procedimentos próprios, conforme previsto nas regras de direito material pertinentes, cuja observância é indispensável para a efetivação da medida.²⁶⁰ É que as regras gerais de jurisdição voluntária, por óbvio, recebem influência direta do direito material.

Via de regra, o procedimento observará a seguinte sequência de atos: a) petição inicial; b) citação dos interessados – os demais condôminos, bem como seus cônjuges (caso se trate de bem imóvel, conforme art. 73, § 1.º, inc. I, do CPC/2015); c) intimação da Fazenda Pública, caso se verifique ônus fiscais a serem adimplidos; d) sentença, que deferirá o pedido para solver as divergências e determinar as medidas necessárias, a depender da natureza do pedido; ou indeferirá o pedido, por entender o juiz não restarem demonstrados os fatos (indivisibilidade ou impropriedade do destino; divergência quanto ao destino do bem comum); e) apelação do interessado que se sinta prejudicado.²⁶¹

Deferido o pedido, deverá o julgador se atentar às regras de preferência e igualdade de condições (arts. 504, 1.322 e 1.323, todos do CC/2002), bem como da maioria de votos (art. 1.325 do CC/2002), e da divisão dos frutos da coisa comum, conforme art. 1.326 do CC/2002.²⁶² No caso de maioria absoluta pela alienação da “coisa comum”, os interessados poderão determinar a forma como a venda se realizará.

Porém, em não havendo concordância, esta se dará em leilão, nos termos do art. 725, parágrafo único, do CPC/2015 e do art. 730 do mesmo Código, podendo ser, inclusive, determinado de ofício pelo juiz.

Caso se verifique que um ou mais interessados, desde que citados, não apresentaram resposta, tal silêncio deverá ser interpretado como anuência à medida requerida.²⁶³

Outro fato importante a se ressaltar é que a deliberação, nos termos do art. 1.325, § 1.º do CC/2002, é obrigatória, devendo se observar a maioria absoluta, conforme valor do quinhão de cada condômino, nos termos do art. 1.325 do CC/2002. Na deliberação, poderá se apresentar solução diversa da requerida na inicial, sem que, com isso, se fale em alteração ou acréscimo do pedido, tratando-se, apenas, de exercício do direito dos demais interessados em manifestarem suas vontades.²⁶⁴

Pontes de Miranda afirma que as votações poderão ser separadas, sendo um para o destino da coisa, por exemplo, e outro, caso se decida pela “administração”, para a escolha do administrador, desde que haja base para a eleição, destacando, porém, que o ato judicial é um só. Ademais, sustenta que “se os condôminos opinam pela escolha do administrador; não se há de determinar o destino da coisa. Se há empate (metade por metade do valor dos quinhões, sempre computado como favorável à medida proposta o quinhão contumaz), decide o juiz por um nome ou por outro. Cabe-lhe o desempate, não como declaração de vontade sua, e sim como resolução judicial. Ouve antes os condôminos sobre as causas das suas preferências”.²⁶⁵

Caso haja dúvida quanto ao valor dos quinhões ou de algum deles, será este avaliado judicialmente, nos termos do art. 1.325, § 3.º, do CC/2002, sendo que, conforme art. 1.315, parágrafo único, do CC/2002, se presumem iguais as partes ideais dos condôminos.

3.6.3 Da preferência

Como determinam os arts. 1.322 e 1.323, ambos do CC/2002, na alienação ou na locação do bem comum, o condômino, além da igualdade de condições de oferta em relação ao estranho, terá preferência sobre este. Explica Nelson Nery que a hipótese do art. 725, inc. VI, objetiva viabilizar o direito de preferência do condômino preterido (art. 504, CC/2002).²⁶⁶

Na alienação há, portanto, uma ordem de preferência entre os condôminos, devendo se observar, entre estes, àquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas. Não havendo quem as tenha, o de maior quinhão, nos termos do art. 1.322, *caput*, do CC/2002.

Não se verificando nenhuma dessas hipóteses, o *parágrafo único* prevê que se fará licitação entre os estranhos e, antes da adjudicação àquele (estranho) que ofereceu o maior lance, será realizada licitação entre os condôminos, a fim de que a coisa seja adjudicada a quem afinal oferecer melhor lance, preferindo-se, em condições iguais, o condômino.

Na licitação de bem imóvel que não comporta divisa cômoda, o donatário tem preferência, se concorrer em igualdade de condições.²⁶⁷

3.6.3.1 Recurso

Da decisão que defere ou indefere o procedimento, cabe apelação, nos termos do art. 724 e ss. do CPC/2015.

3.7 Alienação de quinhão em coisa comum

Não houve alteração no inciso V.

O termo alienação foi utilizado de forma genérica, conforme visto nos comentários anteriores. Alcides de Mendonça Lima aduz que a escolha do legislador foi de extremo rigor terminológico, abrangendo as modalidades *venda, troca e doação*.²⁶⁸ Porém, o art. 504 do CC/2002, que fundamenta o procedimento ora comentado, restringe o direito de *venda* do condômino de coisa comum indivisível, sem nada aduzir quanto às demais formas (troca ou doação).

Dessa forma, seria cabível esse procedimento a fim de doar, ou mesmo trocar, quinhão para terceiro? Entende o autor que, sim, apresentando, inclusive, possível solução para evitar possíveis fraudes ou prejuízos aos demais condôminos. Isso porque “sendo ‘venda’, há preço, que deverá ser mencionado pelo

condômino ao dar conhecimento aos outros, para o necessário depósito, se ocorrer o exercício do direito de preferência”.

Por outro lado, se o condômino pretender “trocar” ou “doar”, de modo verdadeiro ou então como artifício para favorecer o terceiro e lesar os demais condôminos, afastando-os do negócio, estes, pela finalidade social e ética da norma tradicional, não podem ser prejudicados. Para isso, o bem deverá ser avaliado com o objetivo de proporcionar o depósito do “valor” do quinhão (não do preço, no sentido técnico), assegurando-se a adjudicação decorrente da preempção conferida.

Não importará o motivo do ato praticado pelo alienante na permuta ou na doação, ainda que lícito. ²⁶⁹ A solução apontada pelo autor, mostra-se razoável, bem como encontra amparo no art. 723, parágrafo único, do CPC/2015, pois não sendo caso de *venda* não haverá oferta a se cobrir, sendo razoável que, se *troca*, seja avaliado o bem a ser permutado como forma de pagamento pelo quinhão, a fim de garantir, em querendo, o direito de preferência dos condôminos; se *doação*, seja avaliado a coisa comum, a fim de estabelecer o valor do quinhão do doador.

Assim, pode-se concluir que o dispositivo tem como finalidade garantir o exercício por qualquer condômino, desde que verificada a indivisibilidade do bem, de seu direito de preferência (preempção) na aquisição do quinhão, bem como o direito do proprietário em *aliená-lo* (venda, troca ou doação), de forma que só terá cabimento, caso se verifique terceiro pretendente. ²⁷⁰

Cumprе ressaltar que os incs. IV e V, embora tratem do direito de condomínio, se diferem na medida em que: a) no primeiro, o pedido de venda é em relação a todo o imóvel, com fulcro no art. 1.322 do CC/2002; b) no segundo, o interessado deseja alienar apenas a sua *cota parte* (quinhão) do bem comum a terceiro pretendente, sem que haja, de forma alguma, a necessidade de o ato abranger a totalidade da coisa, nem há possibilidade de aplicação das demais modalidades: locação e administração.

Porém prevalecem algumas características comuns, como já era de se esperar, a saber: a) o direito de preferência dos demais condôminos na aquisição da coisa ou do quinhão; e b) que a coisa comum seja indivisível. ²⁷¹

3.7.1 Aspectos materiais do procedimento

Como já observado, o procedimento de jurisdição voluntária aqui tratado recebe influência constante, direta e determinante das respectivas normas de direito material. Os dispositivos do CC/2002 pertinentes já restaram bem elucidados em linhas anteriores.

Ainda assim, repita-se que quinhão é a parte que cabe a cada um dos condôminos de coisa comum indivisível. ²⁷² Sendo o alienante proprietário dessa parte, como preceitua o art. 1.228 do CC/2002, pode dela usar, gozar e dispor, observando-se, para a última, as formas de transferência de propriedade.

3.7.2 Aspectos processuais do procedimento

A alienação de quinhão em coisa comum observa procedimento próprio, conforme previsto nas regras de direito material pertinentes, cuja observância é indispensável para a efetivação da medida. ²⁷³ É que as regras gerais de jurisdição voluntária, por óbvio, recebem influência direta do direito material.

Como o procedimento, via de regra, se dá em razão de *venda* do quinhão, excetuada as formas anteriormente apontadas (item 8), os pressupostos a serem preenchidos pelo interessado em alienar sua *quota parte* são: a) demonstração da existência de condomínio; e b) da indivisibilidade da coisa comum. ²⁷⁴

Pontes de Miranda divide os dois pressupostos sob dois critérios: subjetivo e objetivo. O primeiro se refere ao pressuposto ligado ao interessado (ser condômino). O segundo se refere ao pressuposto ligado à condição do bem (ser indivisível). Além disso, esclarece que “não basta o tornar-se imprópria ao seu destino, se dividida fosse”. ²⁷⁵ Além disso, verifica-se também a necessidade de se demonstrar a existência de oferta séria por terceiro pretendente.

José de Olympio Castro Filho afirma que tal necessidade surge com o intuito de repelir a simulação processual, não rara neste tipo de procedimento, onde o interessado simula pretensão fantástica de terceiro à aquisição do quinhão, na tentativa de impedir o exercício do direito de preempção, dificultá-lo ou mesmo locupletar-se às custas dos demais condôminos, onerando em demasia o valor da venda. ²⁷⁶

3.7.2.1 Petição inicial

Além de observar os requisitos descritos no art. 319 do CPC/2015, o interessado deverá, em sua peça inicial, descrever e comprovar: a) o seu quinhão (valor); b) a origem da comunhão; c) as benfeitorias existentes na coisa comum; d) bem como exporá precisamente a proposta recebida por terceiro, ²⁷⁷ apontando o preço, o prazo e as condições. ²⁷⁸

Entende-se necessária a demonstração da indivisibilidade do bem.

3.7.2.2 As provas necessárias

O interessado, além dos documentos que demonstrem a sua copropriedade da coisa comum, a indivisibilidade desta e o valor do seu quinhão, deverá juntar a proposta de terceiro, por escrito, com firma reconhecida, testemunhada, quando possível, e com prazo de validade, ²⁷⁹ a fim de satisfazer o comando dos arts. 720 e 320, ambos do CPC/2015, podendo empregar todos os meios legais e moralmente legítimos, nos termos do art. 369 do CPC/2015. Se o interessado requerente for casado, bem como a coisa comum imóvel, será necessária a demonstração de anuência do cônjuge, nos termos do art. 73, § 1.º, I do CPC/2015.

3.7.2.3 O procedimento

Este procedimento seguirá, com as devidas adaptações, os mesmos critérios dos procedimentos descritos nos outros incisos: ²⁸⁰ a) Petição inicial, que deverá se atentar para os requisitos e provas anteriormente descritos (v. itens 3.5.2.1 e 3.5.2.2); b) citação dos interessados (quantos condôminos forem); c) instrução; d) sentença; e) apelação.

Cumpra-se destacar que não poderá haver discordância entre os interessados quanto ao pedido de alienação, só podendo se manifestar, a fim de concordar ou exercer seu direito de preempção (preferência), salvo quando a discordância por eles apresentada é quanto à indivisibilidade da coisa comum. O terceiro pretendente, em regra, não é citado, porém o poderá ser, para que preste esclarecimentos sobre sua proposta em audiência.

Caso seja necessário, em razão das questões levantadas (por exemplo, sobre indivisibilidade do bem ou pretendente simulado), o juiz poderá determinar dilação probatória, a fim de se apurar a existência ou não da questão levantada e, após o fazer, decidirá em definitivo. Não havendo discordância, o juiz terá de deferir o pedido de alienação do quinhão a estranho. ²⁸¹

Da decisão caberá apelação pelo interessado prejudicado, nos termos do art. 724 do CPC/2015. Para haver recurso de condômino, este deverá efetuar o depósito do valor do preço ou da avaliação do quinhão, a fim de cumprir o requisito do depósito (v. item 3.5.2.4), previsto na 2.ª parte do art. 504 do CC/2002. ²⁸²

3.7.2.4 Comunicação do que quer adquirir

O art. 504 do CC/2002 dispõe que um condômino, em coisa indivisível, não pode vender a sua parte a estranhos se outro consorte a quiser, tanto por tanto. O condômino, a quem não se der conhecimento da venda, poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de decadência.

Dessa forma, caso tenha interesse em alienar seu quinhão, o condômino alienante deverá comunicar os demais coproprietários sobre a venda. Não há qualquer exigência para que a comunicação feita seja apenas por via do presente procedimento, podendo se dar por qualquer meio particular, “desde que haja prova absoluta da comunicação e do recebimento pelo destinatário, inclusive um documento assinado pelo parceiro (parceiros), destacando-se o ‘ciente’ e manifestando seu desinteresse em adquirir ‘tanto por tanto’ o quinhão oferecido”. ²⁸³

O alienante, portanto, poderá efetivar o negócio jurídico sem a necessidade de intervenção judicial, desde que, cumprindo as condições citadas, nenhum dos demais coproprietários manifestem desejo em adquirir sua parte ideal. Entretanto, se manifestarem tal desejo, este ou estes (condôminos) terão, conforme exaustivamente mencionado, direito de preempção em relação ao terceiro.

Não basta, porém, que os condôminos apenas expressem sua vontade em adquirir. Os coproprietários

interessados na aquisição deverão depositar, no mínimo, o valor da proposta, ou da avaliação,²⁸⁴ sendo que, em igualando a oferta do terceiro, este será afastado, transferindo-se o quinhão para o parceiro ou parceiros optantes.²⁸⁵ A lei não prevê qualquer prazo para o cumprimento do depósito, devendo, portanto, o próprio julgador o estipular, nos termos do art. 218, § 1.º, do CPC/2015 ou, no silêncio deste, observar o disposto no § 3.º, do mesmo artigo, qual seja, prazo de 5 dias.²⁸⁶

Um problema surge quando, sem comunicar um ou todos os demais condôminos, o coproprietário aliena seu quinhão. A segunda parte do art. 504 do CC/2002 aponta a solução. Nesse caso, devem os condôminos, a quem não se deu conhecimento, depositar o preço, podendo haver para si a parte (quinhão) alienada ao terceiro, desde que se observe o prazo decadencial (por se tratar de direito material, e não processual) de 180 dias.

Ocorre que não há qualquer menção, no texto legal, ao ato que deflagraria a contagem do prazo decadencial. Pontes de Miranda, a esse respeito, apresenta três possíveis soluções: a) começa a contar no momento em que houve a venda do bem; b) no momento em que se transfere a propriedade; c) no momento em que o condômino tem ciência da venda.²⁸⁷

Parece ser mais acertada a segunda opção, pois o Código Civil prevê a efetivação do ato de transferência que, em se tratando de imóveis, ocorre quando do registro em cartório de Registro de Imóveis, como se observa do art. 1.245 do CC/2002.²⁸⁸

Assim, o prazo passará a correr do momento da transferência, desde que não tenha tomado conhecimento antes. Se, porém, a transcrição (registro) foi de título sentencial, do qual o condômino não tomou conhecimento, a ineficácia do ato é relativa, desde que dentro do prazo decadencial (180 dias).

3.7.2.5 Preferência

Aqui também os coproprietários gozam do benefício da preempção (preferência) para aquisição do quinhão ofertado pelo condômino alienante (art. 504 do CC/2002).

Havendo ofertas de mesmo valor entre o condômino interessado e o terceiro pretendente, prevalecerá o interesse do primeiro. Porém, havendo mais de um condômino interessado, o parágrafo único do art. 504 do CC/2002 prevê o benefício de ordem para escolha do coproprietário interessado: preferirá o que tiver benfeitorias de maior valor e, na falta de benfeitorias, o de quinhão maior. Porém, se as partes forem iguais, haverá a parte vendido os coproprietários.

Pontes de Miranda, ao tratar da ordem e da forma como os condôminos se sucedem, explica que, sendo um condômino ou sendo alguns, os que vêm no primeiro lugar tem de depositar o preço. O que não depositar é excluído.

“Se um só deposita todo o preço; se dois ou mais do mesmo grau deposita-se a parte que cabe a cada um. O que falha, sendo o único, é substituído pelo grau seguinte, ou pelos que, sendo dois ou mais, aceitarem a comunhão do quinhão alienado; se falha um, ou se falharem alguns dos que foram chamados, a parte ou partes vagas podem ser adquiridas pelos restantes, requerendo-a ao juiz, com o depósito do resto do preço. Se não a quiserem, ou não as quiserem, são chamados os do grau seguinte, como acima se expôs. Sempre que tenha de os chamar, deve o juiz marcar-lhes o prazo para o depósito”.²⁸⁹

3.7.2.6 Natureza Jurídica da decisão

Trata-se de decisão constitutiva declarativa e está condicionada à manutenção da declaração de vontade dos condôminos.²⁹⁰ Isso porque há parte que decide sobre a alienação, e parte que decide sobre a adjudicação, completando-se a resolução judicial.

Na primeira, há declaração do direito a alienação; na segunda, há a constituição do negócio jurídico da compra pelo preferente, isso quando um ou mais dos condôminos manifestam interesse na compra do quinhão. Em não havendo tal interesse, a decisão é apenas declarativa negativa, porque antes da ação, e da consequente decisão, existia pretensão (direito de preferência) pelos coproprietários.²⁹¹

3.7.2.7 Recurso

Cabe recurso de apelação contra a decisão, nos termos do art. 724 do CPC/2015, somente se algum ou

alguns dos competidores fizer o depósito aludido no art. 504 do CC/2002. Para o condômino omitido nas citações, conforme mencionado (v. item 3.5.2.4), deverá se observar o prazo previsto de 180 dias, incumbindo-lhe demonstrar que, se tivesse sido citado, lhe teria sido concedida a aquisição, com exclusão total ou parcial daquele a quem foi atribuída. ²⁹²

3.8 Extinção de usufruto

Quando não decorrer da morte do usufrutuário, do termo da sua duração ou da consolidação, e de fideicomisso, quando decorrer de renúncia ou quando ocorrer antes do evento que caracterizar a condição resolutória.

Embora se verifique alteração na redação do inc. VI, o novo texto apenas formaliza prática já consolidada pela doutrina. “O usufruto que grava o bem móvel ou imóvel quando extinto anormalmente será objeto do procedimento de jurisdição voluntária, para que a sentença cancele a inscrição do registro (eficácia mandamental)”. ²⁹³

O art. 1.410 do CC/2002, prevê que o usufruto se extingue: a) pela renúncia ou morte do usufrutuário (inc. I); b) pelo termo de sua duração (inc. II); c) pela extinção da pessoa jurídica, em favor de quem o usufruto foi constituído, ou, se ela perdurar, pelo decurso de 30 anos da data em que se começou a exercer (inc. III); d) pela cessação do motivo de que se originou (inc. IV); e) pela destruição da coisa, não sendo fungível, guardadas as disposições dos arts. 1.407, 1.408, 2.^a parte, e 1.409 (inc. V); f) pela consolidação (inc. VI); g) por culpa do usufrutuário, quando aliena, deteriora, ou deixa arruinar os bens, não lhes acudindo com os reparos de conservação, ou quando, no usufruto de títulos de crédito, não dá às importâncias recebidas a aplicação prevista no parágrafo único do art. 1.395, pelo não uso ou não fruição da coisa em que o usufruto recai (arts. 1.390 e 1.399) (inc. VII).

Os dois primeiros – morte ou renúncia do usufrutuário (inc. I) e termo da duração (inc. II) – podem ser constatados por simples certidão de óbito, no caso de morte do usufrutuário, ou pelo decurso de prazo prefixado no ato de instituição do usufruto, bastando a apresentação destes documentos para que se averbe o registro. ²⁹⁴

Da mesma forma o fideicomisso, que se extingue: a) se o fideicomissário morrer antes do fiduciário, ou antes de realizar-se a condição resolutória do direito deste último (art. 1.958 do CC/2002) (inc. I); b) quando o fideicomissário morre primeiro que o testador (inc. II); c) quando o fideicomissário renuncia à herança ou legado (art. 1.955 do CC/2002) (inc. III); d) quando desaparecer totalmente a coisa, objeto do fideicomisso, sem culpa do fiduciário (inc. IV). Como se vê, os dois primeiros casos são hipóteses que decorrem de acontecimentos físicos e, por isso, sua extinção não exige a intervenção judicial, bastando a apresentação da certidão de óbito em Cartório para averbação do registro. ²⁹⁵

3.8.1 Aspectos materiais do procedimento

Embora possuam origens diferentes, o usufruto e o fideicomisso se assemelham e, às vezes, até se confundem. ²⁹⁶ Adiante serão conceituados os dois institutos jurídicos, esclarecendo-se, assim, suas diferenças e semelhanças.

3.8.1.1 Usufruto

É direito real (v. art. 1.225, inc. IV, do CC/2002) conferido a uma pessoa, que a autoriza retirar da coisa alheia os frutos e utilidades que ela produz (v. art. 1.394 do CC/2002). ²⁹⁷ Tem previsão no art. 1.951 do CC/2002.

Por ser direito real de uso e fruto sobre bem alheio, haverá dois sujeitos de direito na relação, são eles o usufrutuário, que usa e goza a coisa, e o nu-proprietário, proprietário do bem.

Nos termos do art. 1.390 do CC/2002, o usufruto pode recair em mais de um bem, podendo ser este ou estes, móveis ou imóveis; em um patrimônio inteiro, ou em parte deste, abrangendo-lhe, no todo ou em parte, os frutos e utilidades. Pode ainda, como ressalta Edson, ser vitalício ou temporário, se estipulado para durar enquanto viver o usufrutuário ou se limitado a um prazo determinado pelo instituidor. Caso não seja estipulado um prazo, entender-se-á que se fixou por toda a vida (v. art. 1.921 do CC/2002), sendo que a extinção só se dará com a morte do usufrutuário. ²⁹⁸

No que diz respeito ao direito de alienação pelo nu-proprietário, cumpre destacar que lhe é permitido,

porém, não poderá o adquirente dispor dele (bem) de forma cabal enquanto perdurar o usufruto. A alienação poderá ainda ser em favor do usufrutuário, ocorrendo aí a “consolidação” (art. 1.410, VI, do CC/2002).

Caso seja instituído em favor de duas pessoas ou mais, o art. 1.411 prevê que este será extinto em relação a cada um dos usufrutuários, ou seja, se instituído prazo diferenciado para cada um daqueles, culminado o período determinado para um, este não alcança o outro, que só terá sua extinção reconhecida após o término de seu prazo. Da mesma forma, a morte não alcançará os demais.

O artigo prevê, ainda, exceção para a extinção do usufruto quando falece um dos usufrutuários, desde que haja estipulação expressa para que o quinhão deste passe para o(s) sobrevivente(s).

3.8.1.1.2 Fontes do usufruto

O usufruto pode ser estabelecido por: a) ato entre vivos; b) lei; c) testamento (v. art. 1.225, III; art. 1.226 e 1.227; art. 1.390 a art. 1.411, todos do CC/2002). Pode o testador desmembrar em direitos reais a propriedade, ou deixar ao herdeiro, ou legatário, os direitos reais que tem sobre a coisa de outro. Pode, também, como afirma Pontes de Miranda, legar a pretensão a “haver de outrem” ou legar “direito que se tenha ainda de adquirir”.²⁹⁹

3.8.1.2 Fideicomisso

Aqui também há direito de uso e fruição separados do domínio, sem que, contudo, se confunda este com o usufruto. No primeiro, a propriedade se divide no tempo; no segundo, se parte nos elementos de direito de propriedade – nua propriedade, uso e fruto.³⁰⁰

No fideicomisso verifica-se a existência de dois sujeitos de direito: o fiduciário, que recebe e guarda a herança; e o fideicomissário, que a “terá” depois, embora os dois sejam, nas palavras de Pontes de Miranda, herdeiros da mesma herança. Explica o autor que, “materialmente, as duas sucessões ligam-se ao mesmo instante, o da abertura da sucessão, o da morte do testador. Temporalmente, uma se sobrepõe à outra, começa onde a outra acaba, o fim de uma é o começo de outra”.³⁰¹

Assim, o fiduciário, quer por ato entre vivos ou por testamento, recebe determinado bem, por legado ou herança, que deverá (obrigação) ser transferido a outro (fideicomissário), quando da morte do fiduciário (prazo indeterminado), a tempo certo (prazo determinado) ou sob certa condição.³⁰²

Como já apontado, aqui há um titular efetivo (fiduciário), que está no exercício pleno da propriedade (domínio, posse, uso e gozo) e um titular na expectativa “aguardando a ocorrência da condição resolutiva, para, então, receber o bem sujeito ao gravame”.³⁰³

O fiduciário não está impedido de alienar o bem, porém, aquele que o adquirir, ainda que o alienante (fiduciário) venha a falecer posteriormente, ou que o prazo determinado venha a findar, ou que ocorra, inclusive, a condição resolutória, tendo em vista que a vontade do testador deve ser cumprida (transmissão da propriedade para o fideicomissário ao final).³⁰⁴ A propriedade conferida ao fiduciário é “restritiva e resolúvel”, nos termos do art. 1.953 do CC/2002.

Pode ser instituído de duas maneiras: 1) por testamento, conforme art. 1.951 do CC/2002; b) por ato entre vivos.

3.8.2 Aspectos processuais dos procedimentos

No tópico que se segue serão abordados os principais aspectos processuais deste procedimento, tais como as hipóteses de cabimento, os requisitos da petição inicial, a recorribilidade, direito de preferência, entre outros.

3.8.2.1 Cabimento

Como apontado no início, a literalidade do inc. VI não permanece a mesma. No Código anterior, como assevera Alcides de Mendonça Lima, as causas que substanciavam este procedimento, no que diz respeito ao usufruto, eram todas aquelas previstas nos incisos do art. 739 do CC/1916, atual art. 1.410 do CC/2002.³⁰⁵

Contudo, a nova redação dividiu as hipóteses de cabimento em: a) negativa, não sendo mais cabível

ação de extinção de usufruto para os incs. I (morte), II e VI, do art. 1.410 do CC/2002, mas permanecendo o cabimento quanto aos demais incisos (I (renúncia), incs. III, IV, V, VII e VIII); b) positiva, sendo cabível apenas, no que diz respeito ao fideicomisso, quando decorrer de renúncia – art. 1.955 do CC/2002 ou quando a morte do fideicomissário ocorrer antes de se realizar a condição resolutória do direito deste último – art. 1.958 do CC/2002.

Não se verifica mais a necessidade de intervenção judicial nos casos em que há a morte do fiduciário (forma mais comum de extinção do fideicomisso) ou do usufrutuário, pois a apresentação da certidão de óbito em Cartório para averbação do registro, se bem imóvel (art. 1.391 do CC/2002), é bastante para a extinção dos institutos.³⁰⁶

3.8.2.2 Renúncia

A renúncia é forma de extinção prevista para os dois institutos, conforme se observa do quadro acima. Quanto a esta (renúncia), para a sua validade, entendeu o legislador adotar os ensinamentos de Pontes de Miranda, o qual assevera que “ainda que se trate de pessoas capazes, a renúncia por escritura pública tem de ser apresentada na ação do art. 1.112, inc. VI, do CPC/1973 [atual art. 725, inc. VI, do CPC/2015]”.³⁰⁷

Dessa forma, ainda que haja renúncia por escritura pública, “o oficial de justiça só cancela o registro mediante requerimento que contenha o mandamento judicial, ou se lhe manda, diretamente, o juiz”.³⁰⁸

3.8.2.3 Competência

Determina-se a competência pela: a) conexão – se os institutos proveem de verba testamentária, é competente o juiz do inventário e partilha dos bens deixados em usufruto ou em fideicomisso; b) ligação ao domicílio do doador ou outorgante – ressalta Pontes de Miranda que pode não ser o lugar da doação ou do negócio, o juízo desse domicílio, *em regra jurídica não prevista*; c) situação do bem imóvel.³⁰⁹

Assim, tem-se que se a origem dos institutos for testamentária, o foro competente será o do juízo do inventário, conforme art. 48 do CPC/2015, e por dependência na vara onde ocorreu o antigo feito, se havendo mais de uma, nos termos do art. 286, inc. I, do CPC/2015. Se por ato entre vivos (como, por exemplo, doação) será competente o foro: a) *se bem móvel* : do domicílio do requerente, nos termos do art. 46 e parágrafos, do CPC/2015, em que pese o artigo falar em “réu” e o interessado se equiparar ao “autor”; b) *se imóvel* : o da situação do bem, conforme art. 47, 1.ª parte, do CPC/2015.³¹⁰

3.8.2.4 O procedimento

Estabelecido o foro competente (v. item 3.6.2.3), o procedimento será o seguinte: “a) citação dos interessados (v. g ., inventariante, se houver sucessão aberta; e Fazenda Pública, para fins fiscais, se houver tributo a ser liquidado); b) avaliação do bem [a fim de constatar se foram cumpridas as obrigações pelo usufrutuário ou pelo fiduciário, bem como para apuração de direito fiscal. Ressalta-se que o cálculo do imposto sobre a extinção do usufruto ou de fideicomisso será feito pelo contador do juízo, não sendo necessária a manifestação dos interessados sobre ele, nem que seja proferido em sentença];³¹¹ c) pagamento do imposto com a juntada dos conhecimentos respectivos; d) sentença, declarando o gravame, de natureza constitutiva. Se alguém se sentir prejudicado, poderá interpor apelação, que será recebida no efeito meramente devolutivo”.³¹²

Declarada a extinção do fideicomisso, se houver, porém, vários interessados (fideicomissários), proceder-se-á a partilha, obedecendo-se, também, às normas para inventário, havendo posterior transmissão do bem (ou bens) aos interessados (herdeiros em expectativa).³¹³

3.8.2.5 Desaparecimento da fiduciariade

Cumprida a condição resolutória e, assim, extinto o fideicomisso, não há mais fiduciário, tornando-se estranho para a herança que um dia foi sua. As ações contra ou a favor dos bens da herança já não lhe interessam, não estando autorizado a prosseguir, seja como autor ou réu, em tais processos.

Para Pontes de Miranda, a mudança de sujeitos opera-se *ipso iure* , ao chegar o advento do termo, ou ao realizar-se a condição. Todavia, se deixou de pagar alguma dívida para quem recebeu dinheiro da herança, a sua responsabilidade continua.³¹⁴

Após a entrega dos bens ao fideicomissário, o fiduciário não é mais responsável pelas obrigações da herança. Dessa forma, ainda que posteriormente algum herdeiro retardatário recuse sua quota, ou transite em julgado a sentença que pronunciou a indignidade de um deles, este acréscimo já não lhe aproveita, apenas ao fideicomissário.

Quanto às dívidas contraídas pelo fiduciário, ainda que para a exploração e administração dos bens, cumpre destacar que estes não respondem porque sua destinação os imuniza às obrigações do fiduciário. Pontes de Miranda afirma que: “Os credores da herança são credores do fiduciário, até o montante dos bens herdados, e do fideicomissário, até o mesmo importe”.³¹⁵ Portanto, feito o inventário judicialmente, respondem fiduciário e fideicomissário pelas dívidas da herança que aparecem, salvo sobre aquelas que excedem às forças da herança.

No instante em que o fideicomissário recebe a herança, responde na qualidade de herdeiro. Porém, se o fiduciário não pagou as dívidas a ela correspondentes, paga-as o fideicomissário, assim como os impostos atrasados, multas aplicadas sobre o bem, possuindo, porém, direito de ação contra o fiduciário.³¹⁶

Outro ponto muito importante a se destacar é que os credores do fiduciário não são credores da herança, bem como as dívidas daquele (fiduciário) garantidas pelos bens (hipoteca, penhor, anticrese, caução), com a mudança de sujeitos da propriedade, todas se extinguem, mas somente em relação aos bens, permanecendo o direito de ação dos credores quanto ao fiduciário. Pontes de Miranda ressalta que “se o fiduciário pagou, com dinheiro seu, a hipoteca de bem fideicomitido, dá-se a sub-rogação a seu favor (...)”,³¹⁷ conforme arts. 346, inc. III, e 349, ambos do CC/2002.

3.8.2.6 Impostos

Diante se analisará os impostos que incidem sobre os bens objeto do usufruto e fideicomisso em decorrência de suas extinções.

3.8.2.6.1 Usufruto

Entende Pontes de Miranda que, por haver transmissão do uso e fruto ao proprietário, deverá ser pago o ITCD (Imposto de Transmissão Causa Mortis ou Doação de Bens e Direitos – ITCMD), que será o do tempo da extinção do usufruto, pois, segundo o autor, o outro, o que concerniu ao direito de nua propriedade, já fora pago ao tempo da sucessão. Dessa forma, haveria o pagamento do imposto em dois momentos diferentes: a) no da constituição do usufruto (abertura da sucessão ou doação) e b) no da extinção.

Como se sabe, o art. 155, inc. I, da CF/1988, atribui competência aos Estados e ao Distrito Federal para instituir o ITCD ou ITCMD, devendo se observar a lei de cada Estado (e do DF) para se analisar, caso a caso, a questão. Parece ser um pouco demasiado adotar o pensamento do autor como regra, havendo, inclusive, julgados em sentido contrário.³¹⁸

Porém, há quem entenda exigência quando da extinção.³¹⁹

3.8.2.6.2 Fideicomisso

Quanto à extinção do fideicomisso, o mesmo autor aduz que: “O fideicomisso dá ensejo a duas aquisições de domínio: há duas transmissões simultâneas; os impostos são os do tempo da abertura da sucessão. Se a lei permitiu dividir-se em duas parcelas o imposto do fideicomissário, uma por ocasião da execução testamentária, outra por ocasião da extinção do fideicomisso, houve favor da lei”.³²⁰

Como se vê, entende o autor que, da mesma forma como no usufruto, o fideicomisso gera obrigação tributária sobre as duas situações (instituição e extinção), mas aqui o tributo seria devido simultaneamente.

Ocorre que, da mesma forma que ressaltado no item anterior, a jurisprudência diverge acerca da matéria.³²¹

3.8.2.7 Natureza jurídica da sentença

A sentença aqui é uma só, porém, julga-se o cálculo (se houver); julga extinto o usufruto ou fideicomisso e julga a partilha.

Pontes de Miranda sustenta que “na parte em que julga extinto o usufruto é mandamental negativa, de efeitos constitutivos (efeitos *erga omnes*) de integração da publicidade (dos direitos reais), e não declarativa, a despeito do forte elemento declarativo”. Continua o autor dizendo que: “A distinção é de consequências práticas consideráveis. O usufruto e o fideicomisso estavam extintos, *ex hypothesis*; nas relações entre o usufrutuário e o nu-proprietário ou entre o fiduciário e o fideicomissário, a extinção, por direito material, começara a produzir todos os efeitos. Enquanto a outrem, a publicidade é indispensável e é a isso, não à declaração por sentença, que o chamado processo de extinção do usufruto ou do fideicomisso provê. É a extinção, no plano do direito público, que é processual”.³²²

Assim, percebe-se que os dois elementos preponderantes são o mandamental (situação de publicação do direito real) e o executivo do direito de caráter privado.³²³

3.8.2.8 Recurso

O recurso cabível é o de apelação, nos termos do art. 724, do CPC/2015.

3.9 Expedição de alvará judicial

O alvará judicial constitui-se autorização para a prática de ato, não podendo substituir o contencioso e não comportando a formação de processo com objeto litigioso. Há quem entendesse que se tratava de ato de mera fiscalização.³²⁴

Trata-se de mais uma inovação trazida para o CPC/2015, a fim de encerrar as diversas discussões quanto à submissão do procedimento às regras gerais de jurisdição voluntária, já que não havia unanimidade quanto ao caráter exemplificativo do rol apresentado no antigo art. 1.112 do CPC/1973.³²⁵ Porém, em razão da similitude entre o procedimento ora descrito (alvará judicial) e os de jurisdição voluntária, a doutrina, bem como a jurisprudência, já o reconheciam como tal, submetendo-o às regras gerais dos arts. 1.103 a 1.112, do CPC/1973 (arts. 719 a 724 do CPC/2015).³²⁶ Nesse sentido, há inúmeros acórdãos, por exemplo, com o fim de atender a “requerentes, todos maiores, (...) únicos herdeiros do de cujus, [sem] outros bens a partilhar, o crédito é de pequena monta e não há resistência do consórcio quanto à pretensão de levantamento do fundo de reserva existente em nome do consorciado falecido”.³²⁷

Também quando “valores não recebidos em vida pelo segurado da Previdência Social ou de outros seguros que podem ser pagos aos dependentes habilitados junto à previdência independentemente de inventário ou arrolamento”.³²⁸ Havendo uma pluralidade de bens, o alvará não se presta como procedimento, sendo adequado o inventário.³²⁹

Dessa forma, o legislador apenas formalizou o entendimento que havia sido consolidado pela jurisprudência, de que o Alvará judicial está submetido às regras da jurisdição voluntária.

3.9.1 Aspectos materiais do alvará

O conteúdo material envolvido nos alvarás que autorizam, por meio não contencioso, o levantamento de valores pode ser dos mais variados, tais como previdenciário, trabalhista, securitário, infortunistico, mercantil e outros.

3.9.1.1 Conceito e classificações

A doutrina reconhece como sendo uma ordem escrita, proferida por uma autoridade judicial ou administrativa, para que se cumpra uma decisão, seja por sentença ou por despacho (quando judicial) ou para que se possa praticar determinado ato (quando administrativa).³³⁰ Aqui, entretanto, interessa apenas o judicial, pois trata-se de ação específica direcionada ao poder judiciário.

Assim, os alvarás Judiciais são classificados, ainda, segundo a forma de ajuizamento e quanto ao contexto de ajuizamento – se cível ou penal. Quanto à forma de ajuizamento pode-se dividi-los em dois grupos: autônomos e incidentais.

O autônomo é aquele que existe por si só, proveniente de ação própria.³³¹ Pode-se citar como exemplo, o pedido de alvará judicial para a retirada de FGTS de marido falecido, requerido pela viúva, previsto na Lei 6.858/1980 e pelo Decreto 85.845/1981. Já o incidental é aquele que necessita de um processo preexistente para sua existência. As suas peças se encontram nos autos de outro processo, tido como principal, sendo que seu processamento se dará nos mesmos autos e não em autos apensos.³³²

Como exemplo, pode-se citar o pedido de alvará judicial para a venda de bem imóvel pertencente à menor, órfão de pai e representado pela mãe ou por tutor, em processo de inventário.

Como se pode ver, aqui interessa apenas os Alvarás Judiciais de âmbito Civil e autônomos.

3.9.2 Natureza jurídica

Carlos Mendonça afirma que, a grosso modo, “(...) o alvará judicial presta-se ao requerente para confirmar seu direito e, à autoridade a que é dirigida, para informar que o beneficiário do mesmo está autorizado a exercer tal direito”.³³³ Assim, sua natureza jurídica, em regra, é de autorização judicial e não de ordem judicial.³³⁴ Isso porque, conforme aduz o autor, o alvará tem origem em procedimento em que não se observa o contraditório ou a ampla defesa, bem como o juiz, nos termos do parágrafo único do art. 723, do CPC/2015 (antigo art. 1.109 do CPC/1973), não está adstrito aos critérios da legalidade estrita.³³⁵

A falta de contraditório inviabiliza, assim, a cognição exaustiva, haja vista ser levado a efeito apenas em nível formal, retirando do alvará o caráter cominatório.³³⁶

Não havendo caráter cominatório, não há falar em penalidade por desobediência, nos termos do art. 330 do Código Penal, tendo em vista que, conforme apontado, não há força obrigacional de fazer ou deixar de fazer, possuindo apenas efeito de autorização judicial e não ordem. Poderá, portanto, ser descumprido o alvará judicial sem que haja as penas da lei, desde que o descumpridor justifique ao juiz, de forma fundamentada, o porquê de tal descumprimento.³³⁷

Assim, via de regra, o alvará judicial terá natureza jurídica de autorização e não de ordem judicial.

3.9.3 Aspectos processuais do procedimento

Além das hipóteses de cabimento, participação dos interessados, integração do Ministério Público e Fazenda Pública, petição inicial, instrução e diligências serão tratados brevemente aspectos da sentença e dos eventuais recursos.

3.9.3.1 Hipóteses de cabimento

Tratando-se de alvará judicial autônomo, verifica-se hipótese de cabimento com base na Lei 6.858/1980 e Decreto 85.845/1981 (regulou a Lei). Assim, podem ser recebidos por meio de alvará judicial autônomo, pelos dependentes habilitados, ou, na ausência destes (dependentes), os sucessores do titular, distribuídos em cotas iguais, os valores a título de FGTS, PIS ou PASEP e demais hipóteses previstas nos incisos seguintes do parágrafo único do art. 1.º, do Decreto 85.845/1981, não recebidos pelo falecido(a) em vida,³³⁸ independente de inventário ou arrolamento, conforme se verifica no *caput* do art. 1.º, do Decreto.

A autonomia do alvará judicial está justamente na exceção para percepção de valores deixados pelo *de cujus*, nos termos do art. 666, do CPC/2015, sem que seja necessária abertura de inventário, ou mesmo de arrolamento, como determina o art. 610 do CPC/2015.³³⁹

Assim, o procedimento para expedição de alvará judicial autônomo será cabível quando houver os seguintes valores a serem recebidos pelos dependentes habilitados ou sucessores do titular (incs. do Decreto 85.845/1981): a) quantias devidas a qualquer título pelos empregadores a seus empregados, em decorrência de relação de emprego; b) quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou emprego, pela União, Estado, Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas autarquias, aos respectivos servidores; c) saldos das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS/PASEP; d) restituições relativas ao imposto de renda e demais tributos recolhidos por pessoas físicas; e) saldos de contas bancárias, saldos de cadernetas de poupança e saldos de contas de fundos de investimento, desde que não ultrapassem o valor de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não existam, na sucessão, outros bens sujeitos a inventário.

Dessa forma, entende-se que no que diz respeito ao item “e”, a lei criou dois requisitos de cabimento que devem ser observados: não haja outros bens sujeitos a inventário e que o valor a ser levantado não ultrapasse o montante de 500 ORTN, caso em que, não havendo demonstração inequívoca destes requisitos, o procedimento será julgado improcedente sem resolução de mérito. Tal hipótese foi largamente utilizada para levantamento de valores do FGTS,³⁴⁰ mas “para levantamento dos saldos

bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento”.³⁴¹ Não se presta o procedimento de alvará ao debate sobre o acerto de medida administrativa ou judicial de alienação do mesmo bem.³⁴²

3.9.3.2 Interessados

O Decreto mencionado, assim como a Lei 6.858/1980, determina que estes valores devem ser percebidos pelos dependentes habilitados (interessados), ou seja, aqueles vinculados à instituição de Previdência ou, se for o caso, ao órgão encarregado, na forma da legislação própria, pelo processamento do benefício por morte, nos termos do art. 2.º, do Decreto 85.845/1981 e do art. 1.º, da Lei 6.858/1980. Na falta destes, os valores serão devidos aos sucessores legais do titular (ordem de sucessão), nos termos do art. 5.º, do Decreto e art. 1.º, da Lei citada. Caso não se verifique nenhum destes (dependentes ou sucessores legais), os valores se reverterão em favor, respectivamente, do Fundo de Previdência e Assistência Social, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou do Fundo de Participação PIS-PASEP, conforme se tratar de quantias devidas pelo empregador ou de contas de FGTS e do Fundo PIS-PASEP, nos termos do art. 7.º, do Decreto.

Como se pode notar, os interessados serão determinados conforme caso concreto, sendo que, via de regra, os interessados requerentes serão: os dependentes ou os sucessores; e os demais interessados serão: as instituições à que a verba está vinculada (*exemplo*: se FGTS, será necessária a citação da Caixa Econômica Federal).

No que diz respeito à quota direcionada aos dependentes menores de 18 anos (caso haja), o art. 6.º, do Decreto prevê que estes valores deverão ser consignados em caderneta de poupança até que o menor complete a maioridade, salvo autorização do juiz para aquisição de imóvel destinado a residência do menor e de sua família ou para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor.

3.9.3.2.1 Ministério Público

A participação do ente ministerial estará vinculada à presença de uma das hipóteses previstas nos incs. do art. 178, do CPC/2015, conforme determina o art. 721, do mesmo Código. Em regra, se verificará a atuação deste em casos em que um ou mais dependentes sejam menores ou incapazes, nos termos do inc. II, do art. 178, do CPC/2015.

3.9.3.2.2 Fazenda Pública

Da mesma forma, a participação da Fazenda Pública está associada à defesa de interesses dos entes que integram a Administração Pública. Deve-se analisar caso a caso para determinar o interesse jurídico e econômico (salvo na intervenção anômala). A jurisprudência tem entendido que, em determinados casos (dependendo da legislação estadual que regula o imposto), não há incidência de ITCMD ou ITCD nas hipóteses previstas na Lei 6.858/1980 e Decreto 85.845/1981, art. 1.º, inclusive aqueles oriundos de previdência privada.³⁴³

3.9.3.3 Petição inicial e documentos indispensáveis

O procedimento terá início com a provocação de um ou mais interessados, conforme art. 720 do CPC/2015. A petição inicial deverá obedecer aos requisitos previstos no art. 319 do CPC/2015 (juntando os documentos que comprovem os dados do requerente), bem como indicar todos os possíveis interessados no procedimento, conforme art. 721, do CPC/2015, isso inclui o Ministério Público (nas hipóteses do art. 178 do CPC/2015) e a Fazenda Pública (nos termos do art. 722, CPC/2015). A citação dos interessados é de extrema importância, podendo ocasionar a nulidade do procedimento.³⁴⁴

O interessado deverá demonstrar que o valor por ele pretendido, primeiramente, está elencado nos incs. do § 1.º do art. 1.º, do Decreto 85.845/1981, bem como que estes não foram levantados ou utilizados pelo titular em vida (*caput* do art. 1.º do Decreto). Se os valores por ele pretendidos forem os descritos no inc. V, deverá demonstrar que não há outros bens sujeitos a inventário, bem como que o valor a ser levantado não ultrapassa o montante de 500 ORTN.

A condição de dependente, conforme determina o art. 2.º do Decreto, será demonstrada por documento fornecido pela instituição de Previdência ou, se for o caso, pelo órgão encarregado, na forma da legislação própria, do processamento do benefício por morte. O parágrafo único do artigo citado determina, expressamente, os dados necessários que deverão constar no documento fornecido, quais

sejam: o nome completo, a filiação, a data de nascimento de cada um dos interessados e o respectivo grau de parentesco ou relação de dependência com o falecido.

A inexistência de outros bens sujeitos a inventário, para os fins do item V, parágrafo único, do artigo 1.º, será comprovada por meio de declaração (modelo anexo ao Decreto 85.845/1981), firmada pelos interessados perante a instituição onde esteja depositada a quantia a receber, nos termos do art. 4.º do Decreto. Esta declaração, conforme preceitua o § 1.º do artigo mencionado, goza de presunção de veracidade e, caso verifique-se tratarem-se de afirmações inverídicas, será dado conhecimento do fato à autoridade competente, dentro de 5 (cinco) dias, para instauração de processo criminal, conforme §§ 2.º e 3.º do art. 4.º do Decreto.

3.9.3.4 Competência

Segundo a Súmula 161 do STJ, é competência da Justiça Estadual autorizar o levantamento dos valores relativos ao PIS/PASEP e FGTS, em decorrência do falecimento do titular da conta. Segue o mesmo raciocínio, as demais hipóteses de cabimento do procedimento.

É possível o conflito negativo de competência, como já julgou o Superior Tribunal de Justiça.³⁴⁵ Pode, contudo, ser competente a Justiça Estadual quando não demonstra interesse a União.³⁴⁶ 342

Pode-se, ainda, questionar se a competência é de vara especializada (Família e Sucessões) ou da Vara Comum. Entende-se que a melhor solução é a adotada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas ao julgar conflito negativo de competência, nos autos de número 0002773-27.2011.8.02.0058, que teve como relator o Des. James Magalhães de Medeiros da Seção Especializada Cível, em que se entendeu pela competência da Vara Comum, tendo em vista que a lei autoriza expressamente o levantamento das quantias requeridas (no caso saldo de poupança) independentemente de inventário ou arrolamento, justamente para desburocratizar o levantamento desses pequenos valores para serem usados de imediato e, assim, suprir as necessidades urgentes dos dependentes. Em que pese alguns Tribunais adotarem entendimento diverso.³⁴⁷

3.9.3.5 Recurso

Da sentença que deferir ou indeferir o pedido de expedição, caberá recurso de apelação, nos termos do art. 724 e art. 1009, e seguintes do CPC/2015. Essa possibilidade é concreta especialmente quando da denegação da expedição de alvarás para registro imobiliário em vista da contenciosidade surgida;³⁴⁸ ou pretensão que a Administração resiste.³⁴⁹

3.10 Homologação de autocomposição extrajudicial, de qualquer natureza ou valor

É uma inovação expressiva considerar-se a homologação da autocomposição extrajudicial como jurisdição voluntária com a extensão agora dada. Não é uma inovação integral na legislação processual brasileira a possibilidade de homologação de acordo extrajudicial e seu reconhecimento como título executivo judicial. A Lei dos Juizados de Pequenas Causas, Lei 7.244/1984, art. 55, já previra essa possibilidade e, depois, a Lei 9.099/1995, repetiu a previsão no art. 57.³⁵⁰ O CPC/1973, com a alteração incluída pela Lei 11.232/2005 também passara a considerar como títulos executivos os acordos extrajudiciais homologados em juízo,³⁵¹ sem, contudo, dizerem que se tratava de jurisdição voluntária. A doutrina, em ambos os casos, via na inovação nos juizados especiais como o atendimento de um vazio existente no processo civil, que só admitia a justificável tutela como pedido de sentença de mérito.³⁵² Não notou a maior parte da doutrina que examinava os juizados especiais tratar-se de atividade típica da jurisdição voluntária. Exceção deve ser registrada em relação a José Maria Tesheiner quando observou que “o ato de homologação de acordo extrajudicial é, por natureza, ato de jurisdição voluntária”.³⁵³ A inclusão no CPC/1973, em 2005, teve também boa recepção da doutrina.³⁵⁴

Rompe-se uma postura tradicional e se reconhece à jurisdição voluntária – atividade jurisdicional sem função de solução de controvérsias – a de homologar o fim das controvérsias. Agora estende-se a possibilidade de homologar o final de controvérsias em todas as causas e às mais diversas matérias, sem as limitações de valor próprias dos juizados especiais.

3.10.1 Aspectos materiais da homologação judicial de autocomposição extrajudicial

Admitem a autocomposição os direitos considerados disponíveis. Essa definição singela induz a erros cada vez mais evidentes, uma vez que se associava a disponibilidade dos direitos estritamente aos

interesses privados, quando, a rigor, há interesses privados de caráter não patrimonial que não admitem autocomposição (estado das pessoas), e há uma gama cada vez mais ampla de interesses públicos que admitem a transação.

3.10.1.1 Recepção da conciliação como ato de jurisdição voluntária

Já se observou no *Breve Ensaio Inicial* que a conciliação é vista como a forma consensual de pôr fim ao conflito (material ou processual), por meios diversos, tais como a desistência, a renúncia, o reconhecimento do direito ou a transação; pode se dar de forma *preventiva* (ou *pré-processual*) e *sucessiva* (ou *endoprocessual*) , conforme o momento de sua realização; pode também se dar no ambiente jurisdicional ou administrativo.

Para Eduardo Couture, conciliação é o gênero e a transação é espécie. Sempre que se transige se concilia; nem sempre que se concilia se transige.³⁵⁵ Questão central, e de difícil solução, é saber se todos os atos de conciliação, independentemente do momento de realização e da intensidade da participação do órgão jurisdicional, são atos de jurisdição voluntária.³⁵⁶

3.10.1.2 Solução consensual ou conciliação de controvérsias envolvendo interesses privados

Mantém-se, prioritariamente, como meio de solução de conflitos privados de direitos que admitam composição. Já era discutível a exclusividade do envolvimento de interesses ou direitos privados na jurisdição voluntária; Elio Fazzalari se refere à tendência italiana que acrescentou à terminologia tradicional de *jurisdição voluntária* a posterior, atraente, mas genérica de *administração pública de direito privado* , criticada pelos autores alemães, por tratar também de interesses públicos.³⁵⁷

3.10.1.3 Solução consensual ou conciliação de controvérsias envolvendo interesses públicos especiais transigíveis e disponíveis

Reiteramos aqui o que foi dito acima, o que agora se admite é outra e está relacionada à *transigibilidade*³⁵⁸ de interesses públicos, à *transigibilidade e disponibilidade de valor limitado* desses interesses e à *transigibilidade e disponibilidade de valor não imitado* na Administração Pública. Se se pode tratar os interesses públicos ou da Administração Pública com transigíveis ou disponíveis, não se pode excluir de plano possam eles ser tratados na jurisdição voluntária, após a inclusão no rol dos procedimentos de jurisdição voluntária da “homologação de autocomposição extrajudicial, de qualquer natureza ou valor” (art. 725, inc. VIII).

Desde a década de 1990 vêm se ampliando as possibilidades de transação na Administração Pública com sucessivas normas especialmente federais, que autorizam de forma limitada a conciliação e transação³⁵⁹ e depois, as que autorizam de forma ampla a conciliação e transação,³⁶⁰ as que admitem a arbitragem³⁶¹ e a mediação³⁶² para a solução de conflitos da Administração e outras técnicas antes admitidas apenas para resolução de disputas patrimoniais privadas.

Todas as *portas* do *Sistema Multiportas* idealizado politicamente como alternativa legislativa à crise da multilitigação são chamados também de *meios alternativos de solução de conflitos* , ou *equivalentes jurisdicionais* , tais como a *mediação*, *arbitragem*, *transação* e *espécies negociais inovadoras* .

3.10.2 Petição inicial e documentos indispensáveis

O procedimento terá início com a provocação conjunta dos interessados, representados por advogados, ou diretamente quando se autorizar à autodefesa processual civil (ação de alimentos decorrentes de parentesco, ação acidentária, procedimentos dos juizados especiais e trabalhistas).³⁶³ A petição atenderá ainda art. 720 do CPC/2015 e, também, obedecerá aos requisitos previstos no art. 319 do CPC/2015 (juntando os documentos que comprovem os dados do requerente); bem como indicar todos os possíveis interessados no procedimento, conforme art. 721, do CPC/2015, isso inclui o Ministério Público (nas hipóteses do art. 178 do CPC/2015) e a Fazenda Pública (nos termos do art. 722, CPC/2015). A citação dos interessados é de extrema importância, podendo ocasionar a nulidade do procedimento.

3.10.3 Competência

A competência de jurisdição será da justiça comum dos Estados, do Distrito Federal e da União, mas não apenas essa. Também a Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral, basta ver a disposição expressa do art. 15 do CPC. Especialmente sobre a jurisdição voluntária na Justiça do Trabalho utilizando a

“homologação de autocomposição extrajudicial, de qualquer natureza ou valor” (art. 725, inc. VIII) não há ainda óbice, especialmente por não ter sido excluída essa hipótese na Resolução 203/15-03-2016, do TST, que aprovou a Instrução Normativa 39/2016, que definiu quais institutos do CPC/2015 são inaplicáveis nessa justiça especializada.

Assim, de forma prioritária, todos os juizados poderão fazer a homologação: os *Juizados Especiais Cíveis*, limitados à sua competência de 40 salários mínimos; os *Juizados Especiais Federais* limitados à competência de 60 salários mínimos; e os *Juizados Especiais da Fazenda Pública*, limitados à competência quantitativa (20 a 60 salários mínimos) estabelecida pela lei local, passam a ser espaço de atuação da jurisdição voluntária.

A competência de foro é a dos negócios ou dos contratos ou, ainda, dos negócios processuais (art. 190), podendo as partes eleger o que lhes interessar à comodidade. Nessa eleição do foro não pode se ocultar a má-fé ou qualquer outro subterfúgio que dificulte a participação de interessado ou a atuação jurisdicional.

3.10.4 A atividade judicial de controle de eventual uso da Justiça para fim vedado

Não pode a homologação ser o campo de falsa pacificação que lesa terceiro. Criar-se um “contencioso” fictício ou *contencioso criado*, levar-se ao Estado para este atribuir o selo da pacificação e ocultar lesão a outrem não pode ser o fim da inovação.

Para o controle desse risco, que deveria ser remoto, pode o juiz e seus poderes probatórios expandidos pela natureza da jurisdição voluntária, assim com o extenso arsenal sancionatório que o CPC/2015 oferece aos participantes do processo. ³⁶⁴

3.10.5 Participação de cointeressados

Não há restrição à participação de interessados, mas este procedimento diz respeito, prioritariamente, àqueles que no plano do direito material mantinham o negócio e o potencial conflito; em princípio só a estes interessam. Há, contudo, um potencial remoto de ofensividade àqueles que, num eventual litígio com as mesmas partes seriam terceiros intervenientes. Aqui não há espaço para terceiros, mas tendo notícia da homologação judicial da transação extrajudicial podem vir ao procedimento para opor sua eventual impugnação, sem transformar o procedimento em um meio de finalização de todas as demandas entre todos.

O espaço é estreito, sob pena de evidenciar-se lide que deveria ser discutida em ação de oposição, em embargos de terceiro ou outro procedimento especial ou comum.

3.10.5.1 Intervenção do Ministério Público e da Fazenda Pública

Caso verifique-se tratar-se de hipótese de intervenção pelo Ministério Público, a petição inicial deverá ser elaborada em três vias. Apresentando defeito sanável, o juiz abrirá prazo para que a deficiência seja sanada no prazo de 15 dias, nos termos do art. 321 do CPC/2015, sob pena de extinção do feito. Se houver participação do Ministério Público, após o recebimento da inicial, este será intimado para que analise a petição e os documentos que a instruem, a fim de elaborar parecer sobre o pedido (art. 721 do CPC/2015). Se for o caso, o juiz oficiará a Fazenda Pública, a fim de que se pronuncie (art. 722 do CPC/2015). O juiz poderá, ao analisar o pedido ministerial (caso haja), conforme entender melhor, despachar para que se cumpra eventual diligência apontada como essencial pelo Promotor de Justiça, sob pena de extinção do feito (a fixação de prazo obedecerá aos comandos do art. 218 do CPC/2015). Tendo o interessado cumprido ou não a diligência, será aberto novamente prazo para vista pelo Ministério Público para que apresente parecer favorável ou não. Após isso, ou não havendo participação de qualquer dos entes citados, o juiz decidirá se o direito do interessado existe ou não.

3.10.6 Sentença homologatória, recursos e ações impugnativas

E é recorrível por apelação a sentença homologatória (art. 724) assim como pode ser objeto de ação impugnativa autônoma, ação anulatória ou ação rescisória. A “escolha” entre uma e outra hipótese está associada ao tanto quanto há de decisão no ato homologatório. Entre anulabilidade por ação anulatória (art. 966, § 4.º) e rescindibilidade por ação rescisória (art. 966, incs. I a VIII) está, e estará, associada à identificação ou não, nesses modelos procedimentais *não contenciosos*, de jurisdição, processo, lide, sentença de mérito e coisa julgada material. Quanto mais o juiz examinar fatos e direito, mais próximo se

estará da ação rescisória. Mais próximo também estar-se-á da rescisória se se evidenciarem os vícios rescisórios.

4. Procedimentos de jurisdição voluntária não previstos no CPC/2015 e indicados ou descritos em outras leis especiais

Há também uma gama de outros direitos à tutela pela jurisdição voluntária que não possuem previsão expressa ou a correspondente descrição de procedimento especial correspondente.

Listá-los seria tarefa desmedida, dada a dispersão e a possível indeterminação da lista, mas a indicação, apenas, exemplificativa de alguns desses inúmeros procedimentos indica a multifacetada forma de atuação da jurisdição voluntária. Há autores que fizeram, sem detalhamento, a indicação de parte desses procedimentos esparsos.³⁶⁵

Exemplos atuais:

a) Opção de nacionalidade é o procedimento pelo qual o estrangeiro busca nacionalidade brasileira utilizando a jurisdição voluntária; previsto no art. 3.º da Lei 818/1949, objetiva a homologação pelo juiz competente, unilateralmente, da pretensão do estrangeiro em tornar-se brasileiro; manifesta-se no procedimento o Ministério Público Federal.³⁶⁶

b) Homologação de sentença estrangeira ou de decisão interlocutória é o procedimento pelo qual se internaliza a decisão do Judiciário de outro país, para posterior cumprimento; a sentença que homologa a decisão parcial ou final estrangeira é sujeita a recurso de apelação (art. 724) e dele não se admite, em regra, ação impugnativa autônoma, anulatória e rescisória.³⁶⁷

c) Suprimento de outorga do cônjuge na separação de fato é o procedimento que objetiva substituir, na falta ocasional do outro cônjuge ou no caso de recusa ou de revogação de autorização existente de ato que deveria ser pelo ausente autorizado; são exemplos a venda de bens de titularidade exclusiva do requerente.³⁶⁸

d) Alvará de pesquisa mineral é o procedimento de jurisdição voluntária que objetiva a expedição da autorização minerária e avaliação do valor indenizatório ao proprietário do solo, com participação da União como interessada.

e) Declaração de morte presumida geralmente proposta para fins previdenciários, segue a jurisdição voluntária; pode ter a intervenção do INSS, reveste-se de certa controvérsia quando insuficiente a prova que demonstra o desaparecimento pela extinção do processo.³⁶⁹

f) Autorização para cremação em mortes não naturais é o procedimento voltado a permitir que os parentes do falecido deem o destino ao corpo decidido pelo próprio morto ou por estes parentes remanescentes, sem embaraço de eventuais investigações da causa da morte; pode ser indeferido havendo suspeitas de que pode destruir provas ou ocultar crime.

g) Depósito judicial e integral para fins de suspensão do crédito tributário é procedimento tido como de *jurisdição voluntária*; sem controvérsia, devendo o interessado se conformar com o comportamento da autoridade fiscal quanto ao montante que deverá ser depositado (Lei 6.858/1980).

h) Modificação de registro é o procedimento para a correção de erro, restauração de cancelamentos, aditamento de registros omissos; tem como legitimadas as pessoas que aparecem nos registros; sendo competente a Vara de Registros Públicos, se houver; devem ser “citados” todos os interessados que podem ser afetados pela decisão.³⁷⁰

i) Retificação de registro imobiliário é o procedimento mediante o qual se pede a alteração de dados registrais imobiliários; objetiva o ajuste documental à realidade fática, após georreferenciamento, por exemplo; pode ser unilateral ou com controvérsia; os interessados devem ser “citados” para virem defender seus direitos reais, desejando; sendo competente o foro do local da coisa e também do registro, especialmente a Vara de Registros Públicos.³⁷¹ Há casos de correção de seu registro ou averbação quando se mostrarem omissos os dados, imprecisos ou não exprimirem a verdade, mas não se presta à ampliação de imóvel impugnada por confrontante, hipótese em que perde o caráter voluntário, devendo ser disputado, se for o caso, em processo contencioso.³⁷²

j) Procedimento de dúvida é o pedido formulado pelo oficial do registro, voltado ao esclarecimento de questão posta a pedido do apresentante do título imobiliário, para que o juiz decida sobre a exigência feita, a qual o oficial entende não ter o dever de fazer no modo requerido e pretendido. ³⁷³

k) Tomada de decisão apoiada é o procedimento previsto no *Estatuto da Pessoa com Deficiência* (Lei 13.146/2015), que permite à pessoa com deficiência, por não ter afetada a plena capacidade civil (art. 6.º do Estatuto), decidir, mediante a adoção de processo de tomada de decisão apoiada por duas pessoas que a acompanham (art. 84, § 2.º, do EPD c/c art. 1.783-A do CC/2002), ressalvando-se que nem os apoiadores, tampouco seus parentes, poderão ser beneficiados pelo ato.

l) Internação psiquiátrica compulsória (IPC), ³⁷⁴ prevista na *Lei 10.216/2001*, art. 6.º, par. único, inc. III, só pode ser determinada pela Judiciário, no âmbito de um procedimento especial de jurisdição voluntária diverso e não associado à interdição, que considera regulamentação da *Portaria 2.391/2002*, art. 3.º, § 4.º.

m) Posse em nome do nascituro é o procedimento que vinha arrolado dentre os cautelares no CPC/1973, é considerada jurisdição voluntária, mediante proposição da mãe grávida, com inicial e documentos que comprovem a gravidez e o risco do perecimento de direitos, objetiva a proteção dos interesses do nascituro, com intimação de interessados. ³⁷⁵

Seção II

Da notificação e da interpelação

1. Inovações do CPC/2015 na Seção

O posicionamento das notificações e interpelações dentre os procedimentos de jurisdição voluntária no CPC/2015 corrige erro de localização posto no CPC/1973, e é alertado por grande parte da doutrina de processo civil brasileira. ³⁷⁶ Os argumentos são alinhados entre os autores, cabendo a José Frederico Marques ³⁷⁷ e a Ovídio Baptista da Silva a opinião mais objetiva: “os protestos, notificações e interpelações em geral não chegam a ser verdadeiramente medidas cautelares, correspondendo a simples medidas conservativas de direitos, que prescindem da existência de periculum in mora”. ³⁷⁸ Sem conteúdo de risco ou perigo, não se justificava a presença entre as medidas cautelares no CPC/1973 e, de igual modo, não se justifica hoje a inclusão entre a tutela provisória do CPC/2015 (arts. 294-311), por ser tutela definitiva no interesse de comunicação material.

Ainda segundo o autor, embora não possuam natureza cautelar “as notificações e interpelações (...) exigem ordinariamente um tratamento urgente”. ³⁷⁹ Isso porque constituem medidas destinadas à conservação de direitos, apesar de prescindirem de ameaça de lesão. É que se destinam à preservação do bem jurídico objeto da medida, sem que tal direito se encontre necessariamente em vias de perecer.

Tanto é verdade que não constituem procedimentos contenciosos, nos quais há, tipicamente, uma pretensão resistida e em que se busca o acerto da relação jurídica litigiosa. Antes assumem natureza de jurisdição voluntária, caracterizada pela existência de vontades receptícias entre os envolvidos, cujo interesse na intervenção do Estado-Juiz, que decorre de lei ou de ato volitivo do interessado, reside apenas no modo como se pretende formalizar ato de “manifestação de vontade”. ³⁸⁰

Nessa linha é que o art. 723 do CPC/2015 – que trata das disposições gerais dos procedimentos de jurisdição voluntária – estabelece que o juiz decidirá o pedido em 10 (dez) dias, prazo que se adequa, perfeitamente, aos fins a que se destinam as “técnicas processuais” ³⁸¹ em exame e à singeleza de seus respectivos procedimentos. Não há razão para que lapso temporal maior fosse concedido.

2. Aspectos materiais gerais da Seção – Da notificação e da interpelação

Como dito no *Breve Ensaio Inicial*, política de dualidade procedimental judicial e extrajudicial contempla a tentativa de deformalização de controvérsias, como apontado há muito por Ada Pellegrini Grinover ³⁸² e outros autores.

Segundo Galeno Lacerda e Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, nestes processos o juiz exerce função de transmissor de mensagem passada por outrem, com autoridade, às vezes de veto, algo de telegrafista. ³⁸³ A atuação da autoridade judicante restringe-se, portanto, à comunicação da vontade do interessado que requereu a notificação, interpelação ou protesto, sendo-lhe defeso deliberar sobre a existência ou não de

relação jurídica de direito material que justifique a prática do ato pretendido em Juízo.

Também em obediência aos princípios da inércia da jurisdição, e da congruência ou adstrição, o juiz há de se limitar à análise do pleito notificatório, interpelativo ou de protesto, verificando, inclusive, o preenchimento dos requisitos legais aplicáveis à espécie (interesse em manifestar vontade, relevância jurídica do assunto, identidade de relação jurídica etc.).

Humberto Theodoro Júnior, por outro lado, explica que, na realidade, a atividade do juiz nos protestos, notificações e interpelações é meramente administrativa, nada tendo de jurisdicional. Assim é “em tudo igual à do oficial do Registro de Protestos, nos casos de protestos de títulos cambiários”. Citando Pontes de Miranda, conclui que toda função julgadora se exaure com o deferimento ou indeferimento da medida.³⁸⁴ Nesse sentido, entende ainda uma parte da doutrina que “não há atividade jurisdicional propriamente dita, já que o Judiciário apenas formaliza a manifestação de vontade do particular (...)”.³⁸⁵ Desses posicionamentos, diverge Ovídio Baptista que, interpretando o mesmo texto de Pontes de Miranda, considera que função julgadora existe, o que não existe é julgamento final.³⁸⁶

Como visto, o direito que se está a proteger não está associado propriamente a risco ou prevenção de dano ou mesmo de ilícito, quase sempre secundários; são medidas mais identificadas com a conservação, com os avisos, com os alertas e com a constituição em mora, pelas quais o interessado cuida, guarda, zela e exerce a manutenção de direitos dos quais é titular. Sobre o tema, sustenta Teresa Arruda Alvim Wambier que essas não são medidas “necessárias”, podendo a “parte” obter a finalidade desejada por outros meios. Afirma ainda que “normalmente, o requerente não almeja senão imprimir maior solenidade à sua declaração”.³⁸⁷

Feitas essas considerações iniciais, é necessário ressaltar que tais medidas não se manejam somente em juízo. Arruda Alvim, em parecer sobre a notificação, notou, com propriedade, que diferem a notificação judicial e a extrajudicial, o que também se aplica às interpelações e aos protestos. Em suas razões, argumentou que a lei não elegeria duas opções a quem deseja, por exemplo, constituir seu devedor em mora, se o interessado tem que obedecer às mesmas formalidades em um e em outro caso. Considerando que o legislador admite a interpelação (bem como a notificação e o protesto) judicial ao lado da extrajudicial, tem-se que o regime jurídico da extrajudicial não há de ser o da judicial. Caso contrário, o legislador teria dito inutilidades, o que é inadmissível.³⁸⁸

Nota-se, que a palavra “protesto” não consta do nome da Seção II (*Da notificação e da interpelação*) do Capítulo XV (*Dos procedimentos de jurisdição voluntária*) do Título III (*Dos procedimentos especiais*) do Livro I (*Das normas processuais civis*) do CPC/2015, embora o dispositivo correspondente no código anterior a ela fizesse menção expressa. Como visto, no CPC/1973 a matéria era tratada na Seção X (*Dos protestos, notificações e interpelações*) do Capítulo II (*Dos procedimentos cautelares específicos*) do Título Único (*Das medidas cautelares*) do Livro III (*Do processo cautelar*), na qual o vocábulo compunha o nome da Seção respectiva.

A nova lei deixou de disciplinar o protesto com maiores detalhes, optando o legislador por definir, e regulamentar, com certa minúcia apenas as notificações e interpelações, permitindo, no entanto, que as mesmas regras (igual procedimento) se apliquem ao protesto judicial no que couber (art. 726, § 2.º). O contrário não haveria de ser, porquanto há regulamentação específica e detalhada, por exemplo, para o protesto extrajudicial de títulos e outros documentos de dívida ativa, qual seja, a Lei 9.492/1997, *alterada pela Lei 12.767/2012*.³⁸⁹

Em sentido contrário, era sobre o protesto que o CPC/1973 dispunha de forma mais pormenorizada, permitindo que fossem aplicadas suas regras às notificações e interpelações por expressa disposição do art. 873. Assim dizia a lei: “Nos casos previstos em lei processar-se-á a notificação ou interpelação na conformidade dos artigos antecedentes”.

Ainda assim, fato é que o CPC/2015 continua a disciplinar o protesto judicial, pelo que os motivos de sua omissão no nome da Seção correspondente não estão claros.

3. Aspectos processuais e procedimentais gerais da Seção

Imprescindível detalhar o conteúdo processual e técnica procedimental, os sujeitos, competência, atos processuais, documentos, sentença e detalhes receptícios do exercício da jurisdição.³⁹⁰

3.1 Conteúdo, objeto ou fim processual

A notificação, a interpelação e mesmo o protesto judicial se assemelham quanto ao procedimento, mas se diferenciam quanto ao conteúdo, isto é, quanto à pretensão (objeto ou fim processual) que veiculam. Embora todos constituam forma de manifestação de vontade ou conhecimento, tem-se que a primeira contém pedido de comunicação de fato específico, ao passo que a segunda se destina a obter do interpelado um comportamento omissivo (não fazer) ou comissivo (fazer), atrelado ao direito material (este não analisado pelo juiz). O protesto judicial, por sua vez, objetiva afirmar a titularidade de um direito ou manifestar a intenção de exercê-lo.³⁹¹

Sobre a notificação, dispõe o *caput* do art. 726 que quem tiver interesse em manifestar, formalmente, sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito. Aqui objetiva-se dar a conhecer, e não exatamente exigir ou afirmar algum direito. Pontes de Miranda observava que a notificação pura comunica conhecimento e não admite impugnação, “mas estabelece plano sobre o qual se tem de exercer, eventualmente, os deveres de afirmação e de prova, bem como se hão de apurar as consequências da ciência do notificado e da sua conduta”. “A notificação que comunica vontade é menos frequente, porém suscita atitude do notificado”.³⁹²

A respeito da interpelação, o art. 727 estabelece que também poderá o interessado interpelar o requerido, no caso do art. 726, para que faça, ou deixe de fazer, o que o requerente entenda ser de seu direito. Para Pontes de Miranda, a medida “apenas comunica que se exerce a pretensão: adverte o devedor; é ato do credor, por exemplo, entre a pretensão e a ação que vai nascer da mora. É a *interpellatio* das fontes romanas. Se o interpelado nada deve, é de todo ineficaz; outrossim, se deve outra coisa”.³⁹³

Já quanto ao protesto, o CPC/2015 não deixa claro seu objeto. Limita-se o § 2.º do art. 726 a dispor que as regras impostas às notificações se aplicam, no que couber, ao protesto judicial. Assim, para conhecer seu objeto tem-se de buscá-lo na doutrina e na jurisprudência. É que a nova lei processual civil não inovou quanto a sua finalidade, pelo que é de se considerar mantida a definição já firmada.

Desse modo, Pontes de Miranda define o protesto judicial como “ato processual que supõe ter o protestante declarado o direito a respeito de si próprio, ou a emissão de manifestação de vontade complementar de outra, ou delimitadora da esfera jurídica do protestante, ou manifestação de vontade, ou comunicação de vontade de exercer alguma pretensão. Não tem efeitos que dependam de atos de outrem; são seus. Tem por fim constituir para a prova (protestar) da intenção do agente, ou conservar algo com ela (...)”.³⁹⁴

De forma mais direta, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero destacam que a finalidade do protesto é afirmar a titularidade de um direito ou manifestar a intenção de exercê-lo.³⁹⁵

Tanto a notificação, quanto o protesto, são medidas que possuem consequências jurídicas em si mesmas, ao passo que a interpelação depende do comportamento omissivo ou comissivo que se pretende do interpelado.³⁹⁶

Ressalte-se, entretanto, que em qualquer dessas hipóteses é vedado ao interessado, por óbvio, pretender fim ilícito ou qualquer arbítrio contra o notificado, interpelado ou em face do qual se protesta. De igual modo, não se pode admitir que o ato notificatório, interpelativo ou de protesto imponha ao “requerido” prejuízo superior ao que sofrerá o “requerente” caso não lhe seja deferida a medida judicial.³⁹⁷

Por isso, a despeito dos limites da atividade judicante intrínsecos a esses procedimentos, pode o juiz indeferir o pedido formulado na petição inicial em determinadas situações, conforme será esclarecido com maiores detalhes adiante.

3.2 Sujeitos processuais

Vale destacar quanto aos sujeitos processuais, apenas os interessados e os terceiros, de restrita possibilidade de participação nestes procedimentos de comunicação.

3.2.1 Interessados

Tratando-se de procedimentos de jurisdição voluntária, aos envolvidos na relação jurídica que

justificou o pedido judicial, como referido no *Breve Ensaio Inicial*, não se atribui o nome de partes, mas de interessados, os quais podem ser chamados, apenas para fins de distinção quanto a quem se refere, de promovente (aquele que promove o pedido) e promovido (aquele em face do qual o pedido é formulado) ou, respectivamente, requerente e requerido ou ainda demandante e demandado. Aqui é possível perceber, com maior clareza, o acerto do legislador em retirar do livro das medidas cautelares as notificações e interpelações. Afinal, não havendo conflito de interesses, mas vontades que convergem sem lide, não há motivo para a polarização da demanda.

Diante disso, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero sustentam que tem interesse na medida aquele que, à vista do contexto fático-jurídico narrado, precisa da medida postulada, presente a adequação legal da finalidade apontada pelo demandante. Assim, “a demonstração de interesse liga-se à necessidade de impedir protestos, notificações e interpelações indevidos, cujas realizações possam acarretar prejuízo para o tráfego jurídico – vale dizer, para a livre circulação de bens mediante negócios lícitos”.³⁹⁸

Trata-se aqui, segundo Galeno Lacerda, de “interesse legítimo”, assim compreendido aquele apresentado pelo promovente na petição inicial como motivação para o deferimento da medida, o qual deve ser sempre caracterizado pela ausência de nocividade (“não nocividade” do interesse).³⁹⁹ O fim pretendido pelo interessado não pode ser prejudicial ao promovido, a terceiros ou, de um modo geral, ao interesse público.

O requisito do interesse está, portanto, diretamente ligado ao proveito útil da manifestação formal de vontade que se justifica pela relevância jurídica do assunto abordado, exigindo-se, sempre, que a pretensão do requerente seja exercida sobre pessoas que integram uma mesma relação jurídica de direito material. Trata-se da regra do art. 726, que se extrai dos termos e alocações “interesse em manifestar”, “formalmente”, “vontade”, “sobre assunto juridicamente relevante” e “pessoas participantes da mesma relação jurídica”.

3.2.2 Terceiros e sua improvável intervenção

Sendo as notificações, interpelações e protestos, procedimentos de jurisdição voluntária, não destinados ao accertamento de relação jurídica de direito material, a intervenção de terceiros é, *em regra*, inadmissível. Não se trata de proibição legal expressa, mas de incompatibilidade fático-jurídica decorrente da natureza do procedimento e do fim a que se destinam as modalidades de intervenção de terceiros.

Esse entendimento se deve ao fato de não haver bem da vida em litígio sobre o qual possa haver interesse de pessoa estranha ao vínculo jurídico inicialmente apresentado ao Estado-Juiz, mas tão somente comunicação de vontade livre e incondicionada ou de conhecimento a qual se pretende formalizar solenemente. Logo, tratando-se de procedimento em que sequer há partes (autor e réu) litigantes, natural que a ordem notificatória, interpelativa ou de protesto emitida pelo Judiciário, não repercuta na esfera jurídica de terceiro a ponto de justificar sua intervenção nos autos judiciais.

É que as notificações, interpelações e protestos não admitem, de regra, sequer o contraditório, ante a ausência de pretensão resistida e de alegações a serem contestadas. Com menos razão, portanto, hão de permitir a intervenção de terceiros.

Sobre esse tema, Cândido Rangel Dinamarco, em análise sobre o processo cautelar (ainda sob a vigência do CPC/1973), afirmava que os protestos, notificações e interpelações talvez sejam os procedimentos em que há “menores possibilidades” de intervenção de terceiros, porquanto em feitos desse tipo o “requerido” não é chamado a participar em contraditório, nem é admitido a oferecer resposta. Com mais razão não se concebe a participação do terceiro ao seu lado. Afinal, “nada há a julgar e pretensão alguma que ele tenha poderá acomodar-se nesses processos”.⁴⁰⁰

Contudo, se por alguma razão o terceiro entender violado interesse próprio em virtude da decisão judicial que procede a notificação, interpelação ou protesto, nada impede que impetre mandado de segurança contra o ato do Juiz reputando-o coator, na tentativa de fazer valer direito líquido e certo de que se entende titular. Ou, ainda, outro procedimento direcionado em desfavor do notificante, caso entenda mais adequado. Ubiratan do Couto Maurício admite a intervenção, contrariando numeroso grupo que não admite.⁴⁰¹

Não por menos o legislador, antevendo eventuais reflexos negativos perante o “requerido” e sujeitos

alheios aos autos das medidas judiciais em apreço, já previu mecanismo de prevenção de abusos do direito de petição. É o caso do art. 726, § 1.º, o qual dispõe que, se a pretensão for a de dar conhecimento geral ao público mediante edital, *o juiz só a deferirá se a tiver por fundada e necessária ao resguardo de direito*.

3.3 Competência e inoccorrência de prevenção

Talvez o exame das regras de competência fosse mais relevante sob a égide do CPC/1973, quando as medidas aqui tratadas estavam inseridas no rol das cautelares. Ainda assim, sobretudo nesse período inicial de transição de leis, são relevantes algumas considerações sobre o tema.

Os protestos, notificações e interpelações submetem-se às normas gerais de competência, como bem consideram Pontes de Miranda,⁴⁰² Ovídio Baptista da Silva⁴⁰³ e Luiz Guilherme Marinoni e outros.⁴⁰⁴ O CPC/2015 não estabeleceu nenhuma regra específica para tanto, nem havia razão para fazê-lo. Logo, tratando-se de medidas de natureza tipicamente civil, submetem-se ao juízo cível (justiça comum federal e estadual) e, obviamente, não observam foro por prerrogativa de função, ainda que propostas em face de autoridades detentoras de prerrogativa de foro em razão do cargo que ocupam.

A competência de jurisdição pode ser da justiça comum federal ou comum dos Estados e do Distrito Federal. A competência da Justiça federal está associada à presença da União ou de seus entes, a exemplo das autarquias como o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),⁴⁰⁵ agências reguladoras (Anvisa, ANS, Anatel, Anael etc.), fundações como Fundação Nacional do Índio (FUNAI), empresas públicas (ECT e CAIXA).⁴⁰⁶ Não se tem reconhecido como competentes os Juizados Especiais Cíveis ou Juizados Especiais da Fazenda Pública, para esses procedimentos de comunicação;⁴⁰⁷ igualmente, desde muito, nos Juizados Especiais Federais.⁴⁰⁸

Ressalte-se, todavia, ser também possível o protesto na Justiça do Trabalho, como bem assevera Ovídio Baptista da Silva.⁴⁰⁹ Não se confunda aqui a chamada interpelação criminal, judicial ou extrajudicial, cabível nos casos de crimes contra a honra. Essa constitui o chamado *pedido de explicações*, e possui regulamentação própria, a saber, o art. 144 do Código Penal Brasileiro.

Para Galeno Lacerda e Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, a “competência cabe, de um modo geral, ao juízo do local do fato ou do domicílio dos interessados, salvo preceito de competência absoluta a ser obedecido. É evidente que um protesto contra venda de imóvel será dirigido ao foro cível e não ao criminal, nem aos juízes federais se o assunto escapar a sua jurisdição”.⁴¹⁰ Caso a União seja a pessoa contra quem se pretende o protesto, a notificação ou a interpelação restará justificada a competência da Justiça Federal.

Questão interessante diz respeito à arguição de incompetência absoluta e relativa, tendo em vista os procedimentos em apreço, não admitem contraditório. Ainda conforme os autores referidos, nos dois casos o interessado apenas peticionará nos autos arguindo a incompetência do Juízo, o que fará com base no seu direito de petição, sem que isso atribua caráter litigioso à demanda ou configure exercício do contraditório típico dos processos de jurisdição contenciosa. Não se admite a exceção de incompetência.⁴¹¹

Em qualquer caso, o juízo que apreciar o pedido de protesto, notificação ou interpelação, não se torna prevento para demandas futuras em que se discuta o direito de fundo, porquanto são medidas meramente conservativas de direito sem viés contencioso. Logo, não tendo o juiz conhecido do direito de fundo, não há motivo para que seja considerado prevento. Nesse sentido, o ementário que segue, baseado em jurisprudência⁴¹² majoritária e recentemente publicado.

Assim também entende Humberto Theodoro Júnior que do protesto, da interpelação ou da notificação não resulta prevenção de competência para o futuro e eventual processo, como se dá nas verdadeiras ações cautelares preparatórias.⁴¹³

3.4 Sentença e interesse recursal

Recebida a petição inicial respectiva, preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida vindicada, e ouvido o outro interessado (na hipótese do art. 728 do CPC/2015), será deferida e realizada a notificação, a interpelação ou o protesto pleiteado, consoante se extrai do art. 729 daquele diploma legislativo.

A decisão de deferimento põe fim ao procedimento de jurisdição voluntária em questão sem desafiar, *em regra*, a interposição de qualquer recurso, por ausência de previsão legal. Afinal, em seu ato decisório, o juiz se restringe ao exame formal do pedido notificatório, interpelativo ou de protesto, sem examinar o direito do interessado requerente sob o qual se funda seu pedido.⁴¹⁴

Relativamente ao interesse recursal, escreve Arruda Alvim que essas medidas, quando deferidas, “exaurem-se em si mesmas. Bastam-se”. Por isso não tem sentido se falar em cabimento de recurso. Contudo, considera uma hipótese que desafiaria a impugnação do ato decisório, qual seja, os casos em que “teria de ter havido contraditório e não houve”. “Se for o caso, caberá, a nosso ver, apelação”.⁴¹⁵

Já Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, ao analisarem a recorribilidade da decisão de deferimento da medida postulada em juízo, sustenta que “não há interesse recursal para o emprego de qualquer recurso. Porém, presente esse requisito, tem-se admitido o mandado de segurança para atacar a decisão que defere pedido de protesto, notificação ou interpelação”.⁴¹⁶ Com fundamento em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os mesmos autores consideram que a decisão de indeferimento da petição inicial constitui sentença, cujo recurso é o de apelação. Por outro lado, existindo múltiplos pedidos, se o juiz indeferir apenas um ou alguns deles, o recurso cabível é o de agravo de instrumento.⁴¹⁷

Pontes de Miranda, nos *Comentários ao CPC/1973*, entendia que não há julgamento final do protesto – nem da notificação, nem da interpelação –, motivo pelo qual toda a função jurisdicional se exaure com o deferimento ou o indeferimento. Assim, entendia que não há recurso do deferimento, porque o processo é *inaudita altera parte*, mas considera que o indeferimento inicial da medida pleiteada é indeferimento de formação de relação jurídica processual, a desafiar a interposição de recurso é o de apelação.⁴¹⁸ Desse mesmo entendimento, partilha Galeno Lacerda e Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, que vai além e entende cabível agravo de instrumento da decisão interlocutória por meio da qual “o juiz resolve alguma questão incidente, e.g., suspende a expedição de editais, mantendo, porém, a de ofícios e de mandados” ou, incidentalmente, denega a publicidade por meio de editais.⁴¹⁹ De igual modo, Humberto Theodoro Júnior afirma ser possível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que denega a expedição de edital como resolução de questão incidente.⁴²⁰

Importante considerar, contudo, que o CPC/2015 reduziu sobremaneira as hipóteses de interposição de agravo, extinguindo a modalidade retida e estabelecendo rol taxativo do cabimento do recurso na modalidade de instrumento. Assim, na nova sistemática do processo civil brasileiro apenas se cogitaria a viabilidade de agravo de instrumento nas situações suscitadas por Galeno na hipótese do art. 1.015, inc. II, caso das decisões interlocutórias que versarem sobre mérito do processo. Para tanto, é preciso entender que o mérito do procedimento de jurisdição voluntária se restringe ao pedido de protesto, notificação ou interpelação (mérito da comunicação), jamais o conhecimento do direito de fundo sob o qual tais pedidos se fundam. Ainda assim, é de se questionar a existência ou não de mérito nessas técnicas processuais.

Parte dos *Comentários ao CPC/2015* destacam que as decisões proferidas nestes procedimentos podem vir a ser recorríveis. Assim, é passível de apelação a decisão que indefere o protesto, porquanto extingue o feito, devendo o recorrente arguir razões que demonstrem o seu direito à medida ou a inexistência do fato impeditivo reconhecido pelo juiz. Entende ainda ser possível ao promovente recorrer da decisão que indefere a publicação de edital, caso entenda ser esse ato indispensável à plena eficácia do ato subjacente, bem como daquela que defere o edital, caso entenda ser o ato desnecessário ou causar-lhe prejuízo desproporcional.⁴²¹ Essa é posição mais coerente com a ideologia do CPC/2015, que prima pelo aproveitamento, de modo a evitar a proposição de novo pedido de interpelação, notificação ou protesto, admitindo-se a plena aplicação do duplo grau de jurisdição a estes procedimentos (art. 724).

3.5 Recurso

Sobre a recorribilidade da decisão de indeferimento da petição inicial, também Victor A. A. Bomfim Marins já defendia o cabimento de apelação.⁴²²

Como dito no *Breve Ensaio Inicial*, se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos gerais e documentais (arts. 319-320) ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito (art. 321), pode determinar ao autor que a emende ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias. É dever do juiz, a partir do CPC/2015, indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado (art. 321, 2.^a parte). O indeferimento ocorre se o autor não cumprir a diligência, emendando,

corrigindo ou complementando informações necessárias (art. 321, parágrafo único), decisão de extinção sem exame de mérito, recorrível por apelação.

Consoante art. 316 do CPC/2015, a extinção do processo dar-se-á por sentença. Visto isso, vê-se que, no caso dos procedimentos em exame, a decisão que defere ou indefere a medida vindicada, extingue o respectivo procedimento de jurisdição voluntária, motivo pelo qual constitui, neste simples aspecto, sentença. É o entendimento de Pontes de Miranda que afirma: “tal decisão é sentença. Dela cabe recurso de apelação; a fortiori, porque, *ex hypothesi*, algo se apreciou para se indeferir”.⁴²³

Para Ovídio Baptista da Silva, no entanto, não há sentença de encerramento do processo protestativo (notificatório ou interpelativo), a não ser a que manda que se entreguem os autos ao requerente.⁴²⁴ A esse respeito, argumenta que a decisão de indeferimento aprecia o *meritum cause* sem impedir novo pedido de protesto com novos fundamentos, o que seria impossível se tal decisão produzisse coisa julgada material.⁴²⁵ Também Humberto Theodoro Júnior sustenta que o processado é documento de livre disposição da parte, não havendo nos protestos, notificações e interpelações, qualquer espécie de sentença, nem mesmo homologatória.⁴²⁶

No entanto, a redação do art. 724 do CPC/2015 parece deixar clara a intenção do legislador em admitir algum recurso, ainda que em hipóteses limitadas, quando compatível com a natureza e finalidade de cada medida (consoante entendimentos doutrinários acima destacados), e em atribuir natureza de sentença à decisão “terminativa” proferida nestes procedimentos. O dispositivo de lei, situado na Seção I que trata das disposições gerais dos procedimentos de jurisdição voluntária, prevê expressamente que “da sentença [proferida em feitos dessa natureza – jurisdição voluntária] caberá apelação”.

Fato é que inexistindo texto expresso de lei que vede o cabimento de recurso, difícil suprimir o segundo grau de jurisdição de modo taxativo. Na prática, talvez a análise da recorribilidade esteja mais atrelada ao interesse recursal do que propriamente à natureza jurisdicional do procedimento.

De uma forma ou de outra, após adequada ciência do promovido acerca do ato deferido, e pagas as custas processuais, os autos não serão remetidos ao arquivo, mas entregues ao requerente (art. 729). Isso porque, como visto, não se está diante de litígio, razão pela qual os autos constituem apenas meio de prova em favor do promovente.⁴²⁷

Art. 726 . Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito.

§ 1.º Se a pretensão for a de dar conhecimento geral ao público, mediante edital, o juiz só a deferirá se a tiver por fundada e necessária ao resguardo de direito.

§ 2.º Aplica-se o disposto nesta Seção, no que couber, ao protesto judicial.

1. Inovações do CPC/2015

Há aqui várias inovações. Afora aquela apontada acima, de localização dentre os procedimentos especiais de jurisdição voluntária, o CPC/2015 qualificou o assunto sobre o qual se funda a vontade que se pretende manifestar; previu condições especiais para a publicação de edital; tratou do protesto judicial de forma mais secundária; definiu, de modo mais preciso, a interpelação; estabeleceu que o requerido deverá ser ouvido previamente não apenas nos casos em que o requerente pretende alcançar fim ilícito, mas, também, sempre que este objetivar a averbação da notificação em registro público.

2. Aspectos materiais das notificações para manifestação de vontade e os protestos

A nova lei processual inovou quanto à qualificação do assunto a que se refere à vontade que se pretende manifestar formalmente. O CPC/1973 previa que “qualquer intenção” poderia ser veiculada em protesto, notificação ou interpelação, ao passo que o CPC/2015 exige que a comunicação de vontade ou conhecimento se dê, exclusivamente, sobre “assunto juridicamente relevante”. Além disso, é necessário que o promovido seja participante da mesma relação jurídica de direito material que justificou o pedido notificatório, interpelativo ou protestativo.

Já do *caput* do art. 726 o legislador deixa claro o propósito da notificação: dar ciência ao promovido da vontade do requerente. Define, assim, com maior grau de detalhamento a notificação, o que não se

observava da norma anterior.

Tem-se, portanto, três requisitos essenciais para o pedido de notificação: 1) intenção de manifestar vontade lícita a outrem; 2) vontade sobre assunto juridicamente relevante, que, segundo Teresa Arruda Alvim Wambier e outros,⁴²⁸ deve ser aferida em seu viés subjetivo, não objetivamente considerada; 3) o promovido deve ser sujeito integrante da relação jurídica de fundo. Como o procedimento em apreço não constitui processo, não há dilação probatória, pelo que todos esses requisitos devem estar configurados, e demonstrados, já na petição inicial. Inexistindo contraditório, incabível audiência de conciliação ou mediação. Aliás, a inicial deve cumprir todas as exigências do art. 319 do CPC/2015, à exceção daquelas previstas nos incs. VI e VII, porquanto incompatíveis com a natureza da demanda.

O § 1.º do mesmo dispositivo estabelece condição especial e mais rigorosa, além daquelas já contidas no *caput*, para o deferimento da notificação edital. Dispõe que a pretensão de dar conhecimento geral ao público mediante edital somente será deferida *se fundada e necessária ao resguardo de direito*; caso contrário, o pedido de publicação do edital deverá ser indeferido.

Fundada e necessária é a medida pleiteada com a devida motivação, assim compreendida a fundamentação fática declinada na petição inicial. O requerente deve demonstrar, claramente, as razões que justificam a publicação de edital, bem assim a abrangência desta mesma publicação (âmbito local, estadual, regional ou nacional). É de se considerar, todavia, que sendo possível ao juiz indeferir *in totum* a medida, pode também deferir-lhe parcialmente. Assim, se pretende o promovente a notificação em edital de âmbito nacional, pode o juiz deferir-lhe apenas em âmbito local, por exemplo, se não convencido da necessidade da abrangência defendida na inicial.

Nessa linha, bem afirma Ovídio Baptista da Silva que, em certos casos, poderá o juiz indeferir parcialmente o protesto (notificação ou interpelação) negando, por exemplo, permissão para que a medida seja divulgada pela imprensa ou averbado em registro público, sem, contudo, indeferir-lo totalmente. Poderá, assim, restringir-se à intimação pessoal do requerido e de algum terceiro sem o alarde próprio das intimações edital ou da que deriva a publicidade registraria.⁴²⁹

Para Galeno Lacerda e Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, cumpre ao juiz examinar com prudência e discríção o requisito do legítimo interesse, inclusive, com vistas à necessidade ou utilidade da publicidade por meio de editais, verificando sua eventual nocividade e ponderando os interesses contrapostos.⁴³⁰

Em análise sobre o teor do mencionado § 1.º, entendem também outros autores que a lei faculta o uso do edital, o que, no entanto, deve ser compreendido com ressalvas. A publicação do edital, em tais procedimentos, deve ser deferida apenas em duas hipóteses: a) quando for da essência do ato que se quer praticar que seja levado ao público, sem o que não se teria a sua validade ou a eficácia desejada; ou b) quando não for possível a intimação pessoal do requerido, seja por se encontrar em local incerto e não sabido ou por não terem sido efetivadas as tentativas de intimação pessoal.⁴³¹ O § 2.º estende o procedimento da notificação ao protesto judicial sem maiores minúcias. Como visto, a nova lei processual preocupou-se em regulamentar detidamente as notificações e interpelações, ao contrário do código revogado que tratava principalmente dos protestos.

2.1 As espécies de comunicação mantidas

2.1.1 Notificação

São numerosas as hipóteses de direito material em que a lei exige manifestação formal de vontade mediante uma das técnicas processuais aqui tratadas.

A notificação, como já observado, pode ser facultativa ou obrigatória para o exercício de determinado direito. É obrigatória quando a lei assim o exige para a produção de determinados efeitos jurídicos, e exemplo das seguintes situações:

São exemplos:

a) Locação, em que o locador, desejando “despedir” o locatário, deve notifica-lo com antecedência de 90 dias.⁴³²

b) Resolução de contrato de seguro em que o segurado é obrigado a comunicar ao segurador, de

incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto. ⁴³³

c) Exoneração do fiador que desejar afastar-se da condição de garantidor. ⁴³⁴

d) Obrigações dos sócios nas sociedades de suas obrigações para que responda pelo inadimplemento. ⁴³⁵

e) Resolução da sociedade e retirada do sócio da sociedade sem prazo determinado. ⁴³⁶

f) Alienação de Estabelecimento, para anuir com o pagamento dos credores. ⁴³⁷

Dos exemplos acima analisados, tem-se clara a definição legal da medida notificatória. Em todas essas situações, o direito do requerente à notificação é meramente potestativo (vontade receptícia), porquanto pode ser exercido pelo titular sem resistência ou mesmo oitiva do notificado, que, simplesmente, tomará ciência da vontade manifestada sem que dele se exija nenhuma ação ou omissão para que o direito material justificador da medida possa ser exercido. Não cabe ao juiz, também como na notificação, analisar a matéria de fundo contida na interpelação ou que a motiva. ⁴³⁸

2.1.2 Protesto

Para Nelson Nery Junior, o protesto possui conteúdo “completante” de determinado negócio cuja eficácia depende de trazer ao “conhecimento do interessado, em alto e bom som, a disposição de ver realizada a eficácia *ex lege* ou, excepcionalmente, *ex voluntate* própria do fenômeno jurídico de que se espera um resultado”. Por isso o protesto tem sua própria eficácia subordinada à intenção de quem o postula e à correspondência perfeita dos fatos que se alega terem ocorrido. ⁴³⁹

Argumentava Victor A. A. Bomfim Marins que protesto, em acepção jurídica, significa a declaração perante o agente público acerca de certo fato, cuja autenticidade se afirma, e se pretende assegurar, pelos meios previstos em direito. O protesto judicial, portanto, não confunde com o protesto cambial, pois destina-se, fundamentalmente, a prover a conservação e ressalva de direitos, manifestação de vontade ou de conhecimento dirigido ao juiz. “Não se trata de adquirir por meio do protesto direito novo, mas de manifestar a intenção no sentido do seu exercício”. ⁴⁴⁰

Assim, tem por finalidade afirmar a titularidade de um direito ou manifestar a intenção de exercê-lo. ⁴⁴¹ É o caso, por exemplo, do protesto judicial exigido pela lei civil material para a interrupção da prescrição (efeito interruptivo específico), o qual terá eficácia ainda que deferido por juízo incompetente.

Para a interrupção da prescrição, a lei prevê duas hipóteses (CC/2002, art. 202), interrupção esta que somente poderá ocorrer uma vez, seja “por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual” (inc. I); ou por protesto, nas condições do inc. I do art. 202, (inc. II).

Nesse caso, o interessado protesta objetivando resguardar direito material de que é titular para que este não seja fulminado pela fluência livre e desimpedida do prazo prescricional. A lei permite que o interessado proteste (afinal, o exercício do direito de fundo é uma faculdade), mas exige o protesto enquanto meio interruptivo da prescrição.

3. Aspectos processuais e procedimentais

Em linhas anteriores já se discorreu sobre parte dos aspectos processuais e procedimentais comuns às três espécies de medidas versadas nesta Seção II. No entanto, alguns pontos mais específicos merecem destaque nesse tópico.

3.1 Protestos contra alienação de bens

O parágrafo único do art. 870 do CPC/1973 previa que, quando se tratasse de *protesto contra a alienação de bens*, podia o juiz ouvir, em 3 (três) dias, aquele contra quem foi dirigido o ato, desde que lhe parecesse haver no pedido *ato emulativo, tentativa de extorsão, ou qualquer outro fim ilícito*, decidindo em seguida sobre o pedido de *publicação de editais*.

Essa regra não foi expressamente reproduzida no CPC/2015. No entanto, está implicitamente resguardada no inc. I do art. 728. Desse modo, se houver suspeita de que o requerente, *por meio da notificação (interpelação ou protesto) ou do edital*, pretende alcançar *fim ilícito*, o requerido será

previamente ouvido antes do deferimento da notificação ou do respectivo edital.

O protesto contra alienação de bens consistia em espécie particular e abusiva da medida, ante a “pressão psicológica” que exerce sobre seu destinatário. Ovídio Baptista da Silva, sobre o assunto, relata experiência profissional bastante ilustrativa por ele vivenciada, em que certo protesto dessa espécie foi deferido pelo juiz sem maiores cuidados. Na ocasião, o requerente, que se dizia titular de um crédito modesto, provocou a imobilidade no comércio de mais de 20 mil bolsas de cereal, de propriedade do protestado, uma vez que se propunha a anular toda e qualquer alienação que se fizesse de tal produção.
⁴⁴²

O protesto contra alienação de bens, assim como qualquer outro procedimento versado nesta Seção II, não poderá criar algum impedimento jurídico que torne bem inalienável. Todavia, a influência psíquica exercida pela intimação judicial é certamente inibidora dos eventuais negócios jurídicos de alienação, já que os prováveis adquirentes, por certo, não querem correr o risco de uma futura discussão judicial sobre a legitimidade da aquisição que tenham feito depois do protesto.
⁴⁴³

Na mesma obra, Ovídio Baptista da Silva cogitava o alargamento da interpretação do dispositivo revogado para os casos em que, com o protesto contra a alienação de bens, não necessariamente se pretendesse a intimação, bem assim para quando o interessado não declarasse o fim específico (contra alienação de bens) em sua petição, mas esta provocasse idêntico resultado quando acolhida. Para tanto, bem ponderou o autor: “quem tenha alguma experiência do mundo dos negócios saberá que, para muitos bens, o número de adquirentes às vezes é reduzidíssimo e, dificultada a alienação a dois ou três possíveis interessados, na prática a alienação se torna definitivamente impossível, por absoluta falta de outros adquirentes”. Defendia ainda que o conceito de alienação de bens deveria incluir as formas de transmissão de quaisquer espécies de direitos, seja por cessão, renúncia ou endosso, como acontece nos títulos de crédito que permitam a alienação por tal forma.
⁴⁴⁴

O uso abusivo do protesto, em situações em que desnecessária a comunicação, descabida ou indevida, pode caracterizar violação ao art. 80, inc. III, por “usar o processo para conseguir objetivo ilegal”, justificando a sua extinção e a apuração da má-fé processual, podendo o juiz aplicar as sanções do art. 81.
⁴⁴⁵

Visto isso, a partir de uma análise teleológica do texto da lei, é possível perceber que o CPC/1973 e também o CPC/2015 mais pretenderam advertir o juiz sobre o risco da medida, convidando-o a uma reflexão aprofundada e uma análise revestida de maior prudência, do que impedir todo e qualquer abuso do peticionante. A nova lei, sem dúvidas, há de obter melhores resultados nesse sentido, uma vez que ampliou as possibilidades do juiz ouvir o requerido sempre que vislumbrar a possibilidade de o requerente alcançar fim ilícito, sem restringir essa liberdade do juiz apenas à publicação de edital ou alienação patrimonial. A lei anterior, ao contrário, referia-se claramente à alienação de bens assim declarada na inicial nos casos em que o ato de comunicação se daria por meio editalício.

Tem-se assim acertada inovação legislativa, cujas possibilidades possuem amplitude difícil de delimitar. Somente com a prática forense é que os variados casos de incidência da norma poderão ser melhor enumerados.

3.2 Petição inicial

Conforme ensina Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, a petição inicial tem que expor os fatos e os fundamentos da medida que se pleiteia. O postulante tem o ônus de declinar a causa de pedir – “expondo pormenorizadamente a finalidade da comunicação de vontade e o contexto fático-jurídico subjacente”. O pedido é o de intimação de quem de direito, sendo vedado ao demandante requerer algo além disso. Do mesmo modo, é juridicamente impossível pedido de ordem em protesto ou notificação para que o demandado faça ou deixe de fazer alguma coisa, bem como pedido de declaração sobre qualquer direito ou pretensão do requerente; para este fim existe a interpelação (art. 727). Além da causa de pedir e do pedido, tem o demandante que observar os demais requisitos do art. 319 do CPC naquilo em que for compatível.
⁴⁴⁶

O CPC/2015, como não poderia deixar de fazer, estabeleceu os requisitos essenciais para a elaboração da petição inicial, inclusive, aquela por meio da qual o interessado pleiteia a notificação, interpelação ou protesto.

São requisitos gerais a serem observados em toda e qualquer demanda judicial, os quais estão

previstos no art. 319. Segundo o dispositivo em referência, a inicial indicará: I) o juízo a que é dirigida; II) os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III) o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV) o pedido com as suas especificações; V) o valor da causa; VI) as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII) a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Repita-se que a petição inicial do protesto, da notificação e da interpelação deve preencher os requisitos.

São necessárias algumas considerações acerca do inc. V. Justamente por tais atos não estarem ligados à efetiva existência de direito material que deve ser discutida em ação própria, não há como se atrelar o valor da causa desses procedimentos ao valor condizente com a situação jurídica material subjacente. Como já reconhecido pela jurisprudência, sua eleição se dá para efeitos meramente fiscais.⁴⁴⁷

Argumenta-se que, sendo a notificação judicial, de regra o valor da causa deve corresponder ao proveito pretendido. Todavia, no caso da notificação judicial é possível atribuir à causa valor de alçada, na medida em que inestimável, em termos econômicos, o proveito almejado com a demanda.⁴⁴⁸

De fato, as medidas aqui versadas não se adequam a nenhuma das situações previstas no art. 292 do CPC/2015. Assim, considerando a regra do art. 291 de que a toda causa será atribuído o valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, é de se considerar um valor mínimo, sobretudo, diante da singeleza do procedimento.

Tendo em vista que as três medidas em exame constituem procedimento de jurisdição voluntária e, como tais, não se inserem no conceito de processo e sua contenciosidade, não há dilação probatória. De igual modo, inexistindo contraditório ou lide, incabível audiência de conciliação ou mediação. Sendo assim, são incompatíveis as exigências dos incs. VI e VII, devendo, no entanto, acompanhar a inicial os documentos que atestam o preenchimento dos requisitos específicos.

A esse propósito já estão claros os requisitos específicos das notificações, protestos, como será esclarecido adiante, das interpelações. Trata-se da: 1) intenção de manifestar vontade lícita a outrem; 2) vontade sobre assunto juridicamente relevante; 3) o promovido deve ser sujeito integrante da relação jurídica de fundo.

O propósito notificatório, interpelativo ou protestativo deve ser expresso pelo requerente; o vínculo jurídico ou relação jurídica entre o promovente e o promovido também devem ser suficientes a justificar a intervenção judicial.

Sobre a qualificação do assunto, Teresa Arruda Alvim Wambier e outros autores sustentam que essa há de ser aferida em seu viés subjetivo. Portanto, a relevância objetivamente considerada não deve ser exigida.⁴⁴⁹ A lei faz alusão a “assunto juridicamente relevante”, assim, sustentado pela motivação declinada na inicial. O peticionante deve demonstrar que, para ele próprio e sem prejuízo de quem quer que seja, o tema possui relevo jurídico.

No caso de a comunicação ser direcionada ao público geral, a ser realizada por meio de edital, exige-se, ainda, que a pretensão deduzida na inicial seja *fundada e necessária ao resguardo de direito*. Incumbe ao interessado o ônus de provar tais requisitos. Na visão de Arruda Alvim, é esse “o único caso em que se poderá eventualmente haver a produção de provas, pois o requerente terá de demonstrar que a via eleita é necessária para garantir seu direito, já que uma manifestação aberta a todos, por edital, pode gerar prejuízo ao requerido”.⁴⁵⁰

3.3 Capacidade postulatória

Naturalmente, as notificações, interpelações e protestos exigem capacidade postulatória para serem formuladas perante a autoridade jurisdicional. Portanto, deve o interessado se fazer representar por advogado devidamente constituído nos autos. De igual modo, o requerido, nas hipóteses em que cabível manifestação prévia ou fora delas, mas sempre que pretender se manifestar no feito, deverá se pronunciar por meio de causídico com procuração para tanto.

Os procedimentos distintos das técnicas processuais em exame não se compatibilizam, por exemplo, com o procedimento dos juizados especiais, nos quais há a possibilidade de o interessado demandar sem procurador constituído. Nesse sentido é o seguinte julgado, que, inclusive, traz esclarecimento sobre

regras de competência aplicáveis a tais medidas, além de elucidar detalhe sobre a capacidade postulatória.⁴⁵¹

Humberto Theodoro Júnior, ao analisar as situações em que pedido de edital exige a oitiva do promovido, esclarece que quando isto ocorrer não é o caso de suspender o protesto. Esse será cumprido normalmente por mandado de intimação. Pelo mesmo mandado, “antes da deliberação sobre a publicação de editais para conhecimento de terceiros, o promovido será intimado a pronunciar-se nos autos, por meio de advogado”.⁴⁵²

Do mesmo modo, se pretende o promovido contraprotestar (o contraprotesto não constitui defesa, mas novo protesto ajuizado por aquele que sofrera anteriormente o protesto), deverá obedecer aos mesmos requisitos para que seja concedida a medida que almeja.⁴⁵³ Logo, precisará de patrono para deduzir em juízo sua pretensão.

3.4 Indeferimento

Se faltarem os requisitos gerais da petição inicial, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do procedimento ou as condições da ação após oportunizadas as chances de saneamento (arts. 317 e 321 do CPC/2015), bem como se ausentes a evidente necessidade de *manifestação de vontade a outrem*, a *relação jurídica entre ambos* e o *assunto juridicamente relevante*, é possível que o juiz deixe de fazer a notificação, o protesto ou a interpelação.

A regra é que preenchidos os requisitos legais, a medida pleiteada seja imediatamente deferida, à exceção dos casos em que o requerido deve ser previamente ouvido (art. 728). Nessas situações, antes do deferimento da medida, se oportuniza a oitiva do promovido, sem que isso configure contraditório propriamente dito (defesa) ou atribua caráter litigioso ao procedimento (lide).

O art. 869 do CPC/1973 dispunha que o juiz deveria indeferir o pedido quando o requerente não houvesse demonstrado legítimo interesse e o protesto, dando causa a dúvidas e incertezas, pudesse impedir a formação de contrato ou a realização de negócio lícito. Analisando esse dispositivo, Ovídio Baptista da Silva considerou que o juiz somente poderia indeferir o pedido de protesto, notificação ou interpelação quando duas condições estivessem presentes, são elas: a) falta de legítimo interesse; b) possibilidade de que o protesto gerasse dúvidas e incertezas capazes de impedir a formação de contrato ou a realização de negócio lícito.⁴⁵⁴

A regra não foi repetida no CPC/2015, mas, ainda assim, é possível sob a lei vigente, considerando, por exemplo, os amplos poderes do juiz contidos no art. 139. É que, como bem assevera Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, o interesse na notificação, interpelação ou protesto “configura-se em favor de quem, à vista do contexto fático-jurídico narrado, necessita da medida postulada, presente a adequação legal da finalidade apontada pelo demandante”. A demonstração de interesse está ligada diretamente à necessidade de impedir a prática de atos de comunicação de vontade indevidos, cujas realizações “possam acarretar prejuízo para o tráfego jurídico”, ou seja, para a livre circulação de bens mediante negócios lícitos.⁴⁵⁵ É o que se extrai do *caput* do art. 726, como já evidenciado. Ausente qualquer dos requisitos específicos (intenção do promovente de manifestar vontade lícita a outrem; vontade sobre assunto juridicamente relevante; ser o promovido sujeito integrante da relação jurídica de fundo) é de ser indeferida a medida. Tal entendimento privilegia o direito de petição e, ao mesmo tempo, impede que o jurisdicionado demande em juízo de maneira infundada. Afinal, apesar da simplicidade do procedimento, não deve o judiciário se prestar à análise de questões sem utilidade prática. De nada adianta movimentar a máquina jurisdicional se a pretensão deduzida em juízo é desprovida de qualquer proveito jurídico.

Em outros termos, imprestável o deferimento de notificação sobre assunto sem qualquer relevância jurídica ou em face de pessoa alheia à relação jurídica material que lhe justificou, por inexistência de interesse de agir. Mesmo porque, nos termos do art. 17 do CPC/2015, para se postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, ainda que nos procedimentos de jurisdição voluntária não haja atividade jurisdicional típica ou ação. Trata-se aqui, *com temperamento*, da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação definem-se da narrativa formulada inicial, não da análise de mérito da demanda. Não cabe ao juiz, também, analisar a matéria de fundo contida na notificação ou que a motiva.⁴⁵⁶

Ademais, já ficou claro em linhas anteriores que, no caso do § 1.º do mesmo artigo, o pedido de publicação do edital será igualmente indeferido quando não se demonstrar que a medida é fundada, e

necessária, ao resguardo do direito de fundo.

3.5 Intimação e contraditório

Como regra geral, o promovido não falará nos autos, pelo que será apenas intimado do protesto, notificação ou interpelação. Contudo, será ouvido nas hipóteses já observadas nesta Seção, quando então deverá se manifestar por escrito por intermédio de advogado.

Embora o art. 721 (Disposições Gerais) diga expressamente que os interessados serão citados nos procedimentos de jurisdição voluntária, o ato de chamamento daquele em face de quem se formula o pedido (art. 728) é verdadeira intimação, vez que ao promovido não é facultado o oferecimento de resposta propriamente dita (defesa técnica), mas simples petição em que esclarecerá ao juiz questões fático-jurídicas que a lei prejudicou relevantes – interesse em alcançar fim ilícito e pedido de averbação em registro público.

Para Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero o demandante tem de requerer na petição inicial a intimação de quem de direito, sendo aplicável o regime da citação. Isso porque a intimação tem que ser pessoal (por correio ou oficial de justiça), sendo igualmente possível a sua realização por editais. “Como os protestos, notificações e interpelações constituem simples instrumentos para comunicação formal de vontade, a realização da intimação os exaure (art. 729, CPC)”.

457

Galeno Lacerda e Carlos Alberto Alvaro de Oliveira explicavam que “citação, se houvesse, não poderia tornar a coisa litigiosa, por se tratar de medida voluntária, excludente, por definição, de litigiosidade”.

458

Apesar de não se estar diante de feito contencioso, o interessado poderá arguir em sua manifestação matéria típica de defesa, tal como a ausência de pressupostos processuais e demais requisitos da medida, além de suscitar eventual objetivo ilícito do requerente. Ovídio Baptista da Silva, ao tratar dessa questão ainda sob a égide do CPC/1973, acertadamente disse que a manifestação do requerido corresponde à verdadeira contestação, mas, tecnicamente, não tem essa função. A inserção desse “contraditório” nos procedimentos dessa espécie não chega sequer a negar o princípio que veda a contestação em feitos de jurisdição voluntária. Por isso a lei não confere ao promovido, por exemplo, a faculdade de produção de provas, nem se autoriza que o juiz permita a dilação probatória, quer de ofício, quer por requerimento de qualquer interessado. Na dúvida quanto à licitude do fim pretendido ou quanto à necessidade de averbação da medida em registro público, deve o juiz indeferi-la.

459

Teresa Arruda Alvim Wambier e Outros, no entanto, entende que, em ambos os casos do art. 728, o interessado será “citado” para apresentar manifestação. Não havendo necessidade de audiência, a medida será concedida e o requerido intimado posteriormente.

460

3.6 Abuso do processo e má-fé

Ovídio Baptista da Silva, em análise sobre o art. 869 do CPC/1973 ponderou que “um dos elementos indicativos de abuso do Direito Processual, capaz de permitir o indeferimento do protesto, é a existência de má-fé por parte do requerente, ou o visível sentido emulativo do pedido. Igualmente se o pedido de protesto, notificação ou interpelação tiver propósitos imorais ou ilícitos; ou se o ato ou negócio jurídico contra o qual se protesta for impossível de ser praticado (Moura, *Exegese*, 382) porque, então, faltaria ao requerente legítimo interesse”. Revogado o art. 869, subsiste no novo código a validade desse entendimento, a despeito de previsão normativa expressa.

461

Consoante o art. 79 do CPC/2015, responde por perdas e danos àquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. O art. 80, inc. III, por sua vez, considera litigante de má-fé aquele que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Embora se esteja diante de procedimentos de jurisdição voluntária (sem processo, litígio, autor, réu ou interveniente), é de se aplicar o mesmo dispositivo aos protestos, notificações e interpelações, na medida em que pretendeu o legislador, por certo, impedir que a máquina judiciária fosse indevidamente utilizada para fins ilícitos, contrários à finalidade de pacificação social. Mesmo porque é medida que se impõe para que condutas semelhantes sejam desestimuladas.

Portanto, se o interessado deduzir em juízo pretensão protestativa, notificatória ou interpelativa objetivando fim ilegal, inclusive, mascarando-o maliciosamente em sua petição na tentativa de enganar o juízo, deverá ser condenado ao pagamento de multa. Afinal, pode o juiz aplicar a penalidade pecuniária

mesmo de ofício, conforme autoriza o art. 81 do CPC/2015. Nesse caso a medida será certamente indeferida e o requerente, por certo, poderá interpor recurso de apelação contra seu indeferimento e contra a aplicação da multa.⁴⁶²

Aqui a questão é ainda mais delicada ante a típica ausência de contraditório. Ovídio Baptista da Silva sustenta que “o juiz deve ter extrema prudência no indeferimento do protesto [e também da notificação ou da interpelação] porque, inexistindo contraditório, o juiz tem de valer-se apenas de seu critério pessoal para a decisão, não lhe sendo lícito evidentemente assumir a posição do demandado para defender-lhe o interesse”.⁴⁶³ Por se tratar de matéria de ordem pública, flagrante o interesse coletivo na inibição da má-fé processual.

É claro, contudo, que a configuração do fim ilícito é por vezes difícil, ante a impossibilidade de dilação probatória. Na prática, como já sustentado, será mais prudente o indeferimento da medida de protesto, notificação ou interpelação em havendo dúvida sobre a licitude do fim almejado pelo promovente. Nem sempre a intenção de publicidade, mesmo por editais, caracteriza a má-fé.⁴⁶⁴

3.7 Editais e meios de comunicação

Assim, pelas razões já expostas em tópico antecedente, no qual se tratou da intimação e contraditório, pode, inclusive, o juiz valer-se do modo (procedimento) e hipóteses da citação por edital no caso das notificações, interpelações e protestos. Logo, poderá haver edital sempre que a pretensão for fundada e necessária, conforme considerar a autoridade “julgadora” e demonstrar o requerente.

O CPC/1973, no art. 870 previa a possibilidade de fazer-se a intimação na notificação por editais em três hipóteses: se o protesto fosse para conhecimento do público em geral, nos casos previstos em lei, ou quando a publicidade seja essencial para que o protesto, notificação ou interpelação atinja seus fins; se o citando fosse desconhecido, incerto ou estiver em lugar ignorado ou de difícil acesso; se a demora da intimação pessoal pudesse prejudicar os efeitos da interpelação ou do protesto. Não há mais disposição semelhante no CPC/2015, abrindo-se ao exame do juiz a necessidade de publicação de edital.

Ressalte-se, ademais, que se aplicam aqui as disposições do art. 256 do CPC/2015, segundo o qual a citação por edital será feita: I) quando desconhecido ou incerto o citando; II) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III) nos casos expressos em lei. São hipóteses que em tudo se compatibilizam com as regras dos art. 726 e seguintes.

Para Humberto Theodoro Júnior, “admite-se a intimação por edital, sob as cautelas comuns da citação dessa espécie”. “Há, como se vê, maior facilidade para uso dos editais em protestos, interpelações e notificações do que nas ações em geral, e isso se explica pelo caráter peculiar dessas medidas.”⁴⁶⁵ Galeno Lacerda e Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, a seu modo, posicionam-se no mesmo sentido, afirmando que no silêncio do código “resta a aplicação do regramento específico para as citações-editais (...) com as adaptações necessárias, ou, então, como alternativa, a proposição de Ovídio Baptista da Silva no sentido de que caberia ao juiz exercer discricão, provendo sobre o meio de publicidade recomendado ao caso e respectivos prazos”.⁴⁶⁶

O § 1.º do art. 726, é claro, manteve a possibilidade de publicação de edital para dar conhecimento geral ao público. No entanto, não restringiu a possibilidade de intimação edital apenas para esse caso, mas quis garantir maior rigor à análise de seu deferimento. Também o quis o art. 728 quando tornou necessária a ouvida prévia do promovido antes da comunicação edital.

De qualquer forma, cabe ao juiz a análise acerca da necessidade e abrangência do ato de comunicação (meios de comunicação). Assim, a depender do caso, poderá perfeitamente limitar a amplitude do edital, conforme estiver fundada a necessidade de publicação, deferindo parcialmente a medida, negando, por exemplo, permissão para que seja divulgada pela imprensa, sem indeferi-lo totalmente.⁴⁶⁷

Art. 727. Também poderá o interessado interpor o requerido, no caso do art. 726, para que faça ou deixe de fazer o que o requerente entenda ser de seu direito.

1. Inovações do CPC/2015

Inova o CPC/2015 por destinar lugar específico para a interpelação. É assim conceituada no art. 727 como medida segundo a qual poderá o interessado interpor o requerido, no caso do art. 726, *para que faça ou deixe de fazer o que o requerente entenda ser de seu direito*. Essa definição legal é também

inovação do novo código, não existindo dispositivo correspondente na lei revogada.

2. Aspectos materiais das interpelações para fazer ou deixar de fazer

As interpelações diferem dos protestos e notificações pois por seu intermédio pretende o promovente comportamento omissivo ou comissivo do promovido e não simples comunicação de vontade, afirmação de titularidade de direito ou intenção de exercê-lo. Logo, a eficácia da interpelação depende, ao final, do comportamento que será adotado pelo interpelado, ao contrário do que ocorre nas demais medidas, as quais produzem efeitos instantâneos exaurindo-se de imediato.

Trata-se de espécie de comunicação formal de vontade mantida pela nova lei, mas cuja finalidade assumiu feição mais evidente. Nelson Nery Junior a define como “ato pelo qual se dá a conhecer a pretensão de exercer direito. Exterioriza-se vontade nesse sentido e a eficácia da interpelação dependerá do ato ou da omissão do interpelado [...]”. ⁴⁶⁸

Sobre a disciplina no CPC/2015 afirma-se que a disposição legal expressamente permite a utilização da interpelação relativamente à obrigação de fazer ou não fazer, “contrariando a retrógrada e errônea jurisprudência”. Desse modo, uma vez assumida certa obrigação positiva por contrato sem previsão de prazo para cumprimento, é plenamente possível interpelação para constituir em mora o contratante devedor para que cumpra sua obrigação. O permissivo legal conflui com a moderna compreensão do direito processual civil, que não pode ter sua técnica limitada à prestação de tutela pelo equivalente em direito, mas deve preocupar-se em fornecer meios adequados para a tutela específica. ⁴⁶⁹ A utilização de protestos e interpelações, assim como o é no cumprimento de obrigações de pagar quantia, pode ser medida valorosa para conseguir um rápido cumprimento das obrigações de fazer, positivas ou negativas”. ⁴⁷⁰

Visto isso, importa ressaltar que a necessidade e utilidade da interpelação decorre de imposição legal ou de ato de vontade. São também diversificadas as hipóteses materiais em que a lei indica a necessidade de interpelação, sendo obrigatória quando a lei assim o exige para a produção de determinados efeitos jurídicos em parte delas oferecida ou como uma alternativa à interpelação extrajudicial, a exemplo das seguintes situações:

a) Mora do devedor inadimplente, nos casos em que não há termo no contrato com previsão de prazo para o cumprimento. ⁴⁷¹

b) Cláusula resolutiva tácita, que depende de interpelação para a extinção do contrato. ⁴⁷²

c) Execução de cláusula na venda com reserva de domínio. ⁴⁷³

Estas hipóteses do Código Civil não excluem outras tantas da legislação esparsa, que indicam a mesma finalidade.

Ademais, podem as partes contratantes, no uso de sua liberdade volitiva contratual, firmar cláusula que exija a interpelação para fim específico. Logo, sendo o instrumento pactuado, fazendo lei entre as partes (*pacta sunt servanda*), é possível a interpelação inclusive judicial, atendendo perfeitamente ao requisito do assunto relevante.

3. Aspectos processuais e procedimentais

No tocante aos aspectos processuais e procedimentais relativos à medida em exame, são dispensáveis maiores considerações. Isso porque, como amplamente esclarecido, aplica-se às interpelações o mesmo procedimento inerente à notificação e ao protesto, o que se denota da alocação “no caso do art. 726”. Quis o legislador que fossem observados aqui os mesmos requisitos, forma e trâmite aplicáveis à pretensão notificatória e protestativa.

Em tudo deve observar, portanto, o que já dito sobre competência, interesse em interpelar, requisitos da petição inicial, possibilidade de indeferimento total ou parcial do pedido e disciplina de publicação e tramitação do edital. Não há razão para se repetir o que já elucidado a esse respeito porquanto ausentes peculiaridades nas interpelações que justifiquem maiores minúcias.

Feita a intimação, terá o promovido ciência da ação ou omissão que dele espera o promovente. Assim termina o procedimento.

Não se aguarda a prática do comportamento omissivo ou comissivo almejado, isso é questão alheia aos autos e escapa à apreciação do juízo. Nem se pode pedir que o juiz obrigue o requerido a agir como pretende o requerente, quer porque tal pleito seria juridicamente impossível, quer porque a decisão proferida nestes termos extrapolaria os limites do pedido.

Art. 728 . O requerido será previamente ouvido antes do deferimento da notificação ou do respectivo edital:

I – se houver suspeita de que o requerente, por meio da notificação ou do edital, pretende alcançar fim ilícito;

II – se tiver sido requerida a averbação da notificação em registro público.

1. Inovações do CPC/2015

Inova o CPC/2015 ao abrir à possibilidade nos casos listados nos incs. I e II do art. 728, de oitiva do requerido quando houver suspeita de que se pretende alcançar fim ilícito ou for requerida a averbação da notificação em registro público. Não havia tal previsão na providência cautelar equivalente que vinha prevista no CPC/1973, mas o art. 870 da norma revogada já apontava o receio do legislador acerca do risco de ilicitude da medida vindicada.

2. Aspectos materiais

Já foi evidenciado que o promovido, regra geral, não será ouvido antes do deferimento da medida. O dispositivo em análise, no entanto, estabelece duas hipóteses legais que excedem a essa regra, presente o risco de a notificação, o protesto ou a interpelação, inclusive em caso de publicação de edital, gerarem prejuízo ao requerido.

A primeira delas refere-se ao fim ilícito pretendido pelo requerente. Já foi dito que o código anterior preocupou-se em coibir a finalidade ilícita do pedido do promovente, mas o fez somente nos casos de publicação de edital e em si tratando de alienação de bens, requisitos então cumulativos para que se determinasse a oitiva prévia do interessado. A nova lei é, portanto, significativa e acertadamente mais ampla, na medida em que estabelece a necessidade de manifestação do interessado sempre que existir a suspeita ou o risco aparente de ilegalidade do fim almejado pelo proponente.

Diz Teresa Arruda Alvim Wambier e Outros que “a lei alude expressamente à suspeita que pode se instalar no espírito do juiz, de que, por meio da notificação ou do edital, o requerente possa querer atingir fim ilícito, e, portanto, prejuízo ao requerido. Não há motivo para excluir-se desta regra a interpelação e o protesto”.⁴⁷⁴

Para parte da doutrina “isso deve se dar quando a manifestação de vontade aparentar não corresponder à vontade em si ou aos fatos (*Non valet protestatio facto contraria*), bem como quando se perceber o propósito emulativo ou extorsivo – ou seja, a utilização do Judiciário com o fito de dar uma aparência oficial ou condenatória ao ato, o que certamente pode vir a impressionar ou constranger algumas pessoas. Enfim, quando o juiz suspeitar de alguma irregularidade, deve intimar a parte contrária para que se manifeste, bem como o próprio requerente”.⁴⁷⁵

A segunda, por sua vez, trata do requerimento de averbação da medida em registro público. Nesse caso não se exige qualquer suspeita de ilicitude da finalidade da medida. A previsão legal decorre apenas dos riscos inerentes à averbação deferida de maneira irresponsável e sem as cautelas que o caso exige.

Segundo as interpretações iniciais, a exigência de oitiva prévia nos casos de pedido de averbação se faz “diante dos particulares efeitos decorrentes do registro, como forma de evitar possíveis fraudes”.⁴⁷⁶

3. Aspectos processuais e procedimentais

Da redação do *caput* do artigo é de se considerar que não se trata de uma faculdade a intimação do promovido para manifestação prévia, mas de um direito do interessado. Diz a lei que o requerido “será” previamente ouvido, não que “poderá” o ser.

Nesse sentido é o entendimento de Nelson Nery Jr: “o CPC 728 *obriga* o juiz a tanto, o que se nota pelo uso da forma verbal *será* (...)”.⁴⁷⁷ Na mesma linha afirmam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero que, no caso do art. 728, é obrigatória a prévia oitiva do requerido antes de

realizada a providência buscada, sendo nula a notificação procedida sem a observância desse preceito.⁴⁷⁸

Sendo assim, verificada qualquer das situações previstas nos dois incisos, haverá necessariamente a intimação (e não citação) do promovido para que apresente sua manifestação por escrito. Após, poderá o juiz apreciar o pedido de protesto, notificação ou interpelação.

Por certo, não será o requerente intimado para falar em “réplica”, servindo a petição do promovido apenas para trazer ao conhecimento do juiz elementos mais substanciais que lhe permitam deliberar com maior certeza sobre o deferimento ou indeferimento da medida. Afinal, se originalmente não há contraditório e, por isso, o tem de se valer apenas de “seu critério pessoal” para decidir, também deverá lançar mão do mesmo critério quando da incidência do art. 728, com o bônus de que, nesses casos, terá em mãos algum elemento a mais trazido aos autos pelo promovido.

Nas duas situações previstas nesse artigo deve-se respeitar o “contraditório” prévio, sendo possível, inclusive, que o procedimento se converta em jurisdição contenciosa.⁴⁷⁹

Quanto ao prazo de manifestação, nada disse o código a respeito. Todavia, entende-se que, não havendo prazo específico para tanto, aplica-se a regra geral de 15 dias, em conformidade com o art. 721 do CPC/2015.⁴⁸⁰

3.1 Contraditório e seus efeitos

Mesmo que em linhas anteriores já se tenha discorrido detalhadamente sobre o contraditório nos protestos, notificações e interpelações, inclusive no tocante ao art. 728, é de se proceder agora a uma análise mais detida à luz dos arts. 9.º e 10 do CPC/2015. Assim preceitua o art. 9.º: “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida;” excluem-se a tutela provisória de urgência (inc. I) às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, II e III (inc. II) e a decisão prevista no art. 701 (inc. III). E o art. 10 assegura que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

As medidas em estudo, como se observa, não estão inseridas nas ressalvas do parágrafo único do dispositivo legal acima transcrito, levando a crer que a regra das interpelações, notificações e protesto e a não oitiva do promovido devem seguir o *caput* dos arts. 9.º e 10. A resposta a esse questionamento reside na natureza do procedimento jurisdição voluntária e a amplitude dada ao contraditório no CPC/2015.

A regra do art. 9.º se aplica, logicamente, aos processos de jurisdição contenciosa em que o contraditório é claramente necessário em virtude do conflito de interesses existente. Assim, impõe-se ao juiz, em observância do devido processo legal, o respeito ao direito de defesa do réu oportunizando-lhe o oferecimento de resposta, tudo com vistas ao convencimento motivado da autoridade julgadora. Há partes, processo, litígio (pretensão resistida – conflito de interesses) e mérito diretamente atrelado ao bem da vida pretendido.

Nada disso há nas técnicas processuais de que tratam os arts. 726-729. Logo, não se submetem à disciplina daquele artigo.

3.1.1 Contraditório antecipado e condicionado

A oitiva prévia do promovido constitui, desse modo, contraditório antecipado e também limitado. Antecipado porque precede, em fuga à regra geral, a apreciação do pleito protestativo, interpelativo ou notificatório; limitado porque, como visto, não admite ampla defesa, razão pela qual sequer é permitida a dilação probatória. É da natureza do procedimento não comportar defesa já que não se está diante de hipótese de acerto de relação jurídica.

Há quem diga que sequer constitui contraditório a manifestação do requerido. Assim entende-se, citando Ovídio Baptista da Silva, que nas hipóteses excepcionais em que o demandado é ouvido “não corresponde ao contraditório – não há defesa ou contestação. Isso porque importa para o juiz a prestação de informações para que pondere acerca da existência dos requisitos para o ato requerido ou quanto à existência de propósito ilícito de sua parte”.⁴⁸¹

O demandado poderá se manifestar, portanto, alegando matéria típica de defesa processual, mas o

que realmente se espera é que traga aos autos as informações necessárias à identificação e prevenção dos possíveis danos que possam ocorrer em virtude da averbação da medida no registro público ou do fim ilícito pretendido pelo promovente. Por meio de sua manifestação o requerido pode resguardar os próprios direitos, evitando que o deferimento da notificação, interpelação ou protesto “tenha qualquer consequência jurídica que lhe seja desvantajosa (p. ex., que se presuma determinado comportamento ou fato a ele imputável)”. ⁴⁸²

De qualquer maneira, o exercício desse “limitado contraditório” é, assim, condicionado, porquanto somente será admitido nestes limites e apenas quando verificadas as situações previstas no art. 728, I e II, do CPC/2015.

3.1.2 Ampliação do contraditório na ação posterior e negativa de novo contraditório

Por tudo o que já foi dito, está claro que o contraditório nas técnicas processuais aqui tratadas é extremamente tímido e restrito. Somente poderá e deverá ser ampliado, adquirindo maior envergadura, em ação posterior onde poderá ser utilizada a prova formal da manifestação de vontade, ou seja, o protesto, a interpelação ou a notificação.

Para melhor se entender tal afirmação, tome-se como exemplo um devedor que constituído em mora por interpelação, quando o contrato não previu prazo para cumprimento da obrigação, resiste ao adimplemento por qualquer razão que seja. Nesse caso, é possível e muito provável que o conflito de interesses então surgido seja levado ao conhecimento do juízo competente em feito evidentemente litigioso, no qual se utilizará a interpelação antes realizada e se discutirá no mérito não apenas a medida interpelativa, mas o direito material sobre o qual ela se fundou.

Na ação contenciosa sim será ampliado o contraditório antes limitado no procedimento voluntário. Poderão as partes postular, contestar, reconvir, produzir provas e, de um modo geral, falar nos autos na tentativa de convencer o juiz quanto ao direito que invocam.

Contudo, se houve esgotamento do contraditório durante o procedimento especial *conservativo de direito* não haverá razão para nova contradição ampla e total, especialmente se se considerar a jurisdição voluntária e os procedimentos contidos nos arts. 726-728 como exercício da atividade jurisdicional.

3.1.3 Contraprotesto

O contraprotesto era antes expressamente referido em lei e deveria se dar não nos próprios autos, mas em autos distintos. Assim dizia o art. 871 do CPC/1973: “O protesto ou interpelação não admite defesa nem contraprotesto nos autos; mas o requerido pode contraprotestar em processo distinto”. Constituía na verdade novo protesto, que se submetia ao mesmo procedimento do protesto anterior.

Sobre a redação imprecisa da lei revogada, diziam Galeno Lacerda e Carlos Alberto Alvaro de Oliveira que o CPC/1973 vedava o contraprotesto nos mesmos autos, mas se admitia outro protesto. Tratava-se, portanto, de protesto do requerido contra o requerente, não de contraprotesto propriamente. Ressaltou, todavia, que nos mesmos autos poderia o requerido “impugnar” o pedido por ausência de requisitos ou atacar a relação processual por falta de pressupostos, vez que são matérias que podem ser apreciadas de ofício pelo juiz (matéria de ordem pública). ⁴⁸³

O CPC/2015 não o previu, mas este é plenamente admissível. A mesma sistemática anterior se aplica na vigência da nova lei. Sobre a questão argumenta Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero que o contraprotesto deve se dar em outro processo, pois é novo protesto que veicula manifestação contrária ao primeiro. E acrescenta: “Não há prazo para seu exercício, sujeitando-se às regras gerais do protesto”. ⁴⁸⁴

Desse modo, pode o “contraprotesto” ser manejado enquanto for útil e necessário para fazer frente ao protesto contra o qual se insurge.

3.1.4 Averbação da notificação em registro público

Sobre a possibilidade de averbação da medida em registro público, pontua Teresa Arruda Alvim Wambier e Outros que o inc. II do art. 728 do CPC/2015 resolve matéria antes controvertida. ⁴⁸⁵ Mais debatido ainda na doutrina e na jurisprudência era o cabimento de averbação em registro de imóveis.

Analisando o CPC/2015, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ressaltam que a jurisprudência oscila em admitir o registro da notificação, interpelação ou protesto no Registro de imóveis. Afirma que, segundo precedentes da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, a averbação do protesto em registro imobiliário viola os arts. 869 e 870 do CPC/1973.⁴⁸⁶

É que não se concebia a necessidade de a medida ter tamanha publicação, bem como se buscava desestimular as tentativas do requerente de impedir a formação de contrato ou a realização de negócio lícito. Logo, firmavam-se os defensores dessa tese no argumento de que inexistia lei que autorizasse a averbação do protesto, nem se admitia interpretação extensiva da Lei 6.015/1973 (registros públicos) para ampliar as hipóteses de registro da medida.

Em sentido contrário, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero citam voto divergente proferido no julgamento dos embargos de divergência opostos em sede de recurso especial.⁴⁸⁷ Trata-se do posicionamento adotado naqueles autos pelo Ministro Barros Monteiro, do qual se extrai o quanto segue do qual se pode extrair boas razões,⁴⁸⁸ embora fundamentadas em um *poder geral de cautela* que pode ser confundido, vez que a medida, de muito se sabe, não tem natureza cautelar.

Simpatizantes desse posicionamento, Galeno Lacerda e Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, ainda no início da década de 1990, observavam ser mais numerosa a corrente que inadmitia averbação da medida em registro imobiliário, na medida em que os comentadores da Lei de Registros Públicos geralmente preconizavam interpretação estrita de seus dispositivos. Ainda assim, o autor firmou-se pela admissibilidade da averbação, conforme as circunstâncias, com amparo no poder geral de cautela do magistrado. Logo, nada impede que, como cautela específica, o juiz determine a averbação que se por um lado não é expressa na Lei de Registros Públicos, por outro não era proibida.⁴⁸⁹

Apesar das divergências até então existentes, fato é que o CPC/2015 não deixa dúvidas acerca do cabimento do pedido de averbação da medida, desde que haja prévia oitiva do requerido.

Art. 729. Deferida e realizada a notificação ou interpelação, os autos serão entregues ao requerente.

1. Inovações do CPC/2015

A redação dada ao art. 729 simplificou o procedimento de entrega dos autos ao interessado requerente. O CPC/1973, em seu art. 872, previa que somente após decorridas 48 horas da intimação do requerido acerca do protesto, interpelação ou notificação é que poderiam os autos ser entregues ao postulante.

2. Aspectos materiais

A finalidade é exclusivamente probatória, só servindo os autos ao interessado na interpelação ou notificação, razão pela qual há entrega dos autos, com os documentos e atos que comprovam a realização da medida. Isso não se dá apenas em decorrência da natureza não contenciosa do procedimento, mesmo porque há outros feitos de jurisdição voluntária em que os autos, findo o seu trâmite, são arquivados em juízo. Decorre da natureza peculiar dessas medidas, porquanto destinados à constituição de prova da comunicação formal de vontade. Por serem meros atos de comunicação, se exaurem com a sua realização, sem formar um possível título ou algo que o valha;⁴⁹⁰ sem eficácia declaratória ou condenatória.⁴⁹¹

A formação dos autos se dá justamente para que documentos sejam produzidos em favor de quem requer a medida, para que sirvam de prova hábil a ser utilizada em momento oportuno pelo interessado.

Poderia, é claro, a comunicação ser provada por simples certidão ou cópia da intimação respectiva. Contudo, como não há interesse na permanência dos autos em cartório, optou o legislador por garantir sua entrega ao requerente, tal como previu para os procedimentos de produção antecipada de provas (art. 383, parágrafo único) e de ratificação dos protestos marítimos e dos processos testemunháveis formados a bordo (art. 770, parágrafo único).

3. Aspectos processuais e procedimentais

Apesar de redigido em poucas linhas, o art. 729 suscita questões relevantes e relativamente complexas que precisam ser esclarecidas. Ademais, traz consigo uma sequência de atos que, na prática, podem gerar sérias dúvidas.

Veja-se, adiante, algumas observações relevantes sobre aspectos processuais e procedimentais do encerramento de feitos interpelativos, notificatórios e protestativos.

3.1 Custas processuais: incidência, rateio e pagamento

Quanto ao pagamento de custas, mesmo sem disciplina expressa do novo artigo – como havia no dispositivo correspondente da lei revogada – essas são devidas e precisam ser pagar antes da entrega final dos autos. Contudo, compreendem tão somente as despesas dos atos processuais, não abrangendo honorários advocatícios.

Esse entendimento decorre da premissa de que sem litígio não há parte vencida. Logo, inexistindo sucumbência são incabíveis honorários sucumbenciais.⁴⁹²

Por essa razão prevê o art. 88 do CPC/2015, repetindo o regramento antes estabelecido no art. 24 do CPC/1973, que nos procedimentos de jurisdição voluntária as despesas serão adiantadas pelo requerente e rateadas entre os interessados.

Excluído o caso dos juizados especiais em que só haverá pagamento de custas se houver interposição de recurso (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/1995), bem assim as hipóteses específicas de isenção previstas no CPC/2015, somente a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei (art. 98 do CPC/2015).

Todas as vezes que o legislador quis admitir que as custas não fossem pagas antecipadamente, o fez de modo expresso na lei, a exemplo dos arts. 295 e 1042, § 2º, ambos do CPC/2015. Por isso, inexistindo ressalva no caso do art. 729 e diante do que preceitua o já referido art. 88, devem as despesas com o procedimento ser adiantadas pelo requerente, o que se dá também por força do § 1.º do art. 82, pelo que a entrega final dos autos de que trata o dispositivo em análise somente será realizada após seu adimplemento.

3.2 Entrega efetiva dos autos

Deferida a notificação, a interpelação ou o protesto, realizada a intimação do requerido e pagas as custas processuais, os autos serão imediatamente entregues ao requerente (art. 729).

Caso futuramente o promovido ou outro interessado pretendam ter acesso à documentação que compunha os autos, poderão perfeitamente intentar ação de exibição de documento (art. 396 e ss. do CPC/2015). A esse respeito Lucas Buril de Macêdo considera que a ação exhibitória poderá ser intentada para tal finalidade de forma autônoma ou incidental.⁴⁹³

O CPC/2015 não reproduziu o prazo de 48 horas previsto no código anterior para que os autos fossem entregues ao interessado. Tratava-se de interstício usualmente destinado a outros requerimentos, tais como emissão de certidões e traslados, como bem pontuam Ovídio Baptista da Silva e Galeno Lacerda.⁴⁹⁴

Apesar da ausência de prazo no novo artigo, nada impede, por óbvio, que entre a intimação do requerido sobre o deferimento da medida ou a ordem de entrega dos autos e sua efetiva tradição ao requerente sejam feitos requerimentos simples (pedido de expedição de certidões e extração de cópias dos autos), os quais serão apreciados antes da retirada definitiva dos autos de cartório judicial.

3.2.1 Sentença, recursos e impugnação autônoma

O ato de entrega se dá após despacho nos autos, que determina a intimação do interessado para que compareça ao fórum e os retire em secretaria. Não o fazendo, resta à secretaria remeter o documento ao arquivo.

Quanto à natureza do ato do juiz que ordena a entrega dos autos ao promovente, sustenta Lucas Buril Macêdo que “sendo certificado que o requerido tomou ciência do ato, cumpre ao juiz proferir despacho que extingue o procedimento e determina a entrega dos autos ao requerente”. Já Ovídio Baptista da Silva, ao que se denota, atribui natureza de sentença à decisão que manda que se entreguem os autos ao requerente.⁴⁹⁵

Sendo eletrônicos os autos, não há entrega propriamente dita ao requerente. O interessado permanecerá tendo acesso à documentação no sistema processual do Judiciário. Como todos os atos

processuais são assinados digitalmente, é simples a verificação da autenticidade de documentos impressos, bastando para tanto a conferência da assinatura digital. Logo, sua disponibilidade permanente para consulta e uso do interessado no sistema informatizado do juízo é suficiente para garantia de acesso à prova que consubstancia.

Tal sentença é sujeita a recurso de apelação (art. 724) e dele não se admite, em regra, ação impugnativa autônoma, anulatória e rescisória.⁴⁹⁶

3.3 Reconstituição física

Questão interessante é a reconstituição física no caso das técnicas processuais em estudo. Afinal, os autos são definitivamente entregues ao requerente e, portanto, retirados da esfera de guarda e vigilância do Judiciário sem qualquer expectativa de retorno.

O art. 712 e ss. do CPC/2015 regulamentam o procedimento de restauração de autos e nenhum deles prevê ressalva ou disciplina específica para as notificações, interpelações e protestos. Não há óbice para que tais procedimentos de jurisdição voluntária possam ser restaurados se desaparecidos.

Sendo assim, embora os autos venham a desaparecer após a tradição ao requerente, tem-se por admissível sua restauração em juízo. Mesmo porque é possível que nova notificação, interpelação ou protesto sejam inviáveis/imprestáveis para a conservação do direito tutelado, pelo que o promovente teria interesse em recuperar o feito pretérito em que já havia promovido a comunicação de sua vontade.

3.4 Outras questões

a) Atos de comunicação contra a Administração Pública e seus entes

Não se pode excluir da possibilidade de utilização desse meio de comunicação processual os entes da Administração Pública, de qualquer ente da Federação, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sejam eles próprios, entes da administração direta, ou os entes da administração indireta: autarquias, fundações públicas, empresas e mesmo as sociedades empresariais com participação pública. Em qualquer dos polos, seja como requerente da medida, seja como requerido, observado apenas que a União e seus entes – excepcionadas as sociedades de economia mista, como o Banco do Brasil – têm para si a Justiça Federal, devendo tais procedimentos tramitarem nela, em observância da competência de jurisdição.

b) Uso das notificações para processo arbitral

Nos termos do § 2º do art. 21 da Lei 9.307/1996, os procedimentos de arbitragem sempre respeitarão o princípio do contraditório. Por isso, deve-se pretender que o requerido seja cientificado pessoalmente acerca da instauração do feito arbitral, sob pena de se pôr em risco a validade da sentença eventualmente proferida, a qual poderá ser declarada nula com fundamento no art. 32, inc. VIII, do mesmo ato normativo.

A inobservância do princípio do contraditório e outros vícios de comunicação são também causa para a recusa de homologação de decisão estrangeira. Diz o art. 38, inciso III, da Lei de Arbitragem que será negado reconhecimento e execução à sentença arbitral proferida no exterior quando o réu demonstrar que não foi notificado da designação do árbitro ou do procedimento de arbitragem, ou tenha sido violado o princípio do contraditório, impossibilitando a ampla defesa.

Entretanto, sabe-se que o juízo arbitral não possui estrutura semelhante à do Poder Judiciário, com a envergadura, a jurisdição e acessibilidade. Também não está amparado por vasto número de auxiliares da Justiça distribuídos por todo o território nacional, incumbidos exclusivamente do cumprimento de mandados e detentores de valiosas prerrogativas para o cumprimento de seus deveres funcionais, tais como fé pública e possibilidade de auxílio policial.

Por isso, a cientificação pessoal do requerido, com a certeza e segurança jurídica que legitimamente se esperam, nem sempre é tarefa fácil para o árbitro. Diante disso, a notificação se mostra meio eficaz para garantia de comunicação formal e solene ao interessado acerca da instauração de procedimento em seu desfavor. A medida constitui assim prova inequívoca de que o demandado tomou ciência de que contra si foi formulada demanda e a ela pode responder.

Além disso, referida Lei prevê expressamente em seus arts. 29 e 30 que às partes será dado a conhecer

o teor da sentença arbitral por “notificação ou ciência pessoal”, enviando-se cópia do ato decisório aos interessados por via postal ou outro meio de comunicação, mediante comprovação de recebimento, ou ainda entregando-lhes diretamente. Também aqui o uso da notificação adquire a mesma relevância.

Note-se, por fim, que a Lei de Arbitragem impõe ao interessado o dever de notificar o árbitro na hipótese do art. 12, inciso III, como condição para a extinção do compromisso arbitral. Constitui assim situação em que a medida é obrigatória para se atingir o fim pretendido pela norma.

c) Publicidade ou sigilo nos atos de comunicação

As técnicas processuais em estudo submetem-se às regras gerais de publicidade dos autos jurisdicionais, porquanto também se há de permitir o controle da lisura dos atos do procedimento por parte dos jurisdicionados. Nessa linha sustenta Ovídio Baptista da Silva que apesar das peculiaridades que envolvem essas medidas existe sim função julgadora, o que não existe é julgamento final.⁴⁹⁷ Logo, tratando-se de atividade típica do Poder Judiciário não se pode negar publicidade ao feito, senão nas restritas hipóteses previstas em lei (segredo de justiça).

Analisando o tema, argumenta-se que a exigência de publicidade dos atos processuais contém uma preocupação em se “admoestar à coletividade a respeito da necessidade de respeito à lei, a quem se garante a possibilidade de fiscalização em relação à distribuição de justiça. O respeito à publicidade dos atos processuais serve, ainda, como medida capaz de assegurar ao juiz condições para que possa restar livre de maledicências ou suspeitas em relação ao seu agir”. Por outro lado, o preceito traz consigo “função educativa associada à imposição de publicidade dos atos processuais, permitindo ‘a divulgação de ideias, incentivo ao interesse pela justiça e à elevação da confiança das pessoas no Poder Judiciário’”.

⁴⁹⁸

Contudo, não é só de publicidade geral dos autos e dos atos processuais que se trata esse tópico, mas, sobretudo, da publicidade que deve (necessidade e utilidade) ser dada ao ato interpelativo, notificatório ou protestativo especificamente. Aqui se pondera, por exemplo, o direito do requerente de que seja sua vontade levada ao conhecimento público e, por outro lado, o interesse público e de terceiros decorrente dos efeitos negativos do ato de comunicação, já bem elucidados neste trabalho.

Naquele mesmo estudo, observou-se haver peculiaridades no regime jurídico aplicável em sede de protesto judicial (o que também se aplica às notificações e interpelações). Destacou que na conformidade do art. 870, inciso I, do CPC/1973 a intimação por editais se daria nos casos em que o protesto fosse para conhecimento do público em geral, bem como nos casos previstos em lei e ainda naquelas situações em que a publicidade fosse reputada essencial para que o protesto, notificação ou interpelação atingissem seus fins. Desse modo, “atingido o escopo associado à divulgação no contexto do protesto contra alienação de bens, é possível até mesmo que a publicidade em questão possa ser limitada, de modo a assegurar que outros objetivos tutelados pelo mesmo ordenamento jurídico sejam igualmente assegurados”.⁴⁹⁹

Já se viu que, no CPC/2015, o § 1º do art. 726 preceitua que se a pretensão for a de dar conhecimento geral ao público, mediante edital, o juiz só a deferirá se a tiver por fundada e necessária ao resguardo de direito. O art. 728, por sua vez, demonstra preocupação com os riscos inerentes à publicação de edital quando o promovente intenta obter fim ilícito, bem assim quando o interessado pretende publicidade mediante averbação da medida em registro público.

Nesse caso observou-se, na linha do que sustenta Ovídio Baptista da Silva, que ao juiz é permitido indeferir parcialmente o protesto, a notificação ou a interpelação impedindo que a medida seja divulgada pela imprensa ou averbado em registro público, sem contudo indeferi-lo totalmente. Poderá assim restringir-se à intimação pessoal do requerido e de algum terceiro sem o alarde próprio das intimações-edital ou da que deriva a publicidade registraria.⁵⁰⁰

Aqui se contrapõe o interesse legítimo do requerente à publicidade que almeja e o interesse público que reside, por exemplo, no atingimento dos objetivos do Direito, da Justiça e da prestação jurisdicional: a pacificação social. A medida vindicada não pode ser causa de inquietude para a sociedade, motivo pelo qual a publicização do protesto, notificação e interpelação deve ser apenas aquela julgada suficiente para o atingimento do fim legítimo que dela se espera.

Portanto, “é na dimensão de um interesse convergente comum a todos, que a todos e a cada um pertence, que se situa a razão que justifica seja afastada a exigência de publicidade dos atos processuais”.

Tem-se assim que “a construção de exceções à exigência de publicidade dos atos processuais pautada sob o argumento da presença de interesse público leva a um paradoxo curioso”, porquanto “a Constituição Federal, no art. 93, IX, afirma que é exatamente a presença de interesse público a razão fundante do estabelecimento da regra geral que se pretende excepcionar”.⁵⁰¹

Diante dessa delicada situação invoca-se as válidas lições de Galeno, segundo as quais cumpre ao juiz examinar com prudência e discrição o requisito do legítimo interesse, inclusive com vistas à necessidade ou utilidade da publicização da medida por meio de editais, verificando sua eventual nocividade e ponderando os interesses contrapostos.⁵⁰²

Seção III

Da alienação judicial

1. Inovações do CPC/2015

Não houve expressiva alteração no título da seção, exceto quanto a essa denominação, que deixa de ser *Capítulo* para passar a chamar-se *Seção* e o número, que passa de plural a singular.

2. Aspectos materiais gerais da Seção – Da Alienação Judicial

Considerando que são judiciais todas as alienações que ocorrem sob a vigilância e condução de órgão do Poder Judiciário, este conceito geral abrange não somente os procedimentos tratados nesta Seção, mas aquelas alienações típicas do processo de execução. Contudo, para o que interessa ao estudo aqui proposto, apenas se tratará das alienações que tramitam sobre o pátio da jurisdição voluntária, porquanto ambas diferem claramente.

Sobre o tema, João Paulo Lucena afirma que as alienações judiciais decorrentes de execução forçada por quantia certa não integram, evidentemente, a jurisdição voluntária, mas sim os processos de jurisdição contenciosa.⁵⁰³ Do mesmo modo Pontes de Miranda, em análise ao CPC/1973 e observando a generalidade do título “alienações judiciais” relativamente à jurisdição voluntária, sustentou que os artigos de lei correlatos não compreendiam todos os casos de alienações procedidas em juízo, nem a arrematação dos bens executados, porquanto faltava-lhes a razão suficiente da execução (constrição forçada).⁵⁰⁴

Para Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero as alienações judiciais promovidas na fase de cumprimento de sentença por execução forçada e no processo de execução autônomo, porque pertencentes à normalidade do procedimento, não são disciplinados pelo art. 730 do CPC/2015.⁵⁰⁵

Visto isso, quanto à natureza das alienações judiciais aqui tratadas não inova o CPC/2015. Constituíam procedimento de jurisdição voluntária na lei revogada e permanecem sendo tratadas como tal na lei vigente, como não poderia deixar de ser. As grandes inovações trazidas pelo novo código dizem respeito às hipóteses de cabimento e à sequência de atos processuais que se lhes são aplicados.

Conforme será esclarecido adiante, a Seção III acima referenciada é composta por um único artigo pelo qual quis o legislador simplificar o procedimento da alienação judicial. Para tanto, em vez de prever regras específicas como fazia o CPC/1973, limitou-se a remeter o aplicador da norma a outros dispositivos do código atual.

Entretanto, engana-se quem prejulga singela a nova disciplina. Considerando as remissões feitas pelo dispositivo, tem-se que no total são mais de trinta artigos que regulamentam o procedimento em vigor. Seu trâmite é bem mais complexo do que aparenta, resultado da maior flexibilidade conferida às alienações judiciais, a exigir análise acurada quando de sua aplicação.

3. Aspectos processuais e procedimentais

As alienações judiciais podem se dar de maneira autônoma (em autos próprios) ou incidental (nos autos de ação em curso ou em autos próprios, desde que decorra de processo em trâmite), por requerimento de qualquer interessado ou *ex officio*. O ato alienatório propriamente dito pode ser realizado por iniciativa particular ou em leilão, esse último eletrônico ou presencial.

Porquanto constituem procedimento de jurisdição voluntária, a cognição é deveras limitada. Desse

modo, nas alienações judiciais o juiz não exerce juízo de valor sobre a conveniência da medida pretendida.⁵⁰⁶ Sua atuação enquanto autoridade jurisdicional restringe-se à análise do preenchimento dos requisitos do pedido alienatório e à reta condução da alienação propriamente dita, sendo necessário, entretanto, elevada prudência do juiz de modo a se evitar a utilização da máquina judiciária para o atingimento de fins ilícitos, tais como fraude à execução, fraude contra credoras, litigância de má-fé, prejuízo patrimonial aos incapazes etc.

Art. 730 . Nos casos expressos em lei, não havendo acordo entre os interessados sobre o modo como se deve realizar a alienação do bem, o juiz, de ofício ou a requerimento dos interessados ou do depositário, mandará aliená-lo em leilão, observando-se o disposto na Seção I deste Capítulo e, no que couber, o disposto nos arts. 879 a 903.

1. Inovações do CPC/2015

Inova o art. 730 pela contenção e pela supressão do procedimento que vinha antes descrito entre os arts. 1.113 a 1.119, agora economicamente encaixado em um único dispositivo que na parte final remete à *Seção I do Capítulo XV , Disposições Gerais da Jurisdição Voluntária*, e aos arts. 879 a 903, ou seja, a *Subseção II , Da Alienação* , inserta na seção que trata da expropriação de bens do processo de execução, como procedimento supletivo do modo de realização da alienação em leilão.

Assim, as disposições gerais dos procedimentos de jurisdição voluntária aplicam-se especialmente ao pleito alienatório e as regras de alienação típicas do processo executivo relativamente aos atos de alienação propriamente ditos. Para Parte da doutrina o CPC/2015 adota solução coerente com a unificação procedimental, dispondo que o bem deverá ser alienado observando-se as normas referentes ao procedimento padrão das medidas de jurisdição voluntária e, especialmente quanto aos atos de expropriação, as normas atinentes à alienação do processo de execução.⁵⁰⁷

A ressalva de aplicação *do que couber* exige a interpretação cuidadosa, de modo a não transportar para as alienações voluntárias todas as ressalvas da execução forçada. A remissão à seção que trata da alienação decorrente do processo de execução impõe a interpretação dos limites da aplicação ao ‘que couber’ e for compatível com a seção I do Capítulo que trata da Jurisdição Voluntária.

Nas linhas que se seguem será evidenciado que o art. 730 contém muito mais possibilidades de incidência do que o texto, em sua literalidade, parece permitir. É que o singelo dispositivo demanda um diálogo frequente com uma infinidade de outras regras processuais e materiais, que acabam por ampliar sobremaneira sua interpretação e, conseqüentemente, sua aplicabilidade.

2. Aspectos materiais

Inicialmente, merecem relevo os termos iniciais do artigo em análise: “Nos casos expressos em lei”. Da leitura do texto legal vê-se que somente tem lugar a técnica processual aqui tratada quando a lei expressamente a exigir ou permitir.

Para Parte da doutrina alienação judicial regulada como jurisdição voluntária é procedimento, no mais das vezes, incidental, destinado à proteção de interesses reputados relevantes pelo ordenamento jurídico. Consiste, assim, em verdadeiro requisito de validade para a transferência de um bem.⁵⁰⁸

Em que pese o legislador remeta o intérprete da norma às disposições que regulamentam o processo executivo, a finalidade da alienação na jurisdição voluntária é diversa da alienação forçada própria da fase ou do processo de execução que objetiva a satisfação do credor. Há aqui, em geral, uma convergência de interesses inexistente na alienação conseqüente à expropriação forçada. Há também a possibilidade de divergirem sobre a própria alienação, sobre a conveniência de fazê-la ou o dissenso pode se resumir à forma, à oportunidade, à avaliação ou a outro ponto entre a decisão de alienar e a guarda final dos valores.

Desse modo, embora a lei diga acerca de ausência de acordo “sobre o modo como deve se realizar a alienação do bem” – a pressupor que ao menos há acordo para que a alienação efetivamente ocorra –, a interpretação que se dá ao dispositivo é bem mais ampla. O mesmo se dirá quanto à amplitude do termo “leilão”, já que não há de ser restritivo diante da reconhecida possibilidade de o bem ser alienado também por iniciativa particular.⁵⁰⁹

Aqui surge uma importante observação. Embora o art. 730 exija a ausência de acordo sobre a forma

de alienação do bem, o procedimento por ele regulamentado não é cabível somente nessas situações. Como bem observa Parte da doutrina, quando a lei material determina que a alienação somente poderá ocorrer em juízo, assim deverá ser ainda que os interessados entrem em consenso quanto à forma distinta. Afinal, a disposição legal substantiva é norma específica a prevalecer sobre a disposição processual geral do CPC.⁵¹⁰

Ainda assim, trata-se de forma de aquisição e perda da propriedade, ou mesmo de direito de natureza complexa e de múltiplas subdivisões que afetam ou podem afetar interesses privados de coproprietários, compossuidores, titulares de direito real limitado, promitentes compradores e devedores, de pessoas com ou sem liberdade de disposição de bens e direitos, de credores com ou sem privilégios, ou interesses públicos de entes federativos, entes da administração indireta, delegatários, concessionários etc. Essa miríade de *interessados* e seus potenciais conflitos de interesse tornam a alienação terreno no qual se deve andar com maior zelo e segurança.

É de se considerar também que a alienação não pressupõe apenas a venda de bens. Bem explica Alcides de Mendonça Lima, em comentários ao CPC/1973, que a palavra “alienação” possui sentido genérico e, como tal, mais amplo que o termo “venda”, esse último como variante daquele.⁵¹¹ O primeiro é gênero do qual o segundo é apenas uma espécie.

Assim, o procedimento de jurisdição voluntária aqui tratado abrange toda forma de transferência de propriedade. Para que se pretenda a alienação judicial basta que o interessado objetive transferir propriedade a qualquer outro.

2.1 As razões e a finalidade das alienações judiciais

Muitas são as razões para que se procedam as alienações judiciais; duas são destacáveis: estar o bem submetido ao juízo em vista de algum litígio ou só poder ser alienado mediante a submissão ao escrutínio das razões pelo juízo. O interesse é exclusivo dos interessados ou ‘partes’, vez que só elas terão vantagem com a alienação⁵¹² e a prevenção de dispêndios, riscos, inconveniências etc.

Conforme entente Edson Prata, a finalidade precípua da alienação judicial por leilão compreende a necessidade de preservar os direitos e à cientificação de numerosas pessoas para que possam tomar conhecimento do objeto a ser alienado, escolhendo-se o melhor preço.⁵¹³ Trata-se da preservação de direitos do proprietário, do comprador, do terceiro interessado, entre outros. Por isso são exigidas algumas formalidades legais, tais como a publicação do edital de leilão.

Para instauração dos procedimentos em exame o único requisito imposto pela lei é a falta de consenso dos interessados sobre o modo como deve ocorrer a alienação. Não se exige mais, como antes se fazia, que o bem esteja em risco de deterioração, avariado ou que os custos de sua manutenção sejam elevados. Essas situações antes enumeradas pela lei, agora surgem como meros exemplos das inúmeras possibilidades existentes. A hipótese de cabimento da alienação judicial tornou-se, portanto, mais clara e objetiva.⁵¹⁴

2.1.1 Alienações de bens de pessoas incapazes

Dispõe o art. 3.º do CC/2002 que, regra geral, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de dezesseis anos. O art. 4.º do mesmo diploma legislativo estabelece que são incapazes relativamente para certos atos ou à maneira de exercê-los os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos, os ébrios habituais, os viciados em tóxico, os pródigos e aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade.

Relativamente a essas pessoas a lei exige algumas cautelas para que os bens que integram seu patrimônio possam ser alienados. Isso porque o legislador considerou relevantes os interesses por elas titularizados, ante as limitações que apresentam para o exercício de seus direitos civis. Quis assim prevenir que os incapazes fossem vítimas de abusos, arbítrios e danos causados inclusive por seus próprios representantes, de modo a se preservar seu patrimônio e/ou garantir-lhe o proveito econômico.

Assim, todas as vezes em que a autorização judicial for necessária à alienação de bens de incapazes, esta será necessariamente procedida em juízo.

Pontes de Miranda, em análise ao CPC/1973, observou que o revogado art. 1.117, inciso III, o qual disciplinava a matéria anteriormente, ao tratar dos incapazes fazia referência expressa apenas aos

órfãos (menores de idade submetidos a tutela), repetindo impropriedade do CPC/1939. Mesmo àquela época o jurista já entendia, com acerto, que a regra jurídica se referia a quaisquer incapazes, sejam pela menoridade ou sejam pela interdição. Não havia motivo que justificasse interpretação restritiva ao dispositivo legal, entendimento do qual partilham Alcides de Mendonça Lima, José Olympio de Castro Filho e João Paulo Lucena.⁵¹⁵

O CPC/2015 não repetiu a impropriedade. Previu em seu art. 725, inciso III, que *alienação*, arrendamento ou oneração de bens de *crianças* ou *adolescentes*, de órfãos e de *interditos* serão processados na forma das disposições gerais dos procedimentos de jurisdição voluntária. Ademais, tratou do adiamento da alienação quando se tratar de bem imóvel desses interessados, aqui sim repetindo previsão do art. 701 do código anterior, em seu art. 896.⁵¹⁶

Nota-se que o art. 896 acima transcrito tem lugar apenas quando se tratar de bens imóveis, ante o considerável valor venal tipicamente atrelado a esses bens. São bens de relevo patrimonial que exigem maiores cuidados quando de sua alienação, porquanto se alienados de modo irresponsável pode resultar em prejuízo substancial ao incapaz. É evidente que muitos bens móveis podem ser mais valiosos que bens de raiz, mas a opção legislativa, ao que se vê, não os contemplou nesse artigo.

A lei exige a alienação judicial no trato dos bens de incapazes de acordo com a previsão inserta no art. 1.748, inciso IV, combinado com o art. 1.750, ambos do CC/2002, nesse caso restrito aos menores de dezesseis anos sob tutela, não aqueles submetidos ao poder familiar. Ressai desses dispositivos que compete ao tutor, com autorização do juiz, vender-lhe os bens móveis cuja conservação não convier e os imóveis nos casos em que for permitido, sendo certo que os imóveis pertencentes aos menores sob tutela somente podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz.

A regra se aplica também aos interditos que, como tais, estão submetidos a curatela. O art. 1.774 do CC/2002 determina que se apliquem à curatela as mesmas disposições da tutela, motivo pelo qual a autorização judicial é igualmente imprescindível para que a alienação ocorra regularmente.

Sob a vigência da lei processual civil anterior e antes da entrada em vigor do CC/2002 os bens dos menores sob tutela e de interditos (por força do art. 453 do CC/1916), todos absolutamente incapazes à época, somente poderiam ser alienados em hasta pública. Isso porque o inciso VI do art. 427 do CC/1916 dispunha que competia ao tutor, mediante autorização do juiz, *vender em praça* os bens moveis cuja conservação não convier e os imóveis nos casos em que for permitido. O art. 429 no mesmo Código dizia que os imóveis pertencentes aos menores só poderiam ser vendidos quando houvesse manifesta vantagem e *sempre em hasta pública*.

Diante disso a doutrina e a jurisprudência consideravam que os bens dos menores sob poder familiar (dito pátrio poder), não inseridos naqueles conceitos, poderiam ser vendidos por iniciativa particular, desde que houvesse autorização judicial para tanto.

Com a entrada em vigor do CC/2002 e, sobretudo, após as alterações trazidas pela Lei 13.146/2015⁵¹⁷ (que, dentre outras providências, alterou dispositivos do código civil vigente para reduzir o rol de hipóteses de incapacidade absoluta) e pela nova disciplina processual prevista do CPC/2015, tais embates perderam sua razão de existir. Isso porque não se impõe mais a obrigatoriedade de alienação de bens de absolutamente incapazes em hasta pública.

Já em 2004, José Olympio de Castro Filho, analisando a forma de alienação patrimonial dos menores e outros incapazes, entendia que a alienação em praça ou leilão não era excludente de solução diversa, a saber, de “alienação pela forma do direito privado, sob fiscalização, é obvio, do juiz e do Ministério Público”. Como o texto do CPC/1973 já permitia a alienação por preço inferior ao da avaliação (exceto preço vil), não estaria excluída a alienação por outra forma (iniciativa particular). Com o advento do CC/2002 (art. 1.750), foi suprimida a exigência de hasta pública “para a venda de bens de menores sob tutela e, em consequência, também os bens de menores representados ou assistidos pelos pais”.⁵¹⁸

Note-se que embora o CPC/1939 contemplasse a alienação por iniciativa particular, o legislador pátrio suprimiu essa possibilidade quando da edição do CPC/1973. Somente com o advento da Lei 11.382/2006, que alterou dispositivos da Lei 5.869/1973, é que aquela modalidade de alienação tornou a ser admitida. A partir de então não houve dúvidas de que determinado bem poderia perfeitamente ser alienado em juízo fora de hasta pública. Essa previsão, porque relevante, foi mantida na norma processual vigente.

O CPC/2015, como visto acima, não trouxe regra diversa que pudesse suscitar alguma divergência interpretativa entre as leis processual e material. Observe-se que nem mesmo o art. 1.113, § 3.º, do CPC/1973 – o qual previa que a alienação de bens poderia ser feita independentemente de leilão se todos os interessados forem capazes e nisso convierem expressamente, ou seja, dispensava a hasta pública somente quanto ao patrimônio de pessoas capazes – foi repetido no CPC/2015.

Portanto, não há dúvidas acerca da possibilidade de alienação judicial por iniciativa particular mesmo no tocante aos menores de dezesesseis anos sob tutela (absolutamente incapazes).

2.1.2 Alienações de bens de pessoas capazes

Em se tratando de pessoas capazes para os atos da vida civil a lei não lhes impõe maiores restrições como faz no caso das pessoas incapazes. A alienação judicial de seus bens pode se dar em leilão ou mesmo por iniciativa particular independentemente de autorização judicial. Afinal, tratando-se de direito patrimonial e, portanto, disponível de pessoas plenamente aptas a dispor livremente de seus bens porque detentoras de absoluta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, não há motivo para que a lei oponha obstáculos ao exercício de qualquer pretensão, desde que o fim almejado seja lícito.

José Olympio de Castro Filho explica que para os maiores de idade e capazes a alienação poderá ser de qualquer forma, pois serão os donos do negócio processual que a determinarão, com a única exceção de que não deve ser admitida qualquer forma que importe em fraude.⁵¹⁹ É que o Direito jamais admitirá que a alienação judicial se preste a fins escusos, tais como fraude à execução ou fraude contra credores. A liberdade de dispor do patrimônio em juízo ou fora dele pressupõe sempre a obtenção de fim não defeso em lei.

Nem mesmo no processo executivo se pode tornar obrigatório o leilão entre maiores e capazes, então com menos razão a hasta pública há de ser regra imposta em procedimento de jurisdição voluntária. A esses indivíduos sequer é necessário que a alienação se dê em juízo, sendo essa possibilidade uma faculdade dos interessados. A urgência da alienação pode ser fundamento, mas precisa ser demonstrada.⁵²⁰

Sendo requerida a alienação judicial, o bem da vida poderá ser alienado tranquilamente por iniciativa particular ou por leilão judicial, que pode ser eletrônico ou presencial, havendo uma predileção legal pela primeira, conforme se denota do art. 881.

Note-se que a nova lei processual já não faz mais distinção entre praça e leilão. O CPC/2015 somente faz referência a esse último termo, o qual agora se aplica tanto a bem móveis quanto a imóveis. Não se fala mais em praça como modalidade de hasta pública.

2.2 Objetos ou bens passíveis de alienações judiciais

Quaisquer bens podem ser objeto de alienação judicial – sejam eles móveis ou imóveis, incluindo os chamados semoventes –, desde que estejam vinculados a um processo, casos em que se procederá mediante processo incidente; ou de bens que dependam de autorização para a alienação ou sob os quais simplesmente os interessados divirjam quanto ao modo como deverão ser alienados, casos em que se processará por meio de procedimento autônomo, como abaixo será discriminado.

Em quaisquer dos casos, deve-se analisar qual ou quais as finalidades/propósitos das diversas espécies de alienações. Sobre esse ponto, Humberto Theodoro Júnior, analisando a disciplina do procedimento de jurisdição voluntária das alienações judiciais no CPC/1973, explicou que sua aplicação prática ocorria em três situações distintas: a) como meio de exercer função cautelar, nos casos de bens afetados por constrição judicial quando forem de fácil deterioração, estiverem avariados ou exigirem grandes despesas para sua guarda; b) como meio de resguardar interesses de incapazes ou outros interesses que merecem especial atenção e que levam o legislador a instituir a venda judicial como forma válida de disposição de bens; c) como meio de extinção do condomínio sobre as coisas indivisíveis.⁵²¹

Eram esses os casos previstos pelo CPC anterior, os quais embora não capitulados no novo código estão por ele abrangidos, como elucidado anteriormente. Trata-se de simples exemplos de um universo muito maior de hipóteses de cabimento.

O jurista observou ainda que além das ocasiões acima enumeradas outras justificam alienação em juízo, mas com o fim de realizar-se a execução forçada por quantia certa. Entretanto, já se viu, essas não

são regulamentadas pela sistemática do procedimento especial de jurisdição voluntária e sim pelas regras específicas do processo de execução. ⁵²²

Logo, para se caracterizar o procedimento especial de jurisdição voluntária da alienação judicial a finalidade/propósito dos interessados nunca poderá ser a execução forçada de dívida. Não tem lugar, neste estudo, a constrição judicial.

João Paulo Lucena defende que o procedimento aqui tratado possui *fundo cautelar*, assecuratório dos direitos postos em juízo, com o fito de preservar o valor econômico dos bens depositados judicialmente, muitas vezes ameaçados por uma excessiva demora do processo principal. Diz ainda que essa alienação sem caráter executivo, mas incidental a um processo contencioso não busca satisfazer credor, sendo eventualmente requerida pelo próprio devedor. Destina-se a preservar de forma acautelatória o valor do bem depositado, beneficiando a todas as partes envolvidas. ⁵²³

Alcides de Mendonça Lima, por sua vez, tratando das finalidades das alienações, posicionou-se pelo *caráter protecionista* do que chamou de “alienações de bens fora do exercício do direito de propriedade de seus titulares, isso é, particularmente, mas necessitando da intervenção judicial para sua efetivação”. Protecionista porque visa proteger os interesses, em regra, dos donos do bem da vida objeto da demanda judicial, o “que é, aliás, traço típico da ‘jurisdição voluntária’”. Assim, não se está diante “de litígio, propriamente, sobre o destino do bem ou sobre o direito em torno do mesmo, e, sim, de medida com o objetivo precípuo de efetuar a alienação, evitando mal maior ou solvendo eventual impasse entre os interessados”. ⁵²⁴

De todo modo, a natureza do procedimento em exame não é puramente acautelatória, vez que não constitui procedimento cautelar (tipicamente contencioso). O que pode ou não ser acautelatória é a finalidade/motivo do interessado a justificar da alienação judicial e, mesmo nesta hipótese, não se afasta a natureza de procedimento de jurisdição voluntária (não há conflito de interesses ou acerto de relação jurídica).

As previsões legais de hipóteses de alienação são diversas e se processam na forma estabelecida na Seção relacionada à jurisdição voluntária e conforme preceitua o novo art. 730, que agora remete ao processo de execução. Assim, as disposições gerais da jurisdição não contenciosa e as regras tipicamente executivas se aplicam, no que couber, como “procedimento ordinário” às alienações judiciais. ⁵²⁵

São casos em que a lei vigente dispõe expressamente sobre a necessidade de alienação judicial: a) alienação, arrendamento ou oneração de bens de crianças ou adolescentes, de órfãos e de interditos (art. 725, inc. III); b) alienação, locação e administração da coisa comum (art. 725, inc. IV) e; c) alienação de quinhão em coisa comum (art. 725, inc. V). Cada uma dessas situações foi vista com detalhes em linhas anteriores, quando do estudo das disposições gerais aplicáveis aos procedimentos de jurisdição voluntária.

O CPC/1973, em seu maior grau de detalhamento, estabelecia que a alienação judicial teria lugar nas mesmas hipóteses acima descritas (art. 1.112), bem como nas seguintes ocasiões: a) alienação de bens de difícil partilha (art. 1.117, inc. I); b) alienação de bens indivisíveis (art. 1.117, inc. II); c) alienação de bens de órfãos (art. 1.117, inc. III); d) alienação de bens depositados judicialmente que forem de fácil deterioração, estiverem avariados ou exigirem grandes despesas para a sua guarda (art. 1.113); e) alienação de semoventes e outros bens de guarda dispendiosa, exceto quando algum dos interessados for obrigado a satisfazer ou garantir as despesas de conservação (art. 1.113, § 1o).

Também ao tratar da herança jacente o CPC/2015, repetindo disciplina do art. 1.155 da lei revogada, enumera em seu art. 742 situações em que poderá ser autorizada a alienação judicial, são elas: a) alienação de bens móveis, se forem de conservação difícil ou dispendiosa; b) alienação de semoventes, quando não empregados na exploração de alguma indústria; c) alienação de títulos e papéis de crédito, havendo fundado receio de depreciação; d) alienação de ações de sociedade quando, reclamada a integralização, não dispuser a herança de dinheiro para o pagamento; e) alienação de bens imóveis se ameaçarem ruína, não convindo a reparação, ou se estiverem hipotecados e vencer-se a dívida, não havendo dinheiro para o pagamento. Cada uma dessas hipóteses será detalhada mais adiante neste trabalho, especificamente quando se tratar do procedimento de jurisdição voluntária de arrecadação de herança jacente a que se referem os arts. 738 ao 743 do novo código. TJSP, Ap 1000707-74.2015.8.26.0470, 3.^a Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2016, julgado por Carlos Alberto de Salles, Área do Direito: Imobiliário e Registral

Não cabe, contudo, procedimento de jurisdição voluntária com a denominação de alienação, que vise a expedição de alvará judicial para supressão da declaração de vontade de terceiro; falta-lhe, no caso, interesse processual para o objeto pretendido. ⁵²⁶

3. Aspectos processuais e procedimentais

Como dito acima, na nova *Seção* que trata da alienação judicial não mais se detalha como no CPC anterior o procedimento da alienação voluntária, “observando, sempre, o contido na parte geral do capítulo dos Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária” ⁵²⁷ e aproveitando-se dos arts. 879 a 903 do CPC/2015, naquilo que compatível, como procedimento supletivo para a realização da alienação em leilão. Diante da concisão do art. 730, todo o regramento sobre a avaliação vir da *Subseção II*, *Da Alienação*, contida na seção que trata da expropriação de bens do processo de execução, observando-se a advertência do cabimento.

Esta nova sistemática tem a vantagem da uniformização e da modernização das inovações introduzidas pela Lei 11.382/2006 nas alienações da fase ou do processo de execução, não alcançada pelas alienações previstas na jurisdição voluntária do CPC anterior.

Dentre essas disposições que desde 2006 evoluíram no tocante às alienações estão a iniciativa particular, o leilão por meio eletrônico, a indicação de leiloeiro pelo alienante, o melhor detalhamento dos editais, dentre outras. Mas há também inovações trazidas pelo CPC/2015 que agora poderão ser aproveitadas pela jurisdição voluntária, tais a ampliação e melhoria no uso da comunicação por meio eletrônico, a comunicação a entes federativos, a titulares de direitos, a terceiros e interessados, maior eficiência das avaliações e do pagamento, conforme se detalhará adiante.

Sendo certo que o procedimento aqui tratado é feito de jurisdição voluntária, tem-se claro que este não se destina ao acerto de relação jurídica, já que não pressupõe conflito de interesses (lide). Por essa razão são incabíveis maiores debates sobre os direitos que incidem sobre o bem da vida em questão, mesmo porque, feita a alienação, o valor obtido sub-roga-se no lugar antes ocupado pelo objeto alienado. Eventuais litígios sobre o bem poderão prosseguir de igual modo em feito contencioso, agora sobre o montante alcançado na alienação.

Desse modo, a atuação do juiz comportará análise quanto ao mérito da falta de consenso sobre o modo como deve ser alienado o bem da vida e a possibilidade fático-jurídica de sua alienação em juízo. Nesse sentido sustenta Arruda Alvim que “o juiz não realiza juízo de valor sobre a conveniência de se realizar a alienação. A razão para que ocorram é o dissenso entre os interessados”. ⁵²⁸

Apesar disso, não se pode ignorar que o Judiciário jamais poderá ser usado para a prática de ilegalidades. Por isso, a despeito de a cognição ser limitada em feitos dessa natureza, o juiz deverá atuar com elevada prudência para garantir que os interessados não pretendem alcançar fins ilícitos. Evitará, por exemplo, fraude à execução, fraude contra credores, litigância de má-fé, prejuízos patrimoniais aos incapazes, entre outras ilicitudes. ⁵²⁹

Embora não se trate de feito contencioso, no curso do procedimento haverá maior espaço para o contraditório, inclusive com a oitiva do Ministério Público e da Fazenda Pública quando necessário (arts. 721 e 722), porquanto qualquer outro interessado pode trazer ao conhecimento do juiz, por exemplo, fato impeditivo da alienação. Afinal, nem sempre os interessados peticionarão juntos pela alienação judicial, pois é possível que divirjam até mesmo quanto a sua necessidade.

Sobre o contraditório afirmam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero que este poderá versar sobre a caracterização do bem como sendo passível de alienação judicial incidental e sobre a oportunidade e conveniência da alienação. ⁵³⁰

Parte da doutrina explica que a alienação em juízo pode ser requerida por qualquer interessado, mas todos os demais devem ser citados para que se manifestem quanto à necessidade de alienação e seu modo de ser. Assim, aquele que se opuser à forma de alienação sugerida ou à própria pretensão alienatória deve fundamentar seu requerimento, fazendo prova de suas alegações. Desse modo, deve ser possibilitada, caso relevante, a oitiva de testemunhas ou mesmo a realização de perícia, conduzindo-se todo procedimento com amplo respeito ao contraditório e ao direito de participação na formação da decisão. Ao fim, o juiz há de decidir com base no permissivo normativo da alienação judicial, sempre observando qual das soluções é mais eficiente para a tutela do interesse protegido nos autos, inclusive mediante juízo ponderativo se for o caso. ⁵³¹

Feitas essas considerações, é de se concluir que se o juiz notar, por exemplo, que o fim pretendido pela alienação é fraude à execução, deverá reconhecer a impossibilidade de deferimento da medida pretendida, porque ilícita. São consideradas fraude à execução as circunstâncias previstas no art. 792 do CPC/2015, quais sejam, a alienação ou a oneração de bens realizada quando: 1) sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; 2) tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; 3) quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; 4) quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; 5) nos demais casos expressos em lei.

Como não se trata de processo de execução, a iniciativa da alienação não parte necessariamente de um credor. Logo, a ocorrência de fraude à execução ou contra credores como resultado da alienação judicial é realidade perfeitamente palpável no procedimento especial ora debatido, ao contrário do que ocorre na alienação judicial tipicamente executiva, em que é o próprio exequente, titular do crédito, quem pretende seja alienado o bem penhorado.

De todo modo, a decisão que determina a alienação possui forte carga executiva e sua cognição limita-se às questões referentes ao preenchimento da hipótese fática da norma permissiva da alienação e à sua melhor forma. Por possuir conteúdo decisório, é recorrível por agravo de instrumento.⁵³²

3.1 Espécies e formas de alienação

Em linhas anteriores se observou que há diversas formas de alienação judicial, as quais tem lugar conforme a iniciativa, o modo como se processam e a forma como o bem é efetivamente alienado. Adiante se estudará cada uma delas detidamente, observando suas peculiaridades.

3.1.1 Incidental ou autônoma

Quanto à origem, as alienações podem ser incidentais, quando se procedem no curso de processos ou procedimentos já instaurados, ou autônomas, quando não decorrem de processos em trâmite, mas se iniciam de maneira independente, bastando que haja o interesse em alienar um ou alguns bens e divergência relativamente ao modo, possibilidade, conveniência ou oportunidade de fazê-lo.

No caso das incidentais, não estão abrangidas, logicamente, as alienações promovidas na fase de cumprimento de sentença por execução forçada e no processo de execução autônomo, porque “pertencentes à normalidade do procedimento”. Têm lugar sempre que for necessária alienação judicial em processo pendente, como providência incidental e fora da cadeia normal do procedimento, independentemente de instauração de processo apartado.⁵³³

Os procedimentos indicados no art. 742 (bens na herança arrecadada) e no art. 642, § 3o (satisfação de dívidas no inventário), por exemplo, são incidentais a outros processos ou procedimentos, assim como são todas as alienações determinadas de ofício pelo juiz.⁵³⁴

Ressalte-se, desde agora, conforme defende Parte da doutrina, que a possibilidade de alienação de ofício é reflexo do fato de que nos procedimentos de jurisdição voluntária, por não consubstanciarem atividade jurisdicional propriamente dita, o princípio da inércia do órgão jurisdicional é mitigado. Ainda assim, completa Parte da doutrina, a permissão para que o juiz aja sem provocação deve ser entendida com ressalvas, pelo que a alienação *ex officio* se dá apenas nos casos em que a lei atribui ao órgão jurisdicional a responsabilidade pela guarda da coisa e essa esteja se deteriorando de modo que deva ser alienado, ou quando houver o processo instaurado não destinado à alienação judicial do bem, mas esta medida afigura-se recomendável.⁵³⁵

Por outro lado, são autônomas as alienações de bens em que “não houver acordo sobre divisão de coisa comum (cf. arts. 1.320 e 1.322, parágrafo único do CC/2002), em se tratando de bem imóvel de propriedade de menores sob tutela (cf. art. 1.750 do CC/2002) etc.”, assim como aqueles casos previstos no já mencionado art. 725, incs. III, IV e V.⁵³⁶

Sob a vigência do Código anterior, eram incidentais as alienações autorizadas pelos arts. 1.113 a 1.119 e autônomas aquelas disciplinadas pelos art. 1.112, incs. III, IV e V. Como observado anteriormente, são hipóteses abrangidas pelo CPC/2015, quer por disposição expressa, quer por conclusão lógica.

3.1.2 Iniciativa particular ou leilão judicial (presencial ou eletrônico)

Sejam autônomas ou incidentais, as alienações poderão sempre se dar por iniciativa particular ou em leilão judicial. Trata-se de classificação que leva em conta a técnica utilizada em juízo para a alienação propriamente dita.

Essa dupla possibilidade existe porque a importância do procedimento não se fundamenta na realização do leilão, mas na fiscalização judicial do negócio jurídico em situações reputadas relevantes pelo Direito. Portanto, a lei previu duas técnicas objetivando garantir maior liberdade e melhores resultados aos interessados, embora tenham buscado o controle do Poder Judiciário.

Dispõe o art. 879 do CPC/2015 que a alienação será feita por iniciativa particular (inc. I) ou em leilão judicial eletrônico ou presencial (inc. II). A diferença entre ambas reside no “maior ou menor grau de participação da estrutura judicial para que o bem seja alienado”. Enquanto na primeira a atuação do juízo se limita a estabelecer os parâmetros da alienação, controlando eventuais desvios ou excessos, o segundo ocorre perante a estrutura o próprio “Estado-jurisdição”.⁵³⁷

Em qualquer dos casos haverá sempre o controle judicial, motivo pelo qual a iniciativa particular aqui tratada não se confunde com aquela típica das alienações que ocorrem livremente fora da esfera jurisdicional.

No processo executivo a lei estabelece uma ordem de preferência para a expropriação patrimonial do executado, na qual primeiro se oportuniza a adjudicação do bem e somente depois é intentada sua alienação, com prioridade à iniciativa particular. Na jurisdição voluntária a sistemática da alienação há de seguir a mesma lógica, com maior grau de liberdade aos interessados.

A alienação por iniciativa particular não é novidade no ordenamento jurídico pátrio. Estava prevista no art. 973 do CPC/1939, o qual dispunha que a requerimento de qualquer interessado e ouvido o devedor o juiz poderia assinalar prazo para que a venda se realizasse por iniciativa particular, se não lhe parecer oportuno que se efetue em hasta pública. O CPC/1973, contudo, não repetiu a regra. Somente com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006 é que aquela modalidade de alienação tornou a ser admitida pela lei processual. O CPC/2015, seguindo a mesma tendência, repetiu a previsão legal e a disciplinou conforme art. 880.⁵³⁸

Extraí-se do *caput* desse dispositivo que a alienação por iniciativa particular é realizada, no caso da jurisdição voluntária, pelo próprio interessado ou por corretor ou leiloeiro público credenciado perante a autoridade judiciária (*caput*), os quais devem estar em exercício profissional por não menos de três anos (§ 3.º). Inexistindo profissionais credenciados, cabe aos interessados a indicação – não a escolha final – de corretor ou leiloeiro, o qual será sempre submetido à aprovação da autoridade judiciária (§ 4.º). Afinal, compete também ao juiz, enquanto presidente do feito, exercer o controle de todos os atos do procedimento, inclusive no tocante à garantia de lisura, “idoneidade ou imparcialidade”⁵³⁹ dos auxiliares da justiça que eventualmente atuem na demanda.

Sobre a exigência de credenciamento do leiloeiro, pontua Parte da doutrina, com amparo no Enunciado 192 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis, que a alienação realizada em iniciativa particular por leiloeiro não credenciado perante órgão do Judiciário, por si só, não invalida o negócio jurídico celebrado, salvo comprovado prejuízo.⁵⁴⁰

Para Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, a alienação por iniciativa particular no processo de execução pode ser requerida após a avaliação do bem, que funciona como critério para definição do preço mínimo pelo qual o bem pode ser alienado, até a assinatura do auto de arrematação. O exequente responde, contudo, pelas despesas causadas pela demora na sua opção pela alienação particular, conforme inteligência do art. 93 do CPC/2015. Por outro lado, o termo final para o requerimento é o da assinatura do auto de arrematação, tal como estabelece o art. 903 do mesmo diploma legislativo.⁵⁴¹

O mesmo entendimento vale para a jurisdição voluntária, sendo certo que aqui a alienação por iniciativa particular pode ser requerida por qualquer dos interessados, não apenas por aquele que demandou em juízo. Pode ainda ser determinada de ofício pelo juiz quando se mostrar menos gravosa para os interessados do que o leilão ou mesmo pelo Ministério Público nos casos em que atua como fiscal da lei e, como tal, tem ampla oportunidade de se manifestar nos autos.⁵⁴²

Conforme ressaí do § 1o, incumbe ao juiz a fixação do preço mínimo da alienação (o que faz a partir da avaliação), o prazo em que o bem deverá ser alienado (observando, dentre outros parâmetros, o princípio da razoável duração do processo, a urgência da alienação, as peculiaridades do local da venda e as características do bem), a forma de publicidade (em quais veículos será divulgado, por exemplo, o leilão para se atingir o máximo necessário de possíveis compradores), as condições de pagamento (impostas ao arrematante/adquirente e que devem ser respeitadas pelos interessados) e a comissão de corretagem (remuneração do corretor ou leiloeiro nomeado para o encargo alienatório).

Obtido êxito na iniciativa particular, a alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do adquirente e dos interessados, expedindo-se a respectiva carta de alienação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel, ou a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel. Quanto à forma do termo de alienação, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero sustenta que “a ausência de assinatura gera nulidade apenas se comprometer os fins de justiça do processo”.⁵⁴³

Nem a carta de alienação e nem o mandado de entrega transferem o domínio do bem alienado, servindo apenas de título de aquisição. A carta somada à aquisição possibilita transferência (arts. 1.227 e 1.245 do CC/2002); o mandado autoriza a posse do imóvel pelo adquirente com justo título e a partir dele se dá a tradição (art. 1.226 do CC/2002).⁵⁴⁴

Note-se que além das disposições contidas no artigo em exame é possível que atos normativos infralegais estabeleçam regras específicas para a alienação por iniciativa particular. É que a primeira parte do § 3o autoriza os tribunais a editarem normas complementares para regulamentar com maiores minúcias o procedimento aqui tratado, admitindo, quando for o caso, o concurso de meios eletrônicos, e para dispor sobre o credenciamento dos corretores e leiloeiros públicos.

Por outro lado, em não ocorrendo a alienação por iniciativa particular porque inconveniente ou infrutífera, tem lugar a alienação por leilão. Essa modalidade de alienação, porque procedida com maior grau de controle jurisdicional, possui disciplina mais detalhada, prevista nos art. 881⁵⁴⁵ e seguintes.

Para Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, a alienação judicial em leilão é técnica residual do código, só devendo ser empregada quando não houver interesse na adjudicação ou na alienação pela iniciativa particular.⁵⁴⁶ Aqui são necessárias cautelas na interpretação da regra.

No caso da jurisdição voluntária não se descarta, *prima facie*, a possibilidade de se adjudicar o objeto que, inicialmente, se pretendia alienar. Embora o art. 730 remeta o aplicador do direito apenas aos arts. 879 a 903, não se ignora que outros dispositivos do CPC/2015 hão de comunicar-se com aqueles frequentemente. Assim, afigura-se válida e aplicável também nas alienações judiciais em procedimento de jurisdição voluntária o art. 878, segundo o qual frustradas as tentativas de alienação do bem, será “reaberta” oportunidade para requerimento de adjudicação, caso em que também se poderá pleitear a realização de nova avaliação. Afinal, é possível que no curso do procedimento os interessados alcancem um consenso quanto à conveniência na adjudicação da coisa, embora quando do ajuizamento da demanda dissentissem sobre tal possibilidade.

Sendo assim, da análise do *caput* do art. 880 em conjunto com o art. 878, é viável e por vezes preferível, por exemplo, que na alienação judicial em jurisdição voluntária bens comuns indivisíveis sejam adjudicados a um dos condôminos, inclusive diante das preferências legais tuteladas (hipóteses do art. 725, incs. II e III). Nesse sentido o art. 1.322 do CC/2002 determina que, sendo indivisível a coisa e os consortes não quiserem adjudica-la a um só indenizando os demais, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior. Em acréscimo, preceitua o parágrafo único do mesmo artigo da lei material que se dos condôminos tem benfeitorias na coisa comum e participam todos do condomínio em partes iguais, realizar-se-á licitação entre estranhos e, antes de adjudicada a coisa àquele que ofereceu maior lance, proceder-se-á à licitação entre os condôminos, a fim de que a coisa seja adjudicada a quem afinal oferecer melhor lance, preferindo, em condições iguais, o condômino ao estranho.

O CPC/1973, inclusive, previa expressamente em que art. 1.119 – dispositivo inserido no antigo regramento das alienações judiciais em jurisdição voluntária – que verificada a alienação de coisa comum sem observância das preferências legais, o condômino prejudicado poderia requerer, antes da assinatura da carta, o depósito do preço e adjudicação da coisa.

É certo que neste Título se está tratando de procedimento de alienação judicial, mas se no curso do feito parecer ao juiz e aos interessados que a adjudicação a qualquer deles tornou-se realidade palpável e é mais vantajosa, não se pode reputá-la juridicamente impossível.

Em sentido contrário, não se pode perder de vista que o CPC/2015 inova também quanto ao chamado “negócio processual”, permitindo que as partes/interessados acordem alterações no trâmite do feito. Diz o art. 190 que versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo.

O leilão será sempre realizado por leiloeiro público, salvo nos casos em que o bem objeto de alienação for negociável em bolsa de valores, hipótese em que será alienado dessa forma por corretor especializado nesse tipo de negociação, não em leilão público (§§ 1.º e 2.º).

São duas as espécies de leilão público, quais sejam, o presencial e o eletrônico, sendo esse preferido em face daquele, conforme se extrai do *caput* do art. 882 ⁵⁴⁷. Somente em caso de patente impossibilidade do meio eletrônico é que terá vez o meio presencial.

Em análise a esse artigo de lei, observam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero que para se admitir o leilão eletrônico é necessário preservar as garantias processuais dos interessados e ainda a ampla publicidade, a autenticidade e segurança (art. 882, §§ 1.º e 2.º). Caso não seja possível satisfazer esses requisitos – ou não se consiga observar os requisitos determinados pelo Conselho Nacional de Justiça ou aqueles ditados pela legislação específica a respeito da certificação digital – o leilão presencial será a única opção viável. ⁵⁴⁸

Será realizado por leiloeiro público indicado pelos interessados (art. 883). ⁵⁴⁹ Aqui também se trata de mera indicação, ficando a escolha final ao encargo do juiz pelas razões vistas no caso da alienação por iniciativa particular. Nesse caso o controle judicial tem maior amplitude, já que toda a técnica alienatória tramita sob a vigilância jurisdicional.

O leilão presencial ocorrerá preferencialmente no local em que estejam situados os bens, sobretudo em si tratando de bens de raiz (imóveis em geral), ou em local designado pelo juiz (art. 882, § 3.º). O objetivo da opção legislativa pelo local de situação da coisa é facilitar o acesso de eventuais arrematantes ao objeto da alienação, obtendo-se assim maior número de potenciais adquirentes e melhores preços. Mesmo porque o leiloeiro deve expor aos pretendentes os bens ou as amostras das mercadorias, conforme inc. III.

O leiloeiro designado é incumbido da prática de todos os atos necessários à efetivação da alienação propriamente dita, desde a publicação do respectivo edital (ampla divulgação), observadas todas as exigências dos arts. 886 ⁵⁵⁰ e 887 ⁵⁵¹, até o recebimento e depósito do montante arrecadado no prazo de 1 dia, com a respectiva prestação de contas a ser efetivada nos 2 dias subsequentes ao do depósito (art. 884). ⁵⁵²

Tem direito ao recebimento da comissão estabelecida em lei ou arbitrada pelo juiz. Nos termos do art. 24, parágrafo único, do Decreto 21.981/1932, ⁵⁵³ não havendo estipulação prévia, os percentuais mínimos para a comissão serão de 5% (cinco por cento) e 3% (três por cento) sobre o valor da arrematação, respectivamente para bens móveis e imóveis. Não há percentual máximo fixado em lei ou outro ato normativo.

Descabida exigência de negociação prévia acerca da remuneração do leiloeiro, já que a publicação no edital de todos os termos da alienação, inclusive da comissão fixada (art. 886, inc. II, parte final), constitui ciência inequívoca ao interessado, que poderia ter impugnado o valor respectivo. ⁵⁵⁴

O juiz é incumbido da fixação dos demais parâmetros mínimos da alienação. Assim como ocorre na alienação por iniciativa privada, no leilão judicial incumbe ao juiz a fixação do preço mínimo pelo qual poderá ser alienada a coisa (tendo por base a avaliação ou a última cotação – sendo título da dívida pública ou títulos negociados em bolsa –, não podendo ser considerado vil), a forma de publicidade (conforme as possibilidades exemplificadas no art. 887, §§ 3.º ao 6.º) e as condições de pagamento. “A decisão sobre esses elementos deve pautar-se pelas circunstâncias de mercado do caso concreto”. ⁵⁵⁵

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, analisando esse dispositivo de lei

sob o ponto de vista do processo executivo, entende que referida decisão desafia agravo de instrumento, com fundamento no parágrafo único do art. 1.015, o qual preceitua que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.⁵⁵⁶ É bem verdade que as hipóteses de cabimento dessa espécie recursal são restritas e não abrangem expressamente decisões interlocutórias proferidas em alienação judicial que tramita sob o pálio da jurisdição voluntária. Aqui é de se ponderar a amplitude da alocação “no que couber” inserta no art. 730. Forçoso reconhecer a aplicabilidade do regramento inerente à execução à técnica processual aqui tratado para se admitir a interposição de agravo de instrumento, tanto no leilão judicial quanto na alienação por iniciativa privada. Caso contrário a única forma de impugnar os parâmetros fixados pelo juiz seria o mandado de segurança.

O art. 888 trata sobre a transferência da hasta pública, que consiste no adiamento do leilão, qualquer que seja o motivo que lhe deu causa.⁵⁵⁷ Observa André Vasconcelos Roque que não há mais previsão da exigência de motivo justo, antes contemplada no art. 688 do CPC/1973. Trata-se da transferência do leilão ainda não iniciado, não do prosseguimento do leilão em outro dia, regulado pelo art. 900 do CPC/2015.⁵⁵⁸

Ao ato de transferência deve ser dada ampla publicidade, com observância dos requisitos estabelecidos no art. 887. “A divulgação desse adiamento deve observar as mesmas cautelas naturais à publicação do edital originário”.⁵⁵⁹

Caso a transferência decorra de culpa do escrivão, leiloeiro ou chefe de secretaria, aquele que lhe deu causa deverá arcar com as despesas da nova publicação. Além disso, pode o juiz aplicar-lhe penalidade de suspensão por 5 dias a 3 meses, após regular processo administrativo no qual serão garantidos, por óbvio, o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Bem assevera André Vasconcelos Roque que, “caso o exequente [interessado] entenda que sofreu prejuízos, por exemplo, em razão da perda de proposta relevante para o leilão, poderá também pedir indenização contra o responsável em ação própria para este fim”. Entende ainda que se o responsável pela transferência do leilão foi o “executado” (interessado, no caso da jurisdição voluntária), não se aplica o dispositivo em análise, mas as sanções cominadas ao litigante de má-fé, bem assim deverá indenizar o “exequente” (cointeressado) pelos prejuízos que este sofreu.⁵⁶⁰

3.1.3 Petição inicial

O art. 730, repita-se, diz que nos casos expressos em lei, não havendo acordo entre os interessados sobre o modo como deve se realizar a alienação do bem, o juiz, de ofício ou a requerimento dos interessados ou do depositário, mandará aliená-lo em leilão, observando-se o disposto na Seção I deste Capítulo e, no que couber, o disposto nos arts. 879 a 903.

A petição inicial tem de expor os fatos e os fundamentos que autorizam a alienação judicial por jurisdição voluntária, discriminando em que reside o dissenso dos interessados. O pedido é o de alienação de bem singular ou de conjunto de bens específicos. É possível requerer expressamente a alienação por iniciativa particular ou diretamente o leilão judicial.

Além da causa de pedir e do pedido, tem o demandante que observar os demais requisitos do art. 319 do CPC/2015 naquilo em que for compatível. Segundo o dispositivo em referência, a inicial indicará: I) o juízo a que é dirigida; II) os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III) o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV) o pedido com as suas especificações; V) o valor da causa; VI) as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII) a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

O juízo competente será definido pelas regras gerais de competência previstas nos arts. 42 ao 53. O valor da causa deve corresponder ao proveito pretendido pelos interessados, geralmente estimado pelo valor do bem que se pretende alienar.

Embora as alienações judiciais aqui tratadas constituam procedimento de jurisdição voluntária e, como tais, não se insiram no conceito de processo (não há lide), é possível aos interessados produzirem todas as espécies de provas admitidas em direito. Como a causa de pedir reside em dissenso, nada impede que seja intentada conciliação ou mediação prévia em busca do consenso necessário ao melhor atendimento de todos os interesses envolvidos.

Importa destacar que, no caso das alienações incidentais, estas podem se dar nos autos do processo em curso ou em autos apartados, conforme for conveniente para o desenvolvimento regular da marcha processual. Logo, a petição inicial formalmente considerada pode ser prescindível, bastando que o requerimento alienatório seja feito por simples petição no feito em trâmite.

Sendo determinada de ofício, não há que se falar em petição inicial.

3.1.4 Citação e intimação

O art. 721 das disposições gerais dos procedimentos de jurisdição voluntária estabelece que serão citados todos os interessados, bem como intimado o Ministério Público, nos casos do art. 178, para que se manifestem, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Já o art. 722 dispõe que a Fazenda Pública será sempre ouvida nos casos em que tiver interesse.

Por outro lado, o art. 889, ao qual faz remissão o art. 730, traz regras específicas de cientificação dos interessados nas alienações judiciais. Dispõe que serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: 1) o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo (inc. I); 2) o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal (inc. II); 3) o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais (inc. III); 4) o proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre tais direitos reais (inc. IV); 5) o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução (inc. V); 6) o promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada (inc. VI); 7) o promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada (inc. VII); 8) a União, o Estado e o Município, no caso de alienação de bem tombado (VIII).

João Paulo Lucena defende que, não sendo determinada a alienação judicial por ato de ofício do magistrado, mas sim por requerimento de qualquer interessado (conforme rol exemplificado nos incisos do dispositivo acima transcrito), o juiz obrigatoriamente ordenará a citação dos demais cointeressados para que se manifestem nos autos sobre o pedido do requerente.⁵⁶¹ Aqui estão incluídos não somente as pessoas mencionadas na petição inicial, mas também terceiros que tenham interesse na alienação, o depositário, o Ministério Público e a Fazenda Pública.

A intimação das pessoas indicadas no art. 889, afirma Nelson Nery Jr., é necessária justamente porque têm direito sobre o bem que se pretende alienar em juízo.⁵⁶² Lendo-se “pedido de alienação” no lugar de “penhora” constata-se que mesmo na jurisdição voluntária essas pessoas “devem ter oportunidade de contrapor seu direito” ao suposto direito de alienação sustentado pelo requerente, sobretudo nos casos de crédito com privilégio ou preferência. “A alienação sem intimação dessas pessoas é nula”, conforme art. 804.

Se todos os interessados forem capazes, a venda do bem seguirá as condições por eles acordadas, desde que não incorram em ilicitude. Havendo incapazes, estes serão citados/intimados na pessoa de seus representantes legais, ouvido sempre o Ministério Público (art. 178, inc. II).⁵⁶³

Nos casos em que não for possível a citação pessoal dos cointeressados, essa poderá ser suprida pelo próprio edital de leilão, conforme inteligência do parágrafo único do art. 889 combinado com o art. 256, que disciplina as hipóteses em que é possível a citação por edital.

3.2 Contraditório na alienação

O art. 730 menciona a hipótese nas quais, não havendo acordo entre os interessados sobre o modo como o bem deve ser alienado, o juiz determinará a alienação da coisa e, embora a lei não mais preveja expressamente como fazia o § 2º do art. 1.113 do CPC/1973, impõe-se o contraditório no feito sob a forma de oitiva da outra ou outras partes.⁵⁶⁴ O contraditório deve se restringir à divergência em fazer ou não fazer a alienação e ao modo de se realizá-la.

Já foi dito que o contraditório poderá versar sobre a caracterização do bem como sendo passível de alienação judicial incidental e sobre a oportunidade e conveniência da alienação.⁵⁶⁵ De igual modo, viu-

se que a alienação em juízo pode ser requerida por qualquer interessado, mas todos os demais devem ser citados para que se manifestem quanto à necessidade de alienação e seu modo de ser. Assim, aquele que se opuser à forma de alienação sugerida ou à própria pretensão alienatória deve fundamentar seu pedido, fazendo prova de suas alegações.⁵⁶⁶

Desse modo, deve ser possibilitada, caso relevante, a oitiva de testemunhas ou mesmo a realização de perícia, conduzindo-se todo procedimento com amplo respeito ao contraditório e ao direito de participação na formação da decisão. Ao fim, o juiz há de decidir com base no permissivo normativo da alienação judicial, sempre observando qual das soluções é mais eficiente para a tutela do interesse protegido nos autos, inclusive mediante juízo ponderativo se for o caso.⁵⁶⁷

A relevância do contraditório está principalmente na defesa dos interesses de terceiros considerados relevantes, sobretudo se incapazes, bem assim na prevenção de ilicitudes, tais como as já exemplificadas em linhas anteriores.

3.3 Alienação e interesses de terceiros

Tendo em vista que sobre um mesmo bem podem recair inúmeros interesses, sendo a alienação iniciada por provocação de um interessado todos os demais terão direito de se manifestar nos autos. É possível, no entanto, que mesmo com as devidas cautelas algum deles seja preterido em seu direito de petição. Por isso hão de se comunicar com o regramento posto nos arts. 879 a 903 outros dispositivos do CPC/2015.

Não por menos o legislador previu casos de ineficácia da alienação em relação a terceiros titulares de direitos reais sobre o objeto alienado, dentre outras preferências e privilégios. Assim diz o *caput* do art. 804 que a alienação de bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese será ineficaz em relação ao credor pignoratício, hipotecário ou anticrético não intimado. Também o será: a) a alienação de bem objeto de promessa de compra e venda ou de cessão registrada em relação ao promitente comprador ou ao cessionário não intimado (§ 1.º); b) a alienação de bem sobre o qual tenha sido instituído direito de superfície, seja do solo, da plantação ou da construção, em relação ao concedente ou ao concessionário não intimado (§ 2.º); c) a alienação de direito aquisitivo de bem objeto de promessa de venda, de promessa de cessão ou de alienação fiduciária em relação ao promitente vendedor, ao promitente cedente ou ao proprietário fiduciário não intimado (§ 3.º); d) a alienação de imóvel sobre o qual tenha sido instituída enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso em relação ao enfiteuta ou ao concessionário não intimado (§ 4.º); e) a alienação de direitos do enfiteuta, do concessionário de direito real de uso ou do concessionário de uso especial para fins de moradia em relação ao proprietário do respectivo imóvel não intimado (§ 5.º); f) a alienação de bem sobre o qual tenha sido instituído usufruto, uso ou habitação em relação ao titular desses direitos reais não intimado (§ 6.º).

No caso dos bens indivisíveis, o coproprietário ou cônjuge não intimado da alienação terá direito ao recebimento de sua quota-parte, a qual recairá sobre o valor apurado com a venda da coisa em juízo (art. 843).

Aqui são perfeitamente oponíveis embargos de terceiro. Conforme art. 674 do CPC/2015, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo (ou, no caso aqui tratado, meramente alienatório), poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Sobre o cabimento dessa impugnação nas alienações judiciais em jurisdição voluntária, entende Rodolfo da Costa Manso Real Amadeo que os atos de constrição judicial que dão ensejo à oposição dos embargos de terceiro podem “ser provenientes tanto de procedimentos de jurisdição contenciosa quanto de jurisdição voluntária, como na alienação judicial (CPC/2015, art. 730)”.⁵⁶⁸

O procedimento dos embargos de terceiro é aquele disciplinado nos arts. 675 a 681 do novo código.

3.4 Alienação e legitimidade passiva

A alienação judicial poderá e deverá ser proposta em face de toda e qualquer pessoa que tenha interesse legítimo sobre o bem ou em cuja esfera jurídica a medida vindicada possa ter reflexos diretos, conforme já amplamente esclarecido neste trabalho.

Mesmo que no curso do procedimento qualquer dos interessados consiga, de algum modo, alienar o bem a título particular, a legitimidade do requerente e do requerido na relação jurídica processual restará incólume. Descabida, portanto, sucessão processual sem o consentimento do cointeressado, conforme art. 109.⁵⁶⁹

Contudo, admite-se a intervenção do adquirente ou cessionário como assistente litisconsorcial, mas, intervindo ou não no procedimento, a ele estende-se os efeitos da sentença proferida entre o requerente e requerido originário.

Ao tratar da legitimidade passiva, não se pode perder de vista que as alienações judiciais aqui tratadas constituem procedimento de jurisdição voluntária. A distinção que se pretende fazer neste tópico é meramente didática, porquanto inexistindo conflito de interesses não há que se falar em partes, mas apenas em interessados, assim compreendidos aquele que leva a pretensão alienatória a juízo e aquele deve ser intimado dessa demanda por ter interesse direto sobre o bem.

Em outros termos, diz-se que não se polariza o procedimento, porquanto todos caminham pacífica e harmoniosamente para um fim comum sem lide: a alienação.

3.5 Avaliação

Para que o preço mínimo do bem objeto da alienação possa ser fixado pelo juiz (art. 885),⁵⁷⁰ será realizada avaliação por oficial de justiça ou, se for o caso, avaliador nomeado. Consiste no cálculo do valor da coisa a ser alienada.

Pontes de Miranda considerou a avaliação pressuposto necessário à alienação, porquanto foi sempre exigida como base para venda, salvo os casos em que foi dispensada pelo legislador.⁵⁷¹

Para João Paulo Lucena, enquanto a avaliação é procedimento indispensável nos processos de alienação judicial, sob pena de nulidade, há quem a considere despesa eventualmente onerosa e desnecessária nos procedimentos de jurisdição voluntária entre pessoas capazes, quanto então deixaria de ser imperativa, isso em face do art. 1.109 do CPC/1973, que desobriga o juiz de seguir o critério da legalidade estrita.⁵⁷²

Essa regra foi repetida no parágrafo único do art. 723 do CPC/2015: “O juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna”.

3.5.1 Avaliação e bens em geral

As regras gerais da avaliação de bens estão previstas nos arts. 870 a 875, que tratam da execução por quantia certa. A despeito da falta de remissão expressa a esses dispositivos no art. 730, tem-se que sua aplicação às alienações judiciais em jurisdição voluntária é plenamente admissível e necessária.

Com base nessa nova disciplina e como bem considerou José Olympio de Castro Filho ainda quando analisava o regramento posto no CPC/1973, “nem sempre será de se fazer avaliação”.⁵⁷³ Não será realizada quando: a) um interessado aceitar a estimativa feita por outro; b) se tratar de títulos ou de mercadorias que tenham cotação em bolsa, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial; c) se tratar de títulos da dívida pública, de ações de sociedades e de títulos de crédito negociáveis em bolsa, cujo valor será o da cotação oficial do dia, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial; d) se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a cotação de mercado (art. 871). Embora os interessados tenham consenso quanto à estimativa feita por qualquer deles, a avaliação poderá ser realizada quando houver fundada dúvida do juiz quanto ao real valor do bem (art. 871, parágrafo único).

Títulos e mercadorias com cotação em bolsa não exigem parecer técnico porque seu valor “só pode ser o que resulta daquele meio prático e oficializado de se venderem tais bens”, o qual virá aos autos “mediante fácil decisão”.⁵⁷⁴

É admitida nova avaliação quando: a) qualquer interessado arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo do avaliador; b) se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou

diminuição no valor do bem; c) o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação (art. 873).

Tecendo uma comparação elucidativa com a lei processual anterior, valiosas as observações feitas por Edson Prata em análise ao art. 1.114 do CPC/1973. Explica o processualista que a avaliação seria realizada somente em duas hipóteses, são elas, quando o bem não tivesse sido avaliado anteriormente ou quando tivesse sofrido alteração em seu valor inicialmente apurado. Observou ainda que a avaliação só seria repetida em caso de erro ou dolo do avaliador ou se constatada posterior diminuição do valor dos bens.⁵⁷⁵

Tanto para a avaliação inicial quanto para a nova avaliação nos casos em que permitida pela lei, será possível e comumente necessária a produção de prova, sobretudo técnica, para se apurar, por exemplo, que o bem sofreu majoração ou diminuição em seu valor. Assim diz Alcides Mendonça de Lima que há necessidade de prova para que o juiz possa atender ao pedido de nova avaliação, que poderá ser documental, testemunhal ou pericial.⁵⁷⁶

Consta do art. 872 que a avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: 1) os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram (inc. I) e; 2) o valor dos bens (inc. II).

Assim como no CPC/2015, também no CPC/1973 a avaliação somente era determinada após a oitiva dos interessados, a qual deveria ser procedida por avaliador ou, na falta desse, por perito de confiança do juízo. Avaliado o bem, o avaliador/perito deveria apresentar laudo contendo a descrição, as características, estado e valor de venda da coisa a ser alienada.⁵⁷⁷

3.5.2 Avaliação e bens de incapazes

Tratando-se de bens de incapazes, a precisão do preço apurado na avaliação é ainda mais relevante. É que a lei determina um percentual mínimo a ser alcançado pela alienação. Não sendo atingido esse patamar (80% do valor da avaliação), haverá o adiamento do leilão, ficando o bem sob a guarda e administração de depositário por até um ano (art. 896).⁵⁷⁸

Para Nelson Nery Junior a regra desse artigo é providência de favor aos incapazes, consistente em verdadeira moratória. “A norma vem em resguardo do interesse dos incapazes, visto que não podem opinar a respeito da venda por valor inferior ao de 80% da avaliação, vedando mesmo posicionamento do representante legal a esse respeito”. Por outro lado, sustenta que a flutuação do mercado imobiliário deve ser sempre lavada em consideração nesses casos, já que uma tendência de queda de preços pode tornar o adiamento prejudicial.⁵⁷⁹

Durante o prazo de adiamento do leilão, algum pretendente à arrematação assegurar o preço da avaliação por caução idônea, o juiz ordenará a alienação em leilão. No entanto, se o pretendente se arrepender, terá de arcar com o pagamento de multa em favor do incapaz no montante de 20% sobre o valor da avaliação. A multa será aplicada por decisão fundamentada, que valerá de título executivo.

Visando garantir o proveito útil do imóvel, pode o juiz autorizar sua locação no prazo do adiamento. Decorrido o prazo de suspensão, será intentado novo leilão.

Aqui surge um questionamento relevante: e se o novo leilão também não atingir o preço mínimo? Em resposta, pondera que diante do esforço da lei em proteger o incapaz, as mesmas regras deverão ser observadas novamente, mas a falta de uma diretriz legal faz com que haja o risco de que se prolongue indefinidamente o depósito do bem.⁵⁸⁰

Tendo havido o pagamento de caução, mas não o pagamento do preço no prazo estipulado, haverá a perda da garantia em favor do incapaz, voltando o bem a novo leilão, do qual não poderão participar nem o arrematante faltoso, nem seu fiador (art. 897).⁵⁸¹ Por outro lado, sendo o arrematante remisso, pode o fiador que pagar o lance e a multa requerer para si a arrematação (art. 898).⁵⁸²

3.6 Publicidade

José Olympio de Castro Filho defende que a publicidade na alienação judicial constitui medida indispensável para a seriedade da venda.⁵⁸³ É pressuposto para o atingimento do maior número possível

de potenciais arrematantes e instrumento eficaz para se atingir o melhor preço possível.

Os requisitos do edital do leilão estão previstos no art. 886 e podem ser assim enumerados: 1) a descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros (inc. I); 2) o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado (inc. II); 3) o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes e, tratando-se de créditos ou direitos, a identificação dos autos do processo em que foram penhorados (inc. III); 4) o sítio, na rede mundial de computadores, e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização (inc. IV); 5) a indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro (inc. V); 6) menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados (inc. VI); 7) o valor da última cotação no caso de títulos da dívida pública e de títulos negociados em bolsa (parágrafo único).

Além disso, o art. 887 impõe ao leiloeiro público designado o dever de adotar providências para a ampla divulgação da alienação, devendo o edital ser publicado pelo menos cinco dias antes do leilão (§ 1.º), na rede mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou presencial (§ 2.º). Somente se não for possível a publicação na rede mundial de computadores ou considerando o juiz, em atenção às condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local (§ 3.º).

É possível ao juiz alterar a forma e a frequência da publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de ampla circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou televisão local, bem como em sítios distintos, atendendo ao valor dos bens e às condições da sede do juízo (§ 4.º). No caso de leilão de imóveis e automóveis os editais serão publicados pela imprensa ou por outros meios de divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à publicidade dos respectivos negócios (§ 5.º), podendo as publicações serem feitas em listas referentes a mais de um procedimento análogo (§ 6.º).

Aqui estão os requisitos materiais e formais imprescindíveis para que o edital seja adequadamente publicado. Todas essas informações deverão constar expressa e precisamente do instrumento convocatório da alienação, sob pena de decretação de nulidade. Sem qualquer desses dados o sucesso do leilão e a lisura do procedimento podem ser prejudicados.

É que sem informação clara e precisa dificilmente se obterá arrematantes dispostos à compra do bem. Daí poderão decorrer uma série de prejuízos aos interessados.

Ainda assim aplica-se o princípio o princípio *pas de nullité sans grief*, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, citando precedente do Superior Tribunal de Justiça, entende que “a ausência de qualquer desses requisitos não invalida, por si só, o edital e a eventual arrematação em leilão público. Nesse caso é imprescindível para a decretação de nulidade a demonstração de efetivo prejuízo para os fins de justiça do processo oriundo dessa omissão (STJ, 2.a Turma, REsp 520.039/RS, rel. Min. Eliana Calmon, j. 21.09.2004, DJ 29.11.2004, p. 281)”. ⁵⁸⁴

Cabe ao juiz definir, conforme as circunstâncias do caso, a forma e a frequência da publicidade, ordenando a publicação de edital onde e quando considerar necessário ao atingimento de seu fim.

Como dito, ao ato de transferência deve ser dada ampla publicidade, com observância dos requisitos estabelecidos no art. 887. “A divulgação desse adiamento deve observar as mesmas cautelas naturais à publicação do edital originário.” ⁵⁸⁵

3.7 Melhor oferta (maior lance), vedações, lance vil, formas de pagamento

Aqui o exame da pertinência e aplicabilidade de cada dispositivo requer maior atenção, de modo a não transpor para estas alienações não executivas os rigores intrínsecos à expropriação de bens.

Na alienação judicial, em regra, aquele que fizer a melhor oferta levará o bem. Por melhor oferta entenda-se, *prima facie*, o maior lance ofertado. Segundo Pontes de Miranda, a regra que rege as alienações ao público é o princípio “a quem der mais”. Sempre que há estimativa de preço toma-se esta por base. ⁵⁸⁶

Edson Prata, no mesmo sentido, sustenta que, avaliado o bem, determina o juiz a sua venda em leilão público a quem der mais. ⁵⁸⁷

Sobre esse ponto, José Olympio de Castro Filho entende que a arrematação pelo maior lance oferecido, ainda que inferior ao valor da avaliação, é da índole da hasta pública, ressalvados os casos dos bens de incapazes. ⁵⁸⁸

Na jurisdição voluntária, “a alienação do bem pode ser feita por preço abaixo da avaliação, o que não sucede na arrematação em execução ou cumprimento de sentença, pois, se não houver lance que não cubra o valor da avaliação, o juiz ordenará que sejam leiloados os bens”. ⁵⁸⁹

Entretanto, outras variantes não de ser observadas para a venda do bem e escolha do arrematante mais apto. É preciso analisar se o pretendente incide em algumas das vedações legais que lhe impedem de arrematar a coisa, se apesar de ofertar o melhor lance sua proposta é vil e quais suas possibilidades de pagamento.

3.7.1 Vedações ao oferecimento de lance

A regra geral é a de que todo aquele que estiver na livre administração de seus bens pode lançar na alienação judicial. Porém, na tentativa de defender interesses considerados relevantes, a lei estabelece algumas vedações *ad cautelam* para o oferecimento de lance.

Trata-se de restrições que definem quem pode e quem não pode adquirir o bem objeto da alienação. Decorrem do flagrante conflito de interesses resultante da função exercida no procedimento.

Desse modo, diz o art. 890 que somente aqueles que estiverem na livre administração de seus bens podem lançar, com exceção das seguintes pessoas: 1) dos tutores, dos curadores, dos testamenteiros, dos administradores ou dos liquidantes, quanto aos bens confiados à sua guarda e à sua responsabilidade (inc. I); 2) dos mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação estejam encarregados (inc. II); 3) do juiz, do membro do Ministério Público e da Defensoria Pública, do escrivão, do chefe de secretaria e dos demais servidores e auxiliares da justiça, em relação aos bens e direitos objeto de alienação na localidade onde servirem ou a que se estender a sua autoridade (inc. III); 4) dos servidores públicos em geral, quanto aos bens ou aos direitos da pessoa jurídica a que servirem ou que estejam sob sua administração direta ou indireta (inc. IV); 5) dos leiloeiros e seus prepostos, quanto aos bens de cuja venda estejam encarregados (inc. V); 6) dos advogados de qualquer das partes (inc. VI).

Sobre cada um desses incisos Nelson Nery Junior tece valiosas considerações, adiante aduzidas. Explica que as pessoas indicadas nos incs. I e II naturalmente sacrificam seus próprios interesses em prol de outrem, motivo pelo qual tem interesse em vender o bem confiado à sua guarda por um bom preço, o que é incompatível com o interesse do licitante de “comprar barato”. Aqueles indicados no inc. III e IV podem se aproveitar de sua condição privilegiada para manipular o leilão, estando assim proibidos de arrematar em razão do *múnus* público que exercem. Já os leiloeiros e seus prepostos, enquanto auxiliares da justiça responsáveis pela condução da hasta pública, são os que mais facilidades teriam para manipular o leilão. ⁵⁹⁰

Por fim, no caso do inc. VI, é de se adotar interpretação mais cautelosa. Nelson Nery Junior explica que o antigo Código de Ética Profissional da OAB continha proibição expressa à aquisição de bem penhorado em processo no qual o advogado interviesse. Embora os atuais Estatuto e Código de Ética da OAB não contenham mais essa vedação, o CPC/2015 reafirmou a necessidade de independência no exercício da advocacia, a qual poderia ser prejudicada em razão do interesse na aquisição do bem que se pretende alienar na causa que patrocina, isso sem falar que por ser o patrono da demanda pode possuir informações privilegiadas que lhe privilegiem em face de outros interessados. ⁵⁹¹

3.7.2 Lance vil

Sobre os limites ao preço praticado na alienação, impôs o legislador patamares mínimos para a venda do bem. Por isso diz o art. 891 que não será aceito lance que ofereça preço vil, assim considerada oferta de montante inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital. Não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.

Note-se aqui que a falta de fixação de preço mínimo não torna nulo o procedimento de alienação ou a arrematação, nem impõe o adiamento do leilão. Nesse sentido Parte da doutrina bem destaca o

Enunciado 193 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis, que diz: “Não justifica o adiamento do leilão, nem é causa de nulidade da arrematação, a falta de fixação de preço mínimo para a arrematação”.⁵⁹²

Esse dispositivo se aplica ao caso dos bens de pessoas capazes, cuja regra geral é a de que compete ao juiz fixar o preço mínimo pelo qual o bem poderá ser alienado. Somente na falta de estipulação desse valor é que se tomará por base a metade do montante indicado na avaliação.

Para Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, fora essas regras não existem outros critérios legais específicos para a aferição do que pode ser considerado preço vil. Por isso cabe ao juiz fixá-lo, atendendo às circunstâncias do caso concreto.⁵⁹³

Nelson Nery Junior questiona acerca da possibilidade de o preço vil decorrer justamente do valor fixado pelo magistrado, vez que pode eventual interessado oferecer valor irrisório também nessa hipótese. Assim sugere que nessas situações, por analogia, se tome o percentual de cinquenta por cento como ponto de partida, desta vez incidente sobre o preço fixado pelo juiz. Logo, o legislador “ao eliminar um conceito indeterminado” com a nova lei, “acabou por criar outro”.⁵⁹⁴

No entanto, a despeito desse entendimento, ao dizer que “não será aceito preço vil” e que “considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital” a lei parece clara no sentido de que é inadmissível lance abaixo do montante arbitrado para a alienação. Logo, não há de se cogitar proposta de adquirente em percentual menor que cem por cento do preço fixado pelo juiz, esse sim passível de definição em valor menor que o da avaliação, sendo esta o parâmetro de análise e livre convencimento motivado do julgador.

Analisando a jurisprudência sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero observam que não há um consenso sobre o que é, de fato, preço vil, havendo julgados do STJ anteriores à vigência do CPC/2015 que não admitem lance inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação atualizado (1.a Turma), enquanto outros precedentes da mesma Corte fixam esse patamar mínimo em vinte e cinco por cento da avaliação (2.a Turma) ou ainda em 20% (3.a Turma). Há também entendimento no sentido de que a análise há de ser casuística, levando-se sempre em consideração as condições específicas de cada caso, que podem sugerir, por exemplo, a razoabilidade de alienação por preço inferior à metade da avaliação (4.a Turma).⁵⁹⁵

No caso de bens de incapazes, o art. 896 estabelece que a venda não será realizada se o lance não atingir pelo menos oitenta por cento do valor da avaliação. Se a proposta for a baixo desse limite, o leilão será adiado por até um ano.

Tratando-se ou não de bens de capazes, fato é que cabe ação anulatória contra a alienação procedida por preço vil, objetivando a desconstituição da arrematação.

3.7.3 Pagamento e suas formas

O art. 892 prevê que o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico. Trata-se de regra geral a ser observada apenas na falta de fixação de prazo e modo distinto pelo juiz.

Para Nelson Nery Jr., o legislador agiu com acerto ao incluir nesse artigo a possibilidade de pagamento eletrônico, pois assim é possível garantir o adimplemento de forma mais segura.⁵⁹⁶

Não se vislumbra a aplicabilidade do § 1.º desse dispositivo nas alienações judiciais em jurisdição voluntária, porque específico e restrito ao processo executivo. Referido parágrafo trata da arrematação pelo exequente do bem objeto da constrição judicial e do depósito em juízo do valor que exceder o crédito do qual é titular. Sua inaplicabilidade decorre do fato de que não se discute no caso do procedimento especial em exame relação de crédito e débito, nem se trata de expropriação forçada, daí sua incompatibilidade fática e jurídica para a técnica processual ora apreciada.

Nada impede, porém, que no curso da alienação um dos interessados, nos casos de bem comum, por exemplo, queira para si o bem integralmente. Nesse caso, o interessado poderá arrematar o bem pelo preço definido em juízo, mas sempre tendo em mente que parte do valor do bem já era propriedade do arrematante.

Aplica-se, por outro lado, a regra do § 2.º, segundo a qual havendo mais de um pretendente à arrematação entre eles será procedida licitação e, no caso de igualdade de oferta, terá preferência o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente do executado, nessa ordem. A compatibilidade do dispositivo com as alienações judiciais não constritivas é evidente, na medida em que é perfeitamente viável que aqui também ocorra pluralidade de interessados na aquisição da coisa, pelo que a competição entre eles deve ser realizada com o fim de atingir o melhor aproveitamento econômico do bem (melhor preço), devendo a preferência ser garantida em relação a pessoas vinculadas aos interessados (requerente ou requerido).

Também incide a regra do § 3.º, pelo que sendo tombado o patrimônio terão preferência na arrematação, em igualdade de oferta, a União, os Estados e os Municípios, nesta ordem.

O art. 893 fixa critérios de prelação na hipótese de pluralidade de bens em cuja alienação tem interesse mais de um pretendente. Nesse caso, terá preferência aquele que se propuser a arrematar todo o conjunto patrimonial ofertado, oferecendo para os bens que não tiverem lance preço igual ao da avaliação e, para os demais, preço ao menos idêntico ao do maior lance que, na tentativa de arrematação individualizada, tenha sido oferecido para eles.

Relativamente ao bem imóvel que admite divisão cômoda, diz o art. 894 que, a requerimento do interessado, o juiz ordenará alienação judicial de parte dele. Na jurisdição voluntária os interessados podem perfeitamente pretender que a coisa seja alienada apenas em parte, não para satisfação de exequente ou pagamento das despesas da execução (não é feito contencioso), mas porque assim quiseram e desde que suficientes para o adimplemento das custas do procedimento.

Para os fins desse artigo considera-se cômoda a divisão do imóvel que não lhe compromete a substância, valor ou finalidade. Dizem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero que bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destina.⁵⁹⁷ Note-se que o jurista qualifica a redução do valor do bem dizendo que deve ser “considerável” para que a divisão seja reputada incômoda. Isso porque alguma diminuição do valor originário sempre ocorrerá, já que o fracionamento pressupõe necessariamente a redução do tamanho original do imóvel objeto de alienação judicial.

De qualquer modo, a alienação por partes deve ser requerida a tempo de permitir a avaliação das glebas destacadas e sua inclusão no edital do leilão, cabendo ao interessado instruir o requerimento de divisão cômoda com “planta e memorial descritivo subscritos por profissional habilitado” (§ 2.º).

Caso não haja pretendentes à aquisição de parte do imóvel (em cômoda divisão), a alienação do bem deverá ser realizada em sua integralidade (§ 1.º).

Sobre a possibilidade de parcelamento, o art. 895 preceitua que o interessado pode adquirir o bem objeto da alienação em prestações, mas para tanto deverá apresentar por escrito, até o primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação (inc. I) ou, até o início do segundo leilão, preço que não seja considerado vil (inc. II). Tais propostas serão oferecidas sem que a hasta pública precise ser suspensa (§ 6.º).

Diz-se dois leilões ante a possibilidade de o primeiro ser infrutífero pela ausência de interessados (art. 886, inc. V) ou por não ter sido realizado por qualquer motivo (art. 888), a justificar a realização de um segundo.

O § 1.º do art. 895 estabelece os requisitos da proposta de parcelamento, que deverá conter oferta de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 meses, mediante caução idônea, no caso de bens móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. Além disso, deverão indicar o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo (§ 2.º).

Bem observa Nelson Nery Jr., sob o enfoque do processo executivo, que apesar desse permissivo legal o pagamento à vista terá sempre preferência sobre as propostas de adimplemento parcelado, independentemente do valor oferecido, porquanto a quitação imediata satisfará desde logo a dívida.⁵⁹⁸ Esse entendimento se respalda em disposição expressa do art. 895, § 7.º, do CPC/2015.

No caso da jurisdição voluntária, repita-se, não se discute pagamento de dívida a justificar a alienação, razão pela qual há de se dar maior liberdade aos postulantes para aceitar uma ou outra

proposta. Desse modo, afigura-se razoável que essa preferência seja exercida pelo juiz apenas na falta de consenso dos interessados.

Esse mesmo jurista esclarece, ademais, que o art. 895 foi vetado, em seu § 3.º, porque instituiu a correção monetária mensal por um índice oficial de preços, o que caracterizou indexação. Conforme respectiva mensagem de veto, sua sanção potencializaria a “memória inflacionária, culminando em uma indesejada inflação inercial”.

Tendo sido autorizado o pagamento parcelado, em havendo atraso na incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas (§ 4.º). Ademais, o inadimplemento permite que os interessados intentem a resolução da arrematação ou promovam em face do arrematante a execução do valor devido, o que se dará nos autos do procedimento em que se deu a alienação.

Nesse caso, como certamente surgirá conflito de interesses (litígio) entre os interessados e o arrematante, o feito se convolará em procedimento de jurisdição contenciosa. Finda a execução do débito (atraso das parcelas), poderão ser interpostos os recursos cabíveis no processo executivo. Por outro lado, em se optando pela resolução da arrematação, ainda que assim surja litígio, resolvida a alienação poderá ser intentado novo leilão nos mesmos autos, se for o caso.

Ressalte-se, todavia, que o “valor devido” imputável ao adquirente diz respeito, obviamente, ao atraso do parcelamento acrescido das prestações subsequentes, se consideradas vencidas antecipadamente. Assim explica Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero que “esse montante corresponderá, por óbvio, não apenas ao montante da parcela não paga, mas, pelo vencimento antecipado de todas as demais, ao total das prestações remanescentes”. Contudo, acertadamente entende que havendo caso fortuito ou força maior para o não pagamento da parcela, bem assim qualquer outra causa não imputável ao arrematante, “não ocorrem os efeitos da mora, e o parcelamento deve ser mantido (art. 396, CC)”.⁵⁹⁹

Existindo mais de uma proposta de pagamento parcelado, a ordem de preferência dependerá das condições em que cada uma tiver sido formulada (§ 8.º). Caso oferecidas em diferentes condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida sempre a de maior valor (inc. I). Em igualdade de condições, o juiz escolherá a formulada em primeiro lugar (inc. II).

Não se aplica à técnica processual aqui tratada o disposto no § 9.º, pois como já dito reiteradamente, não se está diante de debate sobre relação creditícia.⁶⁰⁰ Como a autoridade julgadora não exerce juízo de valor acerca da conveniência da medida pretendida, nem sobre a parcela de direitos que cada interessado possui sobre a coisa alienada, não se pode preferir que os pagamentos feitos nas hipóteses de parcelamento sejam entregues preferencialmente ao requerente. Afinal, como se verá adiante, o produto da alienação se sub-rogará no lugar do bem alienado.

3.8 Atraso no levantamento e depósito

Dispunha o *caput* do art. 1.116 do CPC/1973 que uma vez efetuada a alienação da coisa e deduzidas as despesas do procedimento, o preço seria depositado, ficando nele sub-rogados os ônus ou responsabilidades a que estiverem sujeitos os bens alienados. O parágrafo único do mesmo artigo previa que, não sendo o caso de levantamento do preço depositado antes de 30 dias, o juiz determinaria a aplicação do produto da alienação ou do depósito em obrigações ou títulos da dívida pública da União ou do Estado.

Tratava-se, portanto, de sub-rogação legal e de natureza real (substituição de uma coisa por outra), em que todos os encargos do bem alienado eram transferidos ao produto da alienação, de forma que o bem arrematado ficava livre de todo e qualquer ônus, livre e desembaraçado.⁶⁰¹

Para Alcides de Mendonça Lima, em análise ao revogado art. 1.116, o preço não poderia ser utilizado livremente pelo dono da coisa, pois, se assim fosse, seria inútil a necessidade da autorização/alienação judicial. Assim, a intervenção do juiz estaria a revelar a necessidade de ser controlado o destino do preço alcançado. Tratava-se, portanto, de restrição expressa ao exercício do direito de propriedade, no sentido do aproveitamento do preço obtido com a alienação.⁶⁰²

Edson Prata sustentou que o depósito do montante arrecadado tinha função apenas cautelar, objetivando evitar a perda ou o desvio do produto da alienação. Assim, nenhum ato a mais seria preciso para que a sub-rogação acontecesse.⁶⁰³

Sobre a aplicação dos recursos, Pontes de Miranda pontuou que “com isso se evitam os males dos depósitos sem juros e da desvalorização monetária”.⁶⁰⁴ Ocorre que o CPC/2015 não repetiu a regra do art. 1.116 da lei revogada. Não há previsão específica de sub-rogação do preço para alienação judicial em jurisdição voluntária, nem prazo para levantamento, nem autorização legal expressa para aplicação em títulos.

Contudo, nada impede que o juiz, valendo-se do seu poder geral de cautela, determine de ofício ou por requerimento de interessado ou do Ministério Público a prática de medidas conservativas do produto da arrematação quando as circunstâncias assim exigirem, sobretudo nos casos de alienação judicial *ex officio* e, em especial, quando se tratar de interesse de incapaz.

Ademais, aqui não se afasta a ocorrência de sub-rogação. Diga-se mais uma vez que, embora o art. 730 remeta o aplicado do direito apenas aos arts. 879 a 903, não se pode afastar a necessidade de diálogo entre tais artigos e outros dispositivos do CPC/2015. Assim, afigura-se perfeitamente aplicável também nas alienações judiciais o disposto no § 1o do art. 908 da lei vigente, pelo qual, no caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza *propter rem*, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. Logo, os produtos da arrematação devem sim ser considerado sub-rogado no lugar do bem alienado.

3.9 Arrematação e paralisação do procedimento

O art. 899 do CPC/2015 preceitua que será suspensa a arrematação logo que o produto da alienação dos bens for suficiente para o pagamento do credor e para a satisfação das despesas da execução. Referida norma não tem aplicabilidade para as alienações judiciais em jurisdição voluntária, ante a ausência de debate acerca da satisfação de crédito. Assim, sendo lícito o fim pretendido pelos interessados e possível a alienação nesses termos, feita a arrematação e cumpridas as cautelas legais, aperfeiçoado está o procedimento.

Na hipótese de o leilão ultrapassar o expediente forense, a ele será dada continuidade no dia útil subsequente, à mesma hora em que teve início no dia anterior, independentemente de novo edital. Sobre essa disposição contida no art. 900, Nelson Nery Junior argumenta que o leilão nem sempre acontece no edifício do fórum. Logo, caso ocorra em ambiente externo, mais razoável que se admita a prática de atos processuais no período que vai das seis às vinte horas.⁶⁰⁵

Sendo frutífero o leilão, será imediatamente lavrado auto de arrematação, nele mencionadas as condições em que o bem foi alienado (art. 901, *caput*). Arrematada a coisa, efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, paga a comissão do leiloeiro e as despesas do procedimento, será expedida ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse (§ 1o).

Conforme o § 2o daquele mesmo artigo, a carta de arrematação conterá necessariamente a descrição do imóvel, “com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame”. Como visto, nem a carta de alienação e nem o mandado de entrega transferem o domínio do bem alienado, servindo apenas de título de aquisição. A carta somada à aquisição possibilita transferência (arts. 1.227 e 1.245 do CC/2002); o mandado autoriza a posse do imóvel pelo adquirente com justo título e a partir dele se dá a tradição (art. 1.226 do CC/2002).⁶⁰⁶

No caso de bem hipotecado, o código traz peculiaridade a ser observada com atenção. Nessa hipótese, diz o art. 902, que o executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de arrematação, oferecendo preço igual ao do maior lance oferecido. No caso de falência ou insolvência do devedor hipotecário, o direito de remição defere-se à massa ou aos credores em concurso, não podendo o exequente recusar o preço da avaliação do imóvel.⁶⁰⁷ Trata-se aqui, como bem observa Nelson Nery Jr., do instituto da remição enquanto pagamento, não da remissão que consubstancia perdão de dívida.⁶⁰⁸

Mesmo não se estando em debate processo de execução, mas de alienação judicial em jurisdição voluntária, pode o interessado ver-se diante de situação em que poderá optar por remir a hipoteca, pagando ou consignando a importância garantida. É o caso, por exemplo, em que o requerente pretende a alienação de bem gravado com a garantia real e o credor hipotecário, ciente da alienação judicial, ingressa nos autos da demanda impugnando o pedido alienatório. Pode o interessado optar pela remição imediata da hipoteca, liberando o bem do gravame, para então poder aliená-lo livremente.

Quanto ao instrumento processual hábil à paralização da arrematação, tem-se que não há mais que se falar em embargos à arrematação.⁶⁰⁹ Sustenta Frederico Fontoura da Silva Cais que § 1º do art. 903⁶¹⁰ especifica de maneira clara as hipóteses de invalidade (preço vil ou outro vício), ineficácia (se não intimado o credor pignoratício, hipotecário ou anticrético – art. 804) e resolução (não pagamento do preço ou não for prestada caução) da arrematação, sendo uma das grandes inovações do CPC/2015, por meio deste dispositivo legal, a criação de um meio mais célere e simplificado de impugnação.⁶¹¹

Também Nelson Nery Junior afirma que o CPC/2015 pôs fim a tais embargos, “os quais eram decididos à parte e só podiam ser opostos antes da assinatura do auto”. Sob o novo regramento, “se constatado algum dos vícios descritos no § 1.º, o interessado pode alegá-lo por meio de petição simples, desde que não tenha sido expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega do imóvel”.⁶¹²

É que a impugnação em comento “deve ser feita por simples petição nos autos em até 10 (dez) dias do aperfeiçoamento da arrematação (§ 2.º)”. Findo esse prazo será expedida a carta de arrematação e, se for o caso, a ordem de entrega ou o mandado de imissão na posse, pelo que eventuais irresignações supervenientes somente poderão ser veiculadas em ação autônoma, “por meio da qual o arrematante deverá figurar como litisconsorte necessário (§ 4.º)”. Desse modo, “acabam os embargos à arrematação previstos no art. 746 do CPC/1973”.⁶¹³

Pode o arrematante, todavia, desistir da compra, fazendo jus à devolução imediata do depósito que houver realizado se: 1) provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; 2) antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, qualquer interessado alegar causa de invalidade, ineficácia ou resolução da arrematação; 3) uma vez citado para responder a ação autônoma proposta para invalidação da arrematação, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação. São mecanismos elegidos pelo legislador para resguardar direitos do arrematante de boa-fé e preservá-lo de abusos dos interessados na alienação do bem.

Não por menos o § 6º do mesmo artigo considera que comete ato atentatório contra à dignidade da justiça quem suscita de maneira infundada vício com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante, devendo o suscitante ser condenado, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, ao pagamento de multa, a ser fixada pelo juiz e devida não ao exequente (já que não se trata de execução), mas ao cointeressado alienante (não responsável pelo ato ilícito), em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do bem.

Seção IV

Do divórcio e da separação consensuais, da extinção consensual de união estável e da alteração do regime de bens do matrimônio

1. Inovações do CPC/2015

Inova a Seção IV ao incluir duas modalidades não previstas anteriormente no CPC/1973, alterado pela Lei do Divórcio, Lei 6.515/1977 (arts. 34, 39 e 40, § 2.º), enquanto procedimentos especiais voluntários ou consensuais de família: são novas a extinção consensual de união estável e a alteração do regime de bens do matrimônio ao lado das antes existentes, a separação consensual e o divórcio consensual.

A partir de agora se pode dizer que a Seção inclui quatro ações bem distintas: a) a *ação de alteração do regime de bens do casamento*, desde 2002 realizada pelo procedimento comum; b) duas ações que tratam de dissolução do casamento ou união estável: b1) a *ação de divórcio consensual*; b2) a *ação de extinção consensual de união estável*; e c) a *ação de separação consensual*. Três dessas modalidades possuem alternativa extrajudicial, de largo uso, desde a Lei 11.441/2007, sendo duas com previsão expressa em lei desde a vigência do CPC anterior.⁶¹⁴

As ações não-consensuais de família, processos de jurisdição contenciosa foram outro ponto de inovação dentre os procedimentos especiais por ganharem *Capítulo* próprio (Parte Especial, Livro I, Capítulo X), em tratamento agrupado (arts. 693-699), que introduz atos diferenciados e ordem de realização invertida, como uma audiência de conciliação e mediação antes da completa ‘angularização’ do processo, permitindo o chamamento do ‘réu’ para uma audiência, sem que, ainda, tenha completo conhecimento do teor da petição inicial. A audiência de conciliação e mediação prevista de forma obrigatória nas ações de família (arts. 693-699) não se aplica aos procedimentos consensuais, em vista da precedente convergência de interesses e da inexistência de contenciosidade.⁶¹⁵

Se, contudo, desaparecer a consensualidade no curso do procedimento de jurisdição voluntária, convertendo-se o procedimento em jurisdição contenciosa, é de cogitar-se, aí sim, na aplicação das regras dos arts. 693-699 do CPC/2015.

2. Aspectos materiais gerais da Secção – Do Divórcio e da Separação Consensuais, da Extinção Consensual de União Estável e da Alteração do Regime de Bens do Matrimônio

Quatro são as naturezas dos direitos materiais, cada qual com suas razões diferenciadas, correspondentes a ‘ações materiais’ próprias e a procedimentos especiais individuados, justificando o exame individual de cada um desses interesses. Em cada uma delas, identificar-se-á direito, pretensão, ação material e ação processual.⁶¹⁶

2.1 Divórcio consensual

A ação de divórcio consensual não estava e não poderia vir prevista expressamente no CPC/1973, pois a hipótese material surgiria na legislação posterior, Lei do Divórcio, Lei 6.515/1977, regulamentando as modalidades contenciosa e consensual, em decorrência da aprovação da Emenda Constitucional 9, de 28 de junho de 1977.⁶¹⁷ Desse modo, o procedimento especial de jurisdição voluntária contido no Título II, Capítulo III, do antigo CPC/1973 que tratava da separação consensual (anterior ao desquite amigável), passou a ser aplicado ao divórcio consensual pela redação do art. 40, § 2º, da Lei 6.515/1977. A possibilidade material do divórcio se sujeitou a prazos que sofreram alterações desde a redação original de 1977 (cinco anos de separação) até a Emenda Constitucional 66/2010, que afastou qualquer prazo. Portanto, as disposições normativas dos arts. 1.120-1.124 do CPC/1973 passaram a ser aplicadas no que coubessem ao divórcio consensual regulando analogicamente o procedimento desta espécie de ação dissolutória. A EC 66/2010 alterou a redação do art. 226, § 6º, da Constituição Federal de 1988, que passou assim a dispor: “o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”, e, portanto, suprimiu a necessidade prévia de realização da separação judicial por mais de 1 (um) ano ou de comprovada separação de fato por mais de 2 (dois) anos, conforme dispõe o 1.580, § 2º, do CC/2002. Dando-se assim autorização para a possibilidade de divórcio direto.

Anteriormente à entrada em vigor da Lei 6.515/1977 não existia a possibilidade de extinção do vínculo matrimonial, dissolvendo-se a sociedade pelo desquite, haja vista que o divórcio judicial foi introduzido pela referida lei. O art. 1.571 do CC/2002 previa como uma das hipóteses de dissolução do vínculo conjugal o divórcio, conforme consta no inc. IV do art. mencionado, inserido no CC/1916 a partir das alterações trazidas pela Lei 6.515/1977. O art. 267, inciso IV, do CC/1916 previa a possibilidade de extinção da comunhão por meio do divórcio, introduzido pela Lei 6.515/1977.

Prevendo a possibilidade do divórcio direto, assim determinando o § 2º do art. 1.571: “dissolvido o casamento pelo divórcio direto ou por conversão, o cônjuge poderá manter o nome de casado; salvo, no segundo caso, dispondo em contrário a sentença de separação judicial”.

O termo “divórcio consensual” somente apareceu no CPC/1973, introduzido pela Lei 11.441/2007, no art. 1.124-A, que previa a possibilidade de divórcio e separação consensuais extrajudiciais, ou seja, que podem ser realizadas por meio de escritura pública quando não há filhos menores ou incapazes do casal e anteriormente à EC 66/2010 era necessário observar os prazos contidos no art. 1.580 do CC/2002. Essas modalidades paralelas mantêm-se como alternativas neste CPC/2015, art. 733, para os casos em que não houver filhos incapazes ou nascituro fruto da relação que se desfaz.

Verifica-se que ambas as modalidades de dissolução da sociedade conjugal, tanto a separação judicial como o divórcio permanecem como institutos jurídicos materiais no ordenamento, haja vista a possibilidade de ação de conversão de separação judicial em divórcio, conforme suscita o próprio § 2º do art. 1.571 do CC/2002. O divórcio põe termo ao casamento e aos efeitos civis do matrimônio religioso (art. 24, *caput*, da Lei 6.515/1977).

O divórcio consensual pressupõe a concordância integral de ambos os cônjuges, justificando a manifestação expressa na petição inicial da ação de divórcio que deverá ir a juízo firmada por ambos e pelo advogado. A consensualidade deve se estender a todos os pontos que envolvam os interessados, pondo fim a relação entre eles, embora se mantenham legitimados para representação processual de filhos menores.

A extensa divergência doutrinária sobre a subsistência da separação, seja contenciosa ou consensual, após a EC 66/2010, agora parcialmente se aplaca, por conta das referências feitas pelo legislador do

CPC/2015 (arts. 693, 731, 732, 733) que induzem a se acreditar que está mantida a *etapa* de separação, que importa na própria separação de corpos, no fim dos deveres de coabitação, na cessação do regime de bens e na partilha dos bens havidos e partilháveis (CC/2002, arts. 1.574 e 1.576). Autores como Lenio Streck⁶¹⁸ e Paulo Lôbo,⁶¹⁹ porém, defendem que o fim da categoria “separação judicial” foi sedimentada pela EC 66/2010, não podendo o CPC/2015 revivê-la, sob pena de incidir em inconstitucionalidade.

2.2 Separação consensual

Anteriormente à entrada em vigor da EC 66/2010, o texto do art. 226, § 6º, da Constituição Federal de 1988 condicionava a realização do divórcio aos prazos estabelecidos no artigo, que exigia a realização da separação judicial anteriormente ao divórcio. O art. 226, § 6º, determinava a necessidade prévia de realização da separação judicial por mais de 1 (um) ano ou de comprovada separação de fato por mais de 2 (dois) anos, exigência replicada no CC/2002 conforme dispõe o 1.580, § 2º, em acordo com os regramentos trazidos ao ordenamento pela Lei 6.515/1977. Como já exposto após a EC 66/2010 esse entendimento foi alterado e, levando, inclusive, parte da doutrina e jurisprudência a afirmar que a separação judicial havia sido extinta.

No entanto, da leitura do *caput* do art. 731 do CPC/2015, verifica-se a persistência da existência do *degrau alternativo* da separação, seja litigiosa ou consensual, sendo um dos sinais mais claros dados pelo CPC/2015 na matéria relativa à dissolução das uniões pelo casamento. O que se tem não é necessidade de realização de prazos para a possibilidade de conversão da separação em divórcio, o que se verifica é a possibilidade ou opção da proposição da separação judicial ou do divórcio a depender da vontade dos cônjuges, uma vez que ao manter a possibilidade de separação, o CPC/2015 dirime *parcialmente* a dúvida acerca da permanência ou persistência do instituto após a entrada em vigor da EC 66/2010. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado após a vigência do CPC/2015.⁶²⁰

Maria Berenice Dias é crítica acerba à tentativa insistente do legislador do CPC/2015 em manter o “extinto instituto da separação” porque, embora distintos, serviam ao mesmo propósito, tendo sido banida a hipótese pela EC 66/2010.⁶²¹ Flávio Tartuce está também entre os autores que reconhece a manutenção da separação judicial pelo CPC/2015, mas considera tal previsão um verdadeiro retrocesso. O autor obtempera ser “uma grande infelicidade, um total retrocesso. Com essas fortes palavras pode ser resumida a manutenção da separação judicial e extrajudicial no Novo Código de Processo Civil Brasileiro. Vários dispositivos da norma instrumental emergente continuam a tratar das categoriais, o que não deveria ocorrer, em hipótese alguma”.⁶²²

A separação consensual foi incorporada ao CPC/1973, no Capítulo III, do Título II, em substituição ao desquite amigável, no título específico dos Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária, introduzida pela Lei do Divórcio, Lei 6.515/1977, nos arts. 1.120 a 1.224.

A separação litigiosa pode ser convertida em separação consensual em qualquer momento processual por meio do requerimento das partes interessadas, situação a qual deviam ser observadas as disposições do art. 1.121 e § 1.º, do art. 1.122 do CPC/1973 que tratam da necessidade de reduzir a termo as declarações dos cônjuges e depois de ouvido o Ministério Público, em 5 (cinco) dias.

Depois de homologada a separação consensual, as partes deverão por meio da sentença solicitar o averbamento no registro civil da certidão de casamento do divórcio, e se houver bens, que haja averbação da propriedade no cartório de registro de imóvel competente.

A partir da Lei 11.441/2007, que introduziu o art. 1.124-A no CC/2002, admite-se forma extrajudicial de separação por escritura pública, desde que não haja filhos menores ou incapazes do casal, cumulados com o requisito estipulado no § 2.º do art. 1.124-A que dispõe a necessidade de o tabelião lavrar a escritura se os cônjuges “estiverem assistidos por advogado comum ou advogados de cada um deles ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial”. Lembre-se que, conforme o § 1.º do art. 1.124-A, “a escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para o registro civil e o registro de imóveis”.

2.3 Extinção consensual de união estável

A união estável foi incorporada ao texto constitucional de 1988 no art. 226, § 3.º, que dispõe que para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

A Lei 9.278/1996, que regulou o § 3.º do art. 226 da CF/1988, trata de aspectos materiais e procedimentais relativos ao reconhecimento e dissolução de união estável entre companheiros. O art. 1º da referida lei determinava que se reconhecesse como entidade familiar a *convivência duradoura, pública e contínua*, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família. O CC/2002, em seu Livro IV (Do Direito de Família), destaca o Título III para regular a União Estável, revogando as Leis especiais 8.971/1994 e 9.278/1996,⁶²³ e define a união estável como uma entidade familiar configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.

A união estável é considerada uma situação de fato que não se sujeita a nenhuma solenidade, podendo ser formalizada a qualquer tempo, inclusive antes do seu início, a depender da vontade das partes envolvidas.⁶²⁴

Independente, assim, da lavratura de qualquer escritura pública ou do ajuizamento de qualquer ação declaratória para fins da sua constituição legal, pois é categoria de entidade familiar que se aperfeiçoa na própria convivência. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a Administração Pública não pode exigir prévia decisão judicial reconhecendo a existência de união estável, para a concessão de benefício administrativo.⁶²⁵

Logo, sendo a união estável uma entidade familiar de natureza fática, de grande sensibilidade foi o legislador ao não prescrever, no CPC/2015, nenhum procedimento para seu “reconhecimento” ou “constituição”, evitando, assim, contribuir com a posição equivocada de que a união estável de um casal só está apta a produzir efeitos jurídicos após seu reconhecimento por sentença declaratória.

Não obstante, sendo vontade do casal, a lavratura de uma escritura pública ou o próprio ajuizamento de uma ação declaratória não são recursos vedados, daí porque o CPC/2015 fez inserir no ordenamento o instrumento da ação de extinção consensual de união estável.

Quando a união estável não formalizada por qualquer meio for encerrada de forma não consensual, o CPC/2015 também oferece à parte interessada o procedimento contencioso de reconhecimento da união estável, assim como prevê a respectiva dissolução contenciosa. (art. 693).

Após o reconhecimento da união estável homoafetiva nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132 pelo Supremo Tribunal Federal, é possível o ajuizamento da ação de reconhecimento e dissolução de união estável entre companheiros heteroafetivos e homoafetivos, conforme decisões reiteradas do Superior Tribunal de Justiça.⁶²⁶ Ademais, são competentes para conhecimento e julgamentos das ações de reconhecimento e dissolução de união estável as Varas de Família.⁶²⁷

A legitimidade para pleito de reconhecimento e dissolução de união estável pertence aos companheiros, exclusivamente, não podendo terceiros alheios à relação requererem o reconhecimento e dissolução, uma vez que o núcleo central motivador da ação é o ideal de constituição de família, nesse sentido postula jurisprudência do STJ,⁶²⁸ ressalvado o caso de postulação em prol de incapazes, aplicando-se a lógica do dispositivo do par. único do art. 1.582 do CC/2002, o qual determina que “o pedido de divórcio somente competirá aos cônjuges. Parágrafo único. Se o cônjuge for incapaz para propor ação ou defender-se poderá fazê-lo o curador, o ascendente ou o irmão”.

Entretanto, o reconhecimento da união estável não é necessário para aquisição de alguns direitos específicos entre os companheiros, como direitos sobre os bens comuns e direitos previdenciários, se obedecido o precedente do Supremo Tribunal Federal já referido acima.

O regime de bens aplicados à união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, é o regime de comunhão parcial de bens, conforme prescreve o art. 1.725 do CC/2002. Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato escrito.

Interessante divergência doutrinária ainda se mantém quanto às uniões estáveis paralelas, também denominadas poliamor,⁶²⁹ famílias paralelas,⁶³⁰ relações simultâneas conjugais,⁶³¹ entre outras denominações.

Inspirados pela eficácia horizontal da dignidade da pessoa humana e pelo princípio constitucional da

pluralidade familiar, autores como Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk,⁶³² Bruna Barbieri Waquim,⁶³³ e Paulo Roberto Iotti Vecchiatti⁶³⁴ entendem que no âmbito do gênero “família” é juridicamente possível a coexistência das espécies “casamento”, “união estável” e “família paralela”, desde que observados requisitos tais como transparência e boa-fé, a par dos requisitos já previstos expressamente no ordenamento para uma união conjugal, de estabilidade, publicidade e objetivo de constituição de família.

Por outro lado, defendendo o princípio da monogamia, como elemento estabilizador das relações sociais, e a observância dos deveres jurídicos da fidelidade e lealdade, doutrinadores como Rolf Madaleno, Lenio Streck e Zeno Veloso⁶³⁵ sustentam que o casamento e a união estável não admitem simultaneidade, pela própria vedação legal existente quanto aos impedimentos ao casamento e à natureza da união estável de ser conversível em casamento.

Não obstante a riqueza doutrinária quanto a esta divergência, na 50.^a edição de Jurisprudência em Teses é possível observar a tendência do Superior Tribunal de Justiça em manter a tese jurídica de que não é possível o reconhecimento de uniões estáveis simultâneas.⁶³⁶

2.4 Alteração do regime de bens do casamento

Desde a edição do CC/2002, além da ampla disposição prévia sobre os bens, é permitido estipular regime de bens que se lhes aprouver (art. 1.639), exceção feita aos maiores de setenta anos (art. 1.641, inc. II) e aos que dependerem de suprimento judicial para casar (art. 1.641, inc. III), bem como as que contraírem matrimônio com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento estipuladas contidas no art. 1.523 do CC/2002 (art. 1.641, inc. I).

Essa liberdade, observadas as limitações mencionadas, também se estende à possibilidade de “alteração do regime de bens”, realizada por meio de autorização judicial, em “pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros” (art. 1.639, § 2º). A regra, com nítido caráter processual, contida no CC/2002 já permitia a alteração, sujeita aos requisitos materiais cumulativos, de ser o pedido formulado por ambos os cônjuges, motivação relevante e intervenção judicial pelo procedimento voluntário,⁶³⁷ com a presença do Ministério Público se presentes os interesses protegidos do art. 178, inc. II.

Rompia-se, a partir de então, uma tradição de imutabilidade quase completa no regime de bens do casamento.⁶³⁸ A ‘irrevogabilidade’ do regime de bens no CC/1916 se justificava, segundo Clóvis Beviláqua, por duas razões, o risco de um cônjuge abusar da fraqueza do outro e a proteção do interesse de terceiros credores.⁶³⁹ A permissão não alcança, por óbvio, o regime obrigatório de separação de bens.

A demanda que visasse, na vigência do CPC/1973, à alteração do regime de bens, deveria ser proposta por ação litigiosa, haja vista a não previsão da alteração por meio de jurisdição voluntária, razão pela qual a possibilidade de ação de jurisdição voluntária contida no CPC/2015 consiste em verdadeira inovação, observando-se que fica vedada a possibilidade de modificação do regime de bens de forma extrajudicial.

Art. 731 . A homologação do divórcio ou da separação consensuais, observados os requisitos legais, poderá ser requerida em petição assinada por ambos os cônjuges, da qual constarão:

- I – as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns;
- II – as disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges;
- III – o acordo relativo à guarda dos filhos incapazes e ao regime de visitas; e
- IV – o valor da contribuição para criar e educar os filhos.

Parágrafo único. Se os cônjuges não acordarem sobre a partilha dos bens, far-se-á esta depois de homologado o divórcio, na forma estabelecida nos arts. 647 a 658.

1. Inovações do CPC/2015

Primeiramente, pela leitura do *caput* do art. 731 do CPC/2015, verifica-se a persistência da existência da *degrau* da separação, seja litigiosa ou consensual, como um dos sinais mais claros dados pelo CPC/2015 na matéria relativa à dissolução das uniões pelo casamento. O que se tem não é necessidade de

realização de prazos para a possibilidade de conversão da separação em divórcio, o que se verifica é a possibilidade de realização da separação judicial ou do divórcio a depender da vontade dos cônjuges, uma vez que, ao manter a possibilidade de separação prévia, o CPC/2015 dirime a *penas parcialmente* dúvida acerca da permanência do instituto após a entrada em vigor da EC 66/2010.

Nesse sentido, o CPC/2015 divide a relação do vínculo matrimonial da relação patrimonial derivada do casamento.

O CPC/2015 inovou no Capítulo XV que trata dos procedimentos de jurisdição voluntária, ao introduzir na Seção IV o divórcio consensual; a extinção da União Estável e a alteração de regime de bens de patrimônio no rol dos procedimentos especiais, haja vista que no antigo CPC/1973 o legislador previu expressamente apenas a modalidade de separação consensual no rol de procedimentos especiais de jurisdição voluntária.

2. Aspectos materiais da partilha de bens, alimentos, visitas, despesas de educação, nome etc. no divórcio e na separação consensuais

São considerados aspectos materiais das ações de separação consensual, divórcio consensual, extinção de união estável os seguintes requisitos que devem instruir a petição inicial no que couber a cada ação e o seu mérito nos termos do art. 731, incisos I ao IV: disposições relativas à partilha de bens comuns; as disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges; o acordo relativo a guarda dos filhos incapazes e ao regime de visitas; o valor da contribuição para criar os filhos.

3. Aspectos processuais e procedimentais

A audiência de conciliação prevista de forma obrigatória nas ações de família (arts. 693-699) não se aplica aos procedimentos consensuais, em vista da precedente convergência de interesses e da inexistência de contenciosidade.

Com a vigência da EC 66/2010, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela possibilidade de homologação do divórcio direto consensual sem a necessidade de se realizar audiência de conciliação, haja vista a consensualidade presente entre os interessados.⁶⁴⁰

4. Ação de divórcio consensual

O divórcio consensual, introduzido pelo art. 40, § 2º, da Lei 6.515/1977⁶⁴¹ não podia estar previsto no CPC/1973, segue, desde então, as normas do procedimento especial de separação consensual, arts. 1.120 a 1.124.

Portanto, entende-se que as normas processuais relativas ao divórcio litigioso que determina a necessidade de realização de audiência de conciliação prévia de forma obrigatória nas ações de família não serão aplicadas às ações de divórcio consensuais, separação consensual e extinção consensual de união estável uma vez que o art. 731 e seguintes do CPC/2015 não preveem tal necessidade, bem como o entendimento jurisprudencial aplicado tem sido no sentido de desnecessidade de realização de audiência de conciliação prévia, tendo em vista o próprio aspecto consensual da demanda.

O CPC/2015 prevê expressamente o procedimento especial do divórcio consensual, entretanto, aplica as regras do procedimento de forma igualitária entre divórcio consensual, separação consensual, extinção consensual de união estável, excluindo-se apenas o procedimento especial da alteração de regime de bens que segue lógica distinta.

Ademais, o divórcio consensual pode ser realizado em duas modalidades: judicial ou extrajudicial. A modalidade judicial é a modalidade que será analisada neste primeiro tópico, sendo o extrajudicial previsto no art. 733 do CPC/2015, o qual será analisado especificamente em tópico seguinte.

4.1 Legitimidade

O CPC/2015 não indica a quem pertence a legitimidade ativa para o ajuizamento da ação de divórcio consensual, mas exige a assinatura de ambos na petição inicial (art. 731), indicando quem são os únicos interessados. O CC/2002 no art. 1.582 determina que “o pedido de divórcio somente competirá aos cônjuges. Parágrafo único. Se o cônjuge for incapaz para propor ação ou defender-se poderá fazê-lo o curador, o ascendente ou o irmão”.

Haja vista que a ação de divórcio consensual consiste em procedimento de jurisdição voluntária não há que se falar em partes processuais, e sim em interessados processuais, não havendo propriamente um autor e um réu na demanda, uma vez que ambos os cônjuges, em comum acordo, decidem divorciar-se e solicitam a homologação ao juízo competente.

4.2 Competência

O art. 53, inc. I, do CPC/2015 redefine com mais igualdade a competência territorial jurisdicional para atuação nos casos de ação de divórcio, ação de separação, anulação de casamento e reconhecimento e dissolução de união estável determinado a competência sucessiva caso a opção antecedente não seja viável, nos seguintes termos. Pela nova regra é competente o foro para a ação de contenciosa de divórcio aquele de domicílio do guardião de filho incapaz ou o foro do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz, aplicável às ações consensuais ou, ainda o domicílio de qualquer dos interessados do casal.

A competência territorial das ações de divórcio no CPC/1973 era definida pelo domicílio da mulher nos termos do art. 100, inc. I, cuja redação foi definida com base na Lei 6.515/1977.⁶⁴² A competência territorial é relativa, podendo ser ajuizada a ação em domicílio, que não seja o da mulher, conforme reiterado entendimentos jurisprudencial, entretanto, podendo ser impugnada pelo CPC/1973 por meio de exceção de incompetência.

Aqui se trata, também, de competência territorial, e, portanto, relativa, no entanto, o CPC/2015 prevê a possibilidade de arguição da incompetência relativa pela via da contestação, nos termos do art. 340 do CPC/2015.⁶⁴³

No entanto, no caso das ações consensuais, poderá haver negócio sobre a competência relativa devido à convergência dos interessados em ajuizarem a ação em comarcas diversas daquelas mencionadas no art. 53 do CPC/2015. A competência jurisdicional para julgamentos dos casos relativos ao divórcio consensual é as Varas de Família.

4.3 Petição inicial assinada pelos interessados e advogado

O divórcio consensual pressupõe a concordância integral de ambos os cônjuges, justificando a manifestação expressa na petição inicial da ação de divórcio que deverá ir a juízo firmada por ambos e pelo advogado, além de estar instruída com certidão de casamento; contrato antenupcial se houver; a descrição dos bens do casal e a respectiva partilha (dos bens e das dívidas se houver); o acordo relativo a guarda dos filhos menores e o regime de visitas se houver filhos comuns ao casal; a pensão alimentícia a ser prestada por um dos genitores; a pensão alimentícia a cônjuge, se este não possuir bens suficientes para se manter (art. 731, *caput*).

O CPC/2015 prevê expressamente a necessidade de assinatura da petição pelos cônjuges no *caput* do art. 731 do CPC/2015, assim descrito: “Art. 731. A homologação do divórcio ou da separação consensuais, observados os requisitos legais, poderá ser requerida em petição assinada por ambos os cônjuges, da qual constarão”. A necessidade de assinatura pelos advogados persiste tendo em vista que somente advogados inscritos na OAB podem realizar atos próprios de advogados (Lei 8.906/1994) nos termos do art. 1º, inc. I.⁶⁴⁴ Não se concede nessas ações dissolutórias a autodefesa ou direito de postular sem o acompanhamento de advogado, como na ação de alimentos. Entende-se que este ato pode ser irretratável, por ter conteúdo de transação sobre direitos disponíveis, não permitindo o arrependimento de qualquer das partes.⁶⁴⁵

4.4 O objeto do processo ou conteúdo

O art. 731 do CPC/2015 traz as matérias que podem ser postas nas ações de divórcio consensual; sendo matérias relativas à partilha de bens comuns; alimentos entre os cônjuges; acordo relativo a guarda dos filhos incapazes e regime de visitas e alimentos devidos aos filhos. Com o objetivo de verificar de que forma isso se aplicar no novo contexto do CPC/2015 passa-se a tratar sobre os tópicos aqui colacionados no âmbito do divórcio consensual.

4.4.1 Disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns

O art. 731, inc. I, do CPC/2015 dispõe que “a homologação do divórcio ou da separação consensuais, observados os requisitos legais, poderá ser requerida em petição assinada por ambos os cônjuges, da qual constarão as disposições relativas descrição e à partilha dos bens comuns, diferentemente do art.

1.121, inc. I, do CPC/1973 que determinava que contasse a petição inicial da separação consensual com a descrição dos bens do casal e a respectiva partilha.

A partilha de bens comuns refere-se, primeiramente, à necessidade de se pontuar o regime de bens e a data de sua vigência para posterior verificação de quais bens consubstanciam os bens comuns dos cônjuges. Não houve grandes alterações no tema, o termo novo adotado é o “bem comum”. “Os regimes comunitários, nos quais se inclui a comunhão parcial de bens, assentam-se sobre a ideia de que a sociedade conjugal deve associar os interesses pessoais e patrimoniais dos cônjuges. O casamento desencadeia efeitos econômicos, podendo ser considerado sob esse aspecto uma associação financeira, não exclusivamente pelo regime de bens, em vista da necessidade dos cônjuges em contribuírem para o sustento familiar, para as despesas comuns, para a manutenção do lar etc.”⁶⁴⁶

Se outro é o regime que não justifique a partilha, ou se não há bens a partilhar, não se cogita de levar ao processo essa informação e qualquer pedido a ela concernente.

“Dentre os efeitos de natureza patrimonial que podem ser tidos como decorrentes da celebração do casamento ou da união estável, pois a essa se aplica supletivamente ao regime de comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1.725 do CC/2002, destaca-se a formação do acervo comum, ressalvada a hipótese da adoção no casamento do regime de separação voluntária ou obrigatória de bens ou a existência de contrato escrito entre os companheiros prevendo a incomunicabilidade de bens”.⁶⁴⁷

Bens comuns aos cônjuges ou companheiros são aqueles em que há direitos de posse ou de propriedade por ambos os litisconsortes, sendo constituído verdadeiro condomínio ou composses entre eles. A definição dos bens comuns seguirá as regras dos regimes de casamento previstos da legislação civil, quais sejam: separação obrigatória de bens; comunhão universal de bens; comunhão parcial de bens e regime de participação final nos aquestos. Nos termos do art. 1.639 do CC/2002, o regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento. Cessa com a separação, se houver, só se justificando a sobrepartilha sobre bens remotos, sonegados, olvidados etc.”⁶⁴⁸

Para além do patrimônio ativo e passivo, referidos expressamente no Título II do CC/2002 como objetos de partilha, a jurisprudência moderna tem admitido a inclusão no monte partilhável de valores decorrentes de benefícios previdenciários,⁶⁴⁹ previdências privadas,⁶⁵⁰ FGTS⁶⁵¹ e até mesmo as prestações pagas durante a convivência de financiamento imobiliário.⁶⁵² Pode a cessão de bens aos filhos evitar a partilha e caracterizar-se como escritura pública de doação hábil ao registro.⁶⁵³

Também é de recente construção jurídica a tese do pagamento de alugueres por parte do cônjuge que se mantenha na residência exclusiva do imóvel adquirido em conjunto, enquanto não partilhado referido imóvel.⁶⁵⁴

Desde o CC/2002 se consagrou a regra do art. 1.581 do, o divórcio poder ser concedido sem que haja prévia partilha de bens, seguindo os mesmos termos da Súmula 197 do STJ que assim dispôs: “o divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens”. Portanto, há muito não se aplica ao caso o disposto no art. 31 da Lei 6.515/1977, que condicionava uma coisa à outra.

4.4.2 Disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges

Os alimentos decorrentes do Direito de Família se sujeitam a características da reciprocidade, inalienabilidade, impenhorabilidade, irrenunciabilidade, irrepetibilidade e transmissibilidade. Entre os cônjuges e também em relação aos filhos, aos filhos menores e aos filhos incapazes obrigação pode ser resolvida nas ações de divórcio, sendo limitados pelas normas de Direito Constitucional e Direito Civil, dispersas num emaranhado legislativo.⁶⁵⁵

Podem os cônjuges pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação (art. 1.694); ou estabelecer livremente tais disposições na ação de divórcio consensual. Essas estipulações podem referir-se a alimentos permanentes, ou por tempo determinado (transitórios),⁶⁵⁶ pagos sob a forma de pensionamento, hospedagem e sustento ou de pagamento em dinheiro, diretamente ou mediante desconto.

No entanto, com as alterações promovidas pela EC n. 66/2010 quanto à inserção do Divórcio Direto no ordenamento jurídico brasileiro, autores como Cristiano Chaves de Farias⁶⁵⁷ e Rodrigo da Cunha Pereira

⁶⁵⁸ advogam a tese de que não mais cabe a discussão sobre a culpa pela dissolução da união, tampouco a produção de efeitos jurídicos restritivos a eventual culpado pela separação ou divórcio.

Em sentido diverso, Rolf Madaleno defende a subsistência do debate sobre o cônjuge culpado para fins do arbitramento do valor da pensão alimentícia e do perdimento do direito ao sobrenome, conforme previsão dos arts. 1.578 e 1.704 do CC/2002. Não se pode cogitar de renúncia aos alimentos nessas ações, pois além da previsão legal que a veda quanto aos alimentos (CC/2002, art. 1.707), há Súmula do STF 379, que põe fim a essa discussão estatuinto que “não se admite renúncia aos alimentos que poderão ser pleiteados ulteriormente verificados os pressupostos legais”. Ainda assim, parte da doutrina admite a possibilidade de renúncia dos alimentos pelo cônjuge, informando que essa possibilidade deriva da inexistência de relação *ius sanguinis* entre os cônjuges, ademais, para o autor o matrimônio não gera vínculo de parentesco entre os cônjuges. Portanto, consistiriam os alimentos em direitos disponíveis entre os cônjuges. ⁶⁵⁹

O inciso II do art. 731 do CPC/2015 possui relevante alteração da técnica de redação legislativa, quando comparado com o teor do inciso IV do art. 1.121 do CPC/1973. Se, antes, o CPC/1973 previa a restritiva hipótese da pensão alimentícia “do marido à mulher, se esta não possuir bens suficientes para se manter”, o CPC/2015, ao estabelecer somente a hipótese das “disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges”, auxiliou o CC/2002 na abertura do caminho jurisprudencial para inúmeras vertentes quanto aos sujeitos, natureza e temporalidade da obrigação.

Assim, podem ser reciprocamente credores e devedores da pensão alimentícia consorcial tanto o homem quanto a mulher, em relações heteroafetivas, ou qualquer dos consortes, na relação homoafetiva, de acordo com a correspondência do binômio “necessidade x capacidade” ao caso concreto.

Da mesma forma, a pensão alimentícia deixa de objetivar a tutela apenas da subsistência indispensável à vida, em caráter definitivo até que uma eventual revisão seja proposta, pois favorece a redação ampla do CPC/2015 o exercício da pretensão quanto a alimentos compensatórios, ⁶⁶⁰ alimentos transitórios, sendo possível incluir na previsão até mesmo a disposição sobre alimentos gravídicos ⁶⁶¹, embora seu credor finalístico seja o nascituro e não a consorte grávida.

Se aquele que for credor de alimentos contrair novo matrimônio, cessa o dever de prestar alimentos pelo ex-cônjuge nos termos do que estipula o art. 1.708 do CC/2002. ⁶⁶²

4.4.3 Guarda dos filhos incapazes e ao regime de visitas

A guarda poderá ser fixada também nos autos da ação de divórcio, podendo ser definida de forma unilateral para um dos genitores ou na forma compartilhada. O capítulo XI do Título I, subtítulo I, Livro IV, trata da proteção da pessoa dos filhos e o art. 1.583 do CC/2002 prevê que “a guarda será unilateral ou compartilhada”, e “não havendo acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, será aplicada, sempre que possível, a guarda compartilhada”. Entretanto, no divórcio e separação consensuais as cláusulas relativas à guarda do menor devem estar acordadas entre os cônjuges. No exercício do poder familiar compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos exercer a guarda unilateral ou compartilhada.

A guarda da prole comum é um dos pontos mais sensíveis de uma ação de família, seja consensual ou contenciosa, pois à pretensão dos genitores de exercer sua autoridade parental (art. 1.634 do CC/2002) deve ser sempre conjugada a obrigação de alcançar o melhor interesse da criança e do adolescente. ⁶⁶³

Diversas alterações legislativas foram modificando o CC/2002 e a *praxis* sobre a concessão de guarda e fixação do regime de visitas, o que gerou a coexistência de diversas modalidades de guarda (conjunta, unilateral, alternada, *nidal*, compartilhada), até a recente superação da regra da guarda unilateral para a priorização da modalidade de guarda compartilhada, promovida pela Lei 13.508/2014, que determina a distribuição do tempo de convívio com os filhos de forma equilibrada entre ambos os genitores.

Assim, um dos pontos de destaque da petição de divórcio ou separação consensuais deve ser o compromisso dos progenitores em respeitar o direito fundamental da prole comum de usufruir da convivência familiar (art. 227 da CF/1988) com ambos os genitores e núcleos familiares, seja qual for a forma estabelecida.

A despeito da regra material, a partir de 2014, ser a adoção da modalidade da guarda compartilhada, a própria Lei 13.508/2014 deixa cristalino ser possível a fixação da guarda unilateral quando um dos

genitores declarar que não deseja a guarda da prole, ou, ainda, quando não estiver apto a exercer o poder familiar. E, ainda que seja convencionada a guarda compartilhada, é de bom alvitre que sejam minimamente esclarecidos na petição os períodos de custódia física que cada genitor disporá com a criança, em busca do estabelecimento de uma rotina sadia para o infante.

Deve ser também alertado que a convenção original entre os genitores sobre a modalidade de guarda, ainda que pela via consensual, não afasta sua posterior alteração, a requerimento do interessado ou de ofício pelo juiz, quando identificada a prática de Alienação Parental.

A Alienação Parental é caracterizada pela interferência maliciosa de um adulto na harmonia da convivência familiar de uma criança ou um adolescente com outro familiar. Geralmente é manifestada pela tentativa de um genitor em afastar o filho do outro genitor, por meio de campanha de difamação, falsas denúncias de abuso ou manipulação emocional, gerando prejuízos à formação psicológica saudável da prole incapaz.⁶⁶⁴

Nos termos do art. 6.º da Lei 12.318/2010, caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer conduta que dificulte a convivência de criança ou adolescente com genitor, em ação autônoma ou incidental, o juiz poderá, entre outras medidas, determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou sua inversão.

O CPC/2015, em bom tempo, reconheceu a importância da apuração judicial do ato de alienação parental, destinando-lhe recomendação procedimental própria, no art. 699.

4.4.4 Valor da contribuição para criar e educar os filhos

O *princípio da proteção da prole comum* estimula essa atenção e provimento às necessidades dos filhos.⁶⁶⁵ Ainda o CC/2002 prevê que a ruptura entre o casal não modificará os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos (art. 1.579), dever que se centra em promover a manutenção ainda que após a o fim da relação que os gerou (art. 1.709), observado o binômio necessidade e capacidade (art. 1.694, § 1.º) contribuindo para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703), que não se altera com nova união de qualquer dos pais, ou de ambos.

O poder familiar é um direito-dever em que os pais têm alguns deveres, dentre eles dirigir-lhes a criação e a educação.

O inc. IV do art. 731 estabelece o que constará das estipulações e indica os alimentos devidos aos filhos menores como uma delas, ao tratar de “valor da contribuição para criar e educar os filhos”. Os alimentos devidos pelos genitores aos filhos são os alimentos derivados da relação de filiação em que há o exercício do poder familiar nos termos do art. 1.634, inc. I, do CC/2002.⁶⁶⁶

Podem os alimentos ser pleiteados por meio de procedimento especial contido na Lei de Alimentos, Lei 5.478/1968, com vantagens procedimentais, ampliação de poderes do juiz, sem obstar que sejam definidos nas ações de divórcio contenciosas ou consensuais. O parágrafo único do art. 693 do CPC/2015 prevê que a ação de alimentos e a que versar sobre interesse de criança ou de adolescente observarão o procedimento previsto em legislação específica, aplicando-se, no que couber, as disposições deste Capítulo. Nem sempre será necessário seguir a Lei 5.478/1998 (lei especial) ou o Capítulo X, das Ações de Família, típicos modelos conflitivos, para a fixação de alimentos aos filhos, conquanto subsistam meios não contenciosos para esse fim.

A despeito do entendimento tradicional de que os alimentos são devidos a filhos menores de idade, a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que também a filhos maiores de idade é possível a oferta consensual ou o arbitramento contencioso de prestação alimentícia, dedicada ao custeio de despesas relacionadas à instrução da prole em curso universitário ou técnico.

Talvez por isso a especial referência do CPC/2015 à verba para “educar”, ao lado da previsão genérica de “contribuição para criar”, o que permite alinhar o novel código ao entendimento de que “o advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado”, por ser “presumível, no entanto, – presunção *iuris tantum* –, a necessidade dos filhos de continuarem a receber alimentos após a maioridade, quando frequentam curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional.”⁶⁶⁷

Exige-se que, havendo créditos de alimentos em favor de filhos do casal que se divorcia consensualmente, imperativo que se definam nesse procedimento os alimentos desses filhos e a quem encarece o dever, a forma, a periodicidade e todos os detalhes que de segurança à criança, adolescente ou adulto incapaz. Porém, mesmo no procedimento de jurisdição voluntária, em que seja manifestada a concordância das partes quanto ao estabelecimento do montante para custeio das despesas de criação e educação dos filhos, permanece o poder-dever do juiz em recusar a homologação de acordo que observe desguarnecer os melhores interesses da prole.⁶⁶⁸ Admite-se a suspensão temporária do dever, por consenso, em ação de divórcio consensual.⁶⁶⁹

4.4.5 Do Nome

Ainda que o art. 731 não trate da questão da alteração do nome dos cônjuges nas ações em análise, a alteração do nome de casado para o nome de solteiro(a) é possível, a depender do interesse de pelo menos um dos cônjuges, não mais prevalecendo o entendimento do art. 7.º e ss. da Lei 6.515/1977, o qual obriga, caso a mulher seja vencida na ação de separação judicial, a voltar o nome de solteira; ou no caso da ação ser proposta pela mulher, essa também deveria retornar a usar seu nome de solteira; e somente nos demais casos caberia a opção pela manutenção ou não do nome pela mulher. Entretanto, tais artigos perderam sua eficácia a partir da entrada em vigor na Constituição Federal de 1988 que dispõe no art. 226, § 5º o seguinte: “os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher”.

O CC/2002 postula no art. 1.571, § 2º, que “dissolvido o casamento pelo divórcio direto ou por conversão, o cônjuge poderá manter o nome de casado; salvo, no segundo caso, dispondo em contrário a sentença de separação judicial”.

O direito ao nome, aqui incluídos tanto prenome quanto patronímico, é direito da personalidade com ampla tutela no ordenamento jurídico brasileiro, que alcança importância para situações além do próprio encerramento da vida do indivíduo (art. 20, parágrafo único do CC/2002).

Para essa tutela, posto que o direito ao nome aglutina aspectos tanto de interesse público quanto privado, o ordenamento pátrio dispõe do regramento do CC/2002 e da Lei de Registro Civil (n. 6.015/1973), regras estas que têm sido temperadas pela jurisprudência, em virtude da própria dinâmica social transformada pelo decurso do tempo.

A título de exemplo, a vedação do § 2º do art. 57 da Lei 6.015/1973 de que a companheira só poderia acrescentar o sobrenome do companheiro se provado algum impedimento do casamento, já foi afastada pelo Superior Tribunal de Justiça, que entendeu possível o pleito de adoção do sobrenome dentro de uma união estável, em aplicação analógica do art. 1.565, § 1º do CC/2002.⁶⁷⁰

A adoção do patronímico é um procedimento que também tem sido oxigenado pela igualdade substancial entre homens e mulheres, como demonstra pesquisa da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, que aponta que no ano de 2013 cerca de 25% dos homens que se casaram no civil adotaram o sobrenome de suas mulheres, prática esta que subiu 278% em dez anos.⁶⁷¹

Por isso é necessária a ressalva de que, ainda que não expressamente previsto pelo art. 731 do CPC/2015, deve a petição de divórcio ou separação consensual esclarecer sobre a manutenção ou exclusão do patronímico agregado quando da constituição do vínculo, sem prejuízo ao direito à identidade dos ex-consortes.⁶⁷²

4.5 Conversão de ação de divórcio contenciosa em consensual

Os procedimentos contenciosos podem se converter em consensuais, sendo dever do juiz, a qualquer tempo, tentar a conciliação (art. 139, inc. V), sendo esta uma das proposições políticas legislativas mais evidentes do CPC/2015. É possível, também, que a ação de divórcio litigioso, no curso do procedimento, se torne consensual por acordo entre as partes. Porém, a inversa não tem sido admitida; não é possível que o divórcio consensual se converta em divórcio litigioso em caso de desavenças por haver grandes diferenças procedimentais.⁶⁷³ Nesse caso, a parte deverá desistir do procedimento consensual e iniciar outro litigioso, pela via processual mais adequada.⁶⁷⁴

O surgimento de uma lide, um litígio ou conflito franco no curso de uma ação consensual que justificariam a conversão da jurisdição voluntária em jurisdição contenciosa não tem sido admitido

exigindo a proposição de nova ação.

4.6 As provas

Reduziu-se o espectro probatório nas ações consensuais, mais acordes com a intervenção mínima que despreza fatos da intimidade do casal; no procedimento consensual de divórcio, fica ainda mais acentuada essa tendência.⁶⁷⁵

Se não há fato constitutivo do direito de se divorciar, assim como não há mais prazo de duração do casamento ou prazo de dois anos de separação de fato (EC 66/2010) não há o que perquirir sobre tempos. Para se divorciar basta estar casado e não querer assim permanecer.

Desnecessária a audiência inaugural de conciliação/mediação. A audiência de conciliação/mediação prevista de forma obrigatória nas ações de família (arts. 693-699) não se aplica aos procedimentos consensuais, em vista da precedente convergência de interesses e da inexistência de contenciosidade. Com a vigência da EC 66/2010, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já vinha entendendo pela possibilidade de homologação do divórcio direto consensual sem a necessidade de se realizar audiência de conciliação, haja vista a consensualidade presente entre os interessados.⁶⁷⁶

A prova da consensualidade se faz pela aposição da assinatura na petição inicial conjunta, acompanhando a assinatura do advogado. Exigem-se documentos necessários para instruir o processo que são associados a existência do vínculo e à legitimidade como: documentos pessoais dos interessados (RG e CPF); certidão de casamento atualizada (90 dias); certidão de nascimento dos filhos tidos na constância do casamento; documentos de registro dos bens imóveis; documentos comprobatórios da propriedade, posse ou alienação fiduciária de bens móveis; documentos que comprovem as dívidas comuns ao casal; declaração de hipossuficiência ou recolhimento de custas; comprovante de renda no caso de hipossuficiente.

4.7 Sentença e efeitos

A apelação (art. 1.009) é o recurso da sentença que caracteriza o duplo grau de jurisdição, definido como ato pelo qual o processo se submete a uma dupla fase do juízo de mérito; a sentença se sujeita aos meios impugnativos, só transitando em julgado após o exame desses recursos. E como sentença dos procedimentos de jurisdição voluntária, também está sujeita a recurso de apelação (art. 724), obedecendo aos requisitos *intrínsecos* : cabimento, legitimidade e interesse recursal e *extrínsecos* : tempestividade, regularidade formal e preparo.

A sentença proferida no âmbito das ações de divórcio, seja ele consensual ou litigioso, tem o condão de, após o deferimento do pedido de divórcio, determinar a averbação do divórcio na certidão de casamento dos ex-cônjuges. Podendo ser solicitado, caso vontade das partes, que seja expedido ofício ao cartório do respectivo de registro do casamento para que promova a averbação do divórcio na certidão de casamento dos interessados.

Apesar de o art. 731 não tratar da questão da alteração do nome dos cônjuges nas ações em análise, a alteração do nome de casado para o nome de solteiro (a) é possível a depender do interesse de pelo menos um dos cônjuges, não mais prevalecendo o entendimento do art. 7.º e ss. da Lei 6.515/1977, o qual obriga, caso a mulher seja vencida na ação de separação judicial, a voltar o nome de solteira; ou no caso da ação ser proposta pela mulher, essa também deveria retornar a usar seu nome de solteira; e somente nos demais casos caberia a opção pela manutenção ou não do nome pela mulher. Entretanto, tais artigos perderam sua eficácia a partir da entrada em vigor na Constituição Federal de 1988 que dispõe no art. 226, § 5º o seguinte: “os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher”.

O CC/2002 postula no art. 1.571, § 2º, que “dissolvido o casamento pelo divórcio direto ou por conversão, o cônjuge poderá manter o nome de casado; salvo, no segundo caso, dispondo em contrário a sentença de separação judicial”.

4.8 Postergação da partilha no divórcio

O CC/2002 permitiu a possibilidade de ser concedido o divórcio sem que haja prévia partilha de bens entre o casal, o art. 1.581 assim dispõe: “o divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens”. Com isso se alterou regra da Lei do Divórcio⁶⁷⁷ já flexibilizada pela jurisprudência, isolando da

questão matrimonial a questão puramente patrimonial relacionada aos bens do casal.

De igual modo o CPC, no art. 731, par. único, prevê a possibilidade de realização da partilha em outro momento que não nos autos da ação de divórcio consensual, quando não houver acordo entre os cônjuges acerca da partilha dos bens comuns do casal. Assim, “se os cônjuges não acordarem sobre a partilha dos bens, far-se-á esta depois de homologado o divórcio, na forma estabelecida nos arts. 647 a 658”. Ao tempo em que for efetivada a partilha, seguirá igualmente a regra dos arts. 647 a 658 do CPC/2015, realizada em procedimento extrajudicial, ação judicial autônoma consensual ou litigiosa.

Assim, somente a discordância quanto à partilha dos bens permite que seja mantido o caráter consensual do divórcio. Existindo divergência quanto à pensão alimentícia em prol de cônjuge ou prole e/ou, ainda, quanto à convivência familiar com filhos, o CPC/2015 exige que o divórcio e a separação se deem de forma contenciosa, sobre todos os aspectos materiais envolvidos.

4.9 Natureza homologatória da decisão judicial

A homologação consiste na análise judicial que verifica a regularidade formal do acordo entabulado pelas partes, e se estão suficientemente resguardados os interesses da família, nos termos do art. 1.574, parágrafo único do CC/2002. A sentença é reconstitutiva de estado e terá efeitos entre os cônjuges somente a partir do trânsito em julgado, conforme o art. 506 do CPC/2015. Após a averbação do divórcio consensual judicial na certidão de casamento é que essa terá efeito em relação a terceiros. Se houve a partilha de bens imóveis, isso deve constar como averbação da matrícula respectiva dos imóveis.⁶⁷⁸

5. Ação de separação consensual

Mantem-se a previsão da separação consensual no CPC/2015, bem como a outros tipos de procedimentos de jurisdição voluntária no âmbito do Direito de Família. Persiste o debate doutrinário sobre a sua revogação, conforme referências anteriores, solução que caberá, ao final, aos tribunais superiores.

Embora o número de artigos tenha sido reduzido, as disposições sobre detalhes da separação consensual vêm especificamente detalhados se comparados o art. 731 do CPC/2015 aos arts. 1.120 a 1.224. CPC/1973. Não havia disposição ampla sobre a possibilidade de alimentos a qualquer dos cônjuges (art. 731, inc. II). São suprimidas disposições que motivavam maior interferência estatal e confirmação da vontade dos interessados, em audiência (art. 1.222 do CPC/2015).

5.1 Legitimidade

O CPC/2015 não define a legitimidade ativa para o ajuizamento da ação de separação consensual mas exige a assinatura de ambos na petição inicial (art. 731), indicando quem são os únicos interessados. Haja vista que a ação de separação consensual consiste em procedimento de jurisdição voluntária não há que se falar em partes processuais, e sim em interessados processuais. A consensualidade deve se estender a todos os pontos que envolvam esses interessados, pondo fim a deveres entre eles, embora mantenham-se legitimados para representação processual de filhos menores.

5.2 Competência

O art. 53, inc. I, do CPC/2015 redefine com mais igualdade a competência territorial jurisdicional para atuação nos casos de ações de família determinando-se a competência sucessiva caso a opção antecedente não se confirme. Pela nova regra é competente o foro para a ação de contenciosa de separação aquele de domicílio do guardião de filho incapaz ou o foro do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz, aplicável às ações consensuais ou, ainda o domicílio de qualquer dos interessados do casal, igualmente ao divórcio.

A competência territorial das ações contenciosas do CPC/1973 era definida pelo domicílio da mulher nos termos do art. 100, inc. I, redação foi definida com base na Lei 6.515/1977. A competência territorial é relativa, podendo ser ajuizada a ação em domicílio que não seja o da mulher, conforme reiterado entendimentos jurisprudencial⁶⁷⁹ entretanto, podendo ser impugnada pelo CPC/1973 por meio de exceção de incompetência. Aqui se trata, também, de competência territorial, e, portanto, relativa, no entanto, o CPC/2015 prevê a possibilidade de arguição da incompetência relativa pela via da contestação, nos termos do art. 340 do CPC/2015.⁶⁸⁰

No entanto, no caso das ações consensuais poderá haver negócio sobre a competência relativa devido à convergência dos interessados em ajuizarem a ação em comarca diversas daquelas mencionadas no art. 53 do CPC/2015. A competência jurisdicional para julgamentos dos casos relativos ao divórcio consensual é das Varas de Família.

5.3 Petição inicial assinada pelos interessados e advogado

A separação consensual também pressupõe a concordância integral de ambos os cônjuges, justificando a manifestação expressa na petição inicial da ação que deverá ir a juízo firmada por ambos e pelo advogado, além de estar instruída com documentos essenciais com certidão de casamento; contrato antenupcial se houver; a descrição dos bens do casal e a respectiva partilha (dos bens e das dívidas se houver); o acordo relativo à guarda dos filhos menores e o regime de visitas se houver filhos comuns ao casal; a pensão alimentícia a ser prestada por um dos genitores; a pensão alimentícia a cônjuge (art. 731, *caput*). Entende-se que esse ato pode ser irretratável, por ter conteúdo de transação sobre direitos disponíveis, não permitindo o arrependimento de qualquer das partes. ⁶⁸¹

O CPC/1973 já previa a necessidade de assinatura da petição inicial de separação consensual por ambos os cônjuges, o que é aplicada de forma análoga aos divórcios consensuais. O § 2.º art. 1.121 determinava que, caso as assinaturas não sejam colhidas na presença no juiz, deveria ser reconhecida, por reconhecimento de firma, pelo tabelião. Entretanto, não é isso que ocorre na prática forense. O que se tem no dia a dia, desde então, é a necessidade de assinatura da petição de separação consensual advogado que representa ambos os interessados, bem como a assinatura de ambos os cônjuges antes mesmo da propositura da ação, a serem lançadas em rubrica em todas as páginas e de forma completa na página final da petição inicial.

O CPC/2015 prevê expressamente a necessidade de assinatura da petição pelos cônjuges no *caput* do art. 731 do CPC/2015, assim descrito: “Art. 731. A homologação do divórcio ou da separação consensuais, observados os requisitos legais, poderá ser requerida em petição assinada por ambos os cônjuges, da qual constarão”. A necessidade de assinatura pelos advogados persiste tendo em vista que somente advogados inscritos na OAB podem realizar atos próprios de advogados (Lei 8.906/1994) nos termos do art. 1º, inc. I. Não se, concede nessas ações dissolutórias, a autodefesa ou direito de postular sem o acompanhamento de advogado, como na ação de alimentos.

A *causa de pedir* na separação envolve o fim da sociedade conjugal, sem a dissolução do vínculo do matrimônio, mas fazendo cessar o regime de bens;

5.4 O objeto do processo ou conteúdo

O art. 731 do CPC/2015 traz as matérias que podem ser postas neste procedimento de jurisdição voluntária que objetiva a apenas a separação consensual, tais como: partilha de bens comuns; alimentos entre os cônjuges; acordo relativo à guarda dos filhos incapazes e regime de visitas e alimentos devidos aos filhos.

5.4.1 Disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns

O art. 731, inc. I, do CPC/2015 dispõe que “da separação consensuais, observados os requisitos legais, poderá ser requerida em petição assinada por ambos os cônjuges, da qual constarão as disposições relativas descrição e à partilha dos bens comuns, diferentemente do art. 1.121, inc. I, do CPC/1973 que determinava contasse a petição inicial da separação consensual com a descrição dos bens do casal e a respectiva partilha.

Como dito, partilha de bens comuns refere-se primeiramente a necessidade de se pontuar o regime de bens e a data de sua vigência para posterior verificação de quais bens consubstanciam os bens comuns dos cônjuges.

Bens comuns aos cônjuges são aqueles em que há direitos de posse ou de propriedade por ambos os litisconsortes, sendo constituído verdadeiro condomínio ou composses entre eles. A definição dos bens comuns seguirá as regras dos regimes de casamento previstos da legislação civil, quais sejam: separação obrigatória de bens; comunhão universal de bens; comunhão parcial de bens e regime de participação final nos aquestos. Nos termos do art. 1.639 do CC/2002, o regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento. Com a separação cessa o regime de bens e considera-se extinta a forma de comunhão, se havia. Pode a cessão de bens aos filhos evitar a partilha e caracterizar-se como

escritura pública de doação hábil ao registro. ⁶⁸²

Ver item equivalente mais detalhado acima, na ação consensual de divórcio.

5.4.2 Disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges

Como dito, os alimentos decorrentes do Direito de Família se sujeitam a características da reciprocidade, inalienabilidade, impenhorabilidade, irrenunciabilidade, irrepetibilidade e transmissibilidade. Entre os cônjuges e também em relação aos filhos, aos filhos menores e aos filhos incapazes obrigação pode ser estabelecida e regulada nas ações de separação. As disposições contidas na ação de separação consensual podem referir-se a alimentos permanentes ou transitórios, pagos sob a forma de pensionamento, hospedagem e sustento ou de pagamento em dinheiro, diretamente ou mediante desconto.

Podem os cônjuges pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação (art. 1.694); ou estabelecer livremente tais disposições na ação de separação consensual.

Como dito, renunciar aos alimentos é vedado. Há previsão legal que impede a renúncia aos alimentos, há Súmula do STF 379, que pôs fim a essa discussão Mesmo assim, parte da doutrina admite a possibilidade de renúncia dos alimentos pelo cônjuge.

Accacio Cambi entende que com as inovações legislativas a pendência do pagamento de alimentos entre os cônjuges na decisão que homologa a separação judicial não mais impede a conversão da separação judicial em divórcio como era entendido pela jurisprudência durante a vigência do CC/1916. ⁶⁸³

A natureza consensual da ação de separação contida na jurisdição voluntária exclui qualquer debate sobre a culpa, mesmo para a que a suponha subsistente.

Se aquele que for credor de alimentos contrair novo matrimônio, cessa o dever de prestar alimentos pelo ex-cônjuge nos termos do que estipula o art. 1.708 do CC/2002. ⁶⁸⁴

5.4.3 Guarda dos filhos incapazes e ao regime de visitas

A guarda poderá ser fixada também nos autos da ação separação consensual, podendo ser definida de forma unilateral para um dos genitores ou na forma compartilhada. O art. 1.583 do CC/2002 estabelece que “a guarda será unilateral ou compartilhada”, e “não havendo acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, será aplicada, sempre que possível, a guarda compartilhada”. Entretanto, no divórcio e separação consensuais as cláusulas relativas à guarda do menor devem estar acordadas entre os cônjuges.

No exercício do poder familiar compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos exercer a guarda unilateral ou compartilhada.

Ver item equivalente mais detalhado acima, na ação consensual de divórcio.

5.4.4 Valor da contribuição para criar e educar os filhos

Ainda o CC/2002 prevê que a ruptura entre o casal não modificará os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos (art. 1.579), dever que se centra em promover a manutenção ainda que após a o fim da relação que os gerou (art. 1.709), observado o binômio necessidade e capacidade (art. 1.694, § 1.º) contribuindo para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703), que não se altera com nova união de qualquer dos pais, ou de ambos.

O poder familiar é um direito-dever em que os pais têm alguns deveres, dentre eles dirigir-lhes a criação e a educação dos filhos.

O inc. IV do art. 731 estabelece o que constará das estipulações e indica os alimentos devidos aos filhos menores, ao tratar de “valor da contribuição para criar e educar os filhos”. Os alimentos devidos pelos genitores aos filhos são os alimentos derivados da relação de filiação em que há o exercício do poder familiar nos termos do art. 1.634, inc. I, do CC/2002. ⁶⁸⁵ Trata-se do efeito concreto do *princípio da proteção da prole*. ⁶⁸⁶

Podem os alimentos ser pleiteados por meio de procedimento especial contido na Lei de Alimentos, Lei 5.478/1968, com vantagens procedimentais, ampliação de poderes do juiz, sem obstar que sejam definidos nas ações de separação contenciosas ou consensuais. O par. único do art. 693 do CPC/2015 prevê que a ação de alimentos e a que versar sobre interesse de criança ou de adolescente observarão o procedimento previsto em legislação específica, aplicando-se, no que couber, as disposições deste Capítulo. Nem sempre será necessário seguir a Lei 5.478/1998 (lei especial) ou o Capítulo X, das Ações de Família, típicos modelos conflitivos, para a fixação de alimentos aos filhos, conquanto subsistam meios não contenciosos para esse fim.

Exige-se que, havendo créditos de alimentos em favor de filhos do casal que se separa consensualmente, imperativo que se definam nesse procedimento os alimentos desses filhos e a quem encarece o dever, a forma, a periodicidade e todos os detalhes que de segurança à criança, adolescente ou adulto incapaz.

Ver item equivalente mais detalhado acima, na ação consensual de divórcio.

5.5 Conversão de ação de separação contenciosa em consensual

Procedimentos contenciosos podem se converter em consensuais, sendo dever do juiz, a qualquer tempo tentar a conciliação (art. 139, inc. V), sendo esta uma das proposições políticas legislativas mais evidentes do CPC/2015. É possível que a ação de separação contenciosa se converta, no curso do procedimento, em ação consensual por acordo entre as partes.⁶⁸⁷ O inverso não se tem admitido na ação de divórcio, por considerar-se incompatíveis as diferenças procedimentais, recomendando-se a desistência do interessado da ação consensual e a propositura de outras contenciosas mais adequada.

5.6 As provas

Vem se estreitando o campo probatório nas ações consensuais, mais acordes com a intervenção mínima que despreza fatos da intimidade do casal; no procedimento consensual de separação, se confirma a tendência.

Se não há fato constitutivo do direito de se separar, assim como não há mais prazo de duração do casamento ou prazo de dois anos de separação de fato (EC 66/2010) não há o que perquirir sobre tempos. Para se divorciar basta estar casado e não querer assim permanecer.

A prova da consensualidade se faz pela aposição da assinatura na petição inicial conjunta. Exigem-se documentos para instruir o processo que são associados à existência do vínculo e à legitimidade e identificação pessoal, tais como: documentos pessoais dos interessados (RG e CPF); certidão de casamento atualizada (90 dias). Com vistas a definir outras estipulações podem ser juntados: certidão de nascimento dos filhos tidos na constância do casamento; documentos de registro dos bens imóveis; documentos comprobatórios da propriedade, posse ou alienação fiduciária de bens móveis; documentos que comprovem as dívidas comuns ao casal; declaração de hipossuficiência ou recolhimento de custas; comprovante de renda no caso de hipossuficiente.

A instrução se circunscreve à declaração de que os cônjuges desejam se separar. Ver item equivalente mais detalhado acima, na ação consensual de divórcio.

5.7 Sentença e efeitos

A apelação (art. 1.009) é o recurso da sentença que caracteriza o duplo grau de jurisdição, definido como ato pelo qual o processo se submete a uma dupla fase do juízo de mérito; a sentença se sujeita aos meios impugnativos, só transitando em julgado após o exame desses recursos. E como sentença dos procedimentos de jurisdição voluntária, também está sujeita a recurso de apelação (art. 724), obedecendo aos requisitos *intrínsecos* : cabimento, legitimidade e interesse recursal e *extrínsecos* : tempestividade, regularidade formal e preparo.

O art. 10 do CC/2002 determina que a sentença que decretar a separação judicial devem ensejar sua devida averbação no assento devidamente contido no registro público, pois assim dispõe que: “far-se-á averbação em registro público: I – das sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento, o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal”.

5.8 Postergação da partilha na separação

Se é admitida a postergação da partilha de bens no divórcio, mais razão ainda para isolar da questão relacionada à sociedade conjugal a questão puramente patrimonial relacionada aos bens do casal. O CC/2002 permitiu a possibilidade de ser concedido o divórcio sem que haja prévia partilha de bens entre o casal (art. 1.581). De igual modo aplica-se à separação o art. 731, parágrafo único, que prevê a possibilidade de realização da partilha em outro momento que não nos autos da ação de divórcio consensual, quando não houver acordo entre os cônjuges acerca da partilha dos bens comuns do casal.

A regra do art. 7.º, *caput*, da Lei do Divórcio, Lei 6.515/1977 pode ser atenuada,⁶⁸⁸ postergando-se a partilha na separação. Ao tempo em que for efetivada, seguirá igualmente a regra dos arts. 647 a 658 do CPC/2015, realizada, ação judicial autônoma consensual ou litigiosa ou em procedimento extrajudicial.

5.9 Natureza homologatória da decisão judicial

A homologação consiste na análise judicial que verifica a regularidade formal do acordo entabulado pelas partes, e se estão suficientemente resguardados os interesses da família, nos termos do art. 1.574, parágrafo único do CC/2002. A sentença é reconstitutiva de estado e terá efeitos entre os cônjuges somente a partir do trânsito em julgado, conforme o art. 506 do CPC/2015. Após a averbação da separação judicial na certidão de casamento é que essa terá efeito em relação a terceiros. Com ela efetivamente cessam os deveres conjugais, o regime de bens, sem dissolver propriamente, ainda o vínculo matrimonial.

Art. 732. As disposições relativas ao processo de homologação judicial de divórcio ou de separação consensuais aplicam-se, no que couber, ao processo de homologação da extinção consensual de união estável.

1. Inovações do CPC/2015

Inova o CPC/2015 por aproximar as duas ações extintivas das obrigações do casamento da união estável, que, em razão das semelhanças procedimentais entre si, podem ter o modelo procedimental aproveitado para o “processo de homologação da extinção consensual de união estável”. Se no plano material há equivalência de direitos e obrigações, razoável que o direito processual permita o mesmo procedimento, sem necessariamente descrever todos eles.

2. Aspectos materiais

A união estável foi devidamente reconhecida no texto constitucional de 1988 no art. 226, § 3.º, que dispõe que, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

A Lei 9.278/1996 que regula o § 3.º do art. 226 da Constituição Federal de 1988, que trata de aspectos materiais e procedimentais relativos ao reconhecimento e dissolução de união estável entre companheiros. O art. 1.º da Lei 9.278/1996 determina que é reconhecida como entidade familiar a *convivência duradoura, pública e contínua*, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família.⁶⁸⁹

Para Maria Berenice Dias, o CC/2002 não traz um conceito de união estável, sendo a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) que definiu a família como qualquer relação íntima de afeto. “A união estável nasce da convivência, simples fato jurídico que evolui para a constituição de ato jurídico, em face dos direitos que brotam dessa relação” (...) “por mais que a união estável seja o espaço do não instituído, à medida que é regulamentada ganha contornos de casamento”.⁶⁹⁰

A união estável é considerada uma situação de fato que não se sujeitou a nenhuma solenidade, podendo ser formalizada a qualquer tempo, inclusive antes do seu início, a depender da vontade das partes envolvidas.⁶⁹¹ Se a união estável está reconhecida ou formalizada documentalmente a ação consensual para a sua dissolução não tem como pressuposto a declaração de sua existência. Em contrapartida, se não há o reconhecimento e a iniciativa consensual é de dissolução, antes terá de ser ela confirmada pelas partes e reconhecida no próprio ato homologatório; a descrição fática feita pelos interessados confirma primeiro a existência da relação e, depois, a pretensão de dissolução da união.

Após o reconhecimento da união estável homoafetiva nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132 pelo Supremo Tribunal Federal, é possível o ajuizamento da ação de reconhecimento e dissolução de

união estável entre companheiros heteroafetivos e homoafetivos, conforme decisões reiteradas do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, são competentes para conhecimento e julgamentos das ações de reconhecimento e dissolução de união estável as Varas de Família. ⁶⁹²

A legitimidade para pleito de reconhecimento e dissolução de união estável pertence aos companheiros, exclusivamente, não podendo terceiros alheios à relação requererem o reconhecimento e a dissolução, uma vez que o núcleo central motivador da ação é o dial de constituição de família, nesse sentido indica jurisprudência do STJ. ⁶⁹³

3. Aspectos materiais da partilha de bens, alimentos, visitas, despesas de educação, nome etc. na extinção consensual da união estável

Os requisitos materiais na ação de extinção de união estável seguem a mesma linha de raciocínio que se formula para as ações de divórcio e separação tratadas acima. Uma das diferenças reside na fixação do regime de bens aplicado às uniões estáveis.

3.1 Ação de extinção consensual de união estável

A redação do CPC/2015 trata apenas acerca da extinção da união estável, e nada diz acerca do procedimento relativo ao reconhecimento da união estável, razão pela qual se questiona se o reconhecimento deverá ser feito por meio de procedimento comum, ainda que consensual, e a dissolução ou extinção deve seguir o trâmite do procedimento especial.

O regime de bens aplicados à união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, é o regime de comunhão parcial de bens, nos termos dos arts. 1.658-1.666, conforme prescreve o art. 1.725 do CC/2002. Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato escrito, nos termos do art. 5.º da Lei 9.278/1996.

3.2 Aspectos processuais e procedimentais

A sentença extintiva da união estável não será desconstitutiva de estado, mas meramente declaratória de um fato proclamado pelas partes, qual seja, a existência de união estável no período informado, sem prejuízo dos efeitos próprios às demais cláusulas do acordo, segundo Denise Damo Comel. Poderá ser registrada perante o registro civil das pessoas naturais, mas com efeitos apenas entre os companheiros”. ⁶⁹⁴ A facultatividade do registro tanto da sentença declaratória de reconhecimento e dissolução ou extinção está prevista no Provimento CNJ 37, arts. 1.º e 2.º.

Portanto, os dispositivos aplicados ao divórcio e à separação consensuais serão aplicados no que couberem ao procedimento da extinção da união estável. “A equiparação da união estável ao casamento justifica a adoção de regras do art. antecedente (art. 731), aplicáveis praticamente na integralidade”. ⁶⁹⁵

3.3 Legitimidade

Igualmente à separação consensual e ao divórcio consensual, para o processo de homologação da extinção consensual de união estável o CPC/2015 não indica a legitimidade e o CC/2002 não menciona a hipótese de extinção, restringindo-se aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos (art. 1.724) ou o que mais tiver sido estipulado em contrato (art. 1.725).

Desse modo, só se pode cogitar de que os interessados a propor o procedimento de jurisdição voluntária serão os próprios companheiros, acompanhado de advogado. Descabe a proposição unilateral, seja em vida ou após a morte de um dos companheiros, ⁶⁹⁶ pois impossível a convergência de vontades para a manifestação da consensualidade essencial ao procedimento.

3.4 Competência

Também para as ações de dissolução de união estável o art. 53, I do CPC/2015 redefine com mais igualdade a competência territorial jurisdicional para atuação nos casos de ações de família. Pela regra é competente o foro para a ação contenciosa de separação aquele de domicílio do guardião de filho incapaz ou o foro do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz, aplicável às ações consensuais ou, ainda, o domicílio de qualquer dos interessados do casal, igualmente ao divórcio.

No entanto, no caso das ações consensuais poderá haver negócio sobre a competência relativa devido à convergência dos interessados em ajuizarem a ação em comarca diversas daquelas mencionadas no art. 53 do CPC/2015. A competência de foro para julgamentos dos casos relativos às ações de dissolução de união estável será das Varas de Família como indicava a Lei 9.278/1996 (art. 9.º). ⁶⁹⁷

3.5 Petição inicial assinada pelos interessados e advogado

Para o processo de homologação da extinção consensual de união estável se supõe a concordância de ambos os companheiros, justificando a manifestação expressa na petição inicial da ação que deverá ir a juízo firmada por ambos e pelo advogado, além de estar instruída com documentos essenciais com certidão de casamento; contrato antenupcial se houver; a descrição dos bens do casal e a respectiva partilha (dos bens e das dívidas se houver); o acordo relativo à guarda dos filhos menores e o regime de visitas se houver filhos comuns ao casal; a pensão alimentícia a ser prestada por um dos genitores; a pensão alimentícia a cônjuge (art. 731, *caput*, c/c art. 732). Entende-se que esse ato pode ser irretratável, por ter conteúdo de transação sobre direitos disponíveis, não permitindo o arrependimento de qualquer das partes. ⁶⁹⁸

A *causa de pedir* é a proteção dada pelo ordenamento aos envolvidos, companheiros e filhos e a preservação de seus direitos recíprocos; ⁶⁹⁹ o *pedido* é de declaração ou confirmação da existência da união e de sua dissolução, com a homologação das estipulações comuns e a ordem de registro e anotações correspondentes.

3.6 O objeto do processo ou conteúdo

O art. 732 c/c o art. 731 do CPC/2015 permite identificar as matérias que podem ser objeto deste procedimento de jurisdição voluntária que se destina à homologação da extinção consensual de união estável, tais como: partilha de bens comuns; alimentos entre os cônjuges; acordo relativo à guarda dos filhos incapazes e regime de visitas e alimentos devidos aos filhos.

3.6.1 Disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns

Combinados o art. 732 com o art. 731, *caput*, pode-se inferir que no processo de homologação da extinção consensual de união estável na petição assinada por ambos os cônjuges constarão as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns.

Os efeitos de natureza patrimonial da união estável são equivalentes aos dos regimes comunitários, nos termos do art. 1.725 do CC/2002, destaca-se a formação do acervo comum, ressalvada a hipótese da adoção no casamento”. ⁷⁰⁰

A partilha de bens comuns refere-se primeiramente à necessidade de se pontuar o regime de bens e a data de sua vigência para posterior verificação de quais bens consubstanciam os bens comuns dos cônjuges. Não houve grandes alterações no tema, o termo novo adotado é o “bem comum”. Bens comuns aos companheiros são aqueles em que há direitos de posse ou de propriedade por ambos os litisconsortes, sendo constituído verdadeiro condomínio ou composses entre eles. A definição dos bens comuns seguirá comunhão parcial de bens. Pode a cessão de bens aos filhos evitar a partilha e caracterizar-se como escritura pública de doação hábil ao registro. ⁷⁰¹

Ver item equivalente mais detalhado acima, na ação consensual de divórcio.

3.6.2 Disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges

Podem os companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação (art. 1.694); ou estabelecer livremente tais disposições na ação que busca a homologação da extinção da união estável.

Guardam as mesmas características nas relações de companheirismo e se sujeitam a características da reciprocidade, inalienabilidade, impenhorabilidade, irrenunciabilidade, irrepetibilidade e transmissibilidade. Assim, vedada a renúncia aos alimentos em vista da lei (CC/2002, art. 1.707) e da Súmula 379 do STF, que pôs fim a essa discussão estatuidando que “não se admite renúncia aos alimentos que poderão ser pleiteados ulteriormente verificados os pressupostos legais”.

Pela simetria com as relações de casamento, cessa o dever de prestar alimentos pelo ex-companheiro se aquele que for credor de alimentos contrair nova união, seja concubinária, estável ou casamento (art. 1.708 do CC/2002).

3.6.3 Guarda dos filhos incapazes e ao regime de visitas

O art. 732 c/c o art. 731 do CPC/2015 permite identificar as matérias que podem ser objeto deste procedimento de jurisdição voluntária, incluindo a guarda que poderá ser fixada também nos autos dessa ação, podendo igualmente aos casos análogos ser definida de forma unilateral para um dos genitores ou na forma compartilhada. No exercício do poder familiar compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos, exercer a guarda unilateral ou compartilhada.

Ver item equivalente mais detalhado acima, na ação consensual de divórcio.

3.6.4 Valor da contribuição para criar e educar os filhos

Havendo dever ou créditos de alimentos em favor de filhos do casal que deseja a dissolução da união estável, imperativo que se definam nesse procedimento os alimentos desses filhos e a quem encarece o dever, a forma, a periodicidade e todos os detalhes que deem segurança à criança, ao adolescente ou ao adulto incapaz.

Ainda o CC/2002 prevê que a ruptura entre o casal não modificará os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos (art. 1.579), dever que se centra em promover a manutenção ainda que, após o fim da relação que os gerou (art. 1.709), observado o binômio necessidade e capacidade (art. 1.694, § 1.º) contribuindo para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703), que não se altera com nova união de qualquer dos pais, ou de ambos.

O poder familiar é um direito-dever em que os pais têm alguns deveres, dentre eles dirigir-lhes a criação e a educação dos filhos.

O inc. IV do art. 731 estabelece o que constará das estipulações e indica os alimentos devidos aos filhos menores, ao tratar de “valor da contribuição para criar e educar os filhos”. Os alimentos devidos pelos genitores aos filhos são os alimentos derivados da relação de filiação em que há o exercício do poder familiar nos termos do art. 1.634, I, do CC/2002. ⁷⁰²

Podem os alimentos ser pleiteados por meio de procedimento especial contido na Lei de Alimentos, Lei 5.478/1968, com vantagens procedimentais, ampliação de poderes do juiz, sem obstar que sejam definidos nas ações de separação contenciosas ou consensuais. O parágrafo único do art. 693 do CPC/2015 prevê que a ação de alimentos e a que versar sobre interesse de criança ou de adolescente observarão o procedimento previsto em legislação específica, aplicando-se, no que couber, as disposições deste Capítulo. Nem sempre será necessário seguir a Lei 5.478/1968 (lei especial) ou o Capítulo X, das Ações de Família, típicos modelos conflitivos, para a fixação de alimentos aos filhos, conquanto subsistam meios não contenciosos para esse fim. Ver item equivalente mais detalhado acima, na ação consensual de divórcio.

3.7 Conversão de ação comum em ação especial consensual

De regra, os procedimentos contenciosos podem se converter em consensuais, sendo dever do juiz, a qualquer tempo tentar a conciliação (art. 139, V), sendo esta uma das proposições políticas legislativas mais evidentes do CPC/2015. A ação comum que objetive a extinção de modo contencioso da união estável pode se converter em ação para a homologação da extinção consensual dessa mesma. ⁷⁰³ É possível que no curso da ação litigiosa convirjam as partes e se torne consensual o procedimento. As regras de direito intertemporal não preveem esta hipótese, mas ela é aplicável após a criação do procedimento especial consensual.

3.8 As provas

Menor ainda será o âmbito probatório na ação consensual de dissolução da união estável, porquanto o livre desejo de unirem-se corresponde, findo o afeto, ao livre desejo de extinguirem a união.

A prova correspondente às estipulações relativas a deveres recíprocos e a deveres com os filhos podem induzir à necessidade de prova desses vínculos de filiação. Também, se houver estipulação

patrimonial, serão necessários os documentos probatórios da existência do patrimônio a partilhar ou sobre o qual se confere direitos reais limitados.

3.9 Sentença e efeitos

É a apelação (art. 1.009) o recurso da sentença e que caracteriza o duplo grau de jurisdição, definido como “princípio segundo o qual o processo se submete a uma dupla fase do juízo de mérito”.⁷⁰⁴ Ato decisório final do procedimento, qualquer que seja, a sentença se sujeita aos mesmos riscos e meios de ser atacada por recurso só transitando em julgado após o exame desses recursos. E como sentença dos procedimentos de jurisdição voluntária, também está sujeita a recurso de apelação (art. 724), obedecendo aos requisitos *intrínsecos* : cabimento, legitimidade e interesse recursal e *extrínsecos* : tempestividade, regularidade formal e preparo.

A sentença proferida no âmbito das ações de homologação da extinção da união estável pode ser registrada para fins de publicidade.

3.10 Postergação da partilha

Aplica-se analogicamente à ação de homologação da extinção da união estável o que se prevê para o divórcio, quanto à possibilidade de postergação da partilha de bens. O CC/2002 permitiu a possibilidade de ser concedido o divórcio sem que haja prévia partilha de bens entre o casal, o art. 1.581 assim dispõe: “o divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens”. Assim, pode-se homologar a extinção da união estável, sem que se tenha efetivado a partilha combinando o art. 732 com o art. 731, *caput* .

Quando for efetivada a partilha, seguirá igualmente a regra dos arts. 647 a 658 do CPC/2015, se realizada em ação judicial autônoma consensual ou litigiosa ou, também, em procedimento extrajudicial. Ver item equivalente mais detalhado acima, na ação consensual de divórcio.

3.11 Natureza homologatória da decisão judicial

O art. 732 do CPC/2015 prevê que: “as disposições relativas ao processo de homologação judicial de divórcio ou de separação consensuais aplicam-se, no que couber, ao processo de homologação da extinção consensual de união estável”.

Art. 733 . O divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual de união estável, não havendo nascituro ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições de que trata o art. 731.

§ 1.º A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras.

§ 2.º O tabelião somente lavrará a escritura se os interessados estiverem assistidos por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial.

1. Aspectos materiais do divórcio, separação e da união estável em via extrajudicial

Como dito no *Breve Ensaio Inicial* a política de dualidade procedimental judicial e extrajudicial contempla a tentativa de *deformalização* de controvérsias, diante da crise da justiça civil, como apontado há muito por Ada Pellegrini Grinover⁷⁰⁵ e outros autores.

A modalidade extrajudicial está prevista no art. 733 do CPC/2015, que estabelece a possibilidade de o divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual de união estável, não havendo nascituro ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, serem realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições sobre descrição e partilha dos bens comuns, pensão alimentícia entre os cônjuges, o acordo relativo à guarda dos filhos, regime de visitas e o valor da contribuição para criar e educar os filhos.

A redação do art. 733 mantém a mesma lógica normativa do art. 1.124-A do CPC/1973, incluído pela Lei 11.441/2007, que possibilitava a separação consensual e o divórcio consensual, desde que não houvesse filhos menores ou incapazes do casal e fossem observados os requisitos legais quanto aos prazos, para também estabelecer disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à

manutenção do nome adotado quando se deu o casamento. Após isso o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reordenou a hipótese pela Resolução CNJ n. 35/2007, alterada pela Resolução CNJ 120. ⁷⁰⁶

O CPC/2015 inovou ao trazer como restrição para a modalidade extrajudicial de divórcio, separação e extinção da união estável a preexistência do nascituro, como alertara a doutrina. O art. 1.124-A do CPC/1973, reformado em 2007, quanto à limitação exclusivamente nos casos de filhos menores ou incapazes do casal. Essa inovação reflete a proteção aos direitos do nascituro já abarcados em diversos dispositivos no CC/2002 em que “a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, nos termos do art. 2.º do Código mencionado.

Para Christiano Cassettari, mesmo antes da entrada em vigor do CPC/2015, entendia-se pela impossibilidade de realização das modalidades extrajudiciais aqui analisadas, haja vista que o CC/2002 resguarda os direitos do nascituro, uma vez que o nascituro pode pleitear alimentos antes mesmo do seu nascimento com vida. “Isso demonstra que o nascituro possui direitos a serem tutelados, motivo pelo qual se faz necessária a utilização da via judicial, uma vez que a intervenção do Ministério Público será obrigatória”. ⁷⁰⁷

Essas modalidades extrajudiciais são formalizadas em cartório, devendo ser devidamente averbadas as respectivas extinções de vínculos junto à certidão de casamento, sendo assim, o registro da escritura pública de separação e divórcio no tabelionato de notas deve ser averbado junto ao assento de casamento do Cartório de Registro Civil em que a respectiva certidão esteja devidamente registrada, na forma na interpretação analógica do art. 10, I, do CC/2002 que dispõe sobre a necessidade de registro. ⁷⁰⁸ Esse procedimento está devidamente regulado no art. 40 da Resolução 35 do CNJ que estabelece: “o traslado da escritura pública de separação e divórcio consensuais será apresentado ao Oficial de Registro Civil do respectivo assento de casamento, para averbação necessária, independente de autorização judicial e de audiência do Ministério Público”.

É necessário ressaltar que a escritura deve ser apresentada também junto ao registro de imóveis para a promoção de averbação da respectiva partilha dos bens anteriormente comuns ao casal, determinando-se o direito de propriedade para os ex-cônjuges de acordo com a partilha acordada.

1.1 Aspectos procedimentais notariais

Dentre os aspectos relevantes da modalidade extrajudicial estão a competência, a legitimidade, o “pedido inicial” dirigido ao titular do Cartório e documentos. ⁷⁰⁹

1.1.1 Competência

A escrituração dessas medidas não segue a regra de competência estabelecida no art. 53 do CPC/2015, pelo contrário, a escritura pode ser formalizada em qualquer tabelionato de notas nos termos do que dispõe o art. 1.º da Resolução CNJ 35: “para a lavratura dos atos notariais de que trata a Lei no 11.441/2007, é livre a escolha do tabelião de notas, não se aplicando as regras de competência do Código de Processo Civil” e art. 8.º da Lei 8.935/1994: “é livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou o lugar de situação dos bens objeto do ato ou negócio”.

1.1.2 Legitimidade

Ao caso aplica-se a lógica do art. 1.576, parágrafo único, do CC/2002 que determina que: “a separação judicial põe termo aos deveres de coabitação e fidelidade recíproca e ao regime de bens. Parágrafo único. O procedimento judicial da separação caberá somente aos cônjuges, e, no caso de incapacidade, serão representados pelo curador, pelo ascendente ou pelo irmão”. Caso a extinção do vínculo fosse feito na modalidade extrajudicial envolvendo cônjuge incapaz, geraria situação de flagrante nulidade relativa, nos termos do art. 4º, inc. III, do CC/2002: “são incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade” e art. 171, I, do mesmo Código: “Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: I - por incapacidade relativa do agente”.

Haja vista que o divórcio, separação ou extinção da união estável extrajudiciais demandam a expressão volitiva das partes, entende-se que mesmo o incapaz devidamente representado poderia pleitear a extinção do vínculo, no entanto, ao tratar de incapaz a modalidade de divórcio, separação e extinção de união estável consensuais devem ser propostas especificamente junto ao Judiciário, uma vez que é necessária a atuação escrita de membro do Ministério Público nos termos do art. 178, II, do

CPC/2015, prevê a intervenção quando houver interesse de incapaz,⁷¹⁰ incorrendo em flagrante nulidade processual caso o Ministério Público não atue no processo, conforme redação do art. 84 do CPC/1973,⁷¹¹ embora sem equivalente no CPC/2005, produzirá do mesmo modo a mesma nulidade.

Ademais, importante salientar que se deve concordar com Christiano Cassettari, no sentido de compreender a possibilidade de atuação dos cônjuges por procuração nas modalidades extrajudiciais de divórcio, separação e extinção de união estável, uma vez que “entendemos que não é indispensável o comparecimento pessoal das partes à lavratura de escritura pública de separação e divórcio consensuais, sendo admissível ao(s) separando(s) ou ao(s) divorciando(s) se fazer(em) representar por mandatário constituído, desde que por instrumento público, com poderes especiais para a realização do ato”.⁷¹² Segue-se, portanto, a lógica do art. 657 do CC/2002 e o art. 36 da Resolução CNJ 35 que estabelecem.⁷¹³

1.1.3 Competência para registro

A competência para registro do divórcio extrajudicial é do cartório de registro de pessoas civis em que foi registrado o casamento. A averbação do divórcio na matrícula dos imóveis para promoção da partilha de bens é o cartório em que se encontram registrada as respectivas matrículas dos bens imóveis a serem partilhados entre os ex-cônjuges. Importante lembrar que antes da averbação é necessária a escrituração da separação, divórcio e extinção de união estável junto ao Cartório de Notas.

1.1.4 Gratuidade das escrituras de separação, divórcio e extinção de união estável

O art. 733 não traz a previsão da gratuidade em face das taxas cartorárias para escrituração da separação, divórcio e extinção da união estável. No entanto, o § 3.º do art. 1.124-A do CPC/1973 previa que a escritura e demais atos notariais seriam gratuitos àqueles que se declararem pobres sob as penas da lei. Judicialmente a gratuidade é medida que se prevê nos casos estipulados no art. 98 e ss. do CPC/2015, portanto, tal direito não poderia ser afastado da modalidade extrajudicial dentro do Estado Social de Direito.

Para Christiano Cassettari, a possibilidade de concessão de gratuidade nesses casos segue a lógica do art. 1.512, *caput* e parágrafo único, do CC/2002, pois há previsão expressa acerca da gratuidade para as pessoas que tenham estado de pobreza declarado.⁷¹⁴ Portanto, a adoção do casamento, bem como a sua extinção ou dissolução da união estável poderão ser viabilizados extrajudicialmente sem cobrança de taxas diante da comprovação da hipossuficiência dos interessados. Deve-se observar que, nos termos do art. 7.º da Resolução CNJ 35, é necessária a declaração.⁷¹⁵

1.1.5 Pedido inicial e dispensa da assinatura dos interessados e advogado

O CPC/2015 manteve, como visto, a possibilidade de realização extrajudicial de separação ou divórcio do CPC/1973.

Ao contrário do procedimento especial de jurisdição voluntária equivalente, que requer a assinatura dos interessados, o “pedido inicial” extrajudicial não faz essa exigência, devendo ser instruído com assinatura de advogado ou defensor público.

Conforme constava no § 1.º do art. 1.124-A do CPC/1973, a escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para o registro civil e o registro de imóveis.

O advogado ou defensor público não pode ser indicado pelo Tabelião, conforme entendimento defendido por Christiano Cassettari, tomando como fundamento o art. 9.º da Resolução CNJ e arts. 4.º, 28, IV, e 34 do Estatuto da Advocacia, Lei 8.906/1994.⁷¹⁶

1.1.6 Recusa do tabelião de notas, meios impugnativos e ação de procedimento contencioso

É possível a recusa pelo tabelião de notas, em caso de desatendimento a requisitos ou formalidades (art. 156, Lei 6.015/1973). Havendo recusa do tabelião de notas para lavrar a escritura de divórcio, separação ou extinção de união estável consensual, por incerteza na viabilidade da modalidade, pode o tabelião de notas submeter a dúvida ao juiz, para que este a redima e declare possível ou não a lavratura da escritura; medida, seria recorrer à Corregedoria do Tabelionato, com o fim de obter nova avaliação do caso.⁷¹⁷ Após isso, pode-se cogitar de impetração de Mandado de Segurança para proteção do direito líquido e certo dos impetrantes. Caso a situação não seja resolvida, e reste inviabilizada a escrituração, a opção dos interessados é ajuizar a ação judicial de divórcio, separação ou extinção de união estável

consensual, conforme regulamentação dos arts. 731 e 732 do CPC/2015 e art. 2.º da Resolução CNJ 35: “é facultada aos interessados a opção pela via judicial ou extrajudicial; podendo ser solicitada, a qualquer momento, a suspensão, pelo prazo de 30 dias, ou a desistência da via judicial, para promoção da via extrajudicial”.

1.1.7 Requisitos e documentos exigidos

São requisitos para lavratura da escritura pública de separação consensual: a) um ano de casamento; b) manifestação de vontade espontânea e isenta de vícios em não mais manter a sociedade conjugal e desejar a separação conforme as cláusulas ajustadas; c) ausência de filhos menores não emancipados ou incapazes do casal; ⁷¹⁸ d) inexistência de gravidez do cônjuge virago ou desconhecimento acerca desta circunstância; e e) assistência das partes por advogado, que poderá ser comum (art. 47 da Resolução CNJ 35/2007). ⁷¹⁹ A lei não trata da possibilidade de pedido extrajudicial na pendência de processo judicial, com o mesmo fim, matéria regulada por alguns tribunais estaduais, com a exigência de suspensão da via judicial, evitando-se o simultâneo tratamento à mesma questão.

São documentos necessários para a lavratura da escritura de separação, divórcio e no que couber à extinção de união estável junto ao Tabelionato de Notas: certidão de casamento atualizada dos cônjuges (90 dias); documento de identidade pessoal e número de Cadastro de Pessoa Física expedido (CPF) pelo Ministério da Fazenda de ambos os cônjuges; pacto antenupcial (se houver); certidão de nascimento ou documento de identidade oficial dos filhos capazes (se houver); certidão de propriedade de bens imóveis e direitos a ele relativos se for feita a partilha ou declaração de inexistência de bens a serem partilhados; documentos necessários à comprovação da titularidade dos bens móveis e direito de for feita a partilha, ou declaração de inexistência de bens móveis a serem partilhados; declaração de que os bens serão partilhados em momento futuro; comprovante de pagamento de ITBI – imposto de transmissão de bens *inter vivos* (se for o caso); identificação dos advogados por meio da cópia da carteira da OAB; valor da pensão alimentícia, ou a renúncia dos cônjuges, ou a declaração de que a fixação de alimentos será definida em momento posterior; declaração do cônjuge para retomada ou não do nome de solteiro. ⁷²⁰

No caso de conversão de separação judicial em divórcio, é necessário apresentar, além dos já mencionados, as seguintes documentações: certidão de casamento com averbação da separação feita em Cartório de Registro Civil; ⁷²¹ certidão de sentença de separação judicial, ou da liminar de separação de corpos, ou da escritura da separação extrajudicial; e averbação da separação no respectivo assento de casamento. ⁷²²

2. Dispensa da homologação judicial

Ao estabelecer no § 1.º do art. 733 que “a escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras” é nítido o propósito *deformalizador*. Estabelecer a via extrajudicial como alternativa à judicialização ou técnica de deformalização e, ao mesmo tempo, impor como requisito à plenitude dos efeitos a homologação seria um absoluto contrassenso. ⁷²³

O art. 3.º da Resolução CNJ 35 é claro ao determinar a desnecessidade de homologação judicial da separação e do divórcio extrajudiciais, o que se aplica por analogia à extinção da união estável. ⁷²⁴

3. O objeto limitado da via extrajudicial

O divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual da união estável, não havendo nascituro ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições de que trata o art. 731. Ficam excluídos, portanto, dessa possibilidade extrajudicial todas as hipóteses em que houver filhos menores e nascituro, além da hipótese de alteração do regime de bens do casamento.

3.1 Disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns

A partilha de bens não é requisito para se proceder a extinção dos vínculos aqui informados, assim como não é para a realização da separação, divórcio de extinção da união estável pela via judicial, haja vista que o art. 1.581 do CC/2002 informa que a partilha de bens pode ser realizada em ação autônoma, qual seja a ação de sobrepartilha. No entanto, é importante que a escritura de divórcio, separação ou extinção de união estável informe que a partilha de bens será promovida em outro momento, devendo, se possível, descrever os bens que estão em composses ou em condomínio. Podendo, inclusive, ser feita,

em momento futuro, escritura “somente para promover a partilha dos bens do casal, separados ou divorciados, por escritura ou judicialmente, desde que haja consenso entre as partes”.⁷²⁵ Pode a cessão de bens aos filhos evitar a partilha e caracterizar-se como escritura pública de doação hábil ao registro.⁷²⁶ Possível também a renúncia à meação, desde que formalizado.⁷²⁷

No mesmo sentido dispõe o parágrafo único do art. 732 do CPC/2015: “se os cônjuges não acordarem sobre a partilha dos bens, far-se-á esta depois de homologado o divórcio, na forma estabelecida nos arts. 647 a 658”.

3.2 Disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges

Acompanha-se o entendimento de que a fixação de alimentos na escritura também não consiste em requisito da lavratura da escritura de separação, divórcio e extinção de união estável consensuais e extrajudiciais, no entanto, ainda que pese esteja expressa a possibilidade no inc. II do art. 731 do CPC/2015. Segundo Christiano Cassettari, a fixação dos alimentos pode ser estabelecida em momento posterior, seja por escritura pública ou pela via judicial, podendo ainda ser renunciada a fixação pelos cônjuges nos termos do art. 1.707 e Enunciado 263 do CJP: “o art. 1.707 do CC não impede seja reconhecida válida e eficaz a renúncia manifestada por ocasião do divórcio (direito ou indireto) ou da dissolução da união estável. A irrenunciabilidade do direito a alimentos somente é admitida enquanto subsista vínculo de Direito de Família”, portanto, não sendo aplicada a irrenunciabilidade entre os ex-cônjuges.⁷²⁸

3.3 Guarda dos filhos e ao regime de visitas e valor da contribuição para criar e educar os filhos

Para Christiano Cassettari, é possível a fixação por escritura de alimentos devidos aos filhos maiores, no entanto, tal possibilidade estaria inviabilizada em relação aos filhos menores de idade, isso devido à necessidade de atuação do Ministério Público nos termos do que dispõe o art. 178, II, do CPC/2015. Tal situação também se aplica ao caso de regularização da guarda e regulamentação de visitas dos filhos menores.

O óbice também é trazido pelo próprio art. 733 de forma literal: “o divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual de união estável, não havendo nascituro ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições de que trata o art. 731”.

3.4 Modificação consensual extrajudicial de cláusulas e anulação de acordo extrajudicial

Não se pode cogitar de uma vedação absoluta à modificação das cláusulas estabelecidas nos acordos extrajudiciais por novos acordos extrajudiciais realizados por escritura pública em serviços notariais. Ainda que se deva preservar a estabilidade das relações, a autonomia e vontade das partes permitem, por consenso, novas e sucessivas alterações.⁷²⁹

A desconstituição do acordo homologado extrajudicialmente pode se dar por outro acordo extrajudicial que o substitua e crie novas cláusulas e deveres, havendo consenso entre as partes, mas não por procedimento judicial consensual; nas hipóteses não consensuais deve ser considerada a preclusão.⁷³⁰

Outra é a hipótese de anulação por vícios, sujeitas a prazo decadencial de 4 (quatro) anos (art. 178, CC/2002).⁷³¹ A desconstituição do acordo extrajudicial, havendo vícios e conflito posterior entre os acordantes, dar-se-á por ação declaratória de nulidade forma hábil de desconstituir atos de disposição de vontade; se a homologação desse ato tiver sido em juízo, hábil seria a ação anulatória (art. 966, § 4.º), embora tenham as ações o mesmo objetivo.

Art. 734 . A alteração do regime de bens do casamento, observados os requisitos legais, poderá ser requerida, motivadamente, em petição assinada por ambos os cônjuges, na qual serão expostas as razões que justificam a alteração, ressalvados os direitos de terceiros.

§ 1.º Ao receber a petição inicial, o juiz determinará a intimação do Ministério Público e a publicação de edital que divulgue a pretendida alteração de bens, somente podendo decidir depois de decorrido o prazo de 30 (trinta) dias da publicação do edital.

§ 2.º Os cônjuges, na petição inicial ou em petição avulsa, podem propor ao juiz meio alternativo de

divulgação da alteração do regime de bens, a fim de resguardar direitos de terceiros.

§ 3.º Após o trânsito em julgado da sentença, serão expedidos mandados de averbação aos cartórios de registro civil e de imóveis e, caso qualquer dos cônjuges seja empresário, ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins.

1. Inovações do CPC/2015

Inova integralmente o CPC/2015, ao criar modalidade processual própria, consensual, para a finalidade materialmente prevista no CC/2002, de alteração do regime de bens do casamento.

2. Aspectos materiais da alteração do regime de bens do casamento

O CC/2002 alterou a regra do CC/1916 que considerava irrevogável o regime de bens do casamento. A partir do CC/2002 o § 2.º do art. 1.639 prevê que: “é admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros”.

Há também limites materiais e consequentemente processuais que deverão ser impostos, como aqueles relativos às pessoas que se submetem permanentemente ao regime obrigatório, indicada no art. 1.641 do CC/2002.⁷³² Quanto às causas que possam cessar, como o suprimento judicial ou a hipótese de um cônjuge ser o curador do outro cônjuge interditado (arts. 1.775 do CC/2002) e, ainda, nas causas suspensivas do casamento (art. 1.523 do CC/2002), a vedação só tem o sentido de impedir a modificação do regime de bens enquanto persistir a proibição. Havendo causa superveniente que faça cessar a interdição, por exemplo, desaparece a vedação à modificação consensual do regime de bens, podendo ser alterado judicialmente o regime de bens.

Desde a edição do CC/2002, além da ampla disposição prévia sobre os bens, é permitido estipular regime de bens que se lhes aprouver (art. 1.639), exceção feita aos maiores de setenta anos (art. 1.641, II) e aos que dependerem de suprimento judicial para casar (art. 1.641, III), bem como as que contraírem matrimônio com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento estipuladas contidas no art. 1.523 do CC/2002 (art. 1.641, I).⁷³³ Essa liberdade, observadas as limitações mencionadas, também se estende à possibilidade de “alteração do regime de bens”, realizada por meio de autorização judicial, em “pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros” (art. 1.639, § 2.º).

Segundo José Lamartine Correa de Oliveira e Francisco José Ferreira Muniz, nas suas origens, o princípio da imutabilidade da convenção antenupcial se justificava com a ideia de que tais convenções eram pactos de famílias. No direito moderno tal justificativa não é mais aceita. Também se utilizou o argumento de que haveria necessidade de evitar que um dos cônjuges influenciasse o outro para que o regime de bens fosse alterado e assim lhe beneficiar. E ainda, essa proibição tinha a justificativa de proteger terceiros, tal como os credores desatentos à alteração do regime.⁷³⁴

Rompia-se a partir de então uma tradição de imutabilidade quase completa no regime de bens do casamento.⁷³⁵ A “irrevogabilidade” do regime de bens no CC/1916 se justificava, segundo Clóvis Beviláqua, por duas razões: o risco de um cônjuge abusar da fraqueza do outro e a proteção do interesse de terceiros credores.⁷³⁶ Abre-se o caminho acolhendo o *princípio da mutabilidade controlada do regime de bens*.⁷³⁷

A permissão não alcança, por óbvio, o regime obrigatório de separação de bens; mas pode ser feita de um regime de comunicação de bens para outro de não comunicação e vice-versa.

No entanto, a justificativa quanto à alteração não necessita ser exagerada e complexa, bem como não se deve exigir a prova do prejuízo causado pela manutenção do regime de bens originários sob pena de investigar a própria vida íntima dos cônjuges, nesse sentido postulou o Superior Tribunal de Justiça.⁷³⁸ Portanto são requisitos essenciais para a propositura da ação de alteração de regime: a consensualidade entre os cônjuges com as respectivas assinaturas constantes na petição inicial; o pedido motivado para alteração do regime de bens e a autorização judicial, tendo em vista o resguardo do direito de terceiro (art. 734, § 2.º, CPC/2015). Mas não pode ser superficial a ponto de não permitir a identificação das razões efetivas.

José Tadeu Neves Xavier entende que “poderia a codificação civil ter repassado este procedimento, de

perfil eminentemente administrativo, para a via extrajudicial, como o ocorre em relação à modificação incidental do regime patrimonial na união estável. Levando-se em consideração a capacidade civil dos cônjuges, o caráter disponível de suas relações patrimoniais e a total ausência de controvérsia sobre a intenção de adoção de novo regime patrimonial do casal, caberia perfeitamente que essa alteração do estatuto econômico do casamento ocorresse exclusivamente na via cartorária, de forma, portando, extrajudicial, ou que pelo menos fosse facilitado aos cônjuges esta possibilidade como alternativa a via jurisdicional, como ocorre atualmente em relação ao divórcio e ao inventário. Estas hipóteses estariam em perfeita consonância com o ideal de um Direito Civil atualizado e em compasso com as aspirações de um sistema jurídico que combine a forma e a eficiência”.⁷³⁹ Nesse mesmo sentido compreendem outros autores, quando alegam que “não se justifica que a alteração do regime de bens, solicitada por duas pessoas capazes, deve ser feita judicialmente. Se há acordo quanto à mudança do regime e se os interesses de terceiros estão resguardados por força de lei, não há porque objetar o procedimento simples, rápido, desjudicializado, que desafoga o Judiciário e dá resposta mais rápida às questões eminentemente pessoais e patrimoniais”.⁷⁴⁰

A vedação da via extrajudicial tem sentido porque é essencial a análise judicial das razões do pleito de alteração, sendo imprescindível a atuação do Ministério Público no intuito de resguardar direitos de terceiros.

3. Aspectos processuais e procedimentais

É expressa a necessidade do pedido de alteração do regime de bens entre os cônjuges junto ao Poder Judiciário, sendo inequívoca a impossibilidade de realização da alteração extrajudicial, uma vez que, nos itens em que o Legislador entendeu cabível o procedimento cartorário nos demais procedimentos, como divórcio, separação e extinção da união estável consensuais, a previsão é expressa. Caso houvesse interesse no procedimento extrajudicial de alteração, assim o teria feito o legislador do Código Processual.

Desse modo, é de se tratar dos aspectos processuais a serem abordados, tal como a legitimidade, competência, petição inicial e seus requisitos, necessidade de instrução e prova das alegações, sentença e sua publicidade e recursos.

3.1 Legitimidade para a proposição

Seguindo a mesma lógica do art. 1.639, § 2.º, do CC/2002 que considera “admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros”, e o *caput* do art. 734 no qual se dispõe que “a alteração do regime de bens do casamento, observados os requisitos legais, *poderá ser requerida, motivadamente, em petição assinada por ambos os cônjuges*, na qual serão expostas as razões que justificam a alteração, ressalvados os direitos de terceiros” permite afirmar que o pedido de alteração do regime é exclusivo de ambos os cônjuges. Requer-se aqui, por óbvio, ampla capacidade dos cônjuges, para que manifestem suas vontades, não se admitindo para pessoas sujeitas à curatela decorrente de interdição que vede tal alteração.⁷⁴¹ Exceção a hipotética situação só pode ser admitida no campo das pessoas com deficiência que, pela tomada de decisão apoiada (TDA), se amparem em outras para a alteração do regime.⁷⁴²

No entanto, para a definição da legitimidade para postulação na ação de alteração de regime de bens, aplica-se o art. 1.582 do CC/2002, em que a legitimidade é exclusiva dos cônjuges, com exceção da presença de incapaz que poderá ser representado por curador, ascendente ou irmão.

Segundo José Tadeu Neves Xavier, ainda na vigência do CPC/1973, sustentava que as normas aplicadas ao procedimento para modificação do regime patrimonial do matrimônio, por serem de jurisdição voluntária, seriam reguladas pelas *Disposições Gerais* daquele CPC. Com isso sustentava a legitimidade ativa do Ministério Público para ajuizamento da ação de modificação do regime patrimonial do matrimônio. Não há sentido na proposição, uma vez que o Ministério Público já atuará com fiscal da ordem jurídica (*custos legis*) e por tratar-se de interesses privados não abarcados naquelas hipóteses de intervenção (art. 178, incs. I e II).

3.2 Competência

A competência de jurisdição para conhecimento do procedimento de jurisdição voluntária que vise a alteração de regime de bens é das Varas de Família da Justiça Comum estadual, salvo disposição

específica da organização judiciária estadual⁷⁴³ ou distrital federal. No entanto, nos termos do § 3.º, art. 734 do CPC/2015. A competência de foro está secundariamente associada ao interesse e à publicidade desejada.

Em geral, nos procedimentos de jurisdição voluntária, à falta de regra específica nas *Disposições Gerais*, deve a competência ser definida pela circunstância própria de cada espécie procedimental, do direito ou da pessoa⁷⁴⁴, ou das peculiaridades do caso.

3.3 Petição inicial assinada pelos interessados e advogado

Ainda que pese o fato de o *caput* do art. 734 não tratar expressamente da necessidade de assinatura da petição de pedido de alteração de regime de bens do matrimônio, por ser atividade privativa de advogado, é necessária a assinatura da peça processual por um advogado, ademais, por se tratar de ação de jurisdição voluntária, faz-se necessária a assinatura de ambos os cônjuges.

Caracterizam-se os procedimentos consensuais dissolutivos de uniões em Direito de Família desse elemento plástico, ou seja, da dupla manifestação direta na peça processual inicial (petição), secundando a assinatura do advogado. Esse *capricho* se repete nos procedimentos extrajudiciais, ainda que neles não exista uma petição inicial, propriamente. Estendeu-se o mesmo elemento para a ação que busca a alteração do regime de bens.

A causa de pedir está nos fundamentos que motivam o pedido, que pode ser contrariado cointeressados intervenientes, sejam os filhos, sócios, credores; o *pedido* é de autorização para a alteração, com a homologação da proposição e até mesmo das estipulações feitas.

3.4 Diligências iniciais de publicidade e chamamento

A finalidade e natureza deste procedimento impõem a ele uma espécie de *procedimento edital* objetivando dar a conhecer a todos ou quaisquer que possam ter interesse na causa a “pretensão” à alteração de regime de bens proposta pelos interessados. Por isso deve o juiz, “ao receber a petição inicial, o juiz determinar (...) a publicação de edital que divulgue a pretendida alteração de bens”. Essa concepção publicitária de dar conhecimento geral ao público mediante edital se justifica pela proteção a eventual interesse de terceiros que poderiam ser atingidos pela alteração. A publicação de edital, bem assim a sua abrangência (âmbito local, estadual, regional ou nacional) será melhor definida pela jurisprudência.

Em aparente paradoxo, se contrariam as tradicionais regras de sigilo das ações do Direito de Família, trazendo para a luz a pretensão dos interessados, diante do risco que a alteração pode produzir sobre terceiros. Esse era um alerta feito pela doutrina, após a permissão criada pelo CC/2002.⁷⁴⁵

Embora não se delimite diretamente o prazo para manifestar-se, que se soma aos trinta dias do prazo do edital (art. 734, § 1.º), que será de quinze dias, no mínimo, findo o prazo do edital. Poderá o juiz ampliar o prazo de trinta dias do edital com base no modelo de flexibilização procedimental (art. 139, VI).

3.5 Limite da participação dos cointeressados

Pela natureza do direito patrimonial envolvido, cuidou o legislador processual de tornar pública a proposição, afastando a regra constitucional do sigilo. Com o chamamento do procedimento edital pretende-se a publicidade e o alerta aos eventuais interessados; chamados, podem acorrer ao processo para dele saber as razões e, discordando, impugná-las.

Não se pode excluir que a alteração de regime de bens possa afetar o direito sucessório dos filhos; podem também os sócios empresariais dos cônjuges; de modo equivalente os credores e outros. Bem observou a doutrina que, “conforme o regime de bens no matrimônio, diferentemente será a responsabilidade patrimonial de cada cônjuge, e, por conseguinte, diferente será a sua relação com os credores, sejam seus próprios, de ambos simultaneamente, ou aqueles que têm crédito somente para com o outro cônjuge. Quando se verificam tais possibilidades aliadas ao direito da empresa, (...) surgem os casos em que a fraude contra credores encontra guarida no seio familiar”.⁷⁴⁶

3.6 A intimação do Ministério Público

À Exceção dos demais procedimentos consensuais de família, nos quais não há a participação obrigatória do Ministério Público para atuar como fiscal da ordem jurídica (*custos legis*) nas hipóteses de intervenção típicas (art. 178, I e II), neste a previsão de sua participação é expressa, ou seja, ao receber a petição inicial, o juiz determinará a intimação do Ministério Público.

Não se cogita da alteração do regime de bens do casamento sem a participação do Ministério Público, mesmo que não estejam presentes os interesses classicamente defendidos pela referida instituição. A atuação do Ministério Público, segundo Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, seria especificamente para promover a proteção dos direitos e interessados de terceiros”.⁷⁴⁷

3.7 As provas

As provas a instruírem a inicial são as provas de praxe: documentos pessoais dos cônjuges (RG e CPF); certidão de casamento atualizada, eventual pacto antenupcial. A demonstração dos fundamentos ou da causa de pedir poderão demandar instrução com novos documentos, depoimento pessoal, oitiva de testemunhas e outros meios de prova.

Haja vista a necessidade de verificação do juiz no que toca às razões pelos quais a alteração de regime de bens está sendo pleiteada, entende-se pela natureza constitutiva da sentença que defere o pedido e mandamental, que ordena os respectivos mandados de averbação junto aos cartórios mencionados no § 3.º do art. 734 do CPC/2015.

3.8 Sentença, sua eficácia e seus efeitos

Em razão da modalidade judicial para a promoção da alteração, não há necessidade de escrituração e posterior averbação da escritura na certidão de casamento, sendo deferido o pedido, o juiz determina por meio de mandado de averbação que os cartórios averbarem a nova situação jurídica junto à certidão de casamento, junto à matrícula dos imóveis comuns ao casal, bem como junto ao contrato social da pessoa jurídica inscrito da junta comercial caso um dos cônjuges seja empresário.

Ressalta-se que as “dívidas assumidas antes da mudança, a responsabilidade patrimonial continua regida pelo regime existente anteriormente, salvo se tiver havido incremento patrimonial com a alteração do regime (art. 789, CPC)”.⁷⁴⁸

Dúvidas poderão surgir sobre o momento do início da alteração, se do “trânsito em julgado” da decisão ou se retroage à data da propositura; a preponderante eficácia constitutiva indica que mais adequado será considerar-se a data da estabilização, passados os prazos dos recursos.⁷⁴⁹ Eficácia mandamental correspondente à ordem de mandar averbar junto à certidão de casamento deve ser promovida no cartório do respectivo assento matrimonial, bem como o mandado de averbação deve ser enviado aos respectivos cartórios de registro de imóveis, e em caso de um dos cônjuges ser enquadrado como empresário, o mandado deve ser direcionado também à junta comercial conjuntamente.

A eficácia no tempo da alteração do regime de bens do casamento é questão tormentosa, especialmente pelo risco de atingimento de direitos de terceiros;⁷⁵⁰ entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a eficácia é *ex nunc*, valendo desde o momento do trânsito em julgado da decisão que homologar o acordo sobre a mudança do regime de bens.⁷⁵¹

3.9 Recurso da sentença

A apelação (art. 1.009) é o recurso da sentença que caracteriza o duplo grau de jurisdição, definido como ato pelo qual o processo se submete a uma dupla fase do juízo de mérito; a sentença se sujeita aos meios impugnativos, só transitando em julgado após o exame desses recursos. E como sentença dos procedimentos de jurisdição voluntária, também está sujeita a recurso de apelação (art. 724), obedecendo aos requisitos *intrínsecos*: cabimento, legitimidade e interesse recursal e *extrínsecos*: tempestividade, regularidade formal e preparo.

Podem recorrer os cônjuges diante da rejeição do pedido de homologação ou cointeressados que, tendo participado do procedimento, viram suas impugnações serem repelidas. Não se admitirá recurso de terceiro que não tendo integrado o procedimento como interessado, deseje insurgir-se contra a decisão que admitiu a alteração consensual do regime de bens do casamento. Contudo, se restaram direitos de terceiro atingidos ou em risco de serem atingidos cabe a esse terceiro as ações especiais próprias, sejam as assecuratórias, as constitutivas de direito ou desconstitutiva de sentença.

Seção V

Dos testamentos e dos codicilos

1. Inovações do CPC/2015 na Seção

Não há inovações no conteúdo do título, porquanto somente se reordene o que se denominava *Capítulo* que a partir do CPC/2015 passa ser denominado de *Seção* e a correção de número, passando a figurar no plural os testamentos e os codicilos, por se tratar de conjuntos de espécies e não apenas de um codicilo.

2. Aspectos materiais gerais da Seção – Dos Testamentos e dos Codicilos

Muitos são os aspectos materiais que envolvem os codicilos e os testamentos e, embora não seja este um *Comentários* sobre Direito Civil, o que caracteriza os procedimentos especiais, sejam contenciosos ou voluntários, é a forte influência material sobre as regras processuais que determinam ou forçam a persistência ou a criação de regras especiais.

A regra procedimental de abertura e *apresentação* dos codicilos e testamentos, ao manterem-se como uma espécie, respeitam as peculiaridades e solenidades desta manifestação de vontade próprias do Direito das Sucessões.

2.1 O poder de testar

É o poder do testador para: (a) dispor de todo, ou de parte, de seu patrimônio, ou mesmo; (b) de prestar outras declarações de última vontade, como, por exemplo, disposição do próprio corpo para fins altruísticos ou científicos (art. 14 do CC/2002); (c) reconhecimento de filiação (art. 1.609, III, do CC/2002); (d) nomeação de tutor ao filho menor (arts. 1.634, IV e 1.729, ambos do CC/2002) e (e) reabilitação de herdeiro indigno (art. 1.818, do CC/2002), conforme dispõem os arts. 1.857 a 1.859 do CC/2002, por meio de ato próprio, o testamento. ⁷⁵²

Destaca-se que, embora lhe seja conferido dispor sobre todas as matérias acima expostas, há restrições legais que prevalecem sobre as disposições testamentárias naquilo em que divergir, ou que for silente o testamento, como, por exemplo, se observa dos arts. 1.857, § 1.º, e 1.967, ⁷⁵³ ambos do CC/2002, que proíbe a inclusão da legítima em testamento e prevê, caso se verifique excesso nas disposições testamentárias, a forma como se realizará a redução destas até o limite da porção disponível.

O codicilo, entretanto, é espécie de disposição de última vontade, sem, contudo, se equiparar ao testamento. ⁷⁵⁴ O legislador não conferiu a este todos os poderes das disposições gerais (arts. 1.857 a 1.859 do CC/2002). Em verdade, conforme preceitua o art. 1.881 do CC/2002, é possível apenas disposições especiais sobre: a) seu (testador) enterro; b) esmolas de pouca monta a certas e determinadas pessoas; c) ou, indeterminadamente, aos pobres de certo lugar; d) legar móveis, roupas ou joias, de pouco valor, de seu (testador) uso pessoal. ⁷⁵⁵

Ressalta-se que, na superveniência de testamento de qualquer natureza, os atos descritos no art. 1.881 do CC/2002 serão revogados, caso ele (testamento) não os confirme ou os modifique, nos termos do art. 1.884 do CC/2002. ⁷⁵⁶ Diverge Maria Berenice Dias, que aduz: “(...) só a existência de testamento ou de outros codicilos não o revogam. Não há sequer a necessidade de que seja expressamente ratificado. Basta não conflitarem as disposições”. ⁷⁵⁷

2.1.1 Capacidade de testar e portadores de deficiência

O art. 1.857 do CC/2002 prevê que toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, de sua totalidade dos bens, ou de parte deles, para depois de sua morte. Já o art. 1.860, do mesmo Código, aduz que não poderão testar, além dos incapazes, excetuando-se os maiores de 16 anos, aqueles que, no ato de sua elaboração (testamento), não tiverem pleno discernimento. ⁷⁵⁸ Assim, a capacidade ativa do testador é aferida segundo o princípio do *tempus regit actum*, ⁷⁵⁹ ou seja, no momento em que o ato foi praticado, ideia essa consubstanciada pela redação do art. 1.861 do CC/2002, ao estabelecer que a incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento, bem como o testamento feito por incapaz não se valida pela superveniência da capacidade (completar 16 anos ou a maior idade). ⁷⁶⁰

Todavia, em que pese a redação do art. 1.860 do CC/2002 referir-se genericamente aos incapazes,

tratam-se apenas dos absolutamente, nos termos do art. 3.º do CC/2002, cuja nova redação dada pela Lei 13.146/2015, classifica como sendo apenas os menores de 16 anos. Dessa forma, os relativamente incapazes, previstos no art. 4.º do mesmo Código, não estão impedidos de testar, como se faz presumir. Isso porque, conforme bem aponta Maria Berenice Dias: “Em matéria de capacidade testamentária, quer se dar a segurança de que o indivíduo possa exprimir livremente sua vontade (...)”, ⁷⁶¹ desde que tenha compreensão, discernimento, ou seja, saiba o que está fazendo. ⁷⁶²

Sobre este ponto, cumpre destacar que o *Estatuto da Pessoa com Deficiência* (Lei 13.146/2015), além de limitar, como mencionado, a incapacidade absoluta aos menores de 16 anos, definiu, ainda, que a deficiência não afeta a plena capacidade civil (art. 6.º do Estatuto) sendo assegurado o exercício da capacidade legal, mediante a adoção de processo de tomada de decisão apoiada (art. 84, § 2.º, do EPD c/c art. 1.783-A do CC/2002), nada impedindo que, por meio deste (processo de tomada de decisão apoiada), o deficiente também faça testamento, ressalvando-se que nem os apoiadores, nem seus parentes, poderão ser beneficiados pelo ato (testamento). Tratando-se, porém, de surdo-mudo, deverão ser observadas as regras descritas no art. 1.873 do CC/2002, sob pena de comprometer-lhe a validade. ⁷⁶³

2.1.2 Incapacidade acidental

Um ponto que tem atormentado a doutrina é saber se o interdito pode testar em intervalo de lucidez, ou se, apesar da cura, a interdição ainda não tenha sido levantada. A maioria sustenta que o ato não deve ser convalidado, pois traria grande insegurança às relações jurídicas, ainda que existam correntes que admitam a convalidação do ato, desde que se demonstre a higidez do interdito quando da elaboração. ⁷⁶⁴

Ressalta-se, também, que, além das restrições à capacidade de testar, há, ainda, outras, como a limitação aplicada aos que não sabem ler e escrever, os quais estão impedidos de testar por testamento cerrado, nos termos do art. 1.872 do CC/2002, bem como aqueles que não conhecem a língua nacional estão impossibilitados de testar por testamento público, conforme art. 1.871 do mesmo Código. ⁷⁶⁵

2.2 A diferença entre codicilos e testamentos

Primeiramente, vale reforçar que codicilo não é testamento, ainda que ambos sejam instrumentos de manifestação de última vontade. ⁷⁶⁶ Como visto anteriormente (v. item 2.1), codicilo é forma limitada, cabendo, apenas, para disposições especiais sobre: a) seu (testador) enterro; b) esmolas de pouca monta a certas e determinadas pessoas; c) ou, indeterminadamente, aos pobres de certo lugar; d) legar móveis, roupas ou joias, de pouco valor, de seu (testador) uso pessoal, nos termos do art. 1.881 do CC/2002. ⁷⁶⁷ Já o testamento, embora também possua certas limitações (legais), como a do art. 1.857, § 1.º, ⁷⁶⁸ arts. 1.900 e 1.967, todos do CC/2002, é instrumento apto para disposição de todo ou parte do patrimônio do testador, independentemente do valor (respeitada a legítima, art. 1.967 do CC/2002), bem como para disposições de caráter não patrimonial, nos termos do art. 1.857, *caput* e § 2.º, do CC/2002.

Outro ponto a se destacar é que o codicilo não está submetido às mesmas formalidades do testamento solene, ⁷⁶⁹ como, por exemplo, a leitura pelo testador na presença de, pelo menos, três testemunhas e suas respectivas assinaturas, sob pena de invalidade, quando se tratar de testamento particular, ou, no caso de testamento cerrado, da necessidade de entrega do testamento pelo testador ao tabelião, na presença de duas testemunhas, devendo, ainda, o testador manifestar, verbalmente, que é o autor daquele testamento e que o quer aprovado.

2.3 As espécies de codicilos e de testamentos

Os testamentos são divididos em duas categorias: a) ordinários e b) especiais, sendo que cada uma destas comporta três modalidades. Dentre da primeira (ordinários), verifica-se as hipóteses previstas no art. 1.862 do CC/2002, quais sejam: i) público (arts. 1.864 a 1.867 do CC/2002; ii) cerrado (arts. 1.868 a 1.875 do CC/2002) e iii) particular (arts. 1.876 a 1.880 do CC/2002). Já na segunda categoria (especiais), estão enquadradas as modalidades previstas no art. 1.886 do CC/2002, quais sejam: i) marítimo (arts. 1.888 ao 1.892 do CC/2002); ii) aeronáutico (arts. 1.888 ao 1.892 do CC/2002) e iii) militar (arts. 1.893 ao 1.896 – nuncupativo, do CC/2002). ⁷⁷⁰

Os codicilos podem ser elaborados em todas as formas previstas, porém deve-se observar o procedimento de cada um destes para abertura e apresentação (Exemplo: se *cerrado*, deverá seguir o disposto no art. 735 do CPC/2015). ⁷⁷¹

2.4 A jurisdição voluntária e os testamentos

Os procedimentos de abertura, registro e cumprimento dos testamentos visam, tão somente, a conferência, pelo magistrado, dos requisitos essenciais de validade daqueles, bem como a determinação de cumprimento das disposições descritas.⁷⁷²

De forma geral e resumida, num procedimento simples e direto, o juiz, ao receber o testamento, verificará seu estado (se está intacto), bem como se, na sua elaboração, foram observados os requisitos extrínsecos (formais) exigidos por lei, ordenando ao escrivão, posteriormente, que o leia na presença da pessoa que o entregou, lavrando o termo de abertura, que deverá ser assinado pelo juiz e pelo apresentante.⁷⁷³ Havendo questões referentes de indagação mais ampla, devem ser remetidas às vias próprias, fora do procedimento especial para serem resolvidas.⁷⁷⁴

3. Aspectos processuais e procedimentais gerais da Seção

Há alterações e supressões importantes no conjunto dos dispositivos, pois desaparece a divisão anterior em quatro partes que fracionava o *Capítulo*, nas *Seções Da Abertura, do Registro e do Cumprimento* (I); *Da confirmação do Testamento Particular* (II); *Do Testamento Militar, Marítimo, Nuncupativo e do Codicilo* (III); *Da Execução dos Testamentos* (IV), agora expostos em um bloco único. São também retirados os conteúdos do art. 1.129 e parágrafo único, parágrafo único do art. 1.131, art. 1.132; e a *Seção IV* (Execução dos Testamentos), art. 1.135, art. 1.136, art. 1.137, art. 1.138, art. 1.139, art. 1.140, art. 1.141.

Art. 735. Recebendo testamento cerrado, o juiz, se não achar vício externo que o torne suspeito de nulidade ou falsidade, o abrirá e mandará que o escrivão o leia em presença do apresentante.

§ 1.º Do termo de abertura constarão o nome do apresentante e como ele obteve o testamento, a data e o lugar do falecimento do testador, com as respectivas provas, e qualquer circunstância digna de nota.

§ 2.º Depois de ouvido o Ministério Público, não havendo dúvidas a serem esclarecidas, o juiz mandará registrar, arquivar e cumprir o testamento.

§ 3.º Feito o registro, será intimado o testamenteiro para assinar o termo da testamentária.

§ 4.º Se não houver testamenteiro nomeado ou se ele estiver ausente ou não aceitar o encargo, o juiz nomeará testamenteiro dativo, observando-se a preferência legal.

§ 5.º O testamenteiro deverá cumprir as disposições testamentárias e prestar contas em juízo do que recebeu e despendeu, observando-se o disposto em lei.

1. Inovações do CPC/2015

Inova o art. 735 e seus 05 (cinco) parágrafos, ao fundir, parcialmente, os conteúdos dos arts. 1.127, 1.125 e parágrafo único, e 1.126 em um único dispositivo mais coerente, bem como ao acrescentar comando antes não previsto pelo Código (§ 5.º). Outra inovação é a mudança da expressão “auto de abertura”, pela nova “termo de abertura”, já que o novo Código (2015) estabeleceu “termo” como sendo ato lavrado em juízo e “auto” como ato lavrado fora deste (v. item 3.3.2).

2. Aspectos materiais do testamento cerrado

Como se observa do *caput* do artigo, o procedimento nele previsto trata especificamente de testamento cerrado, cujas as regras de elaboração estão previstas no art. 1.868 do CC/2002. É assim denominado, por ser forma sigilosa de manifestação de última vontade, pois suas disposições são conhecidas apenas no momento da sua abertura (também chamado de secreto ou místico).⁷⁷⁵ Nesta forma, verificam-se dois elementos básicos e complementares: a) o testamento propriamente dito e b) a sua aprovação pelo tabelião. Cumpre destacar, em que pese o termo utilizado “auto de aprovação”, o tabelião nada aprova, pois sequer lhe é dada a oportunidade de ler o testamento,⁷⁷⁶ limitando-se apenas a autenticá-lo (cumprir as formalidades previstas no art. 1.868 do CC/2002).⁷⁷⁷

Suas características essenciais são: “(...) (a) ser escrito pelo testador ou a seu rogo; (b) ser entregue pelo testador ao tabelião; (c) a presença de duas testemunhas; (d) a manifestação verbal do testador de ser este o seu testamento e que o quer aprovado; (e) a lavratura do auto de aprovação; (f) a leitura do

auto de aprovação; (g) a assinatura de todos os presentes; (h) ser cerrado e costurado”.⁷⁷⁸

O testamento cerrado poderá ser escrito pelo testador ou por outra pessoa a seu pedido, desde que observados os requisitos dos arts. 1.872, 1.868 e art. 1.801 (deverá conter a identificação e a qualificação do redator, pois não poderá ser beneficiário), todos do CC/2002. Há, ainda, a possibilidade de o testamento, na forma cerrada, ser redigido em língua estrangeira, desde que, quando da sua abertura e registro, seja vertido em português, por meio de tradutor oficial, em razão da regra do art. 192 do CPC/2015.⁷⁷⁹

Assim, verifica-se que a incolumidade do testamento é o objetivo desta fase inicial.

3. Aspectos processuais e procedimentais

3.1 Apresentante e seus atos

O apresentante é a pessoa que detém o testamento sob sua guarda e que, após a morte do testador, o apresenta ao juiz. Geralmente o testamenteiro (sujeito nomeado, a fim de cumprir o testamento); o cônjuge ou companheiro sobrevivente; o herdeiro, ou outro interessado.⁷⁸⁰ A entrega é feita mediante advogado ou por quem detenha capacidade postulatória (Exemplo: Defensoria Pública).⁷⁸¹ Seus atos dentro deste procedimento são: a) a entrega do testamento (em regra lacrado – v. item 3.3) e b) a assinatura do termo de abertura.

Parte da doutrina discorda da necessidade da atuação de advogado neste procedimento, tendo em vista tratar-se apenas de ato material imposto por lei, sem maiores complexidades.⁷⁸²

3.1.1 Detentor

Embora seja aquele sob posse do testamento, se difere do apresentante, na medida em que leva o testamento a registro de forma forçada, nos termos do art. 1.979 do CC/2002.⁷⁸³ Assim, não tendo o detentor apresentado o testamento após a morte do testador ou se negando a fazê-lo, poderá o testamenteiro, ou qualquer parte interessada, requerer que o faça, assim como poderá fazê-lo de ofício o juiz.

José Olympio de Castro Filho, ao comentar o CPC/1973, ressalta que não há qualquer previsão sobre em que processo deverá ser promovida a notificação do detentor para a apresentação do testamento, porém adverte que a praxe forense estabelece que, caso exista inventário em curso, a providência deverá ser requerida neste juízo, em razão da competência universal, nos termos do art. 61 do CPC/2015 (art. 108 CPC/1973). Não existindo inventário, a intimação deverá ser requerida ao juízo onde se encontra o detentor, ou ao juízo competente para o inventário, devendo o requerimento ser instruído com a certidão de óbito do testador e com as razões que possam levar a crer que existe o testamento e que se encontra em poder do indicado,⁷⁸⁴ conforme art. 397 do CPC/2015. Ressalta-se, inclusive, que poderá o juiz se utilizar das medidas descritas nos arts. 139, 400, parágrafo único e 401, parágrafo único, todos do CPC/2015.

3.1.1.2 Sanções civis e penais

Caso o testamento, que foi mandado apreender não seja encontrado, nem trazido a juízo pelo detentor, aplica-se a ele as sanções civis e penais, como, por exemplo, a prevista no art. 1.814, III, do CC/2002, que consiste na exclusão deste da sucessão, se for herdeiro ou legatário, a ser requerida por quem tenha interesse, nos termos do art. 1.815 do CC/2002, além do pagamento das custas e despesas de ordem processual. Poderá ainda sofrer sanção de ordem penal, nos termos do art. 330 do Código Penal (crime de desobediência).⁷⁸⁵

3.2 Competência

Entende Edson Prata que: “O juiz competente para a abertura do testamento é o do inventário, ou seja, aquele da comarca em que o morto era domiciliado. Não importa a ocorrência do falecimento em outro lugar. Predomina o foro de domicílio (arts. 96 e 97) [arts. 48 e 49 do CPC/2015]”.⁷⁸⁶ Porém, discordando de sua visão, José Olympio de Castro Filho afirma que a competência é do juiz do lugar em que se encontra o apresentante, não havendo falar em prevenção do juízo do inventário, pois a imediatidade da abertura se justifica, a fim de se evitar extravio ou fraudes, inclusive para que se efetivem possíveis disposições a respeito do funeral.⁷⁸⁷

Entende-se pela segunda regra, que é, inclusive, o pensamento majoritário da doutrina.⁷⁸⁸ A vara, por outro lado, será determinada conforme as regras de Organização Judiciária do respectivo local.⁷⁸⁹

3.3 Procedimento

O procedimento de abertura dos testamentos e codicilos envolve as etapas do recebimento pelo juiz e verificações iniciais, da citação, leitura, oitiva de interessados, registros, cumprimento e execução; comportando ainda a possibilidade de recurso de apelação.

3.3.1 Citação dos interessados e testamento de ausente

Por se tratar de integração da forma do negócio jurídico à causa de morte (formalidade), não se está, ainda, no exercício da pretensão, sendo desnecessária a citação dos interessados.⁷⁹⁰ Tratando-se de testamento de ausente (sentença transitada em julgado de abertura de sucessão provisória),⁷⁹¹ seguir-se-á a mesma lógica, pois trata-se de sucessão provisória (arts. 6.º, 28, 37 e 38, todos do CC/2002). Deverá o juiz dos ausentes oficial ao dos testamentos, para que o abra.⁷⁹²

3.3.2 Recebimento pelo juiz e verificação da integridade

Após a entrega do testamento, no caso, na forma cerrada, a primeira análise a ser feita é se, no documento, não há vício externo que o torne suspeito de nulidade ou falsidade (art. 735 do CPC/2015 c/c art. 1.875 do CC/2002). Deverá ser, portanto, analisado se o documento está lacrado (cerrado) e se contém todas as formalidades essenciais, como a assinatura das duas testemunhas, por exemplo.⁷⁹³ Embora se fale apenas em vício externo (art. 1.875 do CC/2002), defende Pontes de Miranda (comentários ao CPC/1973) que: “(...) há nulidades visíveis, não intrínsecas, que fazem nenhum o próprio testamento, e fora absurdo que, vendo-as, o juiz ordenasse o cumprimento da cédula”,⁷⁹⁴ apontando, por exemplo, o testamento feito por interdito e pelo menor de 16 anos, como casos típicos. Justifica sua posição no sentido de que o art. 145 do CC/1916, atual art. 166 do CC/2002, ordena que o juiz pronuncie de ofício as nulidades ali previstas, pelo que também o deve fazer no plano processual, art. 735 do CPC/2015.⁷⁹⁵

Importante destacar que, segundo Edson Prata (comentários ao CPC/1973), mesmo verificando-se qualquer sinal de violação, o testamento deverá ser aberto, constando, porém, tal fato no auto de abertura (art. 735, § 1.º, do CPC/2015).⁷⁹⁶ Entende o autor que, encontrando vício externo no invólucro que guarda o testamento, ou recebendo este já aberto, deve o juiz apurar se existe ou não fraude; ou se a sua abertura se deu por inadvertência de alguma pessoa ou se foi causa de revogação por parte do testador (art. 1.972 do CC/2002).⁷⁹⁷ Isso porque, da leitura do art. 1.972 CC/2002, conclui-se que o legislador exceção a abertura do testamento por outra pessoa, sem o consentimento do testador, o que não ensejaria revogação.⁷⁹⁸ Assim, aponta o autor que, caso se verifique a abertura do testamento por algum particular ou autoridade incompetente, pode-se admitir, em juízo, a justificação do fato, citando-se os interessados, de modo que se conclua não ter sido aberto com a intenção de revogá-lo.⁷⁹⁹ Corroborando esta ideia, Alcides de Mendonça Lima (comentários ao CPC/1973), apenas acrescenta que, no tocante ao ônus da prova, incumbe a quem alegue a revogação, tendo em vista que a presunção é pela validade, ou seja, de “(...) que não foi o testador que o destruiu. Tal presunção favorece quem tem interesse na reconstituição, cabendo aos adversários ilidi-la mediante prova convincente”.⁸⁰⁰ Dessa forma, analisando os fatos e averiguando sua formação, o juiz proferirá despacho de “cumpra-se” ou o não, pelo que, qualquer insurgência quanto à “decisão”, deverá ser feita pelos interessados apenas por ação própria (jurisdição contenciosa).⁸⁰¹

3.3.3 Limites da atividade do juiz

José Olympio Castro Filho afirma que, neste procedimento (abertura), a competência do juiz é muito limitada, pois o que dele se requer é, apenas, uma inspeção do testamento, a fim de identificar se atende as formalidades essenciais, só podendo negar o “cumpra-se”, quando visível a falta destes requisitos⁸⁰² ou aquelas pronunciáveis de ofício, nos termos do art. 166 do CC/2002, como, por exemplo, a não observância do número legal de testemunhas no auto de aprovação, ou testamento elaborado por menor de 16 anos (v. item 3.3.2).⁸⁰³ Segundo o autor, não se cogita, neste procedimento, da existência ou não de outras nulidades, senão aquelas evidentes e em ponto substancial verificável a simples inspeção, tendo em vista que aquelas poderão ser alegadas em ação própria (jurisdição contenciosa).⁸⁰⁴

Assim, em regra, o juiz aporá o “cumpra-se”, negando-o apenas quando verificado vício externo que o torne suspeito de nulidade ou de falsidade. Embora limitado aos vícios extrínsecos, sendo incompetente

para julgar as demais nulidades suscitadas por um ou mais interessados, deve, o juiz, nos termos do § 1.º do art. 735, assinalar, no auto de abertura, qualquer circunstância “(...) que possa levar à anulação do testamento, ou mesmo influir na sua fiel interpretação posteriormente”.⁸⁰⁵ Portanto, o seu “cumpra-se” não significa dizer que o documento se encontra regular ou não, traduzindo unicamente a vontade do Estado de que se dê ao documento execução, cabendo no inventário ou em ação própria o exame das questões que acaso o testamento possa suscitar.⁸⁰⁶

Quando aforarem questões referentes à capacidade do testador, devem elas serem remetidas às vias próprias, fora do procedimento especial não-contencioso, para nesse âmbito plenário serem resolvidas.⁸⁰⁷

3.3.4 Leitura e termo de abertura (§ 1.º)

Vale observar que não há falar em “ato” ou, como apontava a doutrina,⁸⁰⁸ em “auto”, mas “termo”. Segundo estabeleceu o CPC/2015, “termo” é ato lavrado em juízo, sendo “auto” utilizado apenas para os atos lavrados fora deste.

Assim, após a entrega do testamento, ultrapassada a análise quanto à existência de vício extrínseco, este será aberto (se cerrado, v. item 3.3.1) e lido pelo escrivão na presença do apresentante, lavrando-se, em seguida, o termo de abertura.

No termo de abertura constarão, obrigatoriamente (§ 1.º do art. 735): a) o nome do apresentante e como ele obteve o testamento; b) a data e o lugar do falecimento do testador (necessária a apresentação de provas – Exemplo: certidão de óbito) e qualquer circunstância digna de nota.

3.3.5 Oitiva e intervenção do Ministério Público (§ 2.º)

O Ministério Público, neste procedimento, atuará como fiscal da lei, sendo intimado para que apresente parecer, opinando como melhor lhe aprouver, inclusive alertando sobre alguma irregularidade, ou nulidade que possa evitar o cumprimento.⁸⁰⁹ Embora tenha seu papel, a conclusão ministerial não vincula a decisão do magistrado, devendo, caso não seja acolhido seu parecer, interpor recurso, nos termos do art. 724 do CPC/2015.⁸¹⁰

3.3.6 Registro e arquivamento (§ 2.º)

O Registro é a anotação realizada em livro adequado, com os respectivos dados indispensáveis à constatação de que o testamento foi apresentado, sendo quase uma repetição do teor do “termo de abertura”.⁸¹¹ Já o arquivamento, consiste na “(...) guarda do testamento nos autos formados após a sua apresentação, entrega e abertura”.⁸¹² Assim, determina o § 2.º deste artigo (735) que, após ouvido o Ministério Público, não levantando este ou mesmo o juiz, qualquer dúvida a ser sanada, deverá o juiz ordenar que se registre, arquive e cumpra-se o testamento.

3.3.7 Cumprimento ou execução do testamento

O “cumpra-se” é, conforme Pontes de Miranda, conteúdo de sentença de constituição integrativa de forma, ou seja, é manifestação judicial de que existe um testamento sem nulidades aparentes ou visíveis (elemento declarativo da sentença). Porém, em que pese a existência de elemento declarativo na sentença, ela não é declarativa, mas sim constitutiva integrativa de forma (v. item 3.3.1).⁸¹³

O “cumprir”, portanto, se difere de “executar”, como bem aponta Alcides de Mendonça Lima (comentários ao CPC/1973), ao definir que o primeiro “(...) revela-se nas várias providências de cunho administrativo para poder o testamento ser utilizado no inventário do testador (...); o segundo verifica-se na incidência de medidas, fiscalização pelo testamentário, para tornar efetiva a última vontade do testador, dentro do inventário”.⁸¹⁴ Aqui, o “cumpra-se” é resultado do provimento do juiz para que o testamento possa ser executado.⁸¹⁵

Porém, ainda que não possa cumprir, em sua integralidade, as disposições testamentais, o juiz cumprirá as “disposições de corpo presente”, do enterro, dos funerais, remetendo, em seguida, cópia autêntica ao juiz competente para o inventário e partilha, a fim de que se execute o título (testamento) quanto às demais disposições.⁸¹⁶

3.3.8 As provas

O texto legal exige apenas a juntada dos documentos que comprovem o local e a data da morte do testador, conforme § 1.º do art. 735. Porém, havendo necessidade de justificação (v. item 3.3.1), devem ser apresentadas provas capazes de consubstanciar as alegações das partes, a fim de que se pronuncie o “cumpra-se” ou não. Lembrando-se que eventual discordância quanto ao despacho deverá ser intentada em ação própria (jurisdição contenciosa).

3.3.9 Recurso

Da decisão que determina ou não o “cumpra-se”, cabe recurso de apelação, nos termos do art. 724.⁸¹⁷

3.4 Chamamento do testamenteiro, aceitação ou substituição (§§ 3.º e 4.º)

O testamenteiro, também conhecido como “executor do testamento”, é alguém indicado pelo testador para que cumpra suas disposições de última vontade, nos termos do art. 1.976 e do art. 1.980, ambos do CC/2002. Sua nomeação pode ser realizada tanto por testamento como por codicilo (art. 1.883 do CC/2002). Há, ainda, a possibilidade de se nomear mais de um testamenteiro, para agirem em conjunto ou separados (art. 1.976 do CC/2002).

Assim, caso se verifique a existência de testamenteiro, este será intimado para que manifeste, em juízo, sua aceitação ou não, pois trata-se de cargo de assunção voluntária, o que afasta, inclusive, a necessidade de recusa fundamentada. Caso aceite, deverá assinar o termo de testamentária, bem como, segundo a praxe jurídica, prestar compromisso,⁸¹⁸ tornando-se, assim, responsável pela execução do testamento, nos termos do art. 1.980 do CC/2002. Porém, se o testador não houver nomeado testamenteiro, ou se ele estiver ausente (art. 22 do CC/2002),⁸¹⁹ ou não aceitar o encargo, o juiz nomeará, nos termos do § 4.º do art. 735 do CPC/2015, testamenteiro dativo, observando-se a preferência legal – cônjuge sobrevivente, ou, na falta deste, um dos herdeiros nomeados pelo juiz (art. 1.984 do CC/2002).

Ressalta Maria Berenice Dias que, embora o texto legal utilize a expressão “o juiz nomeará testamenteiro dativo”, a nomeação não é obrigatória (em caso de não previsão pelo testador), pois não se pode contrariar a vontade do testador, que entendeu ser dispensável tal previsão. A autora aponta, ainda, que o inventariante pode proceder à partilha do acervo sucessório, já que está dentro de suas atribuições, sem que receba, inclusive, qualquer remuneração pelo encargo.⁸²⁰

3.4.1 Impedimentos

Por analogia, aplica-se aqui os mesmos impedimentos para o exercício da tutela (art. 1.735 do CC/2002), não podendo ser testamenteiro, por exemplo, a) aquele que possui débito para com o testador; b) estiver litigando com os herdeiros ou c) for inimigo do testador ou seus sucessores.⁸²¹

3.4.2 Direitos

Entre os direitos do testamenteiro está, além de sua remuneração pela vintena, o de ser ressarcido de despesas que tenha feito para a realização dos atos de abertura do testamento, pois se gastou, não pode a herança enriquecer sem lhe repor despesas que não tinha dever de custear.

A remuneração do testamenteiro se dará de diferentes formas: a) se não for herdeiro (testamentário ou legítimo) ou legatário,⁸²² receberá prêmio, denominado de vintena, nos termos do art. 1.987 do CC/2002, e b) se for beneficiado em testamento (Exemplo: legado), não fará jus ao prêmio. Porém, sustenta a doutrina que, se o legado, a ele conferido, não tiver caráter remuneratório, pode o testamenteiro reclamar que lhe seja paga vintena, embora a lei não crie tal distinção. O valor do prêmio será determinado pelo testador, porém, caso este nada diga, cabe ao juiz fixar valor entre 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) da herança líquida (art. 1.987 do CC/2002). Entende-se por herança líquida, o montante resultante dos ativos menos os passivos (dívidas e tributos), bem como deverá ser excluído para o cálculo o valor da meação.⁸²³

Quando houver herdeiros necessários, o prêmio arbitrado será pago à conta da parte disponível, conforme parágrafo único do art. 1.987 do CC/2002. Destaca-se, que o prêmio a que faz jus o testamenteiro não é legado, a não ser que o valor estipulado pelo testador ultrapasse o limite de 5% (cinco por cento) sobre o valor líquido da herança.⁸²⁴

O testamenteiro deverá, ainda, ser citado para o inventário, nos termos do art. 626 do CPC/2015, passando a ser intimado de todos os atos do processo, bem como possuir legitimidade concorrente para

requerer a abertura de inventário, como preceitua o art. 616, IV, do CPC/2015. Ressalta-se, também, que nas ações em que questione a validade do testamento ou de alguma de suas cláusulas, é do testamenteiro a legitimidade passiva para a ação, sendo litisconsorte necessário. ⁸²⁵

3.4.3 Deveres e obrigações gerais

Embora o CPC/2015 não mais preveja os direitos e deveres do testamenteiro (arts. 1.135 a 1.139 do CPC/1973), estes ainda permanecem. A doutrina já advertia a desnecessidade de previsão destes no Código de Processo, já que atinentes a direito material. Sobre o tema, assim advertia José Olympio de Castro Filho ao comentar o CPC/1973: “As obrigações ou os deveres ou ônus que tocam ao testamenteiro, a rigor, são matéria de direito substantivo, e, assim, nem deveriam figurar na lei processual civil”. ⁸²⁶

Assim, prevê o Código Civil de 2002 (arts. 1.976 a 1.990), os deveres e obrigações do testamenteiro, como: a) administrar os bens, quando na posse destes, bem como requerer o inventário e cumprir o testamento (art. 1.978 do CC/2002); b) requerer que o detentor do testamento o leve a registro (art. 1.979 do CC/2002); c) cumprir as disposições testamentárias no prazo determinado pelo testador e dar contas do que recebeu ou despendeu, sob pena de responsabilidade, enquanto durar a execução do testamento (art. 1.980 do CC/2002). Porém, caso não haja previsão quanto ao prazo, seguir-se-á a regra do art. 1.983 do CC/2002; ⁸²⁷ d) defender a validade do testamento (art. 1.981 do CC/2002); e) exercer as funções de inventariante, se o testador houver distribuído toda a herança em legados (art. 1.990 do CC/2002).

3.4.4 Dever de prestar de contas (§ 5.º)

O testamenteiro, igualmente ao curador da herança jacente, ao depositário e ao administrador, tem o dever de prestar contas da administração de bens e valores alheios. Ademais, “responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo” (art. 161 do CPC/2015). A regra do parágrafo único do art. 161, quanto à responsabilidade civil por prejuízos causados, responsabilidade penal e sanção por ato atentatório à dignidade da justiça destina-se especificamente ao depositário infiel. Qualquer responsabilidade do testamenteiro terá de ser apurada em ação própria e não no âmbito do procedimento de abertura do testamento, com iniciativa de legitimados lesados contra este que supostamente os lesionou.

Como dito, créditos e débitos decorrentes da atividade de administração e de guarda podem, entretanto, ser discutidos na *ação de exigir contas*, arts. 550 a 553 do CPC, procedimento especial próprio a esse fim, permitindo que as contas sejam “apresentadas na forma adequada, especificando as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver”. A natureza dúplice da ação de exigir contas possibilita que a sentença contenha saldo que pode favorecer a qualquer das partes envolvidas na administração (art. 552).

3.4.5 Remoção, não cumprimento do testamento e extinção

Conforme anteriormente apontado, o CPC/2015 deixou de regular a execução dos testamentos (v. item 3.4.3), bem como não prevê a remoção do testamenteiro. Porém, ressalta Maria Berenice Dias que, ao testamenteiro, por exercer as funções de inventariante, aplicam-se as hipóteses previstas no art. 622 do CPC/2015, podendo ser removido a requerimento dos herdeiros ou, inclusive, por iniciativa do juiz. Sendo removido, ou não cumprindo as disposições testamentárias a que se obrigou, não fará jus ao prêmio, que reverterá à herança (art. 1.989 do CC/2002 e art. 553 do CPC/2015).

A atividade do testamenteiro se extingue com a execução completa do testamento.

Art. 736 . Qualquer interessado, exibindo o traslado ou a certidão de testamento público, poderá requerer ao juiz que ordene o seu cumprimento, observando-se, no que couber, o disposto nos parágrafos do art. 735.

1. Inovações do CPC/2015

Inova apenas parcialmente o art. 736, se comparado ao art. 1.128 e parágrafo único, do CPC/1973, sem que, contudo, seu conteúdo tenha sido alterado.

Desparecem as menções expressas que havia à exibição ou busca e apreensão (art. 1.129 e parágrafo único, do CPC/1973), embora quaisquer direitos materiais lesados, seja pela não apresentação ou pela

notória ocultação do testamento podem ser protegidas processualmente por medidas nominadas ou não na tutela provisória (arts. 294-311), bem como pelos arts. 139, 400, parágrafo único e 403, parágrafo único, todos do CPC/2015, para apresentação forçada pelo detentor – art. 1.979 do CC/2002 – (v. comentários ao art. 735, item 3.1.1).

2. Aspectos materiais do testamento público

Os requisitos para feitura do testamento público encontram-se consignados no art. 1.864 do CC/2002, quais sejam: a) ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal em seu livro de notas, de acordo com as declarações do testador, podendo este servir-se de minuta, notas ou apontamentos; b) lavrado o instrumento, ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador e a duas testemunhas, a um só tempo; ou pelo testador, se o quiser, na presença destas e do oficial; c) ser o instrumento, em seguida à leitura, assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião. Devem ser observadas, também, as demais regras descritas nos artigos seguintes – arts. 1.865 a 1.867 do CC/2002, como, por exemplo, se o testador não souber ou não puder assinar, o tabelião ou seu substituto legal assim o declarará, assinando, neste caso, pelo testador, e, a seu rogo, uma das testemunhas instrumentárias (art. 1.865 do CC/2002).

3. Aspectos processuais e procedimentais

Aplicação, no que couber, das disposições do art. 735 e seus 05 (cinco) parágrafos ao testamento público ou aberto. Isso porque, em que pese não haver a solenidade de abertura como no cerrado (art. 735), aqui, também, será elaborado um termo, denominado, porém, de termo de apresentação, onde constarão: (a) o nome do apresentante e como obteve o traslado ou certidão; (b) a data e o lugar de falecimento do testador, com as respectivas provas; e (c) as circunstâncias dignas de nota.

Não há o procedimento de abertura, porque, por óbvio, o testamento não está cerrado, mas sim aberto e disponível para conhecimento de quem quer que seja, bastando ler o texto nos livros do tabelionato em que foi lavrado o testamento. Ainda que se tenha guardado o testamento em algum invólucro, seja pelo testador ou por terceiros, como medida de segurança, a sua “abertura” não se dará como forma de integração de forma do negócio jurídico, como no cerrado, não sendo necessária, portanto, qualquer formalidade para este ato. ⁸²⁸ Porém, semelhantemente ao procedimento anterior, se verificará o cumprimento de determinados requisitos, neste caso, entretanto, serão relevantes apenas os intrínsecos, como, exemplo: capacidade para testar ou ausência das formalidades essenciais ao instrumento, elencadas nos arts. 1.864 e ss. do Código Civil de 2002, bem como os intrínsecos, mandando, em seguida, lavrar o termo de apresentação, com as informações anteriormente citadas, e circunstâncias dignas de nota (qualquer circunstância que possa comprometer a validade do testamento na forma pública).

3.1 Qualquer interessado como apresentante

O interessado é qualquer pessoa vinculada, ou não, por parentesco com o testador, ou que tenha sido contemplada pela verba, como, por exemplo, “(...) o preposto, o procurador, o gerente de firma comercial onde o falecido trabalhava, o gerente ou funcionário do banco onde o documento estivesse guardado e, principalmente, o tabelião em cujo ofício o testamento tenha sido lavrado, ao ter ciência do óbito, sem aguardar o pedido de traslado ou de certidão de terceiro”. ⁸²⁹

Geralmente o testador possui o traslado da escritura, guardado em outro local (Exemplo: banco ou escritório de advogado permanente), mas nada impede que, em não se localizado este (traslado), seja extraído outro após a morte do testador. ⁸³⁰

3.2 Requerimento

O requerimento poderá ser feito verbalmente ao juiz, desde que o interessado (apresentante) compareça ao juízo e, munido do traslado ou da certidão, requeira o seu cumprimento. Porém, também poderá fazê-lo por meio de petição inicial, observando-se, no que couber, o art. 319 do CPC/2015.

Sobre este ponto, Alcides de Mendonça Lima aduz que se o requerimento for feito verbalmente, será imprescindível a lavratura do termo de apresentação, porém, sendo apresentado por meio de petição inicial, entende o autor ser dispensável o termo, tendo em vista que nesta (pet. inicial) deverão conter todas as informações necessárias que estariam no termo de apresentação. ⁸³¹ Dessa forma, se apresentado verbalmente o juiz lavrará termo de apresentação e, se por petição, contendo todas as informações requeridas pelo § 1.º do art. 735, dispensará a lavratura do termo, determinando as providências do § 2.º do art. 735. ⁸³²

3.3 Competência

Em razão da semelhança entre os procedimentos (arts. 735 e 736, CPC/2015), remete-se ao comentário do art. 735, item 3.2.

3.4 Oitiva e intervenção do Ministério Público

Igualmente ao procedimento anterior, após a apresentação, tendo sido lavrado o termo de apresentação ou não (v. item 3.2), será intimado o Ministério Público, a fim de que apresente parecer.

3.4.1 Rito e cumprimento

Em razão da semelhança entre os procedimentos (arts. 735 e 736, CPC/2015), remete-se ao comentário do art. 735, itens 3.3 e ss. Ressalta-se, apenas, que, diversamente do *cerrado*, aqui se verificará vício intrínseco (v. item 3).

3.5 Chamamento do testamenteiro, aceitação ou substituição

Em razão da semelhança entre os procedimentos, remete-se aos comentários do art. 735, itens 3.4 e ss.

Art. 737. A publicação do testamento particular poderá ser requerida, depois da morte do testador, pelo herdeiro, pelo legatário ou pelo testamenteiro, bem como pelo terceiro detentor do testamento, se impossibilitado de entregá-lo a algum dos outros legitimados para requerê-la.

§ 1.º Serão intimados os herdeiros que não tiverem requerido a publicação do testamento.

§ 2.º Verificando a presença dos requisitos da lei, ouvido o Ministério Público, o juiz confirmará o testamento.

§ 3.º Aplica-se o disposto neste artigo ao codicilo e aos testamentos marítimo, aeronáutico, militar e nuncupativo.

§ 4.º Observar-se-á, no cumprimento do testamento, o disposto nos parágrafos do art. 735.

1. Inovações do CPC/2015

Inova também com a mesma técnica do art. 735 neste art. 737 e reúne em quatro parágrafos, parcialmente, os conteúdos dos arts. 1.130, V, 1.131, 1.125 e parágrafo único, e 1.126 em um único dispositivo mais coerente.

Desaparece a menção a algumas pessoas que deveriam ser intimadas para acompanhar à inquirição de testemunhas, tal como o testamenteiro e os legatários.

Desaparece a indicação expressa à ratificação de três testemunhas, porém, verifica-se que não houve revogação expressa do CPC/2015 ao art. 1.878 do CC/2002, pelo que permanece, portanto, a necessidade de oitiva destas, ou de pelo menos uma delas, para que confirmem as assinaturas (das testemunhas e do testador) e as disposições do testamento. Devem ser, ainda, observadas as demais regras previstas no parágrafo único do art. 1.878 do CC/2002 e dos arts. 1.879 e 1.880, do CC/2002, os quais versam sobre a impossibilidade da presença das testemunhas, seja por morte ou por ausência (art. 22 do CC/2002).

Inova o § 3.º em relação ao art. 1.134 do CPC/1973 por introduzir, entre estes testamentos particulares, o testamento aeronáutico, mantendo a expressão militar como correspondente à força armada do exército.

Inova no § 4.º ao determinar que, para o cumprimento, deverá ser observado o disposto nos parágrafos do art. 735, tendo em vista que antes havia previsão genérica quanto à observância das regras contidas nos arts. 1.126 e 1.127, ambos do CPC/1973, os quais, conforme anteriormente mencionado, foram transformados nos parágrafos do art. 735 do CPC/2015.

2. Aspectos materiais do testamento particular e de sua confirmação

O procedimento trata de todos os demais testamentos previstos na legislação brasileira, referindo-se o *caput* ao particular, cuja previsão se encontra no art. 1.876 do CC/2002, e o § 3.º, aos codicilos (art. 1.881 a 1.885, do CC/2002) e as formas especiais (arts. 1.886 do CC/2002), quais sejam: a) marítimo – arts. 1.888,

1.990 a 1.892 do CC/2002; b) aeronáutico – arts. 1.889 a 1.891 do CC/2002; c) militar – arts. 1.893 a 1.896 do CC/2002.⁸³³

Assim como nos outros procedimentos já comentados, deverá ser observada a forma prevista no Código Civil para a elaboração de cada um destes, comprometendo-lhes a validade, como se observa da regra prevista no art. 1.892 do CC/2002, por exemplo.⁸³⁴

3. Aspectos processuais e procedimentais do testamento particular

3.1 Legitimação

Permanecem legitimados os principais “interessados”, como: a) o cônjuge sobrevivente, ou companheiro (desde que legalmente reconhecido); b) os herdeiros (legítimos ou instituídos) e os legatários; c) pelo testamenteiro; e pelo d) terceiro detentor do testamento, desde que impossibilitado de entregá-lo a algum dos outros legitimados para requerê-la.

Alcides de Mendonça Lima, ao comentar o CPC/1973, reconhece também, ainda que não previstos expressamente, a legitimidade ativa do Ministério Público e a Fazenda Pública para requererem o procedimento.⁸³⁵

Cumprir destacar que, neste procedimento, também se verifica a possibilidade de intimação do detentor para que apresente o testamento em seu poder, submetido às mesmas penalidades já descritas (v. comentários ao art. 735).

3.2 Competência

Segue a regra da apresentação e abertura, qual seja: onde estiver o testamento (v. comentários ao art. 735).

3.3 Pedido de abertura do procedimento

O pedido do interessado, que deverá ser formulado em petição inicial, instruída com o testamento, será feito por advogado ou pela Defensoria Pública, tendo em vista que, diversamente dos já tratados, este procedimento terá audiência para a oitiva das testemunhas; intimação dos demais herdeiros (os que não deram início ao procedimento) e manifestação destes e sentença para confirmar o que, como bem adverte Alcides de Mendonça Lima (comentários ao CPC/1973), “(...) não poderia ser feito sem a presença de profissional, mandatário do requerente ou dos requerentes (nada obsta que mais de um vá a juízo para o fim comum)”.⁸³⁶

Essa complexidade no procedimento se justifica, porque, nas palavras de José Olympio de Castro Filho (comentários ao CPC/1973), “(...) falta ao testamento particular a aprovação por tabelião, existente no testamento cerrado, ou a colaboração do tabelião, existente no testamento público, que são elementos reputados idôneos para a verificação de que o ato de última vontade foi efetuado espontaneamente, sem a coação e por pessoa capaz de exprimir sua vontade, torna-se necessária a comprovação em juízo desses requisitos mínimos para sua validade, o que se faz através do procedimento de jurisdição voluntária a que foi dado o nome impróprio de ‘confirmação de testamento particular’”.⁸³⁷

3.3.1 As provas: a audiência para ouvir testemunhas

Serão notificadas as testemunhas para comparecer em audiência e confirmarem, como preceitua o art. 1.878 do CC/2002, a) se as assinaturas constantes do testamento lhes pertencem; b) a testador; c) o conteúdo das disposições de última vontade; d) se o testamento foi lido em sua presença e e) se o testador se encontrava em perfeito juízo quando o assinaram.⁸³⁸ Para a audiência de instrução também serão notificados os sucessores e o Ministério Público.⁸³⁹

O Código Civil prevê, também, os casos de impossibilidade de comparecimento das testemunhas em juízo, ou de parte delas, em razão de morte ou ausência (art. 22 do CC/2002), conforme parágrafo único do art. 1.878, e do art. 1.879, do CC/2002. Dessa forma, ainda que viva apenas uma das testemunhas, se esta reconhecer o testamento, poderá o juiz, desde que entenda suficientemente provada a veracidade deste, confirmá-lo. Admite-se, ainda, conforme José Olympio de Castro Filho, que o mesmo vale para os casos de divergência entre depoimentos, desde que ao menos uma das testemunhas o reconheça e haja prova suficiente de sua veracidade, segundo o convencimento motivado do julgador (art. 371 do

CPC/2015).⁸⁴⁰ Poderá, ainda, o juiz, caso entenda necessário, requerer perícia grafológica, a fim de aferir se as assinaturas ali presentes (no testamento) são mesmo do testador e das testemunhas, ou, na falta destas (morte ou ausência), apenas do testador.⁸⁴¹

Quanto ao termo de apresentação, verificação de defeitos extrínsecos (art. 1.876, § 2.º, do CC/2002) e intrínsecos, bem como o registro, arquivamento e o “cumpra-se”, deverá ser observado o disposto nos parágrafos do art. 735 do CPC/2015 (v. art. 735, item 3.3), conforme aduz o § 4.º do art. 737 do CPC/2015.

3.3.2 Manifestação dos interessados

Embora o Código atual seja omissivo quanto ao ponto, trata-se de oportunidade conferida aos requerentes, bem como aos demais sucessores citados, para apresentarem qualquer discordância quanto ao testamento, sendo dispensável, caso não haja qualquer manifestação. Porém, em havendo contrariedade por qualquer dos interessados, inclusive, pela Fazenda ou pelo Ministério Público, o procedimento será convertido e remetido para a jurisdição litigiosa.⁸⁴²

3.3.3 Oitiva e intervenção do Ministério Público

Feita a oitiva das testemunhas, será ouvido o Ministério Público (*custos legis*), assim como nos demais procedimentos já comentados.

3.3.4 Cumprimento do testamento

Remete-se ao comentário do art. 735, itens 3.3 e ss. Ressalta-se, entretanto, que será analisada a possível existência de vício extrínseco e/ou intrínseco, para que possa ser declarado autêntico o testamento.⁸⁴³

3.4 Chamamento do testamenteiro, aceitação ou substituição

Remete-se aos comentários do art. 735, itens 3.4 e ss.

4. Aspectos materiais e processuais e procedimentais de outras formas de testamentos: o codicilo e os testamentos marítimo, aeronáutico, militar e nuncupativo

4.1 As espécies testamentárias “menores”

Como bem observa Alcides de Mendonça Lima, ao comentar o CPC/1973, “Tanto faz o testamento ser ordinário (público, cerrado e particular), como especial (marítimo, aeronáutico, e militar, inclusive o nuncupativo), como ser um codicilo, a atividade do juiz é a mesma no sentido de aferir a observância dos requisitos intrínsecos e extrínsecos em cada caso, para poder aplicar as normas procedimentais, ordenando, ou não, o cumprimento e posterior execução”.⁸⁴⁴

Assim, cada uma das formas previstas no § 3.º do art. 737 do CPC/2015, deverá observar os critérios de validade previstos na lei civil: a) os codicilos (arts. 1.881 a 1.885 do CC/2002); b) marítimo – arts. 1.888, 1.990 a 1.892 do CC/2002; c) aeronáutico – arts. 1.889 a 1.891 do CC/2002; d) militar – art. 1.893 a 1.896 do CC/2002, sendo este último o do nuncupativo.

As formas aqui descritas, como bem determina o próprio § 3.º, deverão observar os mesmos atos previstos para o “particular”, como, por exemplo, a notificação das testemunhas, bem como a oitiva destas. Já em relação ao cumprimento (registro e arquivamento), deverão observar os parágrafos do art. 735 (v. comentários ao art. 735).

Seção VI

Da herança jacente

1. Inovações do CPC/2015 na Seção

Pouco inova a Seção que trata da herança jacente, mas as pequenas alterações trazidas são especialmente pontuais e relacionadas: ao conteúdo art. 740, *caput* ; terminologia: art. 738; art. 739, § 1.º, I; art. 740, *caput* , art. 741, § 2.º; art. 743, 1.º; incorporações de mudanças legais: art. 740, § 6.º; art. 741, § 3.º; incorporação de inovações tecnológicas na comunicação processual; art. 741, *caput* . No mais, são os mesmos institutos materiais guiados pelo mesmo procedimento especial.

2. Aspectos materiais gerais da Seção – Da herança jacente

A proteção ao Direito Sucessório é a essência das razões materiais do procedimento especial de Herança Jacente, que se materializam pela arrecadação judicial dos bens. Se jaz a herança ⁸⁴⁵ deixada pelo falecimento de seu proprietário original, sua reunião judicial pelo procedimento especial protege direitos de seus eventuais sucessores (art. 1.786 do CC/2002) ausentes ou não identificados ou mesmo os direitos de credores e, ao fim, o direito de reversão ao Estado.

O CC/2002 define as situações em que se configura a herança jacente, define as diligências de arrecadação, de inventário e a chamada de herdeiros por edital para eventual habilitação ou mesmo para renúncia. Protege direitos de herdeiros e credores antes de prever a vacância, que preliminarmente não exclui herdeiros retardatários, até cinco anos desde a abertura da sucessão, quando então os bens passam ao Distrito Federal ou Município e mesmo à União, se situado em Território Federal (art. 1.822 CC/2002).

A redação aberta do art. 1.819 do CC/2002 ⁸⁴⁶ permite encaixar os mais variados casos de herança jacente, de modo diverso do art. 1.591 do CC/ 1916, que restringia às hipóteses ali previstas, como notou a doutrina. ⁸⁴⁷

Não se deve confundir a herança jacente, ⁸⁴⁸ que subsiste ao seu anterior titular após sua morte e aguarda habilitação, com a herança vacante, ⁸⁴⁹ que assim é declarada por falta de habilitação (art. 1.822 do CC): não havendo credores habilitados (art. 1.821) ⁸⁵⁰, nem herdeiros (art. 1.820 do CC); não se habilitando os possíveis herdeiros (art. 1.820, art. 1.822, parágrafo único) ⁸⁵¹ ou renunciando os herdeiros à herança (art. 1.823). Portanto, três são as condições para a configuração da vacância, que é, em algumas hipóteses, precedente temporária ao reconhecimento da vacância da herança.

2.1 Inexistência de herdeiros legítimos e interessados

Para que seja vacante a herança jacente não pode interessados acorrer herdeiros a ela, quando deixada, ou jacente. A existência e o interesse de herdeiros afastam a vacância da herança que jaz após a morte do titular, seja porque existem, seja porque se habilitam, seja porque não renunciaram.

Consideram-se herdeiros os colaterais, mas estes possuem tempo limitado para a habilitação, art. 1.822, parágrafo único, do CC, que se encerra em um ano, podendo ser declarada vacante, também, pela renúncia (art. 723), ⁸⁵² após o que passará ao patrimônio público. ⁸⁵³

2.2 Inexistência de herdeiros testamentários

Para que seja vacante a herança, sobre toda ou parte dela não poderá incidir declaração de vontade em testar, ou seja, não pode a herança ter sido objeto de testamento. O testamento afasta a vacância da herança que jaz após a morte do titular por instituir herdeiro testamentário ou legítimo. ⁸⁵⁴ Casos há em que a caducidade do legado pela pré-morte do beneficiário, somado à ausência de direito de acrescer, não torna jacente a herança, pela interpretação conjunta das disposições testamentárias. ⁸⁵⁵

3. A vacância e o direito do ente federativo: Município ou Distrito Federal

Declarada a vacância, pela inexistência ou desinteresse dos herdeiros, é que submerge o direito do Estado aos bens do morto. O Estado aqui é, em princípio, o ente federativo municipal, ⁸⁵⁶ no qual se situam os bens, ou o Distrito Federal, ou a hipótese mais rara pode vir a pertencer à União se o bem se situar em Território Federal. Isso decorre da expressa redação da segunda parte do art. 1.822 do CC: “decorridos cinco anos da abertura da sucessão, os bens arrecadados passarão ao domínio do Município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União quando situados em território federal”.

Quando os bens se situam em municípios diversos, ambos possuem interesse e legitimidade para iniciativa e participação no processo de herança jacente, ⁸⁵⁷ gerando também direitos materiais à vacância e processuais que se podem desdobrar em feitos acessórios ou paralelos.

O direito do ente federativo só se confirma após os cinco anos, ficando sujeito neste prazo à formação de direito à aquisição por usucapião, que pode se basear em posse iniciada antes ou depois da abertura da sucessão.

4. A natureza jurídica da herança jacente

Divide-se a doutrina na classificação da herança jacente, tratando-a como pessoa jurídica ou como acervo de bens.⁸⁵⁸ Celso Agrícola Barbi define como “estado transitório dos bens, (...) como simples universalidade de bens”,⁸⁵⁹ sem personalidade jurídica, mas com capacidade para ser parte, quer na fase de jacência ou de vacância, sempre antes de serem os bens transferidos aos sucessores.

O art. 75 do CPC, VI, estabelece que a herança jacente, ou vacante, será representada em juízo, ativa e passivamente, ou extrajudicialmente por seu curador, nomeado conforme o art. 739, inc. I, do CPC/2015. Ainda que se considere ente despersonalizado, pode estar em juízo e ser parte autora ou ré.

5. Aspectos processuais e procedimentais gerais da Seção

Os aspectos gerais do procedimento estão integralmente preservados entre os modelos dos CPC/1973 e CPC/2015, conforme virá minudentemente descrito a seguir.

Art. 738. Nos casos em que a lei considere jacente a herança, o juiz em cuja comarca tiver domicílio o falecido procederá imediatamente à arrecadação dos respectivos bens.

1. Inovações do CPC/2015

As inovações do art. 738 são apenas de terminologia, substituindo-se as expressões “sem perda de tempo” por *mediatamente* e “de todos os seus” bens por *dos respectivos* bens; mudanças sem nenhum interesse prático.

2. Aspectos materiais da arrecadação: os casos de jacência

Os casos em que a lei considera jacente a herança são aqueles do art. 1.818 do CC, o falecimento sem deixar herdeiro legítimo ou herdeiro testamentário. A jacência é a falta de assunção imediata à posse,⁸⁶⁰ que pode ser desconsiderada pelo direito de *saisine* (art. 1.784 do CC),⁸⁶¹ que transmite imediatamente a herança aos herdeiros. Contudo, por não se saber a quem efetivamente se transmitiu é que se abre o espaço procedimental à herança jacente.

A arrecadação é a tomada de posse de bens da herança jacente e pode ocorrer antes ou após o arrolamento, estando a ele coligado.

3. Aspectos processuais e procedimentais

Os fins procedimentais são múltiplos e sucessivos.⁸⁶² Primeiro a abertura da sucessão, logo a seguir a arrecadação e resguardo dos bens, depois o chamamento edital e a aceitação ou não das habilitações; confirmadas as habilitações, não se tratará de vacância. Se não atendem ao chamamento os herdeiros e é declarada a vacância no prazo de um ano, esta permanecerá suscetível de reversão pela habilitação tardia, mesmo após a declaração de vacância, pelo prazo de cinco anos desde a abertura da sucessão. Por fim, não havendo herdeiros habilitados ou interessados, a vacância e arrecadação ao Estado.

3.1 Imediatismo

O CPC/2015 substituiu a expressão “sem perda de tempo” pela expressão “imediatamente” para marcar a premência que deve guiar os atos subsequentes à abertura da sucessão daquele que deixando bens, não se sabe se deixou herdeiros ou onde estão esses herdeiros. José Olympio de Castro Filho assevera que “isso não significa, evidentemente, aqodamento judicial para proceder a arrecadação de bens, cumprindo, diversamente, que, ao determinar a medida, tenha o juiz ao menos algum indício de que os bens possam vir a ser considerados herança jacente”.⁸⁶³ Alcides de Mendonça Lima compara a redação do CPC/1973 com o CPC/1939, no qual constava o prazo de 24 horas, mais exíguo e de difícil cumprimento.⁸⁶⁴

Notícia da morte e o pressuposto de considerar-se jacente a herança, que pode ou não ser confirmada pelo atestado de óbito; havendo o óbito e sua confirmação pelo atestado.⁸⁶⁵

Consideram-se indícios suficientes à abertura do processo de herança jacente aqueles que põem em risco a posse ou propriedade dos bens remanescentes e de sua vacância, que justificariam também o procedimento cautelar de arrolamento (art. 301 CPC e art. 381, § 1.º). A jacência, em si, não justifica a

instauração do procedimento, pois os legitimados podem e devem pedir a abertura do inventário no prazo de dois meses desde a abertura da sucessão.⁸⁶⁶ O transpassamento desse prazo pode ser um indício da inexistência de herdeiros, a justificar iniciativa de outros legitimados.

3.2 Iniciativa de abertura

A iniciativa se deve guiar pelo interesse estatal na declaração da vacância e na arrecadação dos bens que não possuam herdeiros ou sobre os bens não pendam direitos de crédito; a legitimidade para a iniciativa na busca da herança jacente é preponderantemente do Estado, do ente federativo, por sua Advocacia Pública. Pode ser a iniciativa do juiz.⁸⁶⁷ Também se cogita do interesse e iniciativa dos legitimados para requerer a abertura do inventário (arts. 615 e 616 do CPC) na herança jacente, mas se interessados e legitimados há na abertura do inventário não é jacente a herança.

Com isso presume-se a existência de interessados, afastando inicialmente a atuação de ofício pelo juiz. Entretanto, a atuação de ofício do juiz, determinando a abertura do procedimento de herança jacente, era reconhecida sem nenhuma objeção pela doutrina na vigência do CPC/1973⁸⁶⁸ e mantida sob a forma de arrecadação no CPC/2015.⁸⁶⁹ Essa iniciativa ou *atividade* pode cingir-se na indicação de um curador e não propriamente nos atos processuais de abertura do procedimento, deixando a este curador, no âmbito de suas expressas atribuições consignadas em lei, isto é, os ônus, os poderes, as faculdades e os deveres processuais correspondentes à parte que estará a representar.

3.3 Abertura de ofício e demais legitimados

Não pode o juiz abrir de ofício o inventário. Não mais se legitima o juiz para a iniciativa inventário, vez que o novo art. 615 do CPC não refere identicamente ao conteúdo do art. 989 do CPC/1973.⁸⁷⁰

Contudo, para o procedimento de herança jacente, mesmo após a supressão do dispositivo do art. 989 do CPC-1973, mantém-se o juiz como “legitimado” para a instauração e para designação de curador, primeiro porque a natureza assecuratória emerge e persiste e, também, porque o art. 738 se mantém incólume neste ponto ao dizer que “o juiz (...) procederá imediatamente à arrecadação”, assim como o art. 740. Trata-se de tutela provisória, de urgência, da espécie cautelar; tal cautelaridade está respaldada pelo art. 297 do CPC e, ainda que se tenha mitigado a ideia que o processo cautelar tutele apenas o processo e não o direito; o direito que se tutela na herança jacente nem se sabe a quem pertence, mas pode estar em risco. Pode ser direito de herdeiros legítimos ou testamentários, pode ser do Estado e nele se conter algum dos interesses públicos.

A legitimidade para abertura do procedimento de herança jacente é dada a quem tem interesse na vacância, especialmente a Fazenda Pública que poderá arrecadar os bens se declarados vacantes, após a confirmação judicial da inexistência de herdeiros ou de herdeiros interessados. Os legitimados a abertura do inventário⁸⁷¹ não o serão para a herança jacente, pois, se herdeiros há, não é jacente a herança, por evidente contradição. Neste caso têm poderes para pedir a abertura do inventário.

Assim, há que se ver com critério a hipótese de que “qualquer interessado” possa pedir a abertura do procedimento de herança jacente em nome próprio, pois deve se identificar vínculo que não seja suficiente à abertura do inventário. Salvo se o objetivo for a conversão em inventário (art. 741, § 3.º).

Igualmente pode pedir a abertura do procedimento especial de herança jacente o Ministério Público, por seu membro Promotor de Justiça, seja porque atua de modo amplo nos procedimentos de jurisdição voluntária (art. 720) ou porque estão identificados no acervo de bens algum dos interesses protegidos pela Instituição. Também a Defensoria Pública poderá identificar interesses protegidos pela Instituição e promover o pedido de abertura ou a conversão da herança jacente em inventário, quando represente herdeiros. Poderá também o titular do Registro Civil comunicar ao Ministério Público ou à Fazenda Pública o falecimento de pessoa em cujo atestado de óbito não há notícia de herdeiros, mas deixou bens.

3.4 Capacidade para estar em juízo e para ser parte

Como dito acima, o art. 75 do CPC, VI, estabelece que a herança jacente, ou vacante, será representada em juízo, ativa e passivamente, ou extrajudicialmente por seu curador, nomeado conforme o art. 739, I, do CPC. Ainda que se considere ente despersonalizado, pode estar em juízo e ser parte autora ou ré.

Assim, tem capacidade para estar em juízo e também de ser parte, capacidade genérica.⁸⁷² A herança jacente pode ela própria ser *legitimada ativa* para proteger-se e proteger patrimônio e bens que possam

sofrer ameaça, desapossamento ou perda da propriedade; pede em nome próprio, com legitimidade processual específica. A herança jacente pode ela própria ser também *legitimada passiva* de procedimento comum ou especial. A possibilidade de existir outro legitimado *passivo* no procedimento especial pode ser cogitada quando o objeto processual for a retomada de bens em posse ilegítima daquele que não é sucessor a qualquer título ou não é credor, por exemplo. Nestes casos a contenciosidade aflora e requer a expedição de medidas protetivas de natureza provisória cautelar, não mais nos contornos voluntários ou “graciosos” da jurisdição voluntária. Para tanto, para ser parte ativa ou passiva é necessária a representação do curador da herança jacente, sem o que não se pode falar em capacidade para estar em juízo ou de ser parte, conceitos que não se confundem.⁸⁷³

3.5 Competência

A competência de jurisdição é da Justiça Comum dos Estados e do Distrito Federal, e a jurisdição de foro determinada pela lei será especificada pela organização judiciária, dependendo da estruturação local. Assim, competente é o juiz da comarca em que tiver domicílio o falecido, podendo recair sobre o juiz único ou o juiz de varas especializadas, tal como o de sucessões.

A competência de foro, competência material, é confirmada pela sucessão de regras processuais contidas no Código Civil e no Código de Processo Civil.

O Código Civil prevê no art. 1.785 que “a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido” e o CPC neste art. 738 reitera que “o juiz em cuja comarca tiver domicílio o falecido procederá imediatamente à arrecadação” dos bens, bem assim o procedimento de identificação dos sucessores legítimos ou testamentários ou a declaração da vacância e a sucessão estatal. Não bastassem as duas referências, o mesmo CPC prevê no art. 48 que “o foro do domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro”.⁸⁷⁴

Como dito, quando os bens se situam em municípios diversos, ambos os entes federativos possuem interesse e legitimidade para iniciativa e participação no processo, sem alterar integralmente a competência que será a priori a do foro do domicílio do autor da herança.

Situações diversas vêm previstas no CPC, tal como a do parágrafo único do art. 48, quando o autor da herança *não possuía domicílio certo*, no qual será competente o foro de situação dos bens imóveis (inc. I); havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes (inc. II); e não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio (inc. III).

Se o autor da herança *possuía vários domicílios* a solução dar-se-á pelo § 1.º do art. 46: “tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles”, ainda que não se possa tratar o autor da herança efetivamente como um “réu” na jurisdição voluntária. Se o autor da herança possuía *bens em domicílio ou domicílios diversos do local de seu domicílio*, ainda que se critique, será competente o foro do domicílio do autor da herança.

A regra dos foros subsidiários sucessivos somente terá sentido quando não se tenha certeza sobre o local do domicílio do autor da herança (sendo ele incerto), situação em que qualquer dos locais onde se situam os bens imóveis será competente; havendo apenas bens móveis no espólio, qualquer dos locais onde estejam esses bens será o competente para o procedimento de herança jacente.

O juízo competente para a herança jacente não tem a capacidade atrativa universal capaz de deslocar a competência de processos outros, como nos processos de inventário, exceto após a conversão em inventário e cumpridos os requisitos do art. 612 do CPC, ou seja, os fatos objeto de prova possam ser demonstrados.

3.6 O objeto, o fim da arrecadação e o credor legitimado

O objeto da arrecadação são os bens da herança jacente.

O fim da arrecadação é formar o monte dos bens deixados a ser preservado à espera do eventual herdeiro que não se tem certeza que exista ou tendo-se certeza da existência, não se sabe onde se encontra, ou mesmo no interesse da proteção dos bens que venham a ser considerados vagos e de destinem a ente público.

O credor que era legitimado expressamente para requerer a arrecadação, por meio do procedimento de herança jacente (art. 856, § 2.º, do CPC/1973), não tem mais o amparo amplo para esse fim na lei processual, deixando dúvida sobre a sua legitimidade para essa medida. O art. 1.821 do CC assegura aos credores o direito de pedir o pagamento das dívidas reconhecidas, nos limites das forças da herança, sem deixar claro se preserva a legitimidade processual para a conservação, pelo arrolamento, por exemplo.⁸⁷⁵ No CPC/1973 a legitimidade do credor para o arrolamento era menor que a legitimidade para a arrecadação pela herança jacente, esta sim dada pelo dispositivo do procedimento cautelar extinto.⁸⁷⁶

Art. 739 . A herança jacente ficará sob a guarda, a conservação e a administração de um curador até a respectiva entrega ao sucessor legalmente habilitado ou até a declaração de vacância.

§ 1.º Incumbe ao curador:

I - representar a herança em juízo ou fora dele, com intervenção do Ministério Público;

II - ter em boa guarda e conservação os bens arrecadados e promover a arrecadação de outros porventura existentes;

III - executar as medidas conservatórias dos direitos da herança;

IV - apresentar mensalmente ao juiz balancete da receita e da despesa;

V - prestar contas ao final de sua gestão.

§ 2.º Aplica-se ao curador o disposto nos arts. 159 a 161.

1. Inovações do CPC/2015

Inova o CPC/2015, especialmente por omitir nesta parte o destinatário dos bens vacantes, que vinham indicados no art. 1.143 do CPC/1973, artigo correspondente a este art. 739, como sendo União, Estados e Distrito Federal, substituídos desde o CC/2002 (art. 1.822) pelo Município e pelo Distrito Federal. Esta alteração trazida originalmente pelo Código Civil desloca de um ente federativo para outro a destinação patrimonial da herança vacante, obrigando ao novo CPC o ajuste que se esperava, vez que já fora derogado pela lei material.

Outra inovação é especialmente terminológica, contida no inc. I do art. 739, que substitui a expressão anterior “assistência” por “intervenção”, de modo correto, pois se tratando do Ministério Público não é adequado que se esperasse dele a assistência, atividade congruente com a atuação da Defensoria Pública, por exemplo.

Quanto às incumbências do curador não há nenhuma inovação no CPC/2015.

2. Aspectos materiais da arrecadação, curadoria para guarda, conservação e administração

Os arts. 739 e 740 têm conteúdo similar ao do CPC anterior, que poderia ser inverso, pois a arrecadação vem descrita (art. 740) após elencarem-se os atos conservativos e as incumbências do curador (art. 739).

O objeto da arrecadação já foi dito, são os bens da herança jacente; os fins materiais do procedimento especial são, inicialmente, a arrecadação, guarda, conservação e administração até que sejam encontrados herdeiros ou declarada a vacância e transferência ao Estado.

Nesse curso, os bens arrecadados, a depender da espécie, do estado, da titularidade da posse, da existência de direitos em formação, da sanidade tributária, entre outros, demandam iniciativas de arrecadação e de conservação concretas do curador.⁸⁷⁷ Os atos materiais e extrajudiciais, de administração ou de gestão da herança jacente são dos mais diversos, tais como a cobrança e recebimento de aluguéis, petição de dividendos, percepção de frutos, pagamento de despesas de administração, pagamento de reformas e de dívidas ou despesas correntes, pagamento de tributos, renovação ou rompimento de compromissos etc.

2.1 Bens móveis, imóveis e semoventes

De mais fácil identificação, bens imóveis, móveis sujeitos a registro ou outros bens móveis e

semoventes são preferencialmente arrolados e arrecadados, seja plena ou limitada a propriedade do autor da herança. São exemplos de bens móveis as obras de arte, objetos de decoração, obras de arte, valores em espécie, títulos de crédito, contas bancárias etc.

2.2 Outros bens e direitos

A arrecadação, como dito na jurisprudência, deve abranger a busca, o arrolamento e apossamento de todos os bens, quando passíveis de posse, corpóreos e incorpóreos, inclusive direitos possessórios e obrigacionais;⁸⁷⁸ aqueles bens ou direitos que não podem ser propriamente possuídos, como os incorpóreos: direitos industriais, marca registrada, patentes, nome empresarial, desenho industrial e o ponto comercial, por exemplo, devem igualmente ser descritos ou arrolados e conservados por medidas protetivas, se pertencentes ao autor da herança.

3. Aspectos processuais e procedimentais

Três aspectos afloram no art. 739: a) os cuidados que demandam a herança jacente; b) o curador e sua nomeação; c) as incumbências iniciais do curador; d) incumbências adicionais do curador. Dentre os cuidados reclamados pela herança jacente estão a arrecadação, a guarda, a conservação e a administração; quanto ao curador deve-se observar a sua escolha e as razões; quanto às suas incumbências iniciais estão a representação em juízo e fora, a própria arrecadação, guarda e administração, as medidas conservativas e a apresentação de balancetes e contas finais; e, por fim, os demais deveres e responsabilidades de sua administração.

3.1 Cuidados que demandam a herança jacente

São cuidados essenciais, sem esquecer de outros que possam decorrer da própria coisa que componha a herança jacente, estão a arrecadação, a guarda, a conservação e a administração ou gestão da massa patrimonial.

3.1.1 Arrecadação e o arrolamento

Como dito, o objeto da arrecadação são os bens da herança jacente; o fim é a preservação dos bens e direitos dos sucessores, sejam herdeiros, credores ou mesmo o Estado, como destinatário final após a vacância.

A arrecadação é a tomada de posse de bens da herança jacente e pode ocorrer antes, simultaneamente ou após o arrolamento, estando a ele coligado e um completando o outro.⁸⁷⁹ Essa arrecadação pode se dar por meio de atos voluntários de entrega dos bens, por atos extrajudiciais conforme descritos no art. 740, com arrolamento e arrecadação, com presença de auxiliares do juízo (oficial de justiça, acompanhado do escrivão ou do chefe de secretaria) e do curador. Essa arrecadação se pode dar também por outras medidas judiciais de conservação, sejam provimentos provisórios de urgência, antecipada ou cautelar ou provimentos finais sentenciais; nestes casos o arrolamento antecede à efetiva arrecadação.

O arrolamento é a listagem dos bens, a descrição pormenorizada de cada um, com características e indicadores essenciais próprios, sejam bens imóveis, móveis ou semoventes, feita sob a forma de *auto de arrolamento e arrecadação*, quando a diligência se realiza nos locais externos ao fórum, tais como a residência do autor da herança ou sob a forma de *termo de arrolamento e arrecadação*, quando realizada nas dependências do órgão jurisdicional. Tais registros devem ser assinados pelo juiz, pelo curador e pelos representantes institucionais da Fazenda Pública e Ministério Público, se acompanharam os atos.

3.1.2 Guarda

“Ter em boa guarda” é preservar, proteger, evitar dispersão e perdas. A guarda, conforme a natureza do bem, requer atos distintos e específicos, para que se considerem bem guardados os bens.

Se bens corpóreos móveis e imóveis a boa guarda se caracteriza pela preservação da posse (poder sobre a coisa) direta ou indireta e a incolumidade do direito real ou da propriedade, plena ou limitada. A proteção da posse é corrente em muitos casos, porquanto os bens da herança podem se encontrar em poder de terceiros ou ser apropriados após a morte do autor da herança, ensejando a proposição dos interditos possessórios (reintegração e manutenção de posse ou interdito proibitório), conforme o nível de agressão à posse e a justiça⁸⁸⁰ ou injustiça dessa apropriação. A proteção da propriedade por meios

das ações petitórias próprias, reivindicatória e de imissão de posse, conforme tivesse ou não a posse do autor da herança ao tempo da abertura da sucessão, são também possíveis. Outras demandas, tais como embargos de terceiro,⁸⁸¹ ação de dano infecto, ação de oposição, ação ou exceção de usucapião, ação de divisão ou de demarcação, declaratórias e anulatórias de marcas também se encontram no largo espectro de demandas e defesas que integram o âmbito reipersecutório de uma herança jacente.

3.1.3 Conservação

Conservação é mais que a simples manutenção da integridade; é dar à coisa ou ao direito o adequado destino. Num primeiro momento é manter produtivo, sem decrescer, mas é fazer produzir mais frutos, render, aumentar.

3.1.4 Administração

A Administração compreende a gestão dos frutos e rendimentos produzidos pelo bem, o custeio adequado das despesas, de modo a fazer render, atos todos demonstráveis pelas apresentações contábeis exigidas pela lei, ou seja, pelos balancetes mensais e prestação final de contas. Esses relatos comuns à atividade mercantil expressam a natureza.

José Maria Tesheiner sintetiza a noção de administração do seguinte modo: “(...) a herança jacente é administrada por um curador nomeado pelo juiz; a herança vacante é administrada pelo Poder Executivo, até sua incorporação ao patrimônio público”.⁸⁸² Assim, a concepção de administração compreende dois períodos razoavelmente demarcados: antes da vacância, aos cuidados do curador e, após a vacância, aos cuidados do Poder Executivo. Crítica é a primeira fase, quando não há ainda a vacância e a assunção estatal. A administração dos bens deixados pelo autor da herança, como outras massas de bens, tais como os bens da insolvência civil, da recuperação de empresas e na falência ou do inventário, demandam a atenção administrativa e a gestão que no caso será de um curador da herança jacente, que por eles zelará com orientação do juiz e fiscalização do Ministério Público.

3.2 O curador, sua nomeação, duração da função e habilidades

O curador, nos Estados em que há curadores judiciais, será dentre estes escolhido; nos demais casos incumbe ao juiz a escolha, podendo recair sobre pessoas capazes de preencher requisitos que se cogita essenciais ao gestor, como a experiência, idoneidade e tino para a atividade de administração patrimonial ou sobre profissionais com habilitação profissional correspondente, que pode ser um administrador, contador, advogado, engenheiro, gestor mobiliário etc.⁸⁸³ Ao contrário do inventariante, escolhido entre os interessados na herança, havendo jacência o curador não possui relação hereditária com o autor da herança e tampouco interesse, regra que também vale para o curador dos bens de ausentes. É ou pode ser, portanto, um estranho.

O art. 739 prevê que os bens ficarão sob a “guarda, a conservação e a administração de um curador”, sem indicar diretamente neste ou nos demais dispositivos que se referem ao curador da herança jacente o ato e a forma de sua nomeação (art. 739, § 1.º e § 2.º; art. 740, *caput*, § 2.º e § 6.º). Esse aparente vazio pode ser contornado por ter o CPC em outros pontos definidos que os curadores, assim como outros auxiliares, dependem deste ato de compromisso, feito por termo nos autos, para o exercício regular de seus misteres. Nas “Disposições Comuns à Tutela e à Curatela”, art. 759 e inc. I vem definido que “(...) o curador será intimado a prestar compromisso no prazo de 5 (cinco) dias contado da (...) nomeação feita em conformidade com a lei”. Tal compromisso se refere não só aos curadores que protegem pessoas, mas também aos curadores de bens e interesses como a herança jacente.

A duração da curatela está coligada aos fins de sua existência e subsistirá enquanto exigirem proteção os bens da herança jacente, sendo temporária e indeterminada,⁸⁸⁴ tendo a plena gestão durante a sua nomeação, podendo ser antecedido por depositário antes da sua nomeação (art. 740, § 2.º), substituído no exercício por interino no caso de extrema gravidade (art. 762) ou substituído por outro curador em caso de remoção (art. 761).

Os predicados exigíveis do curador estão associados aos seus deveres tal como a reconhecida idoneidade (art. 1.745, parágrafo único), a honestidade, a experiência, a disposição e o tirocínio.

3.3 Incumbências iniciais do curador

Várias são as incumbências do curador da herança jacente que se relaciona com essa massa

patrimonial de modo diferente do gestor de negócios, ⁸⁸⁵ desde a representação extrajudicial e judicial, arrolamento, arrecadação, guarda, conservação de bens e direitos, promoção de medidas conservativas, apresentação de balancetes e contas finais.

3.3.1 Representar a herança judicial e extrajudicialmente

Representar civilmente segundo o Código Civil, arts. 115 a 120, se caracteriza pela manifestação de vontade pelo representante (curador) em nome do representado (herança jacente), manifestando vontade nos negócios extrajudiciais. A base para o exercício do poder de representação extrajudicial do curador da herança jacente é conferida pela lei processual (art. 739, § 1.º, I). Representar judicialmente, a seu turno, é ir a juízo em nome de outrem, manifestando vontade nos atos e negócios processuais que exijam a presença e manifestação da parte ou mesmo como terceiro (art. 75, VI).

3.3.2 Guardar e conservar os bens arrecadados

Guardar, considerando-se o que dito acima, é velar, preservar, proteger, evitar dispersão e perdas, conforme seja o bem móvel ou imóvel, corpóreo ou incorpóreo, fungíveis ou infungíveis, divisíveis ou indivisíveis, singulares ou coletivos. Boa guarda é atenção voltada à preservação, ao atendimento dos fins sociais e individuais do bem.

Conservar, por outro lado, traduz a noção de tempo e de seu transcurso, fazendo com que os bens e direitos existentes ao tempo da abertura da sucessão subsistam somados ao que produzirem como frutos e rendimentos; não definham, não se reduzam, não se percam. Conservar é manter; manter com vigor, com higidez, com valor econômico, especialmente.

3.3.3 Promover a arrecadação de outros bens porventura existentes

Promover a arrecadação é ir em busca de outros bens. Requer-se diligência do curador para que amplie a apuração e persecução a outros bens que possam se encontrar em poder de terceiros, perdidos ou mesmo ocultos. O esforço na busca dos bens da herança jacente não se esgota com os atos iniciais de arrolamento e arrecadação, que podem não ter reunido todo o acervo graças à iniciativa judicial, da Fazenda Pública ou do Ministério Público. É dever do curador, tendo notícias, indícios ou elementos indicadores da existência de bens que não estão arrecadados, ir ao encalço desses bens.

Deve-se lembrar também as vedações, como a que impede que sejam comprados, ainda que em hasta pública pelos curadores, testamentários e, os bens confiados à sua guarda ou administração (art. 497, inc. do CC).

3.3.4 Executar as medidas conservatórias dos direitos da herança

Executar medidas conservatórias compreende “providências e diligências relativas a direitos no interesse da herança” jacente. ⁸⁸⁶ Exemplos de iniciativas conservatórias são as medidas interruptivas da prescrição da pretensão ou da decadência, contratação e renovação de contratos.

3.3.5 Prestar contas mensalmente por balancete

É dever do curador da herança jacente apresentar contas ao juiz mediante a apresentação de balancete mensal, discriminando a receita obtida com a administração dos bens e a despesa com a guarda, conservação etc. ⁸⁸⁷ O balancete de verificação, segundo a NBC T 2.7, ⁸⁸⁸ é a relação de contas, com seus respectivos saldos, extraída dos registros contábeis em determinada data. Seu grau será consentâneo com sua finalidade e deve conter no mínimo os seguintes elementos: a) identificação da Entidade; b) data a que se refere; c) abrangência; d) identificação das contas e respectivos grupos; e) saldos das contas, indicando se devedores ou credores; f) soma dos saldos devedores e credores; nome, registro no Conselho Profissional respectivo e assinatura do contabilista responsável.

3.3.6 Prestar contas ao final de sua gestão

É dever de todo administrador de bens ou valores alheios prestar contas de sua administração. A ação própria para esse fim, a partir do CPC/2015 é uma só e não são duas, como no CPC anterior; trata-se da *ação de exigir contas*, arts. 550 a 553 do CPC, procedimento único, mas dúplice, adequado aos direitos que envolvem essas relações de administração, capaz de permitir que as contas sejam “apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver”. E

por ser dúplice a ação de exigir contas possibilita que a sentença contenha saldo favorável ao autor ou réu e a sua consequente execução como título (art. 552).

3.4 Outros direitos, deveres e obrigações aplicáveis ao curador

Perdeu-se a oportunidade de corrigir a omissão do CPC anterior e fazer incluir o curador da herança jacente ao lado do depositário e do administrador, dispensando a remissão do parágrafo único do art. 739. Ao tratar “do Depositário e do Administrador” a Seção III do Capítulo III do Livro III da Parte Geral do novo CPC (arts. 159, 160 e parágrafo único, e 161 e parágrafo único) restringe-se a estes dois auxiliares da justiça e de seus direitos e deveres, principalmente.

A redação do art. 159, que trata da guarda e a conservação de bens, omite os bens da herança jacente, deixando claro que a remissão poderia se restringir aos arts 160 e 161 e seus parágrafos únicos, efetivamente aqueles que descrevem direitos e deveres.

Por seu trabalho, o curador poderá perceber “remuneração que o juiz fixará, levando em conta a situação dos bens, ao tempo do serviço e às dificuldades de sua execução” (art. 160), desde que não seja dativo, o que é possível. Tal remuneração, quando houver, terá de ser como em outros casos de administradores judiciais: proporcional e ajustada à capacidade de pagamento do próprio monte de bens, ao dispêndio de trabalho e à sua complexidade. Considerado o volume de trabalho, poderá o juiz autorizar, a pedido do curador, “um ou mais prepostos” para auxiliá-lo nas funções que ultrapassem a sua capacidade de guarda, conservação e administração (art. 160, parágrafo único); considere-se também que são do curador a representação judicial e extrajudicial, a arrecadação de bens ainda não trazidos ao processo e as medidas judiciais protetivas desses bens. Nesses casos, mantém-se o curador como responsável pela apresentação de balancete, prestação de contas finais e outros deveres, mesmo quando a atividade seja feita por seus prepostos.

Dentre os direitos do curador está, além de sua remuneração, o de ser ressarcido de despesas que tenha feito em favor da herança, ainda quando perca sua remuneração, pois se gastou, não pode a herança enriquecer sem lhe repor despesas que não tinha dever de custear.

O curador da herança jacente, igualmente ao depositário e ao administrador, “responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo” (art. 161 do CPC). A regra do parágrafo único do art. 161, quanto à responsabilidade civil por prejuízos causados, responsabilidade penal e sanção por ato atentatório à dignidade da justiça destina-se especificamente ao depositário infiel. Qualquer responsabilidade terá de ser apurada em ação própria e não no âmbito do procedimento de herança jacente, com iniciativa de legitimados lesados contra o curador que supostamente os lesionou.

Como dito acima, créditos e débitos decorrentes da atividade de administração e de guarda podem, entretanto, ser discutidos na *ação de exigir contas*, arts. 550 a 553 do CPC, procedimento afeito ao direito debatido, permitindo que as contas sejam “apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver”. A natureza dúplice da ação de exigir contas possibilita que a sentença contenha saldo que pode favorecer a qualquer das partes envolvidas na administração (art. 552).

Poderá também responder por ação de depósito ou outro procedimento que tenha a função protetiva da posse ou propriedade, de modo equivalente à responsabilidade de outros administradores judiciais.

889

3.5 Eximção, suspensão e remoção do curador

As “Disposições Comuns à Tutela e à Curatela” (art. 759-763) tratam da nomeação, compromisso e exercício das funções, mas também das possibilidades de eximção mediante escusa, suspensão, remoção e a consequente dispensa dos deveres e encargos, aplicáveis ao curador da herança jacente.

A duração da curatela está coligada aos fins de sua existência e subsistirá enquanto exigirem proteção os bens da herança jacente, sendo temporária e indeterminada, ⁸⁹⁰ tendo a plena gestão durante a sua nomeação, podendo ser antecedido por depositário antes da sua nomeação (art. 740, § 2.º), substituído no exercício por interino no caso de extrema gravidade (art. 762) ou substituído por outro curador em caso de remoção (art. 761).

A *eximção do exercício* é ato próprio de quem não deseja a função e apresenta escusa fundamentada ao juízo, antes ou até cinco dias depois de entrar em exercício (art. 760); a *suspensão do exercício* é ato do juízo em casos de extrema gravidade (art. 762) e a *remoção do exercício* se dá a pedido do próprio curador pelo esgotamento das funções ou do Ministério Público, motivada por desatendimento de seus deveres.

3.6 Intervenção do Ministério Público e da Advocacia Pública

A legitimação da intervenção do Ministério Público, embora ampla na jurisdição voluntária, encontra limite no art. 178, I e II, deixando ao curador o protagonismo, embora possa atuar, em alguns casos extremos, como assistente litisconsorcial.⁸⁹¹

A Advocacia Pública, que atua em representação ao ente público que integra, pode também agir coadjuvando o curador ou mesmo diretamente como parte (art. 17) ou mesmo recorrer (art. 615), desde que demonstre o interesse.

Art. 740 . O juiz ordenará que o oficial de justiça, acompanhado do escrivão ou do chefe de secretaria e do curador, arrole os bens e descreva-os em auto circunstanciado.

§ 1.º Não podendo comparecer ao local, o juiz requisitará à autoridade policial que proceda à arrecadação e ao arrolamento dos bens, com 2 (duas) testemunhas, que assistirão às diligências.

§ 2.º Não estando ainda nomeado o curador, o juiz designará depositário e lhe entregará os bens, mediante simples termo nos autos, depois de compromissado.

§ 3.º Durante a arrecadação, o juiz ou a autoridade policial inquirirá os moradores da casa e da vizinhança sobre a qualificação do falecido, o paradeiro de seus sucessores e a existência de outros bens, lavrando-se de tudo auto de inquirição e informação.

§ 4.º O juiz examinará reservadamente os papéis, as cartas missivas e os livros domésticos e, verificando que não apresentam interesse, mandará empacotá-los e lacrá-los para serem assim entregues aos sucessores do falecido ou queimados quando os bens forem declarados vacantes.

§ 5.º Se constar ao juiz a existência de bens em outra comarca, mandará expedir carta precatória a fim de serem arrecadados.

§ 6.º Não se fará a arrecadação, ou essa será suspensa, quando, iniciada, apresentarem-se para reclamar os bens o cônjuge ou companheiro, o herdeiro ou o testamenteiro notoriamente reconhecido e não houver oposição motivada do curador, de qualquer interessado, do Ministério Público ou do representante da Fazenda Pública.

1. Inovações do CPC/2015

Inova o art. 740, especialmente no *caput*, ao retirar o verbo ‘comparecer’, que induzia à participação direta e obrigatória do juiz do ato de arrecadação e substituiu-o pelo verbo ‘ordenar’. Inova também seus seis parágrafos ao fundir em apenas um artigo as disposições que vinham dispersas em vários do CPC/1973, bem como suprimir algumas disposições consideradas ultrapassadas.

2. Aspectos materiais de arrolamento e da arrecadação

A arrecadação é a tomada de posse de bens da herança jacente diretamente, por atos do curador (acompanhado do juiz, promotor de justiça, auxiliares judiciais ou autoridade policial) ou pela transmissão voluntária da posse ou, ainda, como atos resultantes do cumprimento de medidas judiciais. A arrecadação visa a todos os bens deixados, imóveis e móveis, corpóreos e incorpóreos, direitos industriais, marca registrada, patentes etc. Como dito, o arrolamento é a descrição ou listagem dos bens com características e indicadores próprios, de modo a individuar todo o acervo de bens remanescentes.

3. Aspectos processuais e procedimentais

A complexidade dos atos agora fundidos em um artigo descrevem o arrolamento e a arrecadação, os sujeitos que podem ou devem estar presentes nestes atos externos aos prédios judiciais, o uso da força policial, a arrecadação de bens em comarca diversa, o depositário provisório, a colheita de informações e auto de inquirição e informação, a inspeção de documentos pessoais, guarda e conservação, a suspensão

do arrolamento e da arrecadação, a intervenção do Ministério Público e da Advocacia Pública.

3.1 Arrolamento e a arrecadação e seu registro em auto circunstanciado

Ambos os atos, que podem um anteceder o outro são feitos sob a forma de *auto de arrolamento e arrecadação circunstanciados*; subsequentemente ao arrolamento, em geral, ocorrerá a arrecadação, ato próprio de apossamento dos bens. O *auto circunstanciado* (art. 484) opõe-se ao *termo circunstanciado* (art. 620 do CPC) como texto escrito pelo escrivão ou do chefe de secretaria (art. 159 do CPC), descritivo dos atos e diligências realizadas na residência do autor da herança jacente ou nos demais locais onde possam ser identificados, arrolados e arrecadados seus bens. A norma não mais se refere à residência do morto porquanto esta indicação de local específico não contemplava a amplitude de possibilidades, visto que o ato pode se estender à residência, local de trabalho, locais de lazer ou mesmo a abrigo, casa de idosos, empresa, comércio, indústria, propriedade rural ou outros locais nos quais se possa identificar bens ou direitos do autor da herança jacente. Desta forma o local do arrolamento e da arrecadação é aquele ou aqueles, quaisquer que sejam, nos quais se encontram os bens ou nos quais se possam realizar tais atos.

3.2 Participantes dos atos de arrolamento e arrecadação

A presença do juiz não é mais considerada essencial para a realização do arrolamento. A nova disposição prevê que “oficial de justiça, acompanhado do escrivão ou do chefe de secretaria e do curador, arrole os bens. Não se mostra mais incontornável a exigência o acompanhamento direto do juiz, como no CPC anterior,⁸⁹² em que vinha expressa a necessidade de sua presença ‘à residência do morto’, dispensa esta consentânea com outras medidas conservativas que não exigem o acompanhamento direto do juiz, como arresto ou sequestro. A inquirição prevista pelo § 3.º do art. 740, feita aos moradores da casa, e da vizinhança “sobre a qualificação do falecido, o paradeiro de seus sucessores e a existência de outros bens” poderá ser realizada por autoridade policial, se o juiz não participar dos atos. De modo equivalente, não há mais referência à participação do juiz nos atos em lugares distantes (art. 1.148 do CPC/1973), atos que competirá ao curador e aos demais auxiliares do juízo, oficial de justiça, escrivão ou chefe de secretaria.

O oficial de justiça, acompanhado do escrivão ou do chefe de secretaria, é presença imprescindível para realizarem-se os atos de redação oficial que lhes são próprios, (art. 152, inc. I, do CPC), no autor circunstanciado, com descrição pormenorizada dos bens da herança no auto circunstanciado.

O escrivão ou o chefe de secretaria é essencial, pois lhes são próprios os atos de redação do auto circunstanciado, em acompanhamento à diligência de arrolamento a arrecadação, estas sim, ordenadas pelo juiz e executadas pelo oficial de justiça.

O curador também pode ou não participar dos atos de arrolamento e arrecadação da herança jacente. Da leitura exclusiva do c *aput* do art. 740 se pode imaginar necessária, mas o § 2.º do mesmo artigo excepciona para os casos em que “não estando ainda nomeado o curador, o juiz designará depositário e lhe entregará os bens, mediante simples termo nos autos, depois de compromissado”. Desse modo, estando o curador nomeado, deve participar; não estando, os demais auxiliares do juízo o fazem, ficando os bens aos cuidados de um depositário, até que seja nomeado o curador para assumir tal encargo.

Nos casos em que o juiz é provocado para abertura do procedimento de herança jacente pode ser que lhe seja oferecido o rol parcial ou total dos bens deixados pelo autor da sucessão, restando, neste caso, somente a confirmação da correção do rol de bens e a efetivação da arrecadação, vez que o arrolamento já tenha sido feito por petição.

O auto ou os autos de arrolamento e de arrecadação são registros formais e circunstanciados que devem ser assinados pelos auxiliares judiciais que os acompanharam (oficial de justiça, escrivão ou o chefe de secretaria) pelo curador, se tiver presenciado, pois já nomeado e pelo juiz. Os representantes institucionais da Fazenda Pública e do Ministério Público, se acompanharam os atos, também o assinam.

3.3 Depositário provisório pela ausência do curador

Como observado no item anterior, o curador não pode participar dos atos de arrolamento e arrecadação da herança jacente, se não está ainda nomeado (art. 740, § 2.º), situação em que “o juiz designará depositário e lhe entregará os bens, mediante simples termo nos autos, depois de compromissado”. Essa providência pode ter algumas variantes, como se notou no CPC anterior: “(...) a

rigor, se na comarca não existe ou não está em exercício, o serventuário público que deva funcionar, a escolha do depositário provisório ou foi feita antes da arrecadação ou foi feita no momento desta. Na primeira hipótese compreende-se possa ser o depositário previamente compromissado; mas na segunda o compromisso será posterior”.⁸⁹³ O compromisso do depositário será feito por *termo de compromisso* nos autos, quando realizada em cartório, antecedendo aos atos de arrecadação; se feita no momento e no lugar em que se realiza o arrolamento e a arrecadação, só pode ser por um *auto de compromisso*, que poderá ser ratificada por *termo*, posteriormente ou, ainda, apenas homologado pelo juiz. Em qualquer caso o que se pretende é designar alguém que assuma a responsabilidade, ainda que temporária, pela guarda, podendo ser um depositário profissional, oficial ou não, ou um depositário provisório, mas sempre compromissado com as finalidades conservativas do patrimônio.

Após essa designação provisória há que se fazer a definitiva, preferencialmente ao curador nomeado, este sim com encargos e deveres mais extensos que aquele que atende a uma medida de urgência.

3.4 Colheita de informações e auto de inquirição e informação de autoridade judicial ou policial

A inquirição prevista pelo § 3.º do art. 740, feita aos moradores da casa e aos vizinhos, objetiva inicialmente buscas “sobre a qualificação do falecido, o paradeiro de seus sucessores e a existência de outros bens”, ou informações que levem a essas.

Entendendo-se como facultativa a presença do juiz no arrolamento e na arrecadação, a busca de informações e provas sobre o autor da herança, sobre destinatários da herança jacente ou sobre bens omitidos ou não encontrados poderá ser realizada por autoridade policial e não mais exclusivamente pelo juiz.⁸⁹⁴ Para tanto, cabe ao juiz a convocação dessa autoridade para acompanhar o oficial de justiça, o escrivão ou chefe de secretaria e o curador, se já estiver nomeado.

Como objetiva a busca de informações que possam servir ao procedimento e seus desdobramentos, pode prender-se inicialmente em dados que não constem da certidão de óbito e que possam servir a este procedimento, à sua conversão em inventário ou mesmo à declaração de vacância; indicação e possível paradeiro de herdeiros legítimos ou testamentários, indicações sobre outros bens integrantes da herança ou bens em comarca diversa, além de outros relacionados às finalidades procedimentais. Tal diligência pode coincidir ou não com o arrolamento e a arrecadação, podendo em cada uma de suas hipóteses antecederem ou vir após esses atos.

Dessa diligência será lavrando *auto de inquirição e informação*, diverso do *auto circunstanciado de arrolamento e arrecadação*, segundo se extrai diretamente da norma escrita.

3.5 Inspeção de documentos pessoais, guarda e conservação

O dispositivo que trata do exame de papéis vem agora em sequência ao que dispõe sobre a inquirição de pessoas, § 3.º e § 4.º do art. 740, em distribuição mais adequada das diligências e busca de informações sobre possíveis herdeiros e sobre outros bens além daqueles identificados na residência e em locais de convívio do autor da herança. Ao contrário do ato de ouvir pessoas, que o novo CPC estende à autoridade policial, neste de examinar “reservadamente os papéis, as cartas missivas e os livros domésticos” e, de verificar se, “não apresentam interesse” mandar “empacotá-los e lacrá-los para serem assim entregues aos sucessores do falecido ou queimados quando os bens forem declarados vacantes” preservou-se privativamente ao juiz.⁸⁹⁵

Dois momentos estão demarcados, o *primeiro* de exame ou inspeção dos objetos e registros pessoais ou mesmo íntimos, tais como diários, livros de notas ou memórias, que se pode cogitar nos dias de hoje não se restringem a anotações em papel, mas registros eletrônicos, em mídias, computadores, contas de e-mail, *notes*, redes sociais etc.; o *segundo* de apreciação da utilidade dessas informações para o objetivo da herança jacente, sua destinação a herdeiros ou sua vacância. Dessa apreciação duas novas opções surgem, uma *positiva*, quando as informações colhidas contribuem à identificação de herdeiros e outra *negativa*, resultando na inutilidade das informações para a herança. Diante da primeira-positiva o juiz deve registrá-la e dela valer-se como prova anexada ao processo para diligenciar na identificação de interessados ou de novos bens; diante da segunda-negativa, deve “empacotá-los e lacrá-los para serem assim entregues aos sucessores do falecido ou queimados quando os bens forem declarados vacantes”.⁸⁹⁶ Com isso preserva-se a intimidade do autor da herança, a sua memória, seus registros íntimos, garantidos constitucionalmente.

A destruição dos registros pessoais ou ‘queima’ deve ser interpretada segundo o interesse social, pois

pode haver nesses ‘documentos’ alguns que possam servir à memória coletiva, à comunidade, à cidade, ao país.⁸⁹⁷

3.6 Arrecadação de bens em local diverso daquele da abertura da sucessão

É possível que existam bens em comarcas diversas ou diversas daquela na qual se realiza o ato inicial de arrolamento e arrecadação, informação que pode vir já descrita na abertura do procedimento ou surgir das inquirições do juiz, da autoridade policial ou, ainda, prestadas por curador ou pretensos herdeiros. Neste caso terá o juiz de valer-se da carta precatória (art. 237, inc. III), solicitando como deprecante ao juízo deprecado o arrolamento e a arrecadação; submetendo-se aos rigores formais (art. 260), ao prazo (art. 262), à itinerância (art. 262), à preferência de uso de meios eletrônicos (art. 263 e art. 264), aos riscos de recusa (art. 267) e aos rigores de cumprimento e devolução (art. 267).

Não é de se excluir que existam bens em país diverso daquele em que tinha domicílio o autor da herança, notadamente nas regiões de fronteira. Neste caso poderá valer-se de carta rogatória, por meio de outro tribunal (art. 237, inc. II) ou da cooperação jurídica internacional, por meio de autoridade central (arts. 26 e 27), desde que compatível internamente e no país estrangeiro, para o arrolamento e a arrecadação de bens. Ambos os instrumentos visam originalmente o arrolamento e a arrecadação, mas também podem se destinar a obtenção de informações sobre a existência de herdeiros ou sobre a existência de outros bens, além daqueles que motivaram a comunicação inicial.

Essas iniciativas e o ‘poder inquisitivo’ do juiz que preside a herança jacente se projeta desde as primeiras notícias do falecimento e jacência e após a declaração da vacância, que pode ser revertida pelo aparecimento tardio daqueles herdeiros que preservam seus direitos. Tal poder se transmite também ao juiz que cumpre as cartas precatória ou rogatória, bem como à autoridade internacional cooperante.

A existência de bens em países diversos pode gerar competências paralelas, pois é competente para a ação o país em que se situam os imóveis;⁸⁹⁸ sem exclusão da competência judiciária brasileira, que pode simultaneamente conhecer da herança jacente.

3.7 Não realização ou suspensão do arrolamento e da arrecadação

Só é jacente a herança que não tem herdeiros, sejam legítimos ou testamentários, de quem não possuía cônjuge ou companheiro, que não possui testamenteiro reconhecido; se remanescem herdeiros, não é jacente a herança, não se justificando o procedimento especial. Com isso, se o procedimento especial se iniciou, ainda que não se tenham praticado atos materiais de arrolamento e arrecadação eles não se iniciam, ou se já estão em curso esses atos, devem ser imediatamente interrompidos quando surgem sucessores. Não se justifica seu início ou prosseguimento, até que sejam confirmados ao juízo, por documentos, que há os herdeiros sucessores interessados na herança.

Uma herança jacente só permanece assim e é convertida em herança vacante se não aparecerem os sucessores ou se esses herdeiros declararem o desinteresse pelos bens. O objetivo de proteger os bens deixados e assegurar os direitos desaparece quando os próprios herdeiros surgem em sua busca. Em qualquer fase inicial, média ou final em que se encontre o procedimento de declaração de herança jacente será ela suspensa se “apresentarem-se para reclamar os bens o cônjuge ou companheiro, o herdeiro ou o testamenteiro notoriamente reconhecido”. Esses ‘herdeiros’, ou os herdeiros indicados no art. 1.829 do CC frustram a arrecadação, pois suas manifestações dão fim à presumível jacência e vacância.⁸⁹⁹ Ao testamenteiro incumbe, dentre outras, dar cumprimento às disposições testamentárias, e a administração da herança se não houver cônjuge, companheiro, herdeiros.

O aparecimento de interessados na herança e o silêncio (não oposição) de qualquer outro interessado, do curador, do Ministério Público ou da Fazenda Pública induzem à entrega dos bens a esses interessados. Havendo oposição à entrega dos bens abrem-se hipóteses diferentes, pois se acolhida a oposição, prossegue o procedimento de herança jacente; se rejeitada a oposição, abre-se o inventário ou converte-se a herança jacente em inventário.

3.8 Oposição da Advocacia Pública e do Ministério Público

A oposição aqui tem um sentido lato e não de ação de oposição e se caracteriza pela manifestação de interesse na causa. O objeto da oposição é o afastamento do herdeiro aparente ou o reconhecimento de direito indevido ou inexistente.

Cada um ao seu modo: a) a Fazenda Pública, pelo seu representante judicial, a Advocacia Pública do município ou Distrito Federal, em defesa dos interesses deste ente federativo na arrecadação e posterior declaração de vacância; e b) o Ministério Público para “intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses (...) e nos processos que:” envolvam interesse público ou social (art. 178, inc. I) interesse de incapaz; (art. 178, inc. I) e litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana (art. 178, inc. I). Deve-se observar que “a participação da Fazenda Pública não configura por si só hipótese de intervenção do Ministério Público” (art. 179) e vice versa, pois mesmo na defesa do interesse público ou social a atuação do Ministério Público pode não abranger o interesse público *secundário* que a Fazenda Pública pode defender. Também as Fazendas Públicas dos três níveis federativos podem ter interesses ou créditos tributários a defender, justificando, neste caso, a habilitação e não a oposição aqui mencionada. Essa ‘oposição’ poderá suscitar debates sobre a competência das justiças comum da União e do Estado ou Distrito Federal, com provável manutenção na justiça local, por tratar-se de intervenção anômala.

Art. 741 . Ultimada a arrecadação, o juiz mandará expedir edital, que será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 3 (três) meses, ou, não havendo sítio, no órgão oficial e na imprensa da comarca, por 3 (três) vezes com intervalos de 1 (um) mês, para que os sucessores do falecido venham a habilitar-se no prazo de 6 (seis) meses contado da primeira publicação.

§ 1.º Verificada a existência de sucessor ou de testamenteiro em lugar certo, far-se-á a sua citação, sem prejuízo do edital.

§ 2.º Quando o falecido for estrangeiro, será também comunicado o fato à autoridade consular.

§ 3.º Julgada a habilitação do herdeiro, reconhecida a qualidade do testamenteiro ou provada a identidade do cônjuge ou companheiro, a arrecadação converter-se-á em inventário.

§ 4.º Os credores da herança poderão habilitar-se como nos inventários ou propor a ação de cobrança.

1. Inovações do CPC/2015

Inova o CPC/2015 ao incorporar as vantagens de comunicação trazidas pela rede mundial de computadores e os sítios dos órgãos jurisdicionais criados nesta rede que são desde alguns anos largamente utilizados para fins processuais diversos. Essa incorporação que se iniciara claramente com a Lei 11.419/2006, Lei do Processo Eletrônico, e em mudanças pontuais do CPC/1973, tem no CPC/2015 ⁹⁰⁰ sua ampliação com a permissão à produção, armazenamento, validação e comunicação de atos processuais por meio eletrônico (art. 193); especialmente no plano da comunicação, permite-se a citação edital (art. 257, inc. II), o edital de leilões judiciais (art. 886, inc. IV), a arrecadação de bens de ausentes (art. 745), o edital de depósito de coisas vagas (art. 746, § 2.º), a publicação de sentença de interdição (art. 755, § 3.º), além de outros não descritos. Sabe-se já das vantagens comunicacionais e da redução de custos, não havendo mais razão para resistir a este progresso, observados os princípios ou requisitos da autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação, confidencialidade limitada (art. 195).

Além desse ponto, dois outros chamam a atenção, um menor, com alteração apenas da expressão finado por falecido, sem importância maior e outra com a inclusão no § 3.º do art. 741 do companheiro, equiparado ao cônjuge, como sujeito que ao surgir e manifestar interesse, considera-se suficiente para impedir a abertura ou interromper o procedimento de herança jacente. Quanto ao mais, não há alterações comparando-se o artigo do CPC antecedente.

2. Aspectos materiais da conclusão da arrecadação e identificação de interessados

A arrecadação, como tomada direta da posse de bens da herança jacente visa a reunião todos os bens deixados, imóveis e móveis, corpóreos e incorpóreos, direitos industriais, marcas registradas, patentes etc. Após isso, buscam-se identificar testamenteiro e comunicar aos herdeiros a existência de bens deixados em herança para que ultimem a sua habilitação, que reconhecida, permite a conversão da herança jacente em inventário. Também se prevê o chamamento a credores para cobrança de dívidas deixadas pelo autor da herança; e a comunicação a autoridade consular, quando for estrangeiro o falecido.

3. Aspectos processuais e procedimentais

Neste item serão abordados a comunicação e publicidade, conhecimento sobre os herdeiros, citação, habilitação e conversão da herança jacente em inventário.

3.1 Procedimentos de comunicação dupla e publicidade edital, ciência aos herdeiros e prazos para habilitação ou para atos processuais

A inovação do edital está em não mais ‘estampar’ somente jornais impressos, mas “será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 3 (três) meses, ou, não havendo sítio, no órgão oficial e na imprensa da comarca, por 3 (três) vezes com intervalos de 1 (um) mês, para que os sucessores do falecido venham a habilitar-se no prazo de 6 (seis) meses contado da primeira publicação”.

Não se alteram os prazos do CPC/1973 para este CPC/2015, exceto na indicação do que antes era de trinta dias que passa a ser de um mês, sem obedecer a forma de contagem em dias úteis. Mantém-se expressamente na norma a finalidade do edital, qual seja, o chamamento, “para que os sucessores do falecido venham a habilitar-se” no procedimento de herança jacente e pedir a sua consequente conversão em inventário.

Com a publicação na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça superam-se parcialmente algumas discussões sobre o alcance que possuíam publicações locais, da comarca, imaginando-se que melhor alcance terá agora, com a espantosa propagação que os meios eletrônicos e digitais proporcionam.

A *rede mundial de computadores* é o local no qual estão disponíveis o *sítio do tribunal* a que está vinculado o juízo e também a *plataforma de editais* do Conselho Nacional de Justiça; todos os tribunais dos estados federativos e do Distrito Federal possuem sítios na *rede*, o que faz presumir desnecessária a publicação “no órgão oficial e na imprensa da comarca, por 3 (três) vezes com intervalos de 1 (um) mês”. O tempo de permanência *sítio do tribunal* e na *plataforma de editais* do Conselho Nacional de Justiça deve ser de três meses. Como dito, superam-se parcialmente as discussões sobre os conceitos de *imprensa da comarca* e *imprensa de circulação local* ⁹⁰¹ se grande parte dos editais tiver circulação com êxito na finalidade pelos meios eletrônicos e não apenas na sede do juízo (art. 232, inc. II, do CPC/1973). Mas a publicação dupla na *rede* poderá gerar controvérsia sobre a contagem de prazos, se não for simultânea, vez que o início da publicação abre a contagem de dois prazos (art. 1.820 do CC/2002 e art. 741 do CPC). A solução pode ser a adoção, por analogia, da regra do art. 257, inc. III, do CPC.

Não havendo sítio do órgão judicial a publicação terá de ser feita em dois veículos: a) na *imprensa da comarca* ou *imprensa de circulação local* e; b) em órgão oficial, em geral diário oficial do Estado, diário oficial da Justiça dos Estados ou DF, diário oficial eletrônico ou outro o veículo oficial impresso ou eletrônico para a publicação da comunicação estatal. Essas publicações deverão se repetir por três vezes, com intervalos de um mês entre uma aparição e outra. Não se fazendo do modo descrito, a comunicação dupla não atende à exigência na contagem dos prazos; assim, terão de ser publicados: a1) no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e; a2) na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça ou; b1) no órgão oficial; b2) e na imprensa da comarca. O início da contagem, contudo, dependerá da forma adotada: se seguir a forma a1 + a2, o prazo se inicia a partir do primeiro dia em que seja publicado num dos locais sucessivos (no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e; na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça), se seguir a forma b1 + b2 (no órgão oficial; e na imprensa da comarca), se inicia com a primeira publicação em qualquer dos veículos, obedecendo ao disposto no inc. III do art. 257, CPC/2015 e art. 741. Ainda poderá o juiz “determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias” (art. 257, parágrafo único).

A ciência aos ‘herdeiros’ é o fim principal, senão único dos editais, com a jacência da herança e o chamamento para que manifestem ou não interesse pelos bens deixados.

Os prazos são diferentes para duas categorias de sucessores e para a realização de atos de habilitação. Os colaterais possuem até seis meses a partir da primeira publicação para habilitarem-se, decaindo do direito se não se habilitarem neste prazo (art. 1.822, parágrafo único, do CC); os demais herdeiros possuem também seis meses a partir da primeira publicação para habilitarem-se (art. 741), podendo após este prazo, sem decair do direito, ainda vindicarem (art. 1822, do CC, primeira parte). Após um ano da primeira publicação, “sem que haja herdeiro habilitado, ou penda habilitação, será a herança declarada vacante” (art. 1.820); após cinco anos da abertura da sucessão sem manifestação de interesse de herdeiros, passarão ao domínio definitivo do Município ou do Distrito Federal (art. 1822, do CC, segunda

parte).

3.2 Conhecimento da existência de herdeiros e citação na arrecadação

A comunicação por meio de editais ou outro que alcance os herdeiros interessados, testamentário, objetiva fazer chegar a esses ‘sucessores’ a notícia da morte e abertura da sucessão, para que se habilitem à herança quando não se tem certeza de sua existência ou sabendo-se que existem e quem são, não se sabe onde estão. Tendo-se conhecimento da existência e sabendo-se onde estão, isto é, ‘herdeiro’ certo em lugar certo, a citação terá de ser pessoal, sob pena de nulidade (art. 280 e art. 239).

Contudo, comunicados por edital quaisquer desses ‘herdeiros’, e vindo eles ao processo, demonstrando seu vínculo e qualidade, não mais se justifica a persistência da jacência e improvável a vacância. Com isso, reduzem-se os poderes instrutórios do juiz, apequena-se a atividade de fiscal da ordem jurídica do Ministério Público, decai o interesse patrimonial da Fazenda Pública e seu representante, finda a função gestora do curador e tende à finalização o procedimento de herança jacente.

3.3 Habilitação de herdeiros e seu julgamento

Habilitação é o ato de vir a juízo manifestar interesse no objeto do processo, no caso da herança jacente, manifestar interesse na sucessão dos bens deixados pelo falecido. Aquele que se habilita pede que se lhe reconheça em juízo o direito que tem no plano material.

Julgada procedente a habilitação do herdeiro ou herdeiros deve converter-se o procedimento de herança jacente em procedimento de inventário ou em arrolamento. Essa procedência pode ser favorável ao herdeiro, ao cônjuge ou companheiro ou ao testamentário. Cabe ao curador entregar os bens.⁹⁰² Sendo improcedentes a habilitação ou habilitações, declara-se a vacância da herança e prossegue a contagem do prazo para a atribuição patrimonial dos bens ao Município ou Distrito Federal.

Disputas patrimoniais extrajudiciais ou judiciais não têm lugar neste procedimento, podendo ensejar a instauração de outras ações contenciosas que não se confundem com o procedimento da herança jacente.

3.4 Conversão da arrecadação em inventário ou arrolamento

Conforme o que foi dito acima, vindo os ‘herdeiros’ ao processo, demonstrando seu vínculo e qualidade, não há sentido no prosseguimento do procedimento de herança jacente e nem na declaração de vacância. Habilitadas e confirmadas as habilitações, impõe-se a conversão do procedimento em inventário, cessando ou atenuando-se os poderes, funções, interesses e deveres de juiz, órgão do Ministério Público, Advocacia Pública e curador, respectivamente.

Como visto, se julgada procedente a habilitação, converter-se o procedimento de herança jacente em procedimento de inventário ou em arrolamento; se julgada improcedente a habilitação, declara-se a vacância da herança.

O aproveitamento dos atos do procedimento de herança jacente em inventário segue princípio processual da instrumentalidade, equiparando-se o ato de conversão apenas parcialmente ao ato de abertura do inventário (art. 611), que se processa a requerimento, como também deve ser a conversão. São úteis todos os dados descritivos sobre o patrimônio do falecido, fruto dos esforços de arrolamento e de arrecadação, mas não se dispensa a solenidade de lavratura do termo circunstanciado das primeiras declarações do inventariante, com todas as exigências do art. 620 do CPC, seus parágrafos, seus incisos e alíneas; prosseguindo revestido de todas as minúcias procedimentais que lhe são próprias e foram em maioria preservadas no CPC/2015.

Já o arrolamento terá lugar quando o valor dos bens for inferior a mil salários mínimos (art. 644), sem que se exija neste procedimento simplificado o mesmo rigor descritivo do inventário, sendo aqui dispensada a lavratura de termos iniciais e cabendo a avaliação aos próprios herdeiros (art. 660); ao fim lavrar-se-á um único termo assinado pelo juiz, inventariante, ‘partes presentes’ e advogados.

3.5 Comunicação à autoridade consular o falecimento de estrangeiro

Quando o falecido for estrangeiro incumbe ao juízo comunicar à autoridade consular do país da nacionalidade desse o ‘fato’ da conclusão da arrecadação, sem prejuízo das etapas anteriores de abertura

do procedimento da herança jacente, arrolamento, arrecadação, publicação de editais e citação, pois não há diferenças nessas fases seja o falecido um brasileiro ou um estrangeiro.

Essa autoridade pode ser de um consulado regional ou dos consulados vinculados às representações diplomáticas situadas em Brasília e objetiva precipuamente a ciência dessa autoridade, sem que permita a manifestação direta e própria de representante diplomático no procedimento. Havendo já manifestação de herdeiros interessados, parece desnecessária a comunicação,⁹⁰³ pois visa a ampliação do chamamento e o estímulo à busca da herança, que neste exemplo já está atendido.

Havendo interesse de herdeiros do estrangeiro morto, seja por moto próprio, ou seja, pela ciência dada à representação consular, procederá o interessado do mesmo modo, habilitando-se no procedimento e pedindo a conversão em inventário.⁹⁰⁴ Não se reconhece a sentença estrangeira para o fim de habilitação, salvo se amparada em convenção específica. Jurisprudência considera a exigência da comunicação como imprescindível e seja ‘anulada’ a sentença que concluiu o processo sem a comunicação consular,⁹⁰⁵ para o fim de determinar que se faça o ato faltante e outra sentença seja dada no lugar daquela que foi desconstituída. Como alternativa resta a comunicação consular por meio do Ministério de Relações Exteriores (MRE) ou cooperação jurídica por meio do Ministério da Justiça (MJ).

3.6 Habilitação dos credores, juízo universal e prova do direito

O art. 741, § 4.º, do de modo idêntico ao art. 1.154 do CPC/1973 prevê que “os credores da herança poderão habilitar-se como nos inventários ou propor a ação de cobrança,” permitindo a “habilitabilidade dos credores, enquanto jaz a herança, tal como ocorre quando já aberto o inventário”, do mesmo modo que podem ser propostas ações condenatórias ou executivas de títulos judiciais ou extrajudiciais⁹⁰⁶ e mesmo outras com a finalidade somente declaratória.

Neste sentido identifica-se aqui uma atratividade, sem que se caracterize o juízo universal do inventário, atraindo a competência das demais ações para o juízo da herança (jacente) ainda que seja qualquer forma herança ou monte a partilhar, após arrecadados os créditos e quitadas as dívidas. Assim, tem-se que a competência de jurisdição e de foro da herança jacente é incapaz de atrair para si todas as ações relativas à herança. Diversa é o conflito de competência entre o inventário relativo aos bens de um dos cônjuges, previamente falecido, e a herança jacente decorrente da morte do cônjuge supérstite na pendência do inventário: neste caso “não [se] retira do juízo do inventário a competência para processar e deliberar a respeito do procedimento de arrecadação de herança jacente”.⁹⁰⁷

Se o juízo competente para a herança jacente não for o mesmo do inventário, a conversão daquela neste obriga a remessa ao competente, lugar onde deverão ser feitos os pagamentos, posteriores às habilitações e reconhecimento das dívidas.

Para a habilitação de credores segue-se os arts. 642 a 646, Seção referente ao *Pagamento das Dívidas* na fase que antecede à partilha no inventário. Pontes de Miranda afirma que a verificação dos créditos é incidental, processando-se em apartado, sem afetar a arrecadação dos bens da herança jacente.⁹⁰⁸ Havendo dúvida sobre a correção de determinada dívida, antes que se torne litigiosa a disputa pelos bens da herança é possível a reserva de bens, requerida pelos interessados e autorizada pelo juiz.⁹⁰⁹

A forma está descrita nos parágrafos do art. 642 e 643 do CPC/2015,⁹¹⁰ autua-se em apenso, tratando-se de dívida líquida, que deverá vir demonstrada literalmente, destacando-se valor ou bens suficientes a solvê-la. Faz-se a alienação se necessária ao pagamento, da forma prevista no art. 730 do CPC, após pronunciarem-se o curador, os interessados, o Ministério Público e a Fazenda Pública, por seu representante.

As impugnações à habilitação de qualquer crédito são legítimas e podem ser propostas por quaisquer daqueles que integram adequadamente a relação processual formada.

3.7 Prejudicialidade entre a herança jacente e outras ações

Não se pode excluir a possibilidade de outras ações que tentem infringir o conteúdo de arrecadação contido no procedimento de herança jacente, tal como as declaratórias puras (arts. 19 e 20), declaratória de paternidade,⁹¹¹ embargos de terceiro, ação de oposição, ações possessórias (arts. 554 a 568), declaratórias de domínio ou usucapião, petições, outras ações.

A prejudicialidade e paralisação do procedimento de herança jacente e a eventual declaração de

vacância só tem sentido se há risco de desfalque do patrimônio arrecadado; se há possibilidade de acréscimo, como no caso em que o falecido era autor de uma ação de usucapião, o resultado de improcedência não reduz o patrimônio arrecadado e a procedência o amplia.

Art. 742 . O juiz poderá autorizar a alienação:

- I – de bens móveis, se forem de conservação difícil ou dispendiosa;
- II – de semoventes, quando não empregados na exploração de alguma indústria;
- III – de títulos e papéis de crédito, havendo fundado receio de depreciação;
- IV – de ações de sociedade quando, reclamada a integralização, não dispuser a herança de dinheiro para o pagamento;
- V – de bens imóveis:
 - a) se ameaçarem ruína, não convindo a reparação;
 - b) se estiverem hipotecados e vencer-se a dívida, não havendo dinheiro para o pagamento.

§ 1.º Não se procederá, entretanto, à venda se a Fazenda Pública ou o habilitando adiantar a importância para as despesas.

§ 2.º Os bens com valor de afeição, como retratos, objetos de uso pessoal, livros e obras de arte, só serão alienados depois de declarada a vacância da herança.

1. Inovações do CPC/2015

Não há inovação nenhuma de conteúdo e expressões neste art. 742, que funde os arts. 1.155 e 1.156 do CPC/1973, restando o parágrafo único do art. 1.155 como § 1.º e o art. 1.156 como § 2.º do art. 742 atual.

2. Aspectos materiais da alienação de bens vacantes

A alienação é uma das formas de perda da propriedade, previstas no art. 1.275 do CC, sendo ela um dos elementos integrantes do feixe que integram o direito de propriedade. Alienar integra o direito de propriedade e se sujeita aos interesses ou riscos inerentes ao domínio, que são voluntários ou involuntários. São exemplos de perda além da alienação, a renúncia, o abandono, o perecimento da coisa e a desapropriação.

A alienação consiste na transferência de um bem ou direito, de um titular a outro, que pode ser disposição ou fruto de decisão judicial, que pode também ser onerosa ou gratuita.⁹¹² Nas alienações previstas no art. 742 só se cogita da onerosidade e são justificadas pela conveniência em evitar-se a sua conservação no conjunto de bens da herança jacente, seja no caso de móveis pela dificuldade e custo de conservação, inutilidade imediata em semoventes, risco de depreciação de títulos ou valores mobiliários e; nos imóveis, risco de ruína, hipoteca vencida etc.

Objetivam a preservação patrimonial, no interesse imediato da herança jacente e dos eventuais herdeiros ou do interesse público mediato do Estado, se vacante a herança.

2.1 Bens passíveis de alienação

Embora a alienação deva ser cogitada após a declaração da vacância, ainda durante a jacência, podem a circunstâncias indicadas no artigo justificar essa antecipação. Segundo cada categoria de bem, cogitaram-se razões principais, mas não únicas, para a alienação.

a) Bens móveis, se forem de conservação difícil ou dispendiosa; excluindo-se desse rol os móveis e equipamentos pessoais, de uso profissional e aqueles de valor inestimável associados à memória (art. 742, § 2.º); considera-se dispendiosa a conservação que tende a consumir o próprio valor do bem; considera-se difícil a conservação que envolva técnica própria ou contratação de pessoa.

b) Semoventes, quando não empregados na exploração de alguma indústria, pois tais animais tendem a gerar ônus ou despesas na manutenção. A solução, contudo, é simplista, podendo gerar conflituosidade em vista da relação mantida com animais de estimação, que podem ter outra destinação, que não a

alienação;

c) Títulos e papéis de crédito, havendo fundado receio de depreciação; tal alienação pode demandar decisão com certa complexidade, dada a exigência de avaliação, além dos juízos próprios de conveniência, decorrentes de análise econômica. Ver também os comentários ao art. 730, *Alienações*, no qual foram detalhados aspectos especiais desse procedimento voluntário.

d) Ações de sociedade quando, reclamada a integralização, não dispuser a herança de dinheiro para o pagamento; igualmente no tocante a estas espécies de bens tal alienação pode demandar decisão complexa, dada a exigência de avaliação, além dos juízos próprios de conveniência, decorrentes de análise econômica, financeira e societária. Ver além dos comentários ao art. 730, *Alienações*, no qual foram detalhados aspectos especiais desse procedimento voluntário, os comentários aos arts. 599 a 609, relativos à ação de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres, que interacionam interesses sociais com dos eventuais sucessores.

e) Bens imóveis: a) se ameacem ruína, não convindo a reparação; b) se estiverem hipotecados e vencer-se a dívida, não havendo dinheiro para o pagamento; (a) os bens relacionados na primeira parte devem ser alienados após decisão se condicionam também à apreciação da conveniência da preservação dos bens, dentre os quais pode haver algum também de valor afetivo, embora imóvel; (b) os bens sujeitos à garantia real, quando não há fundos para quitação da aquisição não solvida integralmente, devem ser alienados, considerada a conveniência e a onerosidade das eventuais cláusulas do contrato ou negócio havido.

2.2 Outros bens

A lista do art. 742 não é taxativa ou como querem outros, a lista não é exaustiva, mas enunciativa, sendo possível que existam outras espécies de bens ou mesmo direitos que possam ser alienados, sempre com o mesmo objetivo. Alcides de Mendonça Lima alerta que “as próprias hipóteses estatuídas podem não ser as únicas que tornem necessárias a alienação, pois outros bens, não indicados, podem estar sujeitos à mesma solução, com as devidas adaptações, conforme a espécie ou natureza,⁹¹³ e conforme a urgência.

3. Aspectos processuais e procedimentais

As alienações judiciais vêm agora previstas de forma simplificada no art. 730, tendo-se no CPC/2015 suprimindo o procedimento antes previsto nos arts. 1.113 a 1.119, que remete aos arts. 879 a 903 atuais, como procedimento supletivo do modo de realização da alienação em leilão ínsito no processo de execução, interpretada ‘no que couber’ e for compatível com a seção I do Capítulo que trata da Jurisdição Voluntária.

3.1 Peculiaridades da alienação: legitimidade e forma

A expressão ‘poderá’, contida no CPC/1973 e mantida no CPC/2015, deve ser interpretada de forma ampla, observado cada um dos fundamentos justificadores da alienação, que podem ser o risco, a onerosidade, a inconveniência na preservação, a depreciação, a ameaça de ruína, as obrigações ou outras. Esta amplitude de motivações estende também a legitimação para o pedido, que pode ser de qualquer dos interessados, do Ministério Público, da Fazenda Pública, por sua Advocacia Pública e mesmo por iniciativa do juiz, se ele próprio identifica a necessidade. Essa atuação de ofício possui certa natureza cautelar.

Não se pode cogitar da alienação direta, embora as leis processuais tenham simplificado e incorporado modalidades mais efetivas nos procedimentos de jurisdição voluntária ao absorver as regras de alienação típicas do processo executivo relativamente aos atos de alienação propriamente ditos (art. 730 c/c arts. 870 a 903).

3.2 Sustação da alienação por adiantamento

É possível também que a Fazenda Pública ou habilitado (art. 742, § 1.º) possa adiantar a importância para as despesas geradas pelo procedimento de herança jacente e mesmo pelas outras hipóteses contratuais, legais, infortunistas etc.

O interesse de algum habilitado na preservação dos bens se justifica para o caso de ser este

reconhecido como herdeiro e não se declarar a vacância, mas converter-se a jacência em inventário. O interesse da Fazenda Pública na preservação dos bens se justifica para a hipótese da declaração da vacância da herança jacente e destinarem-se os bens ao ente público. São interesses contraditórios, pois a confirmação do direito do herdeiro habilitado e interessado, inviabilizado estará o interesse da Fazenda Pública. Se um dos interessados adiantou pagamento de despesas e viu frustrada sua pretensão final, terá de habilitar o crédito antecipado no inventário para ter de volta o que despendeu.

3.3 Bens de valor afetivo e alienação condicionada

Os bens com valor de afeição, associados à memória da pessoa falecida, como retratos, objetos de uso pessoal, documentos históricos, anotações, livros e obras de arte, joias, só serão alienados depois de declarada a vacância da herança (art. 742, § 2.º). São bens sem valor definido pela avaliação econômica, mas carregados de sentimento e por isso sobrevalorizados pelo falecido e, presumivelmente, pelos seus eventuais sucessores.

Esses bens catalogados na arrecadação como *de valor de afeição* somente poderão ser vendidos após “decorrido um ano de sua primeira publicação, sem que haja herdeiro habilitado, ou penda habilitação, será a herança declarada vacante.” (CC/2002, art. 1.820) e “passado 1 (um) ano da primeira publicação do edital e não havendo herdeiro habilitado nem habilitação pendente, será a herança declarada vacante” (CPC/2015, art. 743, *caput*). Tal prazo se condiciona à aparição dos herdeiros, que podem preferir a preservação à alienação e à destinação a quem não tinha relações familiares com a pessoa extinta.

Passado o prazo, pode a Fazenda Pública requerer a alienação destes bens ou tomar a posse, cessando os deveres de conservação, zelo, administração que estavam ao encargo do curador. ⁹¹⁴

3.4 Intervenção da Advocacia Pública ou de outro habilitado

Deve intervir a Fazenda Pública, por seus representantes advogados ou procuradores públicos, toda vez que houver interesse do ente ou entes públicos. Outros interessados podem intervir, nos limites da controversão admitida nestes procedimentos, sem que se cogite de pleno contraditório (art. 9.º e 10) e sem a extensão que desnature o procedimento, justificando a conversão para um procedimento contencioso. A Fazenda Pública que aqui se trata, a partir do CC/2002, é do Distrito Federal ou Município e mesmo da União, se situado em Território Federal os bens da herança (art. 1.822).

Art. 743. Passado 1 (um) ano da primeira publicação do edital e não havendo herdeiro habilitado nem habilitação pendente, será a herança declarada vacante.

§ 1.º Pendendo habilitação, a vacância será declarada pela mesma sentença que a julgar improcedente, aguardando-se, no caso de serem diversas as habilitações, o julgamento da última.

§ 2.º Transitada em julgado a sentença que declarou a vacância, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os credores só poderão reclamar o seu direito por ação direta.

1. Inovações do CPC/2015

Não há alterações expressivas, salvo uma alteração verbal no § 1.º e a inclusão do companheiro como legitimado para a ação direta.

2. Aspectos materiais do transcurso do prazo

A regra do *caput* do art. 743 é material e permanece reiterada no Código Civil, tanto de 1916 como de 2002, e Código de Processo Civil, tanto de 1973 como de 2015. Não, portanto, pode pender dúvida sobre ela. O prazo decorrido destinava-se a permitir que se habilitasse algum herdeiro ou legatário, que não surgindo, permite a declaração da vacância.

Mantiveram-se integralmente as disposições, salvo uma alteração linguística sem conteúdo, e outra de caráter atualizador, estendendo ao companheiro o direito de suceder ao falecido, conforme norma própria já consagrada no Código Civil.

Passado um ano desde a publicação do edital sem habilitações, deve ser declarada a vacância da herança jacente.

3. Aspectos processuais e procedimentais

Como dito anteriormente, os prazos contam de forma diferenciada para os herdeiros, segundo o grau de parentesco. Os colaterais possuem até seis meses a partir da primeira publicação de editais para habilitarem-se, decaindo do direito se não se habilitarem neste prazo (art. 1.822, parágrafo único, do CC); os demais herdeiros possuem também seis meses a partir da primeira publicação para habilitarem-se (art. 741), podendo habilitar-se após este prazo e ainda vindicarem, sem decair do direito, (art. 1822, do CC, primeira parte). Após um ano da primeira publicação, “sem que haja herdeiro habilitado, ou penda habilitação, será a herança declarada vacante” (art. 1.820); após cinco anos da abertura da sucessão sem manifestação de interesse de herdeiros, passarão ao domínio definitivo do Município ou do Distrito Federal (art. 1822, do CC, segunda parte).

3.1 A sentença de declaração de vacância e suas eficácias e efeitos

Pontes de Miranda, a partir de sua clássica divisão das eficácias sentenciasais, afirmava que “a sentença que proclama a vacância é *sentença mandamental*, em ação não ainda executiva, com a particularidade de conter reserva de se apresentarem no prazo legal os sucessores do morto. A cognição é incompleta e mantém-se incompleta até cair, com a preclusão, a reserva.” É certo que contém eficácias declaratória e constitutiva, além das demais.⁹¹⁵

A sentença que declara a vacância, pela inexistência de herdeiros ou legatários ou por ausência de interesse completa a terceira fase do procedimento, antecedida pela arrecadação e pelo chamamento edital. A eficácia mandamental, diante da vacância, é a ordem de entregar à Fazenda Pública os bens que ficaram à espera de herdeiro que não se habilitou.

São efeitos da declaração de vacância: a) a cessação dos deveres de zelo pelo curador; b) a entrega dos bens ao Município ou Distrito Federal sob a forma de propriedade resolúvel; c) a assunção das responsabilidades por este ente federativo que passa a ter os mesmos deveres do curador.⁹¹⁶ Tais deveres persistem por todo o prazo restante, até que se completem os “cinco anos da abertura da sucessão sem manifestação de interesse de herdeiros”, quando então passarão ao domínio definitivo do Município ou do Distrito Federal (art. 1822, do CC, segunda parte).

Neste período também está impedido o ente público de alienar total o parcialmente, em razão do risco de resolução da propriedade;⁹¹⁷ assim como vedado está também o aproveitamento de modo diverso do que determina a lei local.

3.2 Processos incidentais de habilitação pendentes e suspensão da vacância

Alcides de Mendonça Lima resumia com clareza essa condição: “o simples fato de um dos interessados pretender provar sua qualidade de cônjuge, herdeiro ou testamentário (esse ao menos para fazer cumprir o testamento, ainda que não seja herdeiro nem mesmo pela verba) já influi na transformação da jacência em vacância. Em tal emergência, a declaração de vacância fica suspensa até o julgamento da habilitação em curso ou, se for o caso, de todas.”⁹¹⁸

No caso de haver habilitações protocoladas no juízo em que tramitam procedimento de arrecadação da herança jacente, sem que, após um ano da publicação do primeiro edital, tenha sido examinada em definitivo, deve a decisão examinar a procedência ou não desses pedidos de habilitação e somente declarar vacante se improcedentes tais pretensões. Se muitas as habilitações, tendo pendentes de julgamentos várias delas, ou são decididas em bloco e – do mesmo modo – somente se declarará vacante a herança se todas forem improcedentes. Bastará uma habilitação de herdeiro ou legatário ser procedente que não se declarará a vacância; sendo caso, nesta hipótese, de conversão da arrecadação em inventário.⁹¹⁹

A sentença tem dois caminhos: não declarar a vacância ou declarar a vacância; essa sentença, qualquer que seja, se sujeita aos mesmos riscos e meios de ser atacada (item 3.6). Se a sentença não declarar a vacância é porque herdeiros havia, foram habilitados e a herança arrecadada se encaminha ao inventário e partilha; se a sentença declarar a vacância, igualmente se sujeita a recursos e em ambas as hipóteses só transita em julgado após o exame desses recursos.

3.3 Trânsito em julgado da sentença de vacância

Suspenso o debate sobre a existência ou não de coisa julgada nos procedimentos de jurisdição voluntária, deve-se examinar a quem atinge a decisão de vacância. Após o decurso de prazo de um ano, desde a primeira publicação, é que se declara vacante a herança, “transitando em julgado” essa sentença

de declaração de vacância e caducando o direito à habilitação, só restará aos herdeiros retardatários a ação própria de petição de herança.⁹²⁰

A coisa julgada, neste caso, só pode atingir aqueles que participaram do procedimento, que integraram de um modo ou de outro o escasso contraditório, por exemplo, que tenha havido nos processos incidentes de habilitação; trata-se do estabelecimento dos limites subjetivos da coisa julgada (art. 506).

3.4 Ação direta e outras ações na pendência da jacência e vacância

Muitas são as hipóteses de proposição de ações na pendência do procedimento, como observado em itens antecedentes, mas aqui chamam a atenção especialmente a ação própria de petição de herança, ação de investigação de paternidade, ação de reconhecimento de união estável⁹²¹ e a ação de usucapião.

3.4.1 Ação direta ou ação própria dos sucessores

A legitimação para a ação é dos herdeiros e legatários, desde que não tenham sido atingidos pela decisão que declarou a vacância, rejeitando, por exemplo as habilitações. Aquele que já possui contra si uma decisão desfavorável não pode propor ação própria para o mesmo fim.

A ação direta ou ação própria compete a quem perdeu o prazo da habilitação,⁹²² ou seja, quem não teve seu pedido examinado e decidido.⁹²³ A ação de petição de herança demanda complexa instrução capaz de demonstrar a condição de herdeiro do proponente, sendo ré o ente da Fazenda Pública destinatário dos bens considerados vacantes. A competência, onde houver, é da Vara da Fazenda Pública da justiça comum dos Estados ou do Distrito Federal e, raramente, da Justiça Comum Federal, no caso de bens situados em território federal.

Há quem entenda que mesmo após os cinco anos da abertura da sucessão os herdeiros e credores poderão postular seus direitos, condicionados aos prazos prescricionais previstos na lei material (arts. 202 do CC).⁹²⁴

3.4.2 Ação de investigação de paternidade

A ação de investigação de paternidade,⁹²⁵ proposta antecedentemente ao procedimento de herança jacente ou durante a jacência e mesmo após a declaração da vacância e antes da constituição integral da propriedade resolúvel em nome da Fazenda pública pode gerar consequências variáveis. O investigador, por não ter a paternidade reconhecida não pode habilitar-se e impedir a vacância, nem propor a ação própria após esta declaração, ficando imobilizado até que se lhe declare que é filho e herdeiro.

Tal situação é diversa daquela do herdeiro ou legatário, que tendo ciência da jacência e da vacância não se manifesta ou expressamente renuncia. No caso do pretendente ao reconhecimento e possível herdeiro os prazos para a prescrição da ação de petição de herança não podem ser os mesmos, como já se entendeu em decisões do Superior Tribunal de Justiça; nesses casos conta-se do trânsito em julgado da investigação de investigação de paternidade.⁹²⁶

3.4.3 Ações de Usucapião

A aquisição por usucapião, que se constitui com a completude dos requisitos da espécie própria (extraordinária, ordinária ou especial) deverá ser declarada por sentença hábil ao registro, se imóvel. A posse para essa modalidade de aquisição originária da propriedade pode coincidir total ou parcialmente com o prazo de jacência e de vacância.⁹²⁷

Essa possibilidade é considerada de difícil configuração pela doutrina,⁹²⁸ embora seja farta a jurisprudência que a reconhece, admitindo a formação do direito à aquisição por usucapião antes ou na pendência da jacência e da vacância, total ou parcialmente,⁹²⁹ o que traz para os herdeiros, legatários ou para a Fazenda pública destinatária uma conflituosidade estranha aos procedimentos de jurisdição voluntária.

Não se exclui também a possibilidade de usucapião de herdeiro ou legatário que tenha posse exclusiva suficiente (e não posse somada e decorrente de sucessão do falecido) por prazo que o habilite a aquisição originária, especialmente as modalidades especiais, de bens móveis e imóveis, com prazos curtos e sem requisitos de justo título e boa-fé.

3.5 Sentença e recurso

O ato decisório final do procedimento é sentença de arrecadação e julgamento da vacância, sendo sentença com reserva.⁹³⁰ Tal sentença, qualquer que seja, se sujeita aos mesmos riscos e meios de ser atacada por apelação. Se a sentença não declarar a vacância ou se a sentença declarar a vacância igualmente se sujeita a recurso e em ambas as hipóteses só transita em julgado após o exame desses recursos.

E como sentença, se sujeita a recurso de apelação (art. 724), obedecendo aos requisitos *intrínsecos* : cabimento, legitimidade e interesse recursal e *extrínsecos* : tempestividade, regularidade formal e preparo.⁹³¹ São legitimados aqueles que se habilitaram à herança e todos os interessados ou cointeressados.

Seção VII

Dos bens dos ausentes

1. Inovações do CPC/2015 na Seção

Não há inovações no conteúdo do título, porquanto somente se reordene o que se denominava *Capítulo* , que a partir do CPC/2015 passa ser denominado de *Seção* .

2. Aspectos materiais da Seção dos Bens dos Ausentes

O ausente que tem bens e os bens dos ausentes merecem proteção, em atenção ao interesse imediato do próprio ausente, que pode retornar, e ao interesse mediato daqueles que sobre os bens tenham ou possam vir a ter direitos. Essas são as razões materiais principais para proteger os bens do ausente (item 2.2, abaixo). O Código Civil divide a ausência em três tópicos diferentes: curadoria dos bens do ausente, sucessão provisória e sucessão definitiva, nos quais estão descritas as formalidades protetivas dos bens e dos direitos.

3. Aspectos processuais e procedimentais gerais da Seção

Os aspectos processuais são variados e vão desde a identificação da legitimidade para propor a abertura do procedimento, competência especialmente de foro, designação de curador, arrecadação, editais e prazos, chamamento e fim da curadoria; abertura de sucessão provisória, legitimidade, decisão de abertura, citação de herdeiros, curador e interessados, caução e restituição dos bens; conversão em sucessão definitiva com declaração de morte presumida. Uma *tripla ordem de normas processuais* rege este procedimento, *as normas gerais* do CPC, notadamente do processo conhecimento; *as normas gerais das Disposições Gerais* da Seção I da Jurisdição Voluntária e *as normas próprias de cada procedimento especial* de jurisdição voluntária.

Art. 744 . Declarada a ausência nos casos previstos em lei, o juiz mandará arrecadar os bens do ausente e nomear-lhes-á curador na forma estabelecida na Seção VI, observando-se o disposto em lei.

1. Inovações do CPC/2015

Inova o CPC/2015 por desvincular a declaração de ausência do conceito de desaparecimento, precisamente por distinguirem-se a própria *ausência* em sentido material civil das *situações de ausência* processuais civis. Neste ponto as modificações foram adequadas, deixando as normas de direito material para o Código Civil, como já estavam desde 1916 e 2002, e mantendo no Código de Processo Civil o que de processual este deve conter.⁹³² Importam no procedimento judicial os atos de proteção dos bens como o exemplo da designação de curador, após a declaração de ausência, e não o detalhamento impróprio e repetitivo do direito material. Pontes de Miranda chegava a dizer que os dispositivos dos arts. 1.159 e 1.160 do CPC/1973 referiam-se de ordinário à ausência do domicílio da pessoa, como negativa de presença no lugar em que é domiciliada, mais a falta de notícias,⁹³³ mas não se confunde com a ausência comum ao processo judicial (art. 9.º, parágrafo único, CPC/1973) que justifica a representação por curador especial.

No CPC/2015 a referência ao *curador especial* do ausente vem posta na citação com hora certa (§ 4.º do art. 253), na citação edital (inc. IV do art. 257), nos procedimentos especiais, como comum a estes procedimentos (inc. I do art. 671); há também a referência ao *curador para o ato* nos protestos e os

processos testemunháveis formados a bordo (art. 769), representantes processuais que não se confundem com o *curador dos bens do ausente* (art. 744) ou com o *curador dos bens da herança jacente* (art. 741).

Este *curador dos bens do ausente* pode ser escolhido entre curadores judiciais ou pelo juiz entre pessoas capazes de preencher requisitos essenciais ao gestor, como a experiência, idoneidade e tino para a atividade de administração patrimonial ou sobre profissionais com habilitação profissional correspondente, que pode ser um administrador, contador, advogado, engenheiro, gestor mobiliário etc. Suas funções são extraprocessuais e processuais, nos mesmos moldes do curador de bens do ausente que zela pelo acervo de bens do ausente (art. 741). Seus deveres são quase iguais àqueles da herança jacente, justificando a repetição dos tópicos correspondentes.

2. Aspectos materiais da ausência

É uma soma de fatores fático-materiais que permitem o pedido e a declaração de ausência e estão associados ao abandono dos bens. Não basta a *situação de ausência*, às vezes identificada no processo jurisdicional, mas a ausência identificada como não presença, que se acrescenta à falta de notícias e à inexistência de representante ou procurador, mandatário, com poderes administrativos sobre os bens do não presente (art. 22 do CC). Igualmente se pode declarar a ausência do não presente que, não obstante tenha deixado o mandatário, não tem deste a atenção aos deveres de preservação e guarda dos bens, “porque não queira, não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes” (art. 23 do CC). A ausência que justifica é a não presença associada à falta de notícias e não apenas a não presença.⁹³⁴

2.1 Desaparecimento e local da ausência

Distinguem-se o ausente civil do ausente processual civil. A *ausência civil* enseja a declaração da ausência, designação de curador, arrecadação de bens e permite a abertura da sucessão provisória (art. 26 do CC), após um ano da arrecadação ou após três anos se deixará representante ou curador; e abertura da sucessão definitiva (art. 37 do CC), após dez anos do trânsito em julgado da sentença que declare aberta a sucessão provisória. A *ausência processual civil*, se assim se pode chamar, independe da ‘declaração de ausência’, caracterizando-se por não se encontrar o interessado processual em seu domicílio, e enseja de modo geral a nomeação de curador especial para o processo em curso (art. 671) ou quando se deseja especificamente citar o ausente, enseja a comunicação de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente (art. 242, § 1.º, do CPC).

A partir de agora se centra no art. 22 e no art. 70 do CC/2002 a definição de ausência, pois “desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência, e nomear-lhe-á curador.” Divergia a doutrina sobre o conceito de ausência, a partir do exame do local de onde ela se efetivaria: se do domicílio (art. 70 do CC/2002),⁹³⁵ da residência ou do local onde possuía seus bens.⁹³⁶ Pontes de Miranda, ao lado de Lopes da Costa e de Carvalho Santos, sugeria que se considerasse “ausência” o afastamento do lugar onde possui bens aquele que se afasta, por entender que a curatela do ausente (dos bens) é *cura rei* e não *cura personae*,⁹³⁷ tanto o é que o art. 1.767 do CC/2002, ao elencar o rol de pessoas sujeitas à curatela, não incluiu o ausente em qualquer de seus cinco incisos.⁹³⁸ Porém, na medida em que se admite a possibilidade de retorno do ausente, mais consentâneo é o entendimento de que a proteção tem caráter duplo, defendendo tanto os bens, como a pessoa (ausente), posição adotada por outros comentadores do CPC/1973.⁹³⁹ As duas questões estão coligadas: a) a ausência é a não presença no domicílio, local em que residia o ausente com ânimo definitivo e não apenas no local em que possui bens, associada à falta de notícias e b) o aspecto de a curatela objetivar a proteção de bens e do próprio ausente, que pode retornar, e de seus interesses.

Não basta, portanto, a ausência do local de residência, mesmo porque algumas pessoas residem em mais de um local e qualquer um deles pode ser considerado domicílio (art. 71 CC/2002). Mesmo o domicílio profissional necessita de exame cuidadoso, pois a pessoa pode ter uma pluralidade de domicílios por conta das atividades profissionais e de seu exercício (art. 72, parágrafo único, CC/2002), o que pode induzir uma aparente ausência. Nestes casos, a demonstração da ausência se deve estender a todos esses locais, ou seja, a não presença e a falta de notícias devem ser também múltiplas e correspondentes.

2.1.1 Morte presumida e impossibilidade de exercício de poderes

A morte presumida é um *mais* em relação à ausência. Estabelece o art. 7.º que “pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência” quando “for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida” e “se alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos após o término da guerra” Porém “a declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento” acrescenta o parágrafo único.

A ausência pela impossibilidade de exercício de poderes pelo mandatário é outra hipótese prevista no Código Civil (art. 23), que prevê a declaração da ausência quando o mandatário nomeado “não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato [art. 682 do CC/2002], ou se os seus poderes forem insuficientes”. Neste caso a ausência já havia, falhando ou carecendo de poderes o mandatário.

2.1.2 O registro declaração da ausência

Para que a ausência tenha conhecimento ou publicidade, deve-se levá-la a registro, conforme disposto no Código Civil no qual se determina que serão registrados em registro público a sentença declaratória de ausência e de morte presumida, assim como determinado na Lei dos Registros Públicos (art. 94). ⁹⁴⁰

2.2 Cuidados materiais que demandam os bens de ausente

Os cuidados que demandam os bens de ausentes são os mesmos cuidados essenciais da herança jacente, sem esquecer outros que decorrem da própria coisa que componha esse acervo. São basicamente a arrecadação, a guarda, a conservação e a administração ou gestão da massa patrimonial.

A arrecadação tem por objeto os bens do ausente com fito de preservação desses bens e direitos de eventuais sucessores ou do próprio ausente, se cessar a ausência. A arrecadação é a tomada de posse de bens do ausente e pode ocorrer antes, simultaneamente ou após o arrolamento, estando a ele coligado e um completando o outro, como na jacência da herança (art. 738). Pode ser voluntária, pela entrega dos bens, por atos extrajudiciais ou se pode dar também por medidas judiciais de conservação, sejam provimentos provisórios de urgência, antecipada ou cautelar, ou provimentos finais sentenciais. O arrolamento também se aplica aos bens dos ausentes, como listagem dos bens e descrição pormenorizada de cada um, com características e indicadores essenciais próprios, sejam bens imóveis, móveis ou semoventes, feita sob a forma de auto de arrolamento e arrecadação, a depender do local da diligência: se realiza nos locais externos ao fórum, tais como a residência do autor da herança ou sob a forma de termo de arrolamento e arrecadação, quando realizada nas dependências do órgão jurisdicional. Tais registros devem ser assinados pelo juiz, pelo curador e pelos representantes institucionais da Fazenda Pública e Ministério Público, se acompanharam os atos.

A guarda é o conjunto de atos, como preservar, proteger, evitar dispersão e perdas e conforme a natureza do bem requer iniciativas distintas e específicas, para que se considerem bem guardados os bens do ausente. Se bens corpóreos móveis e imóveis, a boa guarda se caracteriza pela preservação da posse (poder sobre a coisa) direta ou indireta e a incolumidade do direito real ou da propriedade, plena ou limitada. A proteção da posse é corrente em muitos casos porquanto os bens da herança podem se encontrar em poder de terceiros ou serem apropriados após a morte do autor da herança, ensejando a proposição dos interditos possessórios (reintegração e manutenção de posse ou interdito proibitório), conforme o nível de agressão à posse e a justiça ou injustiça dessa apropriação. A proteção da propriedade por meios das ações petitórias próprias, reivindicatória e de imissão de posse, conforme tivesse ou não a posse o autor da herança ao tempo da abertura da sucessão, é possível de ser exercida. Outras demandas, tais como embargos de terceiro, ação de dano infecto, ação de oposição, ação ou exceção de usucapião, ação de divisão ou de demarcação, declaratórias e anulatórias de marcas também se encontram no largo espectro de demandas e defesas que integram o âmbito reipersecutório dos bens do ausente.

A conservação vai além da manutenção da integridade; é dar à coisa ou ao direito o adequado destino. Num primeiro momento é manter produtivo, sem decrescer, mas é, também, fazer produzir mais frutos, render, crescer.

A Administração compreende a gestão dos frutos e rendimentos produzidos pelo bem, o custeio adequado das despesas, de modo a fazer render, atos todos demonstráveis pelas apresentações contábeis exigidas pela lei, ou seja, pelos balancetes mensais e prestação final de contas. Esses relatos comuns à

atividade mercantil expressam a natureza.

3. Aspectos processuais e procedimentais

Muitos são os aspectos contidos no procedimento, tais como legitimação, competência, procedimento, sentença e seus efeitos, além de todos os aspectos relacionados ao curador, nomeação, encargos e outros, conforme se verá.

3.1 Legitimação para o pedido de declaração de ausência

Não era clara a redação anterior⁹⁴¹ com um sujeito oculto na partícula apassivadora (declarar- se -á) que não deixava ver quem eram os legitimados a abrir o procedimento. A redação do artigo equivalente usa o verbo declarar no tempo passado: “*declarada* a ausência”, para manter o mesmo mistério. Contudo sabe-se que qualquer interessado⁹⁴² pode pedir a abertura do procedimento para: *a) a arrecadação dos bens, a designação do curador e a declaração da ausência*; e, conseqüentemente, se não retornar o ausente: *b) a abertura da sucessão provisória e; c) a conversão da sucessão provisória em definitiva*.

São interessados, por exemplo, todos aqueles descritos no art. 27 do CC/2002, o cônjuge não separado judicialmente; os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários; os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte; os sócios; os condôminos; os proprietários de bens sobre os quais o ausente é titular de direitos reais (usufruto, uso, habitação); os proprietários de bens cedidos por direito pessoal (locação, comodato, cessão de posse, empréstimo) ao ausente; os credores de obrigações vencidas e não pagas; o Ministério Público.⁹⁴³

3.2 Competência

A competência de jurisdição para ações em favor do ausente e dos seus bens é em geral da Justiça Comum dos Estados e do Distrito Federal, salva a rara exceção de identificarem-se direitos ou interesses de entes públicos federais, como já se identificou pela presença da autarquia previdenciária da União (INSS), que pode deslocar a ação para a Justiça Comum Federal.⁹⁴⁴ Se só se pretende arrecadar bens, será incontestavelmente Comum Estadual a competência de jurisdição. Nos casos de pensão por morte contra o INSS, a partir da declaração de ausência do segurado, dispensaram-se formalidades do art. 1.159 do CPC/1973, por considerar que tais exigências se referem a bens.⁹⁴⁵ Considerou-se também inexistir o conflito de competência entre justiça comum estadual e comum federal quando a finalidade da declaração é exclusivamente para fins previdenciários, sem bens a arrecadar.⁹⁴⁶ Assim, havendo bens a arrecadar, permanece ou desloca-se a competência para a justiça comum estadual, servindo a declaração como decisão prejudicial desta justiça e fundamento à busca do benefício previdenciário na justiça federal, se auferido pelo INSS.

Não havendo bens a arrecadar e restringindo-se o interesse pela declaração de ausência apenas para fins previdenciários e sucessão na pensão por morte, a competência será definida pela presença ou não de ente federal, que atrai a competência para a Justiça Federal ou se o ente pagador for Instituto Estadual de previdência, mais uma vez será competente a da Justiça Comum dos Estados ou Distrito Federal.

A competência de foro será determinada pela regra de que a “ação em que o ausente for réu será proposta no foro de seu último domicílio, também competente para a arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias” (art. 49 do CPC). Quanto às pessoas residirem em mais de um local, qualquer desses locais será considerado foro para a ação (art. 71 CC/2002), assim como as pessoas com domicílio profissional ou pluralidade de domicílios (art. 72, parágrafo único, CC/2002) que amplia a quaisquer dos juízes desses locais, a competência de foro.

3.3 O curador, sua nomeação, duração da função e habilidades

Como nos demais casos da curatela (ver comentário equivalente na herança jacente), o curador dos bens dos ausentes será escolhido dentre os curadores judiciais nos Estados; nos demais casos incumbe ao juiz a escolha, podendo recair sobre pessoas capazes de preencher requisitos essenciais ao gestor, como a experiência, idoneidade e tino para a atividade de administração patrimonial ou sobre profissionais com habilitação profissional correspondente, que pode ser um administrador, contador, advogado, engenheiro, gestor mobiliário etc.⁹⁴⁷ Como no caso do inventariante, o curador pode ser escolhido entre os interessados na herança, podendo ser o cônjuge do ausente, desde que não esteja separado judicialmente, ou de fato por mais de dois anos antes da declaração da ausência (art. 25 do CC); à falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente cabe aos pais ou aos descendentes, nesta ordem, observado que

os descendentes mais próximos precedem os mais remotos (art. 25, § 1.º, do CC). Não é, portanto, em princípio, um estranho. Somente à falta das pessoas indicadas, abre-se ao juiz a escolha do curador livremente, regra que vale para a acervo de bens do ausente desde o princípio.

O art. 744 prevê que, “declarada a ausência (...) o juiz mandará arrecadar os bens do ausente e nomear-lhes-á curador na forma estabelecida na Seção VI,” embora a referida seção não diga claramente como deve ser esta nomeação. As referências ao curador são de outra natureza (art. 739, § 1.º e §2.º; art. 740, caput, § 2.º e § 6.º). Essa remissão vaga pode ser contornada por ter o CPC, em outros pontos, definido que os curadores, assim como outros auxiliares dependem deste ato de compromisso, feito por termo nos autos, para o exercício regular de seus misteres. E as “Disposições Comuns à Tutela e à Curatela”, art. 759 e inc. I vem definido que “(...) o curador será intimado a prestar compromisso no prazo de 5 (cinco) dias contado da (...) nomeação feita em conformidade com a lei.” Tal compromisso se refere não só aos curadores que protegem pessoas, mas também os curadores de bens e interesses como a herança jacente. Vale destacar que, conforme aduz o art. 24 do CC/2002,⁹⁴⁸ em sua parte final, aplicam-se, também, os arts. 1.728 a 1.783, do CC/2002, principalmente os arts. 1.741, 1.743, 1.744, 1.745, 1.747, 1.748, 1.749, 1.750, 1.752, *caput*, 1.753, 1.755 e ss. c/c 1.774 e ss., todos do CC/2002.⁹⁴⁹

A duração da curatela está coligada aos fins de sua existência e subsistirá enquanto exigirem proteção aos bens do ausente, sendo temporária e indeterminada,⁹⁵⁰ tendo a plena gestão durante a sua nomeação, podendo ser antecedido por depositário antes da sua nomeação (art. 740, § 2.º), substituído no exercício por interino no caso de extrema gravidade (art. 762) ou substituído por outro curador em caso de remoção (art. 761). As qualidades exigíveis do curador, como em geral dos administradores, estão associadas aos seus deveres, tal como a reconhecida idoneidade (art. 1.745, parágrafo único, do CC/2002), a honestidade, a experiência, a disposição e o tirocínio.

3.4 Incumbências iniciais do curador

Pode-se aqui repetir parcialmente o que foi dito sobre o curador da herança jacente, pois são muito semelhantes e diversificadas as incumbências do curador dos bens do ausente quando se relaciona com essa massa patrimonial deixada. Vai desde a representação extrajudicial e judicial, arrolamento, arrecadação, guarda, conservação de bens e direitos, promoção de medidas conservativas, apresentação de balancetes e contas finais. Cumpre ainda destacar que, nos termos do art. 24 do CC/2002, o juiz poderá atribuir poderes e obrigações, contidos nas normas do Código sobre a tutela e a curatela, desde que se observe a necessidade de cada caso concreto, bem como a compatibilidade entre elas e o caso, a fim de se otimizar a proteção imediata aos interesses do ausente, dos seus herdeiros ou credores e, mediata, do interesse público.⁹⁵¹

3.4.1 Representar o acervo de bens judicial e extrajudicialmente

Representar civilmente, segundo o Código Civil, arts. 115 a 120, se caracteriza pela manifestação de vontade pelo representante (curador) em nome do representado (ausente), manifestando vontade nos negócios extrajudiciais. A base para o exercício do poder de representação extrajudicial do curador do ausente é conferido pela lei processual (art. 744 c/c o art. 739, § 1.º, inc. I). Representar judicialmente, a seu turno, é ir a juízo em nome de outrem, manifestando vontade nos atos e negócios processuais que exijam a presença e manifestação da parte ou mesmo como terceiro (art. 75, inc. VI).

3.4.2 Guardar e conservar os bens arrecadados

Guardar, considerando-se o que já foi dito, é velar, preservar, proteger, evitar dispersão e perdas, conforme seja o bem móvel ou imóvel, corpóreo ou incorpóreo, fungíveis ou infungíveis, divisíveis ou indivisíveis, singulares ou coletivos (art. 744 c/c o art. 739). Boa guarda é atenção voltada à preservação, ao atendimento dos fins sociais e individuais do bem.

Conservar, por outro lado, traduz a noção de tempo e de seu transcurso, fazendo com que os bens e direitos existentes desde a assunção no encargo de curador subsistam somados ao que se produzirem como frutos e rendimentos; não definham, não se reduzam, não se percam (art. 744 c/c o art. 739). Conservar é manter; manter com vigor, com higidez, com valor econômico, especialmente.

3.4.3 Promover a arrecadação de outros bens porventura existentes

Promover a arrecadação é ir em busca de outros bens. Requer-se diligência do curador para que amplie a apuração e persecução a outros bens que possam se encontrar em poder de terceiros, perdidos

ou mesmo ocultos (art. 744 c/c o art. 739, § 1.º, inc. II). O esforço na busca dos bens do ausente não se esgota com os atos iniciais de arrolamento e arrecadação, que podem não ter reunido todo o acervo graças à iniciativa judicial, da Fazenda Pública ou do Ministério Público. É dever do curador, tendo notícias, indícios ou elementos indicadores da existência de bens que não estão arrecadados, ir ao encaço desses bens.

Deve-se lembrar também as vedações relativas ao curador, como a que impede que adquira, ainda que em hasta pública, os bens confiados à sua guarda ou administração (art. 497, inc. do CC).

3.4.4 Executar as medidas conservatórias dos direitos do acervo de bens

Executar medidas conservatórias compreende “providências e diligências relativas a direitos no interesse” do acervo (art. 744 c/c o art. 739, § 1.º, inc. III). Exemplos de iniciativas conservatórias são as medidas interruptivas da prescrição da pretensão ou da decadência, contratação e renovação de contratos etc.

3.4.5 Prestar contas mensalmente por balancete

É dever do curador dos bens do ausente apresentar contas ao juiz mediante a apresentação de balancete mensal (art. 744 c/c o art. 739, § 1.º, inc. IV, do CPC/2015 e arts. 1.755 e ss. c/c arts. 1.774 e 1.781, todos do CC/2002), discriminando a receita obtida com a administração dos bens e a despesa com a guarda, conservação etc.⁹⁵² O balancete de verificação, segundo a NBC T 2.7 que ainda se encontra em vigor, é a relação de contas, com seus respectivos saldos, extraída dos registros contábeis em determinada data. Seu grau será consentâneo com sua finalidade e deve conter no mínimo os seguintes elementos a) identificação da Entidade; b) data a que se refere; c) abrangência; d) identificação das contas e respectivos grupos; e) saldos das contas, indicando se devedores ou credores; f) soma dos saldos devedores e credores; nome e assinatura do contabilista responsável.

3.4.6 Prestar contas ao final de sua gestão

É dever de todo administrador de bens ou valores alheios prestar contas de sua administração. No caso dos bens do ausente esse dever decorre também da aplicação dos dispositivos combinados (art. 744 c/c o art. 739, § 1.º, inc. V). A ação própria para esse fim, a partir do CPC/2015 é uma só e não são duas, como no CPC anterior; trata-se da *ação de exigir contas*, arts. 550 a 553 do CPC, procedimento único, mas dúplice, adequado aos ditos que envolvem essas relações de administração, capaz de permitir que as contas sejam “apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver”. E por ser dúplice, a ação de exigir contas, possibilita que a sentença contenha saldo que pode favorecer autor ou réu e a sua consequente execução como título (art. 552).

3.5 Outros direitos, deveres e obrigações aplicáveis ao curador

Perdeu-se a oportunidade de corrigir a omissão do CPC anterior e fazer incluir o curador dos bens do ausente ao lado do depositário e do administrador, dispensando a remissão do parágrafo único do art. 739. Ao tratar “do Depositário e do Administrador” a Seção III, Capítulo III, Livro III, Parte Geral do novo CPC (arts. 159, 160 e parágrafo único, e 161 e parágrafo único) restringe-se a estes dois auxiliares da justiça e de seus direitos e deveres, principalmente. O Código Civil, ao tratar da *Da Curadoria dos Bens do Ausente* no art. estabelece que “o juiz, que nomear o curador, fixar-lhe-á os poderes e obrigações, conforme as circunstâncias, observando, no que for aplicável, o disposto a respeito dos tutores e curadores.”

A redação do art. 159, que trata da guarda e da conservação de bens, omite os bens do ausente, deixando claro que a remissão poderia se restringir aos arts. 160 e 161 e seus parágrafos únicos, efetivamente àqueles que descrevem direitos e deveres.

Por seu trabalho, o curador poderá perceber “remuneração que o juiz fixará, levando em conta a situação dos bens, ao tempo do serviço e às dificuldades de sua execução” (art. 160), desde que não seja dativo, o que é possível. Tal remuneração, quando houver, terá de ser como em outros casos de administradores judiciais: proporcional e ajustada à capacidade de pagamento do próprio monte de bens, ao dispêndio de trabalho e à sua complexidade. Considerado o volume de trabalho, poderá o juiz autorizar, a pedido do curador, “um ou mais prepostos” para auxiliá-lo nas funções que ultrapassem a sua capacidade de guarda, conservação e administração (art. 160, parágrafo único); considere-se também que são do curador a representação judicial e extrajudicial, a arrecadação de bens ainda não trazidos ao

processo e as medidas judiciais protetivas desses bens. Nesses casos, mantém-se o curador como responsável pela apresentação de balancete, prestação de contas finais e outros deveres, mesmo quando a atividade seja feita por seus prepostos.

Dentre os direitos do curador está, além de sua remuneração, o de ser ressarcido de despesas que tenha feito em favor do acervo, ainda quando perca sua remuneração, pois se gastou, não pode o acervo de bens enriquecer sem lhe repor despesas que não tinha dever de custear.

O curador dos bens de ausentes, igualmente ao depositário e ao administrador, “responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo” (art. 161 do CPC). A regra do parágrafo único do art. 161, quanto à responsabilidade civil por prejuízos causados, responsabilidade penal e sanção por ato atentatório à dignidade da justiça destina-se especificamente ao depositário infiel. Qualquer responsabilidade terá de ser apurada em ação própria e não no âmbito do procedimento de arrecadação dos bens do ausente, com iniciativa de legitimados lesados contra o curador que supostamente os lesionou.

Como dito acima, créditos e débitos decorrentes da atividade de administração e de guarda podem, entretanto, ser discutidos na *ação de exigir contas*, arts. 550 a 553 do CPC, procedimento afeito ao direito debatido, permitindo que as contas sejam “apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver”. A natureza dúplice da ação de exigir contas possibilita que a sentença contenha saldo que pode favorecer a qualquer das partes envolvidas na administração (art. 552).

3.6 A instrução ou prova em cada uma das etapas

A cada etapa procedimental corresponderá a prova própria e hábil a demonstrar os fatos: a) na declaração da ausência, na inexistência ou inexistência de mandatário, representante ou procurador, e, conseqüentemente, b) na persistência da ausência e possibilidade de abertura da sucessão provisória e; c) no decurso do prazo dos dez anos, sem retorno do ausente e, então, a possível conversão da sucessão provisória em definitiva.

3.7 Arrecadação de bens do ausente

Conforme comentado anteriormente (v. item 2.2), é a primeira e obrigatória medida a ser tomada quando verificada a ausência. Tem como objetivo preservar o patrimônio do ausente, portanto, necessária a arrecadação destes bens e a instituição de curador especial (arts. 738 a 743, do CPC/2015) para os administrar, caso já não haja. A arrecadação neste procedimento, tem a mesma finalidade que a arrecadação na herança jacente, devendo-se observar, inclusive, as mesmas disposições para a sua efetivação (art. 740).

Os pressupostos para a arrecadação são: a) a existência de bens na jurisdição do juiz; b) não se ter notícia do proprietário ou possuidor; c) não ter deixado procurador, ou não o ter constituído, estando ausente, para administrar seus bens, ou, caso tenha deixado, este (procurador) não mais quer ou não pode mais administrá-los. ⁹⁵³

Os bens a que se refere o artigo são os existentes no domínio e posse do desaparecido antes e, ainda, os que lhe couberem por direito depois do seu afastamento, abrangendo a herança vacante de que seja herdeiro único o ausente e quinhão hereditário atribuído a este, conforme as regras dos arts. 1.819 a 1.823, ambos do CC/2002. Cabe, portanto, ao curador do ausente habilitar na sucessão do *de cujus* os direitos que possa ter à herança, a quinhão hereditário ou a legado. ⁹⁵⁴

3.8 Eximção, suspensão e remoção do curador dos bens do ausente

As “Disposições Comuns à Tutela e à Curatela” (arts. 759-763) tratam da nomeação, compromisso e exercício das funções, mas também das possibilidades de eximção mediante escusa, suspensão por atos graves, remoção e a conseqüente dispensa dos deveres e encargos do curador, aplicáveis aos bens dos ausentes.

A duração da curatela está ligada aos fins de proteção dos bens do ausente, sendo temporária e indeterminada, tendo a plena gestão durante a sua nomeação, podendo ser substituído no exercício por interino no caso de extrema gravidade (art. 762) ou substituído definitivamente por outro curador em

caso de remoção (art. 761). Cessando a ausência ou abrindo-se a sucessão, cessam as suas funções, como curador, encarregando-se do zelo dos bens o titular ou seus sucessores, respectivamente.

A *Eximiação do exercício* é ato próprio de quem não deseja a função e apresenta escusa fundamentada ao juízo, antes ou até cinco dias depois de entrar em exercício (art. 760); a *suspensão do exercício* é ato do juízo em casos de extrema gravidade (art. 762) e a *remoção do exercício* se dá a pedido do próprio curador pelo esgotamento das funções ou do Ministério Público, motivada por desatendimento de seus deveres.

Art. 745 . Feita a arrecadação, o juiz mandará publicar editais na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 1 (um) ano, ou, não havendo sítio, no órgão oficial e na imprensa da comarca, durante 1 (um) ano, reproduzida de 2 (dois) em 2 (dois) meses, anunciando a arrecadação e chamando o ausente a entrar na posse de seus bens.

§ 1.º Findo o prazo previsto no edital, poderão os interessados requerer a abertura da sucessão provisória, observando-se o disposto em lei.

§ 2.º O interessado, ao requerer a abertura da sucessão provisória, pedirá a citação pessoal dos herdeiros presentes e do curador e, por editais, a dos ausentes para requererem habilitação, na forma dos arts. 689 a 692.

§ 3.º Presentes os requisitos legais, poderá ser requerida a conversão da sucessão provisória em definitiva.

§ 4.º Regressando o ausente ou algum de seus descendentes ou ascendentes para requerer ao juiz a entrega de bens, serão citados para contestar o pedido os sucessores provisórios ou definitivos, o Ministério Público e o representante da Fazenda Pública, seguindo-se o procedimento comum.

1. Inovações do CPC/2015

Inova o CPC/2015 ao incorporar as vantagens de comunicação trazidas pela rede mundial de computadores e os sítios dos órgãos jurisdicionais criados nesta rede que são desde alguns anos largamente utilizados para fins processuais diversos. Essa incorporação que se iniciara claramente com a Lei 11.419/2006, Lei do Processo Eletrônico, e em mudanças pontuais do CPC/1973, tem no CPC/2015 sua ampliação com a permissão à produção, armazenamento, validação e comunicação de atos processuais por meio eletrônico (art. 193); especialmente no plano da comunicação, permite-se a citação edital (art. 257, inc. II), o edital de leilões judiciais (art. 886, inc. IV), a arrecadação de bens de ausentes (art. 745), o edital de depósito de coisas vagas (art. 746, § 2.º), a publicação de sentença de interdição (art. 755, § 3.º), além de outros não descritos. Sabe-se já das vantagens comunicacionais e da redução de custos, não havendo mais razão para resistir a este progresso, observados os princípios ou requisitos da autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação, confidencialidade limitada (art. 195).

Além desse ponto, dois outros chamam a atenção, um menor, com alteração apenas da expressão finado por falecido, sem importância maior e outra com a inclusão no § 3.º do art. 741 do companheiro, equiparado ao cônjuge, como sujeito que ao surgir e manifestar interesse, considera-se suficiente para impedir a abertura ou interromper o procedimento de arrecadação do acervo de bens do ausente. Quanto ao mais, não há alterações comparando-se o artigo do CPC antecedente.

2. Aspectos materiais da conclusão da arrecadação e identificação de interessados

A arrecadação, como tomada direta da posse de bens do ausente visa a reunião de todos os bens deixados, imóveis e móveis, corpóreos e incorpóreos, direitos industriais, marcas registradas, patentes etc.

3. Aspectos processuais e procedimentais

Neste item serão abordados a comunicação e publicidade, conhecimento sobre os herdeiros, citação, habilitação e conversão da arrecadação de bens do ausente em sucessão provisória.

3.1 Procedimentos de comunicação dupla e publicidade edital, ciência aos herdeiros e prazos para habilitação ou para atos processuais

A inovação do edital está em não mais ‘estampar’ somente jornais impressos, mas “será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 3 (três) meses, ou, não havendo sítio, no órgão oficial e na imprensa da comarca, por 3 (três) vezes com intervalos de 1 (um) mês, para que os sucessores do falecido venham a habilitar-se no prazo de 6 (seis) meses contado da primeira publicação.”

Não se alteram os prazos do CPC/1973 para este CPC/2015, exceto na indicação do que antes era de trinta dias que passa a ser de um mês, sem obedecer a forma de contagem em dias úteis. Com a publicação na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça superam-se parcialmente algumas discussões sobre o alcance que possuíam publicações locais, da comarca, imaginando-se que melhor alcance terá agora, com a espantosa propagação que os meios eletrônicos e digitais proporcionam.

A *rede mundial de computadores* é o local no qual estão disponíveis o *sítio do tribunal* a que está vinculado o juízo e também a *plataforma de editais* do Conselho Nacional de Justiça; todos os tribunais dos estados federativos e do Distrito Federal possuem sítios na *rede*, o que faz presumir desnecessária a publicação “no órgão oficial e na imprensa da comarca, por 3 (três) vezes com intervalos de 1 (um) mês”. O tempo de permanência *sítio do tribunal* e na *plataforma de editais* do Conselho Nacional de Justiça deve ser de três meses. Como dito, superam-se parcialmente as discussões sobre os conceitos de *imprensa da comarca* e *imprensa de circulação local* ⁹⁵⁵ se grande parte dos editais tiver circulação com êxito na finalidade pelos meios eletrônicos e não apenas na sede do juízo (art. 232, inc. II, do CPC/1973). Mas a publicação dupla na *rede* poderá gerar controvérsia sobre a contagem de prazos, se não for simultânea, vez que o início da publicação abre a contagem de dois prazos (art. 1.820 do CC/2002 e art. 741 do CPC). A solução pode ser a adoção, por analogia, da regra do art. 257, inc. III, do CPC.

Não havendo sítio do órgão judicial, a publicação terá de ser feita em dois veículos: a) na *imprensa da comarca* ou *imprensa de circulação local* e; b) em órgão oficial, em geral Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da Justiça dos Estados ou DF, Diário Oficial Eletrônico ou outro o veículo oficial impresso ou eletrônico para a publicação da comunicação estatal. Essas publicações deverão se repetir por três vezes, com intervalos de um mês entre uma aparição e outra. Não se fazendo do modo descrito, a comunicação dupla não atende à exigência na contagem dos prazos; assim, terão de ser publicados: a1) no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e; a2) na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça ou; b1) no órgão oficial; b2) e na imprensa da comarca. O início da contagem, contudo, dependerá da forma adotada: se seguir a forma a1 + a2, o prazo se inicia a partir do primeiro dia em que seja publicado num dos locais sucessivos (no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e; na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça), se seguir a forma b1 + b2 (no órgão oficial; e na imprensa da comarca), se inicia com a primeira publicação em qualquer dos veículos, obedecendo ao disposto no inc. III do art. 257, CPC/2015 e art. 741. Ainda poderá o juiz “determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias” (art. 257, parágrafo único).

A ciência aos ‘herdeiros’ é o fim principal, senão único dos editais, com a jacência da herança e o chamamento para que manifestem ou não interesse pelos bens deixados.

Os prazos são diferentes para duas categorias de sucessores e para a realização de atos de habilitação. Os colaterais possuem até seis meses a partir da primeira publicação para habilitarem-se, decaindo do direito se não se habilitarem neste prazo (art. 1.822, parágrafo único, do CC); os demais herdeiros possuem também seis meses a partir da primeira publicação para habilitarem-se (art. 741), podendo após este prazo, sem decair do direito, ainda vindicarem (art. 1.822, do CC, primeira parte). Após um ano da primeira publicação, “sem que haja herdeiro habilitado, ou penda habilitação, será a herança declarada vacante” (art. 1.820); após cinco anos da abertura da sucessão sem manifestação de interesse de herdeiros, passarão ao domínio definitivo do Município ou do Distrito Federal (art. 1.822, do CC, segunda parte).

3.2 A abertura da sucessão provisória

A sucessão provisória se destina a tirar dos cuidados do curador os bens arrecadados e dar a eles um destino que se aproxime de seu destino final. São três as etapas demarcadas na proteção dos bens dos ausentes: a) a arrecadação dos bens, a designação do curador e a declaração da ausência; b) a abertura da sucessão provisória e; c) a conversão da sucessão provisória em definitiva.

Como dito, o “desaparecendo uma pessoa de seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver

deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens”, num primeiro passo, deve “o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público”, declarar a ausência desta pessoa e nomear um curador para a conservação de seus bens (art. 22 do CC/2002). Essa atividade do curador não pode durar por tempo indeterminado.

Após isso, se decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, ou, se ele deixar representante ou procurador, em se passando três anos, sem que sobre esses bens se manifeste interesse o ausente ou seu representante, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão.

Conforme o § 1.º do art. 745, “findo o prazo previsto no edital, poderão os interessados requerer a abertura da sucessão provisória” induzindo-se a pensar que logo após o transcurso do prazo do edital e do prazo para intervir se poderia abrir a sucessão provisória. A parte final do dispositivo, contudo, remete à observância do que “disposto em lei”; que, se supõe, tratar da lei civil (CC/2002, art. 26). Dessa forma, só será possível o pedido de abertura da sucessão provisória, ainda que publicados os editais, nos termos do art. 745 do CPC/2015, caso tenham transcorrido, concomitantemente, os prazos previstos no art. 26 do CC/2002. O artigo (art. 26) prevê dois prazos distintos: a) um ano da arrecadação, se o ausente não houver deixado representante ou procurador, e b) três anos, se houver deixado qualquer um destes.⁹⁵⁶ Porém, parte da doutrina entende que o novo CPC, por ser lei posterior, ao determinar prazo diverso do Código Civil, teria revogado as disposições do arts. 26 e 28, CC/2002, nos termos do § 1.º do art. 2.º da LINDB, o que não parece ser razoável, conforme sustentação supra.

3.2.1 Legitimados ativos

O art. 745, § 1.º, não prevê quais seriam os “interessados”, remetendo, portanto, ao conteúdo do art. 27 do CC/2002. O artigo (art. 27) apresenta um rol taxativo de pessoas legitimadas para requerer a abertura, quais sejam: a) o cônjuge não separado judicialmente ou companheiro, desde que não extinta a união ou suspensão por medida judicial; b) os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários; c) os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte, como, por exemplo, o fideicomisso; c) os credores de obrigações vencidas e não pagas. Cumpre destacar que, embora o rol seja taxativo, não há qualquer benefício de ordem entre os legitimados, cabendo a qualquer um deles a iniciativa. Findando-se o prazo (CC, art. 26) e não havendo interessados na sucessão provisória, caberá ao Ministério Público requerê-la, nos termos do § 1.º do art. 28 do CC/2002.

3.2.2 Citação

Requerida a abertura de sucessão provisória, determina o § 2.º do art. 745, que o interessado pedirá a citação pessoal dos herdeiros presentes e do curador e, por editais, a dos ausentes para requererem a habilitação, na forma dos arts. 689 a 692.

Dessa forma, verifica-se que o Código separou em três grupos de pessoas que devem ser chamadas em juízo, para estarem presentes no procedimento: a) “herdeiros presentes”, que são os domiciliados na comarca onde se procede à arrecadação dos bens;⁹⁵⁷ b) o curador, para que exerça sua função de administrador dos bens e interesses do ausente;⁹⁵⁸ c) os ausentes, que são aqueles não domiciliados na comarca onde se procede à arrecadação dos bens.⁹⁵⁹ João Paulo Lucena, sugere que, tanto o cônjuge (art. 27 do CC/2002) como o Ministério Público, devam ser citados também, de forma pessoal (por mandado).⁹⁶⁰

Além de separar aqueles que devam ser citados, a norma processual prevê, ainda, a forma como devem ser citados, sendo os itens “a” e “b”, de forma pessoal (por mandado) e “d”, por edital, que seguirá a forma descrita no art. 257 do CPC/2015.

3.2.3 Habilitação (arts. 689 a 692 do CPC/2015)

Após as citações, será aberto prazo para que de 5 (cinco) dias úteis se habilitem, contados da juntada aos autos do último mandado de citação cumprido ou, sendo o caso de publicação de edital, do termo final do prazo constante nele, nos termos do art. 690, do CPC/2015.⁹⁶¹

A habilitação nada mais é que o modo pelo qual os interessados citados, no caso, os herdeiros, comprovam sua qualidade para assumir a titularidade dos direitos que lhes competem em função da sucessão provisória, podendo haver, inclusive, impugnação por algum deles,⁹⁶² o que poderá ocasionar a necessidade de dilação probatória ou mesmo de designação de instrução, nos termos do art. 691, do

A habilitação se dará nos mesmos autos da sucessão provisória, conforme preceitua o art. 689, do CPC/2015.

3.2.4 Sentença de abertura da sucessão provisória

Verificado os requisitos de qualidade dos interessados, o pedido será deferido, por meio de sentença, que determinará a abertura da sucessão provisória. Ocorre que, a produção de efeitos da “decisão” só terá início, com o seu trânsito em julgado e após 180 (cento e oitenta dias) depois de publicada pela imprensa, nos termos do art. 28 do CC/2002. Contudo, este mesmo artigo prevê que, logo após a publicação do trânsito em julgado, já se permite a abertura de testamento (se *cerrado*) ou a sua apresentação (se *público*), e, conseqüentemente, ao inventário e partilha dos bens, embora com caráter de eventualidade e de transitoriedade, pois, como o próprio nome já diz, trata-se de sucessão *provisória*.

Pode-se dividir, portanto, a sentença, conforme os seus efeitos, em dois momentos: a) da publicação do trânsito em julgado, momento em que produzirá efeitos *excepcionais* – abertura ou apresentação de testamento e inventário e partilha; b) após o prazo de 180 dias, quando produzirá seus efeitos *normais* – imissão dos interessados na posse dos bens do ausente; em relação à terceiros; pertinente aos sucessores provisórios entre si. ⁹⁶³

Destaca-se que não “comparecendo herdeiro ou interessado para requerer o inventário até trinta dias depois de passar em julgado a sentença” que abre a sucessão provisória, transforma-se arrecadação dos bens do ausente pela forma da herança jacente (arts. 1.819 a 1.823 CC/2002). O acervo que inicialmente aparentava ter herdeiros, mas pertencia a quem desaparecerá sem deixar procurador, agora se sabe que não possui sucessores, sendo herança jacente, que, neste caso, se destinará à Fazenda Pública.

Após o transcurso do prazo de publicação da sentença (180 dias) a ordem procedimental, para o seu cumprimento, deve obedecer os detalhes indicados no direito material, como, por exemplo: a conversão, caso assim julgue conveniente o juiz, de bens móveis em títulos, a fim de lhes preservar (deterioração ou extravio), nos termos do art. 29 do CC/2002; a necessidade de apresentação de garantias (penhor ou hipoteca), na medida do quinhão respectivo, para imissão dos herdeiros na posse dos bens do ausente, conforme art. 30 do CC/2002; a exclusão do daquele que não puder prestar garantia e a manutenção da administração dos bens que lhe cabiam, pelo curador ou outro herdeiro (art. 30, § 1.º, do CC/2002; a posse dos bens do ausente, independentemente de garantia pelo ascendente, descendente e cônjuge/companheiro, uma vez provada sua condição como tal (art. 30, § 2.º, do CC/2002); a possibilidade de alienação ou hipoteca dos bens imóveis do ausente, apenas quando o ordene o juiz e para fins de preservação, conforme art. 31 do CC/2002; a representação ativa e passiva do ausente pelos interessados empossados nos bens, quanto às ações pendentes e as que futuramente forem movidas, nos termos do art. 32 do CC/2002; o direito a todos os frutos e rendimentos dos bens do ausente, respeitada a capitalização da metade destes aos outros sucessores, bem como o dever de prestar contas ao juiz (art. 33 do CC/2002); a perda, em favor do sucessor, da parte dos frutos e rendimentos que caberiam ao ausente, caso este não demonstre ausência involuntária e justificada (art. 33, parágrafo único, do CC/2002); a possibilidade do excluído da posse provisória querer que lhe seja entregue a metade dos frutos e rendimentos do quinhão que lhe tocaria, caso justifique falta de meios (art. 34 do CC/2002); a abertura da sucessão em favor dos herdeiros ao tempo em que se provar a época exata do falecimento do ausente (art. 35 do CC/2002).

3.3 Conversão da sucessão provisória em definitiva e o prazo legal

Passadas as duas etapas antecedentes e dez anos do trânsito em julgado da sentença “que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva”, bem como o levantamento das cauções prestadas pelos sucessores provisórios (art. 37, CC/2002). Os sucessores que tinham adquirido os bens a título provisório transmudam a relação com os bens, deixando ser provisória a sucessão para adquiri-lhes o domínio dos bens, em sucessão definitiva.

A sucessão definitiva também poderá ser requerida, caso se demonstre que o ausente possui oitenta anos de idade, e que fazem, pelo menos, cinco anos desde as últimas notícias dele, conforme art. 38 do CC/2002.

O prazo para requerimento da sucessão definitiva, previsto no art. 37 do CC/2002, deve ser contado levando-se em conta o prazo previsto no art. 26 do CC/2002, ou seja, será o prazo do trânsito em julgado

(publicação), mais um ano, caso não haja procurador estabelecido ou três anos caso haja, mais os dez anos, somando o total de 11 anos ou 13 anos. ⁹⁶⁴

Quanto à tramitação da conversão da provisória em definitiva, a doutrina entende, majoritariamente, que esta não ocorre *ipso iure*, ou seja, sem a necessidade de uma sentença judicial, bastando a ocorrência de uma das situações elencadas nos arts. 35, 37 e 38 do CC/2002, pois: a) a lei determina que o pedido seja feito por meio de requerimento de um dos interessados; b) sobre o requerimento, o juiz deve analisar se restou demonstrada a ocorrência de uma das hipóteses de cabimento da sucessão definitiva, manifestando-se, quanto aos pontos, por meio de decisão motivada; c) nesta mesma sentença, deve, ainda, o juiz, apreciar a gestão dos sucessores provisórios e do curador, se houver, bem como o pedido de levantamento das garantias por esses prestadas; d) deve, ainda, decidir sobre eventual exclusão da sucessão definitiva de algum sucessor provisório que tenha sido imitado na posse do respectivo quinhão da sucessão provisória ou de pretensão sucessor provisório que não tenha prestado garantia e cujo o quinhão tenha sido confiado à guarda do curador; e) há, ainda, a necessidade de uma sentença, para que se substitua, no Registro Público, via averbação, a sentença anterior que determinou a abertura da sucessão provisória (LRP, art. 107, § 1.º); f) é importante, ainda, a existência de uma decisão para desencadear os possíveis efeitos do art. 39, do CC/2002 (art. 745, § 4.º do CPC/2015). ⁹⁶⁵

Outro ponto a se destacar é que, conforme entendimento majoritário da doutrina, a sucessão definitiva não poderá ser aberta sem que antes tenha sido aberta a provisória, pois: “a) a sucessão provisória é imprescindível por prever a citação do ausente por editais, a fim de que compareça e reassuma a posse e a administração dos bens arrecadados; b) a sucessão definitiva é continuação da sucessão provisória, tanto assim que a lei estabelece a data do decurso do prazo do trânsito em julgado da sentença que determina a abertura dessa como *dies a quo* para a contagem do prazo de 10 anos para a abertura daquela”. ⁹⁶⁶ Somente na hipótese do art. 38 do CC é que poderá ser requerida a sucessão definitiva, dispensando-se a abertura provisória e o prazo de 10 anos à que alude o art. 37, do CC/2002.

3.4 Regresso do ausente

O processo de ausência, como verificado, se divide em três fases que se prologam por mais de 20 anos, sendo diversa as consequências na hipótese de reaparecimento do ausente. Têm-se, por exemplo, a hipótese de regresso do ausente nos dez anos seguintes à abertura da sucessão definitiva ou de algum de seus descendentes ou ascendentes. Neste caso, conforme preceitua o art. 39 do CC/2002, o ausente ou qualquer de algum dos seus descendentes ou ascendentes, só poderão reaver os bens existentes no estado em que se acharem, os sub-rogados em seu lugar, ou o preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebido pelos bens alienados depois daquele tempo, sendo necessária a propositura de ação própria para reivindicação destes bens (art. 745, § 4.º do CPC/2015), o qual seguirá o procedimento comum. A finalidade dessa medida, conforme afirmam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, “(...) é a proteção do terceiro de boa-fé, que não pode ter a sua esfera jurídica alcançada pelo regresso do ausente ou de algum dos seus descendentes”. ⁹⁶⁷

Outra hipótese a se destacar é a descrita pelo art. 36, do CC/2002, o qual determina que, retornando o ausente, quando já decretada a sucessão provisória, cessarão, desde logo, as vantagens dos sucessores nela imitados, mantendo-se, entretanto, a obrigação deles quanto à adoção de medidas assecuratórias até a entrega dos bens ao ausente. No mesmo raciocínio, a hipótese de aparecimento do ausente durante o processo de arrecadação, quando os bens já se encontravam na posse do curador.

Decorrendo, entretanto, o prazo de 10 anos da conversão da sucessão provisória em definitiva, ainda que apareça o ausente ou algum dos seus ascendentes ou descendentes, nada mais recebem. Da mesma forma se o ausente aparecer e não demonstrar que sua ausência se deu de forma involuntária e justificada, conforme art. 33, parágrafo único, do CC/2002.

3.5 Incorporação ao patrimônio público

Se no prazo de 10 anos do trânsito em julgado da sentença que concedeu a abertura da sucessão provisória, não regressar o ausente e nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do Município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições ou, se situados em território federal, serão incorporados ao domínio da União, nos termos do art. 39, parágrafo único, do CC/2002.

3.6 Intervenção do Ministério Público

O Ministério Público atua como parte, não é terceiro no processo ou ainda fiscal da ordem jurídica. Quando, por ventura, atua como parte, não necessita de um membro para um fim e outro membro para outro fim; basta um que além de fiscal represente o interessado. ⁹⁶⁸

3.7 Intervenção da Advocacia Pública

A Fazenda Pública não se encontra no rol do art. 27 do CC/2002, não se justificando inicialmente a sua participação, salvo se for credora direta em tributos, por exemplo. Diferentemente da herança jacente, na qual tem expectativa, pela possibilidade de amealhar a herança, neste caso dos bens dos ausentes a Fazenda Pública só participa se houver outros direitos, porque nem expectativa de herdar possui. Somente se não se habilitarem herdeiros e forem os bens convertidos em herança jacente (art. 1.819 CC/2002).

3.8 Sentença e recurso

O ato decisório final do procedimento é sentença, na qual será relatado e homologado o desfecho, que pode contemplar as hipóteses mencionadas acima: seja por não ser conhecido o titular, a divulgação do achado; a tentativa de restituição ao titular; se identificado o titular, a restituição; pagamento da recompensa; ou, se não encontrado o titular, oferta do valor remanescente ao Município ou Distrito Federal. Ainda, se ocorrer outra das hipóteses, tal como o desinteresse do Município ou Distrito Federal, caso em que o bem de pequeno valor será adjudicado ao descobridor, também constará da sentença.

E com sentença, se sujeita a recurso de apelação (art. 724), obedecendo aos requisitos *intrínsecos* : cabimento, legitimidade e interesse recursal e *extrínsecos* : tempestividade, regularidade formal e preparo. ⁹⁶⁹

Seção VIII

Das coisas vagas

1. Inovações do CPC/2015 na Seção

Não há inovações no conteúdo do título, porquanto somente se reordene o que se denominava *Capítulo* que a partir do CPC/2015 passa ser denominado de *Seção* .

2. Aspectos materiais gerais da Seção – Das Coisas Vagas

Pontes de Miranda é preciso ao definir as coisas vagas pelo que chama de critério diferenciador: “A ignorância de quem seja o titular do direito aos bens é que constitui elemento diferenciador” entre coisas vagas, jacentes e de ausentes. Assim, não são *vagos* os bens do morto, a herança jacente, ou os bens dos ausentes, porquanto desses se sabe a quem pertenciam, embora não se possa entregar a quem pertenciam (morto) ou pertencem (ausentes). ⁹⁷⁰

No Código Civil a descoberta vem prevista nos arts. 1.233 a 1.237, sem referir diretamente às coisas vagas, mas “coisa alheia perdida” (art. 1.233), “coisa achada” (art. 1.234). Já a herança jacente (arts. 738 a 743) e os bens de ausentes (arts. 744 a 745) não se confundem com as coisas vagas.

Os bens catalogáveis como coisas vagas, dos quais não se sabe a titularidade, e passíveis de descoberta, são majoritariamente os móveis e os semoventes, sendo remota a hipótese de bens imóveis darem-se por vacantes, embora possam ser também abandonados. Dentre os móveis pode-se cogitar de veículos, joias, documentos, equipamentos eletrônicos, animais, livros e outras tantas espécies de livre cogitação, associando-se sempre a apropriação, preponderantemente aos bens passíveis de posse.

Embora se considere remota ou mais difícil a hipótese de descoberta de bens imóveis, pois improvável a sua invenção. ⁹⁷¹

3. Aspectos processuais e procedimentais gerais da Seção

Houve uma evidente abreviação de diversos aspectos abordados no procedimento do CPC/1973, agora modificados ou retirados. A autoridade policial, antes tida como protagonista paralela à judicial, pelas novas disposições apenas deve encaminhar à autoridade judicial a coisa achada. Foram afastados detalhes tais como: o procedimento de entrega ao proprietário ou possuidor (CPC/1973, art. 1.172); a previsão da alienação de coisas não reclamadas, com abatimento de despesas (CPC/1973, art. 1.173); a

possibilidade de adjudicação diante do desinteresse do titular e interesse do descobridor (CPC/1973, art. 1.174); a aplicação do procedimento às coisas abandonadas em hotéis, oficinas e similares (CPC/1973, art. 1.175); a possibilidade de conversão em inquérito quando houver suspeita de subtração criminosa da coisa (CPC/1973, art. 1.176).

Novas tecnologias são incorporadas pelo CPC/2015, que atualiza as técnicas de comunicação ao permitir a divulgação dos editais por meio da rede mundial de computadores, com as evidentes vantagens da redução de custos.

Art. 746 . Recebendo do descobridor coisa alheia perdida, o juiz mandará lavrar o respectivo auto, do qual constará a descrição do bem e as declarações do descobridor.

§ 1.º Recebida a coisa por autoridade policial, esta a remeterá em seguida ao juízo competente.

§ 2.º Depositada a coisa, o juiz mandará publicar edital na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça ou, não havendo sítio, no órgão oficial e na imprensa da comarca, para que o dono ou o legítimo possuidor a reclame, salvo se se tratar de coisa de pequeno valor e não for possível a publicação no sítio do tribunal, caso em que o edital será apenas afixado no átrio do edifício do fórum.

§ 3.º Observar-se-á, quanto ao mais, o disposto em lei.

1. Inovações do CPC/2015

Há importantes supressões e alterações de dispositivos no art. 746 do CPC/2015, além de correção e atualização da linguagem legal, com convergências às expressões do Código Civil, assim como a atualização dos meios publicitários aos mais modernos, com a preferência em divulgação por meios como a rede mundial de computadores.

A alteração se deu sob o aspecto estrutural ao fundir o conteúdo de dois dispositivos que vinham antes divididos nos arts. 1.170 e 1.171 do CPC/1973 em um único, agora subdividido em dois parágrafos originais e acrescidos de um terceiro parágrafo. Este terceiro: “Observar-se-á, quanto ao mais, o disposto em lei”, tem a finalidade de compensar a supressão de outros cinco dispositivos que tratavam do procedimento de publicidade, oferta, alienação, compensação de despesas etc. decorrentes de ter-se encontrado um bem do qual se ignora a titularidade.⁹⁷² Esta supressão terá de ser compensada pelos dispositivos que estão presentes em outras normas, especialmente nos arts. 1.233 a 1.237 do CC/2002.

Esta supressão terá de ser compensada pelos dispositivos que estão presentes em outras normas, mas deixam dúvida sobre alguns pontos do procedimento.

2. Aspectos materiais

A descoberta de coisa vaga é um ato-fato jurídico, porquanto resultante de uma conduta humana.⁹⁷³ É dever de quem encontra “coisa alheia perdida” restituir ao proprietário ou possuidor (art. 1233), diretamente se o conhece, ou como prevê o procedimento de jurisdição voluntária, por meio de autoridade policial ou judicial. Não mais se situa a descoberta como forma de aquisição da propriedade, por não o ser e vir impropriamente situada nessa categoria no CC/1916, corrigida no CC/2002.⁹⁷⁴ Nem toda descoberta se refere a coisas vagas, pois se o descobridor encontra coisa que sabe a quem pertence, não é vaga a coisa, mas há a descoberta. Nem se confunde com herança jacente ou bens de ausentes, pois destes bens se sabe a titularidade, a propriedade ou posse.

O descobridor tem direito a uma recompensa de valor não inferior a cinco por cento do valor da coisa encontrada, considerando o esforço em encontrar o dono ou possuidor, as possibilidades que teria este de encontrar a coisa e a situação econômica de ambos, além da indenização de despesas de conservação e transporte (art. 1234). Mas também tem obrigações e responde por prejuízos causados à coisa, por dolo (art. 1.235) e responde criminalmente se se apropriar e mantiver consigo “coisa achada” por mais de 15 dias (CP, art. 169, parágrafo único, inc. II).

O CC/2002 prevê a obrigação das autoridades judiciais de publicarem por editais, se o valor comportar (art. 1.236), com o fim de encontrar o possuidor ou titular da propriedade do bem descoberto e fazê-lo saber do ‘achamento’. Neste ponto o CPC/2015 inova ao permitir a divulgação por meio da rede mundial de computadores. Há que se distinguir também a coisa de ninguém ou sem dono (*res nullis*), a coisa

abandonada (*res derelictae*), coisa que o dono expressamente renunciou da coisa perdida, objeto deste procedimento, pois esta última, se encontrada, transmite ao descobridor ou inventor, o dever de tentar encontrar quem a perdeu.⁹⁷⁵

Ao definir no § 3.º do art. 746 que: “quanto ao mais” observar-se-á “o disposto em lei”, está-se a dizer que a lei deve ser obedecida; seja a lei material que se impõe limitando o procedimento, como a lei ou leis processuais que aqui se projetam, complementando a *apócope* que se abateu sobre o regramento anterior, muito mais detalhado.⁹⁷⁶

3. Aspectos processuais e procedimentais

O procedimento judicial sucede às tentativas materiais frustradas de entrega voluntária da coisa pelo descobridor ao proprietário ou possuidor ou tentativas equivalentes da autoridade policial (CC/2002, art. 1.233).

A simplificação abrupta do procedimento pode gerar algumas dúvidas, que devem ser resolvidas no plano procedimental na conexão das ordens normativas que influenciam os procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Assim, cabível o procedimento quando frustrada a devolução por desconhecer o dono ou o legítimo possuidor.

Define-se a amplitude do procedimento a partir das normas gerais e daquilo que a tradição processual construiu, servindo: a) a imediata devolução b) não sendo sabido quem é o titular, a divulgação do achado (CC/2002, art. 1.236); c) a tentativa de restituição ao titular (CC/2002, art. 1.233 e parágrafo único); d) diante da não identificação do titular, alienação (CC/2002, art. 1.237) quando houver possibilidade; e) pagamento da recompensa (CC/2002, art. 1.234 e parágrafo único); e) oferta do valor remanescente ao Município ou Distrito Federal.⁹⁷⁷

3.1 Instauração do procedimento por autoridade policial

A instauração do procedimento pode se dar por autoridade policial (art. 746, § 1.º) ou por autoridade judicial (art. 746). Sendo recebida por autoridade policial, esta, após a lavratura do registro da ocorrência segundo as regras processuais penais e processuais administrativas próprias, “a remeterá em seguida ao juízo competente”.

Neste momento a atividade policial cinge-se à identificação aos elementos essenciais da descoberta, suas circunstâncias, as características da coisa encontrada, oportunidade, o local, a data e a hora. Salvo a circunstância de aflorarem elementos ou indícios que induzam à suspeição de ilícito ou crime, deve a autoridade policial apenas remeter o *boletim da ocorrência* e a própria coisa à autoridade judicial competente.

3.2 Competência

A competência de jurisdição é da Justiça Comum dos Estados e do Distrito Federal, e a jurisdição de foro determinada pela lei será comumente do juiz da comarca em que tiver sido encontrada a coisa móvel ou tenha domicílio o descobridor e, excepcionalmente, sobre o foro de situação da coisa imóvel, de difícil ocorrência. Na maioria dos casos de bens móveis, deve ser fixada pelo critério territorial, sendo relativa.⁹⁷⁸

Mas há situações mais complexas que podem envolver dois foros e fixar-se a competência após as tentativas frustradas de devolução da coisa perdida. Neste caso, não se sabendo qual o domicílio do proprietário da coisa encontrada, competente é o foro de domicílio do descobridor, pois impossível descobrir-se o domicílio do eventual proprietário (art. 46, *caput*), aplicando-se neste caso a regra subsequente, do domicílio do interessado ou descobridor (art. 46, § 2.º, parte final).

3.3 Instauração do procedimento e lavratura do ‘auto’ por autoridade judicial, arrecadação e guarda

Os atos judiciais de recepção das informações policiais ou da recepção direta de requerimento de instauração do procedimento por parte do descobridor ensejam a *processualização* , com registro ou distribuição (art. 43).

O termo lavrado em juízo – e não o *auto* – deve conter as informações essenciais sobre a descoberta e

as circunstâncias que permitam a aferição da veracidade deste fato, as características da coisa encontrada, oportunidade, ou seja, local, data e hora. Essas declarações do descobridor conformam a prova inicial essencial para o prosseguimento e decisão finais. Sendo escassas as informações oriundas da autoridade policial, devem ser completadas em juízo.

A arrecadação da coisa e sua guarda podem demandar, segundo suas características e necessidades, cuidados, comportamentos diversificados, de modo a preservarem-se suas características e valor. Pode a guarda ser encarregada a um depositário judicial ou administrador (art. 159), ao próprio descobridor cabendo a qualquer deles o dever de zelo (CC/2002, art. 1.235; CPC/2015, art. 161).

Há ausência de interesse processual, não se justificando o procedimento, se o valor da coisa não comportar o seguimento procedimental, que prevê a publicação de editais (CC/2002, art. 1.236). Essa hipótese não exclui o dever de diligências materiais policiais ou judiciais para a divulgação da descoberta e tentativa de localização do titular do direito ou posse. Por outro lado, se o bem for de pequeno valor, conceito indeterminado repetido no CPC/2015, deve ser realizada a publicação preferencialmente no sítio do Tribunal. Não sendo possível, o edital será afixado no átrio do edifício do fórum (art. 746, § 1.º).

3.4 Publicação dos editais e outros meios de divulgação

Os editais só devem ser publicados pela autoridade judiciária competente se o seu valor os comportar tal despesa, priorizando a publicidade da menos dispendiosa (CC/2002, art. 1.236).

Têm por finalidade, os editais, tornar pública a descoberta e permitir ao seu proprietário ou anterior possuidor que a reclame, razão pela qual, a partir do CPC/2015, abre-se a qualquer meio de comunicação, órgão oficial do Poder Judiciário, imprensa local, escrita, radiofônica ou outra, mas priorizam-se os meios eletrônicos, com maior capacidade de abrangência e menor despesa de recursos (art. 746, § 2.º). É possível que se repitam as publicações, se não é demasiada a oneração deste ato processual.

3.4.1 Comparecimento e manifestação de interesse

Havendo o comparecimento, identificada e demonstrada a posse ou propriedade, cessa a *vaguedade* ou *vagueza*, justificando-se a finalização do procedimento por sentença. Pontes de Miranda afirma que “comparecendo algum interessado, dono ou possuidor, há de provar o seu direito e, (...) decidirá o juiz.”⁹⁷⁹ A manifestação do interesse no processo deve ser acompanhada da demonstração da titularidade da propriedade do bem, que nos casos de bens móveis pode ser por documentos, sejam documentos fiscais, livros, certificados de propriedade ou outras provas documentais que indiquem tal domínio ou a equivalente tradição. Fotos e outros registros de imagem são exemplos probatórios ou pelo menos da posse de bens materiais, embora possam ser contraditados.

Em caso de simples possuidor que reclama a coisa, a posse demanda prova preponderantemente testemunhal, que pode ser designada para esse fim, embora se admita, em casos especiais, a prova documental da posse.

Não há mais, como no modelo anterior, a necessidade de ouvir o Ministério Público e a Fazenda Pública do Município e do Distrito Federal.

Julgando suficientemente provada a titularidade dominial ou mesmo só a posse cabe ao juiz entregar o bem a quem se diz e demonstra ser titular. Considerando insuficientemente demonstrada a alegação, deve permitir a ampliação da prova ou denegar definitivamente.

Se mais de um interessado alegam propriedade ou posse sobre a coisa, mantendo firmes as alegações, transmuta-se a natureza voluntária, comportando a extinção sem exame do mérito e a remessa aos procedimentos contenciosos que poderão ser possessórios ou mesmo petitórios (reivindicação ou imissão na posse); trata-se de *conversão* ou “remessa às vias ordinárias”, como em outras hipóteses que se inicia consensual o procedimento e, depois, exsurge a divergência.⁹⁸⁰

3.4.2 Ausência de reclamação, desinteresse, renúncia e abandono

Se não houver resposta às sucessivas manifestações públicas de chamado do titular de direito sobre a coisa, pelo prazo de sessenta dias previsto no Código Civil (art. 1.237),⁹⁸¹ entende-se que não há mais interesse do proprietário ou possuidor, que pode ocorrer após a perda ou por motivo de renúncia ou abandono com derrelição. É também possível que o proprietário ou possuidor tenha conhecimento do

chamado e demonstre tácita ou expressamente desinteresse ou mesmo o desejo abandonar a coisa. Quaisquer desses comportamentos justificam o prosseguimento à etapa subsequente.

O abandono da coisa é hipótese de perda da propriedade (CC/2002, art. 1.275, inc. III), podendo inclusive se caracterizar quando “cessados os atos de posse, deixar o proprietário de satisfazer os ônus fiscais” (art. 1.276, § 2.º), sem formalidades; a renúncia se caracteriza pela formalidade, sendo negócio unilateral não receptício, que pode ter como consequência a vacância e a arrecadação, especialmente no caso dos bens imóveis, observada a formalidade do registro imobiliário do negócio unilateral.⁹⁸²

3.4.3 Alienação e pagamentos ao descobridor, ao depositário e ao destinatário do remanescente

Somente se cogita da alienação em hasta pública⁹⁸³ se não houver a manifestação do proprietário do bem (pleno ou limitado). A alienação, como as demais alienações judiciais, deve ser precedida de avaliação, para que o preço apurado com a transmissão da propriedade seja compatível. A avaliação compete ao oficial de justiça avaliador (art. 154, inc. V) ou outro avaliador que tenha tal encargo dado pelo juiz.

Todas as despesas, inclusive as de depósito devem ser subtraídas do valor apurado com a alienação (art. 160); será também descontado o valor da recompensa devida ao descobridor, no valor mínimo de 5% (cinco por cento) do valor da avaliação.

Frustrada a alienação, abrem-se outras hipóteses de transmissão da propriedade ao ente público, que adjudicando, pode indenizar o valor da recompensa, por exemplo.

Não se pode cogitar de alienação da posse, compreendida como poder físico sobre a coisa, sem a correspondente propriedade. Se não há interesse do antigo possuidor em reintegrar-se na posse é da propriedade que se tratará, buscando o dono.

3.4.4 Recompensa e seu valor

A possibilidade de recompensa pela descoberta decorre da lei civil, podendo seu dever surgir da promessa de recompensa (CC/2002, arts. 854 a 860) ou como contrapartida legal pela descoberta (CC/2002, arts. 1.233 a 1.237).⁹⁸⁴ No caso das coisas vagas e de sua descoberta, a recompensa independe da promessa, pois é possível que o titular da posse ou propriedade nem saiba de seu extravio.

3.4.5 Oferta do valor remanescente ao Município ou Distrito Federal

Tendo havido a alienação, o pagamento do valor remanescente ao ente público é o último ato antes da finalização do procedimento, feito após o pagamento da recompensa e os eventuais descontos das despesas decorrentes do depósito, guarda e conservação do bem ou bens.

3.4.6 Sentença e recurso

O ato decisório final do procedimento é sentença, na qual será relatado e homologado o desfecho, que pode contemplar as hipóteses mencionadas acima: seja por não ser conhecido o titular, a divulgação do achado; a tentativa de restituição ao titular; se identificado o titular, a restituição; pagamento da recompensa; ou, se não encontrado o titular, oferta do valor remanescente ao Município ou Distrito Federal. Ainda, se ocorrer outra das hipóteses, tal como o desinteresse do Município ou Distrito Federal, caso em que o bem de pequeno valor será adjudicado ao descobridor, também constará da sentença.

E com sentença, se sujeita a recurso de apelação (art. 724), obedecendo aos requisitos *intrínsecos* : cabimento, legitimidade e interesse recursal e *extrínsecos* : tempestividade, regularidade formal e preparo.⁹⁸⁵

4. Conexão com outros procedimentos especiais

É possível identificar a conexão deste procedimento de arrecadação de coisas vagas com outros como o inventário e arrolamento, a arrecadação, a habilitação etc.

5. Inquérito, ação penal e responsabilidade criminal

É possível que a aparente perda, o abandono ou renúncia não correspondam aos fatos ou mesmo ocultem a exata razão do encontro, achamento ou descoberta. A informação trazida à autoridade policial

ou judicial deve ser verossímil, de modo a permitir o prosseguimento do trâmite administrativo e o procedimento judicial. O dispositivo suprimido que tratava do tema no CPC/1973 referia-se a “fundada suspeita” (art. 1.176) de que a coisa foi criminosamente subtraída, deve a autoridade policial converter a arrecadação em inquérito para a apuração do fato criminoso que se tentava ocultar com a suposta descoberta.⁹⁸⁶ As consequências processuais civis e processuais criminais, neste caso, são completamente diversas, pois a se confirmar a suspeita, cessa a necessidade de procedimento civil, não se justificando a recompensa e; deve o procedimento criminal evoluir com objetivo de identificar os possíveis indícios de materialidade e autoria, a justificarem o oferecimento de denúncia e instauração de processo crime, se este for o caso.

Seção IX

Da interdição

1. Inovações do CPC/2015 na Seção

Há pequena inovação na ordem do título, porquanto somente se reordena o que se denominava *Capítulo* que, a partir do CPC/2015, passa a ser denominado de *Seção*.

A denominação *Da Curatela dos Interditos* foi alterada para *Da Interdição*, medida de correção que indica a natureza do ato material pretendido, a interdição, e o procedimento, que tem por objetivo a eventual prolação da sentença constitutiva de interdição, sem referência direta à sua possível consequência, a curatela. As denominações do CPC/1973 e até mesmo do CPC/1939 recebiam severas críticas por inverter o sentido dos atos ou por serem muito amplas.⁹⁸⁷

2. Aspectos materiais gerais da Seção – Da interdição

A interdição e a curatela estão diretamente ligadas, sendo a segunda uma consequência da primeira. Conforme Pontes de Miranda, a interdição consiste em ato do Poder Público pelo qual se declara ou se retira (= desconstitui), total ou parcialmente, a capacidade negocial de alguém⁹⁸⁸. Tal medida se enquadra no campo do Direito de Família, contexto em que pode ser assegurada de forma mais eficaz e assertiva a proteção da pessoa maior com deficiência física ou mental que não pode conduzir diretamente sua vida, cuidar de seus negócios, bens e interesses, e administrar seu patrimônio.⁹⁸⁹

Contudo, há ainda um caso especial de curatela que ocorre quando falece o pai estando a mulher grávida e ao mesmo tempo destituída do poder familiar. Neste caso específico dar-se-á curador ao nascituro, a teor do que dispõe o art. 1.779 do CC/2002. O caso se apresenta como especial porque se trata de concessão de curatela à pessoa sequer nascida, vale dizer, que ainda não possui personalidade jurídica, mas já é titular de direitos (CC/2002, art. 3.º).

Cabe destacar, ainda, outro caso especial de concessão de tutela, que mais se aproxima de um contrato de *mandato*, que ocorre na hipótese em que a pessoa apresenta deficiência física, de forma transitória ou permanente, e pede judicialmente a nomeação de alguém para lhe representar nos atos da vida civil. Esta incapacidade física, permanente ou transitória, não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 1.767 do CC/2002, que descreve de forma típica as hipóteses de aplicação do instituto da curatela, porém, é caso de trânsito corrente na economia da vida e conta com apoio da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.⁹⁹⁰

Constata-se, também, a existência da denominada *curadoria especial* tal como prevista no art. 72, do CPC/2015 que, em verdade, não se trata da curatela que aqui se discorre, muito embora em ambos os institutos deva o curador zelar pelos interesses do curatelado. A *curadoria especial*, embora ostente nome que possa induzir ao entendimento de que se refira ao mesmo instituto da curatela, tem natureza jurídica de representação no âmbito estritamente *processual*, quando o incapaz não tiver representante legal ou quando os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade; bem assim, quando o réu preso for revel, bem como quando o réu revel for citado por edital ou com hora certa, enquanto não constituído advogado.

A curatela e a tutela são institutos protetivos correlatos, sendo que a curatela está associada ao maior, como está associada ao menor a tutela.

A consequência natural do julgamento procedente do pedido de interdição é a nomeação de curador ao curatelado, interdito ou interditado, que regerá, integral ou parcialmente, os atos da vida civil e os

bens ou somente os bens do interditado. Trata-se de procedimento voluntário, com certo grau de conflituosidade, que se vincula de forma íntima com o direito material aplicável à capacidade pessoal das pessoas físicas.

A proteção garantida por intermédio da interdição e, consequentemente, da curatela, busca tutelar as obrigações sociais, comerciais e pessoais, além dos bens sob a tutela do deficiente físico ou mental.⁹⁹¹ Não é a interdição, contudo, pressuposto à internação compulsória de doentes mentais, pessoas com transtornos graves ou mesmo usuários e dependentes químicos;⁹⁹² mesmo que haja redundância de requisitos, são medidas com finalidade diversa que não podem se confundir.

Anteriormente ao estudo da interdição em si, no entanto, cabe discorrer sobre a *tomada de decisão apoiada*, instituto de cunho material acrescentada ao ordenamento jurídico e ao CC/2002 pela Lei 13.146/2015, qual seja a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa nova norma ajusta a legislação brasileira, ainda que parcialmente, à *Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo*.⁹⁹³

3. Novos parâmetros da interdição e a tomada de decisão apoiada

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146/2015, alterou o CC/2002 na *Parte Especial*, Livro IV – *Direito de Família*, especialmente o Título IV – *Da Tutela e da Curatela* que passa a se chamar *Da Tutela, da Curatela e da Tomada de Decisão Apoiada*. A alteração ocorreu de modo expressivo no Capítulo II, *Da Curatela*, em que foram modificados parte dos artigos da Seção I – *Dos Interditos*, e incluído um Capítulo III – *Da Tomada de Decisão Apoiada* (art. 1.783-A, §§ 1.º a 11).

Basicamente foram alterados os incisos do art. 1.767 do CC/2002,⁹⁹⁴ referente aos sujeitos que podem ser interditados; revogaram-se os arts. 1.768 a 1.773, todos de cunho nitidamente processual, agora abarcados pelos dispositivos do CPC/2015, e acrescentou-se no mesmo título que versa sobre a tutela e a curatela, o instituto da *tomada de decisão apoiada*, art. 1.783-A, regradada em onze parágrafos.⁹⁹⁵

Segundo a própria literalidade do art. 1.783-A do CC/2002, dispositivo inserido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, a *tomada de decisão apoiada* é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 (duas) pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhe elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade.

Pelo que se depreende dos dispositivos que regulam o instituto da *tomada de decisão apoiada*, esse terá aplicação mediante submissão em juízo de pedido devidamente fundamentado, em circunstância notavelmente análoga ao procedimento de jurisdição voluntária da interdição para imposição da curatela. Desse fato, pode-se extrair que esse instituto possui natureza jurídica híbrida, ou seja, *material e processual* no ordenamento jurídico brasileiro, sendo tarefa árdua apontar o enquadramento teórico aplicável à *tomada de decisão apoiada*. O Superior Tribunal de Justiça, após dois anos de vigência do CPC/2015, ainda não enfrentou diretamente a matéria,⁹⁹⁶ já debatida nos Tribunais de Justiça.

Da estrutura desse procedimento pode-se extrair, também, que a *tomada de decisão apoiada* possui igualmente natureza processual de jurisdição voluntária, da mesma forma que o procedimento de interdição. A finalidade do procedimento que habilita o deficiente à *tomada de decisão apoiada* objetiva o exercício de atos da vida civil da mesma forma que a curatela eventualmente decretada em sede de interdição.

À primeira vista pode-se confundir os dois institutos. No entanto, uma análise atenta autoriza inferir que a *tomada de decisão apoiada* consiste em medida cabível numa hipótese mais branda de incapacidade de exprimir vontade ou de deficiência física ou mental, que permite ao deficiente ainda responder de forma satisfatória por seus atos, negócios e administração de seus bens. Além disso, os dois institutos se diferenciam em alguns pontos do procedimento judicial em que foram estabelecidos.

Enquanto a *tomada de decisão apoiada*, nos termos do § 1.º do art. 1.783-A do CC/2002, depende da formulação de pedido pelo deficiente, com indicação expressa dos apoiadores, oportunidade na qual tais sujeitos deverão demarcar os limites do apoio a ser oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de vigência do acordo e o respeito à vontade, aos direitos e aos interesses da pessoa que devem apoiar; não cabe aos interessados nem apoiar a iniciativa unilateral, como definiu o TJSP.⁹⁹⁷ Já a interdição, com a consequente nomeação de curador, envolve a promoção de pedido por terceiros legalmente legitimados para tanto, pai, mãe, cônjuge ou companheiro, parentes ou tutores, representante

da entidade em que se encontra abrigado o interditando ou representante do Ministério Público, este derradeiro, somente em caso de doença mental grave.

Na *tomada de decisão apoiada*, é imprescindível a iniciativa do próprio deficiente, aliada à manifestação de vontade dos apoiadores, enquanto na interdição, procedimento que se enquadra no Direito de Família, o interesse em proteger a pessoa do curatelado e resguardar os seus bens, negócios e relações pessoais advém geralmente de *terceiros interessados* no bem-estar do interditando. Embora o cabimento da promoção do pedido de interdição pelo próprio interditando consista em matéria controversa que deva ser melhor explorada, o interesse para tal propositura é garantido a terceiros.

Não são nem fungíveis, nem conversíveis entre si a *interdição* e *tomada de decisão apoiada*, em que pese a complementariedade ou a característica comum de procedimentos de jurisdição voluntária; podem ser prejudiciais entre si, mas a improcedência de um pode abrir espaço à propositura de outro, consideradas as razões da rejeição do pedido em cada caso. Entretanto o processamento simultâneo dos procedimentos (de *interdição* e de *tomada de decisão apoiada*) pode motivar a reunião e o julgamento conjunto de processos mesmo sem ocorrência de conexão ou continência (arts. 55 e 56), para a preservação da coerência decisória (art. 55, § 3.º).⁹⁹⁸ Tem-se rejeitado o conhecimento dos pedidos de tomada de decisão apoiada recebidos ou deferidos como curatela em interdição, medida adotada pelos juízes de primeiro grau diante do desconhecimento do novo instituto.⁹⁹⁹

A coexistência desses institutos, portanto, aumenta o leque de possibilidades que o deficiente físico ou mental tem em promover atos de guarda e de tomada de decisões, restando ao deficiente ou às próprias pessoas que o circundam optar pela forma mais adequada ao caso concreto. Em face disso, não há que se falar em impossibilidade de coexistência desses institutos, mas sim de harmonia. Casos há em que rejeitada a interdição diante da inexistência de incapacidade ou deficiência grave, sinaliza o juízo para a possibilidade ou alternativa da tomada de decisão apoiada.¹⁰⁰⁰

Acrescente-se, ainda, que a *tomada de decisão apoiada* não é condição de existência, validade ou de eficácia do ato jurídico praticado por este tipo de deficiente que, para todos os efeitos, ainda que não fosse *apoiado*, apresentaria a higidez necessária para vinculá-lo. Por outro lado, a prática de ato jurídico da parte do interditado é nulo, por força do que, disposto no art. 104, I do CC/2002, caso tenha sido produzido sem a necessária intervenção do curador, porque ausente a capacidade da parte do interditado.

Isto se reflete no fato de que o *apoiado* subscreve pessoalmente o negócio jurídico que vier a contratar, podendo o contratado exigir a *contra-assinatura* do contrato pelos *apoiadores* conforme art. 1.783-A, § 5.º do CC/2002, ao passo que o interditado é representado pelo curador, não comparecendo pessoalmente ao negócio jurídico.

4. Aspectos processuais e procedimentais gerais da Seção

Manteve-se a interdição como um procedimento de jurisdição voluntária, apesar da observada *contenciosidade* nela contida, motivo de classificação em outras legislações como jurisdição contenciosa e de extensa controvérsia entre os autores¹⁰⁰¹.

O procedimento de interdição, em sua essência, não sofreu alterações profundas no CPC/2015. As alterações principais desta *Seção* se voltaram ao acréscimo de legitimados ativos aptos a promoverem tanto o pedido de interdição como o levantamento da curatela do interdito, ao acréscimo de procedimentos que se fundam em avanços tecnológicos próprios do período em que o atual ordenamento brasileiro se insere, à especificação das formas de atuação do Ministério Público, ao fortalecimento da instrumentalidade das formas no procedimento de interdição e ao levantamento da curatela do interditado.

Ainda segundo Pontes de Miranda, “a ação e a sentença de interdição têm por fito *organizar* a defesa do incapaz e *assegurar* a [sua] eficácia *erga omnes*”.¹⁰⁰²

Em realidade, pode-se dizer que as alterações promovidas no CPC/2015 advêm da interação dos dispositivos de natureza processual com as normas aplicáveis à curatela dos interditos, estas de natureza material, tal como a tomada de decisão apoiada, incluída no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), que altera o CC/2002.

As alterações mais expressivas no CPC/2015 são referentes à legitimação dos parentes e outras

peessoas, antes restrita ao pai e à mãe, parente próximo ou cônjuge; agora estendido a parentes em geral, tutores e “companheiro” que, atualmente, comporta o companheiro homossexual, autorizado a atuar como parte na propositura do pedido de interdição; além do representante de entidade de abrigo. Cria-se a possibilidade de nomeação de curador provisório, justificando-se a urgência, desde que requerido na inicial. Alteram-se requisitos probatórios iniciais, incumbindo ao requerente a prova por laudo médico de suas alegações ou a justificativa da impossibilidade de fazê-lo. A prova sofre adaptações importantes, com possibilidade expressa de inspeção judicial e entrevista do interditando pelo do juiz, acompanhado de especialista, além da ampliação dos poderes do juiz que pode ouvir parentes e pessoas próximas. ¹⁰⁰³ Amplia-se o prazo de impugnação do interditando de cinco para quinze dias. Admite-se expressamente a possibilidade de que cônjuge, companheiro ou parente intervenha como assistente, caso o interditando não constitua advogado. A prova pericial passa a ser mais ampla, realizada por equipe multidisciplinar e o laudo deve indicar especificamente os atos que são suscetíveis de curatela. A sentença de interdição passa a definir limites da curatela e considerará potencialidades, habilidades e preferências, assim como a indicação dos atos que o interditando poderá praticar autonomamente. A interdição poderá ser levantada total ou parcialmente, incluindo-se entre os deveres do curador a conquista de *autonomia* pelo interditado.

Art. 747 . A interdição pode ser promovida:

I – pelo cônjuge ou companheiro;

II – pelos parentes ou tutores;

III – pelo representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando;

IV – pelo Ministério Público.

Parágrafo único. A legitimidade deverá ser comprovada por documentação que acompanhe a petição inicial.

1. Inovações do CPC/2015

Como visto, inova em alguns aspectos o art. 747, especialmente na legitimidade para o pedido de interdição, que é ampliada para abarcar parentes não próximos, merecendo o detalhamento a seguir realizado.

2. Aspectos materiais da legitimidade para a interdição

Destaca-se na legitimação para o pedido de interdição, inicialmente, a relação parental, agora ampliada, e a legitimação institucional, decorrente da relação administrativa introduzida pelo CPC/2015 dada ao “representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando” que passa a ter poderes para a postulação, todos eles interessados na preservação dos interesses patrimoniais e civis do interditando, tal como garantida pelo Direito de Família. Assim, o interesse meramente patrimonial ou predatório de terceiro na interdição de determinada pessoa não possui espaço na norma processual aplicável a essa matéria. A atuação do Ministério Público é nitidamente restringida por ser subsidiária e limitada aos casos dos incs. I e II e do *caput* do art. 748 do CPC/2015.

Essencial destacar, também, que desde a década de 1990 as leis materiais equipararam cônjuge a companheiro para fins de garantia de direitos e obrigações civis, motivo pelo qual não existe mais qualquer espécie de discriminação entre tais sujeitos quanto à legitimação ativa para procedimentos processuais. Ademais, a interpretação sistemática e atual da Constituição Federal de 1988 e do ordenamento jurídico brasileiro aponta no sentido de que os companheiros homoafetivos podem pleitear, na condição de cônjuges, a interdição um do outro. Isso porque, em 2011, o STF reconheceu como válido, ao julgar a ADIn 4.277 e a ADPF 132, a união estável entre homossexuais como instituto civil-constitucional. O intuito foi o de elidir qualquer interpretação do art. 1.723 do CC/2002 que impedisse o reconhecimento da união entre homossexuais na condição de entidade familiar.

O fundamento principal para o reconhecimento dessa união como entidade familiar está sediada no art. 3.º da Constituição Federal de 1988, que veda a discriminação em virtude de sexo, raça, cor, ou qualquer outro elemento que enseje discriminação entre pessoas. A orientação sexual se enquadrou neste dispositivo, como elemento não mais possível de discriminação. Com isso, o art. 206, também da Constituição, a despeito da sua literalidade apontar para sentido oposto, restou, desde então, expandido

em sua aplicação. No mais, as disposições relativas aos legitimados ativos não sofreram alterações relevantes, à exceção das entidades que foram acrescentadas ao inc. III deste dispositivo.

3. Aspectos processuais e procedimentais

O art. 747 do CPC/2015 estabelece os passos processuais preliminares do procedimento, como a legitimação e a forma de sua demonstração na petição inicial da ação interdição, por meio de documentação que comprove tal legitimação.

3.1 Os legitimados ‘ativos’ ou autores

São legitimados a propor a interdição na qualidade de autor, nos termos das novas disposições do art. 747 do CPC/2015, os cônjuges ou companheiros, os parentes ou tutores, o representante da entidade que abriga o interditando e o Ministério Público, com a ressalva de que o Ministério Público promoverá o pedido de interdição com as limitações impostas pelo art. 748 do CPC/2015, daquele que, por causa transitória ou permanente, não puder exprimir sua vontade (CC, art. 1.767, inc. I), do ébrio habitual e do viciado em tóxico (CC, art. 1.767, inc. III) ou do pródigo (CC, art. 1.767, inc. V).

Como destacava a doutrina, os legitimados ativos para a propositura do procedimento de interdição vinham apontados nas normas materiais e não nas processuais,¹⁰⁰⁴ técnica alterada a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), que revogou os arts. 1.768 a 1.773 do CC/2002, conquanto estivessem contemplados tanto no CPC/1973 como no CPC/2015. A despeito disso, nesta seção, os aspectos processuais serão explicitados, cabendo à exploração material esmiuçar os diversos reflexos sofridos na legislação civil.

Embora reconheça a doutrina não se tratar de um processo de “partes” que pedem umas “contra” as outras,¹⁰⁰⁵ a terminologia neste procedimento especial voluntário o aproxima daqueles especiais contenciosos, justificando o uso da expressão “autor” para o legitimado ativo (art. 749).

3.1.1 Cônjuge ou companheiro

A legitimidade processual da pessoa constante do inc. I do art. 747 restou reservada ao cônjuge ou ao companheiro do interditando que venha figurar como parte passiva de interdição. Com isso, fica evidente que tanto as uniões matrimoniais quanto as uniões estáveis serão consideradas para fins de legitimação ativa do procedimento de interdição.

Alcides de Mendonça Lima propunha, na vigência do CPC de 1973, que não fosse obstáculo para a propositura do procedimento de interdição e à legitimidade ativa, no tocante ao cônjuge, a separação exclusivamente de fato, assim como o regime matrimonial constituído entre os cônjuges ou companheiros. Tais situações podem apenas repercutir na nomeação do curador provisório ou definitivo em fase de sentença, tendo em vista que o juiz optará pela pessoa mais apta a resguardar os interesses do interditando.¹⁰⁰⁶ Observada a finalidade da interdição, plausível que se faça a mesma interpretação mesmo após a edição do CC/2002, seja qual for o regime de bens, entendendo-se legitimado o cônjuge ou o companheiro para a proposição da interdição.

Contudo, há entendimento do STJ¹⁰⁰⁷ no sentido de que mesmo sendo o cônjuge um dos legitimados ativos e preferencial na ordem de nomeação, até mesmo por força da relação de afeto que nutre com o interditando, esta ordem de vocação pode ser alterada caso exista comprovada litigiosidade entre o cônjuge e o interditando, tudo com fundamento no *princípio do melhor interesse do incapaz*.

Aos companheiros, dá-se agora legitimidade ativa, ainda que se exija o reconhecimento dessa relação e a impropriedade da ação de interdição para as duas finalidades: reconhecer a relação de companheirismo e instituir a curatela.¹⁰⁰⁸ Os companheiros de sexos diversos, desde a década de 1990 vêm ampliando seus direitos até alcançarem a igualdade com os direitos aplicados aos cônjuges, tanto em relação aos alimentos, à partilha de bens na dissolução das uniões, à sucessão, dentre outros, justificando-se aqui a equiparação na legitimação processual, largamente ampliada no CPC/2015.¹⁰⁰⁹ Como já demonstrado, também quanto aos companheiros do mesmo sexo, as interpretações dos arts. 1.723 do CC/2002 e 206 da CF/1988, autorizam que a propositura de pedido de interdição por parte de companheiros seja cabível, dado o reconhecimento de uniões homossexuais como entidades familiares equiparadas às uniões heterossexuais. Após a eventual separação no casamento (judicial, cautelar ou definitiva e extrajudicial) ou ações de divórcio e outras ações dissolutórias de uniões, tal legitimidade cessa, restando aos demais legitimados, a possibilidade de proposição da ação de interdição.

3.1.2 Parentes, pai, mãe, irmãos e outros

Houve aqui uma alteração, trocando-se o pai e a mãe por parentes, em claro movimento de ampliação da legitimação familiar para o processo de interdição.

As relações de parentesco vêm definidas no CC/2002, em suas *Disposições Gerais*, arts. 1.591-1.595, e divide-se em parentesco natural, quando decorrente de consanguinidade, ou civil, quando decorrente de outra origem (CC/2002, art. 1.593), dada inexistência de elementos textuais que permitam especificar qual a extensão do termo "parentes". Assim, são legitimados pelo parentesco consanguíneo em linha reta quaisquer parentes ascendentes ou descendentes uns em relação aos outros, sejam consanguíneos ou socioafetivos. Ainda na vigência do CPC/1973, Alcides de Mendonça Lima,¹⁰¹⁰ observava que, em linha reta, todos são legitimados independentemente do grau. Incluem-se nesse termo, assim, pais, avós, bisavós, filhos, netos e bisnetos, como também observara Pontes de Miranda.¹⁰¹¹

Em linha colateral, pode-se cogitar, atendendo às concepções de parentesco do CC/2002, que são parentes os colaterais até o quarto grau, quando descendem de tronco comum sem descenderem essas pessoas uma da outra (CC/2002, art. 1.592). Restam ainda os parentes por afinidade, parentesco caracterizado pela aliança entre cônjuges ou companheiros (CC/2002, art. 1.595), limitado neste caso "aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro" (CC/2002, art. 1.595, § 1.º),¹⁰¹² que passam a ser também legitimados para a propositura da ação de interdição.¹⁰¹³ Independentemente, também nestes casos, de tratar-se de união entre pessoas de sexo diverso ou de mesmo sexo.

3.1.3 Tutores

O direito tutelar objetiva a proteção do menor, associada à perda ou decaída do poder familiar pelos pais ou nos casos de ausência ou falecimento destes. Sua regulação se dá no CC/2002, principalmente pelos arts. 1.728 a 1.766, que regulam a capacidade ou incapacidade de ser tutor, a escusa e exercício da tutela, zelo aos bens e prestação de contas e a cessação da tutela, bem como no *Estatuto da Criança e do Adolescente*, Lei 8.069/1990, arts. 36 a 38 e 164.

Segundo Pontes de Miranda, a tutela consiste no poder conferido pela lei, ou segundo princípios legais, à pessoa capaz, a fim de que esta proteja os bens dos menores que se encontram fora do pátrio poder, hoje poder familiar. Pontes de Miranda expõe, ainda, que o tutor é a pessoa nomeada para resguardar a pessoa e os bens do menor, garantindo a sua educação, alimentação e correção de curso com o auxílio do juiz competente nas hipóteses em que os pais do menor ou do relativamente incapaz entre 16 e 18 anos tenham falecido (art. 1.728, inc. I, do CC/2002), ou tenham decaído do poder familiar (art. 1.728, inc. II, do CC/2002). Conclui-se que a tutela é um dos institutos de direito material mais relevantes para a proteção do menor.¹⁰¹⁴

A legitimidade processual do tutor resta estabelecida neste dispositivo caso o menor torne-se, por causa transitória ou permanente, incapaz de exprimir sua vontade (CC/2002, art. 1.767, inc. I), nos casos em que devesse. Também são motivos que podem ensejar a interdição a embriaguez habitual, o vício em tóxico e a prodigalidade (CC/2002, art. 1.767, incs. III e V), causas que, se ocorrentes no menor sob tutela, podem estar associadas à negligência dos cuidados do tutor, ensejando antes a remoção do tutor que a interdição e curatela do menor.

Em síntese, se o menor já está sob tutela e advém qualquer das causas constantes do art. 1.176 do CC/2002, quais sejam, a perda, ainda que transitória, da capacidade de exprimir a sua vontade, a embriaguez habitual, o vício em tóxico e a prodigalidade, deve o menor ser interditado a pedido do seu tutor. Cabe destacar, portanto, que esta é uma situação excepcional na medida em que nesta hipótese se estará aplicando um instituto que, regra geral, é aplicado somente a pessoas maiores e deficientes em algum grau. Portanto, se por exemplo, o menor já nasce com deficiência mental que de forma provisória ou permanente o impeça de exprimir a sua vontade, é caso de interdição e não de deferimento de tutela.

3.1.4 Representante de entidade de abrigo

As instituições de atendimento ou de acolhimento prestam imprescindível papel social e comunitário. O acréscimo dentre os legitimados ativos do representante de entidades de abrigo responsável pela pessoa a ser interditada representa novidade que contribui para a tutela dos legitimados passivos. Dentre as causas que podem ensejar a interdição do legitimado passivo estão a impossibilidade, por causa transitória ou permanente, de exprimir a sua vontade (CC/2002, art. 1.767, inc. I), a embriaguez habitual, o vício em tóxico e a prodigalidade (CC/2002, art. 1.767, incs. III e V). Excluído o pródigo, os

demais sujeitos citados podem vir a estar abrigados nessas instituições. Os abrigos são instituições presumivelmente diferentes dos asilos sem as garantias legais,¹⁰¹⁵ orfanatos ou abrigos.¹⁰¹⁶

Em realidade, vislumbra-se atualmente de forma recorrente que diversas pessoas com déficits ou vulnerabilidades incapacitantes se encontram sob os cuidados de abrigos, asilos, entidades beneficentes e organizações não governamentais que efetivamente já cuidam do bem-estar de crianças, idosos, doentes mentais, deficientes físicos, ébrios, viciados em tóxico e outros. A respectiva interdição do legitimado passivo e a constituição do representante da entidade acolhedora como curador permite a defesa judicial de direitos sociais, a defesa patrimonial e o cumprimento de obrigações civis.

Com essa alteração, o representante da entidade que abriga o interditando, poderá promover da mesma forma que os demais legitimados o procedimento de interdição. A medida veio em boa hora na medida em que não raras vezes são desconhecidos os parentes de não poucos abrigados, que ficavam à mercê da iniciativa exclusiva do órgão do Ministério Público para promoção de sua interdição a despeito de os representantes de tais entidades melhor conhecerem os fatos que demandavam a interdição, na medida em que eram despossuídos de tal legitimidade.

De igual forma, as entidades que abrigam menores em conflito com a lei agora podem contar com a iniciativa de seus representantes para promoverem ação de interdição de menor ou adolescente que esteja viciado em tóxico, o que não é incomum à realidade do nosso país.

A transitoriedade da permanência do interditando em abrigo não afasta a legitimidade dos demais legitimados, seja cônjuge ou companheiro, parentes ou tutores, embora a extensão dessa legitimidade esteja associada à durabilidade ou perenidade das internações e à suposição de sua inexistência ou inatividade.

A lei processual contempla a legitimidade do representante da instituição de acolhimento (abrigo) sem mencionar o acolhimento familiar (Lei 8.069/1990, art. 19, § 1.º), que possui caráter excepcional e temporário, posto que poderia também legitimar família substituta que tenha a guarda do deficiente, a propor medida protetiva em favor da criança e do adolescente que careça da curatela (Lei 8.069/1990, art. 50, § 11).

3.1.5 Ministério Público

Da leitura exclusiva do inc. IV do art. 747, nota-se que houve pequena alteração com evidente redução da legitimação do Ministério Público para a interdição no CPC/2015, pois comparativamente, as disposições anterior e atual possuem redação quase idêntica. A atuação do Ministério Público passa a ser secundária e condicionada à inércia ou impossibilidade dos interessados diretos, sejam familiares ou não, como ficará mais claro no comentário ao art. 748, mas o campo de atuação anterior passa dos casos genéricos de “anomalia psíquica” para os mais restritos de “doença mental grave”.¹⁰¹⁷

É possível, entretanto, identificar uma legitimação incondicionada do Ministério Público. Quando no polo ativo do procedimento de interdição, na condição de substituto processual, não poderá desistir deste processo, pois, conforme art. 127 da Constituição Federal, é dever desse representante (Ministério Público) a tutela dos direitos sociais e individuais indisponíveis, dispositivo que vincula sua atuação a este procedimento.

Segundo José Olympio de Castro Filho, o Ministério Público possui legitimidade para encampar a ação que qualquer um dos demais legitimados tenha desistido de continuar promovendo, visto que iniciar um procedimento autônomo seria mais custoso e demorado ao interditando que já se encontra no polo passivo da demanda.¹⁰¹⁸

3.2 Legitimidade do interditando para pedir a sua própria interdição

A despeito da falta de manifestação expressa do legislador no CPC/2015, mas em conformidade com o entendimento de Alcides de Mendonça Lima, entende-se que o interditando pode ser parte hábil para promover o próprio pedido de interdição. A pessoa pode ter a percepção de que não está em seu melhor juízo, já que os graus de transtornos mentais não necessariamente são absolutos e definitivos, admitindo gradações. O interesse em resguardar os bens e questões pessoais de natureza civil não poderia ser maior para alguém senão ao próprio titular desse direito.¹⁰¹⁹ Edson Prata posicionava-se contrariamente à esta possibilidade.¹⁰²⁰

O trâmite simultâneo do CPC/2015 e da Lei 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, produziu progressos e algumas incoerências. Uma dessas incoerências é a inclusão expressa da própria pessoa (o interditando) como legitimado ativo para a autointerdição pela inclusão de um inc. IV no art. 1.768 do CC/2002, dispositivo curiosamente revogado pelo CPC/2015.¹⁰²¹

Fredie Didier Jr. sugere que tenha havido revogação tácita, pois a “diferença é evidente e, nesse caso, parece mais adequado considerar que houve revogação tácita do CPC-2015, no ponto, pela Lei 13.146/2015. A legitimidade do Ministério Público para a ação de interdição deve observar o comando do Estatuto da Pessoa com Deficiência”.¹⁰²²

Essa possibilidade cogitada há décadas por Alcides de Mendonça Lima se ajusta à nova legislação, que prevê a *tomada de decisão apoiada* (CC/2002, art. 1.783-A), na qual se admite que a pessoa com deficiência, amparada em *apoiadores*, e baseada em “elementos e informações necessários [...] possa exercer sua capacidade”. De igual modo, a inovação do CPC/2015, que prevê a possibilidade de levantamento parcial da interdição, quando demonstrada a capacidade do interdito para praticar alguns atos da vida civil (art. 756, § 4.º), tem o mesmo sentido e progresso no reconhecimento de uma *autonomia parcial*. Além disso, tal possibilidade se coaduna com a previsão do possível levantamento da interdição promovido pelo próprio interditado (art. 756, § 1.º), que seria parte indubitavelmente interessada nesse procedimento. Uma análise sistemática e analógica dessas inovações aponta, portanto, para a possibilidade do interditando solicitar a própria interdição, em ato que visa resguardar os seus próprios interesses. Resta apenas a incongruência legislativa, por ter-se introduzido a norma no CC/2002 (art. 1.768, inc. IV) e não no CPC/2015, que revogara o mesmo art. 1.768, agora repristinado em seu *caput*.

3.3 Litisconsórcio entre legitimados ativos e intervenção de terceiros

Não se exclui a possibilidade de litisconsórcio entre colegitimados erigir interesses materiais e processuais com evidente conveniência e economia. Uma questão ainda a ser examinada é a de se admitir como legitimado um dos integrantes do rol do art. 747 com o próprio interditando, nas hipóteses em que se admita este como legitimado para a autointerdição (CC/2002, art. 1.767, inc. IV). Admitida esta última hipótese, não se há de estranhar a possibilidade dessa convergência de interesses na interdição, especialmente a parcial.

Alia-se a essa proposta a própria natureza da jurisdição voluntária e sua baixa contenciosidade, a natureza dos interesses tutelados, a amplitude da atividade judicial, a disponibilidade das provas; tudo isso conduz a uma adaptabilidade procedimental e a uma tolerância que desfaz certo formalismo improdutivo.

Já as figuras de intervenção de terceiros, como dito no *Breve ensaio inicial*, item 7.2.3, não são por si avessas à jurisdição voluntária, especialmente em procedimentos como a interdição, com componentes mais intensos de contenciosidade. Arruda Alvim ampara Ubiratan do Couto Maurício que admite a intervenção, contrariando numeroso grupo que não admite.¹⁰²³ A ação de oposição, corretamente deslocada para os procedimentos especiais contenciosos no CPC/2015, era rejeitada na interdição.¹⁰²⁴

3.4 Da legitimidade passiva para o procedimento de interdição

Legitimados passivos do procedimento de interdição são aquelas pessoas sujeitas à curatela e descritas na Seção I (Dos Interditos) do Capítulo II (Da Curatela) do Título IV (Da Tutela, da Curatela e da Tomada de Decisão Apoiada) do Livro IV (Do Direito de Família) da Parte Especial do CC/2002.

A partir da nova redação dada pela Lei 13.146/2015 ao art. 1.767 do CC/2002 são prováveis sujeitos passivos: aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade (art. 1.767, inc. I); os ébrios habituais (art. 1.767, inc. III); os viciados em tóxico (art. 1.767, inc. III) e os pródigos (art. 1.767, inc. V). A nova redação do inc. I do art. 1.767 mantém parte da expressão ampla contida no inc. II revogado: “por outra causa duradoura, não puderem exprimir a sua vontade” de modo a abranger todas as hipóteses prevista na redação original do CC/2002.¹⁰²⁵

3.4.1 Impossibilitados de exprimir sua vontade, por causa transitória ou permanente

Supera-se com essa definição a antiga concepção de interdição e curatela dos loucos, neuróticos e psicóticos, correspondente às pessoas que são acometidas de perturbações mentais, fragilidade mental, consideradas relativamente incapazes de reger os seus bens e a si mesmos e, portanto, demandam pela

intervenção de curador que se mostre capaz de resguardar os bens e suas responsabilidades civis.

De modo muito especial o CC/2002, após as alterações introduzidas pela Lei 13.146/2015, reduz a *incapacidade absoluta* apenas aos menores de 16 anos (art. 3.º, *caput*), incluindo todos os demais sujeitos que, “por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, na condição de *relativamente incapazes* (art. 4.º inc. III), ao lado dos ébrios habituais, viciados em tóxico e pródigos.

A impossibilidade de *expressão da vontade* passa a ser a diretriz desta limitação da capacidade, categoria indicada no inc. II do art. 1.767 do CC/2002, após a redação da Lei 13.146/2015, suprimindo, assim, as indicações repetitivas originais do CC/2002, tais como o *enfermo ou deficiente mental* (inc. I, redação anterior), *deficiente mental* (inc. III, redação anterior), *os excepcionais sem completo desenvolvimento mental* (inc. IV, redação anterior). A alteração criou certa incoerência.

Neste campo amplo e indefinido pelo qual optou o legislador que reformou o CC/2002, cabem duas grandes categorias, as quais, segundo certa técnica classificatória, podem ser definidas por gênero e espécie que são: a) *as pessoas com deficiência* e a1) *as pessoas com transtornos mentais*.

Também os surdos-mudos, que eram considerados passíveis de interdição e curatela, a ela não mais, necessariamente, se sujeitam, pois, embora acometidos de deficiência física que obste sua interação regular com a sociedade, podem ter capacidade de expressão e comunicação. A surdo-mudez admite graus de incapacidade, podendo ser considerada como absolutamente incapacitante somente na hipótese de o seu portador não se mostrar apto a promover os atos básicos relativos à sua esfera patrimonial e pessoal. A adaptação do surdo-mudo mediante aprendizagem do alfabeto e comunicação com outras pessoas o remete à prática de atos cíveis e negociais e até ao consequente levantamento da sua interdição.¹⁰²⁶

3.4.2 Ébrios habituais

O CC/2002, art. 1.767, inc. III, prevê “os ébrios habituais” dentre os sujeitos à curatela, ao lado dos viciados em tóxico e dos pródigos (art. 1.767, III e V), assim como daqueles que “por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade” (art. 1.767, I), como *relativamente incapazes* (CC/2002, art. 4.º inc. II, III e IV).

3.4.3 Viciados em tóxico

O CC/2002, art. 1.767, inc. III, prevê “os viciados em tóxico” dentre os sujeitos à curatela, ao lado dos ébrios habituais e dos pródigos, assim como daqueles que “por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, como *relativamente incapazes* (art. 4.º inc. II).

3.4.4 Pródigos

O CC/2002, art. 1.767, inc. V, prevê “os pródigos” dentre os sujeitos à curatela, ao lado dos viciados em tóxico e dos ébrios habituais, assim como daqueles que “por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, como *relativamente incapazes* (art. 4.º inc. IV). Pródigo é a pessoa que não possui moderação em suas despesas, que se mostram necessariamente superiores à sua renda. A prodigalidade leva à dissipação do patrimônio do portador de tal distúrbio psíquico. Para muitos, a prodigalidade era vista como início da loucura, sendo considerada pela psiquiatria como síndrome degenerativa. A curatela ao prodigo não opera da mesma forma que em relação aos demais legitimados, cabendo ao curador, nesta hipótese, atuar somente nos atos de disposição de patrimônio do interditado, não se estendendo a tutela aos atos civis, privando-se o interditado tão somente “de, sem curador, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração” (CC/2002, art. 1.782).

Vale destacar que o Ministério Público não é parte legítima imediata para a interposição de pedido de interdição do prodigo.¹⁰²⁷

No caso do prodigo, os deveres do curador, em “buscar tratamento e apoio apropriados à conquista da autonomia” do interditado (art. 758), devem se concentrar no desenvolvimento ou recuperação de habilidades concernentes à preservação de seu patrimônio e rendas, de modo a evitar o seu endividamento excessivo ou desproporcional, ao uso consciente do crédito, entre outras.

3.5 Competência

Trata-se de aspecto que o CPC/2015 continuou sem regular de forma explícita, a despeito de críticas anteriores, desde o CPC/1939 e do CPC/1973, acreditando-se que a competência no tocante ao tema, não tenha sofrido alterações. Em função disso, adere-se ao entendimento, de José Olympio de Castro Filho, de que o foro do interditando é o competente para o ajuizamento do procedimento de interdição.¹⁰²⁸ . Isso porque os procedimentos de natureza pessoal são promovidos, em regra, no domicílio do réu, neste caso, entendida como parte passiva do procedimento. Tal previsão legal, outrora se consubstanciava no art. 94 do CPC/1973, ao passo que no CPC/2015, o mesmo se estabelece no art. 46.

Vale destacar que Alcides de Mendonça Lima e João Paulo Lucena¹⁰²⁹ também compartilham do entendimento de que o foro competente para esse procedimento é o do domicílio do interditando, em harmonia também com o entendimento de Pontes de Miranda.¹⁰³⁰

Art. 748 . O Ministério Público só promoverá interdição em caso de doença mental grave:

I – se as pessoas designadas nos incisos I, II e III do art. 747 não existirem ou não promoverem a interdição;

II – se, existindo, forem incapazes as pessoas mencionadas nos incisos I e II do art. 747.

1. Inovações do CPC/2015

Há alterações nos dispositivos do art. 748 e incisos. O artigo sedimenta a redução do espectro de atuação do Ministério Público no âmbito do procedimento de interdição, determinando as hipóteses subsidiárias em que o membro da instituição deve promover a ação, integrando de forma sistemática as novas disposições legais do CPC/2015. Disposições semelhantes, mas com poderes mais amplos, já existiam no CPC/1973, tendo sofrido sutis alterações em seu teor.

O termo genérico “anomalia psíquica” foi substituído pela expressão “doença mental grave”, substituição que se mostra pertinente, já que não necessariamente a anomalia indica a incidência de uma condição negativa ao seu portador.

No inc. I deste artigo do CPC/2015 se promove uma ordenação lógico-sistemática ao demonstrar que a intervenção do Ministério Público seja também subsidiária, ou seja, somente diante da inexistência dos legitimados no art. 747, ou de sua inércia.

No inc. II, a previsão expressa relativa à condição de menor autor ou interessado no procedimento foi substituída, deixando-se apenas a condição jurídica de incapacidade como marco hipotético essencial à substituição processual realizada pelo Ministério Público. Em realidade, a redação mais restritiva do inciso mantém a mesma abrangência, vez que os menores são também absolutamente incapazes (CC/2002, art. 3.º).

2. Aspectos materiais

Como dito, a atividade do Ministério Público, no modelo brasileiro atual, tem mais amplitude que as demais instituições e órgãos legitimados. A ele é atribuído o exercício de Função Essencial à Justiça pela Constituição de 1988 (arts. 127 e ss.), com destaque entre suas funções para a incumbência da “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”. A LC 75/1993, reprisa esta mesma incumbência geral (art. 1.º), assim como o CPC/2015 (art. 176), especialmente para a defesa do interesse do incapaz (art. 178, inc. II).

A substituição do termo amplo “anomalia psíquica” reveladora de preconceito ou condição negativa do interditando pela expressão “doença mental grave”, indica um claro aperfeiçoamento da linguagem processual à terminologia médica, mas sem adotar a terminologia que indica tais doenças como ‘transtornos’. Doença mental grave consiste em termo que remete somente a algumas das hipóteses em que se enquadram os legitimados passivos, e não à maioria ou a todas. Há casos de transtornos mentais moderados e leves. Restringe-se assim a atuação do Ministério Público aos casos considerados graves ou de atuação subsidiária. O CPC/2015 não menciona as hipóteses de transtornos mentais profundos, estágio mais intenso que os graves, identificável em certas espécies, mas que por evidente conclusão lógica, também para estes o Ministério Público estará ativamente legitimado.

A avaliação da intensidade dos transtornos é classificada por normas médicas internacionais tais como CID-9-MC e CID-10-MC, assim como o *Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais* ou

DSM-5, da Associação Psiquiátrica Americana (APA), que descreve os inúmeros transtornos que, ¹⁰³¹ em geral, podem ser classificados em escala leve, moderada e grave.

3. Aspectos processuais e procedimentais

Neste item serão abordados a legitimidade ativa *concorrente e subsidiária* para a interdição, a legitimidade subsidiária do Ministério Público, a *inexistência ou inércia* de cônjuge e a legitimidade do companheiro, pai, mãe, irmãos, tutores ou mesmo do representante da entidade de abrigo, a *incapacidade* de cônjuge, companheiro, pai, mãe, irmãos e tutores e as consequências, bem como a preservação da competência com a presença do Ministério Público, além de outros detalhes procedimentais relativos à petição inicial, documentos essenciais e meios de prova.

3.1 Legitimidade ativa concorrente e subsidiária para a interdição

Num primeiro momento, e para certos sujeitos, a legitimidade ativa é concorrente e disjuntiva, ou seja, qualquer um pode agir, independente da participação ou de litisconsórcio com outro. Não, contudo, para o Ministério Público que somente pode promover a interdição mediante concorrência das seguintes condições: a) a causa da interdição deve ser uma doença mental grave; b) a inexistência ou inércia dos demais legitimados ativos ou, b1) existindo os legitimados ativos (cônjuge ou companheiro; parente ou tutor) sejam estes incapazes. O que será objeto de apreciação nos tópicos seguintes.

3.2 Legitimidade subsidiária do Ministério Público

A propositura do procedimento de interdição pelo Ministério Público é subsidiária à dos legitimados constantes do dispositivo anterior, atualmente o art. 747, e somente cabível quando o interditando esteja acometido de doença mental *grave*. No CPC/2015, a atuação do Ministério Público como substituto processual só se concretiza na hipótese de os legitimados do dispositivo anterior *não existirem* ou quedarem *inertes* na promoção dos interesses do deficiente mental *grave*, ainda que este se enquadre nessa condição de forma provisória.

Vale apontar que o surdo-mudo, por não manifestar necessariamente uma doença mental, acaba por não consistir em parte passiva legítima para o procedimento de interdição promovido pelo Ministério Público, seja de forma autônoma, seja concorrentemente.

Essencial discernir que, a despeito do Ministério Público constar no rol de partes legítimas para a propositura do procedimento de interdição no art. 747, que substituiu o prévio dispositivo 1.147 do CPC/1973, a sua atuação como substituto processual somente se concretiza nas hipóteses elencadas no dispositivo constante do art. 748. Isso ocorre porque o art. 747 estabelece a atuação do *Ministério Público* como premissa geral, dado que a defesa de interesses sociais e individuais indisponíveis são funções inerentes à sua atuação (CF, art. 127, *caput*), ¹⁰³² e delimita, logo em seguida, o âmbito dessa atuação à subsidiária intervenção no caso de inércia ou incapacidade dos demais legitimados ativos. Trata-se de especialidade que prevalece sobre a generalidade criada em dispositivo anterior.

Em função disso, não há que se confundir no tocante à atuação do Ministério Público: além do exercício da função da fiscal da correta aplicação da lei, transcrito nos dispositivos já apontados a sua atuação como substituto se restringe à legitimidade ativa subsidiária.

3.2.1 Inexistência ou inércia de cônjuge, companheiro, pai, mãe, irmãos, tutores ou representante de entidade de abrigo

O inc. I do art. 748 do CPC/2015 prevê, justamente, que a ausência de manifestação *ou inércia* dos legitimados ativos possibilita a intervenção o Ministério Público na figura subsidiária de substituto processual. Caso um dos legitimados constantes do art. 747 simplesmente não exista mais, ou nunca tenha chegado a existir, a exemplo dos tutores e dos representantes de entidades de abrigo, que porventura se responsabilizariam pelo deficiente, o Ministério Público se mostra como legitimado principal para pleitear a interdição na forma de *substituto processual*.

Nos casos de transtornos mentais leves e moderados, mesmo na hipótese de inexistência ou inércia dos demais legitimados, não pode o Ministério Público atuar diretamente, pois subsidiária a sua intervenção.

3.2.2 Incapacidade de cônjuge, companheiro, pai, mãe, irmãos e tutores

O inc. II do art. 748 do CPC/2015 ingressou no ordenamento jurídico com o intuito de completar o teor do inciso anterior. O inc. I prevê a inércia dos legitimados ativos do art. 747 ou a inexistência dos mesmos. A hipótese desses legitimados existirem e serem incapazes é concretizada neste inciso, dando a entender que a inércia dos legitimados não seria necessária para a promoção de pedido por parte do Ministério Público. Caso os legitimados se mostrem provisoriamente ou definitivamente incapazes de resguardar os interesses do deficiente, a inércia, com um indesejável transcorrer do tempo, não seria requisito essencial para a propositura da interdição pelo Ministério Público.

Obviamente, para que a inércia não constitua requisito processual essencial para a propositura do pedido de interdição, o Ministério Público deverá fundamentar o seu pedido neste dispositivo, demonstrando documentalmente que os legitimados ativos do art. 747 efetivamente são incapazes. Da mesma forma, casos de transtornos mentais leves e moderados, ainda que ocorra incapacidade dos possíveis legitimados ativos, não autoriza o Ministério Público atuar diretamente, pois subsidiária a sua intervenção. Em sendo *grave* o transtorno do interditando, pode e deve o Ministério Público atuar, observadas as condicionantes já referidas.

3.3 Preservação da competência com a presença do Ministério Público

O fato de o Ministério Público intervir no procedimento de interdição, na condição de substituto processual, não repercute no foro competente para o conhecimento dessa demanda, que continua sendo o do interditando, nos moldes do art. 46 do CPC/2015.

3.4 Petição inicial e documentos essenciais

Sendo documento essencial a prova do parentesco ou da relação que concede a legitimidade para a proposição da interdição, deverá o juiz aferi-la de imediato. Infere-se que a especificação em parágrafo apartado dessa documentação torna-a indispensável para a prossecução deste procedimento, nos termos dos arts. 319 e 320 do CPC/2015.

Pelo que se vislumbra, nada impede que esse vício, por sua vez, seja sanado por intermédio de juntada posterior da documentação a título de emenda à petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC/2015.

Art. 749. Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou.

Parágrafo único. Justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos.

1. Inovações do CPC/2015

Nota-se que as alterações textuais deste dispositivo não foram mínimas. O termo “assinalará” deixou, corretamente, de ser utilizado, pois não existe a possibilidade de se definir em momento inicial do procedimento a incapacidade do interditando para reger a sua pessoa ou para administrar os seus bens mediante mera juntada documental da parte ativa. Criticava-se tal termo no CPC/1973, já que, na maior parte das vezes, esse tipo de condição se averiguaria com mais rigor e assertividade na realização de perícia médica eventualmente deferida pelo juiz. Alcides de Mendonça Lima também se posicionou da mesma forma, declarando ser possível assinalar a incapacidade da parte somente após a produção da prova pericial determinada pelo próprio juízo.

O termo “anomalia psíquica” também foi suprimido corretamente do texto do art. 749, pois, em realidade, o surdo-mudo sujeito ao processo de interdição não se enquadrava nesse conceito, já que padece somente de anomalia física que inibe tão somente a articulação da palavra e a audição, mas não necessariamente importa em déficit psíquico. ¹⁰³³

Dessa forma, o texto do novo dispositivo constante do art. 749 lhe deu maior tecnicidade ao suprimir os termos outrora constantes no CPC/1973.

Houve também alteração na ordem das espécies de incapacidade a serem declaradas. Anteriormente, dispunha-se que a incapacidade do interditando para reger a sua pessoa viria, textualmente, antes da incapacidade para administrar os bens. Com a alteração, tem-se a incapacidade de administrar os bens

como hipótese prévia à incapacidade para a prática de atos da vida civil, construção que se mostra mais coerente com a realidade.

O parágrafo único foi acrescentado no dispositivo constante do art. 749 a fim de ressaltar o cabimento da nomeação de curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos antes mesmo da prova pericial ou da prossecução do procedimento de interdição, caso se justifique a urgência, a fim de serem acautelados os riscos ao resultado útil do processo.

Evita-se o uso da interdição como meio de concretização de desígnios torpes ou criminosos, motivo pelo qual a tutela máxima é adotada em momento prévio à prolação da sentença.

Os novos entendimentos do CPC/2015 relativos à tutela provisória, que por sua vez abarca a tutela de urgência, acabam sendo aplicáveis a esse procedimento processual, dada a utilização do termo urgência.

2. Aspectos materiais

A incapacidade para a prática de atos civis descrita pelo novo dispositivo remete de forma sistemática ao sistema harmônico constituído tanto pelo CC/2002 quanto pelo CPC/2015.

Este dispositivo não inova materialmente, apenas faz alusão aos legitimados passivos que, por intermédio de laudos médicos e da instrução processual, podem ser revelados como estando acometidos por deficiências físicas ou provisórias que incapacitam a administração dos seus bens ou a prática de atos civis.

3. Aspectos processuais e procedimentais

Dois pontos serão aqui tratados: a instrução da petição inicial da ação de interdição com os fatos que possam sugerir a necessidade de interdição e a incidência da tutela provisória de urgência.

3.1 As provas que acompanham a petição inicial da ação de interdição

Este dispositivo explana de que forma e em qual momento o proponente, constante do rol do art. 747, irá comprovar e demonstrar os fatos que embasarão o pedido de interdição. A petição inicial seguirá os moldes determinados pelos arts. 319 ao 321 do CPC/2015 e se harmonizará com o disposto no parágrafo único do art. 747 ainda da Lei 13.105/2015.

Com essa alteração e consequente harmonização com o art. 747, o foco exclusivo passa a ser a instrução dos fatos e documentos que lastrearão o pedido feito.

Outro aspecto que merece consideração consiste em que a descrição dos fatos que possam sugerir a necessidade da interdição funcionarão como uma espécie de *termo legal* a partir do qual a sentença, a despeito de constitutiva, ou seja, de produzir efeitos *ex nunc*, poderá alcançar atos pretéritos a ponto de poder gerar a anulação de atos outrora praticados pelo interditando quando este já não mais gozava da plena capacidade civil. Porém, entende o STJ ¹⁰³⁴ que a anulação dos atos pretéritos demanda ajuizamento de ação autonomia, não sendo efeito automático da sentença que decreta a interdição.

3.2 A incidência da tutela provisória de urgência

O termo *urgência* utilizado neste parágrafo único inevitavelmente remete ao art. 294 e ss. do CPC/2015. O que se depreende é que os requisitos previstos no próprio art. 300, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo, se mostram cabíveis no presente caso.

Presume-se que essa tutela de urgência, uma vez constante do próprio procedimento de interdição, não possuirá natureza cautelar, mas sim antecipada e na forma incidental, dado que paralela à promoção do pedido inicial. A despeito disso, não resta excluída a incidência de uma medida provisória de urgência cautelar e na forma antecedente, ou seja, prévia ao procedimento processual de interdição.

Embora a tutela de urgência consista numa das espécies inerentes ao gênero da tutela provisória, não se refuta a possível incidência também da tutela de evidência. Nos termos do art. 311 do CPC/2015, a tutela de evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I) ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II) as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas

documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em Súmula Vinculante; III) se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV) a petição inicial foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Obviamente, algumas das hipóteses suscitadas na tutela provisória de evidência não são adequadas ao procedimento de interdição, tais quais os incs. I e III denotam. No entanto, as demais previsões se mostram aplicáveis à interdição, não se refutando o seu cabimento nesse procedimento.

Nessa linha, o efeito da concessão da tutela provisória, tanto de urgência quanto de evidência, resultará na nomeação de curador provisório ao interditando de forma anterior à prossecução do procedimento de interdição.

3.3 A nomeação do curador provisório

José Rubens Costa atualizando a obra de José Olympio de Castro Filho já sugeria, com base em ampla jurisprudência, a inclusão da possibilidade de nomeação do curador provisório, ainda que com base no “poder geral voluntário do juiz” que lhe permitiria determinar medidas urgentes diante de riscos processuais e materiais.¹⁰³⁵

Diante da previsão normativa específica, mais segura a decisão judicial. Justificada, portanto, a urgência, segundo os requisitos acima, pelas razões que foram demonstradas pelos interessados ou que pelas próprias diligências do juiz foram obtidas, pode este nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos.

Reputa-se urgente a nomeação quanto o retardamento e a espera pela nomeação do curador definitivo possa causar prejuízo ao interditando, seja para seu acompanhamento de saúde, seja para a realização de atos da vida social.

Art. 750 . O requerente deverá juntar laudo médico para fazer prova de suas alegações ou informar a impossibilidade de fazê-lo.

1. Inovações do CPC/2015

Trata-se de medida que reduz o tempo de tramitação do procedimento de interdição, tornando compulsória a prévia colação de laudo médico já por ocasião da propositura da demanda, desde que possível, que, em realidade, será indubitavelmente necessário à instrução do procedimento de interdição.

2. Aspectos materiais

A dimensão material do procedimento de interdição não teve aprofundamento neste dispositivo, a norma possui teor e aplicação eminentemente processual.

3. Aspectos processuais e procedimentais

Este dispositivo regula, ainda, a instrução documental da petição inicial na qual se promove o pedido de interdição, ressaltando a importância, independentemente da produção de prova pericial posterior ao procedimento de interdição, de juntar como documento inicial o laudo médico que embasa as alegações de incapacidade do interditando de administrar seus bens ou de realizar atos civis válidos.

Caso não seja possível colacionar à peça inicial o laudo médico, deve-se informar a impossibilidade de o fazê-lo, logicamente com o fundamento cabível para tal impossibilidade.

Pode-se depreender que, em função da própria relevância que o laudo médico possui, que chegou a ser destacada em dispositivo único e apartado, a não juntada desse documento em específico acarreta indeferimento da peça inicial, caso não justificada a impossibilidade, dada a sua natureza indispensável para a propositura da ação, conforme dispõe o art. 320 do CPC/2015.

3.1 Oportunidade de juntada, a forma e a interpretação da regra

Inova a regra ao impor um ônus “condicionado” ao interessado que propõe a interdição de juntar

laudo médico para fazer prova de suas alegações ou informar a impossibilidade, que deve ser cumprida com a petição inicial.

O laudo ou laudos são documentos médicos revestidos de componentes técnico-científicos e devem seguir na sua forma as regras específicas dos Conselhos Profissionais respectivos de cada profissão ou, ainda, se exclusivamente médicos, das Sociedades Médicas especiais que regulam a matéria. Os laudos correspondem aos exames clínicos feitos diretamente pelo médico ou a outros exames científicos dos quais analisa os resultados.

Deve conter, no mínimo, CID ou equivalente internacional, nome do transtorno ou da patologia, informações detalhadas sobre o transtorno ou patologia, possibilidade de reversão, cura, atenuação dos sintomas ou não, comorbidades e se o interditando tem ou não condições de reger, por si só, os atos da vida civil. Exige-se que o laudo médico seja conclusivo.

3.2 O não atendimento ao ônus, emenda ou dispensa

É possível que o requerente não junte, por razões que devem ser justificadas, sejam econômicas, técnicas ou mesmo decorrentes da própria razão que justifica a interdição, criando um paradoxo com a exigência.

Pela sistemática atual, no procedimento comum, se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos gerais e documentais (arts. 319-320) ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito (art. 321), pode determinar ao autor que a emende ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias. Cabe ao juiz, a partir do CPC/2015, indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado (art. 321, 2.^a parte).

É possível que o juiz dispense a juntada, acolhendo a justificativa da impossibilidade, e determine que o laudo seja produzido de ofício ou mesmo a requerimento de outro cointeressado, se houver.

Se o interessado devia juntar o laudo e não justificou a sua ausência, cabe ao juiz abrir nova oportunidade e o indeferimento só ocorrerá se o autor não cumprir a diligência, emendando, corrigindo ou complementando as informações necessárias (art. 321, parágrafo único), decisão de extinção sem exame de mérito, recorrível por apelação.

Art. 751 . O interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidas a termo as perguntas e respostas.

§ 1.º Não podendo o interditando deslocar-se, o juiz o ouvirá no local onde estiver.

§ 2.º A entrevista poderá ser acompanhada por especialista.

§ 3.º Durante a entrevista, é assegurado o emprego de recursos tecnológicos capazes de permitir ou de auxiliar o interditando a expressar suas vontades e preferências e a responder às perguntas formuladas.

§ 4.º A critério do juiz, poderá ser requisitada a oitiva de parentes e de pessoas próximas.

1. Inovações do CPC/2015

A entrevista como ato em substituição ao exame judicial é a grande inovação terminológica e material, porquanto a unilateralidade que se poderia identificar, ao ser examinado, se atenua com a dialogicidade presumida na ‘entrevista’. Estendem-se ainda mais os poderes do juiz para planos circunscritos a questões pessoais e até íntimas, tal como laços familiares e afetivos, com o intuito de permitir a cognição mais ampla e aprofundada, com o fito de alcançar a decisão mais adequada. Na mesma linha de ampliação da cognição do juiz, é a introdução expressa de possibilidade de oitiva de parentes e de pessoas próximas, sejam aquelas ligadas por laços de amizade e afeto, como aquelas ligadas por vínculos profissionais, a exemplo dos profissionais de saúde ou mesmo dos cuidadores. ¹⁰³⁶

Traz-se para o procedimento a possibilidade de aproveitamento de novas tecnologias, tais como os equipamentos eletrônicos que permitem a comunicação ou a manifestação de vontade.

2. Aspectos materiais

Os avanços tecnológicos que foram conquistados no período entre o CPC/1973 e o CPC/2015 foram incorporados à análise da capacidade do interditando, que poderão explicitar de forma mais contundente qual é o grau de sua incapacidade. De acordo com o grau dessa incapacidade, o deficiente poderá ter os efeitos de sua interdição modulados na sentença a ser prolatada, sendo ainda capaz de administrar determinados bens de sua propriedade, ou tomar decisões de natureza civil que ainda lhe seriam inerentes.

3. Aspectos processuais e procedimentais

3.1 A necessária citação do interditando

Discutia-se nos regimes processuais do CPC/1939, tendo-se corrigido no CPC/1973, a necessidade de citação do interditando. ¹⁰³⁷

A citação é necessariamente feita para o *comparecimento perante o juízo* para a realização de entrevista, termo que já nesta oportunidade substituiu a ideia de uma audiência de interrogação do interditando.

Percebe-se que, ao se analisar o *caput* do novo dispositivo ora em exame, foram acrescentados alguns elementos a serem suscitados na entrevista a ser realizada com o interditando. No Código de 1973, a interrogação a ser protagonizada pelo juiz responsável pelo procedimento necessariamente conteria perguntas sobre a vida, os negócios e os bens do interditando. À exceção destes temas, as perguntas remanescentes seriam elaboradas à critério do magistrado.

No CPC/2015, as perguntas do juiz voltadas às preferências, laços familiares e afetivos do interditando foram acrescentadas a esse rol exemplificativo de interrogações a serem promovidas.

Embora tenha havido alteração textual no que é pertinente à *redução a termo acerca das perguntas e respostas* da entrevista, conforme disposição do novo CPC, entende-se que o teor desse ônus não se alterou na transição de Códigos.

Uma alteração que se mostra correta e que foi efetivamente promovida no novo CPC consiste na reforma da expressão “para ajuizar do seu estado mental”, que passou a ser representada pela expressão: “convencimento quanta à sua capacidade para o exercício da vida civil”. Nada mais correto, dado que para ajuizar o estado mental de um interditando, o juiz teria de se utilizar de conhecimentos científicos da medicina, medida esta que não se almeja neste procedimento e não se mostra, inclusive, alcançável ou possível. O estado de saúde do interditando será demonstrado e declarado por laudo médico, documento emitido por médico habilitado, enquanto o juiz promoverá uma análise essencialmente jurídica, que terá em conta a capacidade civil do interditando para a prática de atos da vida civil.

Os parágrafos 1.º a 4.º foram acrescentados a este dispositivo com o intuito de especificar de que maneira deverá ser realizada a entrevista pelo juiz. Os acréscimos tiveram o cuidado de demarcar e aplicar os avanços tecnológicos contemporâneos que efetivamente incrementarão o procedimento da entrevista.

3.1.1 As excludentes de citação

O CPC/2015 endossou do Código de 1973 as hipóteses nas quais a citação não seria realizada. Outrora constante do art. 217, o agora art. 244 dispõe que não se fará a citação, salvo para evitar o perecimento do direito, nos presentes casos: I) a quem estiver assistindo a qualquer ato de culto religioso; II) ao cônjuge ou a qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta, ou na linha colateral em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 (sete) dias seguintes; III) aos noivos, nos 3 (três) primeiros dias de bodas; e IV) aos doentes, enquanto grave o seu estado.

Entende-se que os casos acima descritos impedem a citação também do interditando, ainda que a citação nesse procedimento não seja voltada à apresentação de defesa, mas sim ao comparecimento em entrevista a ser ministrada e conduzida pelo juiz competente para o conhecimento da causa.

Contudo, partindo do pressuposto de que a citação é ato essencial a qualquer processo na forma do art. 239 do CPC/2015, admitidas as exceções já apontadas, merecem consideração algumas questões acerca da situação do interditando por ocasião da sua citação.

A primeira diz respeito à comprovação *de plano* por parte do legitimado ativo quando do ajuizamento da demanda, por intermédio de laudo médico, de que o interditando é mentalmente incapaz (CPC/2015, art. 750 e art. 245, § 3.º), hipótese em que lhe deve ser nomeado curador especial na pessoa do Defensor Público (CPC/2015, art. 72).

A segunda questão cuida das hipóteses em que a interdição não resultou da perda absoluta de toda a capacidade civil do interditando, como ocorre, por exemplo, nos casos de prodigalidade, surdo-mudez, embriaguez habitual e vício em tóxico (CC, art. 1.767). Nestes casos a situação aparente do interditando deverá ser objeto de descrição minuciosa pelo oficial de justiça na certidão de citação (CPC/2015, arr. 245, § 1.º). Ocorrendo tais hipóteses nada impede que o interditando seja citado pessoalmente, porque tem capacidade para entender o ato de citação e de se determinar de acordo com este entendimento, uma vez que o eventual fato que acomete a sua capacidade plena não teria comprometido a sua autodeterminação para a prática de atos civis.

Destaca-se, ainda, que o interditando, a despeito de ter impugnado a sua capacidade e, portanto, a possibilidade de praticar ato civil válido, pode constituir validamente advogado para promover a sua defesa, conforme CPC/2015, art. 752, § 2.º, que a seguir será explorado, uma vez que, não sendo caso de comprovação da incapacidade total e de plano por laudo médico, os atos praticados pelo interditando são hígidos. Isto porque ainda não atestada a deficiência, bem como porque a sentença a ser eventualmente proferida tem caráter constitutivo, vale dizer, a princípio tem efeitos somente *ex nunc*, ou seja, dali em diante.

Revela-se, ainda, a possibilidade de a citação do procedimento de interdição objetivar justamente o perecimento do direito do interditando, retirando-o da função da administração dos seus bens que, em função de sua gestão temerária, correm o risco concreto de perecerem. Tal hipótese, que ocorreria ainda que as situações descritas se concretizassem, no entanto, não é a mais característica desse procedimento, e não é, certamente, a regra geral aplicável a esse caso.

3.2 A entrevista pessoal conduzida pelo juiz competente

A expressão “interrogatório”, constante do CPC/1973, foi substituída pela expressão “entrevista”, consentânea à nova dignidade dada ao interditando, especialmente após a Lei 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência ou Estatuto da Pessoa com Deficiência. A possibilidade de o juiz se deslocar até à localidade física do interditando já era utilizada na prática, embora o CPC/1973 não dispusesse de forma explícita nesse sentido. Prata já manifestou entendimento nessa linha, aduzindo que, na impossibilidade do interditando comparecer em juízo, o juiz poderá se dirigir ao local em que o interditando se encontra, seja essa de natureza residencial, hospitalar ou assistencial.¹⁰³⁸

Essa entrevista é essencial, como o era o antigo interrogatório,¹⁰³⁹ sob pena de nulidade. Além disso, a entrevista também poderá ser acompanhada da oitiva de testemunhas que o juiz considere úteis ou proveitosas ao andamento do interrogatório. A escrita do dispositivo dá a entender que tal oitiva poderá ser realizada de forma concomitante à entrevista, em uma espécie de reunião entre magistrado, técnicos, interditando e testemunhas que possam aferir com a máxima precisão possível qual o grau de incapacidade do deficiente.

3.3 A possibilidade da inspeção judicial

Embora já estivesse prevista dentre os meios probatórios e fosse utilizada nestes casos, a previsão expressa da possibilidade de o juiz deslocar-se até o local onde estiver o interditado para entrevistá-lo (art. 751, § 2.º) humaniza e confere maior atenção ao peculiar procedimento protetivo da interdição. Neste ponto o CPC/2015 se aproxima da Constituição Federal, na extensão da garantia à pessoa e do respeito às diferenças.

As regras próprias das inspeções judiciais (arts. 481 a 484) devem balizar a atuação do juiz, especialmente a possibilidade de fazer-se acompanhar por perito (art. 482) ou por outros profissionais; deixar-se acompanhar pelos demais interessados (art. 483, parágrafo único) e por seus assistentes técnicos, permitir a presença do membro do Ministério Público, sempre no intuito obter os esclarecimentos que permitam a decisão mais adequada.

Art. 752. Dentro do prazo de 15 (quinze) dias contado da entrevista, o interditando poderá impugnar o pedido.

§ 1.º O Ministério Público intervirá como fiscal da ordem jurídica.

§ 2.º O interditando poderá constituir advogado, e, caso não o faça, deverá ser nomeado curador especial.

§ 3.º Caso o interditando não constitua advogado, o seu cônjuge, companheiro ou qualquer parente sucessível poderá intervir como assistente.

1. Inovações do CPC/2015

O prazo para apresentação de impugnação por parte do interditando foi estendido de 5 (cinco) dias para 15 (quinze) dias no caput do art. 752.

Além disso, o § 1.º do art. 752 do CPC/2015 definiu de que forma o Ministério Público atuará no caso, qual seja, na condição de fiscal da aplicação da lei (*custos legis*), ao passo que o exercício da função do Ministério Público como representante processual do interditando foi excluído da redação no mesmo dispositivo.

No *caput* , o termo audiência de interrogação foi substituído pelo termo “entrevista”, alteração que se mostra mais harmônica com o procedimento efetivamente realizado.

Promoveu-se alteração também no sentido de tornar obrigatória a constituição de advogado que patrocine os interesses do interditando em juízo. Caso não seja possível constituir advogado, um curador especial será nomeado para a defesa dos interesses do interditando que, nos termos do art. 72, I do CPC/2015, será a Defensoria Pública.

Por fim, o § 3.º do dispositivo em análise determinou que, caso não seja possível ao interditando constituir advogado, necessariamente o cônjuge, o companheiro ou o parente sucessível poderá intervir como assistente. Vale destacar que a disposição relativa ao ônus decorrente dos honorários advocatícios devidos pelo interditado foi retirada do texto do CPC/2015.

2. Aspectos materiais

Novamente, os legitimados ativos: o cônjuge, o companheiro ou o parente acessível, capazes de propor o pedido de interdição, figuram como possíveis assistentes do interditando, que atuarão em cooperação com o curador especial na hipótese de não ser constituído advogado que defenda os interesses do deficiente.

Contudo, aqui é preciso atentar para o fato de que, não raras vezes e por diversos motivos, o cônjuge, o companheiro ou o parente sucessível do interditando, têm interesse em que seja promovida a sua interdição, razão pela qual não se revela possível sua atuação como assistente *do interditando* nesta hipótese uma vez evidenciado o conflito de interesses. Relembre-se que o assistente deve ter o seu interesse alinhado com o interesse do assistido, a teor do que dispõe o art. 119, *caput*, do CPC/2015.

O Ministério Público, regra geral, atua na condição de fiscal da aplicação da lei. Conforme já visto, a ausência de advogado do interditando não suscita o papel de representação por parte do Ministério Público em defesa do deficiente.

3. Aspectos processuais e procedimentais

Neste item serão abordadas a revelia e seus efeitos, a atividade do interditando, a possibilidade de reconvenção e contrapedido, a participação do Ministério Público e a possibilidade de recursos.

3.1 Da impossibilidade de revelia no procedimento de interdição

Importante ressaltar que, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, o não oferecimento de impugnação por parte do interditando não acarretará sua revelia. Neste sentido, manifesta-se João Paulo Lucena,¹⁰⁴⁰ ao passo em que aduz que, a despeito do prazo de impugnação ter corrido *in albis* , o interditando ainda poderá juntar sua defesa aos autos, sem prejuízo do exercício do direito de contraditório e sem os efeitos prejudiciais da revelia.

É que a interdição é ação de estado e, portanto, ainda que sem resposta do interditando, isto não resulta na admissão da veracidade e da consequência dos fatos afirmados pelo autor da demanda, por

força do que disposto no art. 345, II do CPC/2015.

3.2 Natureza e âmbito da impugnação oferecida pelo interditando

A impugnação oferecida pelo interditando possui natureza de peça contestatória, motivo pelo qual as regras aplicáveis a essa espécie se mostram manifestamente cabíveis, do modo como prevista no CPC/2015. Toma-se como referência para elaboração da impugnação os arts. 335 e ss. do CPC/2015.

Prata destaca que mais de uma resposta pode ser oferecida no procedimento de interdição. O Ministério Público, na condição de fiscal da aplicação da lei, o interditando e o advogado por ele constituído, ou até mesmo o curador provisório, poderão juntar aos autos as referidas respostas, sendo necessário ao juiz analisar uma por vez antes de prosseguir no procedimento. ¹⁰⁴¹

3.2.1 Reconvenção ou contrapedido e os objetivos delimitadores da interdição e da curatela

A doutrina em geral rejeitava a possibilidade de reconvenção na jurisdição voluntária ¹⁰⁴² admitindo-a, com rara exceção, em casos específicos. ¹⁰⁴³

Mas se se pode cogitar da legitimidade ativa do interditando para a proposição da autointerdição, do mesmo modo que para o pedido de levantamento da curatela (art. 756, § 1.º) e, de modo consentâneo, para todas as alterações trazidas pela Lei 13.146/2015, *Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência ou Estatuto da Pessoa com Deficiência*, pode-se também cogitar de que o processo civil e seus procedimentos especiais possam se adaptar aos sujeitos especiais a que são destinados.

De modo muito próprio, o CC/2002, após as alterações introduzidas pela Lei 13.146/2015, reduz a *incapacidade absoluta* apenas aos menores de 16 anos (art. 3.º, *caput*). Todos os demais sujeitos que, “por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, são considerados *relativamente incapazes*. Essa peculiar extensão da incapacidade relativa amplia a possibilidade de atuação direta desses interessados no processo, alarga o espectro da contenciosidade, distinguindo ainda mais o procedimento de interdição e justificando a admissão da reconvenção ou de contrapedido do interditando.

A peculiar posição da interdição para a imposição de curatela entre os procedimentos voluntários, em que pese a sua possível conflituosidade, permite pensar-se na reação do interditando ao pedido feito pelos demais legitimados, mas não se pode imaginar tão facilmente a reconvenção e a conversão da interdição numa tomada de decisão apoiada, observadas as diferenças procedimentais da TDA, que pressupõe um acordo ou negócio prévio entre apoiado e apoiadores. ¹⁰⁴⁴

3.2.2 Intervenção do Ministério Público

O papel do Ministério Público nesse procedimento processual, se limitará, regra geral, à fiscalização da aplicação da lei, com a óbvia exceção dos casos em que o *Ministério Público* esteja atuando como *substituto processual* do legitimado ativo.

A atuação do Ministério Público na condição de fiscal da aplicação da lei, ao que parece, não elide a possibilidade de oferecer impugnação ao pedido de interdição promovido pelo suposto legitimado ativo de forma paralela ao advogado e ao interditando envolvidos no procedimento.

Com essa disposição, harmonizada com o disposto nos arts. 747 e 748 do CPC/2015, resta muito mais evidente quais são os limites da atuação do Ministério Público. No art. 747, o legislador determinou que o Ministério Público, na condição de *substituto processual*, é parte legítima para a promoção do pedido de interdição do deficiente. No art. 748, por sua vez, restou delimitada a atuação do Ministério Público à intervenção subsidiária à inércia dos legitimados ativos do art. 747. Por fim, o art. 752 estabeleceu o papel de fiscal da aplicação lei como função geral do Ministério Público no procedimento de interdição, eliminando diversas controvérsias e dúvidas inerentes ao diploma processual anterior.

3.2.3 Interesse recursal dos legitimados ativos e do interditando

Todos os interessados, O Ministério Público e o interditando têm legitimidade recursal contra as decisões dadas neste procedimento. O recurso do interditando, ¹⁰⁴⁵ com as novas alterações, sejam materiais ou processuais, ganha também mais relevo, seja pela sua reconhecida legitimidade, seja porque as concepções sobre suas limitações foram reduzidas.

Art. 753 . Decorrido o prazo previsto no art. 752, o juiz determinará a produção de prova pericial para avaliação da capacidade do interditando para praticar atos da vida civil.

§ 1.º A perícia pode ser realizada por equipe composta por expertos com formação multidisciplinar.

§ 2.º O laudo pericial indicará especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá necessidade de curatela.

1. Inovações do CPC/2015

O *caput* do art. 753 não promoveu alterações substanciais em relação ao dispositivo do CPC/1973. O prazo ao qual seu texto se refere consiste no prazo que foi estendido no art. 752, aberto ao interditando para que possa promover impugnação ao pedido suscitado em petição inicial. Observa-se, no entanto, que a expressão “perito” foi substituída pela expressão “produção de prova pericial”.

Contudo, pode-se vislumbrar uma mudança notável na dispensa da designação de audiência de instrução e julgamento, que deixou de ser adotada neste procedimento de interdição do CPC/2015. Tal alteração será devidamente analisada e discutida.

O § 1.º foi acrescentado, determinando que a perícia pode ser realizada por uma equipe com formação *multidisciplinar*, ampliando a abrangência técnica da perícia a ser produzida no procedimento de interdição.

O § 2.º, a fim de fortalecer o fato de que a interdição não necessariamente é integral, determina que na própria produção da prova pericial, os atos para os quais haverá necessidade de curatela já restarão explicitados.

2. Aspectos materiais

O procedimento de interdição, no âmbito da produção de prova pericial, fortalece a premissa de que as provas produzidas em juízo e os laudos médicos, agora obrigatoriamente colacionados à inicial da interdição, determinarão da maneira mais específica possível o grau de incapacidade do interditando, a fim de que a modulação dos efeitos da sentença de interdição possa ser extensível a atos prévios que já poderiam se mostrar acometidos de vício subjetivo em sua confecção. Além disso, a especificação desse grau de incapacidade permitirá ao juiz determinar de forma precisa o papel do curador que for constituído em juízo, garantindo uma visão moderna do procedimento de interdição.

3. Aspectos processuais e procedimentais

Vale frisar que a supressão da audiência de instrução e julgamento do procedimento de interdição será analisada no dispositivo a seguir, ainda que a retirada textual da audiência tenha se dado neste artigo.

No mais, a composição da equipe da entrevista a ser protagonizada pelo magistrado, em consonância com o dispositivo anterior (art. 752), permite a incorporação de avanços tecnológicos e da expertise decorrente da especialização de profissionais cada vez mais capacitados para a avaliação do grau de incapacidade do interditando, ou até mesmo a declaração da ausência de incapacidade.

Mais uma vez a integração sistemática e harmônica dessa seção fortalece a especificação do grau de incapacidade do interditando, garantindo a ampla participação e incremento dos mais diversos profissionais e aparato tecnológicos.

3.1 As provas em geral

Como reiterado aqui, o objeto da prova são os atos e fatos relacionados ao direito posto em debate. Os poderes instrutórios do juiz, tradicionais na história processual brasileira,¹⁰⁴⁶ permitem-lhe “de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito” (art. 370), de forma mais acentuada na jurisdição voluntária, na qual se reconhece maior liberdade e menores limites, inclusive probatórios.¹⁰⁴⁷

Não há restrições probatórias ou cognitivas no procedimento de interdição, sendo admitidos todos os meios de prova não vedados ou não ilícitos. Tem muita importância as inspeções judiciais (arts. 481 a 484) e podem pela *imediatez* aos fatos da causa permitir uma cognição mais ajustada à natureza do

direito posto assim como qualificar a atuação do juiz. Assim também pode ter especial importância a prova testemunhal, colhendo as informações das pessoas que circundam o interditando.

3.2 A prova pericial e assistência técnica

Sob o aspecto funcional, a prova pericial tem a finalidade de levar ao processo e ao julgador a experiência técnica que ele não possui, para que seja aproveitada no modelo decisório judicial. Destina-se inicialmente ao juiz, mas em vista da comunidade dos seus elementos de convicção podem servir a qualquer interessado ou 'parte'. Contém a prova pericial os juízos técnicos especializados a respeito dos fatos em exame no processo e sobre os quais devem incidir as normas de direito.

Neste caso, a prova técnica tem especial peso em função da presença de fatos que só podem ser identificados, avaliados e confirmados por médicos e outros profissionais de áreas afins como a psicologia, a psiquiatria e a fonoaudiologia.

São aplicáveis as regras de direito probatório pericial (arts. 464 a 480).

Embora o CPC/2015 não mencione a presença de assistente técnico, a natureza controvertida do procedimento de interdição justifica a participação de assistente ou assistentes técnicos do interditando ou dos demais interessados.¹⁰⁴⁸

Art. 754 . Apresentado o laudo, produzidas as demais provas e ouvidos os interessados, o juiz proferirá sentença.

1. Inovações do CPC/2015

Houve, em comparação com o CPC/1973, acréscimo de dispositivo estritamente processual, cuja alteração de maior destaque é a dispensa da audiência de instrução e julgamento na hipótese de existência de provas, tanto documentais quanto periciais suficientes, conforme relatado no art. 753 do CPC/2015 já estudado.

2. Aspectos materiais

O art. 754 não inovou no aspecto material da interdição, tendo cunho eminentemente processual e, portanto, procedimental. Vale apenas observar que, com a dispensa da realização de audiência de instrução e julgamento em momento posterior à produção de prova pericial, efetivamente buscou-se primar pela celeridade do procedimento, alinhando-se ao disposto no art. 5.º, LXXVII, da Constituição Federal.

3. Aspectos processuais e procedimentais

Por intermédio da inovação deste dispositivo, pode-se vislumbrar que o procedimento de interdição no CPC/2015 incorporou a crítica voltada à realização de duas audiências no mesmo procedimento de interdição. Edson Prata encabeça essa crítica, aduzindo que a audiência de instrução e julgamento posterior à realização da entrevista seria inócua, e surge como entrave processual,¹⁰⁴⁹ já que a prova pericial e o laudo médico esgotariam por completo a necessidade de qualquer produção de prova em sede de audiência de instrução e julgamento. Em função disso, a realização dessa audiência já se mostrava dispensável, restando claro que o CPC/2015 endossou tal entendimento e dispensou a realização de audiência em etapa posterior à entrevista promovida pelo juiz e à produção da prova pericial em juízo.

Dessa forma, a inócua realização de duas audiências foi eliminada, sendo cabível ao juiz determinar, ou não, a interdição do suposto deficiente a partir dos dados adquiridos e acumulados na entrevista que conduziu, bem como das provas documentais consistentes em laudos médicos colacionadas obrigatoriamente aos autos desde o início do procedimento de interdição.

Vale ressaltar que João Paulo Lucena também compartilhou do entendimento de que a audiência de instrução e julgamento não era obrigatória no CPC/1973, caso o juiz já tivesse examinado pessoalmente o interditando.¹⁰⁵⁰ O que se promoveu no CPC/2015, foi somente a dispensa obrigatória da audiência posterior à realização da entrevista e à análise das impugnações eventualmente apresentadas, bem como dos laudos obrigatoriamente juntados pela parte ativa desse procedimento. Primou-se, dessa forma, pela celeridade do procedimento, que garante o zelo e a preservação, caso confirmada a incapacidade, dos

bens e dos atos pessoais civis do interditado.

Art. 755 . Na sentença que decretar a interdição, o juiz:

I – nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito;

II – considerará as características pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, vontades e preferências.

§ 1.º A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado.

§ 2.º Havendo, ao tempo da interdição, pessoa incapaz sob a guarda e a responsabilidade do interdito, o juiz atribuirá a curatela a quem melhor puder atender aos interesses do interdito e do incapaz.

§ 3.º A sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente.

1. Inovações do CPC/2015

Percebe-se que as inovações textuais, neste dispositivo, não foram mínimas. Nota-se primeiramente que os arts. 1.183 e 1.184 do CPC/1973 foram mesclados em um único dispositivo do CPC/2015, qual seja o art. 755. A notável preocupação do legislador, no tocante a este dispositivo, consiste na especificação do procedimento a ser adotado no momento da decretação da interdição, por ocasião da sentença, e nos passos seguintes.

Primeiramente, no *caput*, restou definido que o ato judicial que decreta a interdição é a sentença. Dessa forma, resta indubitável que a apelação é o recurso processual cabível na hipótese de decretação, ou não, da interdição. ¹⁰⁵¹

O inc. I deste dispositivo reproduz de forma parcial o teor do art. 1.183 do CPC/1973. No entanto, delimita que o próprio legitimado ativo para a propositura do pedido de interdição pode ser o curador nomeado em juízo, podendo também ser curador pessoa que o proponente do procedimento de interdição tenha indicado, ou qualquer outra pessoa, fundamentadamente escolhida pelo juiz competente. O § 1.º do inc. II transcreve que a escolha desse curador deve ser feita de acordo com as especificidades do caso, sendo obrigação do juiz ponderar que pessoa seria capaz de atender da melhor forma os interesses do interditado.

O inc. I ainda frisa que a interdição deve ser modulada de acordo com o grau de incapacidade do interditado, conforme as alterações do CPC/2015 insistem em reiterar.

O inc. II deste dispositivo integra a disposição do inc. I, que determina que a sentença necessariamente considerará as características pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, vontades e preferências. Tal teor reforça a necessidade de se promover, ao longo do procedimento de interdição, atos voltados à real análise e aferimento das capacidades do interditando e do grau de sua deficiência.

O § 2.º apresenta ao CPC/2015 a possibilidade de se estender ao incapaz que se encontre sob a guarda e a responsabilidade do interditado a curatela constituída em sede de sentença, conforme aduz o art. 757 do CPC/2015. Resta estabelecido já nesta oportunidade que o momento adequado para a nomeação de curador que vise tutelar, tanto o interdito quanto o incapaz que esteja sob sua autoridade, é a própria sentença e, em função disso, a ponderação e a análise do juiz se estenderá a esse ponto, também, nessa mesma oportunidade.

O § 3.º, por sua vez, reproduz parcialmente o disposto no art. 1.184 do CPC/1973, dispositivo que busca regular o procedimento de publicação da sentença de decretação de interdição. Observa-se que, em acréscimo à inscrição da sentença no registro de pessoas naturais, o legislador determinou a sua imediata publicação na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses,

na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente.

2. Aspectos materiais

Nem sempre é melhor para o interditando que seja nomeado curador, a pessoa que promove a ação de interdição. Isto porque, por vezes, o que promove a ação nutre pelo interditando algum grau de animosidade e não seria razoável que este legitimado ativo regesse os atos civis da vida do interditando, dentre esses, os atos de caráter patrimonial. O curador deve objetivar a autonomia, quando possível, do interdito (CPC/2015, art. 758). Isto pressupõe que deve haver um grau mínimo de afeto e de comprometimento entre as pessoas do interdito e seu curador, o que não se revela possível quando presente litigiosidade entre essas pessoas (CPC/2015, art. 755, I e § 1.º). Ao nomear o curador o juiz deve observar o princípio do melhor interesse do interditado. O STJ ¹⁰⁵² já decidiu que a ordem de nomeação do curador é taxativa, mas não preferencial. Assim, nem mesmo aquele que figure como antecedente na ordem de nomeação (CPC/2015, art. 747) pode ser a pessoa mais indicada para o exercício do encargo.

Seguindo a orientação do mesmo princípio, o juiz deve observar que existem graus de incapacidade. Deste modo, a limitação a ser imposta ao interdito e os poderes de intervenção do curador deverão ser calibrados. Esta a razão pela qual na interdição do pródigo, a limitação somente atingirá os atos que importem em “emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração” (CC/2002, art. 1.782).

3. Aspectos processuais e procedimentais

3.1 A natureza jurídica da sentença de decretação de interdição

Nenhuma disposição específica do CPC/2015 buscou regular ou especificar os limites e a natureza da sentença que decreta a interdição, motivo pelo qual se depreende que tal esclarecimento, de fato, não veio a acontecer.

Pontes de Miranda destaca, assim, diversos aspectos processuais aplicáveis à sentença em estudo. Primeiramente, que a eficácia *erga omnes* da sentença só se concretiza após sua inscrição no registro de pessoas naturais. Caso tal registro não seja promovido, a publicidade da sentença de interdição é garantida pela própria publicação desse ato judicial. Nesta linha, o art. 1.012, inc. VI do CPC/2015, determina que a sentença que decreta a interdição terá efeito imediato após a sua publicação.

Atualmente, com o aumento das vias que permitem a publicidade da sentença prolatada, o presente estudo opta por considerar que a eficácia *erga omnes* é alcançada a partir do momento em que a decretação da interdição é determinada e veiculada na rede mundial de computadores, ou pela própria inscrição da sentença no registro de pessoas físicas. O intuito do procedimento é resguardar os bens e atos civis atribuíveis ao interditado, depreendendo-se que a mínima exteriorização da decretação de interdição já deveria garantir o efeito *erga omnes*.

Caso qualquer uma das diligências de publicidade deste dispositivo sejam descumpridas, infere-se, ainda segundo Pontes de Miranda, que a eficácia da sentença não possui efeito *erga omnes*.

Quanto à natureza jurídica estrita da sentença de interdição, tem-se que essa possui natureza tanto *declaratória* quanto *constitutiva*, que por sua vez se alia de forma intrínseca ao efeito desconstitutivo. Segundo Pontes de Miranda: “O elemento declarativo é alto, porém não preponderante. O estado da pessoa é declarado e o que se constitui é a incapacidade. O argumento de que pode haver eficácia retroativa, o que importaria a classificação da ação como declarativa, não bastaria”. ¹⁰⁵³

De fato, a condição de deficiência física ou mental que acomete o interditado pode ter se configurado em momento prévio ao procedimento de interdição, motivo pelo qual a sentença efetivamente possui um viés declaratório. Porém, como brilhantemente ensinado por Pontes de Miranda, tal aspecto não é o preponderante desse procedimento: o que se destaca é a *constituição* do estado de interdito, com a necessária e consequente nomeação de curador que se preste a executar os atos da vida civil e administrar os bens do deficiente. Com isso, nulidades de negócios jurídicos podem ser declaradas com fundamento no *efeito retroativo*, *ex tunc*, da sentença de interdição, mas não somente por isso ela seria considerada tão somente declaratória. Ocorre, em realidade, uma desconstituição de um estado de capacidade civil plena do ora deficiente, e se promove a constituição de um estado de interditado, com

consequente exclusão da capacidade de promoção de seus atos. O que se tem, ao final dessa linha de raciocínio, é que o procedimento de interdição possui natureza eminentemente constitutiva. João Paulo Lucena também endossa tal entendimento, a despeito das correntes opostas. ¹⁰⁵⁴

O fundamento legal para a propositura do procedimento de interdição, como já demonstrado, é a defesa dos interesses do interditando fundada no Direito de Família. No entanto, da declaração de incapacidade retroativa do deficiente pode advir a anulação de negócios jurídicos celebrados quando o sujeito já se mostrava incapaz. Nesse espeque, a anulação dos negócios pode ser buscada pelos interessados mediante a apresentação da própria sentença de interdição em contexto diferenciado. Opta-se, assim, por afirmar que a *nulidade* do negócio jurídico somente acomete os atos posteriores à sentença de interdição, enquanto que a *anulabilidade* acomete os atos civis realizados anteriormente, assim como Edson Prata também entende. ¹⁰⁵⁵

3.2 Efeito da apelação interposta contra a sentença que decreta interdição

A despeito da apelação ser interponível em face da sentença judicial que decreta a interdição do deficiente, essencial frisar que esse recurso, necessariamente terá efeito apenas *devolutivo*. Tal impasse foi resolvido mediante o acréscimo do art. 1.012, inc. VI do CPC/2015, que determina que a sentença que decreta a interdição começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação e, em face disso, não seria passível de apelação com efeito suspensivo, mas apenas devolutivo. Tal dispositivo merece crítica, pois retira a clareza que o CPC/1973 dispunha ao determinar em seu art. 520 que a apelação só será recebida no efeito devolutivo quando interposta de sentença que contivesse os casos previstos nos seus incisos. Uma interpretação sistemática e histórica, no entanto, permite vislumbrar que o intuito do CPC/2015 é impedir a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença de interdição.

Nota-se que o Ministério Público, e o próprio interditado, são partes legítimas para a interposição do recurso de apelação face à sentença de interdição.

3.3 Incremento tecnológico nas plataformas de publicidade

A publicidade da interdição foi ampliada com o avanço tecnológico nos procedimentos judiciais e na sociedade. O ato publicado especificará o grau da incapacidade e os limites da interdição prolatada em juízo, e ainda será disponibilizado na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça. Concomitantemente, a interdição deve ser inscrita no registro de pessoas naturais, publicada na imprensa local e no órgão oficial do juízo, especificando ainda qual a limitação do interditado caso ainda possua capacidade para o exercício de determinados atos.

3.4 Registro de pessoa natural

Segundo Edson Prata, a sentença de interdição, no CPC/1973, em disposição que se manteve inalterada no CPC/2015, deveria ser inscrita no Registro Civil de Pessoas Naturais, cartório do 1.

Ofício ou de subdivisão judiciária da Comarca, com os seguintes dados: ¹⁰⁵⁶

a) Data do registro; b) Nome, prenome, idade, estado civil, profissão, naturalidade, domicílio e residência do interditado, data e cartório em que forem registrados o nascimento e o casamento, bem como o nome do cônjuge, se for o casado; c) Data da sentença, nome e vara do juiz que proferiu a sentença; d) Nome, profissão, estado civil, domicílio e residência do curador; e) Nome do requerente da interdição e causa desta; f) Limites da curadoria, quando parcial a interdição; g) Lugar onde está internado o interditado.

Art. 756. Levantar-se-á a curatela quando cessar a causa que a determinou.

§ 1.º O pedido de levantamento da curatela poderá ser feito pelo interditado, pelo curador ou pelo Ministério Público e será apensado aos autos da interdição.

§ 2.º O juiz nomeará perito ou equipe multidisciplinar para proceder ao exame do interditado e designará audiência de instrução e julgamento após a apresentação do laudo.

§ 3.º Acolhido o pedido, o juiz decretará o levantamento da interdição e determinará a publicação da

sentença, após o trânsito em julgado, na forma do art. 755, § 3.º, ou, não sendo possível, na imprensa local e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, seguindo-se a averbação no registro de pessoas naturais.

§ 4.º A interdição poderá ser levantada parcialmente quando demonstrada a capacidade do interdito para praticar alguns atos da vida civil.

1. Inovações do CPC/2015

No *caput* deste dispositivo, pode-se observar que o termo interdição foi substituído por curatela, alteração esta que não promove impactos significativos.

Acrescentou-se o Ministério Público ao rol dos legitimados para a promoção do pedido de levantamento da curatela no § 1.º deste dispositivo, fato que confirma o entendimento doutrinário de alguns autores que já se manifestavam de forma positiva sobre essa possibilidade.

2. Aspectos materiais

O dispositivo ora discutido mantém a disposição que possibilita o levantamento da curatela na hipótese da cessação da causa que determinou a interdição.

No § 4.º deste dispositivo, a possibilidade de levantamento parcial da interdição foi sedimentada, contanto que a capacidade para a prática de alguns atos da vida civil seja demonstrada pelo interdito. Depreende-se que a aferição dessa capacidade será medida a partir do próprio exame e do laudo médico produzido.

3. Aspectos processuais e procedimentais

Dentre os aspectos procedimentais estão a legitimidade para o levantamento, a competência, a prova, e a necessidade de novo laudo médico pericial e a independência entre um e outro procedimentos inicial e final.

3.1 Legitimidade ativa para o pedido de levantamento da curatela

No Código de 1973, vigorava dúvida quanto à possibilidade de o próprio interditado pleitear o levantamento da curatela. José Olympio de Castro Filho observou que tal legitimidade era matéria controversa, sendo que autores como Clóvis Beviláqua, Carvalho Mourão, Eduardo Espíndola e José Duarte negavam o pedido de levantamento da curatela pelo próprio interditado. ¹⁰⁵⁷

Com o advento do CC/2002, e com a disposição textual do presente dispositivo, a possibilidade do interditado pleitear o levantamento da própria curatela resta evidente e incontestável.

Além do interditado, todos os demais legitimados para a propositura da ação originária de interdição, quais sejam os parentes próximos, agora o próprio curador, cônjuges, companheiros e também o representante da entidade que abriga o interditado, podem propor o pedido de levantamento da curatela. O Ministério Público também o poderá fazer, o que será objeto de oportuna análise à parte deste presente tópico.

Pontes de Miranda confirma a legitimidade ativa para o levantamento da curatela das mesmas partes que se mostravam aptas a promover o procedimento originário de interdição, sendo que a legitimação dessas pessoas é independente da pretensão para promover a interdição: trata-se de pretensão ao processo inquisitivo. ¹⁰⁵⁸

3.2 Produção de prova pericial

A despeito da possibilidade de a curatela ser *levantada*, caso a condição do interditado melhore ou sofra alteração, essencial destacar que o § 2.º determina ser necessário a produção de prova pericial, seja por perito ou por equipe de especialistas aptos a trabalhar no caso.

José Olympio de Castro Filho já apontava para a necessidade de produção de prova pericial médica na hipótese de promoção de pedido de levantamento da curatela. Como se trataria, a princípio, de um novo procedimento, a produção de novas provas que venham a embasar a tomada de decisão do juiz se mostra tão necessária quanto a realização de audiência de instrução e julgamento em fase posterior à produção

da prova pericial.¹⁰⁵⁹

Seguir-se-á aqui o mesmo procedimento probatório inicial, para a decretação da interdição, com as mesmas inovações trazidas.

3.3 O levantamento da interdição como procedimento novo e autônomo

Embora não reste explicitado que o pedido de levantamento da curatela seja um procedimento processual autônomo, depreende-se das aplicações cabíveis que se trata de uma nova ação que corre em apartado ao procedimento original de interdição. Desse fato, nasce a necessidade de se promover novas provas periciais, nova audiência de instrução e julgamento e nova prolação de sentença, que será proferida mediante a análise das novas circunstâncias de fato e de direito nessa oportunidade suscitados.

O fato deste procedimento ser novo e poder contar com a promoção do pedido de levantamento por parte do próprio interditado, ao nosso ver, reitera que a interdição e seus consectários legais se enquadram de forma harmônica sobre o conceito de jurisdição voluntária. Isso porque no procedimento de levantamento de curatela, o próprio interditado pode figurar no polo ativo, possibilidade que supostamente o coloca como também parte passiva deste mesmo procedimento. Neste caso, cabe ainda menos espaço para a litigiosidade que pode se manifestar no procedimento inicial de interdição.

Eventualmente, os interessados podem se opor ao levantamento da curatela do interditado cabendo nesse espeque um espaço para litigiosidade. No entanto, o pressuposto fundamental da manifestação dos interessados é a busca do melhor tratamento para o interditado, e não necessariamente a manutenção da curatela para fruição de proveitos próprios e indevidos. Assim, embora o intuito e pressuposto geral seja de auxílio ao interditado, o procedimento abre espaço à invocação de motivos e fundamentos torpes por ocasião do levantamento da interdição por parte de um interessado.

Inclusive, Alcides de Mendonça Lima destaca,¹⁰⁶⁰ em concordância com Pontes de Miranda,¹⁰⁶¹ que o fundamento da ação de levantamento de curatela pode ser a própria inexistência de motivo de interdição, sendo esta possibilidade ponto firme na doutrina. A eficácia não seria, porém, retroativa (*ex tunc*), no tocante à constitutividade negativa *erga omnes*.

3.4 Do procedimento de levantamento de curatela

O procedimento processual de levantamento da curatela, em si mesmo, não sofreu alterações substanciais, motivo pelo qual o que era anteriormente aplicado continuará sendo neste novo Código.

Alcides de Mendonça Lima aduzia que este procedimento é quase idêntico ao de interdição, divergindo somente nas adaptações. Em um primeiro momento, após a protocolo do pedido de levantamento da curatela, o ato imediato do juízo será a nomeação de perito ou equipe multidisciplinar cujo objetivo é a análise do estado do interditado, a fim de que se averigue se a causa da interdição chegou a existir e, acaso tenha, se já cessou os seus efeitos, ainda que parcialmente.

Vale ressaltar que, segundo Alcides de Mendonça Lima,¹⁰⁶² a nomeação do perito sempre enseja a indicação de assistentes técnicos em nome dos interessados. A partir dessa nomeação, os quesitos são elaborados e respondidos como em qualquer procedimento de perícia.

Curioso notar que neste dispositivo não restou ressaltada a possibilidade de se promover uma entrevista tal qual se promove no procedimento inicial de interdição. Neste procedimento de jurisdição voluntária, vislumbra-se o uso do termo “audiência”, e não “entrevista”. Em função disso, a natureza desse procedimento permanece controverso ou incerto, já que no procedimento originário, o juiz poderia promover interrogatório em sede de entrevista e dispensar a realização da audiência de instrução e julgamento. Ainda segundo Alcides de Mendonça Lima,¹⁰⁶³ a presença do juiz consiste em elemento de conveniência, não sendo esse magistrado, portanto, obrigado a promover pessoalmente o interrogatório na residência do interditado. Essa dispensa de entrevista, por sua vez, não seria aconselhável, já que poderia prejudicar a devida apreciação pelo juiz da situação atual do interditado.

Prata, por sua vez, considera que o exame pessoal do juiz é imprescindível para a prossecução do procedimento, já que a ausência desse exame pessoal acarretaria nulidade absoluta do processo.¹⁰⁶⁴

A nosso ver, como o dispositivo do CPC/2015 não reduz a termo em seu texto o *exame pessoal* por parte do juiz como requisito indispensável para a prossecução do procedimento, a ausência desse

mentionado *exame* prévio não necessariamente acarretaria nulidade absoluta do procedimento, até mesmo porque a presença do juiz na audiência de instrução e julgamento é imprescindível.

A despeito da não obrigatoriedade do *exame* pessoal do interditado por parte do magistrado, o aconselhável é que tal *interrogatório pessoal* efetivamente aconteça, pois colaborará para a formação da convicção pessoal do juízo. Além disso, a realização do *interrogatório pessoal* em ato prévio à audiência de instrução e julgamento pode se revelar suficiente meio para o juiz proferir sentença, assim como se dá no procedimento originário de interdição. Caso tal posicionamento seja adotado, a própria noção de paralelismo processual e lógica sistemática resta fortalecida no instituto da interdição.

3.5 Competência do juízo para o julgamento do pedido de levantamento da curatela

Pelo fato do procedimento de levantamento da curatela constituir procedimento novo e que deve ser autuado em apenso ao procedimento originário de interdição, concebe-se que o foro competente para o julgamento da interdição será também competente para o julgamento do levantamento. Trata-se, segundo Pontes de Miranda, da incidência da regra de *competência por conexão*, situação que afastaria qualquer ligação ao domicílio presente do curatelado, ou de qualquer mudança de circunstância determinante de competência.

Alcides de Mendonça Lima assertivamente destaca que a competência por conexão em relação ao procedimento originário de interdição não deve consistir em competência absoluta e, em função disso, inalterável. Isso porque essa espécie de fixação de competência pode causar dificuldade ou transtorno ao interditado que, efetivamente, pode ter se afastado do foro no qual o procedimento originário tramitou justamente em busca de tratamento para a deficiência que deu causa à sua interdição. A residência ou domicílio do interditado, portanto, podem ser alterados até mesmo em função do deslinde da interdição. Assim, Lima coloca a possibilidade de se considerar essa competência como relativa, em busca do melhor interesse do interditado, ou então, embora represente um caminho mais árduo, o pedido pode ser promovido no juízo da interdição, com a consequente solicitação de pedidos cabíveis por intermédio de emissão de cartas precatórias, com posterior julgamento do caso. Esta última opção dificultaria imensamente o procedimento de levantamento da curatela, motivo pelo qual, nesta hipótese, assume-se que a competência deve ser relativizada. ¹⁰⁶⁵

3.5.1 Intervenção do Ministério Público

A inclusão do Ministério Público no rol de partes legitimadas ativas para a propositura do pedido de levantamento da curatela do interditado simplifica o entendimento do seu papel tanto no procedimento de interdição como no de seu levantamento.

Como o procedimento de levantamento da curatela é de jurisdição voluntária o pressuposto básico e geral é que o *Ministério Público* atuará nesse procedimento na condição de fiscal da aplicação da lei (*custos legis*). Nesse sentido, Lucena aduz: “O requerimento com este objetivo constitui novo procedimento de jurisdição voluntária, independente da interdição, exigindo instrução, manifestação do curador e do Ministério Público, bem como decisão por meio de sentença judicial”. ¹⁰⁶⁶

A distinção entre a atuação do Ministério Público no procedimento de levantamento de curatela em relação ao procedimento de interdição consiste em que na promoção do pedido de levantamento de curatela, naturalmente em procedimento autônomo e novo de jurisdição voluntária, o Ministério Público age como *substituto processual*, e não mero representante ou fiscal da aplicação da lei.

Sendo assim, pode-se distinguir que, na hipótese constante do § 1.º do art. 175, o Ministério Público age como *substituto processual*. À exceção dessa previsão, o Ministério Público precisa ser acionado para agir na condição de fiscal da aplicação da lei (*custos legis*).

Importante ressaltar que, segundo Pontes de Miranda, ¹⁰⁶⁷ quando o Ministério Público promove o pedido de levantamento da curatela do interditado, não pode desistir da ação.

Art. 757. A autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens do incapaz que se encontrar sob a guarda e a responsabilidade do curatelado ao tempo da interdição, salvo se o juiz considerar outra solução como mais conveniente aos interesses do incapaz.

1. Inovações do CPC/2015

Este dispositivo ressalta e esclarece a condição estabelecida no art. 755 da mesma seção do CPC/2015. O curador nomeado em juízo estende seus poderes ao incapaz dependente do interditado. Tal condição não é inalterável, motivo pelo qual um arranjo mais assertivo ao caso analisado deverá ser cuidadosamente organizado.

2. Aspectos materiais

Este dispositivo preconiza uma probabilidade que merece atenção, já que possibilita que o juiz da interdição promova ato judicial que busca resguardar eventual incapaz que, outrora à interdição, se encontrava sob a tutela do interdito.

A preferência por parte do juiz de ato judicial, qual seja a sentença, nos moldes do art. 755 do CPC/2015, que estenda o poder familiar do interditado ao curador no próprio procedimento de interdição, portanto, resta agora possível. A partir dessa disposição, será possível que o curador, caso o juízo entenda por bem, exerça a curatela tanto do interdito quanto do incapaz dele dependente, sendo cabível nesse conceito menores de idades, pessoas provisoriamente incapazes, deficientes, e outras possibilidades legalmente determinadas.

Caso o incapaz entenda que a sentença proferida não adotou a melhor e mais conveniente solução aos seus interesses, resta possível recorrer, ou pleitear a nomeação de curador mais apto em procedimento próprio e diferente do de interdição do interdito.

O Juízo pode nomear mais de uma pessoa como curador do interditado. Dispõe o art. 1.775-A do CPC/2015 que esses curadores exercerão a curatela de forma *compartilhada*, o que parece ser distinto da protutória conforme consta do art. 1.742 do CC/2002, porque esse dispositivo estabelece que o protutor exercerá fiscalização sobre os atos do tutor. A curatela compartilhada sugere que ambos os curadores exercerão o encargo público em igualdade de condições sem sujeição de um deles à fiscalização por parte do outro, mas de modo igualmente autônomo e dotados dos mesmos direitos e obrigações no desempenho do encargo (*múnus*).

De forma semelhante e no mesmo sentido ocorre com a tomada de decisão apoiada em que o apoiado elege *pelo menos* duas pessoas para lhe prestar auxílio na tomada de decisão (CC/2002, art. 1.783-A). A necessidade de escolha de *pelo menos duas pessoas* encontra justificativa no fato de que a tomada de decisão apoiada tem por objetivo auxiliar o apoiado na prática de atos da vida civil, em especial negócios (CC/2002, art. 1.783-A, § 6.º), o que demanda do apoiador algum entendimento técnico acerca do negócio a ser celebrado, a fim de não importar em prejuízo para o apoiado.

Essa solidariedade no exercício desses tipos de encargos público se revela interessante na medida em que possibilita a repartição de responsabilidades na condução da vida e dos negócios de terceiro (curatelado, tutelado ou apoiado) em contexto cada vez mais complexo que se apresenta na quadra atual. Por fim, a decisão de nomear mais de um curador para o interditado deve ser tomada tendo em mira o princípio do melhor interesse do deficiente.

3. Aspectos processuais e procedimentais

Trata-se de dispositivo novo do CPC/2015 que garante uma instrumentalidade maior ao procedimento de interdição, dado que, no mesmo processo em que se promove a curatela do interditado, pode-se estender neste mesmo ato a *autoridade* do curador à pessoa e aos bens do incapaz que se encontram sob a guarda do interditado.

Essa disposição consiste em medida que economiza o tempo e o custo necessários a tutela dos bens e das pessoas dependentes do interditado. Como a incapacidade para realização de atos da vida civil e para a administração dos bens pode ser em grau reduzido, mostra-se correto aproveitar o momento em que tal incapacidade é constituída e mensurada em juízo, a fim de que se repare de forma explícita desde logo quais são os limites do interditado. Caso o interditado não tenha mais a capacidade de tutelar e administrar os bens e pessoas que dependem de sua pessoa, o curador pode assumir mais este encargo.

Por sua vez, caso o curador não se mostre capaz de administrar os bens do interditado ou até mesmo de exercer a guarda de uma pessoa também dependente do interditado, o presente dispositivo possibilita a propositura ou tratamento da questão no próprio procedimento de interdição, prerrogativa que facilita de forma contundente também a curatela eventual incapaz dependente do interditado.

Art. 758 . O curador deverá buscar tratamento e apoio apropriados à conquista da autonomia pelo interdito.

1. Inovações do CPC/2015

Inova o CPC/2015 ao concretizar proposição de reinserir o interdito na sociedade de forma plena e operativa, mediante o apoio e tratamento das condições que o levaram à interdição e à curatela. Essa disposição dirigida diretamente ao curador tem especial alcance nos casos de transtornos mentais passageiros, em que a natureza da incapacidade é transitória e nas deficiências que podem ser criadas pela habilitação e reinserção ou recuperadas pela reabilitação.

Como o interditado necessariamente é uma pessoa não emancipada e, anteriormente à sentença de interdição, podia ser parcial ou plenamente capaz de praticar os atos da vida civil e de administrar os seus bens, a tendência que o CPC/2015 introduz com esse dispositivo é o encargo ao curador de buscar a sua autonomia.

A *Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência* estabelece este dever de busca da autonomia dos deficientes aos Estados parte; ¹⁰⁶⁸ prevista também na Lei 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência ou Estatuto da Pessoa com Deficiência. ¹⁰⁶⁹

2. Aspectos materiais

Este dispositivo, em realidade, possui maior teor material do que processual, comprovando a íntima relação entre Direito Civil e Direito Processual Civil do que o CPC/2015 concretizou.

Normas anteriores, como a Lei 10.216/2001, que “dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental”, ainda não possuíam essa atenção à autonomia do deficiente. ¹⁰⁷⁰

Embora a Lei 13.146/2015, *Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência* ou *Estatuto da Pessoa com Deficiência*, tenha avançado muito mais ao tratar da autonomia, seja ao tratar de suas definições de acessibilidade (art. 3.º, inc. I), tecnologia assistiva ou ajuda técnica (art. 3.º, inc. III, e art. 74), moradia (art. 3.º, inc. XI), habilitação e reabilitação (art. 14), saúde (art. 18, § 2.º), educação (art. 28, incs. III e XII), assistência social (art. 39), há ainda críticas ao modelo material e processual de interdição.

Essas novas disposições, ainda que tímidas no CPC/2015, contudo mais amplas na Lei 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência alteram sobremaneira a interpretação legal dos institutos relacionados à capacidade, suas limitações, e à possibilidade de adoção de medidas judiciais intermediárias e não radicais como a interdição total.

O intuito de se promover o tratamento e a melhora da condição deficitária que acometeu ou acomete o interdito resta flagrantemente explicitada neste artigo, entendendo-se que tanto o tratamento do interdito que vise a melhora da sua condição com eventual levantamento integral da curatela é incentivado, bem como a busca da autonomia desse interdito, ainda que de forma independente do levantamento da curatela. Todavia, é evidente que o ideal é o tratamento do interdito até o ponto em que se revele possível o levantamento dessa curadoria, já que o pressuposto geral é que o estado deficitário do interdito é provisório.

Conclui-se que este artigo fortalece o fato de que o curador deve buscar, sempre que nomeado como tal, o resguardo dos bens e das obrigações do interdito, garantindo a satisfação de seus interesses bem como promova atos de tratamento que possam vir a mudar a condição do deficiente, caso possível.

A partir da Lei 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência, deve-se compreender a curatela num contexto de igualdade de direitos entre a pessoa sujeita à medida extraordinária (art. 85, § 2.º) e os demais que acerçam.

3. Aspectos processuais e procedimentais

Este dispositivo não possui nenhum conteúdo expresse de natureza processual, mas serve apenas para reiterar o objetivo final e às vezes limitado do procedimento de interdição e o papel do curador nomeado em juízo, qual seja a busca do melhor interesse do interdito.

Dele, contudo, se pode extrair a imposição de novos deveres, agora amparados não mais no CC/2002

apenas, mas neste conjunto normativo criado pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e pelas leis subsequentes.

O desatendimento aos deveres inerentes ao encargo por parte do curador pode ensejar a sua suspensão ou sua remoção. A suspensão do curador (art. 762), existia no sistema anterior (CPC/1973, art. 1.197) e a remoção (art. 761 e parágrafo único), sendo assim também desde o sistema anterior, tanto para a curatela como para a tutela (CPC/1973, art. 1.194).

Ainda que o CPC/2015 tenha se contido em apontar novo dever ao curador neste dispositivo, sem estabelecer eventual sanção pelo descumprimento, nem mesmo mencionara a suspensão ou remoção, pode-se inferir da nova ordem normativa que são possíveis essas medidas caso o curador não busque “tratamento e apoio apropriados à conquista da autonomia pelo interdito”.

Seção X

Disposições comuns à tutela e à curatela

1. Inovações do CPC/2015 na Seção

Não há inovações no conteúdo do título, porquanto somente se reordenou o que se denominava *Capítulo* que, a partir do CPC/2015, passa ser denominado de *Seção*.

2. Aspectos materiais gerais da Seção – Disposições comuns à tutela e à curatela

O direito tutelar objetiva a proteção do menor, associada à perda ou decaída do poder familiar pelos pais ou nos casos de ausência ou falecimento destes. Sua regulação se dá no CC/2002, principalmente pelos arts. 1.728 a 1.766, que tratam da capacidade ou incapacidade de ser tutor, da escusa e do exercício da tutela, do zelo aos bens, da prestação de contas e da cessação da tutela, bem como, ainda, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990, arts. 36 a 38 e 164.

Segundo Pontes de Miranda, a tutela consiste no poder conferido pela lei a pessoa capaz, a fim de que proteja os bens dos menores que se encontram fora do pátrio poder, hoje *poder familiar*. Assim, o tutor é aquele que exerce a tutela. Afirma, ainda, o autor, que o tutor é a pessoa indicada para resguardar a pessoa e os bens do menor, garantindo sua educação, alimentação e correção de curso, com o auxílio do juiz competente, tanto na hipótese em que os pais do menor, ou do relativamente incapaz entre 16 e 18 anos, tenham falecido (art. 1.728, inc. I, do CC/2002), ou tenham decaído do poder familiar (art. 1.728, inc. II, do CC/2002). Conclui-se que a tutela é um dos institutos do direito material mais relevantes para a proteção do menor. ¹⁰⁷¹

A legitimidade processual do tutor para a promoção da interdição e consequente convolação da tutela em curatela do menor e do adolescente sob sua autoridade está assegurada caso o menor se torne, por causa transitória ou permanente, incapaz de exprimir sua vontade (CC/2002, art. 1.767, inc. I), nos casos em que devesse. Também são motivos que podem ensejar a interdição do menor e do adolescente a sua embriaguez habitual, o vício em tóxico e a prodigalidade (CC/2002, art. 1.767, incs. III e V), causas que se ocorrentes no menor sob tutela, podem estar associadas à negligência dos cuidados do tutor, ensejando antes a remoção do tutor que a interdição e curatela do menor.

Também já se demonstrou que a interdição e a tutela são intimamente conexas. Conforme Pontes de Miranda, a interdição consiste em ato do Poder Público pelo qual se declara ou se retira (= desconstitui), total ou parcialmente, a capacidade negocial de alguém. ¹⁰⁷² Tal medida se enquadra no campo do Direito de Família, contexto em que pode ser assegurada de forma mais eficaz e assertiva a proteção de pessoa com deficiência física ou mental e de seus bens, pessoas maiores que não podem conduzir diretamente sua vida, cuidar de seus negócios, bens e interesses, bem como administrar seu patrimônio. ¹⁰⁷³ A curatela e a tutela são institutos protetivos correlatos, sendo que a curatela está associada ao maior, como a tutela está associada ao menor.

A consequência natural do julgamento procedente do pedido de interdição é a nomeação de curador ao curatelando ou interditando, curador este que, por sua vez, regerá, integral ou parcialmente, os atos da vida civil e os bens ou somente os bens do interditado. Trata-se de procedimento voluntário, com certo grau de conflituosidade, que se vincula de forma íntima com o direito material aplicável à capacidade das pessoas físicas.

A proteção garantida por intermédio da interdição e, conseqüentemente, da curatela, busca zelar e gerir as obrigações sociais, comerciais e pessoais, além dos bens sob a tutela do deficiente físico ou mental.¹⁰⁷⁴

3. Aspectos processuais e procedimentais gerais da Seção

A seção a ser analisada, em realidade, regulamenta o procedimento processual de nomeação de curador ou tutor, expondo que atos são necessários tanto para a sua regular nomeação, como para sua remoção, conforme se verá a seguir.

Art. 759 . O tutor ou o curador será intimado a prestar compromisso no prazo de 5 (cinco) dias contado da:

I – nomeação feita em conformidade com a lei;

II – intimação do despacho que mandar cumprir o testamento ou o instrumento público que o houver instituído.

§ 1.º O tutor ou o curador prestará o compromisso por termo em livro rubricado pelo juiz.

§ 2.º Prestado o compromisso, o tutor ou o curador assume a administração dos bens do tutelado ou do interditado.

1. Inovações do CPC/2015

A alteração mais notável é a inclusão do § 2.º, que remete à assunção da administração de bens alheios em momento imediatamente posterior à nomeação e à prestação do compromisso por parte do novo tutor ou curador.

2. Aspectos materiais

Pontes de Miranda leciona que a nomeação é ato judicial de natureza constitutiva, extensível a qualquer pessoa que venha a ser tornar tutora ou curadora. De tal disposição, depreende-se que a nomeação é o ato específico que garante a condição jurídica de tutor ou curador.

Segundo o autor, o ato de nomeação do tutor ou curador, deve se dar em momento imediatamente posterior ao fato, ou evento, que fundamente a nomeação de pessoa apta a defender os bens e interesse alheios.

O § 2.º, por sua vez, determina indiretamente a necessidade de prestação de contas por parte do administrador dos bens do tutelado ou do interditado, isso em combinação com a normativa de cunho material. Contudo, em grande parte das intervenções os interditados e tutelados são pessoas simples e de poucos recursos, não sendo raro a dispensa da *prestação de contas*, com a aquiescência do Ministério Público, tudo a depender do volume de patrimônio e da percepção de rendimentos de que disponham os interditos ou curatelados, de que por vezes são até mesmo despossuídos ou não supera o *mínimo vital*, bem como da comprovada idoneidade do tutor ou curador, na forma do art. 1.745, parágrafo único do CC/2002, aplicável à tutela e curatela. Portanto, embora tal prática não conte com apoio legal, tem sido observado na rotina destes procedimentos.

Essencial frisar também, segundo João Paulo Lucena,¹⁰⁷⁵ que a nomeação de tutor ou curador consiste em encargo obrigatório, que somente a partir de abertura de prazo específico, a seguir explicitado, poderá ser recusado, ou mediante demonstração de fato impeditivo relevante e suficiente para afastar tal encargo.

3. Aspectos processuais e procedimentais

As “Disposições Comuns à Tutela e à Curatela” (arts. 759-763) tratam da nomeação, compromisso e exercício das funções, mas também das possibilidades de escusa, suspensão, remoção, exoneração dos deveres e encargos.

O prazo para o tutor ou curador prestar compromisso será de 5 (cinco) dias úteis (CPC/2015, art. 219) para o exercício do encargo após a nomeação pelo juiz (art. 759, I), bem como no mesmo prazo quando decorrente de testamento ou instrumento público em que tenha sido instituída a tutela ou curatela, neste

caso a contar do despacho do juiz que mandou lhe dar cumprimento (art. 759, II).

3.1 Nomeação do tutor ou curador

Este ‘procedimento’ pressupõe a “[...] preexistência de nomeação de curador e de tutor feita pelo juiz quando lhe chega às mãos procedimento em que se verifique a necessidade da medida, ou a preexistência de nomeação de tutor feita pelos pais em conjunto”, ¹⁰⁷⁶ *não se trata, portanto, de um procedimento propriamente dito, ao qual correspondam autos próprios (acessório ou dependente), mas de incidente processual proposto e resolvido nos próprios autos do procedimento originário. No caso, a nomeação é feita no mesmo procedimento, a exemplo da interdição, onde se declarará a incapacidade, bem como se instituirá curador. Nomeado o curador, abrir-se-á prazo para que preste o compromisso previsto neste artigo (759).* Embora a doutrina não seja clara quanto ao fato de o “compromisso” se tratar ou não de um procedimento autônomo ou não, entende-se que o seu silêncio deva ser interpretado em favor do entendimento da prescindibilidade de autos apartados para colher o *termo de compromisso*, até mesmo por medida de economia processual já que pode ser feito nos autos originários.

Não é este o entendimento, todavia, quando se tratar da *remoção* do tutor ou curador, conforme será tangenciado no art. 761, parágrafo único, que desde já é anunciado para fins de cotejamento, posto que nesta ocasião a remoção ou não do tutor ou curador demandará autos apartados para se evitar tumulto processual, na medida em que este será citado e lhe será oportunizado o devido processo legal. Após o acerto desta questão, a cópia da decisão dele resultante deve ser juntada aos autos principais e estes autos acessórios serão arquivados.

Assim, o tutor, nos termos do art. 1.729, do CC/2002, será nomeado em testamento, pelos pais do menor, de comum acordo. Não havendo tal previsão, segue-se a regra dos arts. 1.731, 1.732 e 1.734, todos do CC/2002. Já o curador será nomeado sempre pelo juiz, obedecendo-se as regras dos arts. 1.774 a 1.778 do CC/2002. Contudo, este entendimento acerca da primazia da vocação para o encargo da curatela não deve ser tomado de forma rígida. Há entendimento do STJ, ¹⁰⁷⁷ no sentido de que mesmo sendo o cônjuge um dos legitimados ativos preferencial na ordem de nomeação, até mesmo por força da relação de afeto que nutre com o interditando, esta ordem de vocação pode ser alterada caso se comprove a existência de litigiosidade entre o cônjuge e o interditando, tudo com fundamento no *princípio do melhor interesse do incapaz*.

Nada obsta, como aponta Pontes de Miranda, “[...] à nomeação da mesma pessoa, pelo juiz, como tutor ou curador dativo, até a investidura do tutor ou curador testamentário”. ¹⁰⁷⁸

3.2 Compromisso, momento e forma de sua realização

Nomeados, tanto o tutor como o curador deverão assinar compromisso de que exercerão, “bem e fielmente”, o encargo, ainda que esta expressão não conste da lei. O termo deverá ser assinado, ainda que designados, na falta de determinação pelos pais em testamento ou documento autêntico – art. 1.729, parágrafo único, do CC/2002, ¹⁰⁷⁹ sejam os parentes consanguíneos, determinados no art. 1.731, do CC/2002. ¹⁰⁸⁰ *Já o curador, é sempre nomeado pelo juiz, sem qualquer interferência decisiva da vontade subjetiva de seus parentes próximos (Exemplo: Pais; avós e etc.), decorrendo, sempre e necessariamente, do magistrado, perante o qual deverá prestar compromisso, ¹⁰⁸¹ observando preferencialmente a ordem legal, mas não prioritária da lei, sempre com vista ao melhor interesse do interditado.*

O tutor ou curador, serão intimados, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, que, na forma do art. 759, será contado a partir da: a) nomeação feita em conformidade com a lei (*Exemplo*: sentença de interdição – arts. 1.781 e 1.767; sentença que cassar o poder familiar – ECA, arts. 24 e 155, pelo CC, arts. 1.728, II e 1.732; e pela sentença que declarar os pais ausentes – CC, art. 1.728, I) e b) intimação do despacho que mandar cumprir o testamento ou instrumento público que o houver instituído – arts. 1.728, I e 1.729.

3.3 Assunção da administração e deveres do tutor e do curador

Prestado o *compromisso* e assinado o *termo*, o tutor assume a administração dos bens do tutelado (art. 1.741 do CC/2002), passando, também, a exercer e responder pelas atividades e responsabilidades previstas nos arts. 1.740 a 1.752, do CC/2002. Quanto à curatela, observa-se que se aplicam as mesmas disposições dirigidas à tutela, inclusive em relação ao exercício e responsabilidades, conforme preceitua o art. 1.774, do CC/2002, excetuando-se apenas aquelas descritas nos arts. 1.782 e 1.783, do CC/2002.

Trata-se de matéria atinente ao direito material, pelo que não serão aprofundadas as discussões

quanto às atividades e responsabilidades do tutor e do curador, remetendo-se aos comentários dos livros específicos sobre a matéria.

3.3.1 Hipoteca legal

Quanto à antiga necessidade de hipoteca legal, no atual Código já não se verifica tal incumbência como necessária, em verdade, como aponta Nelson Nery Junior, o parágrafo do art. 1.188, do CPC/1973, já não estava em vigor na parte em que trazia a necessidade de *especificação de hipoteca*.¹⁰⁸² Segunda as disposições do Código Civil sobre o tema, poderá o juiz exigir *caução* bastante, tanto do tutor como do curador, caso o patrimônio do menor, ou do interditando, seja de valor considerável, podendo, ainda, dispensá-la (caução) se o tutor, ou curador, for de reconhecida idoneidade, nos termos do parágrafo único do art. 1.745, do CC/2002. Ressalta-se, ainda, a responsabilidade, direta ou subsidiária, do juiz quanto à exigência da garantia, nos termos do art. 1.744, do CC/2002.

3.3.2 Prestação de contas

Estão ainda obrigados, tanto o tutor como o curador, a prestarem contas das suas administrações, nos termos do art. 1.755, do CC/2002. O ‘procedimento’ a se observar será o do art. 553, do CPC/2015, devendo ser prestadas em apenso aos autos do processo em que tiverem sido nomeados (tutor ou curador), no prazo descrito pelos arts. 1.576 e 1.757, do CC/2002.

3.4 Duração da tutela ou curatela

A duração da tutela e da curatela está coligada aos fins de sua existência e subsistirá enquanto exigirem proteção ao tutelado ou curatelado, os bens do menor ou do interditado, sendo temporária e indeterminada,¹⁰⁸³ tendo a plena gestão durante a sua nomeação, substituído no exercício por interino no caso de extrema gravidade (art. 762) ou substituído por outro tutor ou curador em caso de remoção (art. 761). Ressalta-se que o desatendimento aos deveres do tutor ou do curador pode ensejar, conforme se verá, além da sua responsabilização (art. 1.752 do CC/2002), a sua suspensão (art. 762) ou sua remoção (art. 761 e parágrafo único).

Art. 760. O tutor ou o curador poderá eximir-se do encargo apresentando escusa ao juiz no prazo de 5 (cinco) dias contado:

I – antes de aceitar o encargo, da intimação para prestar compromisso;

II – depois de entrar em exercício, do dia em que sobrevier o motivo da escusa.

§ 1.º Não sendo requerida a escusa no prazo estabelecido neste artigo, considerar-se-á renunciado o direito de alegá-la.

§ 2.º O juiz decidirá de plano o pedido de escusa, e, não o admitindo, exercerá o nomeado a tutela ou a curatela enquanto não for dispensado por sentença transitada em julgado.

1. Inovações do CPC/2015

A alteração dos textos normativos acima transcritos não acarretou mudança substancial da matéria, mas tão somente um rearranjo de termos na transição de diplomas processuais. O art. 1.193 foi incluído como parágrafo do art. 760, já que tratava de mera extensão do pedido de escusa do tutor ou curador.

2. Aspectos materiais

Em regra, o exercício da tutela ou da curatela não depende da vontade do nomeado, quer seja parente ou estranho ao incapaz. Trata-se, como bem adverte Alcides de Mendonça Lima, *múnus* que o Estado impõe para salvaguardar os interesses do incapaz,¹⁰⁸⁴ ressaltada a hipótese do art. 1.737 do CC/2002 – aplicável tanto ao tutor como ao curador (art. 1.774 do CC/2002).

Porém, o dispositivo possibilita ao curador ou tutor eximir-se do encargo, conforme regras específicas previstas nos arts. 1.736 ao 1.739, do CC/2002, nos momentos processuais pertinentes para o peticionamento.

3. Aspectos processuais e procedimentais

3.1 Requerimento da eximção e competência

A *Eximção do exercício* é ato próprio de quem não deseja a função e apresenta escusa fundamentada ao juízo, antes de aceitar o encargo (art. 760, I) ou até cinco dias, quando já no exercício do encargo, sobrevier o motivo da escusa (art. 760). Dessa forma, o peticionamento, para fins de eximção, é faculdade conferida ao tutor ou curador, que deverá ser, por óbvio, formulada por petição escrita, subscrita por advogado ou por quem detenha o *jus postulandi* (*exemplo*: defensoria pública), sendo que o silêncio, neste caso, será entendido como anuência ou à continuidade do encargo já incumbido.

A petição deverá ser instruída com os documentos que demonstrem as causas de escusa, previstas nos arts. 1.736 e 1.737, do CC/2002.

O juízo competente para apreciar o pedido será o mesmo que o nomeou (tutor ou curador). Cumpre destacar que o Ministério Público também deverá ser ouvido quanto ao pedido, dado que presente na prossecução processual, seja condição de *custos legis*, seja como parte ativa, a depender da gênese do procedimento.¹⁰⁸⁵

O transcorrer do prazo redundará, a priori, em preclusão do prazo aberto no dispositivo. No entanto, trata-se de prazo impróprio e que não repercute em inexistência de oportunidade de manifestação posterior para o curador ou tutor, a eximção em razão da superveniência de fatos que impossibilitem o exercício do encargo, devendo-se observar o prazo de 5 dias, a partir da constatação.

3.2 ‘Decisão’ e recurso

Caso o pedido de eximção não seja deferido em juízo, o tutor ou curador exercerá o encargo até o trânsito em julgado de sentença que reverta o indeferimento impugnado via recurso, nos termos do art. 1.739 do CC/2002 e § 2.º do art. 760, do CPC/2015. Como bem adverte Alcides de Mendonça Lima (comentários ao CPC/1973), a expressão “de plano”, mantida pelo Código de 2015 (§ 2.º do art. 760), é utilizada apenas para informar o intérprete de que a sentença será proferida, sem a necessidade das formalidades como, por exemplo, instrução, audiência etc. Analisará, portanto, as provas documentais juntadas pelo requerente (tutor ou curador) em sua petição, podendo, o magistrado, requerer outras além destas (art. 723, parágrafo único) para formação de seu convencimento (art. 371).

Como não se vislumbra disposição expressa no tocante à natureza do ato decisório que denega o pedido de dispensa, poder-se-ia supor que consiste em decisão interlocutória e, em função disso, ser impugnada mediante agravo de instrumento, com base no art. 1.015, inc. II, do CPC/2015. Porém, como determina a regra geral dos procedimentos de jurisdição voluntária, bem como o entendimento de que a permanência ou não de determinada pessoa em tal encargo efetivamente é questão de vocação e de mérito, deverá ser interposto recurso de apelação contra a decisão que defere ou indefere o pedido de eximção, nos termos do art. 724 do CPC/2015.¹⁰⁸⁶

Art. 761 . Incumbe ao Ministério Público ou a quem tenha legítimo interesse requerer, nos casos previstos em lei, a remoção do tutor ou do curador.

Parágrafo único. O tutor ou o curador será citado para contestar a arguição no prazo de 5 (cinco) dias, findo o qual observar-se-á o procedimento comum.

1. Inovações do CPC/2015

Não se vislumbrou nesta transição, também, alteração substancial nos dispositivos supratranscritos. A notável distinção a fazer feito no novo diploma processual é a disposição expressa no tocante à adoção de procedimento comum no processo de remoção de tutor ou curador nomeado judicialmente para determinado encargo.

2. Aspectos materiais

Conforme trabalhado, têm-se que a regra é que o tutor ou curador continuará exercendo o encargo, enquanto cumprir fielmente suas obrigações e compromissos assumidos. Porém, caso se constate circunstância diversa ao exercício regular do seu encargo, a remoção se torna medida imperiosa.

A *remoção* é ato que remete ao mau desempenho do tutor ou curador em suas atividades, independentemente de negligência, prevaricação, ou outro motivo grave, bem como à falta de capacidade para o exercício do encargo (art. 1.735 do CC/2002). Dessa forma, para a concretização dessa

modalidade de provimento judicial, deverão ser levados em conta motivos graves constantes dos arts. 1.735, 1.740, 1.748, 1.749, 1.751, 1.752 e 1.756 do Código Civil de 2002.

José Olympio de Castro Filho adverte que, embora o tutor e o curador estejam limitados ao exercício de atos com a autorização do juiz, como, por exemplo, o pagamento de dívidas (art. 1.748, I, do CC/2002) ou propor ação (art. 1.748, V, do CC/2002), não há falar em pedido de exoneração, pura e simplesmente, caso o faça sem autorização judicial, a qual, inclusive, poderá ser suprida ulteriormente, nos termos do parágrafo único do art. 1.748, do CC/2002, desde que ajam de forma razoável e com bom senso, buscando o melhor interesse do incapaz. ¹⁰⁸⁷

Além dos motivos elencados anteriormente, cumpre destacar, também, que o pedido de remoção não depende da prática de ato negligente, ou mesmo de culpa, do tutor ou curador, bastando, apenas, que seu desempenho cause prejuízo ao incapaz. Razoável, portanto, ainda que involuntariamente, nos casos em que se verifique pouca inteligência, inexperiência ou mesmo quando o tutor ou curador tenha seu tempo absorvido por muitas ocupações, para a configuração do lesivo exercício das funções. ¹⁰⁸⁸

Em verdade, o caso concreto aliado ao esquadro estabelecido permitirá ao juízo, bem como ao Ministério Público, avaliar a existência de mau desempenho por parte do tutor ou do curador que enseje prossecução do procedimento de remoção.

3. Aspectos processuais e procedimentais

3.1 Legitimidade do Ministério Público e dos demais interessados

A atuação do Ministério Público no procedimento de remoção não sofreu alteração substancial, continuando no exercício regular de suas funções constitucionais e democráticas.

Da mesma forma que no procedimento de instituição de tutoria, estando o Ministério Público no polo ativo do procedimento de interdição, na condição de substituto processual, dele não poderá desistir. O art. 127 da Constituição Federal estabelece que é dever desse representante a defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis, dispositivo que vincula sua atuação a este procedimento.

Segundo José Olympio de Castro Filho, todavia, o Ministério Público também possui legitimidade para continuar a ação que qualquer um dos demais legitimados dela tenha desistido, visto que iniciar um procedimento autônomo seria mais custoso e demorado ao tutelando ou curatelando que já se encontra no polo passivo da demanda. ¹⁰⁸⁹

Além do Ministério Público, são legitimados os interessados previstos no art. 747 e 752, § 3.º, do CPC/2015, os quais também poderão apresentar pedido de remoção em virtude de atos de mau desempenho do encargo por parte do tutor ou curador.

3.2 Citação para o tutor ‘contestar’ (parágrafo único)

Importante ressaltar que o termo “citado” não foi alterado no art. 761, deste novo diploma processual, motivo pelo qual a defesa a ser exercida pelo tutor ou curador é de natureza *contestatória*, devendo observar as regras descritas no procedimento comum para a contestação (arts. 335 ao 337, do CPC/2015). Cabe ainda a *exceção*, conforme aduz Alcides de Mendonça Lima. ¹⁰⁹⁰

O prazo para apresentação da contestação é de 5 (cinco) e não o de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada da citação aos autos. ¹⁰⁹¹

3.3 Procedimento comum, sentença e recurso

O procedimento a ser observado é o comum, conforme determina o parágrafo único do art. 761, o qual terá início por meio de petição inicial (art. 319 do CPC/2015) proposta pelo Ministério Público ou por quem tenha legítimo interesse. Quanto ao pedido de *remoção* do curador, também aplicável ao tutor, trata-se de ação autônoma que, segundo Nelson Nery Junior, “[...] não guarda relação com a ação de interdição já finda”, ¹⁰⁹² sendo competente o foro de domicílio do interditado (princípio do melhor interesse do incapaz). Especificamente em relação ao pedido de remoção de tutor de menor vulnerável (ECA, art. 98), este deverá ser proposto na vara de infância e juventude, conforme preceitua o art. 148, parágrafo único, alínea *b*, do ECA, bem como, além de observar o procedimento comum, deverá aplicar a regra do art. 164 do ECA. ¹⁰⁹³

Caso se verifique a necessidade de produção de prova em audiência de instrução, poderá o juiz determiná-la, devendo ser intimada às partes para comparecimento, nos termos dos arts. 358 a 367, do CPC/2015. ¹⁰⁹⁴ Será indeferido o pedido de designação de audiência, caso se verifique a hipótese de julgamento antecipado da lide (art. 354, do CPC/2015). ¹⁰⁹⁵

Da sentença que deferir ou indeferir o pedido de remoção, caberá apelação, nos termos do art. 724 do CPC/2015.

Art. 762 . Em caso de extrema gravidade, o juiz poderá suspender o tutor ou o curador do exercício de suas funções, nomeando substituto interino.

1. Inovações do CPC/2015

Observa-se que não houve efetiva alteração de conteúdo neste dispositivo na transição de diplomas processuais, mas tão somente a reordenação de elementos textuais. Em função disso, o disposto no artigo alhures transcrito segue com sentido inalterado.

2. Aspectos materiais

João Paulo Lucena explana que a incidência deste dispositivo implica suspensão do exercício do tutor ou curador, constituindo-se medida antecipatória de futura remoção, por meio de pedido expresso (tutela de urgência – arts. 300 a 302) ou de ofício

Os casos de extrema gravidade são aqueles que “[...] põem em risco iminente a saúde, a segurança, a vida e formação do órfão ou curatelado; ou que comprometam seriamente a segurança e a administração de seu patrimônio”. ¹⁰⁹⁶ Já Alcides Mendonça Lima constata que o ato de extrema gravidade pode ser de ordem moral, econômica, ou de qualquer natureza diversa dos exemplos citados, contanto que demonstre sempre potencial lesivo relevante e inaceitável. ¹⁰⁹⁷

Após o afastamento do tutor ou curador estabelecido, o juiz nomeará *substituto interino*, o qual exerce tal cargo de forma meramente provisória até o afastamento da situação de gravidade extrema.

Edson Prata afirma que, uma vez nomeado o curador ou tutor interino, este prestará compromisso, poderá oferecer hipoteca legal, e receberá os bens que outrora se encontravam sob a administração do substituído, tradição que comporta na lavratura de *termo de recebimento e de entrega de bens*, ¹⁰⁹⁸ seguindo a mesma forma do art. 759 do CPC/2015 (v. comentários ao art. 759).

É também de posicionamento doutrinário majoritário que o fim da prestação da atividade de tutor ou curador acarreta em necessária prestação de contas, dada a incontestável administração de bens alheios. ¹⁰⁹⁹

3. Aspectos processuais e procedimentais

Como aduzido, o procedimento poderá ser provocado (arts. 300 a 302 do CPC/2015) pelo Ministério Público ou por qualquer legitimado para propor o procedimento de remoção. Mas também, poderá ser, como aponta Pontes de Miranda, que o juiz receba informe de infração do tutor ou do curador e não haja tempo para a apuração da verdade (procedimento da remoção) sem que se comprometa a saúde, a segurança ou a vida do incapaz, ou mesmo a segurança e administração de seu patrimônio, sendo necessária a suspensão das atividades do tutor ou do curador de forma imediata, nomeando-se substituto interino, até que se apure a necessidade de remoção ou não. ¹¹⁰⁰ Nesse caso, identifica-se, inclusive, a possibilidade de atuação de ofício pelo juiz, conforme se verá mais detalhadamente a seguir.

3.1 Reconhecimento do risco e decisão de suspensão

O dispositivo remete a situação de extrema gravidade que enseja intervenção, a priori, de ofício por parte do magistrado ¹¹⁰¹ que, ao receber a petição de remoção, identifique tratar-se de falta de *extrema gravidade*, não sendo razoável a permanência do tutor, ou do curador, em sua atividade até o fim da apuração (procedimento de remoção). Nada impede a possibilidade de peticionamento em juízo, que demonstre situação fática emergencial apta a ensejar atuação do juízo como medida de urgência (arts. 300 a 302 do CPC/2015). Assim, a exposição de fatos de “extrema gravidade” poderá, independentemente de haver pedido expresso, ensejar a atuação de ofício do juiz.

José Olympio de Casto Filho elucida que, por se tratar de medida sumária e pertinente em hipótese de

urgência, não se faz com a oitiva do tutor ou do curador (*inaudita altera pars*), constituindo, assim, decisão judicial de natureza não definitiva, apenas provisória.¹¹⁰² Uma vez suspenso, deverá o tutor, ou curador, ser citado para se defender do ato que lhe foi imputado, ou para ser definitivamente afastado (removido).¹¹⁰³ O procedimento, portanto, após a decisão liminar, será o da remoção, inclusive no que diz respeito a competência (v. comentários ao art. 761).

Segundo a classificação das tutelas provisórias do CPC/2015, dividida nas espécies da *evidência* e da *urgência*, certamente se tratará da subespécie cautelar; cautelaridade esta decorrente do risco, tutelável pelo *poder cautelar geral* (art. 297), ainda que se tenha mitigado a ideia que o processo cautelar tutele apenas o processo e não o direito. Dessa forma, o pedido observará as disposições concernentes à tutela de urgência (arts. 300 a 302, do CPC/2015).

Contudo, a despeito do entendimento da concessão liminar da medida, não está afastada a possibilidade de designação de prévia *audiência de justificação* para fim de melhor embasamento da decisão a ser tomada pelo Juízo, porque não se deve olvidar que esta medida também é extrema, ou seja, somente deve ser adotada quando houver constatação da probabilidade de prática de ato atentatório à incolumidade física ou psicológica do interditado ou curatelado, bem como à integridade do seu patrimônio (art. 300, § 2.º).

Caso o tutor, ou curador, não apresente contestação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos narrados na petição, aplicação analógica do art. 307 do CPC/2015.

3.2 Decisão e recurso

A decisão é interlocutória, sendo sujeita a agravo a ser interposto pelo curador ou tutor afastado, que poderá insurgir-se contra a decisão, pretendendo o retorno. No entanto, uma vez confirmado o afastamento (remoção) em sentença, Alcides de Mendonça Lima define que o recurso oponível é a apelação, fato que acaba por imputar natureza definitiva à decisão de afastamento do tutor ou curador responsável por ato de extrema gravidade.

Por fim, após possível peticionamento, atuação de ofício pelo magistrado, ou mera substituição de tutor/curador, o Ministério Público sempre terá de se manifestar, dado que sua atuação em demanda desta espécie é integral e inafastável. Após o afastamento realizado nos moldes deste dispositivo, o disposto nos novos artigos 760 e 761, será integralmente aplicado, posto que estabelece procedimento geral para o afastamento definitivo de tutor ou curador.

3.3 Nomeação do tutor ou curador interino e deveres

Na hipótese de suspensão, deverá o juiz nomear tutor ou curador interino, que, como próprio nome diz, será provisório, até que se tenha sentença determinativa quanto à remoção ou manutenção do nomeado originariamente, permanecendo os mesmos deveres e responsabilidades para o interino.

Art. 763. Cessando as funções do tutor ou do curador pelo decurso do prazo em que era obrigado a servir, ser-lhe-á lícito requerer a exoneração do encargo.

§ 1.º Caso o tutor ou o curador não requeira a exoneração do encargo dentro dos 10 (dez) dias seguintes à expiração do termo, entender-se-á reconduzido, salvo se o juiz o dispensar.

§ 2.º Cessada a tutela ou a curatela, é indispensável a prestação de contas pelo tutor ou pelo curador, na forma da lei civil.

1. Inovações do CPC/2015

De pronto, não se constata mudanças profundas na atualização do presente diploma processual. O silêncio do tutor ou curador, na hipótese de abertura de prazo para a manifestação quanto à continuidade do exercício do encargo, comporta em anuência à continuidade no exercício da função.

O § 2.º consistiu em acréscimo de prática que já se realizava após o afastamento de tutor ou curador, posto que tais atividades pressupõem a administração e gestão de bens de terceiros, como explanado no art. 762 já comentado. Embora outrora tal aplicação fosse mais indireta, considera-se como benéfica posituação da prestação de contas no novo diploma processual.

2. Aspectos materiais

Ao nomear tutor ou curador em juízo, o juiz pode estipular prazo para o exercício do encargo, sedimentando o entendimento de o exercício desta função não se dá necessariamente por período indeterminado. Não se estipulando expressamente o período do exercício do encargo, pressupõe-se que se dará pelo tempo de 2 anos, conforme combinação do presente dispositivo com o art. 1.765 do Código Civil de 2002, e art. 444 do Código Civil de 1916.

Ao prazo estipulado em juízo e ao aplicado em função do art. 1.765 do Código Civil constitui exceção o afastamento emergencial relatado no artigo anterior. Desconsiderada tal hipótese, o eventual afastamento ou pedido de exoneração do tutor ou curador se dá nos moldes aqui previstos.

Caso silente o tutor ou curador quando aberto ou prazo para sua manifestação, considera-se ocorrida recondução, que comporta impugnação mesmo após transcorrer do prazo caso existam motivos supervenientes e válidos para tanto.¹¹⁰⁴ Nesta recondução, a continuação do exercício da função não está temporalmente limitada, dispensando-se novo termo de compromisso, visto que se trata de documento já existente.

3. Aspectos processuais e procedimentais

Alcides de Mendonça Lima, assim como o dispositivo sob análise, ressalva a possibilidade do próprio titular pugnar em sede de petição por sua exoneração, pedido que deve ser realizado por intermédio de procurador com poderes especiais, dada a repercussão da matéria para o direito material. Seu prazo de manifestação, conforme consta, é de 10 dias.

Caso ocorrente a interposição e deferimento do pedido de exoneração,¹¹⁰⁵ o Ministério Público, dada a sua já mencionada atuação como fiscal da lei, deverá se manifestar no tocante a tal pedido.

Plenamente cabível, também, a promoção de pedido de afastamento após o transcorrer do prazo legal pelo Ministério Público. Neste espeque, a situação vislumbrada seria invertida, e cada parte envolvida recorrerá, utilizando-se da apelação, para alcançar seus objetivos.

3.1 Cessação da Tutela e da Curatela

O juízo competente para julgar o pedido é o da nomeação, sendo analisado em autos em apenso. Importante destacar que o pedido de exoneração poderá ser indeferido caso se verifique que o prazo determinado para o exercício do encargo é menor que o biênio legal (art. 1.765, do CC/2002), da mesma forma que, caso tenha sido determinado período maior que dois anos, poderá requerer sua exoneração, desde que tenha exercido o múnus pelo prazo mínimo legal.

Prevê-se o prazo de 10 dias, após verificada a hipótese de exoneração, para que a requeira, tanto o tutor, como o curador, sob pena de preclusão, já que há previsão expressa de recondução, caso corra *in albis*. Porém, não se deve interpretar e aplicar a lei com extremo rigor, pois, caso haja motivo relevante, que justifique a demora no requerimento, e esteja devidamente demonstrado, poderá o juiz analisá-lo e deferi-lo.¹¹⁰⁶ Até porque mesmo finalizado o prazo preclusivo de 10 dias para o requerimento da exoneração, podem surgir motivos supervenientes e relevantes que autorizem a formulação do pedido, que deve ser avaliado pelo juiz, com prévia manifestação do Ministério Público, cuja decisão há de ser calcada no princípio do melhor interesse do interditado ou curatelado. O silêncio, entretanto, não significa que o tutor, ou curador, será obrigatoriamente reconduzido, pois é faculdade do juiz aceitar, ou não, sua permanência, nos termos do parágrafo único do art. 1.765 do CC/2002.

3.2 Prestação de contas

Deferido o pedido de exoneração, exigirá, o juiz, ou o Ministério Público, a prestação de contas pelo tutor ou pelo curador (v. comentários ao art. 759, item 3.3.2).

3.3 Sentença e apelação

Se a petição é deferida, cabe apelação do Parquet; caso indeferida, o próprio titular poderá apelar do *decisum*.¹¹⁰⁷ Percebe-se, a partir desse registro, a mesma natureza definitiva ao ato que tanto afasta quanto mantém o tutor ou curador no encargo previsto.

Tal sentença, qualquer que seja, se sujeita aos mesmos riscos e meios de ser atacada por apelação. E como sentença, se sujeita a recurso de apelação (art. 724), obedecendo aos requisitos *intrínsecos* :

cabimento, legitimidade e interesse recursal e *extrínsecos* : tempestividade, regularidade formal e preparo. ¹¹⁰⁸ São legitimados aqueles que se habilitaram à herança e todos os interessados ou cointeressados.

Seção XI

Da organização e da fiscalização das fundações

1. Inovações do CPC/2015 na Seção

Não há inovações no conteúdo do título, porquanto somente se reordene o que se denominava *Capítulo* que a partir do CPC/2015 passa a ser denominado de *Seção* . Mantém-se o título sem mencionar toda a extensão material dos procedimentos que permitem, também, a extinção das fundações (art. 765).

2. Aspectos materiais gerais da Seção – Da organização e da fiscalização das fundações

Os procedimentos especiais se deixam influenciar demasiadamente pelo direito material, conjunto integrado pelas normas que criam e extinguem relações jurídicas, ponderando o lícito e ilícito, ao passo que o direito processual é o ramo do direito que tem, em geral, como finalidade assegurar, por meio de procedimentos, o cumprimento do direito material, quando não são prontamente cumpridos transformando-se em controvérsias (jurisdição contenciosa) ou sem solução de controvérsia (jurisdição voluntária). Em outras palavras, mesmo tratando-se de funções, finalidades e naturezas próprias, o direito processual está interligado ao direito material, realizando-o, influenciando-o conquanto instrumento de sua realização.

Observe-se que as instituições indicadas nos arts. 764 e 765 do CPC/2015 são fundações de natureza privada, definidas no art. 44, inc. II, do CC/2002, e delimitadas nos arts. 62 a 69 do mesmo Código, em Capítulo próprio, Das Fundações, Parte Geral, Livro I, Título II, Capítulo III. Antes de tratar sobre os aspectos processuais que envolvem as fundações, sua fiscalização e organização, deve-se partir do direito material que rege as fundações, a partir do CC/2002.

2.1 Espécies de pessoas jurídicas previstas no Código Civil

De acordo com art. 44 do CC/2002, são pessoas jurídicas de direito privado: as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos, e as empresas individuais de responsabilidade limitada.

As associações são as uniões de pessoas organizadas para fins não econômicos (art. 44, inc. I e art. 53, CC/2002) compostas pelos elementos, pessoal e patrimonial; as sociedades nascem com a celebração de contrato entre pessoas que se obrigam reciprocamente a contribuir com bens ou serviços para o exercício da atividade econômica e a divisão dos resultados (art. 44, inc. II, art. 53 e art. 981 CC/2002); as organizações religiosas abrangem todas as entidades religiosas, como pessoas jurídicas de direito privado, com liberdade de criação, organização, estruturação interna e funcionamento, vedando-se ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro (art. 44, inc. IV, CC/2002); os *partidos políticos* são organizações com princípios que orientam ação política, destinados a assegurar o regime democrático, direitos fundamentais e sistema representativo (art. 44, inc. V, CC/2002) e; por fim, as *empresas individuais de responsabilidade limitada* , nada mais são do que uma espécie de sociedade empresarial, porém com o fito de responsabilidade limitada do empresário individual, com riscos limitados diante do exercício empresarial individual (art. 44, inc. VI, CC/2002).

A *fundação* se assemelha à associação, mas sob prismas antagônicos; as fundações possuem os mesmos elementos integrativos das associações, pessoal e patrimonial, entretanto o enfoque patrimonial se sobrepõe ao pessoal, ocorrendo o contrário nas fundações.

Essa ampliação do objeto das associações torna ainda mais relevante o estudo de suas finalidades.

2.1.1 Das Fundações

O ordenamento jurídico prevê dois gêneros de fundações, as públicas e as privadas. Apesar disso, estas não se confundem. A fundação de direito privado é regida pelo Direito Civil e prevista no Código Civil, ao passo que a fundação de direito público é regida pelo Direito Administrativo, submetida a outros normativos legais que organizam a administração pública. ¹¹⁰⁹ Assim, distinguem-se as fundações públicas das fundações privadas pela forma como são criadas, pela opção legal de regime jurídico a que

se submetem, pela titularidade de poderes e também pela finalidade e natureza dos serviços por elas prestados.

A doutrina atual identifica as fundações privadas onde “há de início um patrimônio despersonalizado, destinado a um fim. Ao contrário das sociedades e associações, que são uma reunião de pessoas, uma coletividade, as fundações assentam sua razão de ser no patrimônio para certa finalidade”. ¹¹¹⁰

Também considera que “diferentemente das associações e das sociedades, as fundações resultam não da união de indivíduos, mas da afetação de um patrimônio, por testamento ou escritura pública, que faz o seu instituidor, especificando o fim para o qual se destina”. ¹¹¹¹

Assim a fundação somente é constituída com a sua personificação, isto é, após a aquisição de personalidade jurídica, daí passando a submeter-se aos precedentes de criação, fiscalização e extinção, ao contrário das associações e sociedades que não se submetem a tal controle.

Os requisitos para a criação decorrem da lei material, ou seja, do Código Civil, que estipulará a finalidade fundacional, a dotação patrimonial, a suficiência, a licitude e a determinação do negócio fundacional. ¹¹¹²

O CPC/2015, Lei 13.151/2015, acrescentou ao art. 62 do CC/2002, novas finalidades para as quais uma fundação poderá ser constituída, são elas: assistência social; cultura; defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; educação; saúde; segurança alimentar e nutricional; defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos; promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos e atividades religiosas.

O presente comentário restringe-se às fundações privadas, sua organização, fiscalização do funcionamento e extinção, sem nada afetar as demais pessoas jurídicas assemelhadas.

2.2 Espécies fundacionais submetidas à organização, fiscalização e extinção

Há uma variada diversidade de fundações privadas, nem todas submetidas à organização e fiscalização prevista na *Seção XII* (CPC, Parte Especial, Livro I, Título III), segundo a acurada obra e classificação de José Eduardo Sabo Paes: a) fundações instituídas por pessoas físicas e jurídicas; b) fundação instituída por empresa; c) fundação instituída por partido político; d) fundação de apoio à instituição de ensino superior; e) fundação de previdência privada ou complementar fechada. ¹¹¹³ - As fundações municipais de saúde ou para outros fins, dependem de leis desses entes estatais que autorizem tal criação, especialmente se fogem à natureza pública. ¹¹¹⁴

Dentre essas, apenas as fundações de previdência privada ou complementar fechada não se submetem ao modo de organização, de fiscalização ¹¹¹⁵ e de extinção, no sentido estrito aqui posto; ¹¹¹⁶ todas as demais se submetem, como dito, no sentido aqui posto, à organização, fiscalização e extinção pelo meio procedimental aqui descrito, sejam as fundações instituídas por pessoas físicas, jurídicas ou empresas, fundações instituídas por partido político ou fundações de apoio à instituição de ensino superior.

3. Aspectos processuais e procedimentais gerais da Seção

Os comentadores do CPC/1973, em sua maioria, ¹¹¹⁷ não destacaram que as regras contidas nos seis artigos referentes à *Organização e Fiscalização das Fundações* tratavam também de direito material. Ali estavam descritos atos materiais referentes à instituição e elaboração do estatuto (art. 1.199), submissão do estatuto ao Ministério Público (art. 1.200), autuação no Ministério Público, prazo para decisão e sujeição das alterações do estatuto ao Ministério Público (art. 1.203).

Mantêm-se no CPC/2015, nos dois artigos, algumas regras materiais, em menor escala que no CPC/1973, e normas processuais regentes do procedimento em que o interessado pode requerer a aprovação ou alterações estatutárias. Essa regra não impõe a todas as fundações privadas a chancela judicial, pois poderão livremente ter patrimônio estipulado e também organizarem-se sem o escrutínio judicial. ¹¹¹⁸

Art. 764 . O juiz decidirá sobre a aprovação do estatuto das fundações e de suas alterações sempre que

o requeira o interessado, quando:

I – ela for negada previamente pelo Ministério Público ou por este forem exigidas modificações com as quais o interessado não concorde;

II – o interessado discordar do estatuto elaborado pelo Ministério Público.

§ 1.º O estatuto das fundações deve observar o disposto na Lei 10.406, de 10.01.2002 (Código Civil).

§ 2.º Antes de suprir a aprovação, o juiz poderá mandar fazer no estatuto modificações a fim de adaptá-lo ao objetivo do instituidor.

1. Inovações do CPC/2015

Inova razoavelmente o CPC/2015 na Organização e Fiscalização das Fundações, especialmente por retirar a parte que tratava de direito material, afeta desde 2002 ao Código Civil (arts. 62-69). Embora parecesse óbvia a destinação de cada matéria a um Código, muitas vezes o Código de Processo Civil adentra ao direito material e ao Código Civil ao processo, criando até mesmo impropriedades embaraçosas.

Desta vez o CPC/2015 toma o cuidado de não trazer, nesta parte, como outrora, regras de puro direito material, mas faz isso com certo constrangimento, ao ponto de introduzir um § 1.º no art. 764, completamente desnecessário, para dizer que: “o estatuto das fundações deve observar o disposto na Lei 10.406/2002 (Código Civil)”. Não poderia, por certo, ser de outro modo; o estatuto das fundações deve obedecer ao que determina a lei material civil e de modo mais específico ao Código Civil.

2. Aspectos materiais das Fundações e de sua fiscalização e organização

Nesse tópico serão reescritas as fundações e os aspectos principais de sua criação, incluindo seus estatutos.

2.1 Fundações privadas

Conceitua-se fundação como a reunião de bens destinados à consecução de finalidades sociais, previamente estipuladas pelo instituidor, por meio de escritura pública (*inter vivos*) ou de testamento (*mortis causa*), dotada de personalidade jurídica e, como observa José Eduardo Sabo Paes “é instrumento efetivo para que os homens prestem serviços sociais e de utilidade pública diretamente a todos aqueles que necessitam, bem como possam transmitir às sucessivas gerações seus ideais e convicções, e seguir atuando”. ¹¹¹⁹

Ou ainda, é a atribuição de personalidade jurídica a um patrimônio, que a vontade humana destina a uma finalidade social. ¹¹²⁰ É um acervo de bens, que recebe da ordem legal a faculdade de agir no mundo jurídico e realizar as finalidades idealizadas pelo seu instituidor. ¹¹²¹

O Código Civil no art. 62 estabelece as condições para a criação das fundações e no parágrafo único, as finalidades. ¹¹²² Em linhas gerais, a criação de uma fundação está ligada à disposição de determinada parcela do patrimônio pessoal do instituidor, podendo ser composta de bens móveis e imóveis, conforme fim específico.

Em outras palavras, a instituição de uma fundação está ligada e/ou condicionada, diretamente, à vontade do seu instituidor. No entanto, embora essa criação esteja vinculada a uma destinação expressa dos bens, há ainda, as hipóteses de silêncio do instituidor ou de inexecuibilidade da sua vontade, quanto à insuficiência de bens. Há autor que, baseado na moderna doutrina alemã, distingue o conceito de “fim da fundação” e “objeto” ou “objeto social”, sendo este último o modo ou meio para atingir o fim. ¹¹²³ Como cabe ao juiz a interpretação dos objetivos, tal distinção pode ganhar importância.

Nesse sentido, o art. 63 do CC/2002 prevê a possibilidade no caso de insuficiência dos bens destinados à criação da fundação, estabelecendo que o patrimônio já destinado deverá ser incorporado em outra fundação com semelhante ou igual fim.

2.2 Criação das fundações privadas

A criação de uma entidade é decorrente da averbação dos atos constitutivos no registro adequado,

condição para a obtenção de personalidade jurídica, conforme preceitua o art. 45 do CC/2002.

O ato constitutivo, necessariamente formalizado por escrito, no caso das fundações, chamado de estatuto ou, ainda, segundo José Eduardo Sabo Paes de ato fundacional será realizado por quem queira ou tenha o dever de fazer essa declaração de instituir uma fundação, ¹¹²⁴ por intermédio de escritura pública (inter vivos) ou de testamento (*mortis causa*).

Especificamente, para as fundações há momentos específicos de criação, quais sejam o da instituição com o registro da escritura pública ou do testamento no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, de natureza constitutiva, e ainda o da personificação gerada com a aprovação do registro do estatuto pelo Ministério Público, de natureza declaratória.

2.2.1 Estatuto fundacional

O estatuto é o esqueleto, espécie de regimento interno, fundamental e norteador da organização e funcionamento da fundação.

Para Caio Mário da Silva Pereira, trata-se de lei interna, designa a aplicação do patrimônio pelas pessoas estipuladas pelo instituidor, sob a luz de sua vontade.

Nota-se, o estatuto serve como ferramenta fundamental a disciplinar a maneira como a fundação atuará no exercício de suas atividades, como será sua composição interna, designando os poderes dos dirigentes.

Inclusive, neste ponto, aplica-se, concomitantemente, a Lei 6.015/1973, Lei de Registros Públicos, a qual estabelece, especificamente, requisitos obrigatórios e facultativos do estatuto, para fins de registro das fundações, arts. 120 e 121. ¹¹²⁵

O Código Civil, nos arts. 67 e 68 preveem condições para a alteração do estatuto, dentre as quais, a deliberação por dois terços dos competentes para gerir e representar a fundação, desde que não contrarie ou desvirtue o fim para o qual foi criada, e a aprovação pelo Ministério Público, no prazo máximo de 45 dias; no caso de denegação há a possibilidade de supri-la judicialmente, desde que requerido pelo interessado.

2.2.1.1 Da estrutura fundacional

A fundação, no exercício de suas funções, é realizada por meio de órgãos, devidamente previstos em sua escritura pública, pré-definindo as competências, atribuições e composição, forma de manifestação de vontades e exercício de poderes. Precipuamente, como função, esses órgãos controlam o patrimônio em consonância com a finalidade. Pontes de Miranda define que na fundação falta a pluralidade de pessoas, não há a figura dos sócios, como nas sociedades, e ainda, que são os membros, ocupantes dos órgãos ou estrutura jurídica, que figuram na administração da entidade. ¹¹²⁶

Ainda, acerca dos membros integrantes dos órgãos, em princípio, por meio de mandato, permitida a reeleição ou recondução ao mesmo cargo, sem remuneração, em virtude da natureza social nas finalidades desenvolvidas.

A ausência destes participantes e a finalidade social da dotação patrimonial mostram a fiscalização do Ministério Público, como será exposto a seguir.

2.3 O Ministério Público

Primeiramente, cumpre destacar previsão na Constituição Federal de 1988, o Ministério Público é instituição permanente atuante em defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, além de lhe conferir a titularidade para o ajuizamento de ação civil pública em busca da proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. ¹¹²⁷

O CPC/2015 prevê a atuação do Ministério Público como fiscalizador do fiel cumprimento do estatuto, em defesa do cumprimento das finalidades definidas e da destinação do patrimônio constituído. Entretanto, incumbe, também, àquele órgão a aprovação do estatuto elaborado pelo interessado, sugerir modificações ou desaprová-lo.

A competência para fiscalização é do Ministério Público Estadual ou do Distrito Federal onde situada a

fundação. O art. 66 do Código Civil, modificado pela Lei 13.151, de 28.07.2015, atribuiu nova competência para a fiscalização das fundações situadas no Distrito Federal e Territórios, transferindo o encargo do Ministério Público Federal para o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.¹¹²⁸ Admite-se também a legitimidade do Ministério Público Federal na fiscalização de fundações privadas instituídas por entes públicos da União,¹¹²⁹ excluindo-se, contudo os Tribunais de Contas.¹¹³⁰

3. Aspectos processuais e procedimentais

O juiz na jurisdição voluntária atua de modo e em limites diversos daqueles previstos para a jurisdição contenciosa, como descrito no *Breve Ensaio Inicial* e em diversos procedimentos típicos (arts. 726-770) ou nominados (art. 725).

3.1 Atuação jurisdicional posterior à atuação do Ministério Público

O art. 764, sem correspondente no CPC/1973, prevê duas hipóteses de atuação jurisdicional, ambas *contra* “ato administrativo” do Ministério Público. Haverá a incitação judicial, pelo interessado, quando o estatuto for denegado, total ou parcialmente, pelo Ministério Público, ou ainda, quando o interessado não concordar com o estatuto elaborado mediante a apresentação de petição inicial motivada.

Segundo Pontes de Miranda, o interessado ao instar o juiz a manifestar-se, quer seja pela negativa de aprovação total do estatuto, quer seja pela aprovação parcial, busca o suprimento da aprovação,¹¹³¹ conforme a expressa redação do § 2.º, do art. 764. De acordo com este § 2.º, do art. 764, antes de suprir a aprovação, não convencido, o juiz poderá determinar diligências a fim de sanar eventuais dúvidas quanto ao objetivo para o qual foi criada a fundação, e ainda determinar modificações no intuito de adaptar o estatuto ao fim almejado pelo instituidor.

O juiz ao avaliar o pedido do interessado, decidirá com base na vontade do instituidor, e julgará autorizando a constituição do negócio jurídico fundacional.

A sentença, de natureza constitutiva, aprovará o estatuto elaborado pelo instituidor, por quem foi designado, ou ainda pelo Ministério Público. Do comando judicial que aprova ou denega o estatuto cabe apelação, sendo legitimado a recorrer os interessados, inclusive o Ministério Público.

3.2 A diversidade da atuação do Ministério Público nas Fundações

Além da atuação extrajudicial do Ministério Público nas etapas de elaboração do Estatuto da Fundação, na qual tem o encargo de “aprovar como autoridade competente” (art. 65 do CC/2002), incumbindo-lhe diversas possibilidades de intervenção procedimental, como parte ou como fiscal da ordem jurídica,¹¹³² desde a sua criação ou organização, nas alterações estatutárias e na extinção.

Quanto à atuação judicial, o Ministério Público poderá fazê-lo de forma ativa, como parte autora, ou como fiscal da ordem jurídica, velando pela correta administração, possuindo como meios jurídicos de proteção aos interesses difusos e coletivos: a) ação de execução por quantia certa contra devedor solvente, b) ação declaratória de ineficácia de escritura pública ou testamento, c) ação de extinção de fundação, d) ação de responsabilidade civil contra dirigente causador de dano à fundação, e) ação de destituição de dirigente, f) g) ação civil pública, relacionados ao objeto das fundações,¹¹³³ valendo-se para isso de todas as espécies de tutela que o CPC/2015 e a legislação esparsa oferecem, sejam tutelas condenatórias, mandamentais ou executivas lato sensu.

O Ministério Público intervirá nos casos previstos no art. 178 do CPC/2015. Conforme prevê, o art. 180 terá o prazo em dobro para manifestar-se nos autos, contado da sua intimação pessoal, findo o qual, e ausente a manifestação ministerial, o juiz dará andamento ao processo. A ausência do Ministério Público nos casos em que se considere obrigatória a sua manifestação, gera nulidade sujeita a recursos e ações impugnatórias autônomas.

3.3 Legitimidade dos interessados

São legitimados a atuarem como interessados no plano processual aqueles que no plano material têm ou teriam função estabelecida pelo instituidor na aplicação do patrimônio, no zelo, e na fiscalização, no cuidado (art. 65 CC/2002).

3.4 Competência

A competência é em geral das Varas Cíveis da justiça comum estadual e do Distrito Federal e não das varas de Registros Públicos, nem mesmo nos casos que envolvam a declaração de ineficácia de escrituras públicas ou de testamentos. ¹¹³⁴

3.5 Petição inicial

A petição inicial é regulada pelo arts. 319 e 320, e o procedimento aqui previsto nos arts. 720 a 724, ambos do CPC/2015. Momento em que será avaliado e controlado pelo juiz a legalidade, a conveniência e a oportunidade dos atos praticados pelo Ministério Público, na função de zelador da fundação. E ainda, analisando os critérios impostos no art. 62 do CC/2002, referente à sua organização e à aplicação da finalidade para a qual foi destinada, bem como se os bens destinados estão corretamente designados.

3.6 Recurso da sentença e remessa necessária

O cabimento da apelação está consagrado desde o CPC/1973 (art. 724), recorribilidade está associada à sucumbência ou ao prejuízo, sem o que não se cogita de recursos contra decisões judiciais. Há também a possibilidade de remessa necessária, art. 496 do CPC/2015, sendo sucumbente ou condenada a Administração Pública. Para isso devem estar presentes no procedimento especial de jurisdição voluntária algum ou alguns dos entes indicados no inc. I do referido dispositivo: a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, observadas, contudo, as limitações quantitativas do § 3º do mesmo artigo, incs. I, II e III, além daquelas restritivas de reexame contidas no § 4º do mesmo art. 496.

Art. 765 . Qualquer interessado ou o Ministério Público promoverá em juízo a extinção da fundação quando:

- I – se tornar ilícito o seu objeto;
- II – for impossível a sua manutenção;
- III – vencer o prazo de sua existência.

1. Inovações do CPC/2015

Não há alteração no conteúdo do dispositivo, sendo suprimida apenas a expressão “órgão” em relação ao Ministério Público e mantendo-se, no mais, quase idêntico o art. 765 neste CPC/2015 ao seu correspondente art. 1.204 do CPC/1973.

2. Aspectos materiais

A norma tem conteúdo material e processual.

Quando trata da possibilidade de extinção, refere-se ao direito material e a todas as consequências advindas da extinção de um ente criado para determinado fim a partir de um patrimônio, conceito coincidente com o de fundação privada.

Quando indica a possibilidade de extinção por via judicial, dizendo quem são os sujeitos que podem formular tal pedido, trata de legitimidade e, portanto, de processo.

2.1 A extinção da fundação

Como qualquer extinção de uma pessoa jurídica, a extinção da fundação nada mais é do que a exclusão da pessoa jurídica de direito privado “mundo” jurídico, acarretando a liquidação do seu patrimônio.

Em verdade, o art. 765 deve ser interpretado concomitantemente com o art. 69, do CC/2002, o qual determina que com a extinção da fundação, o seu patrimônio será destinado à outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante, designada pelo juiz; não se admitindo destinação diversa daquela prevista em lei. ¹¹³⁵

Consoante o art. 69 do CC/2002, são causas de extinção da fundação, quando esta se torna “ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação, ou vencido o prazo de sua existência”.

Ademais, lembra José Eduardo Sabo Paes, que “por ser a extinção de uma fundação um fenômeno jurídico e social, em razão das finalidades afetadas ao seu patrimônio, cabe ao próprio Estado, por meio de órgão do Ministério Público, competente, verificar se existem situações de fato e de direito a justificarem a supressão dessa pessoa jurídica. Mesmo porque cabe ao Ministério Público – como autoridade competente – sempre que entender que a extinção é inconveniente, encontrar maneiras dentro do seu poder de velamento, de alterar a administração, destituir administradores, reforçar ou reconstituir o patrimônio ou até permitir uma adequação aos fins para que a entidade possa sobreviver”.
¹¹³⁶

Há a possibilidade de extinção administrativa, deliberada por *quorum* especial, devidamente motivada, e ainda com o aval do Ministério Público.

3. Aspectos processuais e procedimentais

O legislador foi claro ao prever que o interessado ou Ministério Público são legitimados para pleitearem a extinção da entidade, condicionando o pedido da extinção da fundação, quando esta se tornar ilícito seu objeto, for impossível a sua manutenção, ou vencer o prazo de sua existência.

3.1 A legitimidade de qualquer interessado

Identicamente ao procedimento para aprovação ou alterações no estatuto da fundação, são legitimados a atuarem como interessados no plano processual para a extinção da fundação aqueles que no plano material têm ou teriam função estabelecida pelo instituidor na aplicação do patrimônio, no zelo, na fiscalização, no cuidado (art. 65 CC/2002). As razões descritas no dispositivo, a justificar a extinção: se tornar ilícito o seu objeto (art. 767, inc. I); II – for impossível a sua manutenção (art. 767, inc. II); se vencer o prazo de sua existência (art. 767, inc. III) podem ampliar a legitimação de interessados a sujeitos que possuam em seus deveres contratuais, estatutários ou mesmo institucionais os de zelo aos preceitos violados.

3.2 A legitimidade do Ministério Público

De forma expressa é mantida também a legitimidade ativa do Ministério Público para o procedimento de extinção das fundações. Se não atuar como autor, por seus membros, o Ministério Público intervirá nos casos previstos no art. 178 do CPC/2015, atuando, com as prerrogativas do art. 180, tendo prazo em dobro para manifestar-se nos autos, contado da sua intimação pessoal, findo o qual, e ausente a manifestação ministerial, o juiz dará andamento ao processo. A ausência do Ministério Público nos casos em que se considere obrigatória a sua manifestação, gera nulidade sujeita a recursos e ações impugnatórias autônomas.

Outra questão é a desnecessidade de dois representantes do Ministério Público, que pode ser parte e/ou fiscal da ordem jurídica. Quando atua como parte não necessita de um membro para um fim e outro membro para outro fim; basta um que além de fiscal o mesmo membro represente o interesse social tutelado.
¹¹³⁷

3.3 Petição inicial

Como na situação antecedente, art. 764, para aprovação ou alterações no estatuto da fundação, neste caso da extinção, a petição inicial é regulada pelos mesmos arts. 319 e 320, e o procedimento previsto nos arts. 720 a 724, todos do CPC/2015.

Nesta oportunidade será avaliada a pertinência do requerimento do Ministério Público ou do interessado que propõe a extinção da fundação. As hipóteses elencadas no art. 69 do CC/2002, ilicitude, impossibilidade e inutilidade e vencimento do prazo coincidem parcialmente com as que agora trazem o art. 765 e incisos. O descompasso é apenas na hipótese de *inutilidade da fundação*, que embora ausente do CPC/2015, é fundamento suficiente à extinção, porquanto presente no CC/2002.

3.4 A prova das razões da extinção

Incumbe ao requerente a demonstração de suas alegações, tanto sendo um pedido do Ministério Público ou de outro interessado. Trata-se de um ônus, que não atendido, pode resultar na improcedência do pedido ou, substitutivamente, na iniciativa probatória estendida do juiz que pode diligenciar.

Já foi dito anteriormente que nos procedimentos de jurisdição voluntária ampliam-se sobremaneira

os poderes do juiz sob justificativas lógicas, que se ajustam com o interesse estatal em manter sob o seu exame (Estado) certas *questões da vida privada* abarcadas pela jurisdição voluntária. O juiz da jurisdição voluntária não conhece outra *verdade* que não a *verdade* do interessado e, por isso, ganha mais amplos poderes instrutórios, em contrapartida aos estímulos que o processo em contraditório (contencioso) possui e lhe proporciona.

Vários são os motivos encontráveis na jurisprudência, tais como desvio de finalidade, irregularidades na prestação de contas, ausência de receita, inviabilidade de efetivo exercício das atividades previstas no estatuto.¹¹³⁸

3.5 O procedimento voluntário e o risco de contenciosidade

O dispositivo indica que a atuação do Ministério Público e dos demais interessados pode conduzir à confrontação de alegações e à contenciosidade que desviam o processo da jurisdição voluntária e o encaminham a uma diversidade de procedimentos comuns ou especiais.

3.6 A destinação do patrimônio, cumprimento e execução

Deve-se dar ao patrimônio da fundação o destino constante da vontade do instituidor ou aquele que a lei prevê, podendo tal questão tornar-se parte do objeto da decisão judicial e mesmo fazer com tal debate avançar ao âmbito da contenciosidade. Essa questão integra, necessariamente, a inicial e a eventual manifestação dos demais interessados chamados ao processo, assim como do Ministério Público, demandando prova que pode se estender à prova técnica pericial e deve integrar a decisão final, a sentença. Nestes casos, pode-se cogitar de cumprimento da decisão, que corresponda à entrega da posse ou propriedade de bens, com sua correspondente transmissão e até mesmo a execução da decisão para a satisfação dos destinos previstos pelo instituidor ou pela lei.

3.7 A sentença que extingue a fundação e a recorribilidade por apelação

São recorríveis por apelação as sentenças da jurisdição voluntária (art. 724) e assim será também a sentença deste procedimento especial que sirva tanto a apreciação dos estatutos, da fiscalização ou mesmo de extinção das fundações. A recorribilidade está associada à sucumbência ou ao prejuízo, sem o que não se cogita de recursos contra decisões judiciais.

Seção XII

Da ratificação dos protestos marítimos e dos processos testemunháveis formados a bordo

1. Inovações do CPC/2015 na Seção

O retorno de determinados procedimentos especiais ao CPC é uma inovação do CPC/2015 em relação ao CPC/1973, que optara por manter vigente parte do CPC/1939 (arts. 725-729) e parte dos “processos especiais” não reproduzidos em 1973. São exemplos dessa técnica legislativa a *Ratificação dos Protestos Marítimos e a Ratificação dos Processos Testemunháveis Formados a Bordo*, além de procedimentos de jurisdição contenciosa, como a *Ação de Dissolução Parcial de Sociedades* e a *Regulação de Avaria Grossa*. Parte daqueles procedimentos marítimos não foram extintos com o CPC/1973, de forma que continuaram sendo utilizados em casos concretos e reconhecidos pela jurisprudência, com amparo no inc. VIII do art. 1.218,¹¹³⁹ sem qualquer alteração quanto ao Código antecedente (CPC/1939).

Cria-se agora, no CPC/2015, um *Capítulo* e uma *Seção* próprios para tais procedimentos marítimos considerados relevantes, que seguirão procedimento especial, restando ao procedimento comum todos os demais pedidos que envolvam o Direito Marítimo¹¹⁴⁰ e ao Direito da Navegação¹¹⁴¹ que, por sua vez, aqueles procedimentos que se coligam ao Direito Portuário, Direito Aduaneiro, disciplinas que às vezes se inter-relacionam e se confundem.

Com isso a Ratificação dos Protestos Marítimos e os Processos Testemunháveis Formados a Bordo não seguirão o procedimento especial de jurisdição voluntária estabelecido para os demais protestos dos art. 726, § 2.º (Seção II, Capítulo XV, Título III, Livro I, Parte Especial), transposto junto com as notificações e interpelações do Livro do Processo Cautelar do CPC/1973 para este Livro I da Parte Especial. Fatos acontecidos a bordo de embarcações possuem evidente peculiaridade, além da importância econômica e jurídica a ponto de serem regidos pelas leis próprias do comércio e da navegação, sujeitos à proteção legal e à regulação estatal, seja direta, pela fiscalização, ou regulatória, pelas agências próprias.

O projeto do Novo Código Comercial, em tramitação legislativa na Câmara dos Deputados desde 2011, não mencionava o Direito Marítimo e o Direito da Navegação na versão original, assim como os procedimentos marítimos previstos no CCom/1850.¹¹⁴²

2. Aspectos materiais gerais da Seção – Da ratificação dos protestos marítimos e dos processos testemunháveis formados a bordo

Antes que sejam examinados os aspectos processuais, deve-se abordar o substrato material que está contido nos procedimentos especiais relativos à Ratificação dos Protestos Marítimos e aos Processos Testemunháveis Formados a Bordo. Como dito, há matérias afetas ao *Direito Marítimo*, com regras de navegação e comércio marítimo, fluvial e lacustre, relações de pessoas e bens, que abarcam direito público, direito privado interno e o direito internacional; e ao *Direito da Navegação*, relacionado ao tráfego, segurança, sinalização, vias, que abarcam normas de Direito Público interno e internacional e que se relacionam com outras áreas do direito público e privado, material e processual, tais como trabalhista e contratual, infortunistico e responsabilidade civil.

2.1 O Código Comercial e o comércio marítimo

Duas são as razões de diferenciação procedimental entre a Ratificação dos Protestos Marítimos e os Processos Testemunháveis Formados a Bordo, *primeiro* a especificidade material contida neles e o zelo com tal conteúdo especialmente afeto ao direito probatório e, *segundo*, a importância econômica e regulatória da matéria de Direito Marítimo, de Direito da Navegação e Direito Portuário. A finalidade central do procedimento especial é probatória e esse direito material à prova exsurge e é dado àqueles que possuam interesse processual em demonstrar pelos meios possíveis e legais a ocorrência de fatos que são de seu interesse material.

O Código Comercial, Lei 556, de 25.06.1850 (CCom/1850), mantém-se ainda vigente na sua *Parte Segunda (Comércio Marítimo)*, tendo sido revogadas a *Parte Primeira (Do Comércio em Geral)* e a *Parte Terceira (Quebras)*; nessa *Parte Segunda*, arts. 500, 501, 502 e 503, local em que estão indicadas as obrigações de “ter escrituração regular de tudo quanto diz respeito à administração do navio” (art. 501), registros esses que devem ser feitos em três livros próprios, sendo o *primeiro*, Livro de Carga, com registros de entradas e saídas, números, marcas e quantidades, carregadores e consignatários, portos, fretes “e quaisquer outras circunstâncias ocorrentes que possam servir para futuros esclarecimentos”, além do registro de passageiros e circunstâncias relativas a esse transporte (art. 502); *segundo*, Livro de Receita e Despesas da Embarcação, com conta corrente de tudo o que receber e despende, assim como os gastos individuados da tripulação (art. 503); *terceiro*, Livro Diário da Navegação, com assento diário dos trabalhos enquanto estiver aportado, consertos e reparos, assim como as “derrotas de viagem (...) e todas as ocorrências interessantes à navegação, acontecimentos extraordinários que possam ter lugar a bordo (...), especialidade os temporais, e os danos ou avarias que o navio ou a carga possam sofrer” (art. 504).

Cabe ainda ao capitão inventariar, antes da partida, os artigos essenciais à navegação e suas alterações durante a viagem (art. 506 CCom/1850), não abandonar o navio, salvo no caso extremo de naufrágio, quando deve salvar preferencialmente papéis e livros, dinheiro e mercadorias de maior valor (art. 508 CCom/1850).

Exemplo de reflexos no plano comercial, de transporte ou tributário pode ser identificado na jurisprudência, a partir do procedimento de ratificação de protesto marítimo. Em casos específicos, o legislador conferiu ao transportador a possibilidade de eximir a sua responsabilidade mediante protesto formado a bordo do navio e ratificado pela autoridade judiciária competente, preenchidos alguns requisitos que serão abordados neste capítulo, de forma que o mesmo não seria obrigado a pagar o tributo ou prestação pecuniária naquele caso concreto.¹¹⁴³

Com o advento do Dec.-Lei 2.472/1988 que alterou a redação do inc. II do art. 32 do Dec.-Lei 37/1966,¹¹⁴⁴ que dispõe sobre imposto de importação, reorganiza os serviços aduaneiros e dá outras providências, é possível responsabilizar tributariamente o comandante de navio que transporta cargas importadas do estrangeiro, em razão dos arts. 121¹¹⁴⁵ e 128¹¹⁴⁶ do Código Tributário Nacional. As eventuais derrotas marítimas causadoras de perdas de mercadorias somente são provadas pela confirmação dos documentos e registros da navegação que revelam a importância da recuperação legal destes procedimentos especiais de jurisdição voluntária.

2.2 Conceito de Protesto Marítimos e seus aspectos materiais

O protesto marítimo é ato escrito e registrado no *Livro da Navegação* do navio com a finalidade de comprovar acontecimentos ocorridos durante a expedição marítima que tenham relações com a própria embarcação, passageiros, tripulantes e com a carga que estava transportando.

Portanto no protesto estarão discriminadas as justificativas de eventuais acidentes, assim como as circunstâncias em que eles ocorreram e seus resultados em caso de avarias (tanto no navio quanto na carga), tempestades, arribadas, que forçaram o comandante a tomar atitudes diferentes daquelas habituais e estabelecidas em contrato de transporte e que poderiam resultar ou não em dever de indenização, com o condão de afastar a responsabilidade de capitão em casos fortuitos ou de força maior.¹¹⁴⁷

Em tais casos, ainda, cabe ao comandante seguir de acordo com o que preconiza o art. 509 do CCom/1850, de forma a organizar uma junta composta por todos os oficiais da embarcação e pelos interessados no navio ou na carga, caso estes estiverem a bordo, antes de tomar as atitudes que possam causar danos ou desviar as rotas pelas quais ele estaria obrigado a seguir. Todavia, caso discorde das deliberações da junta, poderá o comandante, por sua própria responsabilidade pessoal utilizar seu voto de qualidade sempre que achar conveniente.¹¹⁴⁸

2.3 As avarias e os sinistros ratificáveis e testemunháveis

Deve-se observar que esta *Seção* trata exclusivamente de institutos jurídicos afetos ao Direito Comercial e ao comércio marítimo, contendo conceitos não identificados diretamente no Direito Civil e no Direito Processual Civil. São específicas do Código Comercial Brasileiro e do Direito Marítimo os incidentes passíveis de responsabilização do capitão da embarcação, entre os mais comuns: (a) avaria; (b) arribada; (c) borrascas; (d) alijamento, (e) abalroação; (f) abandono; e (g) naufrágio.¹¹⁴⁹

Por serem o objeto material da prova a ser ratificada ou formada, cumpre brevemente distingui-los e conceituá-los da seguinte forma:

A) Avaria: definida no art. 761 do CCom/1850, engloba todas as despesas extraordinárias ou danos causados, tanto no navio quanto na carga ou em ambos, desde o embarque e a partida até a volta e desembarque.¹¹⁵⁰ Esse conceito é dividido em simples (ou particulares) e grossas (ou comum).

A1) Avaria Simples ou particular: prevista no art. 766 do CCom/1850, é aquela cuja a “vontade humana não intervém para resguardar interesses relativos ao navio ou à carga; decorrem de casos fortuitos ou de força maior, de imprudência, imperícia ou negligência, de dolo do comandante, equipagem ou empregados do armador, ou até de terceiros”.¹¹⁵¹ Nesses casos, somente a parte que sofre o dano arca com as despesas, possibilitando uma ação de regresso posteriormente.

A2) Avaria Grossa ou comum: prevista no art. 764 do mesmo dispositivo legal e que ocorrem em razão da vontade do comandante ou da Junta de Deliberação para fins de bem comum, em caso de perigo ou desastre imprevisto. Nesses casos, todos os interessados na viagem deverão contribuir com a indenização e reparação do dano.

B) Alijamento: previsto nos arts. 769-770 do CCom/1850 é ato voluntário de *despejo* ou *lançamento* de carga ao mar, que poderá ser considerado avaria grossa ou não, dependendo se este tiver o fim de beneficiar todos da embarcação.

C) Arribada: termo empregado para os procedimentos das situações descritas nos arts. 505, 512 e 743 do CCom/1850, em que o navio entra em um porto não previsto nas escalas preestabelecidas, ou quando o mesmo retorna ao porto de partida sem terminar a sua viagem, de forma forçada ou voluntária, causando despesas.

C1) Arribada Forçada: prevista nos arts. 740 a 748 do CCom/1850 e nos arts. 772 a 775 do CPC/1939, é espécie de ocorrência na expedição marítima que se dá por caso fortuito ou de força maior alheio à vontade do comandante, que é obrigado a mudar o roteiro da viagem,¹¹⁵² entrando em porto ou lugar diferente dos previstos na viagem. Se feita de forma justificada, entende-se que as despesas ocasionadas deverão ser custeadas pelo fretador, ou afretador. Considera-se como uma avaria grossa.¹¹⁵³

C2) Arribada Voluntária: ainda que ação tomada por vontade do capitão, por justificativa que não as expostas no Código Comercial Brasileiro, tem que seguir os procedimentos do mesmo e o comandante será o responsável pelas despesas.

D) Borrascas: são as tempestades, temporais e furacões que, apesar do avanço tecnológico e da engenharia naval, ainda são capazes de estremecer a estrutura da embarcação, apesar de ser muito difícil de causarem danos relevantes no navio ou na carga. ¹¹⁵⁴

E) Abalroação: prevista nos arts. 849-752 do CCom/1850 é o choque entre embarcações capaz de causar dano a este ou à carga.

F) Abandono: previsto nos arts. 753-760 do CCom/1850 consiste em deixar ou livrar-se dos objetos segurados sem perder o seguro em situações previstas na lei comercial tais como a apreensão por potência estrangeira, “naufrágio ou varação”, perda ou deterioração de $\frac{3}{4}$ do objeto segurado e falta de notícia do navio de transporte; há outras exigências para admitir-se o abandono e garantir a cobertura do seguro da carga.

G) Naufrágio e salvados: os arts. 731-739 do CCom/1850, que tratavam parcialmente da matéria foram expressamente revogados pela Lei 7.542/1986, que passou a regular a matéria, conforme art. 1.º. ¹¹⁵⁵ Não define mais a lei o que seja o naufrágio, mas os efeitos deste seguem sendo parcialmente regulados pela *Parte Segunda (Do Comércio Marítimo)*.

Todos esses eventos e outros não detalhados podem ser objeto dos protestos marítimos e dos processos testemunháveis, obedecendo para registro e ratificação as leis e regulamentos próprios do Direito Marítimo, servindo o processo civil como suporte confirmatório.

Art. 766 . Todos os protestos e os processos testemunháveis formados a bordo e lançados no livro Diário da Navegação deverão ser apresentados pelo comandante ao juiz de direito do primeiro porto, nas primeiras 24 (vinte e quatro) horas de chegada da embarcação, para sua ratificação judicial.

1. Inovações do CPC/2015

A redação do art. 766 guarda semelhança com o art. 727 do CPC/1939, ¹¹⁵⁶ ao estipular o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que o comandante apresente ao juiz de direito mais próximo, o protesto ou o processo testemunhável, tendentes a comprovar sinistros ou avarias ou quaisquer perdas na embarcação, para a sua ratificação, sob pena de seu indeferimento. ¹¹⁵⁷ O prazo é decadencial.

Ainda seguindo o CPC/1939, o protesto deverá ser apresentado juntamente com o Diário da Navegação, visto que este possui a finalidade de “autenticar a existência do protesto, para que ele não seja forjado *a posteriori*”, ¹¹⁵⁸ o que corrobora com a nova sistemática procedimental do CPC/2015.

2. Aspectos materiais

O Decreto 87.648/1980 no Capítulo XIV, que trata *Dos Deveres do Capitão e dos Tripulantes*, estabelece no art. 141 que entre os diversos deveres do Capitão está o de “ter a escrituração de tudo quanto diz respeito à administração e à navegação da embarcação, empregando, para esse fim, os livros estabelecidos na legislação em vigor” (art. 141, inc. XXVII); e, principalmente, “ratificar dentro de 24 horas úteis, depois da entrada, perante a autoridade competente do primeiro porto, e tendo presente o Diário da Navegação, todos os processos testemunháveis e protestos formados a bordo, tendentes a comprovar sinistros, avarias, perdas ou arribadas (art. 141, inc. XXVI). O art. 766 é expresso a impor que todos os protestos marítimos e os processos testemunháveis, com qualquer conteúdo, desde que lançados no Livro da Navegação, sejam apresentados pelo comandante ao juiz.

2.1 O objeto material dos protestos e dos processos testemunháveis

Os procedimentos de *Ratificação dos Protestos Marítimos* e dos *Processos Testemunháveis Formados a Bordo* têm como matéria central os fatos da navegação. O *processo testemunhável formado a bordo*, se refere, propriamente, à necessidade de registro documental dos fatos considerados relevantes que venham gravados no Diário da Navegação, que devem transpor-se a outros autos, caso houver impossibilidade de o livro sair da embarcação, para servir de prova. O protesto em si apresenta as justificativas dessas deliberações feitas, visto que o fretador, a princípio, tem culpa presumida na verificação de avaria, de ordem objetiva imprópria, com a inversão do ônus da prova. ¹¹⁵⁹

Neste diário deverão constar todos os assentos das deliberações dos oficiais da embarcação, os fatos e ocorrências inerentes ao transporte, principalmente aquelas extraordinárias que ocasionaram danos no navio ou na carga durante a expedição marítima. ¹¹⁶⁰

Desse modo, esse registro tem a finalidade de apontar a real responsabilidade do Comandante que tomou as decisões ou dos demais oficiais da embarcação, em caso de danos causados em face de vício na própria carga, defeito no navio, irresponsabilidade do transportador ou caso fortuito ou de força maior ¹¹⁶¹ que consubstanciaram no inadimplemento do contrato. ¹¹⁶²

O processo de registro tem natureza quase notarial, uma vez que não há juízes de direito a bordo para analisar e julgar, de imediato, a ocorrência. Por este motivo, em regra, os fatos ali anotados sobre os acontecimentos relevantes passados na embarcação, serão presumidos verdadeiros.

Entretanto, por não ser um instrumento absoluto, poderá ser relativizado pelo juiz do primeiro porto que irá analisar as provas, a perícia técnica, interrogar a tripulação e os passageiros sobre a veracidade dos fatos para proferir sua decisão em acolher o pedido de ratificação do protesto ou processo testemunhável ¹¹⁶³ que, assim, com a sua homologação, será dotado de fé pública com capacidade de prova judicial ¹¹⁶⁴ ou extrajudicial.

2.2 A forma de apresentação e os requisitos do protesto e processos formados a bordo

Não há mais uma forma prevista no CPC para o protesto marítimo e protesto formado a bordo. O CPC/1939 previa no art. 726 uma série de requisitos para que o “protesto ou o processo testemunhável” fosse considerado completo, tais como ser “escrito pelo piloto, datado e assinado pelo capitão, pelos maiores da tripulação – imediato, chefe de máquina, médico, pilotos, mestres, e por igual número de passageiros, com a indicação dos respectivos domicílios.” Essas exigências não são convergentes com a nova sistemática e até conflitam com o Decreto 87.648/1980, Capítulo XIV, que especifica *Deveres do Capitão e dos Tripulantes*, que estipulam entre os deveres do capitão o de “fazer escriturar o Diário da Navegação, Diário de Máquinas e Diário de Serviço de Comunicações”, protesto, incêndio, colisão, abandono, atas de deliberação, registros de nascimento, óbitos e testamentos, reparos etc. (art. 141, inc. XXVIII, letra ‘a’).

Deste modo, tanto o Livro Diário da Navegação e neles inscritos os protestos e processos testemunháveis apresentados ao juiz, bem como a sua transcrição na petição inicial não possuem mais forma descrita na lei processual e devem obedecer às normas de Direito Marítimo em geral e de tráfego marítimo, em especial. Importa, sobremaneira, que contenham os dados essenciais e “tendentes a comprovar sinistros, avarias, perdas ou arribadas”; esse é o objeto material do procedimento.

3. Aspectos processuais e procedimentais

Dentre os fins processuais se destacam o objeto processual ou pedido, que se sintetiza na ratificação das provas colhidas a bordo, a competência de jurisdição e competência de foro, além do prazo de 24 horas. Este prazo deve ser contado em horas úteis.

3.1 O objeto processual e valor probante

O objeto processual da ratificação procedimental com finalidade probatória é a confirmação dos fatos materiais registrados no Livro de Navegação, atas de deliberação etc., já que tal processo e procedimentos judiciais não criam, modificam ou extinguem direitos gerados pelos próprios fatos, mas dá-lhes revestimento e o caráter de prova legal pré-constituída a fim de atribuir ao responsável a sua obrigação de reparar o dano, por exemplo. ¹¹⁶⁵

Se o objeto processual é a ratificação, depende o procedimento dos meios probatórios hábeis a essa demonstração judicial. Para atender esse objeto, o legislador exige a apresentação da ata de deliberação, a que se refere o protesto, devidamente registrada no Diário da Navegação para que o pedido de ratificação seja aceito pelo juízo competente. Pontes de Miranda aponta que sem este registro no referido livro, o juiz deverá indeferir o pedido liminarmente. ¹¹⁶⁶

Em caso de ausência parcial ou total do livro em razão de algum acidente, o interessado poderá valer-se de outros meios probatórios. Na doutrina anterior era sugerido o protesto em cartório de registros de títulos e documentos, depois de esgotadas as vias judiciais, a fim de prevenir e resguardar seus direitos, caso o recebedor ou transportador entre com ação própria em face do dano. ¹¹⁶⁷ As atas notariais previstas no CPC/2015 (art. 384), como forma demonstrar a “existência e o modo de existir de algum fato” que tenham ocorrido durante a navegação e não se tenham tomado o registro no livro próprio ou se tenha perdido o livro.

4. Competência

Como dito e reiterado, a ratificação do protesto marítimo e processos formados à bordo é medida de mera pretensão à constituição de prova, referente a danos ou avarias ocorridas na embarcação, na carga ou até mesmo nos passageiros.¹¹⁶⁸ Como tal e conforme o disposto no art. 766 do CPC/2015, compete ao “juiz de direito do primeiro porto”, em clara indicação da competência de jurisdição e de foro.

A competência de jurisdição é da justiça comum dos Estados, única a possuir juízes de direito. Não possui competência para o presente procedimento do Tribunal Marítimo, destinado a julgar os acidentes e fatos da navegação marítima, fluvial e lacustre e as questões relacionadas com tal atividade.¹¹⁶⁹ Difícil se imaginar que possa hoje a justiça comum do Distrito Federal ter competência, em vista de inexistir transporte comercial baseado na navegação, ainda que sejam conhecidas a navegabilidade do Lago Paranoá e o uso preponderante para embarcações de passeio.

Portanto, não se cogita imediatamente de competência da justiça comum federal e não há de se falar em prerrogativa de foro da União se o protesto não envolver tratado internacional, crime cometido a bordo do navio ou for contrato firmado entre União e Estado estrangeiro, ou qualquer das demais hipóteses estabelecidas no art. 109 da Constituição Federal.¹¹⁷⁰ Mas casos podem haver de interesse da União ou de seus entes de administração indireta que podem eventualmente atrair a competência para a justiça comum federal.

A competência de foro é do juiz de direito do primeiro porto no qual for ancorada a embarcação ou ao largo do qual esteja aguardando a atracação, preponderando as ocorrências nas varas cíveis estaduais das comarcas nas quais se situam os portos de maior movimento no Brasil, dentre os quais: Rio Grande-RS, Imbituba-SC, Itajaí-SC, Paranaguá-Antonina-PR, Santos-SP, Rio de Janeiro-RJ, Vitória-ES, Salvador-BA, Itaquí-MA, Belém-PA, Manaus-AM, dentre tantos outros de menor movimentação de carga.

4.1 O prazo legal e sua contagem em horas

O prazo para a apresentação da petição inicial é contado somente em horas úteis, a partir do momento em que o capitão pode desembarcar no primeiro porto, e a ratificação judicial é condição de validade do protesto marítimo, que produzirá os mesmos efeitos do protesto judicial.¹¹⁷¹ No CPC/1939 admitia-se que fosse feita a apresentação do protesto sem petição, que reduzido a termo, iniciaria o procedimento. Agora, pelo CPC/2015, ao exigir-se que seja feito por petição, por advogado representante judicial, mostrando-se exíguo o prazo de 24 horas, desde a chegada da embarcação ao largo do porto e não necessariamente da atracação, que pode levar semanas.¹¹⁷²

Conta-se o prazo em horas de minuto a minuto, conforme o art. 132, § 4.º, do CC/2002, de modo que, tendo o comandante desembarcado em um dia útil, vencerá seu prazo 24 horas após esse desembarque. Ocorrendo o desembarque em um dia sem expediente forense, seja sábado, domingo ou feriado (nacional ou local), as 24 horas somente terão curso a partir do início da atividade no primeiro dia útil subsequente ao dia do feriado ou do final de semana.

Se possível o protocolo eletrônico da petição inicial e de documentos digitalizados no foro competente para o procedimento, contar-se-á o prazo da hora do protocolo eletrônico, sem adoção da regra do art. 213, referente aos prazos em dias e não aplicável para o prazo em horas.

Perdido este prazo, o procedimento não pode ser processado e não podem ser ratificados o protesto ou processo formado a bordo.¹¹⁷³

Art. 767 . A petição inicial conterá a transcrição dos termos lançados no livro Diário da Navegação e deverá ser instruída com cópias das páginas que contenham os termos que serão ratificados, dos documentos de identificação do comandante e das testemunhas arroladas, do rol de tripulantes, do documento de registro da embarcação e, quando for o caso, do manifesto das cargas sinistradas e a qualificação de seus consignatários, traduzidos, quando for o caso, de forma livre para o português.

1. Inovações do CPC/2015

A redação do art. 767 guarda semelhança apenas parcial com os arts. 725 e 727 do CPC/1939,¹¹⁷⁴ quanto aos termos que deverão ser ratificados, mas aponta-se que a atualização do CPC exige que o protesto formulado pelo comandante seja apresentado mediante petição, enquanto no CPC anterior, bastava o termo lavrado no dia da apresentação, com a sua consequente distribuição e atuação para o

prosseguimento do feito e homologação.

O CPC/2015 não prevê prazo, como aquele de até 5 (cinco) dias o CPC/1939, para o proprietário apresentar protesto do recebimento da carga avariada, se o comandante não formular tal protesto. ¹¹⁷⁵ Conforme regra geral do CC/2002, art. 186, há responsabilidade do transportador apenas por atos ilícitos, presumindo-se que carga foi entregue em bom estado e em conformidade ao contrato de transporte, quando não há reclamação. O protesto do destinatário da carga não segue formalidades iguais a dos *protestos marítimos ou processos testemunháveis formados a bordo* que trata essa Seção, podendo ser manifestado no ato de entrega da mercadoria transportada.

2. Aspectos materiais

Muitos são os aspectos materiais envolvidos nesses procedimentos especiais de jurisdição voluntária, atraindo atenção especialmente às cargas, mas também, bagagens, equipamentos, utensílios e uma diversidade de avarias ou despesas próprias da navegação.

2.1 Cargas sinistradas

Correspondem àqueles bens transportados que, independente da vontade de seu responsável, sofrem acidente ou prejuízo material, que pode ser parcial ou total, dependendo das circunstâncias. Tais ocorrências deverão ser discriminadas em relatório circunstanciado, que indicará as causas, local onde se deu o sinistro e as provas que atestem os fatos de forma técnica. ¹¹⁷⁶

O prejuízo parcial ocorre quando a carga se deteriora por alguma colisão, incêndio, causando estragos que podem ser reparados pela transportadora ou companhia segurada por um custo não muito significativo. O prejuízo total ocorre em casos de roubo, furto ou estragos que inviabilize a utilização do bem transportado, podendo ser indenizável ou não, de acordo com o contrato firmado entre as partes. ¹¹⁷⁷

A prova do sinistro total ou parcial e das avarias pode ter reflexos em todos ou qualquer daqueles campos indicados, fazendo necessária a mais ampla e detalhada coleta de informações daqueles que podem confirmar os fatos ocorridos a bordo.

2.2 Outras avarias grossas

O art. 764 do CCom/1850 diz o que são as avarias grossas e pelo largo rol de hipóteses se pode extrair um conjunto variado de hipóteses fáticas que podem merecer registro no Livro Diário da Navegação e posterior ratificação.

São elas: bens dados a piratas; coisas alijadas para salvação comum; equipamentos, utensílios da embarcação danificados para salvação do navio e carga; âncoras, amarras coisas abandonadas para salvamento; danos causados pelo alijamento de mercadorias ao mar; danos feitos deliberadamente ao navio para facilitar a evacuação d'água e os danos acontecidos por esta ocasião à carga; tratamentos de saúde, sustento e indenizações da tripulação ferida ou mutilada defendendo o navio; indenização ou resgates pagos para salvaguarda da tripulação; soldadas e sustento da tripulação durante arribada forçada; direitos de pilotagem, e outros de entrada e saída num porto de arribada forçada; alugueis de armazéns em que se depositem, em, porto de arribada forçada, despesas da reclamação do navio gastos de descarga, e salários para aliviar o navio e entrar numa barra ou porto, quando o navio é obrigado a fazê-lo por borrasca, ou perseguição de inimigo, e os danos acontecidos às fazendas pela descarga e recarga do navio em perigo; danos acontecidos ao corpo e quilha do navio, despesas feitas para pôr a nado o navio encalhado; recompensas; perdas ou danos sobrevindos em barcas ou lanchas; soldadas e sustento da tripulação, se o navio depois da viagem começada é obrigado a suspendê-la por ordem de potência estrangeira, ou por superveniência de guerra.

3. Aspectos processuais e procedimentais da petição inicial

A petição inicial deve atender aos requisitos ordinários, tal como ir acompanhada de procuração e endereços eletrônico e não eletrônico do advogado (art. 287) e, ainda a indicação do juízo a que é dirigida, os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor, o fato e os fundamentos jurídicos e as especificidades do pedido, o valor da causa, as provas testemunhais com que o autor pretende demonstrar os fatos alegados

(art. 319); e instruída com documentos indispensáveis (art. 320).

3.1 Petição inicial e seus requisitos adicionais

O conteúdo do art. 768 é essencialmente referente à petição inicial, embora induza a pensar-se que trate de detalhes da audiência (art. 769) e da antecedente distribuição.

Não se cogita mais seja o pedido apresentado sem petição inicial, sem representação de advogado, com anteriormente, ou deliberadamente sem os requisitos dos arts. 287, 319 e 320, e, ainda, o art. 720 do CPC/2015.

A petição inicial deve atender a distribuição aos requisitos do art. 287, ou seja, “deve vir acompanhada de procuração, que conterà os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico”, considerando a necessidade de imediata comunicação para a possível emenda e complementação.

Os requisitos do art. 319 devem também ser atendidos, tais como: o juízo ao qual é dirigida (inc. I); os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no CPF ou CNPJ, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor (inc. II); o fato e os fundamentos jurídicos do pedido (inc. III); o pedido com as suas especificações (inc. IV); o valor da causa (inc. V); as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados (inc. VI); a necessidade de realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação, neste caso (inc. VII). Caso o autor não possua as informações, pode indicar o equivalente ou requerer diligência para a complementação, não podendo ser razão para o indeferimento da inicial à falta de elementos indicados no inc. II do art. 319 (art. 319, § 1.º e § 2.º).

Também a petição inicial deve vir acompanhada ou “instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação” (art. 320). São indispensáveis para os fins de ratificação: a) transcrição dos termos lançados no livro Diário da Navegação, na língua portuguesa, ainda que a tradução não seja juramentada (art. 767); b) cópias das páginas que contenham os termos que serão ratificados (art. 767); c) cópias dos documentos de identificação do comandante, que permitam além de sua identificação, a relação funcional e administrativa com a embarcação ou empresa de navegação (art. 767); d) cópia dos documentos de identificação das testemunhas arroladas, que podem ser entre duas ou quatro (art. 767); e) lista dos tripulantes (art. 767); os documentos de registro da embarcação (art. 767); e, quando for o caso, do manifesto das cargas sinistradas e a qualificação de seus consignatários (art. 767). O rol não é exaustivo, pois a diversidade do conteúdo dos transportes marítimos, pode se caracterizar pela necessidade de outros documentos.

A possibilidade de indeferimento liminar era vista como possível, conforme observou Pontes de Miranda, quando desacompanhado do registro no referido livro. ¹¹⁷⁸

Hoje, especialmente e mais amplamente após o CPC/2015, são diversas as possibilidades de correção procedimental, saneamento e mesmo salvamento do processo. O § 1.º do art. 319 tolera que a parte deixe de informar parte daqueles elementos contidos no inc. II do mesmo dispositivo, “requerendo ao juiz diligências necessárias a sua obtenção”; e pelo § 3.º do mesmo art. 319, “petição inicial não será indeferida pelo não atendimento das indicações dos elementos do inc. II se a “obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça”. Tratando-se de transportador estrangeiro, é possível que não possua as informações dos documentos indicados no inc. II do art. 319, ou que não tenham perecido em acidente da navegação.

Pela nova sistemática, se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito (art. 321), determinará ao autor que a emende ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias. É dever do juiz, a partir do CPC/2015, indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado (art. 321, 2.ª parte). Se o autor não cumprir a diligência, emendando, corrigindo ou complementando informações necessárias, o juiz indeferirá a petição inicial (art. 321, parágrafo único). A decisão de extinção sem exame de mérito é recorrível por apelação.

Mas há hipóteses cogitáveis e uso impróprio do processo. Se houver suspeita de que protesto marítimo e do processo testemunhável formado a bordo da embarcação se destina a fim ilícito, deve o juiz indeferir o pedido de formação ou de ratificação, como no caso específico das interpelações (art. 727) ou protestos (art. 728, inc. I).

Os atos subsequentes são de instrução processual, leitura da petição inicial, exame e valoração dos documentos e oitivas do comandante e das testemunhas.

3.1.1 Exigência de documentos traduzidos acompanhando a inicial

A língua portuguesa é de uso obrigatório em todos os atos e termos do processo (art. 192), tradição comum no Brasil e em outras nações. De regra exige-se que “o documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa (...) firmada por tradutor juramentado.

Neste caso, em virtude das urgências que contornam os procedimentos de *protestos e os processos testemunháveis formados a bordo e lançados no livro Diário da Navegação*, se flexibiliza a regra rígida do uso da língua portuguesa, vertidas por tradutor juramentado permitindo que sejam “traduzidos, quando for o caso, de forma livre para o português” (art. 767, parte final).

A doutrina ratifica essa inovação,¹¹⁷⁹ que facilita o acesso à jurisdição, diante da urgência que justifica a dispensa da tradução juramentada por tradução livre.

3.1.2 Livro Diário da Navegação e outros documentos que acompanham a inicial

Essencial neste procedimento é o Livro Diário da Navegação que pode ou não ser juntado no original, conforme a disponibilidade de sua permanência em juízo durante o trâmite do procedimento, considerado que pode ser desentranhado e devolvido à parte após a ordem de expedição do traslado.

Neste Diário da Navegação, segundo o art. 504 do CCom/1850 “se assentarão diariamente, enquanto o navio se achar em algum porto, os trabalhos que tiverem lugar a bordo, e os consertos ou reparos do navio. No mesmo livro se assentará também toda a derrota da viagem, notando-se diariamente as observações que os capitães e os pilotos são obrigados a fazer, todas as ocorrências interessantes à navegação, acontecimentos extraordinários que possam ter lugar a bordo, e com especialidade os temporais, e os danos ou avarias que o navio ou a carga possam sofrer, as deliberações que se tomarem por acordo dos oficiais da embarcação, e os competentes protestos”.

Nelson Nery Junior menciona os “motivos do capitão”, razões para a decisão tomada a bordo, exigíveis no CPC/1939 e não repetidos no CPC/2015 como informações que embora não sejam mais imprescindíveis, podem ser acrescentadas à petição inicial, como esclarecimento dos fatos ocorridos na embarcação.¹¹⁸⁰

Art. 768. A petição inicial deverá ser distribuída com urgência e encaminhada ao juiz, que ouvirá, sob compromisso a ser prestado no mesmo dia, o comandante e as testemunhas em número mínimo de 2 (duas) e máximo de 4 (quatro), que deverão comparecer ao ato independentemente de intimação.

§ 1.º Tratando-se de estrangeiros que não dominem a língua portuguesa, o autor deverá fazer-se acompanhar por tradutor, que prestará compromisso em audiência.

§ 2.º Caso o autor não se faça acompanhar por tradutor, o juiz deverá nomear outro que preste compromisso em audiência.

1. Inovações do CPC/2015

A redação do art. 768 não tem correspondência no CPC/1973, que optou por manter vigente parte do CPC/1939 (Disposições Transitórias, art. 1.218).

2. Aspectos materiais

O próprio Código Comercial, art. 545, prevê que “são obrigações dos oficiais e gente da tripulação” item 7, “prestar os depoimentos necessários para ratificação dos processos testemunháveis, e protestos formados a bordo (artigo 505)”, impondo a estes o cumprimento desses deveres de esclarecimento e veracidade.

3. Aspectos processuais e procedimentais

A petição inicial, como dito, deve obedecer aos requisitos ordinários (arts. 287, 319, 320 e 720), mas também deverá atender a outros requisitos próprios e afetos ao direito material envolvido,

especialmente na identificação do comandante, da embarcação, da hora da chegada ao porto, dos documentos juntados em cópia e os originais exigidos etc.

3.1 Legitimação do comandante e substituição

O comandante, identificado também na legislação nacional como capitão ou mestre (CCom, arts. 496-497) é o autor do procedimento ou o interessado, devendo outorgar a procuração ao advogado para representá-lo em juízo, oferecer os documentos e prestar o depoimento pessoal.

3.2 Distribuição e designação de atos processuais imediatos

O exíguo prazo de 24 horas úteis para o capitão propor a procedimento também se reflete nos atos judiciais do cartório ou secretaria do juízo, que deverão ser praticados considerando a necessidade de imediata instrução, que antecedida do ato de registro, hoje possíveis de serem realizados eletronicamente, conforme a organização judiciária de cada Estado (arts. 284 e 285).

Perdido este prazo, o procedimento não pode ser processado e não podem ser ratificados o protesto ou processo formado a bordo,¹¹⁸¹ restando ao comandante ou aos demais interessados, a constituição de prova dos fatos por outro meio judicial ou extrajudicial.

3.3 Instrução, documentos e depoimentos do comandante e das testemunhas

Língua portuguesa é meio de comunicação no processo civil brasileiro, como de resto nos processos e procedimentos administrativos marítimos.¹¹⁸² Essencial, como dito é o Livro Diário da Navegação, que pode ter sido escrito em outra língua, mas terá necessariamente de ser traduzido para a língua portuguesa, nos trechos de interesse à ratificação.

O Decreto 87.648/1980, no Capítulo XIV, que trata *Dos Deveres do Capitão e dos Tripulantes*, estabelece no art. 142 que o tripulante tem entre seus deveres o de “prestar os depoimentos necessários nos processos testemunháveis e nos casos de protestos” (art. 142, inc. XIII).

Os depoimentos devem ser do comandante, já mencionado anteriormente, especialmente porque dele é o “dever de escrituração regular de tudo quanto diz respeito à administração do navio, e à sua navegação (...) pena de responder por perdas e danos que resultarem da sua falta de escrituração regular”. Se tem o dever de escrituração nos livros próprios, tem também o dever de depor sobre o que vai escrito no Livro Diário da Navegação.

As testemunhas devem ser retiradas daquele pessoal de bordo, tal como o piloto (CCom, arts. 538-542), que também possui deveres de escrituração dos fatos da navegação (CCom, art. 504), e seu contramestre, os marinheiros, outras pessoas empregadas a bordo (CCom, art. 564) e até mesmo os passageiros (CCom, arts. 629-632). Não menciona o procedimento especial nenhum daqueles interessados, tais como proprietários e mandatários (CCom, arts. 513 e 516), seguradores e doador em risco (CCom, art. 648), por presumir-se que não tenham conhecimento direto sobre os fatos a serem ratificados, pela ausência da embarcação durante a viagem.

No depoimento das testemunhas deve-se colher o compromisso de dizer a verdade e registrar em ata a eventual escusa em depor ou em responder pergunta específica. O autor que presta depoimento pessoal não presta o compromisso.

Como nos demais procedimentos, cabe ao requerente a demonstração de suas alegações, ônus que não atendido pode ocasionar a improcedência do pedido. Observa-se também a ampliação dos poderes do juiz pois este não conhece outra *verdade* que não a *verdade* do interessado e, pode diligenciar se suspeitar ou identificar sinais de inverdade, pois possui poderes instrutórios ampliados.

3.3.1 Designação direta ou requerimento de tradutor

Os atos processuais devem ser produzidos em língua portuguesa, sejam as trocas de escritos, a juntadas de documentos ou as audiências.

De regra o juiz deve nomear tradutor quando necessário “verter para o português as declarações das partes e das testemunhas que não conhecerem o idioma nacional (art. 162, inc. III); mas neste procedimento especial sugere que nos casos de depoimento de “estrangeiros que não dominem a língua portuguesa, o autor deverá fazer-se acompanhar por tradutor, que prestará compromisso em audiência”

(art. 768, § 1.º) e, como alternativa a esse dever de cooperação, no caso em que “o autor não se faça acompanhar por tradutor, o juiz deverá nomear outro que preste compromisso em audiência” (art. 768, § 2.º).

Neste tema impõe-se a ordem normativa própria do procedimento *ratificação dos protestos marítimos e dos processos testemunháveis formados a bordo*, que transfere à parte, ao comandante da embarcação, em geral, o dever de fazer-se acompanhar de seu tradutor.

Art. 769. Aberta a audiência, o juiz mandará apregoar os consignatários das cargas indicados na petição inicial e outros eventuais interessados, nomeando para os ausentes curador para o ato.

1. Inovações do CPC/2015

A redação do art. 769 não tem correspondência no CPC/1973, que optou por manter vigente parte do CPC/1939 (Disposições Transitórias, art. 1.218), mas guarda semelhança parcial com o art. 728 do CPC/1939.¹¹⁸³

2. Aspectos materiais

O processo civil brasileiro ainda que seja predominantemente escrito é marcado por um *procedimento em audiências*, no qual se sucedem eventos e são realizados atos associados à oralidade.¹¹⁸⁴ A audiência é o ato próprio, senão exclusivo, para a colheita da prova oral, na qual se baseiam preponderantemente as ratificações do protesto marítimo e de processos testemunháveis. O chamamento dos consignatários das cargas e de outros eventuais interessados objetiva dar notícia a estes terceiros sobre direitos que possam, oportunamente, tomar iniciativas de defesa e preservação. Nesses procedimentos também deve ser admitida a prova documental, especialmente a entrega do Livro Diário da Navegação e outros documentos que possam confirmar os fatos narrados na inicial.

3. Aspectos processuais e procedimentais da audiência

Há uma aparente inversão na ordem dos conteúdos deste art. 769 e do antecedente. Ao tratar de detalhes da audiência este art. 769, após o art. 768, que trata da petição inicial e de seus detalhes, tal como prazo de apresentação do pedido, necessidade de oitivas do comandante e testemunhas, número de testemunhas, e a necessidade da presença de tradutor na audiência. As ordens normativas gerais, presentes no CPC/2015 se aplicam aos procedimentos, conforme descrição feita na parte introdutória deste volume.

3.1 Saneamento e organização no procedimento de jurisdição voluntária

Sanear e organizar é preparar o processo para o julgamento, desobstruindo e delimitando o objeto a ser provado e decidido. Para isso é necessário resolver as questões processuais pendentes, (art. 357, inc. I), como o defeito de representação; delimitar as questões de fato para a prova e especificar os meios de prova admitidos (art. 357, inc. II); definir a *distribuição* do ônus da prova, observado o art. 373 (art. 357, inc. III);¹¹⁸⁵ delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito (art. 357, inc. IV); designar, se necessário, a audiência (art. 357, inc. V) nos casos em que não é expressa sua necessidade ou desnecessidade.

É possível à parte ou interessado, discordando do que foi definido, pedir ajustes no saneamento em 5 dias (art. 357, § 1.º); e delimitar questões consensuais de fato e direito para vincular a colheita da prova restrita a certo objeto (art. 357, § 2.º).

Admite-se o saneamento em audiência com a cooperação das *partes* ou interessados e mesmo de terceiros intervenientes para questões complexas, (art. 357, § 3.º) devendo, neste caso, levarem rol de testemunhas (art. 357, § 5.º); Se há testemunhas para serem ouvidas, nos casos em que não é obrigatória a apresentação do rol de testemunhas com a inicial, abre-se prazo de 15 dias para indicar as testemunhas (art. 357, § 4.º); podendo-se o juiz limitar o número de testemunhas (art. 357, § 6.º), quando não há previsão expressa desse limite;

Prova pericial, se houver, deve observar o art. 465 (art. 357, § 7.º), embora a finalidade exclusiva deste procedimento seja apenas a verificação da veracidade dos registros e colheita dos depoimentos.

3.2 Chamamento aos consignatários e interessados

No chamamento dos consignatários de carga e de outros interessados traz-se tais pessoas para o acompanhamento das audiências, sem que se lhes dê, de início, direito à manifestação. Pode o juiz, contudo, ouvi-los sobre os fatos que são objeto do processo e não sobre outros aspectos que envolvam a avarias, sinistros, derrotas etc., fatos narrados no protesto marítimo, formado a bordo durante a viagem ou processo testemunhável que se queira formalizar no porto, após a chegada. Sobre tais fatos acontecidos a bordo, dos quais não foram testemunha, não dispõem esses consignatários e outros interessados conhecimento para informar. Mas há fatos climáticos, borrascas acontecidas na costa e as notícias ou documentos. Fatos exclusivamente associados à consignação de carga, ao fretamento, seus direitos e obrigações. ¹¹⁸⁶

A redação do art. 728 do CPC/1939 não fazia referência aos consignatários de carga, mas exclusivamente aos (eventuais) interessados. Também não trazia referência ao pregão apenas daqueles que estavam indicados na inicial, pois podem acorrer à audiência, tendo notícia do processo, pedindo a intervenção incidente.

Como o objeto das inquirições é limitado e serve à confirmação dos fatos havidos durante a viagem e não mais que isso, são passíveis de indeferimento as intervenções e as manifestações impertinentes à confirmação dos fatos objeto do protesto marítimo e do processo testemunhável formado a bordo da embarcação.

3.3 O curador dos ausentes

O curador para os atos nos protestos marítimos e para os processos testemunháveis formados a bordo, art. 769, é representante processual que não se confunde com outros curadores, como aquele dos bens do ausente (art. 744) ou com o curador dos bens da herança jacente (art. 741). ¹¹⁸⁷ É curador judicial, apenas. Após o pregão inicial da audiência, identificadas as ausências daqueles que poderiam estar presentes ao ato processual, deve o juiz designar o curador judicial. Não há citação editalícia, nestes casos. ¹¹⁸⁸

A Defensoria Pública dos Estados pode considerar que não reclama a sua atuação em defesa dos ausentes, ¹¹⁸⁹ em vista de não se tratar, em geral, de público alvo da atividade desta instituição ¹¹⁹⁰ o proprietário da carga ou da embarcação, o consignatário ou segurador.

3.4 Limites do “contraditório” no protesto marítimo e no processo testemunhável formado a bordo

A visão contida no dispositivo não induz a entender-se este procedimento como cenário de um processo em contraditório. Não se trata propriamente de um processo com a intervenção de partes, o que minimiza a aplicação do art. 9.º do CPC, ¹¹⁹¹ embora os procedimentos de jurisdição voluntária não estejam entre as exceções de contraditório postecipado ou diferido do parágrafo único do mesmo artigo.

Desse modo restringe-se à participação dos consignatários de carga e dos eventuais interessados nestes procedimentos de jurisdição voluntária, que terão ao seu dispor outros procedimentos probatórios, caso desejem a produção antecipada (arts. 381-383), seja contenciosa (art. 382, § 1.º) ou não contenciosa (art. 383, § 5.º). Na mesma linha de raciocínio, não se tratam estes procedimentos de jurisdição voluntária de uma interpelação (art. 727) ou protesto (art. 726, § 2.º), nos quais, de ordinário, poder-se-ia ouvir o interpelado ou destinatário do protesto. Se houver suspeita de que protesto marítimo e processo testemunhável, formado a bordo da embarcação, se destina a fim ilícito, deve o juiz indeferir, em vez de ampliar o contraditório e atrair terceiros para o procedimento como nas notificações, interpelações ou protestos (art. 728, inc. I).

Nelson Nery Junior admite que tanto os interessados indicados pelo capitão ou comandante, como aqueles que não tenham sido indicados e tenham notícia do trâmite procedimental podem acorrer ao processo, pedindo a sua admissão à “participação” processual, devendo ser admitidos, desde que demonstrem a qualidade e o interesse. ¹¹⁹²

4. As provas: a instrução e julgamento no procedimento de jurisdição voluntária

A audiência de instrução destes procedimentos especiais segue a regra processual geral (arts. 358-368), devendo ser aberta no dia e na hora designados pela declaração do juiz, mandando a seguir, apregoar o autor e seu respectivo advogado, bem como outras pessoas que dela devam participar (art. 358).

A realização da audiência de instrução está relacionada à necessidade de colheita de prova oral, ou seja, oitiva de depoimento pessoal e de testemunhas (arts. 358-368) na qual se pode tentar a conciliação, havendo alguma espécie de controversão, embora rara neste procedimento (art. 359). É dever do juiz neste ato manter a ordem, tratar a todos com urbanidade, registrar eventuais requerimentos (art. 360), e sob sua presidência ouvir os depoimentos em ordem preferencial e não mais obrigatória de peritos, depoimento pessoal e depois testemunhas do autor e testemunhas do réu (art. 361); esta audiência pode ser adiada (art. 362) ou antecipada (art. 363); nela são eventualmente oferecidas alegações finais orais (art. 364) ou escritas se complexas (art. 365) e pode ser prolatada a sentença, caso contrário será dada em 30 dias (art. 366). O registro da audiência é feito em geral por meio escrito, mas pode também a audiência poder ser gravada em áudio ou vídeo (art. 367 e §§). Na concepção atual a sentença é o ditado da descrição feita pelo depoente aos fatos, assinada se feita em papel e se feita em meio eletrônico, assinada eletronicamente, pelo juiz, pelos advogados, pelas partes, representantes do Ministério Público etc.

Art. 770 . Inquiridos o comandante e as testemunhas, o juiz, convencido da veracidade dos termos lançados no Diário da Navegação, em audiência, ratificará por sentença o protesto ou o processo testemunhável lavrado a bordo, dispensado o relatório.

Parágrafo único. Independentemente do trânsito em julgado, o juiz determinará a entrega dos autos ao autor ou ao seu advogado, mediante a apresentação de traslado.

1. Inovações do CPC/2015

A redação do art. 770 não tem correspondência no CPC/1973, que optou por manter vigente parte do CPC/1939 (Disposições Transitórias, art. 1.218). O *caput* não tem correspondência anterior, mas o parágrafo único guarda semelhança de conteúdo e finalidade com o art. 729 do CPC/1939. ¹¹⁹³

2. Aspectos materiais

Os fins materiais principais dos procedimentos especiais de jurisdição voluntária são dois: confirmar judicialmente os fatos registrados preventivamente no Livro Diário da Navegação por meio de protesto ou processo testemunhável e entregar ao interessado, ao autor, os autos (por traslado) com a prova ratificada ou colhida para que faça o uso que lhe aprouver. Na redação do art. 729 do CPC/1939 mandava “dar o instrumento à parte”, ou seja, entregava-se ao interessado os autos originais. ¹¹⁹⁴

O CPC/2015 trata de maneira similar dois procedimentos atuais: na cautelar de antecipação de provas, após sentença e findo o prazo de um mês para extração de cópias e certidões pelos interessados, os autos serão entregues ao promovente da medida (art. 383) e nos procedimentos de notificação, interpelação ou protestos, deferida e realizada qualquer das medidas, os autos serão entregues ao requerente (art. 729).

Os fins primeiro e último dos procedimentos de *Ratificação dos Protestos Marítimos* e dos *Processos Testemunháveis Formados a Bordo* serão sempre a ratificação ou a constituição da prova dos fatos relacionados às avarias e aos sinistros ocorridos a bordo das embarcações, que se destinam a prova em outro processo ou procedimento, extrajudicial ou judicial, de qualquer natureza.

3. Aspectos processuais e procedimentais

Muitos são os desdobramentos finais dos procedimentos descritos na *Seção XII*, arts. 766-770, que podem se resumir aos atos de colheita dos depoimentos e exame dos documentos que acompanham a inicial ou são juntados posteriormente. Após a fase oral em audiência e diante inexistência de necessidade de qualquer diligência, o procedimento é conduzido à fase final com a sentença e à fase posterior de entrega por traslado dos autos ao autor ou seu representante judicial. Existe a possibilidade de outros desdobramentos, em vista da recorribilidade das eventuais decisões interlocutórias e da apelabilidade da sentença, assim como pela viabilidade da interposição de ação impugnativa autônoma.

Não é possível admitir-se o julgamento antecipado (art. 355), pois incorrentes as duas hipóteses que permitem essa abreviação procedimental. O julgamento antecipado parcial do mérito (art. 356) também é de difícil configuração, embora não possa ser completamente excluído, em situações complexas, com fatos da navegação sucessivos, nas quais parte do objeto processual possa imediatamente ser provado e parte demande maior tempo ou espera para a instrução.

3.1 Leitura da inicial e documentos pelo juiz

Prevê o dispositivo que o juiz, “convencido da veracidade dos termos lançados no Livro Diário da Navegação, em audiência, ratificará por sentença o protesto ou o processo testemunhável lavrado a bordo”.

Esta atividade cognitiva do juiz e de verificação preliminar da veracidade dos registros do Livro de Navegação é ato próprio da atividade jurisdicional na jurisdição voluntária, na qual o juiz tem expandidos os poderes instrutórios e inclusive maior liberdade decisória (art. 723, parágrafo único).

3.2 Conclusão das inquirições e decisão de ratificação

Como nota a doutrina “o juiz não se limita a homologar o protesto marítimo ou processo testemunhável. Tem o dever de examinar a prova produzida, a fim de avaliar a veracidade dos fatos descritos no Diário da Navegação.” ¹¹⁹⁵ Se a embarcação não possui a escrituração regular, se são defeituosos os registros, se não há correspondência entre os registros e a narrativa dos fatos também no procedimento atual, como nos equivalentes anteriores, ¹¹⁹⁶ pode o juiz rejeitar o pedido, de plano ou após a instrução em audiência. ¹¹⁹⁷

Completa-se a instrução com os depoimentos do comandante e das testemunhas (entre 2 e 4) e com o exame dos documentos, especialmente o Livro Diário da Navegação estando o processo pronto para a decisão confirmatória da narrativa dos fatos. Se houver necessidade de novas diligências, podem estas ser requeridas pelo autor ou determinadas de ofício pelo juiz; não havendo, o processo está maduro para a sentença. Essas diligências devem se limitar aos fatos objeto do processo e não a outros relacionados aos negócios com a carga, a tributos, fretamento etc.

O convencimento do juiz é essencial para ratificação por sentença do protesto ou o processo testemunhável lavrado a bordo, ou para a sentença de procedência do pedido. Não se convencendo o juiz da veracidade da narração contida no Livro Diário da Navegação ou sua contradição com um ou mais depoimentos do comandante ou das testemunhas, a sentença deve ser de improcedência do pedido.

Este é o ato de ratificação que confirma a veracidade dos fatos colhidos e registrados no Livro Diário da Navegação, seja o Protesto Marítimo ou qualquer outro Processo Testemunhável feito a bordo. Se desaparece o livro, se não correspondem os fatos descritos nele com os fatos narrados pelas testemunhas, se as assinaturas apostas ao protesto não conferem com os sujeitos que deveriam assinar ou se não está assinado, por exemplo, pode ser rejeitado o pedido de ratificação.

O prazo para decisão do juiz é de 10 (dez) dias (art. 723).

3.3 Sentença simplificada, apelação e desconstituição

A sentença, segundo o CPC/2015, “é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento” especial, que a partir de agora contém exigências importantes na fundamentação (art. 489, incs. I a VI do § 1.º; § 2.º e § 3.º). São elementos dela, segundo o art. 489, o relatório, os fundamentos e o dispositivo; o “relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo” (art. 489, inc. I).

De modo diverso da regra geral, dispensa-se no art. 770, parte final, o relatório da sentença que ratifica o protesto ou o processo testemunhável lavrado a bordo. Essa dispensa ocorre também nos procedimentos dos juizados especiais, ¹¹⁹⁸ nos quais deve o juiz “fazer breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, além da ata da audiência”, que pode ser técnica simplificadora a ser adotada também nestes procedimentos especiais marítimos.

São recorríveis por apelação as sentenças da jurisdição voluntária (art. 724) e assim será também com as sentenças destes procedimentos especiais de Protesto Marítimo ou qualquer outro Processo Testemunhável feito a bordo. A irrecorribilidade não mais se cogita, como antes do CPC/1939, quando se considerava insuscetível de agravos, recursos da sentença e contraprotestos as decisões desse procedimento. Tanto são agraváveis as interlocutórias, como recorrível a sentença.

Saber-se se são rescindíveis ou anuláveis as sentenças nestes procedimentos depende da confirmação ou não da existência de coisa julgada.

Se são atos das partes, sem a evidência de contraditório e sem a presença de uma sentença que

adjudique certo direto a uma dessas partes, não se pode falar em ação rescisória e de seus dois juízos rescindendo e rescisório, mas se tanto e mais apropriadamente de ação anulatória do art. 966, § 4.º. A noção de anulabilidade, como expresso no dispositivo agora com mais clareza e acerto, se ajusta aos “atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.” Desse modo, ação anulatória é o meio adequado para desconstituir qualquer ato de disposição, das partes ou intervenientes, trazido ou produzido no processo que seja homologado pelo juízo, seja por sentença ou não, transite em julgado ou não. ¹¹⁹⁹

Para que se cogite de ação anulatória ter-se-ia de identificar, portanto, os *vícios de consentimento* contidos na lei civil, tais como erro ou ignorância (arts. 138-144, CC/2002), dolo (arts. 145-150, CC/2002), coação (arts. 151-1155, CC/2002), estado de perigo (art. 156, CC/2002), lesão (art. 157, CC/2002), fraude contra credores (arts. 158-165, CC/2002), simulação (art. 167, CC/2002) e a *reserva mental* (art. 166, CC/2002), que também vicia o ato ou negócio.

3.4 Entrega dos autos, custas e honorários advocatícios

A entrega dos autos ao autor deve ser feita independentemente de trânsito em julgado, caso haja o requerimento para tanto. Se há interesse recursal, decorrente da sucumbência parcial ou total, por certo o interessado não requererá a entrega dos autos originais, mas a expedição de certidão, se prova da decisão parcial ele pretender. De modo diferente do CPC/1973, neste CPC/2015 dependerá de traslado a entrega dos autos; nos processos preventivos do CPC/1973, tais como protestos, interpelações e notificações eram “os autos entregues à parte, independentemente de traslado” (art. 872), regra que se aplicava aos protestos marítimos. A regra do parágrafo único do art. 770 agora é expressa: entregar-se-á ao “autor ou ao seu advogado”, os autos, “mediante a apresentação de traslado”. ¹²⁰⁰

Custas incidentes e ainda não pagas devem ser satisfeitas antes da entrega do traslado dos autos ao interessado. Não incidem honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a característica do procedimento, desprovido de litigiosidade não comporta tal imposição, conforme pode ser identificada na jurisprudência. ¹²⁰¹

3.5 Protestos e prescrição das ações

O Dec.-Lei 116/1967 estabelece o prazo de prescrição das pretensões por extravio de carga, bem como as ações por falta de conteúdo, diminuição, perdas e avarias ou danos à carga; ¹²⁰² regra especial diversa daquelas previstas no CC/2002, arts. 205 e 206.

NOTAS DE RODAPÉ

1

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*, 2. ed., vol. X, art. 1.103, item n. 1, p. 1. A rigor, deve-se esclarecer, o *Anteprojeto de Código de Processo Civil*, apresentado pelo professor Alfredo Buzaid ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores, em janeiro de 1964, não continha o *Livro IV*, correspondente aos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. Tal inclusão se deu concomitantemente ao trabalho da Comissão Revisora instituída em 1969 e composta pelos professores Luiz Machado Guimarães, José Frederico Marques e Guilherme Estellita, depois sucedido por Luiz Antonio de Andrade. Aroldo Valadão atribui o texto correspondente aos procedimentos especiais ao próprio Alfredo Buzaid, por inserção tardia, sem registro no Diário Oficial (Comentários ao CPC vol. XII – RT).

2

Pode-se classificar no Capítulo III como: *extensão* Seção IV, que tratam agora não só da Separação Consensual, mas também do Divórcio e da Separação Consensuais, da Extinção Consensual de União Estável e da Alteração do Regime de Bens do Matrimônio; *transposição* na Seção II notificações e interpelações e se introduz uma Seção XII,

para tratar da Ratificação dos Protestos Marítimos e dos Processos Testemunháveis Formados a Bordo.

3

Eduardo J. Couture. *Fundamentos del Derecho Procesal* , item n. 29, p. 45-46.

4

José Frederico Marques. *Ensaio sobre a Jurisdição Voluntária* , 1. ed., revista e atualizada, § 19, item n. 4, p. 221-222.

5

Alfredo de Araújo Lopes da Costa. *A Administração Pública e a ordem jurídica privada (Jurisdição Voluntária)* , item n. 122-123, p. 169, 171-174.

6

José Maria Rosa Tesheiner. *Jurisdição voluntária* , índice, p. 5-7, ver itens n. 3, 4, 5 e 6.

7

Leonardo Greco. *Jurisdição voluntária moderna* , item n. 1.7, p. 27.

8

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil* , 2. ed., vol. X, art. 1.103, item n. 3, p. 16.

9

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil* , t. XVI, cap. I, item n. 2, p. 6 e 12. O autor, como em sua tradicional teoria, afirmava que na jurisdição voluntária “há a pretensão à tutela jurídica, há o direito, a pretensão e a ação de direito material e há a ‘ação’ (remédio processual)”.

10

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil* , t. XVI, cap. I, item n. 2, p. 11; referindo que há algo de contenciosidade em certos procedimentos, tais como remoção de tutor e outras. Niceto Alcalá-Zamora Y Castillo. Eficacia de las providencias de la jurisdicción voluntaria, *Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México* , vol.15, n. 45, item n. 1, nota n. 4, citando Friz Baur, p. 522.

11

José Manoel de Arruda Alvim Netto. *Manual de Direito Processual Civil* : parte geral, 7. ed., item n. 57, p. 221 e p. 223. Admite, contudo, a existência de *dissenso* .

12

Neste mesmo sentido, referindo-se ao CPC/1973, e justificando a aplicação dos Livros I, II e III, ver: Leonardo

13

Edson Prata. *Jurisdição voluntário* , tit. III, item n. 7, p. 110, embora o mesmo autor, nos *Comentários ao Código de Processo Civil* , vol. 7, art. 1.112, não retome explicitamente a posição.

14

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil* , t. XVI, art. 1.103, item n. 2, p. 16. José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil* , 2. ed., vol. X, art. 1.103, item n. 4, p. 17-18, nota 24a. José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil* , 5. ed., vol. X, art. 1.103, item n. 4, p. 17-18, nota 24a. Nelson Nery Junior. Rosa Maria de Andrade Nery. *Código de Processo Civil Comentado* . 10. ed., art. 1.112, item n. 1, p. 1255. José Miguel Garcia Medina. *Código de Processo Civil Comentado* , art. 1.112, p. 1040.

15

Não consideram taxativo o rol do CPC/2015: Tereza Arruda Alvim Wambier; Maria Lúcia Lins Conceição; Leonardo Ferres da Silva Ribeiro. Rogério Licastro Torres de Mello. *Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil* , art. 725, p. 1072.

16

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil* , t. XVI, Cap. I, item n. 1, p. 13.

17

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil* , 2. ed., vol. X, art.1.103, item n. 37, p. 91.

18

Art. 725, parágrafo único. As normas desta Seção aplicam-se, no que couber, aos procedimentos regulados nas seções seguintes.

19

Art. 719. Quando este Código não estabelecer procedimento especial, regem os procedimentos de jurisdição voluntária às disposições constantes desta Seção.

20

Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.

21

Art. 191. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso. § 1.º O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais, devidamente justificados. § 2.º Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário.

22

Ricardo Cunha Chimenti. *Teoria e prática dos juizados especiais cíveis*, art. 57, item n. 57.2, p. 334.

23

Cristiano Chaves Farias. O cumprimento de testamento no novo código de processo civil e a possibilidade de adaptação procedimental (cláusula geral negocial) do inventário, *Revista de Direito*, vol. 7, n. 1 (2015), item n. 3, p. 32-34.

24

Alfredo de Araújo Lopes da Costa. *A Administração Pública e a ordem jurídica privada (Jurisdição Voluntária)*, item n. 28, p. 62.

25

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

26

Alfredo de Araújo Lopes da Costa. *A Administração Pública e a ordem jurídica privada (Jurisdição Voluntária)*, cap. VI, item n. 424, p. 80-82.

27

José Frederico Marques. *Ensaio sobre a Jurisdição Voluntária*, 1. ed. revista e atualizada, § 8.º, item n. 3, p. 105.

28

Marcelo Zenkner. *Ministério Público e efetividade do processo civil*, item n. 3.2.4, p. 172.

29

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

30

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil* , v. XII, item n. 3.1, p. 35.

31

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil* , 2. ed., v. X, art.1.104, item n. 5-A, p. 35.

32

Idem, item n. 3.2, p. 37.

33

Idem, item n. 3.2, p. 37.

34

“Art. 2.º O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.”

35

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil* , v. XII, item n. 3, p. 34.

36

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil* , t. XVI, Disposições Gerais, item n. 1, p. 18.

37

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil* , v. XII, item n. 3, p. 35.

38

Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil* , art. 720, item n. 2, p. 1555.

39

Araken de Assis. O procedimento de dúvida e o princípio de adstrição do juiz ao pedido da parte . *Revista Jurídica* , a. XXXI, v. 107, item n. 10 p. 41.

40

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil* , t. XVI, item n. 1, p. 17.

41

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*. t. III,

art. 720, item n. 2, p. 699.

42

Edson Prata. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 7, arts. 1.103-1.220, item n. 7, p. 19.

43

Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil*, art. 872, item n. 4, p. 1555.

44

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*. t. III, art. 720, item n. 2, p. 699.

45

Edson Prata. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 7, arts. 1.103-1.220, item n. 3, p. 23.

46

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, item n. 3.3, p. 38.

47

Edson Prata. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 7, arts. 1.103-1.220, item n. 3, p. 23.

48

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.104, item n. 3.1, p. 36.

49

Idem, item n. 3.2, p. 37.

50

Cleber Francisco Alves. *A justiça para todos: assistência judiciária gratuita nos Estados Unidos, França e Brasil*, item 5.3.2, p. 273-277.

51

Luiz Guilherme Marinoni. Sérgio Cruz Arenhart. Daniel Mitidiero. *Novo código de processo civil comentado*. t. III, art. 720, item n. 2, p. 699.

52

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. v. X, item n. 7, p. 36.

53

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, item n. 2, p. 20; José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. vol., X, item n. 7, p. 37.

54

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. v. X, item n. 7, p. 37.

55

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.104, item n. 3.4, p. 39.

56

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*. t. III, art. 720, item n. 4, p. 699.

57

Edson Prata. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 7, art. 1.103, item n. 3, p. 14.

58

Idem, *ibidem*.

59

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. v. X, item n. 7-A, p. 37.

60

Edson Prata. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 7, art. 1.103, item n. 3, p. 14.

61

Idem, item n. 6, p. 15.

62

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*. t. III, art. 720, item n. 3, p. 699.

63

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.104, item n. 3.4, p. 39.

64

65

TRF3, Primeira Seção, rel. Des. Nilton dos Santos, CC – Conflito de Competência – 9740, *j*. 19.07.2007, *DJU* 19.10.2007.

66

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.104, item n. 3.5, p. 40.

67

Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil*, art. 720, item n. 5, p. 1555.

68

STJ, *REsp* 1.431.036-SP, *DJe* de 24.04.2018, 3.^a Turma, rel. Min. Moura Ribeiro.

69

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.104, item n. 3.5, p. 40.

70

Idem, *ibidem*.

71

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, item n. 8.3, p. 51.

72

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. v. X, item n. 9, p. 40. Atualizada por José Rubens Costa.

73

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*. t. III, art. 721, itens n. 1-3, p. 699-700.

74

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, item n. 1.

75

“Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em

que deva intervir”.

76

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. v. X, item n. 8, p. 39.

77

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, item n. 4, p. 42.

78

Idem, *ibidem*.

79

João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil*. v. 15, item n. 1, p. 68.

80

Edson Prata. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 7, item n. 3, p. 25.

81

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, item n. 5, p. 44.

82

Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil*, art. 721, item n. 2, p. 1556.

83

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, item n. 4, p. 42.

84

João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil*. v. 15, item n. 1, p. 68.

85

Luiz Guilherme Marinoni. Sérgio Cruz Arenhart. Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*. t. III, art. 721, itens n. 4, p. 700.

86

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, art. 1.105, item n. 1, p. 19.

87

Edson Prata. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 7, item n. 3, p. 23.

88

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, item n. 6, p. 46.

89

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*. t. III, art. 721, itens n. 2, p. 700.

90

Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil*, art. 721, item n. 3, p. 1556.

91

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, item n. 6.1, p. 46.

92

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XVI, art. 1.105, item n. 1, p. 19.

93

Cândido Rangel Dinamarco. *Fundamentos do Processo Civil Moderno*, 3. ed., v. I, Cap. XIII, item n. 176, p. 399.

94

A favor da participação obrigatória: Nery Junior, *Código de Processo Civil comentado*, p. 1.038, e *Revista de Processo*, n. 46/7, Intervenção do Ministério Público nos procedimentos especiais de jurisdição voluntária; Fadel, *Código de Processo Civil comentado*, t. V, p. 274.

95

João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil*. v. 15, item n. 2, p. 70.

96

STJ, RESP 46770-RJ, DJ de 17.03.1997, p. 7505, 4.^a Turma, rel. Min. Salvo de Figueiredo Teixeira: “Processo civil – procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Extinção de condomínio pela venda de coisas comuns. Não-obrigatoriedade da intervenção do ministério público. art. 1.105. Interpretação lógico-sistemática com art. 82, CPC. (...)”.

97

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, item n. 8.2, p. 51.

98

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, item n. 2, p. 23.

99

Edson Prata. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 7, (arts. 1.103-1.220), item n. 2, p. 26.

100

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. v. X, item n. 9, p. 40. Atualizada por José Rubens Costa.

101

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, item n. 2, p. 23.

102

João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil*. v. 15, item n. 1, p. 74. Neste mesmo sentido: Nery Junior, *Código de processo civil comentado*, p. 1.039.

103

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. v. X, item n. 9, p. 40. Atualizada por José Rubens Costa.

104

Luiz Guilherme Marinoni. Sérgio Cruz Arenhart. Daniel Mitidiero. *Novo código de processo civil comentado*. t. III, art. 721, itens n. 4, p. 700.

105

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, item n. 4, p. 22.

106

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. v. X, item n. 11, p. 46. Atualizada por José Rubens Costa.

107

João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil*. vol. 15, item n. 1, p. 72.

108

João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil*. v. 15, item n. 1, p. 77.

109

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, item n. 12, p. 58.

110

Bruno Freire e Silva. Antonio do Passo Cabral; Ronaldo Cramer (coord.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, 2.a ed., art. 722-724, item n. 1, p. 1034.

111

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, item n. 12, p. 58.

112

Idem, *ibidem*.

113

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, item n. 4, p. 24.

114

No mesmo sentido: Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, item n. 13.1, p. 59. “O legislador considerou prudente – ainda que, do ponto de vista eminentemente teórico, possa ser ocioso – ressaltar, separadamente, o interesse da Fazenda Pública para ser ‘ouvida’ (*sic*), mesmo que, amplamente, já se estivesse incluída entre os “interessados” do art. 1.105”.

115

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. v. X, item n. 14, p. 49. Atualizada por José Rubens Costa.

116

Idem, p. 50. Atualizada por José Rubens Costa.

117

João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil*. v. 15, item n. 1, p. 78.

118

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, item n. 13, p. 59.

119

João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil*. v. 15, item n. 1, p. 77.

120

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo civil comentado*. t. III, art. 722, itens n. 1, p. 700.

121

Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil*, art. 722, item n. 2, p. 1557.

122

Zulmar Duarte de Oliveira Junior; Lenio Luiz Streck; Dierle Nunes; Leonardo Cunha (orgs.). *Comentários do Código de Processo Civil (de acordo com a Lei n. 13.256/2016)*, art. 722, item n. 2, p. 956.

123

Marcelo Miguel Conrado; José Sebastião Fagundes Cunha (coordenador-geral); Antonio César Bochenek; Eduardo Cambi (coordenadores). *Código de Processo Civil Comentado*, art. 722, p. 1012.

124

Leonardo Carneiro da Cunha. *A Fazenda Pública em juízo*, 13. ed., item n. I.1.1, p. 5-6.

125

María José Falcon y Tella. *Equidad, derecho y justicia*, cap. 2, item n. 3.1.3, p. 267-270.

126

Idem, p. 269.

127

Zulmar Duarte de Oliveira Junior. Lenio Luiz Streck; Dierle Nunes; Leonardo Cunha (orgs.). *Comentários do Código de Processo Civil (de acordo com a Lei n. 13.256/2016)*, art. 723, item n. 2.1, p. 956.

128

Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil*, art. 723, item n. 2, p. 1557.

129

Idem, ibidem.

130

Luiz Guilherme Marinoni. Sérgio Cruz Arenhart. Daniel Mitidiero. *Novo código de processo civil comentado*. t. III, art. 723, item n. 2, p. 701.

131

Estabelece os elementos essenciais da sentença.

132

§ 1.º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I – se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II – empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; Sem correspondência no CPC/1973. IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V – se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. § 2.º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. § 3.º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

133

Enrico Tullio Liebman. *Manuale di Diritto Processuale Civile* . v. 1, item n. I-17, p. 28. Antonio Carlos Marcato. *Procedimentos especiais* , 15. ed., item n. 4, p. 10.

134

José Frederico Marques. *Ensaio sobre a Jurisdição Voluntária* , 1. ed. revista e atualizada, § 29, item n. 4, p. 313-314.

135

“O mesmo se diga com relação à previsão de um recurso (§ 5.º do art. 76) a ser julgado pelas Turmas Recursais, que em nada altera a natureza graciosa do instituto”. Rogério Pacheco Alves. A transação penal como ato da denominada jurisdição voluntária, *Revista da EMERJ* , v. 4, n. 13, item n. 2, p. 173.

136

Niceto Alcalá-Zamora y Castillo. *Eficacia de las providencias de la jurisdicción voluntaria* , Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México, vol. 15, n. 45, p. 593.

137

Eduardo J. Couture. *Fundamentos del Derecho Procesal Civil* , item, n. 30, p. 49.

138

Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil* , art. 724, item n. 2, p. 1558; Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil*

comentado. t. III, art. 724, item n. 1, p. 701.

139

Edson Prata. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 7, arts. 1.103-1.220, item n. 2, p. 42. Cumpre ressaltar que o artigo a que se refere no exemplo (art. 1.169, do CPC/1973) não teve correspondente no novo Código, porém, o seu parágrafo único, que determina a observância do procedimento ordinário (procedimento comum, no novo Código), se encontra no § 4.º do art. 745, do CPC/2015.

140

Edson Prata. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 7, arts. 1.103-1.220, item n. 2, p. 42.

141

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, item n. 20, p. 77.

142

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. v. X, item n. 20, p. 64. Atualizada por José Rubens Costa.

143

Idem, *ibidem*. NA – Encontra correspondência o art. 742, do CPC/2015, o qual manteve a mesma redação anterior.

144

Eduardo J. Couture. *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*, item, n. 30, p. 49.

145

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, item n. 19.2, p. 72.

146

Idem, *ibidem*.

147

Edson Prata. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 7, item n. 3, p. 42.

148

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, item n. 20.1, p. 77.

149

Idem, *ibidem*.

150

Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil*, art. 337, item n. 11, p. 926-927; Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*. t. I, art. 337, item n. 8, p. 361.

151

(TRF1, Terceira Seção, rel. Des. Carlos Moreira Alves, AR 1997.01.00.061288-6, j. 17.12.2013, *DJF1* 13.01.2014). 1. Orientação jurisprudencial da Suprema Corte no sentido de que a ação rescisória, tendo por fim a desconstituição de coisa julgada material, não é cabível contra decisões proferidas em sede de jurisdição voluntária, sendo certo, à luz do disposto no art. 1.111, do Código de Processo Civil, que em procedimentos da espécie a sentença pode vir a ser modificada, sem prejuízo dos efeitos já produzidos, se ocorrerem circunstâncias supervenientes. (...).

152

Bruno Freire e Silva; Antonio do Passo Cabral; Ronaldo Cramer (coord.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, 2. ed., art. 722-724, item n. 1, p. 1034.

153

§ 4.º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

154

Eduardo J. Couture. *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*, item, n. 31, p. 50

155

COSTA, Alfredo de Araújo Lopes da. *A Administração Pública e a ordem jurídica privada (Jurisdição Voluntária)*, item n. 127, p. 159.

156

RIZZI, Sérgio. *Ação rescisória*, item n. 10, p. 30-31.

157

Alfredo de Araújo Lopes da Costa. *A Administração Pública e a ordem jurídica privada (Jurisdição Voluntária)*, cap. VII, item n. 284, p. 344. “A ‘conciliação’ é o ato pelo qual, com a discreta intervenção de um juiz de jurisdição voluntária ou de um juiz jurisdição contenciosa, funcionando em sede de jurisdição voluntária, as partes amigavelmente compõem o conflito de interesses que as divide”.

158

José Frederico Marques. *Ensaio sobre a Jurisdição Voluntária*, 1. ed. revista e atualizada, § 19, item n. 4, p. 222.

159

Jefferson Carús Guedes. Transigibilidade de interesses públicos: prevenção e abreviação de demandas da Fazenda Pública. *Advocacia de Estado* : questões institucionais para a construção de um Estado de Justiça, p. 243-272.

160

A Lei 13.129/2015, que alterou a Lei 9.307/1996, estendeu a arbitragem para a “administração pública direta e indireta (...) para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis”, evidenciando a existência também de interesses disponíveis dentre os interesses públicos.

161

A Lei 13.140/2015 (CPC/2015) admite o uso da “mediação como meio de solução de controvérsias entre particulares e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública” (art. 1.º).

162

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*. t. III, art. 725, item n. 2, p. 702; MACÊDO, Lucas Buril de. Lenio Luiz Streck; Dierle Nunes; Leonardo Cunha (orgs.). *Comentários do Código de Processo Civil (de acordo com a Lei n. 13.256/2016)*, art. 725, item n. 2.1, p. 958; Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil*, art. 725, item n. 2, p. 1558. Marcelo Miguel Conrado; José Sebastião Fagundes Cunha (coordenador-geral); Antonio César Bochenek; Eduardo Cambi (coordenadores). *Código de Processo Civil Comentado*, art. 725, p. 1013.

163

João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil*. v. 15, item n. 1, p. 99.

164

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*. t. III, art. 725, item n. 1, p. 702.

165

João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil*. v. 15, item n. 1, p. 99.

166

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, item n. 25, p. 85.

167

Idem, item n. 25.2, p. 86.

168

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, item n. 26.2, p. 87.

169

Idem, ibidem.

170

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, item n. 26.3, p. 88.

171

TRF5, Pleno, rel. Des. Federal Luiz Alberto Gurgel de Faria, Conflito de Competência 200505000287003, j. 29.03.2016, *DJ* 27.04.2016.

172

Clovis Beviláqua. *Código Civil*, 4. ed., v. I, p. 194.

173

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, item n. 2, p. 41.

174

Idem, item n. 2, p. 40. Pontes De Miranda refere-se a ato divestitivo como aquele de quem se desveste do direito.

175

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. v. X, Atualizada por José Rubens Costa, art. 1.112, item n. 26, p. 76.

176

João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil*. v. 15, item n. 5, p. 108.

177

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. v. X. Atualizada por José Rubens Costa, art. 1.112, item n. 26, p. 75.

178

João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil*. v. 15, item n. 5, p. 108.

179

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. v. X. Atualizada por José Rubens Costa. Item n. 26, p. 76.

180

Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil*, art. 725, itens n. 4 e 5, p. 1559.

181

João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil*. v. 15, item n. 5, p. 109.

182

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. v. X, item n. 26, p. 76. – O art. 7.º, do CPC/1973, a que se refere o autor, se encontra no atual art. 70 do CPC/2015, que diz: “ *Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo* ”.

183

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, item n. 9, p. 46. – O autor se refere à idade mínima de 18 anos, porém, assim o faz, em virtude do Código Civil de 1916.

184

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, item n. 9, p. 46.

185

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, item n. 27.3, p. 91.

186

Idem, item n. 27.2, p. 91.

187

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. v. X, item n. 26, p. 78. João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil*. v. 15, item n. 5, p. 108.

188

Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil*, art. 725, item n. 7, p. 1559.

189

João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil*. v. 15, item n. 5, p. 108.

190

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, item n. 5, p. 44.

191

João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil* . v. 15, item n. 5, p. 109.

192

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil* , t. XVI, item n. 6, p. 45.

193

Idem, ibidem.

194

João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil* . v. 15, item n. 5, p. 109.

195

Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil* , art. 725, item n. 3, p. 1559.

196

Luciano de Camargo Penteado. *Direito das coisas* , 2. ed., cap. III, item n. 29.2, p. 189-190. Sobre restrição à autonomia da vontade, ver: José Manoel de Arruda Alvim Netto. *Manual de Direito Processual Civil* : parte geral, 7. ed., item n. 57, p. 219.

197

Art. 1.848. Salvo se houver justa causa, declarada no testamento, não pode o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade, e de incomunicabilidade, sobre os bens da legítima. (...) § 2.º Mediante autorização judicial e havendo justa causa, podem ser alienados os bens gravados, convertendo-se o produto em outros bens, que ficarão sub-rogados nos ônus dos primeiros.

198

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, art. 1.112, item n. 12, p. 48.

199

Ver, neste sentido: Carlos Alberto Dabus Maluf. *Das Cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade* , 3. ed., itens 4.1-4.3, p. 28-34, onde aponta objeções práticas, econômicas e constitucionais.

200

João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil* . v. 15, art. 1.112, item n. 6, p. 110.

201

Idem, ibidem.

202

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.112, item n. 28, p. 94.

203

Idem, *ibidem*.

204

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.112, item n. 28, p. 94.

205

STF. Súmula 49. A cláusula de inalienabilidade inclui a incomunicabilidade dos bens.

206

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII (arts. 1.103-1.210), item n. 28, p. 94; Edson Prata, *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 7, arts. 1.103-1.220, item n. 3, p. 50.

207

Carlos Alberto Dabus Maluf. *Das Cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade*, 3. ed., item 12, p. 75.

208

Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil*, art. 725, item n. 8, p. 1559.

209

TJSP. Processo 583.00.2008.211882-9 – São Paulo (10.º SRI) – rel. Gustavo Henrique Bretas Marzagão – j. 19.12.2008 – *DJE* 19.01.2009.

210

Edson Prata, *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 7, arts. 1.103-1.220.

211

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.112, item n. 28.6, p. 96.

212

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.112, item n. 28.6, p. 96.

213

Edson Prata, *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 7, art. 1.112, item n. 3, p. 50.

214

A *distribuição do ônus da prova* nos procedimentos de jurisdição voluntária se concentra sobre o autor, diante da inexistência de partes em seu sentido próprio e da inexistência, na maior parte destas modalidades, de uma contradição clara e ostensiva entre contendores.

215

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.112, item n. 28.6, p. 96.

216

Idem, *ibidem*.

217

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, (art. 1.112), item n. 28.11, p. 98.

218

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, art. 1.112, item n. 23, p. 55.

219

TJSP, Ap 1006773-59.2016.8.26.0624, 35.^a Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2017, julgado por Artur Marques da Silva Filho.

220

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, art. 1.112, item n. 25, p. 56.

221

Idem, *ibidem*.

222

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. v. X, art. 1.112, item n. 28, p. 84 (Ressalta-se que a conclusão do autor é pela manutenção do fiscal).

223

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.112, item n. 28.8, p. 97.

224

Idem, item n. 28.8, p. 97 e 98.

225

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.112, item n. 28.8, p. 98. José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. v. X, art. 1.112, item n. 28, p. 84.

226

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, art. 1.112, item n. 18, p. 51.

227

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. v. X, art. 1.112, item n. 29, p. 85.

228

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, art. 1.112, item n. 22, p. 54.

229

Idem, item n. 21, p. 54.

230

Idem, item n. 24, p. 55.

231

Idem, item n. 22, p. 54.

232

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.112, item n. 28.12, p. 99.

233

Idem, item n. 28.13, p. 99.

234

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. v. X, art. 1.112, item n. 30, p. 85.

235

Idem, ibidem.

236

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil* , t. XVI, item n. 27, art. 1.112, p. 57.

237

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil* , v. XII (arts. 1.103-1.210), item n. 29, p. 100.

238

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil* , v. XII, item n. 29.2, p. 101. Edson Prata, *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 7, arts. 1.103-1.220, item 4, p. 51

239

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil* , v. XII, item n. 29.2, p. 101.

240

Idem, *ibidem*.

241

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil* . 5. ed. v. X, item n. 32, p. 86.

242

Zulmar Duarte de Oliveira Junior; Lenio Luiz Streck; Dierle Nunes; Leonardo Cunha (orgs.). *Comentários do Código de Processo Civil (de acordo com a Lei n. 13.256/2016)*, art. 725, item n. 2.4, p. 958.

243

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil* . 5. ed. v. X, item n. 32, p. 87.

244

Idem, *ibidem*.

245

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil* , v. XII, item n. 29.3, p. 102.

246

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil* , t. XVI, item n. 33, p. 59.

247

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil* , v. XII (arts. 1.103-1.210), item n. 29.3, p. 102. Edson Prata, *Comentários ao Código de Processo Civil* , v. 7, arts. 1.103-1.220, item 4, p. 54.

248

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII (arts. 1.103-1.210), item n. 29.4, p. 103.

249

Idem, p. 104.

250

Edson Prata, *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 7, arts. 1.103-1.220, item 4, p. 53.

251

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, item n. 30, p. 104.

252

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, item n. 43, p. 66.

253

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, item n. 30.1, p. 104.

254

Idem, *ibidem*.

255

Idem, *ibidem*.

256

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, item n. 42, p. 65.

257

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, item n. 43, p. 65. Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII (arts. 1.103-1.210), item n. 30.2, p. 105.

258

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, item n. 30.3, p. 105.

259

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, item n. 44, p. 67.

260

Zulmar Duarte de Oliveira Junior; Lenio Luiz Streck; Dierle Nunes; Leonardo Cunha (orgs.). *Comentários do Código de Processo Civil (de acordo com a Lei n. 13.256/2016)*, art. 725, item n. 2.4, p. 958.

261

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, item n. 30.5, p. 106.

262

Idem, p. 107.

263

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, item n. 46, p. 69.

264

Idem, item n. 45, p. 68.

265

Idem, item n. 50, p. 70.

266

Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil*, art. 725, itens n. 15, p. 1560.

267

Idem, *ibidem*.

268

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII (arts. 1.103-1.210), item n. 31, p. 107.

269

Idem, *ibidem*.

270

Idem, (art. 1.112), itens n. 31 e 31.6, p. 107 e 110.

271

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.112, item n. 31, p. 107.

272

Edson Prata, *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 7, art. 1.112, item 6, p. 56.

273

Zulmar Duarte de Oliveira Junior; Lenio Luiz Streck; Dierle Nunes; Leonardo Cunha (orgs.). *Comentários do Código de Processo Civil (de acordo com a Lei n. 13.256/2016)*, art. 725, item n. 2.4, p. 958.

274

Edson Prata, *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 7, art. 1.112, item n. 6, p. 57.

275

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, item n. 57, p. 74.

276

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*, 5. ed. v. X, art. 1.112, item n. 35, p. 92.

277

Edson Prata, *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 7, art. 1.112, item n. 6, p. 57.

278

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.112, item n. 31.4, p. 109.

279

Edson Prata, *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 7, art. 1.112, item n. 6, p. 57.

280

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.112, item n. 31.4, p. 109.

281

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*, 5. ed. v. X, art. 1.112, item n. 35, p. 91.

282

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.112, item n. 31.4, p. 110.

283

Idem, item n. 31.2, p. 108.

284

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, item n. 61, p. 76.

285

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.112, item n. 31.3, p. 109.

286

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*, 5. ed. v. X, art. 1.112, item n. 35, p. 91.

287

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, item n. 64, p. 77.

288

Idem, item n. 64, p. 78.

289

Idem, item n. 61, p. 76.

290

Idem, item n. 60, p. 75.

291

Idem, item n. 56, p. 74.

292

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, item n. 62, p. 76.

293

Zulmar Duarte de Oliveira Junior; Lenio Luiz Streck; Dierle Nunes; Leonardo Cunha (orgs.). *Comentários do Código de Processo Civil (de acordo com a Lei n. 13.256/2016)*, art. 725, item n. 2.5, p. 958.

294

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. v. X, (arts. 1.103-1220). Atualizada por José Rubens Costa. Item n. 36, p. 92.

295

Idem. Item n. 36, p. 93.

296

Edson Prata, *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 7, arts. 1.103-1.220, item 7, p. 58.

297

Idem, p. 57.

298

Idem, p. 58.

299

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, item n. 67, p. 81.

300

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, item n. 66, p. 80.

301

Idem, ibidem.

302

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII (arts. 1.103-1.210), item n. 33, p. 116.

303

Idem, ibidem.

304

Idem, ibidem.

305

Idem, item n. 33.1, p. 117

306

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. v. X, (arts. 1.103-1.220). Atualizada por José Rubens Costa. Item n. 36, p. 93.

307

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, item n. 77, p. 88.

308

Idem, ibidem.

309

Idem, item n. 70, p. 83.

310

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII (arts. 1.103-1.210), item n. 32.5, p. 114-115. F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, item n.70, p. 84.

311

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, item n. 73, p. 84.

312

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII (arts. 1.103-1.210), item n. 32.5, p. 115.

313

Idem, item n. 33.3, p. 118.

314

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, item n. 76, p. 86.

315

Idem, item n. 76, p. 87.

316

Idem, ibidem.

317

Idem, ibidem.

318

TJ-DF – APO: 20140111314478, 1.^a Turma Cível, rel. Teófilo Caetano, j. 26.08.2015, Data de Publicação: Publicado no *DJE* : 22/01/2016, p. 224.

319

(TJ-RS – AC: 70038483590 RS, rel. Nelson José Gonzaga, j. 22.08.2013, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28.08.2013). A extinção do usufruto é fato gerador da Incidência do ITCD, por

disposição legal. Correta a exigência do oficial registrador de que fosse apresentado o comprovante do recolhimento do tributo para o registro da extinção do usufruto nas matrículas dos imóveis. O fato gerador, no usufruto, é a sua extinção, a qual se consuma com a averbação no registro imobiliário, e não com a morte do usufrutuário. Afastada a arguição de prescrição quinquenal.

320

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, item n.78, p. 88.

321

(TJ-MG – AC: 10035140057171001 MG, rel. Alberto Vilas Boas, j. 10.05.2016, Câmaras Cíveis, 1.^a Câmara Cível, Data de Publicação: 18.05.2016). A circunstância de ter havido parcelamento administrativo da dívida tributária, somente inviabiliza a discussão judicial acerca da matéria fática, mas não retira do autor o direito de discutir a legitimidade da relação jurídico-tributária estabelecida com a Administração. – A transmissão da propriedade por meio do fideicomisso ocorre no momento em que os bens são transmitidos pelo fideicomitente ao fiduciário, com incidência do ITCD, não havendo que taxar novamente o mesmo bem quando se realiza o fato extintivo do instituto – implemento da condição resolutiva ou advento do termo final – e o bem é transmitido ao fideicomissário.

322

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, item n. 77, p. 86.

323

Idem, item n. 73, p. 85.

324

Eduardo J. Couture. *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*, item, n. 31, p. 51.

325

Carlos Mendonça. *O essencial sobre alvará judicial*, 2. ed., cap. IV, p. 72.

326

Idem, p. 71.

327

TJ-MG – AC: 10134091280666001 MG, rel. Guilherme Luciano Baeta Nunes, j. 25.06.2013, Câmaras Cíveis/18.^a Câmara Cível, Data de Publicação: 01.07.2013.

328

TJ-RS – AC: 70065285637 RS, rel. Alzir Felipe Schmitz, Data de 08.10.2015, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14.10.2015.

329

TJMG, ApCiv 1.0043.15.003686-1/001, 2.^a Câmara Cível, j. 07.03.2017, julgado por Caetano Levi Lopes; TJRS, ApCiv 70074731662, 7.^a Câmara Cível, j. 24.10.2017, julgado por Jorge Luís Dall'Ágnol.

330

Carlos Mendonça. *O essencial sobre alvará judicial*, 2. ed. Item 1.1, p. 26.

331

Idem. Item 1.4, p. 35.

332

Idem. Item 1.4, p. 36.

333

Idem. Item II.1.1, p. 55.

334

Idem. Item II.1.1, p. 56.

335

Felipe Camilo Dall'Alba. A ampla defesa vista sob o olhar constitucional processual. *Temas atuais de Direito Público*, itens n. 2, p. 253. Carlos Mendonça. *O essencial sobre alvará judicial*, 2. ed. Item II.1.1, p. 56.

336

Carlos Mendonça. *O essencial sobre alvará judicial*, 2. ed. Item II.1.1, p. 57.

337

Idem, p. 58.

338

Idem. Item XI.2.2, p. 151.

339

(...) Dessa maneira, fica claro que não há que se falar em necessidade de procedimento especial a ser processado na Vara de Sucessões, posto que a lei expressamente autoriza o levantamento das quantias requeridas independentemente de inventário ou arrolamento. A requerente no pedido de expedição de alvará, bem como seus filhos menores, são dependentes do falecido, fazendo, desta feita, jus ao levantamento das quantias não recebidas pelo de cujus do saldo de poupança (fl. 13) em procedimento mais célere e simplificado do que o de

inventário, como claramente permitido em lei. Vê-se que o propósito do referido diploma legislativo foi justamente desburocratizar o levantamento desses pequenos valores que possam ser usados de imediato para suprir necessidades urgentes dos dependentes, evitando que as quantias permanecessem retidas até o processamento do inventário ou do arrolamento. Desta feita, resta mais que evidente a desnecessidade do procedimento especial de inventário, tornando inadequada a remessa dos autos pela 2.^a Vara Cível de Arapiraca à 7.^a Vara de Arapiraca – Família e Sucessões. Ademais, insta ressaltar que o caso em comento trata de interesse eminentemente patrimonial, podendo ser aferida, portanto, a ausência de aspectos que reflitam no âmbito familiar e que imponham a remessa do processo ao Juízo especializado. (...) (TJ – AL, Seção Especializada Cível, CC 00027732720118020058 AL 0002773-27.2011.8.02.0058, rel. Des. James Magalhães de Medeiros, j. 04.12.2013, Publicação: DJ 09.12.2013).

340

TJ-MG – AC: 10183130136546001 MG, rel. Alberto Vilas Boas, j. 16.09.2014, Câmaras Cíveis/1.^a Câmara Cível, Data de Publicação: 24.09.2014.

341

TJ-MG – AC: 10183120128941001 MG, rel. Edilson Fernandes, j. 23.04.2013, Câmaras Cíveis/6.^a Câmara Cível, Data de Publicação: 17.05.2013.

342

TJRS, ApCiv 70067747527, 8.^a Câmara Cível, j. 31.03.2016, julgado por Ricardo Moreira Lins Pastl.

343

TJ-RJ – AI: 00135778420168190000, Rio de Janeiro Capital, 3.^a Vara ORFAOS SUC, rel. Mônica Maria Costa Di Piero, j. 19.07.2016, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21.07.2016. TJ-PE – AGV: 2951760 PE, rel. Antenor Cardoso Soares Junior, j. 26.09.2013, 3.^a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03.10.2013.

344

TRF-1 – MS: 00200525220004010000 0020052-52.2000.4.01.0000, rel. Desembargador Federal João Luiz de Sousa, j. 22.09.2015, Primeira Seção, Data de Publicação: 02.10.2015 e-DJF1, p. 2157. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo INSS com vistas à suspensão da eficácia da ordem judicial (alvará judicial) que determina o levantamento de resíduos de benefícios decorrentes da aplicabilidade imediata do art. 201, § 5.º da CF, sob o argumento de ausência de citação. 2. Por força do quanto disposto no art. 1.105 do CPC, serão citados, sob pena de nulidade, nos procedimentos de jurisdição voluntária, todos os interessados e o Ministério Público. 3. Se o INSS se opôs ao pleito em seu mérito, caracterizando pretensão resistida, o alvará judicial perdeu a sua natureza de jurisdição voluntária e adquiriu feições de contencioso. 4. Hipótese em que configurada a ausência de citação do INSS para contestar a lide no procedimento de jurisdição voluntária, em afronta ao art. 1.105 do Código Civil. 5. Segurança concedida.

345

STJ – CC: 102854 SP 2009/0017122-6, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.03.2009, S1 – Primeira Seção, Data de Publicação: DJe 23.03.2009. 1. Em se tratando de pedido de expedição de alvará judicial requerido nos termos da Lei 6.858/1980, ou seja, em decorrência do falecimento do titular da conta, inexistente lide a ser solucionada. Cuida-se, na verdade, de medida de jurisdição voluntária com vistas à mera autorização judicial para o levantamento,

pelos sucessores do de cujus, de valores incontestes depositados em conta de titularidade de pessoa falecida “independente de inventário ou arrolamento”. 2. Desse modo, a Caixa Econômica Federal não é parte integrante da relação processual, mas mera destinatária do alvará judicial, razão por que deve ser afastada a competência da Justiça Federal. 3. Incide, à espécie, o enunciado 161 da súmula do STJ, segundo o qual: “É da competência da Justiça estadual autorizar o levantamento dos valores relativos ao PIS/PASEP e FGTS, em decorrência do falecimento do titular da conta”. 4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 2.^a Vara de Cotia.

346

Apelação Cível 70054747340, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, rel. Luiz Felipe Brasil Santos, j. 31.10.2013. 1. Não havendo resistência por parte do Ministério da Defesa quanto à pretensão da requerente, de receber os valores devidos ao falecido mediante alvará judicial, é da Justiça Estadual a competência para apreciação do presente pedido de alvará. Precedente do STJ (CC 90044/SP). 2. A Lei 6.858/1980 se destina a regular o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de pequenos valores devidos pelos empregadores aos empregados, não recebidos em vida pelo respectivo titular. No caso, tratando-se de verbas oriundas de benefícios do Ministério da Defesa, devidas em razão de cargo exercido pelo falecido no Exército, é de ser deferido o alvará postulado, com fulcro no art. 1.^o da Lei 6.858/1980 c/c art. 1.^o, inc. III, do Decreto 85.845/1981, mormente pelo fato de que os herdeiros, todos maiores e capazes, concordam com o levantamento da integralidade da quantia disponível pela requerente.

347

Agravo De Instrumento – Alvará Judicial – Levantamento De Valores Deixados Pelo Falecido – Direito Das Sucessões – Lei 6.858/1980 – Competência do Juízo de Sucessões E Ausência – Decisão Proferida Pelo Juízo Cível – Incompetência Absoluta – Nulidade Dos Atos Decisórios. – A matéria jurídica subjacente ao procedimento de alvará judicial, fundado na Lei 6.858/1980, se refere ao Direito das Sucessões (Livro V, do Código Civil) e, pois, se encontra circunscrita à competência especializada da Vara de Sucessões e Ausência. – O Juízo Cível é absolutamente incompetente para conhecer e julgar o pedido de alvará judicial para resgate de valores deixados pelo *de cujus*, nos casos disciplinados pela Lei 6.858/1980 – Declarada a incompetência absoluta, deve ser reconhecida a nulidade dos atos decisórios e determinada a remessa dos autos ao Juízo competente, nos termos do § 2.^o, do art. 113, do CPC/1973.

TJ-MG – AI: 10024134296938001-MG, rel. Ana Paula Caixeta, j. 04.08.2015, Câmaras Cíveis, 4.^a Câmara Cível, Data de Publicação: *DJe* 07.08.2015. 1. O procedimento de expedição de Alvará Judicial para levantamento de valores deixados por falecido requerido por esposa, filha e neto, tem natureza de jurisdição voluntária no qual não se pretende discutir eventual direito sucessório dos interessados ou a partilha de bens, mas tão somente o direito ao recebimento de valores nos termos da Lei 6.858/1980. 2. Havendo interesse de incapaz, a competência para processar e julgar o feito é do juízo de família, aplicando-se a regra prevista no artigo 85, III, do CODJERJ. Apesar de o dispositivo ressalvar a competência do juízo de órfãos e sucessões, a questão em conflito não se insere nas hipóteses previstas no art. 87 do mesmo Código, como sustenta o juiz suscitante, por não se tratar de matéria sucessória. CONFLITO IMPROCEDENTE, COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE, 1.^a VARA DE FAMÍLIA DA REGIÃO OCEÂNICA DE NITERÓI.

TJ-RJ – CC: 00010013020148190000 RJ 0001001-30.2014.8.19.0000, rel. Des. Mônica de Faria Sardas, j. 11.02.2014, VIGÉSIMA PRIMEIRA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: *DJe* 16.04.2014.

348

TJRS, 19.^a Câmara Cível, ApCiv 70074554742, j. 07.06.2018, julgado por Mylene Maria Michel.

TJRS, 2.ª Câmara Cível, ApCiv 70069918662, j. 30.08.2016, julgado por Ricardo Torres Hermann.

Juizados Especiais de Pequenas Causas: art. 55. O acordo extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, poderá ser homologado, no juízo competente, independentemente de termo, valendo a sentença como título executivo judicial. Juizados Especiais Cíveis e Criminais, art. 57. O acordo extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, poderá ser homologado, no juízo competente, independentemente de termo, valendo a sentença como título executivo judicial. As leis dos Juizados Especiais Federais e Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública silenciaram sobre essa possibilidade, como a indicar que os litígios da Fazenda Pública não pudessem a essa altura ser resolvidos extrajudicialmente.

Art. 475-N. São títulos executivos judiciais: (...) V – o acordo extrajudicial, de qualquer natureza, homologado judicialmente. (Incluído pela Lei 11.232, de 2005).

Cândido Rangel Dinamarco. *Manual das pequenas causas*, cap. VI, item n. 119, p. 123; Cândido Rangel Dinamarco. *Manual dos juizados cíveis*, 2. ed., cap. XVIII, item n. 131, p. 218.

José Maria Rosa Tesheiner. *Elementos para uma Teoria Geral do Processo*, item n. 6, p. 74. Embora o autor cometa o equívoco de afirmar que aqueles juizados não integravam o Poder Judiciário.

Daniel Amorim A. Neves; Glauco Gumerato Ramos; Rodrigo da Cunha Lima Freire; Rodrigo Reis Mazzei. *Reforma do CPC*: Leis 11.187/2005, 11.232/2005, 11.276/2006, cap. 9, art. 475, item n. 2.2, p. 259; os autores propunham a mesma simplicidade adotada nos juizados especiais.

Eduardo J. Couture. *Estudios de Derecho Procesal Civil*, t. 1, item n. 4, p. 230.

José Frederico Marques. *Ensaio sobre a Jurisdição Voluntária*, 1. ed. revista e atualizada, § 19, item n. 4, p. 222; a opinião do autor tem por base as proposições de Niceto Alcalá Zamora y Castillo. Cristina Ferraz. *Jurisdição voluntária no processo civil*, item n. 6.26, p. 258.

Elio Fazzalari. *La giurisdizione volontaria*: profilo sistematico, Introduzione, § 2, item n. 1, p. 36-37, especialmente nota n. 40. O autor cita Albert Hänel, *Die Verwaltung des Privatrechts im deutschen Staatsrecht*, I, Leipzig, 1892; e Hermann Bürckner, *Der Privatrechtsgestaltende staatsakt*; Verlag, Leipzig, 1930.

358

Jefferson Carús Guedes. Transigibilidade de interesses públicos: prevenção e abreviação de demandas da Fazenda Pública. *Advocacia de Estado* : questões institucionais para a construção de um Estado de Justiça, p. 243-272.

359

A Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais Cíveis e Criminais) excluiu a Administração Pública dos litígios solucionáveis nesses juizados; Lei 10.259/2001 (Juizados Especiais Federais) e a Lei 12.153/2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública) foram criadas especialmente para a solução de conflitos envolvendo a União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

360

A Lei 9.469/1997, prevê desde a sua redação original, e de forma mais ampla por alterações posteriores, a autorização para a realização de acordos ou transações, tanto para prevenir como para terminar litígios, extrajudiciais ou judiciais.

361

A Lei 13.129/2015, que alterou a Lei 9.307/1996, estendeu a arbitragem para a “administração pública direta e indireta (...) para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis”, evidenciando a existência também de interesses disponíveis dentre os interesses públicos.

362

A Lei 13.140/2015 admite o uso da “mediação como meio de solução de controvérsias entre particulares e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública” (art. 1.º). Admitida a autocomposição.

363

Há, ainda, as hipóteses de algumas ações trabalhistas e o procedimento especial criminal de *habeas corpus* , que permitem a atuação desacompanhada da parte, sem defesa técnica ou advogado.

364

Brunela Vieira de Vincenzi. *A boa-fé no processo civil* , item n. 1.2.4, p. 112 e ss.

365

José Frederico Marques. *Ensaio sobre a Jurisdição Voluntária* , 1. ed. revista e atualizada, § 28, itens 1-16, p. 288-305. Alfredo de Araújo Lopes da Costa. *A Administração Pública e a ordem jurídica privada (Jurisdição Voluntária)* , cap. XVI, item n. 284, p. 344. Leonardo Greco. *Jurisdição voluntária moderna*, cap. IV a IX, item n. p. 62.

366

STF, RE 418096/RS, rel. Min. Carlos Velloso. “3. A opção pela nacionalidade, embora potestativa, não é de forma livre: há de fazer-se em juízo, em processo de jurisdição voluntária, que finda com a sentença que homologa a

opção e lhe determina a transcrição, uma vez acertados os requisitos objetivos e subjetivos dela” (Informativo n. 381).

367

Berenice Soubhie Nogueira Magri. *Ação Anulatória: art. 486 do CPC*, item n. 9.8, p. 243.

368

Theotonio Negrão; José Roberto F. Gouvêa; Luis Guilherme A. Bondioli; João Francisco N. da Fonseca. *Código de Processo Civil e legislação processual civil em vigor*. 46. ed., art. 11, nota 11-1a.

369

Art. 78. Por morte presumida do segurado, declarada pela autoridade judicial competente, depois de 6 (seis) meses de ausência, será concedida pensão provisória, na forma desta Subseção. § 1.º Mediante prova do desaparecimento do segurado em consequência de acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes farão jus à pensão provisória independentemente da declaração e do prazo deste artigo. § 2.º Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessará imediatamente, desobrigados os dependentes da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé. Art. 79. Não se aplica o disposto no art. 103 desta Lei ao pensionista menor, incapaz ou ausente, na forma da lei.

370

José Orlando Rocha de Carvalho. Procedimentos previstos na Lei de Registros Públicos. *Procedimentos especiais cíveis* : legislação extravagante, item n. 6.1, p. 1278-1290.

371

Idem, item n. 6.2, p. 1290-1304.

372

TJMG, 13.ª Câmara Cível, ApCiv 1.0671.14.001340-8/001, j. 26.03.2018, julgado por Rogério Medeiros.

373

Araken de Assis. O procedimento de dúvida e o princípio de adstrição do juiz ao pedido da parte. *Revista Jurídica*, a. XXXI, v. 107, item n. 1, 35-36.

374

MUSSE, Luciana Barbosa. *Novos sujeitos de direito* : as pessoas com transtorno mental na visão da bioética e do biodireito, item n. 474, p. 95-96.

375

Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. *A tutela de urgência no Direito de Família*, item n. 28, p. 76; Humberto Dalla Bernardina de Pinho. *Direito processual civil contemporâneo* : processo de conhecimento, cautelar, execução e

procedimentos especiais, 2. ed., cap. 2, item 2.12. Carlos Alberto Alvaro de Oliveira reconhece, contudo, que trata-se de medida unilateral, com contraditório e participação de legitimados passivos, item n. 30, p. 77-78.

376

Lacerda Galeno; Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 2. ed. v. VIII, t. II (arts. 813-889), art. 867, item n. 173, p. 279. Ovídio A. Baptista da Silva. *Do processo cautelar*, 2. ed., art. 867-868, item n. I, p. 454. Victor A. A. Bomfim Marins. *Tutela cautelar: teoria geral e poder geral de cautela*, 2. ed., item n. 140, p. 331, afirmando de modo categórico que jamais serão cautelares.

377

José Frederico Marques. *Ensaio sobre a Jurisdição Voluntária*, 1. ed. revista e atualizada, § 28, item 10, p. 299.

378

Ovídio A. Baptista da Silva *Do processo cautelar*, 2. ed., art. 867-868, item n. II, p. 455.

379

Idem, art. 870, item n. III, p. 462.

380

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*. art. 726, item n. 1, p. 702.

381

Idem, ibidem.

382

Ada Pellegrini Grinover. Deformalização do processo e deformalização das controvérsias, *Novas tendências do direito processual*, 2. ed., item n. 1.5, p. 179.

383

Lacerda Galeno. Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 2. ed. v. VIII, t. II (arts. 813-889), art. 867, item n. 173, p. 279. Eduardo Couture é mais solene, e diz que os juízes “se limitam a fiscalizar se o que afirmou o peticionante é prima facie certo, ajustado ao que ele mesmo oferece. É uma tarefa de simples verificação externa, unilateral e formal” Eduardo J. Couture. *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*, item, n. 31, p. 50.

384

Humberto Theodoro Júnior. *Processo Cautelar*, item n. 286, p. 378.

385

Bruno Freire e Silva; Antonio do Passo Cabral; Ronaldo Cramer (coord.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, 2. ed., art. 726, item n. 1, p. 1036.

386

Ovídio A. Baptista da Silva. *Do processo cautelar*, 2. ed., art. 872, p. 468.

387

Teresa Arruda Alvim Wambier; Maria Lúcia Lins Conceição; Leonardo Ferres da Silva Ribeiro; Rogério Licastro Torres de Mello. *Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, art. 726, p. 1074.

388

Arruda Alvim. Regime jurídico da notificação extrajudicial, *Revista de Processo*, n. 3, Jul.-Set., 1976, p. 222-229, item n. IV.

389

Para incluir o *parágrafo único no art. 1.º*: “Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas”.

390

Leonardo Greco. *Jurisdição voluntária moderna*, cap. IV, p. 62.

391

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo código de processo civil comentado*, art. 726, item n. 1, p. 702.

392

Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XII, arts. 796-889, art. 873, item n. 1, p. 341.

393

Idem, item n. 2, p. 341-342.

394

Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XII, arts. 796-889, Seção X, item n. 1, subitem “a”, p. 317.

395

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*, art.

726, item n. 1, p. 702.

396

Ovídio A. Baptista da Silva. *Do processo cautelar*, 2. ed., art. 867-868, item n. II, p. 455.

397

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*, art. 726, item n. 7, p. 703. STJ, REsp, 56030/PR, 3.^a Turma, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 15.10.1996, *DJ* 03.02.1997, p. 714.

398

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*. t. III, art. 726, item n. 6, p. 703.

399

Lacerda Galeno; Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 2. ed. v. VIII, t. II (arts. 813-889), art. 869, item n. 175, p. 286.

400

Cândido R. Dinamarco. Intervenção de terceiro em processo cautelar. *Doutrinas Essenciais de Processo Civil*, v. 5, p. 889, Out/2011 item n 2, p. 1.

401

Ubiratan do Couto Maurício. *Assistência simples no Direito Processual Civil*, item n. 7.5.2, p. 79.

402

Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XII, arts. 796-889, art. 867, item n. 2, p. 328.

403

Ovídio A. Baptista da Silva. *Do processo cautelar*, 2. ed., art. 867-868, item III, p. 456.

404

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*. t. III, art. 726, item n. 5, p. 703. STF, Pleno, Ag Reg na Pet 1.738/MG, rel. Min. Celso de Mello, j. 01.09.1999, *DJ* 01.10.1999, p. 42. STJ, Corte Especial, Pet 4.470/PB, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.02.2006, *DJ* 24.02.2006.

405

São corriqueiras as notificações contra o INSS, tanto na Justiça Federal como na Justiça Estadual, especialmente pela competência delegada, como nos litígios acidentários, de competência dessa justiça comum local. TJSP, Ap

406

Exemplos comuns de procedimentos desta espécie envolvem tanto interpelações, notificações ou protestos.

407

TJSP, CComp 0012264-25.2018.8.26.0000, Câmara Especial, j. 14.05.2018, julgado por Fernando Torres Garcia

408

TRF-3 – Primeira Seção, CC 89770-SP 2006.03.00.089770-0 , j. 19.09.2007, relator Des. Nelton dos Santos.

409

Ovídio A. Baptista da Silva. *Do processo cautelar* , 2. ed., art. 867-868, item III, p. 456.

410

Lacerda Galeno; Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. *Comentários ao Código de Processo Civil* . 2. ed. v. VIII, t. II (arts. 813-889), art. 868, item n. 174, p. 282.

411

Idem, ibidem.

412

Processual Civil. Conflito Negativo de Competência. Ação Cautelar de Protesto Interruptivo de Prazo Prescricional. Medida Meramente Conservativa de Direito. Prevenção Inexistente. Ação Principal. Conflito Conhecido. Competência. Juízo Suscitado. 1. A jurisprudência majoritária perfilha entendimento no sentido de que a existência de uma ação de protesto, meramente conservativas de direito, não tem o condão de torná-la preventa para o julgamento da ação principal, principalmente pelo fato de não possuírem natureza contenciosa. Precedentes desta e. Corte e do c. STJ. 2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 6.^a Vara da Seção Judiciária do Amapá/AP, suscitado. (TRF1, Primeira Seção, rel. Juiz federal Cleberson José da Rocha. CC – Conflito de Competência – 00489135720144010000, j. 24.02.2015, DJF1 06.03.2015).

413

Humberto Theodoro Júnior. *Processo Cautelar*. Item n. 286, p. 379.

414

Humberto Theodoro Júnior. *Curso de Direito Processual Civil* . 52. ed., vol. II, item n. 289, p. 492-493.

415

Teresa Arruda Alvim Wambier; Maria Lúcia Lins Conceição; Leonardo Ferres da Silva Ribeiro; Rogério Licastro

Torres de Mello. *Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, art. 729, p. 1075.

416

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*. t. III, art. 729, item n. 1, p. 705. STJ, RMS 9.570/SP, 4.^a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 25.06.1998, DJ 21.09.1998, p. 163.

417

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*. t. III, art. 726, item n. 8, p. 704. Ver REsp 35.631/CE e REsp 706.293/RS.

418

Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XII, arts. 796-889, art. 872, item n. 4, p. 341.

419

Lacerda Galeno; Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 2. ed. v. VIII, t. II (arts. 813-889), art. 871, item n. 177, p. 293.

420

Humberto Theodoro Júnior. *Processo Cautelar*. Item n. 285, p. 378.

421

Lucas Buril de Macêdo; Lenio Luiz Streck; Dierle Nunes; Leonardo Cunha (orgs.). *Comentários do Código de Processo Civil (de acordo com a Lei n. 13.256/2016)*, art. 729, item n. 2, p. 962.

422

Victor A. A. Bomfim Marins. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 12, *Do processo cautelar*, arts. 813-889, art. 872, item n. 10, p. 354-346. (TJPR – 1.a Câm. Cív. ApCiv 0036999500, Ac. 12752, rel. Des. Oto Sponholz, unânime – ementa parcial).

423

Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XII, arts. 796-889, art. 873, item n. 5, p. 344.

424

Ovídio A. Baptista da Silva. *Do processo cautelar*, 2. ed., art. 867-868, item IV, p. 457.

425

Idem, art. 868. Item I, p. 458.

Humberto Theodoro Júnior. *Processo Cautelar*. Item n. 286, p. 378.

Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil*, art. 729, item n. 2, p. 1564.

Teresa Arruda Alvim Wambier; Maria Lúcia Lins Conceição; Leonardo Ferres da Silva Ribeiro; Rogério Licastro Torres de Mello. *Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, art. 726, p. 1074.

Ovídio A. Baptista da Silva. *Do processo cautelar*, 2. ed., art. 869, item II, p. 460.

Lacerda Galeno; Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 2. ed. v. VIII, t. II (arts. 813-889), art. 870, item n. 176, p. 290.

Lucas Buril de Macêdo; Lenio Luiz Streck; Dierle Nunes; Leonardo Cunha (orgs.). *Comentários do Código de Processo Civil (de acordo com a Lei n. 13.256/2016)*, art. 726, item n. 2, p. 960.

CC/2002, Art. 576. Se a coisa for alienada durante a locação, o adquirente não ficará obrigado a respeitar o contrato, se nele não for consignada a cláusula da sua vigência no caso de alienação, e não constar de registro. § 2º. Em se tratando de imóvel, e ainda no caso em que o locador não esteja obrigado a respeitar o contrato, não poderá ele despedir o locatário, senão observado o prazo de noventa dias após a notificação.

CC/2002, Art. 769. O segurado é obrigado a comunicar ao segurador, logo que saiba, todo incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à garantia, se provar que silenciou de má-fé. § 1º. O segurador, desde que o faça nos quinze dias seguintes ao recebimento do aviso da agravação do risco sem culpa do segurado, poderá dar-lhe ciência, por escrito, de sua decisão de resolver o contrato. § 2º. A resolução só será eficaz trinta dias após a notificação, devendo ser restituída pelo segurador a diferença do prêmio.

CC/2002, Art. 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor.

435

CC/2002, Art. 1.004. Os sócios são obrigados, na forma e prazo previstos, às contribuições estabelecidas no contrato social, e aquele que deixar de fazê-lo, nos trinta dias seguintes ao da notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo dano emergente da mora.

436

CC/2002, Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa.

437

CC/2002, Art. 1.145. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores, ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em trinta dias a partir de sua notificação.

438

TJSP, Ap 1001049-54.2015.8.26.0157, 6.ª Câmara de Direito Privado, j. 21.10.2016, julgado por Eduardo Sá Pinto Sandeville.

439

Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil*, art. 726, item n. 3, p. 1563.

440

Victor A. A. Bomfim Marins. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 12, do processo cautelar, arts. 813-889, art. 867, item n. 3, subitem 3.1, p. 337.

441

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*. t. III, art. 726, item n. 1, p. 702.

442

Ovídio A. Baptista da Silva. *Do processo cautelar*, 2. ed., art. 870, item V, p. 463-465.

443

Idem, *ibidem*.

444

Idem, *ibidem*.

445

Ver: Helena Najjar Abdo. *O abuso de processo* , item n. 18, p. 107, dentre outros; Brunela Vieira de Vincenzi. *A boa-fé no processo civil* , item n. 1.2.4, p. 112.

446

Luiz Guilherme Marinoni. Sérgio Cruz Arenhart. Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*. t. III, art. 726, item n. 4, p. 703.

447

Lucas Buril de Macêdo; Lenio Luiz Streck; Dierle Nunes; Leonardo Cunha (orgs.). *Comentários do Código de Processo Civil (de acordo com a Lei n. 13.256/2016)* , art. 726, item n. 2, p. 960.

448

Marcelo Miguel Conrado; José Sebastião Fagundes Cunha (coordenador-geral); Antonio César Bochenek; Eduardo Cambi (coordenadores). *Código de Processo Civil Comentado*, art. 726, p. 1013-1014.

449

Teresa Arruda Alvim Wambier; Maria Lúcia Lins Conceição; Leonardo Ferres da Silva Ribeiro; Rogério Licastro Torres de Mello. *Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil* , art. 726, p. 1074.

450

Idem, ibidem.

451

Processual Civil. Conflito de Competência. Notificação Judicial. Valor da Causa. Juizado Especial e Juízo Comum. 1. Conquanto disciplinados no Livro III do Código de Processo Civil, os protestos, as notificações e as interpelações não são medidas cautelares, pois não visam a assegurar o resultado útil de provimento jurisdicional futuro e tampouco pressupõem o concurso do *fumus boni juris* e do *periculum in mora* . 2. Os protestos, as notificações e as interpelações previstos nos arts. 867 e seguintes do Código de Processo Civil não possuem conteúdo econômico imediato, de sorte que o valor da causa pode ser atribuído livremente pelo requerente. 3. O rito especialíssimo dos protestos, notificações e interpelações não se ajusta ao procedimento seguido nos Juizados Especiais. 4. Dada a especialidade do respectivo rito, os protestos, as notificações e as interpelações devem tramitar perante o Juízo comum e não pelos Juizados Especiais, ainda que se atribua à causa valor inferior a sessenta salários mínimos. 5. A distribuição, a determinado juízo, para processar pedido de notificação, protesto ou interpelação não gera prevenção para eventual demanda futura. (TRF3, Primeira Seção, rel. Des. Nelson dos Santos, CC – Conflito De Competência – 9740, j 19.07.2007, DJU 19.10.2007).

452

Humberto Theodoro Júnior. *Processo Cautelar* , item n. 285, p. 378.

453

Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil* , art. 726, item n. 4, p. 1563.

454

Ovídio A. Baptista da Silva. *Do processo cautelar* , 2. ed., art. 869, item n. I, p. 458.

455

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*. t. III, art. 726, item n. 6, p. 703.

456

TJSP, Ap 1001049-54.2015.8.26.0157, 6.ª Câmara de Direito Privado, j. 21.10.2016, julgado por Eduardo Sá Pinto Sandeville.

457

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*. t. III, art. 726, item n. 3, p. 703.

458

Lacerda Galeno; Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. *Comentários ao Código de Processo Civil* . 2. ed. v. VIII, t. II (arts. 813-889), art. 870, item n. 176, p. 289.

459

Ovídio A. Baptista da Silva. *Do processo cautelar* , 2. ed., art. 870, item V, p. 465.

460

Teresa Arruda Alvim Wambier; Maria Lúcia Lins Conceição; Leonardo Ferres da Silva Ribeiro; Rogério Licastro Torres de Mello. *Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil* , art. 728, p. 1075.

461

Ovídio A. Baptista da Silva. *Do processo cautelar* , 2. ed., art. 869, item II, p. 459.

462

Ver: Brunela Vieira de Vincenzi. *A boa-fé no processo civil* , item n. 1.2.4, p. 112. Helena Najjar Abdo . *O abuso de processo* , item n. 18, p. 107.

463

Ovídio A. Baptista da Silva. *Do processo cautelar* , 2. ed., art. 869, item II, p. 460, citando Hugo Simas, *Comentários* , v. VIII, t. 2, p. 292.

464

TJSP, Ap 1002381-35.2017.8.26.0400, 23.^a Câmara de Direito Privado, j. 09.03.2018, julgado por Sebastião Flávio da Silva Filho.

465

Humberto Theodoro Júnior. *Processo Cautelar*. item n. 285, p. 377.

466

Lacerda Galeno. Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 2. ed. v. VIII, t. II (arts. 813-889), art. 870, item n. 176, p. 289.

467

Ovídio A. Baptista da Silva *Do processo cautelar*, 2. ed., art. 869, item II, p. 460.

468

Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil*, art. 727, item n. 2, p. 1563.

469

Luiz Guilherme Marinoni. *Técnica processual e tutela dos direitos*, item n. 7.8.1, p. 190; embora o autor não se refira à técnica comunicacional, esta pode ser identificada como útil à proteção de direitos.

470

Lucas Buril de Macêdo; Lenio Luiz Streck; Dierle Nunes; Leonardo Cunha (orgs.). *Comentários do Código de Processo Civil (de acordo com a Lei n. 13.256/2016)*, art. 727, item n. 2, p. 960-961.

471

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

472

Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial.

473

Art. 525. O vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o comprador em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial.

474

Teresa Arruda Alvim Wambier; Maria Lúcia Lins Conceição; Leonardo Ferres da Silva Ribeiro; Rogério Licastro Torres de Mello. *Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, art. 729, p. 1075.

475

Lucas Buril de Macêdo; Lenio Luiz Streck; Dierle Nunes; Leonardo Cunha (orgs.). *Comentários do Código de Processo Civil (de acordo com a Lei n. 13.256/2016)*, art. 728, item n. 2, p. 961.

476

Idem, p. 962.

477

Idem, item n. 2, p. 1564.

478

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*. t. III, art. 728, item n. 1, p. 704.

479

Marcelo Miguel Conrado; José Sebastião Fagundes Cunha (coordenador-geral); Antonio César Bochenek; Eduardo Cambi (coordenadores). *Código de Processo Civil Comentado*, art. 728, p. 1014.

480

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*. t. III, art. 728, item n. 4, p. 705.

481

Lucas Buril de Macêdo; Lenio Luiz Streck; Dierle Nunes; Leonardo Cunha (orgs.). *Comentários do Código de Processo Civil (de acordo com a Lei n. 13.256/2016)*, art. 728, item n. 2, p. 961.

482

Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil*, art. 728, item n. 2, p. 1564.

483

Lacerda Galeno; Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 2. ed. v. VIII, t. II (arts. 813-889), art. 871, item n. 177, p. 292.

484

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart. Daniel Mitidiero. *Novo código de processo civil comentado*. t. III, art. 728, item n. 2, p. 704.

485

Teresa Arruda Alvim Wambier; Maria Lúcia Lins Conceição; Leonardo Ferres da Silva Ribeiro; Rogério Licastro Torres de Mello. *Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, art. 728, p. 1075.

486

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*. t. III, art. 728, item n. 3, p. 704.

487

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*. t. III, art. 728, item n. 3, p. 704. (STJ, REsp 440.837/RS Corte Especial, rel. Ministra Eliana Calmon. Para acórdão Min. Barro Monteiro, j. 16.08.2006, DJ 28.05.2007, p. 260).

488

“Penso ser cabível a averbação do protesto contra a alienação de bens, sobretudo em face do poder geral de cautela do Juiz, na linha do que dispõe o art. 798 do Código de Processo Civil. Na verdade, a averbação não agride direito algum dos ora embargantes, uma vez que, ante o princípio da publicidade, tem ela por escopo dar conhecimento a terceiros interessados do protesto deferido, visando com isso a proteger o adquirente de boa-fé. Em julgado anterior (REsp 146.942-RS), sob a relatoria do Ministro Cesar Asfor Rocha, aquele mesmo órgão julgador admitira a averbação do protesto contra a alienação de bens, escudado na seguinte motivação: “Ademais, a averbação está dentro do poder geral de cautela do juiz (art. 798, CPC) e ela se justifica pela necessidade de dar conhecimento do protesto a terceiros e isso porque eventual alienação do bem poderá vir a ser desconstituída. Não é outra a finalidade da publicação dos editais, mas que nem sempre, como a prática demonstra, alcança seus objetivos e o comprador pode acabar seriamente prejudicado com o desfazimento do ato. O meio realmente eficaz é o lançamento no Registro de Imóveis, onde os possíveis adquirentes deverão consultar”.

489

Lacerda Galeno; Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 2. ed. v. VIII, t. II (arts. 813-889), art. 872, item n. 178, p. 294-295.

490

TJSP, Ap 1135920-61.2016.8.26.0100, 26.^a Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2017, julgado por Antonio Benedito do Nascimento.

491

TJSP, Ap 1123015-24.2016.8.26.0100, 1.^a Câmara de Direito Privado, j. 20.02.2018, julgado por Francisco Loureiro.

492

RECURSO ESPECIAL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. ART. 213, INCISO I, ALÍNEAS *D E E* , DA LEI 6.015/1973. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de ação de retificação de matrícula de imóvel (jurisdição voluntária), objetivando a correta delimitação do bem registrado, em que foi equivocadamente indicada pessoa para ser citada como suposta proprietária de área confrontante. 2. Inviável o acolhimento do pleito exordial, em recurso especial, pois o dispositivo legal invocado (art. 216, I, alíneas *d e e* , da Lei 6.015/1973) não garante automaticamente a retificação do registro, nem infirma o fundamento adotado no acórdão recorrido para rejeitar a pretensão inicial, qual seja, a insuficiência de prova da propriedade da área reclamada. Incidência da Súmula 284/STF. 2. *Em procedimento de jurisdição voluntária, a existência de litigiosidade excepciona a regra de não cabimento de condenação em honorários advocatícios. Precedentes.* 3. *No caso, a mera alegação de ilegitimidade de parte citada como confrontante não torna litigiosa a demanda, não lhe cabendo, portanto, honorários sucumbenciais.* 4. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, Terceira Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, RESP – RECURSO ESPECIAL – 1524634, j. 27.10.2015, DJ 03.11.2015) E mais: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. INCIDÊNCIA. REGISTRO IMOBILIÁRIO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. – Falta prequestionamento quando o tema objeto do Recurso Especial não foi debatido na formação do acórdão recorrido (Súmulas 211, do STJ e 282, do STF). – *Não são devidos honorários advocatícios no pedido de retificação do registro imobiliário – procedimento de jurisdição voluntária* . Eventual impugnação não transforma em jurisdicional a atividade administrativa nele exercida pelo juiz. (STJ, Terceira Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, AGA – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – 387066, j. 25.09.2006, DJ 16.10.2006) E mais: PROCESSUAL CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. RATEIO. – *Em procedimento de jurisdição voluntária não existe vencedor ou vencido a justificar a condenação em honorários advocatícios. – As despesas processuais, conforme preceitua o art. 24 do CPC, devem ser rateadas entre requerente e requerido.* – Apelação provida, em parte. (TRF5, Primeira Turma, rel. Des. Cesar Carvalho, AC – Apelação Cível – 309803, j. 21.10.2004, DJ 30.11.2004).

493

Lucas Buril de Macêdo; Lenio Luiz Streck; Dierle Nunes; Leonardo Cunha (orgs.). *Comentários do Código de Processo Civil (de acordo com a Lei n. 13.256/2016)*, art. 729, item n. 2, p. 962.

494

Ovídio A. Baptista da Silva. *Do processo cautelar* , 2. ed., art. 872, p. 468; Lacerda Galeno; Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. *Comentários ao Código de Processo Civil* . 2. ed. v. VIII, t. II (arts. 813-889), art. 872, item n. 178, p. 294.

495

Ovídio A. Baptista da Silva. *Do processo cautelar* , 2. ed., art. 867-868, item IV, p. 457.

496

Berenice Soubhie Nogueira Magri. *Ação Anulatória: art. 486 do CPC* , item n. 9.5, p. 229-230.

497

Ovídio A. Baptista da Silva. *Do processo cautelar* , 2. ed., art. 872, p. 468.

498

Luis Alberto Reichelt. *A exigência de publicidade dos atos processuais na perspectiva do direito ao processo justo*. Revista de Processo, vol. 234/2014, p. 77-97, ago./2014, item n. 2, p. 2.

499

Luis Alberto Reichelt. *A exigência de publicidade dos atos processuais na perspectiva do direito ao processo justo*. Revista de Processo, vol. 234/2014, p. 77-97, ago./2014, item n. 4.1, p. 5.

500

Ovídio A. Baptista da Silva. *Do processo cautelar*, 2. ed., art. 869, item II, p. 460.

501

Luis Alberto Reichelt. *A exigência de publicidade dos atos processuais na perspectiva do direito ao processo justo*. Revista de Processo, vol. 234/2014, p. 77-97, ago./2014, item n. 4.3.2, p. 9.

502

Lacerda Galeno; Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 2. ed. v. VIII, t. II (arts. 813-889), art. 870, item n. 176, p. 290.

503

João Paulo Lucena. *Comentários ao código de processo civil*. v. 15, art. 1.113, item n. 1, p. 120.

504

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, arts. 1.113 e 1.114, item n. 1, p. 91.

505

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*, art. 730, item n. 1, p. 705.

506

Teresa Arruda Alvim Wambier; Maria Lúcia Lins Conceição; Leonardo Ferre da Silva Ribeiro; Rogério Licastro Torres de Mello. *Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, art. 730, p. 1076.

507

Bruno Freire e Silva; Antonio do Passo Cabral; Ronaldo Cramer (coord.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, 2a ed., art. 730, item n. 2, p. 1040.

508

Lucas Buril de Macêdo; Lenio Luiz Streck; Dierle Nunes; Leonardo Cunha (orgs.). *Comentários do Código de*

509

Bruno Freire; Silva Antonio do Passo Cabral; Ronaldo Cramer (coord.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, 2a ed., art. 730, item n. 2, p. 1040.

510

Lucas Buril de Macêdo; Lenio Luiz Streck; Dierle Nunes; Leonardo Cunha (orgs.). *Comentários do Código de Processo Civil (de acordo com a Lei n. 13.256/2016)* , art. 730, item n. 2, p. 963.

511

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil* , v. XII, art. 1.113, item n. 34, p. 119.

512

Edson Prata. *Comentários ao Código de Processo Civil* , v. 7, art. 1.113, item n.14, p. 62.

513

Idem, item n. 4, p. 64.

514

Bruno Freire; Silva Antonio do Passo Cabral; Ronaldo Cramer (coord.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, 2a ed., art. 730, item n. 2, p. 1039-1040.

515

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil* , t. XVI, art. 1.117, item n. 4, p. 106; Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil* , v. XII, art. 1.117, item n. 49, p. 140; José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil* . 5. ed. v. X, art. 1.117, item n. 49, p. 123; João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo civil* . v. 15, art. 1.117, item n. 4, p. 132.

516

Art. 896. Quando o imóvel de incapaz não alcançar em leilão pelo menos oitenta por cento do valor da avaliação, o juiz o confiará à guarda e à administração de depositário idôneo, adiando a alienação por prazo não superior a 1 (um) ano. § 1.º Se, durante o adiamento, algum pretendente assegurar, mediante caução idônea, o preço da avaliação, o juiz ordenará a alienação em leilão. § 2.º Se o pretendente à arrematação se arrepender, o juiz impor-lhe-á multa de vinte por cento sobre o valor da avaliação, em benefício do incapaz, valendo a decisão como título executivo. § 3.º Sem prejuízo do disposto nos §§ 1.º e 2.º, o juiz poderá autorizar a locação do imóvel no prazo do adiamento. § 4.º Findo o prazo do adiamento, o imóvel será submetido a novo leilão.

517

Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

518

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil* . 5. ed. v. X, art. 1.113, item n. 40-A, p. 110.

519

Idem, p. 109.

520

TJSP, Ap 0005485-14.2015.8.26.0306, 6.^a Câmara de Direito Privado, j. 30.05.2018, julgado por Rodolfo Pellizar.

521

Humberto Theodoro Júnior. Alienações judiciais . *Revista de Processo* , vol. 21/1981, p. 9-18, Jan.-Mar./1981, item n. 1, p. 1.

522

Idem, ibidem.

523

João Paulo Lucena. *Comentários ao código de processo civil* . v. 15, art. 1.113, item n. 1, p. 121.

524

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil* , v. XII, art. 1.113, item n. 35, p. 121.

525

Edson Prata. *Comentários ao Código de Processo Civil* , v. 7, art. 1.113, item n.1, p. 62.

526

TJSP, Ap 1000707-74.2015.8.26.0470, 3.^a Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2016, julgado por Carlos Alberto de Salles.

527

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado* , art. 730, item n. 4, p. 705.

528

Teresa Arruda Alvim Wambier; Maria Lúcia Lins Conceição; Leonardo Ferre da Silva Ribeiro; Rogério Licastro Torres de Mello. *Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil* , art. 730, p. 1076.

529

Ver Brunela Vieira de Vicenzi. *A boa-fé no processo civil*, item n. 1.2.4, p. 112; Helena Najjar Abdo. *O abuso de processo*, item n. 18, p. 107.

530

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*. t. III, art. 730, item n. 2, p. 705.

531

Lucas Buril de Macêdo; Lenio Luiz Streck; Dierle Nunes; Leonardo Cunha (orgs.). *Comentários do Código de Processo Civil (de acordo com a Lei n. 13.256/2016)*, art. 730, item n. 2, p. 963-964.

532

Lucas Buril de Macêdo; Lenio Luiz Streck; Dierle Nunes; Leonardo Cunha (orgs.). *Comentários do Código de Processo Civil (de acordo com a Lei n. 13.256/2016)*, art. 730, item n. 2, p. 964.

533

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo código de processo civil comentado*. t. III, art. 730, item n. 1, p. 705.

534

José Miguel Garcia Medina. *Direito Processual Civil Moderno*. 2. ed. Art. 730, item n. 3.3, p. 885.

535

Lucas Buril de Macêdo; Lenio Luiz Streck; Dierle Nunes; Leonardo Cunha (orgs.). *Comentários do Código de Processo Civil (de acordo com a Lei n. 13.256/2016)*, art. 730, item n. 2, p. 963.

536

José Miguel Garcia Medina. *Direito Processual Civil Moderno*. 2. ed. Art. 730, item n. 3.3, p. 885.

537

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*. t. II, art. 879, item 1, p. 822.

538

Art. 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. § 1.º O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem. § 2.º A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, expedindo-se: I – a carta de

alienação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel; II – a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel. § 3.º Os tribunais poderão editar disposições complementares sobre o procedimento da alienação prevista neste artigo, admitindo, quando for o caso, o concurso de meios eletrônicos, e dispor sobre o credenciamento dos corretores e leiloeiros públicos, os quais deverão estar em exercício profissional por não menos que 3 (três) anos. § 4.º Nas localidades em que não houver corretor ou leiloeiro público credenciado nos termos do § 3.º, a indicação será de livre escolha do exequente.

539

Luiz Guilherme Marinoni. Sérgio Cruz Arenhart. Daniel Mitidiero. *Novo código de processo civil comentado*. t. II, art. 880, item n. 10, p. 823.

540

Bruno Freire; Silva Antonio do Passo Cabral; Ronaldo Cramer (coord.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, 2a ed., art. 730, item n. 1, p. 1029.

541

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*, art. 880, item n. 2, p. 822.

542

Idem, item n. 3, p. 822-823.

543

Idem, item n. 6, p. 823.

544

Idem, item n. 7, p. 823.

545

Art. 881. A alienação far-se-á em leilão judicial se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular. § 1º O leilão do bem penhorado será realizado por leiloeiro público. § 2º Ressalvados os casos de alienação a cargo de corretores de bolsa de valores, todos os demais bens serão alienados em leilão público.

546

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*, art. 881, item n. 1, p. 824.

547

Art. 882. Não sendo possível a sua realização por meio eletrônico, o leilão será presencial. § 1.º A alienação judicial por meio eletrônico será realizada, observando-se as garantias processuais das partes, de acordo com

regulamentação específica do Conselho Nacional de Justiça. § 2.º A alienação judicial por meio eletrônico deverá atender aos requisitos de ampla publicidade, autenticidade e segurança, com observância das regras estabelecidas na legislação sobre certificação digital. § 3º O leilão presencial será realizado no local designado pelo juiz.

548

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*, art. 882, item n. 2, p. 824.

549

Art. 883. Caberá ao juiz a designação do leiloeiro público, que poderá ser indicado pelo exequente.

550

Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá: I – a descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros; II – o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado; III – o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes e, tratando-se de créditos ou direitos, a identificação dos autos do processo em que foram penhorados; IV – o sítio, na rede mundial de computadores, e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização; V – a indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro; VI – menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados. Parágrafo único. No caso de títulos da dívida pública e de títulos negociados em bolsa, constará do edital o valor da última cotação.

551

Art. 887. O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla divulgação da alienação. § 1.º A publicação do edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada para o leilão. § 2.º O edital será publicado na rede mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou presencial. § 3.º Não sendo possível a publicação na rede mundial de computadores ou considerando o juiz, em atenção às condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local. § 4.º Atendendo ao valor dos bens e às condições da sede do juízo, o juiz poderá alterar a forma e a frequência da publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de ampla circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou televisão local, bem como em sítios distintos do indicado no § 2.º § 5.º Os editais de leilão de imóveis e de veículos automotores serão publicados pela imprensa ou por outros meios de divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à publicidade dos respectivos negócios. § 6.º O juiz poderá determinar a reunião de publicações em listas referentes a mais de uma execução.

552

Art. 884. Incumbe ao leiloeiro público: I – publicar o edital, anunciando a alienação; II – realizar o leilão onde se encontrem os bens ou no lugar designado pelo juiz; III – expor aos pretendentes os bens ou as amostras das mercadorias; IV – receber e depositar, dentro de 1 (um) dia, à ordem do juiz, o produto da alienação; V – prestar contas nos 2 (dois) dias subsequentes ao depósito. Parágrafo único. O leiloeiro tem o direito de receber do

arrematante a comissão estabelecida em lei ou arbitrada pelo juiz.

553

Regula a profissão de Leiloeiro ao território da República.

554

(STJ, 5.^a Turma, REsp 680.140/RS, rel. Min. Gilson Dipp, j. 02.02.2006, DJ 06.03.2006. p. 429). Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*, art. 884, item n. 1, p. 825.

555

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*, art. 885, item n. 1, p. 825.

556

Idem, ibidem.

557

Art. 888. Não se realizando o leilão por qualquer motivo, o juiz mandará publicar a transferência, observando-se o disposto no art. 887. Parágrafo único. O escrivão, o chefe de secretaria ou o leiloeiro que culposamente der causa à transferência responde pelas despesas da nova publicação, podendo o juiz aplicar-lhe a pena de suspensão por 5 (cinco) dias a 3 (três) meses, em procedimento administrativo regular.

558

André Vasconcelos Roque; José Rogério Cruz e Tucci; Manoel Caetano Ferreira Filho; Ricardo de Carvalho Aprigliano; Rogéria Fagundes Dotti; Sandro Gilbert Martins (coord.). *Código de Processo Civil Anotado*. OAB/SP, art. 888, item I, p. 1374.

559

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*. t. II, art. 888, item n. 1, p. 827.

560

André Vasconcelos Roque; José Rogério Cruz e Tucci; Manoel Caetano Ferreira Filho; Ricardo de Carvalho Aprigliano; Rogéria Fagundes Dotti; Sandro Gilbert Martins (coord.). *Código de Processo Civil Anotado*. OAB/SP, art. 888, item II, p. 1374.

561

João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil*. v. 15, art. 1.113, item n. 3, p. 122.

562

Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil* , art. 889, item n. 3, p. 1771.

563

João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil* . v. 15, art. 1.113, item n. 3, p. 122.

564

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado* , art. 730, item n. 2, p. 705; José Rogério Cruz e Tucci; Manoel Caetano Ferreira Filho; Ricardo de Carvalho Aprigliano; Rogéria Fagundes Dotti; Sandro Gilbert Martins. *Código de Processo Civil Anotado* , art. 730, p. 1132, (Eduardo Parente).

565

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*. t. III, art. 730, item n. 2, p. 705.

566

Lucas Buril de Macêdo; Lenio Luiz Streck; Dierle Nunes; Leonardo Cunha (orgs.). *Comentários do Código de Processo Civil (de acordo com a Lei n. 13.256/2016)* , art. 730, item n. 2, p. 963-964.

567

Idem, ibidem.

568

OAB/SP p. 1058.

569

Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1.º O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2.º O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. § 3.º Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.

570

Art. 885. O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante.

571

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda; *Comentários ao Código de Processo Civil* , t. XVI, arts. 1.113 e 1.114, item

n. 6, p. 96.

572

João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil* . v. 15, art. 1.114, item n. 1, p. 124.

573

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil* . 5. ed. v. X, art. 1.114, item n. 42, p. 112.

574

Idem, *ibidem*.

575

Edson Prata. *Comentários ao Código de Processo Civil* , v. 7, art. 1.114, item n.1, p. 65.

576

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil* , v. XII, art. 1.114, item n. 39, p. 126.

577

João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil* . v. 15, art. 1.114, item n. 1, p. 123.

578

Art. 896. Quando o imóvel de incapaz não alcançar em leilão pelo menos oitenta por cento do valor da avaliação, o juiz o confiará à guarda e à administração de depositário idôneo, adiando a alienação por prazo não superior a 1 (um) ano. § 1.º Se, durante o adiamento, algum pretendente assegurar, mediante caução idônea, o preço da avaliação, o juiz ordenará a alienação em leilão. § 2.º Se o pretendente à arrematação se arrepender, o juiz impor-lhe-á multa de vinte por cento sobre o valor da avaliação, em benefício do incapaz, valendo a decisão como título executivo. § 3.º Sem prejuízo do disposto nos §§ 1.º e 2.º, o juiz poderá autorizar a locação do imóvel no prazo do adiamento. § 4.º Findo o prazo do adiamento, o imóvel será submetido a novo leilão.

579

Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil* , art. 896, item n. 2, p. 1779.

580

Idem, item n. 3, p. 1780.

581

Art. 897. Se o arrematante ou seu fiador não pagar o preço no prazo estabelecido, o juiz impor-lhe-á, em favor do exequente, a perda da caução, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o

arrematante e o fiador remissos.

582

Art. 898. O fiador do arrematante que pagar o valor do lance e a multa poderá requerer que a arrematação lhe seja transferida.

583

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil* . 5. ed. v. X, art. 1.113, item n. 41, p. 111.

584

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*. t. III, art. 886, item n. 1, p. 825.

585

Idem, item n. 1, p. 827.

586

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil* , t. XVI, art. 1.115, item n. 1, p. 98-99.

587

Edson Prata. *Comentários ao Código de Processo Civil* , v. 7, art. 1.115, item n.1, p. 66.

588

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil* . 5. ed. v. X, art. 1.115, item n. 43, p. 113.

589

João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil* . v. 15, art. 1.113, item n. 1, p. 121.

590

Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil* , art. 890, item n. 1, p. 1772.

591

Idem, item n. 6, p. 1773.

592

Bruno Freire; Silva Antonio do Passo Cabral; Ronaldo Cramer (coord.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, 2. ed., art. 730, item n. 1, p. 1029.

593

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*. t. II, art. 891, item n. 1, p. 829.

594

Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil*, art. 891, item n. 3, p. 1774.

595

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*. t. II, art. 891, item n. 1, p. 829.

596

Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil*, art. 895, item n. 2, p. 1778.

597

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*. t. III, art. 894, item n. 1, p. 830.

598

Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil*, art. 895, item n. 2, p. 1778.

599

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*. t. II, art. 895, item n. 2, p. 831-832.

600

§ 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.

601

João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil*. v. 15, art. 1.116, item n. 1, p. 128; José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. v. X, art. 1.116, item n. 44, p. 113-114.

602

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.116, item n. 44.1, p. 131.

Edson Prata. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 7, art. 1.116, item n.1, p. 67.

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, art. 1.116, item n. 3, p. 102.

Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil*, art. 900, item n. 2, p. 1781.

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*, art. 880, item n. 7, p. 823.

Art. 902. No caso de leilão de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de arrematação, oferecendo preço igual ao do maior lance oferecido. Parágrafo único. No caso de falência ou insolvência do devedor hipotecário, o direito de remição previsto no caput defere-se à massa ou aos credores em concurso, não podendo o exequente recusar o preço da avaliação do imóvel.

Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil*, art. 902, item n. 2, p. 1782.

Alienação judicial. Embargos à arrematação. Impossibilidade “Na alienação judicial de coisa comum (CPC, arts. 1.112 a 1.119), inadmissível é a oposição de embargos à arrematação” (STJ, 4.^a T., REsp 184465/MG, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. em 10.10.2000, DJU de 18.02.2000).

Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4.^o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. § 1.^o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: I – invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício; II – considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804; III – resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. § 2.^o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1.^o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação. § 3.^o Passado o prazo previsto no § 2.^o sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1.^o, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse. § 4.^o Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário. § 5.^o O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: I – se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a existência de ônus

real ou gravame não mencionado no edital; II – se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no § 1.º; III – uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata o § 4.º deste artigo, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação. § 6.º Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a suscitação infundada de vício com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante, devendo o suscitante ser condenado, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, ao pagamento de multa, a ser fixada pelo juiz e devida ao exequente, em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do bem.

611

Frederico Fontoura da Silva Cais; José Rogério Cruz e Tucci; Manoel Caetano Ferreira Filho; Ricardo de Carvalho Aprigliano; Rogéria Fagundes Dotti; Sandro Gilbert Martins (coord.). *Código de Processo Civil Anotado*. OAB/SP, art. 903, item II, p. 1392.

612

Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil*, art. 903, item n. 2, p. 1783.

613

Frederico Fontoura da Silva Cais; José Rogério Cruz e Tucci; Manoel Caetano Ferreira Filho; Ricardo de Carvalho Aprigliano; Rogéria Fagundes Dotti; Sandro Gilbert Martins (coord.). *Código de Processo Civil Anotado*. OAB/SP, art. 903, item II, p. 1392.

614

Introduzidos pela Lei 11.441/2007, que introduziu o art. 1.124-A no CPC/1973, permitiu a separação consensual e o divórcio consensual por escritura pública, não havendo filhos menores ou incapazes do casal, permitindo a partilha dos bens comuns, a pensão alimentícia e, ainda, retomada ou manutenção do nome do cônjuge. A matéria foi disciplinada pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução 35, de 24 de abril de 2007, que foi recentemente alterada pela Resolução 220, de 26 de abril de 2016, que acrescentou a hipótese de o cônjuge virago se encontrar em estado gravídico como também fator impeditivo para a lavratura de escritura pública de separação consensual.

615

Pontes de Miranda, referindo-se ao desquite amigável, destaca que nessa ação “duas as pessoas que exercem, juntas, a pretensão à tutela jurídica, de modo que há a simultaneidade”. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, cap. I, item n. 1, p. 6-7.

616

F. C. Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, Disposições Gerais, item n. 2, p. 6 e 12. O autor, como em sua tradicional teoria, afirmava que na jurisdição voluntária “há a pretensão à tutela jurídica, há o direito, a pretensão e a ação de direito material e há a ‘ação’ (remédio processual)”.

617

A Constituição Federal de 1967 dispunha no artigo 175 que: “A família é constituída pelo casamento e terá direito

à proteção dos Podêres Públicos”, cujo caráter de indissolubilidade do vínculo conjugal era expressamente reforçado pelo teor do seu § 1.º: “O casamento é indissolúvel”. Somente a partir da Emenda Constitucional 9/77, que alterou o referido teor do § 1.º para dispor, expressamente, que “O casamento somente poderá ser dissolvido, nos casos expressos em lei, desde que haja prévia separação judicial por mais de três anos”, é que foi incluída no ordenamento pátrio a possibilidade jurídica do divórcio e da separação, os quais foram posteriormente regulados pela Lei 6.515/1977.

618

Lenio Luiz Streck. Por que é inconstitucional “repristinar” a separação judicial no Brasil. Consultor Jurídico. 18 de novembro de 2014. Disponível em: [www.conjur.com.br/2014-nov-18/lenio-streck-inconstitucional-repristinar-separacao-judicial]. Acesso em: 11 ago. 2016. Recorrendo ao próprio histórico do desenvolvimento jurídico do instituto da separação judicial, o autor identifica que a transformação do divórcio em espécie de direito potestativo, por força da EC 66/2010, esvaziou a própria relevância e utilidade da separação como etapa prévia exigida para o divórcio. É do autor a reflexão de que “Para o tema voltar ao ‘mundo jurídico’, só por alteração da Constituição”.

619

Paulo Lôbo. Novo CPC não recriou ou restaurou a separação judicial. Consultor Jurídico. 08 de novembro de 2015. Disponível em: [www.conjur.com.br/2015-nov-08/processo-familiar-cpc-nao-recriou-ou-restaurou-separacao-judicial]. Acesso em: 11 ago. 2016. O autor ressalta a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, após a EC 66/2010, foi incisiva ao afirmar que o instituto da separação judicial havia sido excluído do ordenamento jurídico brasileiro.

620

STJ, REsp 1.247.098 , 4.ª T., j. 14.03.2017, julgado por Maria Isabel Diniz Gallotti Rodrigues. Neste julgamento restou vencido o Ministro Luis Felipe Salomão.

621

Maria Berenice Dias. *Manual de Direito das Famílias* , 11. ed., item n. 13.2, p. 210.

622

Flávio Tartuce. *O novo CPC e o direito civil: impactos, diálogos e interações*. 2. ed. item n. 13, p. 377.

623

Em relação ao direito real de habitação, previsto pelo art. 7º da Lei 9.278/1996 e não reproduzido pelo CC/2002, a doutrina defende que não houve sua revogação.

624

STJ, 3.ª T., REsp 1383624/MG, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 12.06.2015.

625

Informativo STF 824. MS 33008/DF, rel. Min. Roberto Barroso, 03.05.2016.

(STJ, 3.^a T., REsp 1291924/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, *DJe* 07.03.2013). 1. Recurso especial tirado de acórdão que, na origem, fixou a competência do Juízo Civil para apreciação de ação de reconhecimento e dissolução de união estável homoafetiva, em detrimento da competência da Vara de Família existente. 2. A plena equiparação das uniões estáveis homoafetivas, às uniões estáveis heteroafetivas trouxe, como corolário, a extensão automática àquelas, das prerrogativas já outorgadas aos companheiros dentro de uma união estável tradicional. 3. Apesar da organização judiciária de cada Estado ser afeta ao Judiciário local, a outorga de competências privativas a determinadas Varas, impõe a submissão dessas varas às respectivas vinculações legais construídas em nível federal, sob pena de ofensa à lógica do razoável e, *in casu*, também agressão ao princípio da igualdade. 4. Se a prerrogativa de vara privativa é outorgada ao extrato heterossexual da população brasileira, para a solução de determinadas lides, também o será à fração homossexual, assexual ou transexual, e todos os demais grupos representativos de minorias de qualquer natureza que tenham similar demanda. 5. Havendo vara privativa para julgamento de processos de família, esta é competente para apreciar e julgar pedido de reconhecimento e dissolução de união estável homoafetiva, independentemente das limitações inseridas no Código de Organização e Divisão Judiciária local. 6. Recurso especial provido.

(STJ, 4.^a Turma, REsp 964489/RS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, *DJe* 20.03.2013). 1. O Juízo da Vara de Família é competente para dirimir as questões relativas à união estável homoafetiva, diante da aplicação isonômica da legislação que regula a união estável. 2. Aplica-se às relações estáveis homoafetivas, por analogia, a legislação atinente às relações estáveis heteroafetivas, tendo em vista a caracterização dessa relação como modelo de entidade familiar (STF, ADI 4.277/DF, rel. Ministro Ayres Britto, *DJe* 05.05.2011). 3. Recurso especial desprovido. (STJ, 4.^a Turma, REsp 964489/RS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, *DJe* 20.03.2013).

(STJ, 3.^a T., REsp 1.305.767/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, *DJe* 16.11.2014). 1. Cinge-se a controvérsia a saber se o credor detém legitimidade ativa para requerer a declaração de união estável existente entre a devedora e terceiro. 2. A legitimidade requer a existência de uma relação de pertinência subjetiva entre o sujeito e a causa. O elemento subjetivo da ação declaratória é o desejo de constituir família, que deve ser nutrido por ambos os conviventes. A sua falta impede o reconhecimento da união estável. 3. O interesse econômico ou financeiro de credor não o legitima a propor ação declaratória de união estável, haja vista que esta tem caráter íntimo e pessoal. Precedente. 4. Recurso especial não provido. STJ, 3.^a T., REsp 1305767/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, *DJe* 16.11.2014.

Pablo Stolze Gagliano. Direitos da(o) amante – na teoria e na prática (dos Tribunais). *Revista IOB de Direito de Família*, v. 9, n° 49, p. 51-61.

José Carlos Teixeira Giorgis. *Direito de Família Contemporâneo*, item n. 6, p. 42-43; Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka. Famílias paralelas. *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo*, v. 108, p. 199-219, jan./dez. 2013.

Bruna Barbieri Waquim. Universos paralelos e danos de amor. *Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões*, v.13, n.23, p. 65-83, ago./set. 2011.

632

Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk. *Famílias simultâneas*: da unidade codificada à pluralidade constitucional.

633

Bruna Barbieri Waquim. Relações simultâneas conjugais: o lugar da Outra no Direito de Família.

634

Paulo Roberto Iotti Vecchiatti. Famílias paralelas e poliafetivas devem ser reconhecidas pelo Judiciário. Consultor Jurídico. 05 de agosto de 2014. Disponível em: [www.conjur.com.br/2014-ago-05/paulo-iotti-familias-paralelas-poliafetivas-reconhecidas#_ftn1_6588]. Acesso em: 13 ago. 2016.

635

Rolf Madaleno. A União (ins)Estável (relações paralelas). Disponível em: [www.rolfmadaleno.com.br/novosite/conteudo.php?id="323"]. Acesso em: 13 ago. 2016. Lenio Luiz Streck. O ativismo, o justo, o legal e a Lesão por Esforço Epistêmico Repetitivo. Consultor Jurídico. 31 de julho de 2014. Disponível em: [www.conjur.com.br/2014-jul-31/senso-incomum-ativismo-justo-legal-lesao-esforco-epistemico-repetitivo]. Acesso em: 13 ago. 2016. Zeno Veloso. *Código Civil Comentado*, v. XVII. Coord. Álvaro Villaça Azevedo.

636

Disponível em:
[www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/Not%C3%ADcias/Not%C3%ADcias/Uni%C3%A3o-est%C3%A1vel-%C3%A9-tema-da-nova-edi%C3%A7%C3%A3o-de-Jurisprud%C3%Aancia-em-Teses-do-STJ]. Acesso em: 13 ago. 2016.

637

Fredie Didier Jr. *Regras processuais no Código Civil*, 4. ed., item n. XII, p. 215.

638

A Lei do Divórcio, Lei n. 6.515/1977, previa hipóteses no § 3.º do art. 5.º, no art. 45, além de outros que a jurisprudência admitia.

639

Clóvis Bevilacqua. *Código Civil dos Estados Unidos do Brasil Comentado*, Edição Histórica, 5. tir. v. 1, art. 230, item n. 3, p. 582.

640

(STJ – REsp: 1483841 RS 2014/0058351-0, rel. Ministro Moura Ribeiro, Data de Julgamento: 17.03.2015, T3 –

Terceira Turma, Data de Publicação: *DJe* 27.03.2015). 1. Em razão da modificação do art. 226, § 6º, da CF, com a nova redação dada pela EC 66/10, descabe falar em requisitos para a concessão de divórcio. 2. Inexistindo requisitos a serem comprovados, cabe, caso o magistrado entenda ser a hipótese de concessão de plano do divórcio, a sua homologação. 3. A audiência de conciliação ou ratificação passou a ter apenas cunho eminentemente formal, sem nada produzir, e não havendo nenhuma questão relevante de direito a se decidir, nada justifica na sua ausência, a anulação do processo. 4. Ainda que a CF/1988, na redação original do art. 226, tenha mantido em seu texto as figuras anteriores do divórcio e da separação e o CPC tenha regulamentado tal estrutura, com a nova redação do art. 226 da CF/1988, modificada pela EC 66/2010, deverá também haver nova interpretação dos arts. 1.122 do CPC e 40 da Lei do Divórcio, que não mais poderá ficar à margem da substancial alteração. Há que se observar e lembrar que a nova ordem constitucional prevista no art. 226 da Carta Maior alterou os requisitos necessários à concessão do Divórcio Consensual Direto. (...). 6. Recurso especial a que se nega provimento.

641

Art. 40 (...) § 2º – No divórcio consensual, o procedimento adotado será o previsto nos arts. 1.120 a 1.124 do Código de Processo Civil, observadas, ainda, as seguintes normas: I – a petição conterá a indicação dos meios probatórios da separação de fato, e será instruída com a prova documental já existente; II – a petição fixará o valor da pensão do cônjuge que dela necessitar para sua manutenção, e indicará as garantias para o cumprimento da obrigação assumida; III – se houver prova testemunhal, ela será produzida na audiência de ratificação do pedido de divórcio a qual será obrigatoriamente realizada. IV – a partilha dos bens deverá ser homologada pela sentença do divórcio.

642

Art. 100. É competente o foro: I – da residência da mulher, para a ação de separação dos cônjuges e a conversão desta em divórcio, e para a anulação de casamento.

643

Art. 340. Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico” bem como, no capítulo VI que trata da contestação, o art. 337, § 5.º, que dispõe “Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: § 5.º Excetuada a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste art.

644

Art. 1.º São atividades privativas de advocacia: I – a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais”. Portanto, a petição inicial de divórcio consensual deve ser assinada por advogado devidamente constituído como procurador das partes.

645

STJ, *REsp* 1.558.015 , 4.ª Turma, j. 12.09.2017, julgado por Luis Felipe Salomão. Neste caso tratava-se de dissolução de união estável.

646

Jefferson Carús Guedes; Fredie Didier Junior; Cristiano Chaves de Farias Guilherme Calmon Nogueira da Gama;

647

Mairan Gonçalves Maia Junior. *A família e a questão patrimonial*, 3. ed. p. 145.

648

STJ, REsp 1.719.739, 3ª T., julgado por Nancy Andrigli, j. 05.06.2018, *DJe* 07.06.2018.

649

(STJ 3.ª T., REsp 918.173/RS, rel. Min. Massami Uyeda, j. em 10.06.2008, *DJe* 23.06.2008). 1. No regime da comunhão universal de bens, as verbas percebidas a título de benefício previdenciário resultantes de um direito que nasceu e foi pleiteado durante a constância do casamento devem entrar na partilha, ainda que recebidas após a ruptura da vida conjugal. 2. Recurso especial não conhecido” (STJ 3.ª T., REsp 918.173/RS, rel. Min. Massami Uyeda, j. em 10.06.2008, *DJe* 23.06.2008)

650

(TJRS, AC 70066624701 RS, rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, *DJe* 22.02.2016). O demandado sustenta que seria admissível desconsiderar o caráter pessoal do plano de previdência se comprovado o seu intento remuneratório de quantia pecuniária ou se houve a utilização do plano para evitar partilhar bens. No caso, restaram demonstradas movimentações de valores, com saques para aquisição de bens e serviços, de modo que, na circunstância específica dos autos, indubitosa a configuração de conta ou fundo de investimento dada pelo demandado, devendo ser mantida a sentença que determinou a partilha do saldo existente na data da separação fática. (TJRS, AC 70066624701 RS, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, *DJe* 22.02.2016).

651

(REsp 1.266.527/RS, Quarta Turma, relator Ministro Raul Araújo, *DJe* de 29.4.2014).

652

(Agravado de Instrumento 70065470734, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 29.06.2015). 1. Adquirido o imóvel mediante financiamento, são partilháveis, apenas, os valores pagos no curso da convivência. 2. Como a agravante continua residindo no imóvel, pode ela arcar com as prestações do bem; e, para fins de partilha, esses valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, e, em momento subsequente, se o pagamento das demais prestações for feito, até a ultimação do contrato, por certo que a ela caberá, com exclusividade, esses valores, após a separação fática das partes. NEGADO SEGUIMENTO. (Agravado de Instrumento 70065470734, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, rel. Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 29.06.2015).

653

STJ, REsp 1.537.287, 3ª T., julgado por Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.10.2016, *DJe* 28.10.2016.

654

(TJSP, APL 40045446620138260079 SP, rel. Alexandre Lazzarini, *DJe* 23.02.2016). 1- A sentença julgou parcialmente procedente ação ajuizada pelo apelado, para arbitrar aluguéis a serem pagos pela ré, que habita o imóvel comum, em favor do autor, na proporção de metade do valor locativo, a ser apurado em liquidação de sentença. 2- O aluguel pelo uso exclusivo do imóvel pela mulher é devido a partir da citação e não da separação de fato. É a partir da citação que há a exigência do pagamento, sendo que no período anterior, sem reclamação, importa a anuência com a ocupação gratuita. 3- Apelação não provida. (TJSP, APL 40045446620138260079 SP, Rel. Alexandre Lazzarini, *DJe* 23.02.2016).

655

Sergio Gilberto Porto. *Doutrina e prática dos alimentos*, 3. ed., item n. 6, p. 28-40.

656

Ver Marco Aurélio Gastaldi Buzzi. Alimentos transitórios: uma obrigação por tempo certo.

657

Cristiano Chaves de Farias. A tutela jurídica da confiança aplicada ao Direito de Família. In Família e Dignidade humana. *Anais do V Congresso Brasileiro de Direito de Família*. São Paulo: IOB Thomson, 2006.

658

Ver Rodrigo da Cunha Pereira. *Divórcio*: Teoria e Prática. 2. ed.

659

Washington Epaminondas Medeiros Barra. Alimentos entre cônjuges e ex-cônjuges. A intervenção do Ministério Público, *Revista dos Tribunais online*. Vol. 5. p. 1109-1120. São Paulo: Revista dos Tribunais, ago./2011. Item n. 4.

660

Ver Rolf Madaleno. Curso de direito de família.

661

Cf. Lei 11.804 de 05 de novembro de 2008, que “Disciplina o direito a alimentos gravídicos e a forma como ele será exercido e dá outras providências”.

662

“Art. 1.708. Com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos. Parágrafo único. Com relação ao credor cessa, também, o direito a alimentos, se tiver procedimento indigno em relação ao devedor”. Os alimentos devidos entre os Cônjuges são denominados de alimentos transitórios.

663

O princípio do melhor interesse da criança, também nominado superior ou maior interesse, advém do compromisso do Brasil ao aprovar internamente a Convenção sobre os Direitos da Criança, por meio do Decreto

legislativo 28/1990, defendendo Rossato, Lepore e Sanches sua natureza de verdadeiro postulado normativo, por orientar a aplicação de todos os princípios de regras referentes ao direito da criança e do adolescente.

664

Ver especialmente: Bruna Barbieri Waquim. *Alienação Familiar Induzida* : aprofundando o estudo da Alienação Parental.

665

Carlos Dias Motta. *Direito matrimonial e seus princípios jurídicos* , 2. ed., item n. 10.3.2, p. 333-345.

666

Art. 1634. Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores: I – dirigir-lhes a criação e a educação, sendo verdadeiro dispositivo reprodutor de sentido do art. 229 da Constituição Federal de 1988 que dispõe o que segue: “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.

667

(REsp 1218510/SP, rel. a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27.09.2011, *DJe* 03.10.2011).

668

(TJDF, AGI 20140020149812 DF, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, *DJe* 08.10.2014). 1. O acordo celebrado pelos pais em sede de execução de alimentos fixando valor irrisório a título de verba alimentícia, tornam desguarnecidos os interesses do menor. 2. Recurso desprovido. (TJDF, AGI 20140020149812 DF, rel. Des. Mario-Zam Belmiro, *DJe* 08.10.2014).

669

STJ, AgInt no REsp 1.704.218 , Terceira Turma, j. 12.06.2018, julgado por Moura Ribeiro.

670

(STJ. REsp. 1.206.656 – GO, rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 16.10.2012).

671

Folha de São Paulo. Adotar sobrenome da mulher já é escolha de 25% dos homens ao casar. 06 de outubro de 2013. Disponível em: [www.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/10/1352493-adotar-sobrenome-da-mulher-ja-e-escolha-de-25-dos-homens-ao-casar.shtml]. Acesso em: 13 ago. 2016.

672

(STJ, Resp 241.200/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 04.04.2006). O Tribunal a *quo* , em embargos de declaração, decidiu que, no divórcio direto, a continuação do uso do nome de casada pela mulher constitui uma faculdade. Ademais, como assinalado na ementa do acórdão impugnado, a ora embargada foi casada durante 45

anos e, já com 70 anos de idade, o nome se incorporou à sua personalidade. Assim, o acórdão recorrido fundou-se nos elementos probatórios constantes dos autos, não cabendo a este Superior Tribunal revolvê-los a teor da Súm. 7-TJ. A Turma não conheceu do recurso” (STJ, REsp 241.200/RJ, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 04.04.2006).

673

Fernanda Tartuce. *Processo civil aplicado ao Direito de Família*, item II, 3.2, p. 231.

674

(STJ, 3.^a Turma, AREsp 804261, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, *Dje* 04.12.2015). “Em razão da completa incompatibilidade procedimental, não se admite a conversão da ação de divórcio consensual em procedimento de jurisdição contenciosa. Deve ser admitido o pedido de desistência formulado pela requerente na ação de divórcio consensual dado o conflito de interesses instaurado e a autonomia de vontade das partes que o processo não inibe” (STJ, 4.^a T., REsp 990795, rel. Min. Luis Felipe Salomão, *Dje* 15.09.2010).

675

Fernanda Tartuce. *Processo civil aplicado ao Direito de Família*, item II, 3.2.8, p. 248.

676

(STJ – REsp: 1483841 RS 2014/0058351-0, rel. Ministro Moura Ribeiro, Data de julgamento: 17.03.2015, T3 – Terceira Turma, Data de Publicação: *Dje* 27.03.2015) 1. Em razão da modificação do art. 226, § 6.º, da CF, com a nova redação dada pela EC 66/2010, descabe falar em requisitos para a concessão de divórcio. 2. Inexistindo requisitos a serem comprovados, cabe, caso o magistrado entenda ser a hipótese de concessão de plano do divórcio, a sua homologação. 3. A audiência de conciliação ou ratificação passou a ter apenas cunho eminentemente formal, sem nada produzir, e não havendo nenhuma questão relevante de direito a se decidir, nada justifica na sua ausência, a anulação do processo. (...)

677

Lei 6.515/1977: Art. 31 – Não se decretará o divórcio se ainda não houver sentença definitiva de separação judicial, ou se esta não tiver decidido sobre a partilha dos bens.

678

José Sebastião Fagundes Cunha (Coord.). *Código de Processo Civil Comentado*, art. 734, p. 1017.

679

(TJ-RS – AI: 70058018185 RS, rel. Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 20.03.2014, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: *Diário da Justiça* do dia 24.03.2014). Em que pese a previsão do inc. I do art. 100 do CPC, que estabelece o foro privilegiado da residência da mulher, trata-se, no caso, de competência territorial, que é relativa, devendo ser arguida por meio de exceção, na forma dos arts. 112 e 307 do CPC. Neste contexto, em que não se está frente a caso de incompetência absoluta, que poderia ser declinada inclusive de ofício, esta previsão procedimental não pode ser relativizada, devendo ser mantida a decisão agravada, que indeferiu o pedido da recorrente/demandada. (...). (Agravo de Instrumento 70058018185, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, rel. Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 20.03.2014) (TJ-RS – AI: 70058018185 RS, rel. Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 20.03.2014, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: *Diário da Justiça* do dia

680

Art. 340. Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico” bem como, no capítulo VI que trata da contestação, o art. 337, § 5.º, que dispõe “Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: § 5.º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo.

681

STJ, REsp 1.558.015, 4.ª Turma, j. 12.09.2017, julgado por Luis Felipe Salomão. Neste caso tratava-se de dissolução de união estável.

682

STJ, REsp 1.537.287, Terceira Turma, julgado por Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.10.2016, DJe 28.10.2016.

683

Acácio Cambi. Conversão de separação em divórcio, pendente obrigação alimentar. Possibilidade à luz da doutrina moderna. *Revista de Direito Privado*, v. 3. p. 945-948. On-line, ago./2011.

684

“Art. 1.708. Com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos. Parágrafo único. Com relação ao credor cessa, também, o direito a alimentos, se tiver procedimento indigno em relação ao devedor”. Os alimentos devidos entre os Cônjuges são denominados de alimentos transitórios.

685

Art. 1634. Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores: I – dirigir-lhes a criação e a educação, sendo verdadeiro dispositivo reprodutor de sentido do art. 229 da Constituição Federal de 1988 que dispõe o que segue: “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.

686

Carlos Dias Motta. *Direito matrimonial e seus princípios jurídicos*, 2. ed., item n. 10.3.2, p. 333-345.

687

Fernanda Tartuce. *Processo civil aplicado ao Direito de Família*, item II, 3.2, p. 231.

688

Art. 7.º – A separação judicial importará na separação de corpos e na partilha de bens. (...) § 2.º – A partilha de bens poderá ser feita mediante proposta dos cônjuges e homologada pelo juiz

689

Parte da doutrina entende que apenas parte das regras contidas nessa norma permanece vigente após a entrada em vigor do CC/2002. Especialmente as normas processuais e o direito real de habitação teriam permanecido vigentes após 2002.

690

Maria Berenice Dias. *Manual de direito das famílias* . 11. ed., p. 242.

691

STJ, REsp 1383624/MG, 3.^a Turma, rel. Min. Moura Ribeiro, *DJe* 12.06.2015.

692

(STJ, REsp 964489/RS, 4.^a Turma, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, *DJe* 20.03.2013). 1. O Juízo da Vara de Família é competente para dirimir as questões relativas à união estável homoafetiva, diante da aplicação isonômica da legislação que regula a união estável. 2. Aplica-se às relações estáveis homoafetivas, por analogia, a legislação atinente às relações estáveis heteroafetivas, tendo em vista a caracterização dessa relação como modelo de entidade familiar (STF, ADI n. 4.277/DF, rel. Min. Ayres Britto, *DJe* 05.05.2011). 3. Recurso especial desprovido. (STJ, REsp 964489/RS, 4.^a Turma, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, *DJe* 20.03.2013).

693

(STJ, REsp 1305767/MG, 3.^a Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, *DJe* 16.11.2014). 1. Cinge-se a controvérsia a saber se o credor detém legitimidade ativa para requerer a declaração de união estável existente entre a devedora e terceiro. 2. A legitimidade requer a existência de uma relação de pertinência subjetiva entre o sujeito e a causa. O elemento subjetivo da ação declaratória é o desejo de constituir família, que deve ser nutrido por ambos os conviventes. A sua falta impede o reconhecimento da união estável. 3. O interesse econômico ou financeiro de credor não o legitima a propor ação declaratória de união estável, haja vista que esta tem caráter íntimo e pessoal. Precedente. 4. Recurso especial não provido.

694

José Sebastião Fagundes Cunha (coord.). *Código de Processo Civil Comentado* . São Paulo: Ed. RT, 2016. p. 1017.

695

Idem, *ibidem*.

696

TJSP, Ap 1000904-77.2017.8.26.0011, 10.^a Câmara de Direito Privado, j. 15.08.2017, julgado por Élcio Trujillo.

697

Fernanda Tartuce. *Processo civil aplicado ao Direito de Família* , item II, 4.2, p. 257.

698

STJ, REsp 1.558.015, 4.ª Turma, j. 12.09.2017, julgado por Luis Felipe Salomão.

699

Fernanda Tartuce. *Processo civil aplicado ao Direito de Família*, item II, 4.5, p. 267.

700

Mairan Gonçalves Maia Junior. *A família e a questão patrimonial*. 3. ed., p. 145.

701

STJ, REsp 1.537.287, Terceira Turma, julgado por Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.10.2016, DJe 28.10.2016.

702

Art. 1.634. Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores: I – dirigir-lhes a criação e a educação, sendo verdadeiro dispositivo reprodutor de sentido do art. 229 da Constituição Federal de 1988 que dispõe o que segue: “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.

703

Fernanda Tartuce. *Processo civil aplicado ao Direito de Família*, item n. II, 3.2, p. 231.

704

Piero Zaccardi. Doppio grado o doppia fase del giudizio di merito? Una scelta politica, *Studi in onore di Enrico Tullio Liebman*, vol. III.

705

Ada Pellegrini Grinover. Deformalização do processo e deformalização das controvérsias, *Novas tendências do direito processual*, 2. ed., item n. 1.5, p. 179.

706

“Art. 34. (...) Parágrafo único. As partes devem, ainda, declarar ao tabelião, na mesma ocasião, que o cônjuge virago não se encontra em estado gravídico, ou ao menos, que não tenha conhecimento sobre esta condição.”

707

Christiano Cassettari. *Separação, divórcio e inventário por escritura pública*: teoria e prática, 5. ed. p. 66-67.

708

“Art. 10. Far-se-á averbação em registro público: I - das sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento, o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal”.

709

Esse “pedido inicial” é *sui generis*, pois não há previsão legal, porquanto como uma forma de compartilhar a responsabilidade do advogado em relação ao ato.

710

“O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam...) II - interesse de incapaz,”.

711

“CPC/1973. Art. 84. Quando a lei considerar obrigatória a intervenção do Ministério Público, a parte promover-lhe-á a intimação sob pena de nulidade do processo”.

712

Christiano Cassettari. *Separação, divórcio e inventário por escritura pública* : teoria e prática, 5. ed., p. 76-77.

713

CC/2002. Art. 657. “A outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado. Não se admite mandato verbal quando o ato deva ser celebrado por escrito”. Resolução CNJ 35: “Art. 36. O comparecimento pessoal das partes é dispensável à lavratura de escritura pública de separação e divórcio consensuais, sendo admissível ao(s) separando(s) ou ao(s) divorciando(s) se fazer representar por mandatário constituído, desde que por instrumento público com poderes especiais, descrição das cláusulas essenciais e prazo de validade de trinta dias”.

714

Christiano Cassettari. *Separação, divórcio e inventário por escritura pública* : teoria e prática, 5. ed., p. 83.

715

“Para a obtenção da gratuidade de que trata a Lei n. 11.441/07, basta a simples declaração dos interessados de que não possuem condições de arcar com os emolumentos, ainda que as partes estejam assistidas por advogado constituído”.

716

O art. 9.º estabelece: “É vedada ao tabelião a indicação de advogado às partes, que deverão comparecer para o ato notarial acompanhadas de profissional de sua confiança. Se as partes não dispuserem de condições econômicas para contratar advogado, o tabelião deverá recomendar-lhes a Defensoria Pública, onde houver, ou, na sua falta, a Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil”.

717

Christiano Cassettari. *Separação, divórcio e inventário por escritura pública* : teoria e prática, 5. ed., p. 83-84.

718

Uma hipótese cogitada pelas entidades notariais é a desnecessidade de processo judicial, embora existam filhos incapazes, quando todas as questões atinentes a este ou estes incapazes estejam previamente definidas em ação judicial anterior, seja a separação de corpos em relação à separação, ou a separação em relação ao divórcio. Justifica-se tal entendimento pela ausência de riscos, visto que no procedimento antecedente já houve a participação do Ministério Público, dentre outras exigências.

719

Resolução CNJ 35, alterada pela Resolução CNJ 220.

720

Christiano Cassettari. *Separação, divórcio e inventário por escritura pública* : teoria e prática, 5. ed., p. 76-77.

721

A Resolução CNJ 35, alterada pela Resolução CNJ 120, prevê que: “Art. 52. Os cônjuges separados judicialmente podem, mediante escritura pública, converter a separação judicial ou extrajudicial em divórcio, mantendo as mesmas condições ou alterando-as. Nesse caso, é dispensável a apresentação de certidão atualizada do processo judicial, bastando a certidão da averbação da separação no assento do casamento”.

722

Christiano Cassettari. *Separação, divórcio e inventário por escritura pública* : teoria e prática, 5. ed., p. 76-77.

723

Ada Pellegrini Grinover. Deformalização do processo e deformalização das controvérsias, *Novas tendências do direito processual*, 2. ed., item n. 1.5, 179.

724

Assim dispõe o supramencionado dispositivo: “as escrituras públicas de inventário e partilha, separação e divórcio consensuais não dependem de homologação judicial e são títulos hábeis para o registro civil e o registro imobiliário, para a transferência de bens e direitos, bem como para promoção de todos os atos necessários à materialização das transferências de bens e levantamento de valores (Detran, Junta Comercial, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, instituições financeiras, companhias telefônicas etc.)”.

725

Christiano Cassettari. *Separação, divórcio e inventário por escritura pública* : teoria e prática, 5. ed., p. 105.

726

STJ, REsp 1.537.287 , 3ª Turma, julgado por Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.10.2016, DJe 28.10.2016.

727

STJ, REsp 1.620.710 , 3.^a Turma, j. 14.03.2017, julgado por Ricardo Villas Bôas Cueva.

728

Christiano Cassettari. *Separação, divórcio e inventário por escritura pública* : teoria e prática, 5. ed., p. 107.

729

A doutrina já se posicionava assim, desde a vigência da Lei n. 11.441/2007: MUCILLO, Daniela. A modificação de cláusula na separação extrajudicial e na separação judicial consensual, *Separação, divórcio, partilhas e inventários extrajudiciais* , 2. ed . cap. 18, p. 301-312.

730

STJ, REsp 1.620.710 , 3.^a Turma, j. 14.03.2017, julgado por Ricardo Villas Bôas Cueva.

731

STJ, REsp 1.621.610 -SP, 4.^a Turma, j. 07.02.2017, julgado por Luis Felipe Salomão.

732

Art. 1.641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento: I - das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento; II – da pessoa maior de 70 (setenta) anos; III - de todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial.

733

Jefferson Carús Guedes; Fredie Didier Junior; Cristiano Chaves de Farias; Guilherme Calmon Nogueira da Gama; Nagib Salib Filho. *Comentários ao Código Civil Brasileiro* – Do Direito de Família – Direito Patrimonial, vol. XV, arts. 1.658 a 1.693, p. 103-299; José Tadeu Neves Xavier. Questões relevantes sobre a mutabilidade do regime de casamento. *Revista de Direito Privado*. vol. 52., p. 193-228. (on-line), out-dez 2012, item 1.

734

José Lamartine Corrêa de Oliveira e Francisco José Ferreira Muniz, *Direito de família: direito matrimonial* , item n. 17.8, p. 362.

735

A Lei do Divórcio, Lei 6.515/1977, previa hipóteses no § 3.º do art. 5.º, no art. 45, além de outros que a jurisprudência admitia.

736

Clóvis Beviláqua. *Código Civil dos Estados Unidos do Brasil Comentado* , Edição Histórica, 5. tir. vol. 1, art. 230, item n. 3, p. 582.

(STJ, REsp 1119462/MG, 4.^a Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, *DJe* 12.03.2013). 1. O casamento há de ser visto como uma manifestação vicejante da liberdade dos consortes na escolha do modo pelo qual será conduzida a vida em comum, liberdade essa que se harmoniza com o fato de que a intimidade e a vida privada são invioláveis e exercidas, na generalidade das vezes, em um recôndito espaço privado também erguido pelo ordenamento jurídico à condição de “asilo inviolável”. 2. Assim, a melhor interpretação que se deve conferir ao art. 1.639, § 2.º, do CC/2002 é a que não exige dos cônjuges justificativas exageradas ou provas concretas do prejuízo na manutenção do regime de bens originário, sob pena de se esquadriñar indevidamente a própria intimidade e a vida privada dos consortes. 3. No caso em exame, foi pleiteada a alteração do regime de bens do casamento dos ora recorrentes, manifestando eles como justificativa a constituição de sociedade de responsabilidade limitada entre o cônjuge varão e terceiro, providência que é acauteladora de eventual comprometimento do patrimônio da esposa com a empreitada do marido. A divergência conjugal quanto à condução da vida financeira da família é justificativa, em tese, plausível à alteração do regime de bens, divergência essa que, em não raras vezes, se manifesta ou se intensifica quando um dos cônjuges ambiciona enveredar-se por uma nova carreira empresarial, fundando, como no caso em apreço, sociedade com terceiros na qual algum aporte patrimonial haverá de ser feito, e do qual pode resultar impacto ao patrimônio comum do casal. 4. Portanto, necessária se faz a aferição da situação financeira atual dos cônjuges, com a investigação acerca de eventuais dívidas e interesses de terceiros potencialmente atingidos, de tudo se dando publicidade (Enunciado n. 113 da I Jornada de Direito Civil CJF/STJ). 5. Recurso especial parcialmente provido.

José Tadeu Neves Xavier. Questões relevantes sobre a mutabilidade do regime de casamento. *Revista de Direito Privado*. vol. 52. p. 193-228. São Paulo, Revista dos tribunais online, out.-dez. 2012. item 2.1.

Lenio Luiz Streck; Dierle Nunes; Leonardo Carneiro Cunha (org.). *Comentários ao Código de Processo Civil* : de acordo com a Lei n. 13.256/2016, art. 724, p. 970.

TJSP, Ap 1029960-14.2014.8.26.0577, 1.^a Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2017, julgado por Durval Augusto Rezende Filho.

Estatuto da Pessoa com Deficiência (*Lei 13.146/2015*), que permite à pessoa com deficiência, por não ter afetada a plena capacidade civil (*art. 6.º* do Estatuto), decidir, mediante a adoção de processo de tomada de decisão apoiada por duas pessoas que a acompanham (*art. 84, § 2.º, do EPD c/c art. 1.783-A do CC/2002*), ressaltando-se que nem os apoiadores, tampouco seus parentes, poderão ser beneficiados pelo ato.

TJSP, Ap 0001415-92.2012.8.26.0100, 5.^a Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2016, julgado por Erickson Gavazza Marques.

744

Patricia Miranda Pizzol. *A competência no processo civil*, item n. 4, p. 637-646.

746

Luiz Gustavo Lovato. O uso do regime de bens do casamento para fraudar terceiros credores: o cônjuge laranja”, *Ações de Direito de Família*, item n. 6, p. 135.

747

Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil*, art. p. 1578.

748

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015. p. 709.

749

Carlos Dias Motta. *Direito matrimonial e seus princípios jurídicos*, 2. ed., item n. 11.2.4, p. 395; o autor, baseado nas expectativas da doutrina, de forma premonitória, reclamava a inclusão do procedimento na nova lei processual, com editais etc.

750

STJ, *REsp* 1.533.179, Terceira Turma, Rel. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.09.2015, *DJe* 23.09.2015. Em sentido contrário: TJRS, ApCiv 70075983296, 8.^a Câmara Cível, j. 26.04.2018, julgado por José Antônio Daltoé Cezar, ressaltando, como assegura a lei material e as duas decisões conformes, o direito de terceiros.

751

STJ, *REsp* 1.300.036, Terceira Turma, julgado por Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.05.2014, *DJe* 20.05.2014.

752

Sílvio de Salvo Venosa. *Direito Civil. Direito das Sucessões*, 6. ed., vol. VII, item n. 10.1, p. 183.

753

Art. 1.967. As disposições que excederem a parte disponível reduzir-se-ão aos limites dela, de conformidade com o disposto nos parágrafos seguintes. § 1.º Em se verificando excederem as disposições testamentárias a porção disponível, serão proporcionalmente reduzidas as quotas do herdeiro ou herdeiros instituídos, até onde baste, e, não bastando, também os legados, na proporção do seu valor. § 2.º Se o testador, prevenindo o caso, dispuser que se inteirem, de preferência, certos herdeiros e legatários, a redução far-se-á nos outros quinhões ou legados, observando-se a seu respeito a ordem estabelecida no parágrafo antecedente.

754

755

Art. 1.881. Toda pessoa capaz de testar poderá, mediante escrito particular seu, datado e assinado, fazer disposições especiais sobre o seu enterro, sobre esmolas de pouca monta a certas e determinadas pessoas, ou, indeterminadamente, aos pobres de certo lugar, assim como legar móveis, roupas ou joias, de pouco valor, de seu uso pessoal.

756

Art. 1.884. Os atos previstos nos artigos antecedentes revogam-se por atos iguais, e consideram-se revogados, se, havendo testamento posterior, de qualquer natureza, este os não confirmar ou modificar.

757

Maria Berenice Dias. *Manual das sucessões* . 4. ed., item 36, p. 385.

758

Sílvia de Salvo Venosa. *Direito Civil. Direito das Sucessões* , 6. ed., vol. VII, item n. 10.1.2, p. 185.

759

Maria Berenice Dias. *Manual das sucessões* . 4. ed., item 32.1, p. 342.

760

Art. 1.861. A incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento, nem o testamento do incapaz se valida com a superveniência da capacidade.

761

Maria Berenice Dias. *Manual das sucessões* . 4. ed., item 32.1.2, p. 344.

762

Idem, *ibidem*.

763

Art. 1.873. Pode fazer testamento cerrado o surdo-mudo, contanto que o escreva todo, e o assine de sua mão, e que, ao entregá-lo ao oficial público, ante as duas testemunhas, escreva, na face externa do papel ou do envoltório, que aquele é o seu testamento, cuja aprovação lhe pede.

764

Maria Berenice Dias. *Manual das sucessões* . 4. ed., item 32.1.3, p. 345.

765

Idem, ibidem.

766

Maria Berenice Dias. *Manual das sucessões* . 4. ed., item 36, p. 384.

767

Sílvia de Salvo Venosa. *Direito Civil. Direito das Sucessões* , 6. ed. vol. VII, item n. 11.8, p. 231.

768

Art. 1.857. [...] § 1.º A legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento.

769

Maria Berenice Dias. *Manual das sucessões* . 4. ed., item 36, p. 384.

770

Sílvia de Salvo Venosa. *Direito Civil. Direito das Sucessões* , 6. ed., vol. VII, item n. 11.6, p. 225.

771

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil* , vol. XII, art. 1.134, item n. 130, p. 267.

772

João Paulo Lucena. *Comentários ao código de processo civil* . vol. 15, art. 1.125, item n. 3, p. 160.

773

Idem, ibidem.

774

TJMG, ApCiv 1.0701.12.008139-6/002, 8.ª Câmara Cível, j. 19.10.2017, julgado por Teresa Cristina da Cunha Peixoto.

775

Sílvia de Salvo Venosa. *Direito Civil. Direito das Sucessões* , 6. ed., vol. VII, item n. 11.4, p. 211.

776

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil* . 5. ed., vol. X, art. 1.125, item n. 69, p. 168.

777

Maria Berenice Dias. *Manual das sucessões* . 4. ed., item 35.1.2, p. 372.

778

Idem, *ibidem*.

779

Maria Berenice Dias. *Manual das sucessões* . 4. ed., item 35.1.2, p. 372 e Edson Prata, *Comentários ao Código de Processo Civil* , vol. 7, art. 1.125, item n. 5, p. 152.

780

Edson Prata, *Comentários ao Código de Processo Civil* , vol. 7, art. 1.125, item n. 9, p. 153.

781

Idem, *ibidem*.

782

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil* , vol. XII, art. 1.125, item n. 90.1, p. 226.

783

Art. 1.979. O testamenteiro nomeado, ou qualquer parte interessada, pode requerer, assim como o juiz pode ordenar, de ofício, ao detentor do testamento, que o leve a registro.

784

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil* . 5. ed., vol. X, art. 1.129, item n. 75, p. 178.

785

Idem, *ibidem*.

786

Edson Prata, *Comentários ao Código de Processo Civil* , vol. 7, art. 1.125, item n. 12, p. 155.

787

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil* . 5. ed., vol. X, art. 1.125, item n. 72, p. 171.

788

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil* , t. XVI, art. 1.125, item 9, p. 161; Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil* , vol. XII, art. 1.125, item n. 88.2, p. 223; João

Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil* . vol. 15, item n. 3, p. 160.

789

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil* , vol. XII, art. 1.125, item n. 88.2, p. 223.

790

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil* , t. XVI, art. 1.125, item 8, p. 160.

791

Edson Prata, *Comentários ao Código de Processo Civil* , vol. 7, art. 1.125, item n. 11, p. 155.

792

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil* , t. XVI, art. 1.125, item 8, p. 160.

793

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil* . 5. ed., vol. X, art. 1.125, item n. 69, p. 168.

794

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil* , t. XVI, art. 1.126, item 5, p. 165.

795

Idem, *ibidem*.

796

Edson Prata, *Comentários ao Código de Processo Civil* , vol. 7, art. 1.125, item n. 9, p. 154.

797

Art. 1.972. O testamento cerrado que o testador abrir ou dilacerar, ou for aberto ou dilacerado com seu consentimento, haver-se-á como revogado.

798

Edson Prata, *Comentários ao Código de Processo Civil* , vol. 7, art. 1.125, item n. 9, p. 154.

799

Idem, *ibidem*.

800

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil* , vol. XII, art. 1.125, item n. 87.1, p. 220.

801

Idem, ibidem.

802

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil* . 5. ed., vol. X, art. 1.125, item n. 69, p. 169.

803

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil* , t. XVI, art. 1.126, item 5, p. 165.

804

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil* . 5. ed., vol. X, art. 1.125, item n. 69, p. 169.

805

Idem, ibidem.

806

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil* . 5. ed., vol. X, art. 1.125, item n. 69, p. 170.

807

TJMG, ApCiv 1.0701.12.008139-6/002, 8.^a Câmara Cível, j. 19.10.2017, julgado por Teresa Cristina da Cunha Peixoto.

808

Alcides de Mendonça Lima . *Comentários ao Código de Processo Civil* , vol. XII, art. 1.125, item n. 90, p. 225. “Embora, no parágrafo único do art. 1.125, conste, das publicações oficiais, a palavra “ato”, em evidente erro tipográfico, a mesma, portanto, deve ser lida como “auto”, que é termo técnico”.

809

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil* , vol. XII, art. 1.126, item n. 93, p. 229.

810

Idem, ibidem.

811

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil* , vol. XII, art. 1.126, item n. 94, p. 230.

812

Idem, ibidem.

813

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, art. 1.126, item 9, p. 162.

814

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. XII, art. 1.126, item n. 95, p. 230.

815

Idem, ibidem.

816

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, art. 1.126, item 9, p. 162.

817

Idem, ibidem.

818

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed., vol. X, art. 1.126 e 1.127, item n. 73, p. 176.

819

Idem, p. 175.

820

Maria Berenice Dias. *Manual das sucessões*. 4. ed., item 50.3, p. 511.

821

Idem, item 50.2.1, p. 510.

822

Neste ponto, ressalta-se a existência de duas correntes: uma que entende que a *ratio legis* é assegurar a remuneração daquele que em nada se relaciona com o testamento, não sendo beneficiado por ele economicamente. Dessa forma não caberia ao herdeiro, seja ele testamentário ou legítimo, nem ao legatário, o pagamento de prêmio. Já a outra corrente entende que o herdeiro legítimo, recebe parte da herança em razão da lei, sem nada receber pela incumbência (testamenteiro), pelo que, a esse, caberia a remuneração do prêmio. Maria Berenice Dias. *Manual das sucessões*. 4. ed., item 50.5, p. 512.

823

Maria Berenice Dias. *Manual das sucessões* . 4. ed., item 50.5, p. 512-513.

824

Antonio Carlos Marcato. *Procedimentos especiais* , 15. ed., cap. IV, item n. 218, p. 10; Maria Berenice Dias. *Manual das sucessões* . 4. ed., item 50.5, p. 514. Antonio Carlos Marcato. *Procedimentos especiais* , 15. ed., item n. 4, p. 10.

825

Maria Berenice Dias. *Manual das sucessões* . 4. ed., item 50.8, p. 515.

826

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil* . 5. ed. vol. X, art. 1.137, item n. 83, p. 191.

827

Art. 1.983. Não concedendo o testador prazo maior, cumprirá o testamenteiro o testamento e prestará contas em cento e oitenta dias, contados da aceitação da testamentaria. Parágrafo único. Pode esse prazo ser prorrogado se houver motivo suficiente.

828

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil* , vol. XII, art. 1.128, item n. 99, p. 239.

829

Idem, ibidem.

830

Idem, ibidem.

831

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil* , vol. XII, art. 1.128, item n. 99.2, p. 240.

832

Idem, ibidem.

833

Sílvio de Salvo Venosa. *Direito Civil. Direito das Sucessões* , 6. ed. vol. VII, itens n. 11.5 e 11.6, p. 218-225.

834

Art. 1.892. Não valerá o testamento marítimo, ainda que feito no curso de uma viagem, se, ao tempo em que se

fez, o navio estava em porto onde o testador pudesse desembarcar e testar na forma ordinária.

835

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. XII, art. 1.130, item n. 114, p. 252.

836

Idem, ibidem.

837

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed., vol. X, art. 1.130, item n. 77, p. 180.

838

Idem, ibidem.

840

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed., vol. X, art. 1.130, item n. 79, p. 183.

841

Idem, ibidem.

842

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. XII, art. 1.132, item n. 124, p. 258.

843

Idem, p. 263.

844

Idem, p. 266.

845

Pontes de Miranda afirma que a herança não mais jaz, desde que não mais se distingue a morte e a adição. Francisco Cavalcanti PONTES DE MIRANDA. *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XVI, Cap. V, item n. 1, p. 269.

846

Art. 1.819. Falecendo alguém sem deixar testamento nem herdeiro legítimo notoriamente conhecido, os bens da herança, depois de arrecadados, ficarão sob a guarda e administração de um curador, até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou à declaração de sua vacância.

847

João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil*. vol. 15, art. 1.142, item n. 3, p. 202. O autor ainda identifica como hipóteses a arrecadação de bens hereditários enquanto se aguarda o nascimento de único herdeiro, a instituição de herdeiro, sob condição suspensiva, enquanto não é implementada a condição e o direito sucessório de pessoa jurídica ainda não constituída.

848

Confundiu-as o atualizador dos *Comentários ao CPC* de José Olympio de Castro Filho ao dizer que “a lei civil declara a herança jacente (= *hereditas iacens*) as duas hipóteses em duas hipóteses, em havendo ou não havendo testamento (...) Em síntese, há jacência quando não houver a quem deferir a herança”. José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed., vol. X. Atualizada por José Rubens Costa, art. 1.142, item n. 88, p. 201. O STJ observou essa diferença: “Civil - Vocação hereditária - Legitimidade de Município para sucessão de bem vacante. I - A jurisprudência acolhe entendimento no sentido de que o Município tem legitimidade para a sucessão de bem jacente, cuja declaração de vacância deu-se na vigência da lei que alterou dispositivo que, retirando o Estado-Membro, substituiu-o na ordem hereditária” (STJ, REsp 71551/SP, 2.ª Seção, rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ 09.11.1998).

849

Art. 1.820. Praticadas as diligências de arrecadação e ultimado o inventário, serão expedidos editais na forma da lei processual, e, decorrido um ano de sua primeira publicação, sem que haja herdeiro habilitado, ou penda habilitação, será a herança declarada vacante.

850

Art. 1.821. É assegurado aos credores o direito de pedir o pagamento das dívidas reconhecidas, nos limites das forças da herança.

851

Art. 1.822. A declaração de vacância da herança não prejudicará os herdeiros que legalmente se habilitarem; mas, decorridos cinco anos da abertura da sucessão, os bens arrecadados passarão ao domínio do Município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União quando situados em território federal. Parágrafo único. Não se habilitando até a declaração de vacância, os colaterais ficarão excluídos da sucessão.

852

Art. 1.823. Quando todos os chamados a suceder renunciarem à herança, será esta desde logo declarada vacante.

853

TJRS, 8.ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento Nº 70034415331, rel. Des. Alzir Felipe Schmitz, j. 06.05.2010, DJ 13.05.2010) Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO. HERANÇA JACENTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1819 E 1822 DO CC/2002. Se os recorrentes não são herdeiros da inventariada, que era casada com o tio dos agravantes, pré-morto, inexistindo herdeiros conhecidos, correta a decisão que declarou a herança jacente.

854

TJSP, Ap 1000725-44.2016.8.26.0411, 4.^a Câmara de Direito Privado, j. 09.05.2017, julgado por Natan Zelinschi de Arruda.

855

STJ, REsp 1.532.544, 4.^a Turma, j. 08.11.2016, julgado por Marco Aurélio Gastaldi Buzzi.

856

João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil* . vol. 15, art. 1.142, item n. 3, p. 201.

857

Leonardo Greco. *Jurisdição voluntária moderna* , item n. 8.2, p. 140.

858

João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil* . vol. 15, art. 1.142, item n. 2, p. 199–200. O autor cita doutrina anterior que classifica a herança jacente como patrimônio especial e autônomo, estado de fato ou massa de bens arrecadados sob a fiscalização de autoridade judiciária, até que venham em sua busca os legítimos titulares de direitos sucessórios.

859

Celso Agrícola Barbi. *Comentários ao Código de Processo Civil* . 8. ed., vol. I, item n. 128, p. 87.

860

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil* , t. XVI, Cap. V, item n. 1, p. 269.

861

O direito de *saisine* ou *saisina* (ver Marinoni, p. 717, acórdão STJ).

862

Pontes de Miranda identificava uma cumulação objetiva sucessiva de ações e pedidos, primeiro com a ação constitutiva da curadoria e depois com a ação de devolução dos bens à Fazenda Pública: Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil* , t. XVI, Cap. V, item n. 4, p. 271.

863

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 2. ed., art. 1.142, item n. 88, p. 190.

864

Alcides de Mendonça. *Comentários ao Código de Processo Civil* , vol. XII, art. 1.142, item n. 158, p. 308. Passamos de “24 horas” (1939) para “sem perda de tempo” (1973 e, agora, para “imediatamente” (2015), sem que tais

mudanças possam impor claramente uma mudança.

865

CC/2002, Art. 615. (...) Parágrafo único. O requerimento será instruído com a certidão de óbito do autor da herança.

866

Art. 611. O processo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de 2 (dois) meses, a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 (doze) meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos, de ofício ou a requerimento de parte.

867

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. XII, art. 1.142, item n. 156, p. 306.

868

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. XII, art. 1.142, item n. 156, p. 306; Leonardo Greco. *Jurisdição voluntária moderna*, item n. 8.2, p. 140: “(...) instaura *ex officio* pelo próprio juiz, desde que tome conhecimento de alguém que, tendo bens, não deixou testamento nem herdeiros notoriamente conhecidos”.

869

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*, art. 738, item n. 3, p. 713.

870

Tendo notícia o Poder Judiciário da existência de bens deixados pelo morto, sem que se saiba da existência de herdeiros legítimos ou testamentários, incumbe ao juiz, como em outros casos previstos na lei, dar a notícia aos legitimados na defesa do patrimônio público, seja ao Estado, diretamente, ou ao Ministério Público e Advocacia Pública do ente estatal legitimado.

871

Art. 615. O requerimento de inventário e de partilha incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio, no prazo estabelecido no art. 611. Parágrafo único. O requerimento será instruído com a certidão de óbito do autor da herança. Art. 616. Têm, contudo, legitimidade concorrente: I - o cônjuge ou companheiro supérstite; II - o herdeiro; III - o legatário; IV - o testamenteiro; V - o cessionário do herdeiro ou do legatário; VI - o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança; VII - o Ministério Público, havendo herdeiros incapazes; VIII - a Fazenda Pública, quando tiver interesse.

872

Assim: “Para ser parte é necessário ter capacidade para estar em juízo”. Mas isso não é suficiente, pois, “para que alguém possa atuar, agir em processo” deve éter também a legitimidade processual. Thereza Alvim. *O direito processual de estar em juízo*, item n. III-2, p. 79 e item n. III-2.2, p. 100.

873

Thereza Alvim. *O direito processual de estar em juízo*, item n. III-1.7, p. 71. A autora denomina de parte complexa a composta pelo legitimado e pelo legitimante.

874

A competência prevista do art. 48 do CPC é territorial e como tal, competência relativa e prorrogável, segundo extensa base doutrinária brasileira. Por todos ver: Patrícia Miranda Pizzol. *A competência no processo civil*, item n. 3.3.2.3, p. 179, especialmente nota n. 196.

875

Tal legitimidade se justifica, sob pena de, mais adiante, verem-se frustrados os seus direitos de extrair daquela massa patrimonial o direito de percepção de seu crédito. Caso contrário, a solução seria a possibilidade de o credor representar ao Ministério Público, solicitando o início do procedimento.

876

Mantém-se dentre os procedimentos cautelares o *arrolamento*, sem a descrição dos legitimados do CPC/1973. Agora vem listado de modo genérico, em rol não taxativo: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assecuração do direito”.

877

Exemplo disso é a usucapião, que se pode formar nesse período: STJ, 3.^a Turma, AgRg no Ag 1.212.745/RJ, rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 19.10.2014; REsp 36.873/SP, rel. Min. Ari Pargendler, Terceira Turma, DJ de 28.05.2001.

878

TJSP, 2.^a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento 281986-1, 2, rel. Des. Donaldo Armelin. No caso a herança jacente era cessionária de direitos correspondente à promessa de compra e venda de apartamento, direitos obrigacionais, que a decisão manda serem ‘arrecadados’ à herança jacente.

879

Entende-se, contudo, que “o ‘arrolamento’ é diligência que antecede à arrecadação”, neste sentido ver: Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. XII, art. 1.142, item n. 156, p. 306.

880

(...) “As ações possessórias visam proteger a posse e o possuidor, não admitindo a discussão pura e simples acerca do domínio. 2. No âmbito da herança jacente, em que se desconhece os herdeiros e se quer proteger o patrimônio deixado pelo de cujus, a arrecadação dos bens promovida pelo Curador da herança visa afastar a posse injusta, clandestina, precária ou a mera detenção por parte de terceiros, de acordo com o art. 1.145 do CPC. Entretanto, essa arrecadação não pode prejudicar a posse legítima exercida por terceiro, (...)” (STJ, AREsp 610547-RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 1.09.2015).

881

Sobre Embargos de Terceiro e proteção à posse de terceiros ver: “Ementa: Embargos De Terceiro. Herança Jacente. Compromisso de Compra e venda. Posse. Locação. Prova. Não é cabível a arrecadação, para a herança jacente, de bem imóvel comprometido à venda, cujo saldo foi inteiramente quitado no âmbito do inventário dos promitentes vendedores. No caso, a arrecadação deve endereçar-se ao valor depositado judicialmente e não ao acervo imobiliário, de que os autores têm nítido direito possessório, desfrutando de garantia que não pode ser esbulhada pela arrecadação. E possível a oposição de embargos de terceiro, fundados na alegação de posse de quem é titular do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que não registrado. Apelação provida” (TJRS, 7.ª Câmara Cível, Apelação Cível 70004918058, rel. Des. José Carlos Teixeira Giorgis, j. 09.10.2002).

882

José Maria Rosa Tesheiner. *Jurisdição voluntária*, item n. 3.3, p. 74.

883

A lei processual não define nem dá preferência a certo profissional ou certa habilitação, como a Lei 11.101/2005, Lei de Recuperação Judicial de Empresas e Falências, que no art. 21 exige profissional idôneo, de preferência advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou pessoa jurídica especializada.

884

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. XII, art. 1.143, item n. 160, p. 310.

885

O gestor de negócios (art. 861 do CC) deve “dirigi-lo segundo o interesse e a vontade presumível de seu dono”, tendo neste um reflexo imediato, ao passo que o administrador da herança não tem a possibilidade de ouvir o ‘dono’ e sua forma de condução patrimonial.

886

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. XII, art. 1.144, item n. 166, p. 314.

887

Dever equivalente incumbe ao empresário na penhora de faturamento (art. 867, § 2.º).

888

As Normas Brasileiras de Contabilidade são estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, por meio de Resoluções que ordenam a forma de apresentação e as exigências de conteúdo das informações a trabalhos profissionais.

889

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. XII, art. 1.144, item n. 169, p. 318.

Idem, art. 1.143, item n. 160, p. 310.

Idem, item n. 164, p. 314.

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, tomo XVI, art. 1.145, item 1, p. 294, considerava indispensável, tendo por inexistente o ato realizado sem a sua presença. No mesmo sentido: José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. v. X, art. 1.145, item 95, p. 212; Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.145, item 170, p. 316; João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil*. v. 15, art. 1.145, item 1, p. 210; No CPC/2015 não se pode mais cogitar dessa exigência.

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. v. X, art. 1.145, item 95, p. 212-213.

Identificava-se o dispositivo anterior correspondente (art. 1.150 do CPC/1973) como confirmador do poder mais amplo que possui o juiz na jurisdição voluntária, próprio da índole desta espécie jurisdicional, que lhe permite iniciativas de direção e de inquisição mais fortes. Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.150, item 186, p. 330.

Pontes de Miranda observava a existência de uma inquisitividade do juiz (Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, tomo XVI, art. 1.147, item 4, p. 296). A "inquisitividade" comum aos procedimentos de jurisdição voluntária, que elastecem os poderes do juiz, neste § 4.º é preservada, ao contrário do § 3.º (oitiva de testemunhas e vizinhos) em que é mitigada na medida em que se pode substituir o juiz por um policial.

O sentido de empacotar e lacrar deve ser atualizado, não mais com os rigores apenas físicos, com fitas e assinaturas, como parecia suficiente ao sigilo quando se tratava de papéis, cartas, diários etc., mas agora, diante de novos meios de suporte eletrônico, os 'lacs' devem ser adaptados ao meio informático e eletrônico que vede o acesso remoto.

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, tomo XVI, art. 1.147, item 6, p. 297; "não se queimem, por exemplo, por exemplo, cartas de conteúdo científico, nem livros domésticos que serviria. (...) à cultura, à moral, à atividade artística (...)".

Art. 23. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra: I – conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil; II – em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional.

899

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I – aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares; II – aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; III – ao cônjuge sobrevivente; IV – aos colaterais.

900

Ver, por todos: Petrônio Calmon. *Comentários à Lei de Informatização do Processo Judicial*, especialmente Parte II, p. 43-154.

901

O atual CPC preserva a expressão ‘imprensa da comarca’ nos procedimentos especiais de Herança Jacente e Coisas Vagas, mantendo ainda o debate sobre os conceitos de *imprensa da comarca* e *imprensa de circulação local* que se deu também na vigência do CPC anterior;

902

STJ já decidiu no CComp 140.830. No presente caso concreto, o juiz julgou a habilitação do herdeiro em ação de herança jacente e converteu-a em ação de inventário, nos termos do art. 1.143 do CPC. O curador da herança jacente é obrigado a fazer a entrega da massa a quem o juiz determinar, podendo ser considerado depositário infiel se não o fizer, e prestar contas ao final de sua gestão (art. 1.144, inc. V, do CPC), conforme previsto nos arts. 914 e ss. do CPC. Assim, a decisão que julgou boa as contas finais prestadas pela curadoria põe termo ao procedimento autônomo de jurisdição voluntária (ação de herança jacente) e, portanto, é sentença, desafiando recurso de apelação (art. 1.110 do CPC).

903

Edson Prata. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 7, art. 1.152, item 4, p. 243.

904

Aplica-se a esta manifestação processual do herdeiro estrangeiro as mesmas exigências documentais e linguísticas que na habilitação de um nacional. Deve ele fazer a prova de sua relação com o falecido e com a herança, seus direitos sucessórios, sempre em língua portuguesa, traduzindo os documentos que por ventura sejam originais de outra língua e nacionalidade.

905

TJRS, ApCiv 70009038548, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, rel.: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, j. 15.12.2004). Ementa: HERANÇA JACENTE. APELAÇÃO. AJG. INTERESSE E LEGITIMIDADE DO COMPANHEIRO DA DE CUJUS. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO DE ÓBITO DE PESSOA ESTRANGEIRA QUE

DEIXA BENS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Tendo o companheiro da falecida postulado o benefício da gratuidade e sendo pobre, cabível o deferimento da assistência judiciária. 2. O fato de ter sido indeferida a habilitação do companheiro como herdeiro, pois a lei vigente no momento da abertura da sucessão não lhe conferia tal capacidade sucessória, não exclui o seu interesse econômico no feito, tendo legitimidade para recorrer e aponta falha processual. 3. É imprescindível a comunicação do óbito de estrangeiro, com bens e inexistência de herdeiros, à autoridade consular. Inteligência do art. 1.152, § 2.º, do CPC. Prefaciais rejeitadas. Sentença desconstituída. Recurso conhecido e provido.

906

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, tomo XVI, art. 1.154, item 1, p. 308.

907

TJPR. 12.ª Câmara Cível. rel. Des. Luiz Cezar Nicolau. Conflito Negativo de Competência 1.364.664-5-2. Suscitante: Juiz da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paranaguá Suscitado: Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Paranaguá.

908

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, tomo XVI, art. 1.154, item 3, p. 309.

909

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.154, item 203, p. 347.

910

CPC/2015, Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. § 1.º A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário. § 2.º Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento. § 3.º Separados os bens, tantos quantos forem necessários para o pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-los, observando-se as disposições deste Código relativas à expropriação. § 4.º Se o credor requerer que, em vez de dinheiro, lhe sejam adjudicados, para o seu pagamento, os bens já reservados, o juiz deferir-lhe-á o pedido, concordando todas as partes. § 5.º Os donatários serão chamados a pronunciar-se sobre a aprovação das dívidas, sempre que haja possibilidade de resultar delas a redução das liberalidades. Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.

911

TJRS, 8.ª Câmara Cível, AI 70047950639, rel. Des. Rui Portanova, j. 21.03.2013 *DJ* 26.03.2013. ‘Ementa: AI. Sucessões. Herança Jacente. Relação de prejudicialidade com Ação Declaratória. Suspensão do Inventário. Sendo inquestionável a relação de prejudicialidade entre a ação ordinária e o inventário, de rigor a suspensão de ofício do inventário até o julgamento final da ação declaratória e negatória de paternidade. Nestes termos, vai

desprovido agravo de instrumento, porquanto o reconhecimento da relação de filiação não vai conhecida agora no âmbito do inventário.'

912

Luciano de Camargo Penteado. *Direito das coisas* , 2. ed., cap. X, item 73, p. 361.

913

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil* , v. XII, art. 1.155, item 204, p. 349.

914

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil* , tomo XVI, art. 1.156, item 2, p. 314.

915

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil* , tomo XVI, art. 1.157 e 1.158, item 2, p. 315.

916

João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil* . v. 15, art. 1.157, item 1, p. 228.

917

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. v. X, art. 1.157, item 107, p. 229.

918

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil* , v. XII, art. 1.157, item 216.1, p. 363. Acrescente-se agora como legitimado também à habilitação o *companheiro* ou *companheira*, *heteroaferivo* ou *homoaferivo* .

919

Edson Prata. *Comentários ao Código de Processo Civil* , v. 7, art. 1.157, item 2, p. 244.

920

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. v. X, art. 1.158, item 108, p. 229; José Maria Rosa Tesheiner. *Jurisdição voluntária* , item 3.3, p. 73. Persiste, porém, o direito à petição de herança, como detalhado acima.

921

TJSP, AgIn 2002572-36.2016.8.26.0000, 10.^a Câmara de Direito Privado, j. 21.03.2017, julgado por Cesar Ciampolini.

922

José Maria Rosa Tesheiner. *Jurisdição voluntária*, item 3.3, p. 74.

923

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.157, item 218, p. 364.

924

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*, art. 744, item 6, p. 718.

925

A ação de investigação de paternidade é imprescritível: Súmula 149/STF “É imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a de petição de herança.”

926

STJ. 3.^a Turma. REsp não indicado (segredo de justiça). rel. Min. João Otávio Noronha. “Dessa forma, conclui-se que, a teor do artigo 189 do Código Civil, o termo inicial para o ajuizamento da ação de petição de herança é a data do trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade, quando, em síntese, confirma-se a condição de herdeiro”. (Sítio [www.stj.jus.br], ‘Prescrição de pedido de herança conta do trânsito em julgado do reconhecimento da paternidade’, 31.05.2016).

927

STJ, 3.^a Turma, AgRg no Ag 1212745/RJ, rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 19.10.2014. Art. 21. O administrador judicial será profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou pessoa jurídica especializada.010, *DJe* 03.11.2010 (...) 2. “O bem integrante de herança jacente só é devolvido ao Estado com a sentença de declaração da vacância, podendo, até ali, ser possuído *ad usucapionem*. Incidência da Súmula 83/STJ”. TJRS, ApCiv 598576445, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, rel.: Rubem Duarte, j. 21.12.1999).

928

Fabio Caldas de Araujo. *Usucapião*, 2. ed., item 6.1.5.3-d), p. 216.

929

TJSP, Ap 0168437-30.2002.8.26.0100, 7.^a Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2017, julgado por Luis Mário Galbetti.

930

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, tomo XVI, art. 1.154, item 3, p. 309.

931

Ver sobre o tema, por todos: Gilberto Gomes Bruschi, *Apelação civil* : teoria geral, procedimento e saneamento de vícios pelo tribunal, itens 3.1-3.2, p. 87-164. Gleydson Kleber de Oliveira. *Apelação no Direito Processual Civil Brasileiro* , itens 3.1-3.7, p. 92-169. Flavio Cheim Jorge. *ApCiv* : teoria geral e admissibilidade, itens 5.1-5.2, p. 79-208.

932

A redação do art. 1.159 do CPC/1973 repetia quase integralmente o art. 463 do CC de 1916, modificado parcialmente no CC de 2002.

933

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil* , tomo XVI, Cap. VI, item 1, p. 333. Em sentido similar: Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil* , v. XII, art. 1.159, item 220, p. 366-367.

934

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil* , v. XII, art. 1.159, item 220.2, p. 368-369.

935

Art. 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo.

936

João Paulo Lucena sintetiza as três hipóteses, com base na doutrina antecedente: João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil* . v. 15, art. 1.159, item 2, p. 235.

937

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil* , tomo XVI, Cap. VI, item 1, p. 323; art. 1.159, item 1, p. 326-327. Para este e os demais autores citados o Código Civil de 1916 usara a expressão *domicílio* impropriamente e a ausência seria a não presença na residência.

938

Everaldo Augusto Cambler; Wanderlei de Paula Barreto; Marcelo Navarro Ribeiro Dantas; Marcelo Terra. *Comentários ao Código Civil Brasileiro – Parte Geral*, art. 22, item n.1, p. 222.

939

João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil* . v. 15, art. 1.159, item 2, p. 235-238. Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil* , v. XII, art. 1.159, item 221, p. 369. José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. v. X, art. 1.159, item 110-B, p. 233.

940

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil* , v. XII, art. 1.159, item 224, p. 373-374.

941

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.159, item 220.2, p. 368-369.

942

Edson Prata. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 7, art. 1.159, item 6, p. 253-254.

943

Everaldo Augusto Cambler; Wanderlei de Paula Barreto; Marcelo Navarro Ribeiro Dantas; Marcelo Terra. *Comentários ao Código Civil Brasileiro – Parte Geral*, art. 23, item n.5, p. 232.

944

Casos há de demandas previdenciárias envolvendo os Regimes Próprios de Previdência dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios que também serão de competência da Justiça Comum estadual, assim como outras demandas da previdência complementar fechada (fundos de pensão).

945

TRF3, 2.^a Turma. ApCiv 50171, rel. Des. Fed. Souza Pires, j. 26.05.1992, *DOE* 22.06.1992.

946

STJ, 2.^a Seção. CComp 86809. rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.09.2007, *DJ* 20.09.2007, com seguintes fundamentos: “Conquanto fundamentado o pedido inicial nas disposições dos arts. 1.160 e ss. do CPC, o ausente não deixou quaisquer bens para serem arrecadados, pretendendo a autora, com a declaração de ausência do marido, auferir benefícios previdenciários, dentre outros que cita, tais como depósitos fundiários e verbas porventura pertencentes ao desaparecido. – Não havendo bens a arrecadar, dispensando-se, por consequência, o procedimento previsto nos arts. 1.159 e ss. do CPC (...)”

947

A lei processual não define nem dá preferência a certo profissional ou certa habilitação, como a Lei 11.101/2005, Lei de Recuperação Judicial de Empresas e Falências, que no art. 21 exige profissional idôneo, de preferência advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou pessoa jurídica especializada.

948

Art. 24. O juiz, que nomear o curador, fixar-lhe-á os poderes e obrigações, conforme as circunstâncias, observando, no que for aplicável, o disposto a respeito dos tutores e curadores.

950

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.143, item 160, p. 310.

951

Everaldo Augusto Cambler; Wanderlei de Paula Barreto; Marcelo Navarro Ribeiro Dantas; Marcelo Terra. *Comentários ao Código Civil Brasileiro – Parte Geral*, art. 24, item n.1, p. 234.

952

Dever equivalente incumbe ao empresário na penhora de faturamento (art. 867, § 2.º).

953

Everaldo Augusto Cambler; Wanderlei de Paula Barreto; Marcelo Navarro Ribeiro Dantas; Marcelo Terra. *Comentários ao Código Civil Brasileiro – Parte Geral*, art. 23, item n.4, p. 231.

954

Idem, ibidem.

955

O atual CPC preserva a expressão ‘imprensa da comarca’ nos procedimentos especiais de Herança Jacente e Coisas Vagas, mantendo ainda o debate sobre os conceitos de *imprensa da comarca* e *imprensa de circulação local* que se deu também na vigência do CPC anterior.

956

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo código de processo civil comentado*, art. 745, item 2, p. 720. Lenio Luiz Streck; Dierle Nunes; Leonardo Carneiro Cunha (org). *Comentários ao Código de Processo Civil : de acordo com a Lei 13.256/2016*, art. 745, item 2, p. 985.

957

João Paulo Lucena. *Comentários ao código de processo civil* . v. 15, art. 1.164, item 1, p. 258.

958

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil* , v. XII, art. 1.164, item 241, p. 392.

959

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado* , art. 745, item 3, p. 720.

960

João Paulo Lucena. *Comentários ao código de processo civil* . v. 15, art. 1.164, item 1, p. 258.

961

Idem, ibidem.

962

Alcides de Mendonça Lima. Comentários ao Código de Processo Civil, v. XII, art. 1.164, item 242, p. 393.

965

Idem, ibidem.

966

Idem, ibidem.

967

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*, art. 745, item 9, p. 721.

968

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.105, item 6.1, p. 46.

969

Ver sobre o tema, por todos: Gilberto Gomes Bruschi, *Ap civil*: teoria geral, procedimento e saneamento de vícios pelo tribunal, itens 3.1-3.2, p. 87-164. Gleydson Kleber de Oliveira. *Ap no Direito Processual Civil Brasileiro*, itens 3.1-3.7, p. 92-169. Flavio Cheim Jorge. *Ap Civil*: teoria geral e admissibilidade, itens 5.1-5.2, p. 79-208.

Seção VIII

Das coisas vagas

970

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, tomo XVI, Capítulo VII, item 1, p. 356.

971

Luciano de Camargo Penteado. *Direito das coisas*, 2. ed., cap. VII, item 54, p. 308. Clovis Beviláqua considerava que “(...) bens móveis, únicos que constituem as “coisas vagas”, Alcides de Mendonça Clovis Beviláqua Lima, o processualista, *Revista de Processo*, n. 23, item 19.^a (versão eletrônica).

972

CPC/1973: (...) Art. 1.172. Comparecendo o dono ou o legítimo possuidor dentro do prazo do edital e provando o seu direito, o juiz, ouvido o órgão do Ministério Público e o representante da Fazenda Pública, mandará entregar-lhe a coisa. Art. 1.173. Se não for reclamada, será a coisa avaliada e alienada em hasta pública e, deduzidas do preço as despesas e a recompensa do inventor, o saldo pertencerá, na forma da lei, à União, ao Estado ou ao Distrito Federal. Art. 1.174. Se o dono preferir abandonar a coisa, poderá o inventor requerer que lhe seja adjudicada. Art. 1.175. O procedimento estabelecido neste Capítulo aplica-se aos objetos deixados nos hotéis, oficinas e outros estabelecimentos, não sendo reclamados dentro de 1 (um) mês. Art. 1.176. Havendo fundada

suspeita de que a coisa foi criminosamente subtraída, a autoridade policial converterá a arrecadação em inquérito; caso em que competirá ao juiz criminal mandar entregar a coisa a quem provar que é o dono ou legítimo possuidor.

973

Marcos Bernardes de Mello. *Teoria do fato jurídico. Plano da existência*. 20. ed., p. 188.

974

Luciano de Camargo Penteado. *Direito das coisas*, 2. ed., cap. VII, item 52, p. 307-308.

975

João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil*. v. 15, art. 1.170, item 1, p. 279; o autor faz a distinção a partir de Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda.

976

Alcides de Mendonça Lima criticava a inutilidade da descrição do procedimento em sete artigos, que nunca seriam utilizados pela circunstância da vida moderna. Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1170, item 262, p. 411.

977

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*, art. 746, item 1, p. 721.

978

Idem, p. 721-722.

979

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XVI, art. 1.770, item 4, p. 358.

980

Cristina Ferraz. *Jurisdição voluntária no processo civil*, item 6.22.2, p. 249-250. A autora não admite a hipótese no sistema do CPC/1973; no CPC/2015, diante das concepções de aproveitamento, salvamento e instrumentalidade, é de se repensar e admitir a conversão.

981

Este prazo pode ser dilatado, especialmente na jurisdição voluntária e, notadamente após o permissivo do art. 139, inc. VI, no qual se autoriza “dilatatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito.”

982

Luciano de Camargo Penteado. *Direito das coisas*, 2. ed., cap. VII, item 74-75, p. 362-363. Cristiano Chaves de Farias; Nelson Rosendal. *Direitos Reais*, 5. ed., cap. III, item 9.3, p. 324-326.

983

Art. 1.237. Decorridos sessenta dias da divulgação da notícia pela imprensa, ou do edital, não se apresentando quem comprove a propriedade sobre a coisa, será esta vendida em hasta pública e, deduzidas do preço as despesas, mais a recompensa do descobridor, pertencerá o remanescente ao Município em cuja circunscrição se deparou o objeto perdido. Parágrafo único. Sendo de diminuto valor, poderá o Município abandonar a coisa em favor de quem a achou.

984

Art. 1.234. Aquele que restituir a coisa achada, nos termos do artigo antecedente, terá direito a uma recompensa não inferior a cinco por cento do seu valor, e à indenização pelas despesas que houver feito com a conservação e transporte da coisa, se o dono não preferir abandoná-la. Parágrafo único. Na determinação do montante da recompensa, considerar-se-á o esforço desenvolvido pelo descobridor para encontrar o dono, ou o legítimo possuidor, as possibilidades que teria este de encontrar a coisa e a situação econômica de ambos.

985

Ver sobre o tema, por todos: Gilberto Gomes Bruschi, *Ap civil*: teoria geral, procedimento e saneamento de vícios pelo tribunal, itens 3.1-3.2, p. 87-164. Gleydson Kleber de Oliveira. *Ap no Direito Processual Civil Brasileiro*, itens 3.1-3.7, p. 92-169. Flavio Cheim Jorge. *Ap Civil*: teoria geral e admissibilidade, itens 5.1-5.2, p. 79-208.

986

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.176, item 276, p. 425-427.

987

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.177, item 278, p. 428-429, criticava o CPC/1973 por inverter e indicar a curatela, que é possível consequência da interdição, antes desta: “o efeito, portanto, aparece antes da causa.”

988

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Tratado de Direito Privado*, tomo IX. Direito de Família. Direito Parental, § 1.030, item 4, p. 426.

989

Zeno Veloso. *Código Civil Comentado*, v. XVII, art. 1.767, p. 208-209.

990

Brasil. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.286.133/MG, 3.^a Turma rel.: Min. Marco Aurélio Belize. Brasília, DF, 5 abr. 2016. Disponível em: [\www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?

991

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.177, item 280, p. 432.

992

TJSP, Ap 0001398-22.2014.8.26.0412, 5.^a Câmara de Direito Público, j. 18.04.2016, julgado por Heloísa Martins Mimessi.

993

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinada em Nova York em 30 de março de 2007, foi aprovada pelo Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo 186/2008, promulgada pelo Decreto 6.949/2009, do Presidente da República.

994

Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: I – aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; II – (Revogado); III – os ébrios habituais e os viciados em tóxico; IV – (Revogado); V – os pródigos.

995

Art. 1.783-A. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 (duas) pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. § 1.º Para formular pedido de tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência e os apoiadores devem apresentar termo em que constem os limites do apoio a ser oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de vigência do acordo e o respeito à vontade, aos direitos e aos interesses da pessoa que devem apoiar. § 2.º O pedido de tomada de decisão apoiada será requerido pela pessoa a ser apoiada, com indicação expressa das pessoas aptas a prestarem o apoio previsto no caput deste artigo. § 3.º Antes de se pronunciar sobre o pedido de tomada de decisão apoiada, o juiz, assistido por equipe multidisciplinar, após oitiva do Ministério Público, ouvirá pessoalmente o requerente e as pessoas que lhe prestarão apoio. § 4.º A decisão tomada por pessoa apoiada terá validade e efeitos sobre terceiros, sem restrições, desde que esteja inserida nos limites do apoio acordado. § 5.º Terceiro com quem a pessoa apoiada mantenha relação negocial pode solicitar que os apoiadores contra-assinem o contrato ou acordo, especificando, por escrito, sua função em relação ao apoiado. § 6.º Em caso de negócio jurídico que possa trazer risco ou prejuízo relevante, havendo divergência de opiniões entre a pessoa apoiada e um dos apoiadores, deverá o juiz, ouvido o Ministério Público, decidir sobre a questão. § 7.º Se o apoiador agir com negligência, exercer pressão indevida ou não adimplir as obrigações assumidas, poderá a pessoa apoiada ou qualquer pessoa apresentar denúncia ao Ministério Público ou ao juiz. § 8.º Se procedente a denúncia, o juiz destituirá o apoiador e nomeará, ouvida a pessoa apoiada e se for de seu interesse, outra pessoa para prestação de apoio. § 9.º A pessoa apoiada pode, a qualquer tempo, solicitar o término de acordo firmado em processo de tomada de decisão apoiada. § 10. O apoiador pode solicitar ao juiz a exclusão de sua participação do processo de tomada de decisão apoiada, sendo seu desligamento condicionado à manifestação do juiz sobre a matéria. § 11. Aplicam-se à tomada de decisão apoiada, no que couber, as disposições referentes à prestação de contas na curatela.

996

No AREsp 1056169, relatado pelo Min. Antonio Carlos Ferreira, o instituto foi referido ao examinar-se um pedido de interdição rejeitado em dois graus de jurisdição, ali considerada a TDA uma “medida intermediária quando comparada à interdição.

997

TJSP, AgIn 2157658-63.2017.8.26.0000, 7.^a Câmara de Direito Privado, j. 28.03.2018, julgado por José Rubens Queiroz Gomes; neste caso pretendia o terceiro interveniente a conversão do procedimento de interdição em tomada de decisão apoiada.

998

Improvável que se cogite de conexão (art. 55) entre os dois procedimentos de *interdição* e de *tomada de decisão apoiada*, visto possuírem causas de pedir que são diversas e pedidos também diferentes; a continência não se revela possível, pela mesma razão final da diferença entre pedidos nos dois procedimentos e pela diversidade de ‘partes’. Mesmo assim, havendo coincidência temporal de procedimentos de *interdição* e de *tomada de decisão apoiada*, envolvendo a mesma pessoa pode ser justificável a reunião de processos de modo a prevenir o “risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso [sejam] decididos separadamente” (art. 55, § 3.º).

999

TJSP, AgIn 2049735-75.2017.8.26.0000, 1.^a Câmara de Direito Privado, j. 18.09.2017, julgado por Rui Cascaldi; neste caso o tribunal reformou a decisão recorrida que concedera curatela frente ao pedido de TDA à pessoa portadora de limitações decorrentes de diabetes.

1000

TJRS, ApCiv 70073799488, 8.^a Câmara Cível, j. 17.08.2017, julgado por Luiz Felipe Brasil Santos; TJRS, ApCiv 70069874634, 8.^a Câmara Cível, j. 28.07.2016, julgado por Rui Portanova; TJSP, Ap 0006290-33.2013.8.26.0242, 6.^a Câmara de Direito Privado, j. 02.06.2016, julgado por Eduardo Sá Pinto Sandeville.

1001

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XVI, art. 1.777, item 3, p. 376. Também: Edson Prata. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 7, art. 1.177, item 3, p. 294-295; Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.177, item 279, p. 430-432.

1002

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XVI, cap. VIII, item 1, p. 368.

1003

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XVI, art. 1.177, item 1, p. 374; “o autor fala em grande dose de inquitividade”, embora considere uma ação como outras, com estrutura própria.

1004

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, item 280, p. 432-433. O autor alertava que por ser hipótese de *legitimatio ad causam*, estava adequadamente indicada na regra de direito material,

aspecto agora desconsiderado pela Lei 13.146/2015.

1005

O conceito da teoria do processo é singelo mas preciso: “autor é aquele que deduz em juízo uma pretensão (*qui res in iudicium deducit*); e réu, aquele em face de quem aquela pretensão é deduzida (*is contra quem res in iudicium deducitur*)”; Antônio Carlos de Araújo Cintra; Ada Pellegrini Grinover; Cândido Rangel Dinamarco. *Teoria Geral do Processo* . 20. ed., item 187, p. 295.

1006

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil* , v. XII, art. 1.177, item 282.1, p. 433.

1007

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 138.599/SP, 4.^a Turma, rel.: Min. Ruy Rosado de Aguiar. Brasília, DF, 8 out 1997. Disponível em: [http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre="curatela&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=31].” Acesso em: 13.08.2016.

1008

TJSP, AgIn 2138836-26.2017.8.26.0000, 5.^a Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2017, julgado por Moreira Viegas.

1009

O CPC/2015 estende os efeitos das relações processuais, assim como direitos, deveres, ônus etc., em diversos dispositivos não previstos anteriormente, passando de duas referências equiparadoras no procedimento de inventário do CPC/1973 para dezoito no CPC/2015. Seja quanto a impedimentos (art. 144, incs. III, IV e VIII) e suspeições (art. 145, inc. III); seja a equiparação na limitação de efeitos ou deveres probatórios (art. 391, par. único; art. 448, inc. I); seja equiparando na legitimação em procedimentos (art. 600, par. único; art. 616, inc. I e IX; art. 617, inc. I e II; art. 620, inc. II; art. 649; art. 653, inc. I, a; art. 674, inc. I; art. 740, § 6.º; art. 741, § 3.º); responsabilidade patrimonial (art. 790, inc. IV).

1010

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil* , v. XII, art. 1.177, item 282.2, p. 434.

1011

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao CPC* (1973), v. XVI, art. 1.777, item 2, p. 374; idem (1939), cit., vol. VIII, p. 23, n. 2.

1012

Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil* , art. 747, item 3, p. 1595, admite qualquer doa afins como legítimo para a ação de interdição.

1013

O CC/2002, art. 1.768, inc. II, previa a possibilidade de interdição a “qualquer parente”, disposição revogada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), sem distinguir colaterais e afins. Essa supressão no Código Civil não altera a interpretação da legitimidade dos parentes afins, da leitura exclusiva do CPC/2015.

1014

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Tratado de Direito Privado*, tomo IX. Direito de Família. Direito Parental, § 1.012, item 1, p. 348.

1015

A Lei 10.216/2001, que prevê os direitos das pessoas com transtornos mentais estabelece que: Art. 4.º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. (...) § 3.º É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2.º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2.º.

1016

A Lei 8.069/1990, Estatuto da Criança e Adolescente, desde as alterações Lei 12.010/2009, denomina os antigos orfanatos ou abrigos como *instituições de acolhimento*.

1017

A diferenciação entre a expressão aberta “anomalia psíquica” e restrita “doença mental grave” deve ser estabelecida no âmbito estrito das ciências médicas e pela prova pericial obtida antecedentemente (art. 381) ou no curso do processo (arts. 466-479), que pode induzir a ilegitimidade do Ministério Público e à extinção do processo sem exame do pedido.

1018

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*, 5. ed. v. X, art. 1.178, item 135-A, p. 271.

1019

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1177, item 284, p. 436.

1020

Edson Prata. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 7, art. 1.177, item 8, p. 300.

1021

“Art. 1.768. O processo que define os termos da curatela deve ser promovido: (...) IV – pela própria pessoa”.

1022

Fredie Didier Junior. *Editorial 187*, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Código de Processo Civil de 2015 e Código Civil: uma primeira reflexão. Disponível em: [<http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-187>].

1023

Ubiratan do Couto Maurício. *Assistência simples no Direito Processual Civil*, item 7.5.2, p. 79.

1024

TJMG, ApCiv 1.0313.15.026302-5/001, 6.^a Câmara Cível, j. 13.12.2016, julgado por Edilson Fernandes.

1025

Art. 1.767. (...) I – aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para os atos da vida civil; II – aqueles que, por outra causa duradoura, não puderem exprimir a sua vontade; III – os deficientes mentais, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos; IV – os excepcionais sem completo desenvolvimento mental; V – os pródigos.

1026

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Tratado de Direito Privado*, tomo IX. Direito de Família. Direito Parental. § 1.033, p. 436-440.

1027

Edson Prata. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 7, art. 1.177, item 7, p. 299.

1028

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. v. X, item 134, p. 269.

1029

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.177, item 285, p. 43. João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil*. v. 15, art. 1.177, item 3, p. 294.

1030

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XVI, art. 1.177, item 1, p. 374.

1031

Transtornos do neurodesenvolvimento, esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, transtorno bipolar e transtornos relacionados, transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo e transtornos relacionados, transtornos relacionados a trauma e a estressores, transtornos dissociativos, transtorno de sintomas somáticos e transtornos relacionados, transtornos alimentares, transtornos da eliminação, transtornos do sono-vigília, disfunções sexuais, disforia de gênero, transtornos disruptivos, do controle de impulsos e da conduta, transtornos relacionados a substâncias e transtornos aditivos, transtornos neurocognitivos, transtornos da personalidade, transtornos parafilicos, outros transtornos mentais, transtornos do movimento induzidos por medicamentos, e outros efeitos adversos de medicamentos.

1032

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, Rosa Maria Andrade Nery. *Tratado de Direito Privado*, tomo IX. Direito de Família. Direito Parental, § 1037.B, p. 457.

1033

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.180, item 292, p. 446.

1034

Brasil. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.251.728/PE, 3.^a Turma, rel.: Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Brasília, DF, 14.05.2013. Disponível em: [www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre="curatela&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=9]. Acesso em: 13.08.2016.

1035

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. v. X, art. 1.181, item 138-A, p. 227; a sugestão de nomeação era do atualizador desta edição.

1036

Pontes de Miranda já observara as peculiaridades do procedimento, muito antes destas alterações, destacando a alta dose de inquisitividade. Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XVI, art. 1.177, item 1, p. 374.

1037

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, tomo XVI, art. 1.777, item 1, p. 374.

1038

Edson Prata. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 7, arts. 1.103-1.220, art. 1.181, item 1, p. 307.

1039

STJ, REsp 1.686.161, 3.^a Turma, j. 12.09.2017, julgado por Nancy Andrigli, *DJe* 15.09.2017. “O interrogatório do interditando é medida que garante o contraditório e a ampla defesa de pessoa que se encontra em presumido estado de vulnerabilidade.”

1040

João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil*. v. 15, art. 1.182 – V. 15, item 1, p. 310.

1041

Edson Prata. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 7, arts. 1.103-1.220, p. 312, item 1.

1042

Nelson Nery Junior, *Código de Processo Civil comentado*, p. 1.039. João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil*. v. 15, item 1, p. 74. Cristina Ferraz. *Jurisdição voluntária no processo civil*, item 6.21.2, p. 238.

1043

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. v. X, item 10, p. 43, com referências à jurisprudência em ambos os sentidos.

1044

Talvez se possa cogitar, após a vigência e experimentação do CPC/2015, de pedidos alternativos que se contenham em um mesmo procedimento, em que autor peça tomada de decisão apoiada ou curatela, considerando as inovações permitidas pelo art. 327, § 2.º, parte final. Ver sobre nova teoria dos procedimentos especiais: Fredie Didier Junior; Antonio do Passo Cabral; Leonardo Carneiro da Cunha. *Por uma nova teoria dos procedimentos especiais: dos procedimentos às técnicas*, item n. 8.4, p. 84-97.

1045

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, tomo XVI, art. 1.777, item 2, p. 375.

1046

No Regulamento 737/1850, norma processual comercial do Império do Brasil – 45 anos antes da *Zivilprozessordnung* de 1895, austríaca, já havia a possibilidade de o juiz ordenar diligências independentemente do requerimento das partes, art. 230; no CPC/1939 destacavam-se os arts. 112 e 117, que conferiam poderes do juiz na instrução, após vários Códigos Estaduais; também presentes no art. 130 CPC/1973. Ver: Jefferson Carús Guedes. *Direito Processual Social Atual: entre o Ativismo Judicial e o Garantismo Processual*. *Revista Brasileira de Direito Processual*, n. 82, item 2.b, p. 51.

1047

O CPC/2015 não reproduziu o teor do art. 1.107 do CPC/1973: “Os interessados podem produzir as provas destinadas a demonstrar as suas alegações; mas ao juiz é lícito investigar livremente os fatos e ordenar de ofício a realização de quaisquer provas.”

1048

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. v. X, art. 1.183, item 142, p. 284.

1049

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. v. X, art. 1.181, item 138-A, p. 227.

1050

João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil*. v. 15, São Paulo: Ed. RT, 2000, art. 1.183 item 2, p. 314.

1051

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, tomo XVI, art. 1.184, item 5, p. 394.

1052

Brasil. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.346.013/MG, 3.^a Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. Brasília, DF, 05.10.2015. Disponível em: [https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1450912&num_registro=201202016516&data=20151020&formato=PDF]. Acesso em: 14 ago 2016.

1053

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, tomo XVI, Capítulo VIII, item 1, p. 367.

1054

João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil*. v. 15, art. 1.184 – V. 15, p. 319.

1055

Edson Prata. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 7, arts. 1.103-1.220, art. 1.185, item 5, p. 320.

1056

Idem, item 3, p. 319.

1057

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. v. X., art. 1.186, item 151, p. 297-298.

1058

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, tomo XVI, art. 1.186, item 3, p. 404.

1059

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. v. X, art. 1.186, item n 156, p. 297-298.

1060

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.186, item 321. p. 474.

1061

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, tomo XVI, art. 1.186, item 4, p. 404.

1062

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.186, item 323.1, p. 475.

1063

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.186, item 323.1, p. 475.

1064

Edson Prata. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 7, arts. 1.103-1.220, item 5, p. 326.

1065

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.186, item 323. p. 475.

1066

João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil*. v. 15, art. 1.186, item 1. p. 324.

1067

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, tomo XVI. art. 1.186, item 4, p. 404.

1068

No Preâmbulo. (...) n) Reconhecendo a importância, para as pessoas com deficiência, de sua autonomia e independência individuais, inclusive da liberdade para fazer as próprias escolhas. Art. 3 Princípios Gerais. a) O respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e a independência das pessoas; Art. 16 Prevenção contra a exploração, a violência e o abuso. (...) 4. Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para promover a recuperação física, cognitiva e psicológica, inclusive mediante a provisão de serviços de proteção, a reabilitação e a reinserção social de pessoas com deficiência que forem vítimas de qualquer forma de exploração, violência ou abuso. Tais recuperação e reinserção ocorrerão em ambientes que promovam a saúde, o bem-estar, o autorrespeito, a dignidade e a autonomia da pessoa e levem em consideração as necessidades de gênero e idade.

1069

Art. 14. O processo de habilitação e de reabilitação é um direito da pessoa com deficiência. Parágrafo único. O processo de habilitação e de reabilitação tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas.

1070

Pode-se considerar como sinal contido na norma de 2001, dessa posterior busca e estímulo à autonomia da pessoa com transtorno mental o direito à cientificação pessoal (art. 2.º), direito à presença médica (art. 2.º, inc. V), direito a “ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade” (art. 2.º, inc. V), dentre outros.

1071

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Tratado de Direito Privado*, tomo IX. Direito de Família. Direito Parental, § 1.012, item 1, p. 348.

1072

Idem, § 1.030, item 4, p. 426.

1073

Zeno Veloso. *Código Civil Comentado*, v. XVII, art. 1.767, p. 208-209.

1074

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.177, item 280, p. 432.

1075

João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil*. v. 15, art. 1.187, item 1, p. 329.

1076

Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil*, art. 759, item I: 3, p. 1605.

1077

Brasil. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 138.599/SP, 4.^a Turma, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar. Brasília, DF, 8 out 1997. Disponível em: [http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre="curatela&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=31].” Acesso em: 13.08.2016.

1078

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, tomo XVI, art. 1.187, item 4, p. 410.

1079

Art. 1.729. O direito de nomear tutor compete aos pais, em conjunto. Parágrafo único. A nomeação deve constar de testamento ou de qualquer outro documento autêntico.

1080

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.143, item 326, p. 481.

1082

Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil*, art. 759, item §§ 1.º e 2.º: 6, p. 1605.

1083

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.143, item 160, p. 310.

1084

Idem, art. 1.192, item n. 340, p. 492.

1085

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.197, item n. 342, p. 494.

1086

Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil*, art. 759, item § 2.º: 4, p. 1606.

1087

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. v. X, art. 1.194, item 156, p. 306.

1088

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.194, item 346.1, p. 499.

1089

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*, 5. ed. v. X, art. 1.178, item 135-A, p. 271.

1090

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.194, item 349, p. 501.

1091

Edson Prata, *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 7, art. 1.195, item 1, p. 340 e 341.

1092

Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil*, art. 761, item 5, p. 1607.

1093

Idem, item 2, p. 1606.

1094

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.194, item 350.1, p. 502.

1095

Idem, item 350, p. 502.

1096

Código de Processo Civil comentado, art. 1.197, p. 1.427. João Paulo Lucena. *Comentários ao Código de Processo Civil*. v. 15, art. 1.197, item 1, p. 349.

1097

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.197, item 352, p. 503.

1098

Edson Prata, *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 7, art. 1.197, item 2, p. 343.

1099

Idem, ibidem.

1100

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, tomo XVI, art. 1.197, item 6, p. 423.

1101

Edson Prata, *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 7, art. 1.197, item 1, p. 342.

1102

José Olympio de Castro Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*, 5. ed. v. X, art. 1.197, item 158, p. 307.

1103

Idem, p. 308.

1104

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.198, item 356, p. 507.

1105

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.198, item 357, p. 507.

1106

Idem, item 358, p. 508.

1107

Idem, item 357, p. 507.

1108

Ver sobre o tema, por todos: Gilberto Gomes Bruschi, *Ap civil* : teoria geral, procedimento e saneamento de vícios pelo tribunal, itens 3.1-3.2, p. 87-164. Gleydson Kleber Lopes de Oliveira. *Ap no Direito Processual Civil Brasileiro*, itens 3.1-3.7, p. 92-169. Flavio Cheim Jorge. *Ap Civil* : teoria geral e admissibilidade, itens 5.1-5.2, p. 79-208.

1109

De acordo com a Lei 7.596, de 10 de abril de 1987, a fundação de direito público é toda entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes.

1110

Sílvia de Salvo Venosa. *Direito Civil*, Vol. I, 4. ed., cap. 13, item 13.12, p. 299.

1111

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho. *Novo Curso de Direito Civil, Parte Geral*, v. I. I, cap. VI, item 7.2.3, p. 263.

1112

Daniel Pires Novais Dias. *Negócio Fundacional, Criação de Fundações Privadas*, item 4.1 – 4.2, p. 101-144.

1113

José Eduardo Sabo Paes. *Fundações, Associações e Entidades de Interesse Social*, 7. ed., cap. IV, item 6, p. 249-300.

1114

TJMG, ApCiv 1.0704.15.009525-2/001, 2.ª Câmara Cível, j. 08.11.2016, rel. Hilda Maria Pôrto de Paula Teixeira da Costa.

1115

Essas fundações possuem participantes de fundos que possuem outros instrumentos de fiscalização e acompanhamento, tal como a ação de prestação de contas. Ver: STJ, REsp 1.561.427, 2.^a Seção, j. 22.02.2018, rel. Min. Luis Felipe Salomão.

1116

As fundações de previdência privada ou complementar fechada ou ‘fundos de pensão’ são organizadas segundo as Leis Complementares 108/2001 e 109/2001, leis ordinárias, decretos e normas menores emitidas preponderantemente pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), agência reguladora do setor organizada sob a forma de autarquia federal (Lei 12.154/2009), encarregada de autorizar a constituição e funcionamento, fiscalizar, controlar, intervir e liquidar essas fundações.

1117

Exceções podem ser vistas em: Edson Prata. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 7, art. 1199, item 4, p. 346. O autor nota que a fiscalização não compete exclusivamente ao juiz, pelo menos do modo como viera indicada nos arts. 1.299-1.205 do CPC/1973. Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1199, item 359, p. 509.

1118

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*, art. 764, item 1, p. 731.

1119

José Eduardo Sabo Paes. *Fundações, Associações e Entidades de Interesse Social*, 7. ed., cap. I, item 1.7.1, p. 71.

1120

TJMG, AgIn 1.0672.11.014069-2/001, 9.^a Câmara Cível, j. 24.03.2017, rel. Amorim Siqueira.

1121

Caio Mário da Silva Pereira. *Instituições de Direito Civil*, V. I, 28. ed., cap. XII, item 62, p. 302.

1122

Art. 62. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina, e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se para fins religiosos, morais, culturais ou de assistência. Parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se para fins de: I – assistência social; II – cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; III – educação; IV – saúde; V – segurança alimentar e nutricional; VI – defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; VII – pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos; VIII – promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos; IX – atividades religiosas; e X – (VETADO).

1123

Daniel Pires Novais Dias. *Negócio Fundacional, Criação de Fundações Privadas*, item 3.3.1, p. 79.

1124

José Eduardo Sabo Paes. *Fundações, Associações e Entidades de Interesse Social*, 7. ed., cap. V, item 2, p. 302.

1125

Art. 120. O registro das sociedades, fundações e partidos políticos consistirá na declaração, feita em livro, pelo oficial, do número de ordem, da data da apresentação e da espécie do ato constitutivo, com as seguintes indicações: I – a denominação, o fundo social, quando houver, os fins e a sede da associação ou fundação, bem como o tempo de sua duração; II – o modo por que se administra e representa a sociedade, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; III – se o estatuto, o contrato ou o compromisso é reformável, no tocante à administração, e de que modo; IV – se os membros respondem ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais; V – as condições de extinção da pessoa jurídica e nesse caso o destino do seu patrimônio; VI – os nomes dos fundadores ou instituidores e dos membros da diretoria, provisória ou definitiva, com indicação da nacionalidade, estado civil e profissão de cada um, bem como o nome e residência do apresentante dos exemplares. Parágrafo único. Para o registro dos partidos políticos, serão obedecidos, além dos requisitos deste artigo, os estabelecidos em lei específica. Art. 121. Para o registro serão apresentadas duas vias do estatuto, compromisso ou contrato, pelas quais far-se-á o registro mediante petição do representante legal da sociedade, lançando o oficial, nas duas vias, a competente certidão do registro, com o respectivo número de ordem, livro e folha. Uma das vias será entregue ao representante e a outra arquivada em cartório, rubricando o oficial as folhas em que estiver impresso o contrato, compromisso ou estatuto.

1126

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, tomo XVI, item 2, p. 426.

1127

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: (...) III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.

1128

Art. 66. Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas. § 1.º Se funcionarem no Distrito Federal ou em Território, caberá o encargo ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. § 2.º Se estenderem a atividade por mais de um Estado, caberá o encargo, em cada um deles, ao respectivo Ministério Público.

1129

STJ, AgInt no Agravo no REsp 893.358, 2.ª Turma, j. 08.05/2018, rel. Min. Assusete Magalhães.

1130

STF, MS 32.703 AgRg, 2.ª Turma, j. 10.04.2018, rel. Min. Dias Toffoli.

1131

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, tomo XVI, item 6, p. 431.

1132

Art. 65. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, em tendo ciência do encargo, formularão logo, de acordo com as suas bases (art. 62), o estatuto da fundação projetada, submetendo-o, em seguida, à aprovação da autoridade competente, com recurso ao juiz.

1133

José Eduardo Sabo Paes. *Fundações, Associações e Entidades de Interesse Social*, 7. ed., cap. XIII, item 3.5.2., p. 600.

1134

José Eduardo Sabo Paes. *Fundações, Associações e Entidades de Interesse Social*, 7. ed., cap. XIII, item 3.5.2., p. 601.

1135

TJRS, ApCiv 70072398878, 15.^a Câmara Cível, j. 31.05.2017, rel. Otávio Augusto de Freitas Barcellos.

1136

José Eduardo Sabo Paes. *Fundações, Associações e Entidades de Interesse Social*, 7. ed., cap. X, item 1, p. 424.

1137

Alcides de Mendonça Lima. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. XII, art. 1.105, item 6.1, p. 46; Nelson Nery Junior. Intervenção do Ministério Público nos procedimentos especiais de jurisdição voluntária. *Revista de Processo*, v. 46, p. 7-28, item 6 (versão eletrônica).

1138

TJ-SP – Ap 00003645720098260292 SP 0000364-57.2009.8.26.0292 (TJ-SP).

1139

Art. 1218. Continuam em vigor até serem incorporados às leis especiais os procedimentos regulados pelo Dec.-lei 1.608, de 18.09.1939, concernentes: (...) VIII – aos protestos formados a bordo (arts. 725 a 729).

1140

Para Osvaldo Agripino de Castro Junior, o Direito Marítimo “abrange o conjunto de normas que regulam a navegação, o comércio marítimo, os contratos de transportes de mercadorias, e pessoas, por via marítima, fluvial e lacustre, os direitos, deveres e obrigações do armador, dos capitães e demais interessados nos serviços de navegação privada, bem como a situação dos navios a seu serviço.” (Osvaldo Agripino de Castro Júnior. Aspectos

1141

Para Osvaldo Agripino de Castro Junior, o “Direito da Navegação, que pode ser aérea e marítima, de natureza pública, pois prevalecem as normas de direito público interno e internacional, como a universalidade, a supremacia do interesse público, a origem costumeira (*jus cogens*), a imutabilidade e a irretroatividade, além da generalidade das normas de ordem pública.” (Osvaldo Agripino de Castro Júnior. Aspectos introdutórios do direito marítimo, *Revista de Direito Privado* , n. 19, item 2.2, p. 215-242).

1142

O Projeto de Lei 1572/2011, de autoria do Deputado Vicente Cândido e relatoria-geral do deputado Paes Landim, tem sido largamente debatido por parlamentares e entidades interessadas, tendo nas versões mais recentes incorporado Livro próprio do Direito Comercial Marítimo, onde são incluídos os processos testemunháveis formados a bordo.

1143

Ementa: (...) II. Embargos à Execução Fiscal. Caso fortuito no trajeto. Prova Inequívoca. Ratificação de protesto marítimo lavrado a bordo. Exclusão da responsabilidade do transportador. Verba honorária afastada. (TRF-3, AC 59982-SP 95.03.059982-2, rel. Juiz Lazarano Neto, *DJU* 23.05.2006).

1144

Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Dec.-lei 2.472, de 01.09.1988) (...) II – o representante, no País, do transportador estrangeiro. (Redação dada pela MP 2158-35, de 2001).

1145

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. (...) Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: I – contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; II – responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.

1146

Art. 128 do CTN. “Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação”.

1147

Carla Adriana Comitre Gibertoni. *Teoria e Prática do Direito Marítimo* , 2. ed., item VII, p. 261.

1148

Art. 509 do CCom/1850. Nenhuma desculpa poderá desonerar o capitão que alterar a derrota que era obrigado a seguir, ou que pratica algum ato extraordinário de que possa provir dano ao navio ou à carga, sem ter precedido

deliberação tomada em junta composta de todos os oficiais da embarcação, e na presença dos interessados do navio ou na carga, se algum se achar a bordo. Em tais deliberações, e em todas as mais que for obrigado a tomar com acordo dos oficiais do navio, o capitão tem voto de qualidade, e até mesmo poderá obrar contra o vencido, debaixo de sua responsabilidade pessoal, sempre que o julgar conveniente.

1149

Ementa: Ratificação de Protesto Marítimo. Direito Marítimo. Jurisdição voluntária. Embarcação que zarpou de Singapura, atravessando mau tempo no Oceano Índico. Ventos, tempestades, ondas gigantes. Carga ao mar. Avarias ocasionadas a algumas embalagens. Notificação dos interessados. (...) Provimento do Recurso. Precedente Citado: TJRJ AI 2008.002.17313, rel. Des. Galdino Siqueira Neto, julgado em 18.11.2008 e AI 2008.002.13216, rel. Des. Lucia Miguel S. Lima, julgado em 14.10.2008. (TJRJ. 13ª Câmara Cível. AI 4775-44.2009.8.19.0000 (2009.002.09547). rel. Des. Sirley Abreu Biondi. j. 12.08.2009).

1150

Art. 761 do CCom/1850. “Todas as despesas extraordinárias feitas a bem do navio ou da carga, conjunta ou separadamente, e todos os danos acontecidos àquele ou a esta, desde o embarque e partida até a sua volta e desembarque, são reputadas avarias”.

1151

Carla Adriana Comitre Gibertoni. *Teoria e prática do Direito Marítimo*, 2. ed., item VII, p. 211.

1152

Art. 740, CCom/1850. Quando um navio entra por necessidade em algum porto ou lugar distinto dos determinados na viagem a que se propusera, diz-se que fez arribada forçada (art. 510).

1153

Há contundente crítica doutrinária à classificação feita pelo CCom/1850 que classificou a arribada forçada como avaria simples, seguindo os Códigos Comerciais de Portugal e Espanha. Ver, neste sentido João Vicente Campos. *Dos sinistros marítimos*, item 124, p. 139-140.

1154

“No caso vertente, através dos elementos constantes dos autos, verifica-se que, durante a viagem, entre o Porto de Yokohama, no Japão, e o de Balboa, no Panamá, nos dias 2 a 6.2.85, o navio enfrentou verdadeira borrasca em alto mar (ventos violentíssimos com velocidade de 110km/h, que chegaram até a força 11 da escala de Beaufort). As águas atingiram os porões, causando avarias na mercadoria transportada, embora esta se encontrasse devidamente estivada e peiada, para evitar o entrecchoque de volumes. O comandante formulou protesto marítimo a bordo da embarcação, ratificado em Juízo, nos termos do art. 505 do CComercial, caracterizando-se o caso fortuito ou força maior.” (1.º TACivSP. 7.ª Câmara. ApCiv 432.903-1, rel. Juiz Renato Riotaro Takiguthi. j. 24.04.1990).

1155

Art. 1.º As coisas ou bens afundados, submersos, encalhados e perdidos em águas sob jurisdição nacional, em terrenos de marinha e seus acrescidos e em terrenos marginais, em decorrência de sinistro, alijamento ou

fortuna do mar, ficam submetidos às disposições desta lei.

1156

Art. 727. Dentro das vinte e quatro (24) horas úteis da entrada do navio no porto, o capitão se apresentará ao juiz, fazendo-lhe entrega do protesto ou processo testemunhável, formado a bordo, e do Diário da Navegação.

1157

Ementa: Protesto Marítimo – Pedido de Ratificação – Indeferido – art. 505 do C. Comercial de 1850 – Não comparecimento – art. 727 do CPC de 1939 – Ausência de provas, art. 333 do CPC – Recurso não Provido”. (TJSP, 24.^a Câmara de Direito Privado, APL 991010312790 SP, rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, DJ 09.11.2010).

1158

Jorge Americano. *Comentários ao Código de Processo Civil do Brasil*, v. 3, art. 725, p. 142.

1159

Paulo Henrique Cremoneze. *Prática de Direito Marítimo*, p. 175.

1160

Art. 504 do CCom/1850 “No terceiro livro, que será denominado – Diário da Navegação – se assentarão diariamente, enquanto o navio se achar em algum porto, os trabalhos que tiverem lugar a bordo, e os consertos ou reparos do navio. No mesmo livro se assentará também toda a derrota da viagem, notando-se diariamente as observações que os capitães e os pilotos são obrigados a fazer, todas as ocorrências interessantes à navegação, acontecimentos extraordinários que possam ter lugar a bordo, e com especialidade os temporais, e os danos ou avarias que o navio ou a carga possam sofrer, as deliberações que se tomarem por acordo dos oficiais da embarcação, e os competentes protestos.”

1161

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, 2. ed., tomo IX, art. 725, item 1, p. 182.

1162

“Ementa: Tributário – Imposto sobre importação – Auto de infração – Avaria – Defasagem no peso da mercadoria importada – Caso fortuito no trajeto – Prova inequívoca – Homologação judicial de ratificação de protesto marítimo – Inexistência de responsabilidade do transportador. 1. Ausência de comprovação acerca da correspondência do peso total da mercadoria descrita nas D.I.s (Declarações de Importação) com o peso conjunto das sacas de arroz efetivamente internalizadas por meio das três operações de importação ensejadoras das autuações. 2. Consoante o disposto no artigo 480, do Decreto 91.030/85, antigo Regulamento Aduaneiro, o legislador eximiu de responsabilidade o transportador que, mediante “protesto formado a bordo de navio ou de aeronave” e “ratificado pela autoridade judiciária competente” materializar prova de caso fortuito ou força maior. 3. Demonstração, por meio de Processos de Homologação Judicial de Ratificação de Protesto Marítimo, que os navios utilizados para o transporte das mercadorias importadas foram surpreendidos, em seu percurso, por incidentes de ordem natural decorrentes de mau tempo enfrentado em alto mar. 4. Eventuais perdas decorrentes do entrechoque das sacas de arroz nos porões dos navios nenhuma responsabilidade poderiam

acarretar à empresa transportadora frente à Administração Aduaneira. 5. Ausência de amparo ao procedimento de constituição do crédito tributário sobre a importação de mercadorias cuja internalização, a despeito de declarada e despachada, deixa de ocorrer por circunstâncias alheias à vontade do importador. 6. “Ex vi” do artigo 3.º do Código Tributário Nacional, tributo não tem natureza sancionatória de ato ilícito”. (TRF-3, 6.ª Turma, AC 97459 SP 93.03.097459-0, rel. Des. Federal Mairan Maia, DJ 25.04.2007).

1163

“Art. 505 do CCom. “Todos os processos testemunháveis e protestos formados a bordo, tendentes a comprovar sinistros, avarias ou quaisquer perdas, devem ser ratificados com juramento do capitão perante a autoridade competente do primeiro lugar onde chegar; a qual deverá interrogar o mesmo capitão, oficiais, gente de equipagem (art. 545, 7) e passageiros sobre a veracidade dos fatos e suas circunstâncias, tendo presente o Diário da Navegação se houver sido salvo”.

1164

Carla Adriana Comitre Gibertoni. *Teoria e prática do Direito Marítimo*, 2. ed., item VII, p. 262.

1165

Jorge Americano. *Comentários ao Código de Processo Civil do Brasil*, v. 3, art. 725, p. 143.

1166

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, 2. ed., tomo IX, art. 727, item 1, p. 185.

1167

Jorge Americano. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 3, art. 727, p. 146.

1168

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, 2. ed., tomo IX, Cap. II, item 2, p. 181.

1169

Lei 2.180/1954: “Art. 1.º O Tribunal Marítimo, com jurisdição em todo o território nacional, órgão, autônomo, auxiliar do Poder Judiciário, vinculado ao Ministério da Marinha no que se refere ao provimento de pessoal militar e de recursos orçamentários para pessoal e material destinados ao seu funcionamento, tem como atribuições julgar os acidentes e fatos da navegação marítima, fluvial e lacustre e as questões relacionadas com tal atividade, especificadas nesta Lei.” (Redação dada pela Lei 5.056/1966).

1170

“Entendimento jurisprudencial confirmado pelo julgado: CComp. Protesto Marítimo. Ratificação. Matéria regida pelo ordenamento jurídico pátrio. Direito comercial. Jurisdição Voluntária. Ausência de interesse de ente Federal. A ação de ratificação de protesto marítimo, ainda que guarde certa correlação com as hipóteses previstas nos incs. III e IX do artigo 109 da Constituição da República, determinantes da competência da Justiça Federal, trata

de feito de natureza não contenciosa, onde não se estabeleceu relação jurídica na qual figurassem os entes federais com prerrogativa de foro. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo suscitado” (STJ, Corte Especial, CC 59.018/PE, rel. Min. Castro Filho, *DJ* 19.10.2006).

1171

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, 2. ed., tomo IX, art. 727, item 1, p. 185. Jorge Americano. *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 3, art. 727, p. 145.

1172

Nelson Cavalcante e Silva Filho. O projeto do novo Código de Processo Civil e o Direito Marítimo. *Revista de Processo*, n. 203, item 3, p. 181-206.

1173

Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil*, art. 767, item 3, p. 1612.

1174

O protesto ou processo testemunhável formado a bordo declarará os motivos da determinação do capitão, conterà relatório circunstanciado do sinistro e referirá, em resumo, a derrota até o ponto do mesmo sinistro, declarando a altura em que ocorreu.

1175

Essa era a disposição do art. 756 do CPC/1939 c/c art. 1218, inc. XI, do CPC/1973.

1176

TJSP, Ap 1015559-55.2014.8.26.0562, 24.^a Câmara de Direito Privado, j. 03.08.2017, rel. Walter Rocha Barone.

1177

Ementa: Comercial e civil. Transporte marítimo. Extravio de mercadoria. Responsabilidade. Reembolso de importância despendida a título de indenização. (...) durante o transporte, formulou protesto marítimo, que foi devidamente ratificado, com o que provou que a fúria do mar arrancou do convés do navio aquela mercadoria, inclusive os volumes cobertos pelo conhecimento 51 – Antuérpia – Santos. Assim, se a autora pagou mal a sua segurada, ficou afetado o direito de sub-rogação. (TFR, 3.^a Turma Cível. ApCiv 45940, rel. Min. Lauro Franco Leitão, j. 24.09.1981).

1178

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, 2. ed., tomo IX, art. 727, item 2, p. 185.

1179

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*, art. 767, item 2, p. 733.

1180

Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil*, art. 767, item 3, p. 1613.

1181

Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil*, art. 767, item 3, p. 1612.

1182

Ver o Decreto 87.648/1980, art. 359, que obriga “os documentos não escritos em português só serão recebidos acompanhados da tradução feita por tradutor público juramentado.”

1183

Art. 728. Feita a notificação dos interessados, o juiz, nomeando curador aos ausentes, procederá na forma do art. 685.

1184

Ver: Jefferson Carús Guedes. *O princípio da oralidade* : procedimento por audiências no Direito Processual Civil brasileiro, item 5.1, p. 91-95.

1185

A distribuição do ônus da prova nos procedimentos de jurisdição voluntária se concentra sobre o autor, diante da inexistência de partes em seu sentido próprio e da inexistência, na maior parte destas modalidades, de uma contradição clara e ostensiva entre contendores.

1186

TJSP, Ap 1015559-55.2014.8.26.0562, 24.ª Câmara de Direito Privado, j. 03.08.2017, rel. Walter Rocha Barone. Nesse caso disputam a responsabilidade regressiva a empresa seguradora contra as transportadoras que teriam dado causa aos danos da carga.

1187

O curador para os atos do processo não deve se confundir como curador dos bens do ausente, escolhido entre curadores judiciais ou pelo juiz entre pessoas capazes de preencher requisitos essenciais ao gestor, como a experiência, idoneidade e tino para a atividade de administração patrimonial ou sobre profissionais com habilitação profissional correspondente, como administrador, contador, advogado, engenheiro, gestor mobiliário etc., com funções extraprocessuais e processuais (art. 741).

1188

Nelson Cavalcante e Silva Filho. O projeto do novo Código de Processo Civil e o Direito Marítimo. *Revista de Processo*, n. 203, item 3, p. 181-206.

1189

Ementa: Ratificação de Protesto Marítimo. Direito Marítimo. Jurisdição voluntária. (...). Defensoria Pública que entendeu não poder atuar como Curador de Ausentes. Provimento do Recurso. (TJRJ. 13.^a Câmara Cível. AI 4775-44.2009.8.19.0000 (2009.002.09547). rel. Des. Sirley Abreu Biondi. j. 12.08.2009).

1190

A Constituição Federal estabelece no art. 5.^o que “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (inc. LXXIV).

1191

Art. 9.^o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I – à tutela provisória de urgência; II – às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incs. II e III; III – à decisão prevista no art. 701.

1192

Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil*, art. 769, itens 2 e 3, p. 1614.

1193

Art. 729. Finda a inquirição e conclusos os autos, o juiz, por sentença, ratificará o protesto, mandando dar instrumento à parte.

1194

No CPC/1973 havia duas formas de tratamento dos autos ao final dos processos probatórios preventivos ou preparatórios: no procedimento ‘cautelar’ de antecipação de provas (arts. 846-851) prevê-se que os autos “permanecerão em cartório”, permitindo-se aos interessados pedirem dos mesmos as certidões que desejarem; nos protestos, notificações e interpelações (arts. 867-873) prevê-se que “sejam os autos entregues à parte, independentemente de traslado” (art. 872).

1195

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*, art. 770, item 1, p. 734.

1196

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, 2. ed., tomo IX, art. 727, item 2, p. 185.

1198

Os juizados especiais são compostos por sistema baseado em três leis: Juizados Especiais Cíveis e Criminais (Lei 9.099/1995), Juizados Especiais Federais (Lei 10.259/2001), Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009). Os Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública; apenas a Lei 9.099/1995 prevê no art. 38 que “A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório”.

1199

O CPC/1973, nesta parte, art. 485, inc. VIII, causava certa confusão; a nova redação do dispositivo que trata da ação rescisória suprime o inciso que proporcionava longos debates sobre a anulabilidade das sentenças que não transitam ou rescindibilidade das sentenças que transitam em julgado e a distinção entre sentenças ‘homologatórias’ e ‘meramente homologatórias’. Ver: Ronaldo Cramer. Da ação rescisória (arts. 966-975), *Comentários ao novo Código de Processo Civil*, art. 966, item 5, p. 1400. Antonio Carlos Marcato. *Procedimentos especiais*, 15. ed., item 4, p. 10, identifica apenas a coisa julgada formal.

1200

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, com sua peculiar capacidade analítica, distinguia na redação do CPC/1939 os autos do instrumento, quando no art. 729 mandada “dar instrumento à parte”, que não se confundia com os autos inteiros. Ver: Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, 2. ed., tomo IX, art. 727, item 1, p. 186.

1201

Assim, conforme decisão de 1.º grau da Justiça de Pernambuco: “Cumpridas as formalidades previstas em lei, homologo por sentença, com fundamento no art. 729 do CPC de 1939 c.c. art. 1.218, inc. VIII, do CPC de 1973 (...) para que tenha os efeitos legais. Custas satisfeitas. Sem honorários. Entreguem-se os autos ao Requerente, independentemente de traslado, com baixa na distribuição. P. R. I.” (TJPE. Ipojuca (PE). Vara da Fazenda Pública. Processo 0003148-90.2015.8.17.0730, Juíza Ildete Veríssimo de Lima).

1202

Dec.-Lei 116, de 25.01.1967. Art. 8.º Prescrevem ao fim de um ano, contado da data do término da descarga do navio transportador, as ações por extravio de carga, bem como as ações por falta de conteúdo, diminuição, perdas e avarias ou danos à carga.

745

Carlos Dias Motta. *Direito matrimonial e seus princípios jurídicos*, 2. ed., item n. 11.2.4, p. 395.

839

Idem, *ibidem*.

949

Everaldo Augusto Cambler; Wanderlei de Paula Barreto; Marcelo Navarro Ribeiro Dantas; Marcelo Terra. *Comentários ao Código Civil Brasileiro – Parte Geral*, art. 24, item n.2, p. 234.

963

Everaldo Augusto Cambler; Wanderlei de Paula Barreto; Marcelo Navarro Ribeiro Dantas; Marcelo Terra. *Comentários ao Código Civil Brasileiro – Parte Geral*, art. 28, item n.1, p. 250.

964

Everaldo Augusto Cambler; Wanderlei de Paula Barreto; Marcelo Navarro Ribeiro Dantas; Marcelo Terra. *Comentários ao Código Civil Brasileiro – Parte Geral*, art. 37, item n. 2, p. 282.

1081

Idem, *ibidem*.

1197

Entendimento jurisprudencial de que a falta de protesto formal é suprida por outros meios: Ementa “Responsabilidade Civil. Transporte Marítimo Mercadoria Avariada. Falta de Protesto (art. 756 do CPC) suprível por outros meios. Carência afastada (...)”. (1.º TASP, 3.ª Câmara, Ap 287.422, 81/6).

© desta edição [2018]

Referências Bibliográficas

- ABDO, Helena Najjar. *O abuso de processo*. São Paulo: Ed. RT, 2007.
- ABREU, Célia Barbosa. *Curatela & interdição civil*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.
- ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Niceto. Eficacia de las providencias de la jurisdicción voluntaria. *Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México*, vol. 15, n. 45. México, 1962.
- _____. *Proceso, autocomposición y autodefensa*. 2. ed. México: UNAM, 1970.
- ALDEA MOSCOSO, Rodolfo Alejandro. *De la autocomposición: una contribución al estudio de la solución de los conflictos jurídicos*. Santiago de Chile: Jurídica de Chile, 1989.
- ALLORIO, Enrico. Ensayo Polémico Sobre la “Jurisdicción Voluntaria”. *Problemas de Derecho Procesal*, vol. 2, t. 2. Trad. Santiago Sentis Melendo. Buenos Aires: EJE, 1963.
- ALMEIDA, Fernando Henrique Mendes de. Tipicidade e atipicidade nos atos administrativos. *Revista da Faculdade de Direito*, vol. 60, p. 165-171. São Paulo: USP, 1965.
- ALVES, Cleber Francisco. *A justiça para todos: assistência judiciária gratuita nos Estados Unidos, França e Brasil*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.
- ALVES, Rogério Pacheco. A transação penal como ato da denominada jurisdição voluntária. *Revista da EMERJ*, vol. 4, n. 13. Rio de Janeiro: EMERJ, 2001.
- ALVIM NETTO, José Manoel de Arruda. *Direito processual civil – Teoria geral do processo de conhecimento*. São Paulo: Ed. RT, 1972. vol. II.
- _____. *Manual de direito processual civil: parte geral*. 7. ed. São Paulo: Ed. RT, 2000. vol. 1.
- _____. Regime jurídico da notificação extrajudicial. *Revista de Processo*, n. 3. São Paulo: Ed. RT, jul.-set. 1976.
- ALVIM WAMBIER, Teresa Arruda; MEDINA, José Miguel Garcia. *O dogma da coisa julgada: hipóteses de relativização*. São Paulo: Ed. RT, 2003.
- ALVIM, Thereza. *O direito processual de estar em juízo*. São Paulo: Ed. RT, 1996.
- AMERICANO, Jorge. *Comentários ao Código de Processo Civil do Brasil*. 3. Rio de Janeiro: Forense, 1942. vol. 3.
- AMORIM, Sebastião Luiz; OLIVEIRA, Euclides B. de. Aspectos da herança jacente e da herança vacante. *Revista de Direito Civil*, n. 38. São Paulo: Ed. RT, out.-dez. 1986; *Doutrinas Essenciais Família e Sucessões*, vol. 6, p. 263-270. São Paulo: Ed. RT, 2011.
- ARAUJO, Fabio Caldas de. *Usucapião*. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2005.
- _____. *Curso de Processo Civil: procedimentos especiais*. São Paulo: Malheiros, 2018. t. III.

- ASSIS, Araken de. O procedimento de dúvida e o princípio de adstrição do juiz ao pedido da parte. *Revista Jurídica*, a. XXXI, vol. 107, set.-out. 1984.
- _____. *Processo civil brasileiro. Parte Especial: procedimento comum (demanda à coisa julgada)*. São Paulo: Ed. RT, 2016. vol. III.
- _____. *Processo civil brasileiro. Parte Geral: fundamentos e distribuição de conflitos*. São Paulo: Ed. RT, 2016. vol. I.
- _____. *Processo civil brasileiro. Parte Geral: institutos fundamentais*. São Paulo: Ed. RT, 2016. vol. II. t. I e II.
- BAPTISTA DA SILVA, Ovídio A. *Do processo cautelar*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999.
- _____; GOMES, Fábio. *Teoria geral do processo civil*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2000.
- BARBI, Celso Agrícola. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 8. ed. (arts. 1.º-153). Rio de Janeiro: Forense, 1993. vol. I.
- BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A função social do processo civil moderno e o papel do juiz e das partes na direção e na instrução do processo. *Revista de Processo*, n. 37. São Paulo: Ed. RT, 1985.
- _____. *Comentários ao CPC*. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. vol. 5.
- _____. Julgamento e ônus da prova. *Temas de Direito Processual* (segunda série). São Paulo: Saraiva, 1980.
- _____. La igualdad de las partes en el proceso civil. *Revista de Processo*, n. 44. São Paulo: Ed. RT, 1986.
- _____. *O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento*. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012.
- BARRA, Washington Epaminondas Medeiros. Alimentos entre cônjuges e ex-cônjuges. A intervenção do Ministério Público. *Revista dos Tribunais* (online). vol. 5. p. 1109-1120. São Paulo: Ed. RT, ago. 2011.
- _____. Alimentos entre cônjuges e ex-cônjuges. A intervenção do Ministério Público. *Revista dos Tribunais* (online). vol. 5. item 4. p. 1109-1120. São Paulo: Ed. RT, ago. 2011.
- BEDAQUE, José Roberto dos Santos. *Direito e processo: influência do direito material sobre o processo*. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1997.
- _____. *Efetividade do processo e técnica processual*. São Paulo: Malheiros Editores, 2006.
- _____. Ministério Público no processo civil: algumas questões polêmicas. *Revista de Processo*, n. 61, p. 36-56, jan.-mar. 1991.
- _____. O Ministério Público e a jurisdição voluntária. *Justitia*, vol. 147, p. 49-59, 1989.
- _____. *Poderes instrutórios do juiz*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2001.
- BEVILÁQUA, Clóvis. *Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado*. Edição Histórica. 5. tir. Rio de Janeiro: Rio, 1976/1980. vol. 1.
- _____. *Direito de família*. 7. ed. Rio de Janeiro: Rio, 1976.
- BOMFIM MARINS, Victor A. A. *Tutela cautelar: teoria geral e poder geral de cautela*. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2002.

BORGES, Marcos Afonso. Jurisdição voluntária. *Revista de Processo*, vol. 11-12, p. 210-219. São Paulo: Ed. RT, jul.-dez. 1978.

_____. Jurisdição voluntária. *Revista Brasileira de Direito Processual*, vol. 18, a. V, Rio de Janeiro: Forense, 2. trim. 1979.

_____. Jurisdição. *Revista da Faculdade de Direito da UFG*. Goiânia: UFG, jan.-dez. 1979.

BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Em busca de um conceito fugidio: o ativismo judicial. In: FELLET, André; GIOTTI DE PAULA, Daniel; NOVELINO, Marcelo (org.). *As novas faces do ativismo judicial*. Salvador: JusPodivm, 2011.

BRULLIARD, M. Germain. L'évolution de la notion de juridiction dite "gracieuse" ou "volontaire" et de celle de juridiction d'après les récents travaux de la doctrine italienne. *Revue Internationale de Droit Comparé*. vol. 9, n. 1, janvier-mars, 1957.

BRUSCHI, *Apelação civil: teoria geral, procedimento e saneamento de vícios pelo tribunal*. São Paulo: Saraiva, 2012.

BUZAID, Alfredo. *Anteprojeto de Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1964.

_____. Linhas fundamentais do sistema do Código de Processo Civil brasileiro. In: *Estudos e pareceres de direito processual civil*. São Paulo: Ed. RT, 2002.

BUZZI, Marco Aurélio Gastaldi. *Alimentos transitórios: uma obrigação por tempo certo*. Curitiba: Juruá, 2003.

CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Teoria geral dos procedimentos especiais. In: DE FARIAS, Cristiano Chaves; DIDIER JR., Fredie (coord.). *Procedimentos especiais cíveis, legislação extravagante*. São Paulo: Ed. RT, 2002.

CALMON, Petrônio. *Comentários à Lei de Informatização do Processo Judicial*. Rio de Janeiro: Forense, 2007.

CAMBI, Accácio. Conversão de separação em divórcio, pendente obrigação alimentar. Possibilidade à luz da doutrina moderna. *Revista de Direito Privado* (online), vol. 3, p. 945-948. São Paulo: Ed. RT, ago. 2011.

CAMBLER, Everaldo Augusto; BARRETO, Wanderlei de Paula; DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro; TERRA, Marcelo. *Comentários ao Código Civil Brasileiro – Parte Geral* (arts. 1.º a 103). vol. I. Rio de Janeiro: Forense/FADISP, 2005.

CAMPOS, João Vicente. *Dos sinistros marítimos*. Rio de Janeiro: Forense, 1961.

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryan. *El aceso a la justicia: la tendencia en el movimiento mundial para hacer efectivos los derechos*. Trad. Mónica Miranda. Ciudad del México: Fondo de Cultura Económica, 1996.

CARBRAL, Antonio do Passo. Imparcialidade e imparcialidade: por uma teoria sobre repartição e incompatibilidade de funções nos processos civil e penal. In: DIDIER JR., Fredie; JORDÃO, Eduardo Ferreira (org.). *Teoria do processo: panorama doutrinário mundial*. Salvador: JusPodivm, 2008.

CARNEIRO, Athos Gusmão. *Jurisdição e competência*. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.

CARNELUTTI, Francesco. *Instituciones del derecho procesal*. 2. ed. Trad. Santiago Sentis Melendo. Buenos Aires: EJE, 1973. vol. 1 e 2.

CARVALHO DIAS, Ronaldo Brêtas de. *Responsabilidade do Estado pela função jurisdicional*. Belo

Horizonte: Del Rey, 2004.

CARVALHO, José Orlando Rocha de. Procedimentos previstos na Lei de Registros Públicos. In: DE FARIAS, Cristiano Chaves; DIDIER JR., Fredie (coord.). *Procedimentos especiais cíveis: legislação extravagante*. São Paulo: Saraiva, 2003.

CARVALHO, Luiz Gonzaga de. *Dos insanos mentais: nulidade do negócio jurídico, conflito jurisprudencial*. São Paulo: Juarez de Oliveira Ed., 2005.

CASSETTARI, Christiano. As consequências do processo judicial de modificação do regime de bens no casamento. In: ASSIS, Araken de et al. (coord.). *Direito civil e processo: estudos em homenagem ao professor Arruda Alvim*. São Paulo: Ed. RT, 2008.

_____. *Separação, divórcio e inventário por escritura pública: teoria e prática*. 5. ed. São Paulo: Método, 2012.

CASTRO JÚNIOR, Osvaldo Agripino de. Aspectos introdutórios do direito marítimo. *Revista de Direito Privado*, n. 19, p. 215-242. São Paulo: Ed. RT, jul.-set. 2004.

_____. *Direito marítimo, regulação e desenvolvimento*. Belo Horizonte: Fórum, 2011.

CASTRO FILHO, José Olympio de. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 2. ed. vol. X (arts. 1.103-1220). Rio de Janeiro: Forense, 1980.

_____. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. vol. X (arts. 1.103-1220). Atualizada por José Rubens Costa. Rio de Janeiro: Forense, 2004.

CHIMENTI, Ricardo Cunha. *Teoria e prática dos juizados especiais cíveis* (Lei 9.099/1995 – Parte Geral e Parte Cível – comentada artigo por artigo). 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. *Teoria Geral do Processo*. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2004.

COSTA, Alfredo de Araújo Lopes da. *A administração pública e a ordem jurídica privada (jurisdição voluntária)*. Belo Horizonte: Bernardo Álvares, 1961.

COUTURE, Eduardo J. *Fundamentos del derecho procesal civil*. Buenos Aires: Depalma, 1976.

CRAMER, Ronaldo. Da ação rescisória (arts. 966-975). In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (org.). *Comentários ao novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

CREMONEZE, Paulo Henrique. *Prática de direito marítimo*. São Paulo: Aduaneiras. 2015.

CUENCA, Humberto. *Derecho procesal civil*. 9. ed. Caracas: Ediciones de La Biblioteca, 2005. vol. 1.

CUNHA, José Sebastião Fagundes (coord.). *Código de Processo Civil comentado*. São Paulo: Ed. RT, 2016.

CUNHA, Leonardo Carneiro da. *A Fazenda Pública em juízo*. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

DALL'ALBA, Felipe Camilo. A ampla defesa vista sob o olhar constitucional processual. In: SALMEIRÃO, Antonio Marcos Guerreiro; BOCCHINO, Leslie de Oliveira (org.). *Temas atuais de direito público*. Curitiba: UTFPR, 2007.

DIAS, Daniel Pires Novais. *Negócio fundacional: criação de fundações privada*. Rio de Janeiro/São Paulo: Forense/Método, 2014.

DIAS, Maria Berenice. *Manual de direito das famílias*. 11. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016.

- DIDIER JR., Fredie. *Recurso de terceiro: juízo de admissibilidade*. São Paulo: Ed. RT, 2002.
- _____. *Regras processuais no Código Civil*. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
- _____; CUNHA, Leonardo Carneiro. Ação rescisória e a ação de invalidação de atos processuais previstas no art. 966, § 4.º, do CPC/2015. *Revista de Processo*, vol. 252, p. 231-241, fev. 2016.
3. _____. *Curso de direito processual civil*. 13. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. vol. _____.; FARIAS, Cristiano Chaves de; GUEDES, Jefferson Carús; GAMA, Guilherme Calmon N. da; SLAIBI FILHO, Nagib. *Comentários ao Código Civil brasileiro*. Do Direito de Família. Direito Patrimonial (arts. 1.639 a 1.783). vol. XV. Rio de Janeiro: Forense/FADISP, 2005.
- _____. Editorial 187. Estatuto da Pessoa com Deficiência, Código de Processo Civil de 2015 e Código Civil: uma primeira reflexão. Disponível em: [www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-187]. Acesso em: 19 set. 2016.
- _____. Editorial 23. Coisa julgada material em jurisdição voluntária. O exemplo do pedido de homologação de separação/divórcio/partilha consensual. Lei Federal 11.441/2007. Disponível em: [www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-23]. Acesso em: 19 set. 2016.
- _____. CABRAL, Antonio do Passo; CUNHA, Leonardo Carneiro da. *Por uma nova teoria dos procedimentos especiais: dos procedimentos às técnicas*. Salvador: JusPodivm, 2018.
- DINAMARCO, Cândido Rangel. *A instrumentalidade do processo*. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2005.
- _____. *Fundamentos do processo civil moderno*. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. vol. I e II. Revisão e atualização de Antonio Rulli Neto.
- _____. *Litisconsórcio*. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 1996.
- _____. *Manual das pequenas causas*. São Paulo: Ed. RT, 1986.
- _____. *Manual dos juizados cíveis*. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2001.
- _____.; LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. *Teoria geral do novo processo civil*. São Paulo: Malheiros, 2016.
- FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993. vol. VIII. t. III.
- _____. Justificação teórica dos procedimentos especiais. *Ensaio de direito processual*. Rio de Janeiro: Forense, 2003.
- FADEL, Sergio Sahione. *Código de Processo Civil comentado*. 8. ed. atual. por José Eduardo Carreira Alvim e Luciana Gontijo Carreira Alvim Cabral. Rio de Janeiro: Forense, 2010. vol. I e II.
- FALCÓN Y TELLA, María José. *Equidad, derecho y justicia*. Madrid: Centro de Estudios Ramon Areces, 2005.
- FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. *Direitos reais*. 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.
- _____. O cumprimento de testamento no novo Código de Processo Civil e a possibilidade de adaptação procedimental (cláusula geral negocial) do inventário. *Revista de Direito*, vol. 7, n. 1 (2015). Viçosa: UFV, 2015.

- FAZZALARI, Elio. *Istituzioni di diritto processuale*. 7. ed. Padova: Cedam, 1996.
- _____. *La giurisdizione volontaria, profilo sistematico*. Padova: Cedam, 1953.
- FERRAZ, Cristina. *Jurisdição voluntária no processo civil*. Curitiba: Juruá, 2008.
- _____. Reflexões sobre os novos rumos da jurisdição voluntária. In: DIDIER JR., Fredie; MACÊDO Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre (org.). *Procedimentos especiais, tutela provisória e direito transitório*. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2016.
- FREITAS, José Lebre de. *Introdução ao processo civil: conceito e princípios gerais*. 2. ed. Coimbra: Coimbra, 2009.
- FRONTINI, Paulo Salvador. O Ministério Público no Juizado Espacial das Pequenas Causas. In: WATANABE, Kazuo (coord.). *Juizado especial de pequenas causas (Lei 7.244, de 7 de novembro de 1984)*. São Paulo: Ed. RT, 1984.
- GAGLIANO, Pablo Stolze. Direitos da(o) amante – na teoria e na prática (dos Tribunais). *Revista IOB de Direito de Família*, vol. 9, n. 49, p. 51-61. São Paulo, ago. 2008.
- _____; PAMPLONA FILHO, Rodolf. *Novo curso de direito civil*. Parte Geral. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. vol. I.
- GAJARDONI, Fernando da Fonseca. *Flexibilização procedimental: um novo enfoque para o estudo do procedimento em matéria processual*. São Paulo: Atlas, 2008.
- GALENO, Lacerda; ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 1991. 2. ed. vol. VIII. t. II (arts. 813-889).
- GALENO, Lacerda. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993. vol. VIII, t. I (arts. 796-812).
- GARAIGE NETO, Zaiden. *Ação rescisória: o lento caminhar do direito escrito, comparado às rápidas transformações das sociedades contemporâneas*. São Paulo: Ed. RT, 2009.
- GIANESINI, Rita. *Revelia no processo civil brasileiro*. São Paulo: Ed. RT, 1977.
- GIBERTONI, Carla Adriana Comitre. *Teoria e prática do direito marítimo*. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1998.
- GIORGIS, José Carlos Teixeira. *A lide como categoria comum do processo*. Porto Alegre: LEJUR, 1991.
- _____. *Direito de família contemporâneo*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.
- GONZALEZ GARCIA, Jesús María. *La proliferación de procesos civile*. Madrid: McGraw Hill, 1996.
- GRECO, Leonardo. *Jurisdição voluntária moderna*. São Paulo: Dialética, 2003.
- GRINOVER, Ada Pellegrini. Deformalização do processo e deformalização das controvérsias. In: _____. *Novas tendências do direito processual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1990.
- GUEDES, Jefferson Carús. *Comentários ao novo Código de Processo Civil* (arts. 674-686). Rio de Janeiro: Forense, 2015. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (org.).
- _____. Direito processual de grupos sociais no Brasil: uma versão revista e atualizada das primeiras linhas. *Revista Brasileira de Políticas Públicas*, vol. 5, p. 553-587, número especial, 2015.

_____. Direito processual social atual: entre o ativismo judicial e o garantismo processual. *Revista Brasileira de Direito Processual – RBDPro*, ano 21, n. 82, p. 45-79, Belo Horizonte: abr.-jun., 2013.

_____. Direito processual social no Brasil: as primeiras linhas. *Revista de Processo*, n. 142. São Paulo: Ed. RT, 2006.

_____. *Igualdade e desigualdade*: introdução conceitual, normativa e histórica dos princípios. São Paulo: Ed. RT, 2014.

_____. Linhas mínimas para a descrição de uma teoria dos procedimentos cautelares. In: ALVIM, Arruda e ARRUDA ALVIM, Eduardo (coord.). *Inovações sobre direito processual civil*: tutelas de urgência. Rio de Janeiro: Forense, 2003.

_____. *O princípio da oralidade*: procedimento por audiências no direito processual civil brasileiro. São Paulo: Ed. RT, 2003.

_____. Procedimento por audiências e princípio da oralidade nos juizados especiais federais. In: GUEDES, Jefferson Carús (coord.). *Juizados Especiais Federais*. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

_____. Transigibilidade de interesses públicos: prevenção e abreviação de demandas da Fazenda Pública. In: GUEDES, Jefferson Carús; SOUZA, Luciane Moessa de (org.). *Advocacia de Estado*: questões institucionais para a construção de um Estado de Justiça. Estudos em homenagem a Diogo de Figueiredo Moreira Neto e José Antonio Dias Toffoli. Belo Horizonte: Fórum, 2009.

_____; DIDIER JR., Fredie; FARIAS, Cristiano Chaves de; GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da; SALIB FILHO, Nagib. *Comentários ao Código Civil brasileiro - Do Direito de Família - Direito Patrimonial* (arts. 1.639 a 1.783). vol. XV. Rio de Janeiro: Forense/FADISP, 2005.

_____; FREIRE, Rodrigo da Cunha Lima. Juizados Especiais Cíveis Federais. In: FARIAS, Cristiano Chaves de; DIDIER JR., Fredie (coord.). *Procedimentos especiais cíveis*: legislação extravagante. São Paulo: Saraiva, 2003.

_____; HAUSCHILD, Mauro Luciano; COSTA, Alexandre Bernardino; SILVA, Adriana Medeiros; SILVA, Beatriz Cruz da; ROCHA, Eduardo; MEDEIROS, Jorge Luiz Ribeiro de; TEMPERANI, Priscila Bezerra. *Nos Limites da história*: a construção da Advocacia-Geral da União. Brasília: UNIP/UNAFE, 2009.

_____. Jurisdição Voluntária no CPC/2015 como meio de resolução de ‘controvérsias’ com a Administração Pública. *Revista Brasileira de Políticas Públicas* (online), vol. 7, n. 1. Brasília, 2017.

_____. *Procedimentos especiais a partir do CPC 2015*: a resignificação do confronto entre as técnicas processuais diferenciadas e o atual procedimento comum (flexível e fundível). Prelo.

GUIMARÃES, Luiz. Machado. Homologação de sentença estrangeira. *Estudos de direito processual civil*. Rio de Janeiro/São Paulo: Jurídica/Universitária, 1969.

HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Famílias paralelas. *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo*, vol. 108, p. 199-219. São Paulo, jan.-dez. 2013.

JAUERNIG, Othmar. Problemas de qualificação da jurisdição voluntária: judicatura – administração: ato estatal – negócio jurídico privado. *Revista de Processo*, ano X, n. 39, jul.-set. 1985.

JORGE, Flavio Chein. *Apelação cível*: teoria geral e admissibilidade, itens 5.1-5.2, p. 79-208. São Paulo: Ed. RT, 1999.

LIEBLE, Stefan. *Proceso civil alemán*. Trad. Rodolfo Witthaus. Medellín: Biblioteca Jurídica Diké

e Konrad-Adenauer-Stiftung, 1999.

LIEBMAN, Enrico Tullio. *Manuale di diritto processuale civile*. Milano: Giuffrè, 1984. vol. 1.

LIMA, Alcides de Mendonça. Clovis Beviláqua, o processualista. *Revista de Processo*, n. 23. jul-set. São Paulo: Ed. RT, 1981.

_____. *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 1982. vol. XII (arts. 1.103-1.210).

_____. Efeitos da apelação na jurisdição voluntária. *Revista da AJURIS*, n. 29, ano X, nov. 1983.

LIMA, Fernando Antônio Negreiros. *Intervenção do Ministério Público no processo civil brasileiro como custos legis*. São Paulo: Método, 2007.

LOPES, João Batista. Os poderes do juiz no aprimoramento da prestação jurisdicional. *Revista de Processo*, vol. 9, n. 35, p. 24-67. São Paulo: jul.-set. 1984.

LOVATO, Luiz Gustavo. O uso do regime de bens do casamento para fraudar terceiros credores: “o cônjuge laranja”. In: MADALENO, R. (coord.) *Ações de direito de família*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006.

LUCENA, João Paulo. *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2000. vol. 15.

_____. *Natureza jurídica da jurisdição voluntária*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996.

MACÊDO, Lucas Buril. Questões Gerais sobre a Jurisdição Voluntária no CPC/2015. In: DIDIER JR., Fredie; MACÊDO Lucas Buril de, PEIXOTO, Ravi e FREIRE, Alexandre (org.). *Procedimentos especiais, tutela provisória e direito transitório*. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2016.

MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Jurisdição voluntária. *Revista de Processo*, a. X, n. 37, jan.-mar. de 1985

MADALENO, Rolf. A união (ins)estável (relações paralelas). Disponível em: <http://www.rolfmadaleno.com.br/novosite/conteudo.php?id=323>. Acesso em: 13 ago. 2016.

_____. *Curso de direito de família*. Rio de Janeiro: Forense, 2008.

MAGRI, Berenice Soubhie Nogueira. *Ação anulatória*: art. 486 do CPC. São Paulo: Ed. RT, 1999.

MAIA JUNIOR, Mairan Gonçalves. *A família e a questão patrimonial*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2015.

MAIA, Daniel Netto. Homologação de acordo extrajudicial. *Revista Jus Navigandi*. Teresina, ano 18, n. 3733, 20 set. 2013. Disponível em: [<http://jus.com.br/artigos/25347>]. Acesso em: 4 nov. 2015.

MALUF, Carlos Alberto Dabus. *Das cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade*. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1986.

MARCATO, Antonio Carlos. *Procedimentos especiais*. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2013.

MARINONI, Luiz Guilherme. A jurisdição no Estado Contemporâneo. In: MARINONI, Luiz Guilherme (coord.). *Estudos de direito processual civil – Uma homenagem ao Professor Egas Moniz de Aragão*. São Paulo: Ed. RT, 2006.

_____. *Novas linhas do processo civil: o acesso à Justiça e os institutos fundamentais do direito processual*. São Paulo: Ed. RT, 1993.

- _____. *Técnica processual e tutela dos direitos*. São Paulo. Ed. RT, 2004.
- _____. *Tutela inibitória (individual e coletiva)*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2000.
- _____; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. *O novo processo civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- _____; _____. *Novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- _____; _____. *Curso de processo civil*. São Paulo: Ed. RT, 2007. vol. 3.
- _____; _____. *Curso de processo civil*. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Ed. RT, 2006. vol 1.
- MARQUES, José Frederico. *Ensaio sobre a jurisdição voluntária*. 1. ed. revista e atualizada por Ovídio Rocha Barros Sandoval. Campinas: Millennium, 2000.
- _____. *Manual de direito processual civil*. Ed. atualizada. Campinas: Bookseller, 1997.
- MAZZILLI, Hugo Nigro. O Ministério Público e a jurisdição voluntária. *Revista de Processo*, ano XII, n. 48, out.-dez. 1987
- MEDEIROS, Maria Bernardete de Moraes. *Interdição civil: proteção ou exclusão*. São Paulo: Cortez, 2007.
- MEDEIROS, Maria Lúcia M. C. de. *A revelia sob o aspecto da instrumentalidade*. São Paulo: Ed. RT, 2003.
- MEDINA, José Miguel Garcia. *Código de Processo Civil comentado: com remissões e notas comparativas ao projeto do novo CPC*. São Paulo: Ed. RT, 2011.
- MELLO, Marcos Bernardes de. *Teoria do fato jurídico: plano da existência*. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
- MENDONÇA, Carlos. *O essencial sobre alvará judicial*. São Paulo: Servanda, 2004.
- MESQUITA, José Ignácio Botelho de. O juizado especial em face das garantias constitucionais. Disponível em: [www.abdpc.org.br]. Acesso em: 3 nov. 2015.
- MICHELI, Gian Antonio. Per una revisione della nozione di giurisdizione volontaria. *Rivista di Diritto Processuale*, vol. 2, n. 1, p. 18-45, 1947.
- MITIDIERO, Daniel Francisco. *Colaboração no processo civil: pressupostos sociais, lógicos e éticos*. São Paulo: Ed. RT, 2009.
- _____. *Elementos para uma teoria contemporânea do processo civil brasileiro*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.
- _____. *Processo civil e Estado constitucional*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.
- _____. *Elementos para uma teoria contemporânea do processo civil brasileiro*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.
- MONTERO AROCA, Juan. El proceso civil llamado “social” como instrumento de “justicia” autoritária. In: MONTERO AROCA, Juan (coord.). *Proceso civil e ideología: un prefacio, una sentencia, dos cartas y quince ensayos*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2006.
- MOTTA, Carlos Dias. *Direito matrimonial e seus princípios jurídicos*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2009.

MUCILLO, Daniela. A modificação de cláusula na separação extrajudicial e na separação judicial consensual. *Separação, divórcio, partilhas e inventários extrajudiciais*, 2. ed. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2010.

MUNNO, Eleonora. *L'intervento di volontaria giurisdizione del giudice nelle società di capitali*. Roma: LIUSS - Libera Università Internazionale Degli Studi Sociali Guido Carli (Dottorato de Ricerca), 2014.

MUSSE, Luciana Barbosa. *Novos sujeitos de direito: as pessoas com transtorno mental na visão da bioética e do biodireito*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. *Curso de direito do trabalho*. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

NEGRÃO, Thetonio; GOUVÊA, José Roberto F.; BONDIOLI, Luis Guilherme A.; FONSECA, João Francisco N. da. *Código de processo civil e legislação processual civil em vigor*. 46. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

NERY JR., Nelson. *Princípios do processo na Constituição Federal*. 12. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016.

_____. Intervenção do Ministério Público nos procedimentos especiais de jurisdição voluntária. *Revista de Processo*, vol. 46, p. 7-28. São Paulo: Ed. RT, abr-jun, 1987.

_____. *Princípios do processo civil na Constituição Federal*. 5. e 12. ed. São Paulo: Ed. RT, 1999 e 2016.

_____; NERY, Rosa Maria de Andrade. *Código de processo civil comentado*. 10. ed. São Paulo: Ed. RT, 2007.

_____; _____. *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015.

NEVES, Celso. Classificação das ações. *Revista da Faculdade de Direito UFPR*, vol. 18. Curitiba: UFPR, 1976.

_____. *Estrutura fundamental do processo: tutela jurídica processual, ação, processo e procedimento*. Rio de Janeiro: Forense, 1995.

NEVES, Daniel Amorim A.; RAMOS, Glauco Gumerato; FREIRE, Rodrigo da Cunha Lima; MAZZEI, Rodrigo Reis. *Reforma do CPC: Leis 11.187/2005, 11.232/2005, 11.276/2006*. São Paulo: Ed. RT, 2006.

OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. *A tutela de urgência no Direito de Família*. São Paulo: Saraiva, 1988.

OLIVEIRA, Euclides B. de; AMORIM, Sebastião Luiz. Destinação da herança vacante. *Revista dos Tribunais*, 689, p. 84-92. São Paulo: Ed. RT, mar. 1993; *Doutrinas Essenciais Família e Sucessões*, vol. 6, p. 287-300. São Paulo: Ed. RT, ago. 2011.

OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de e MUNIZ, Francisco José Ferreira. *Direito de Família: direito matrimonial*. 3. ed. Curitiba: Juruá, 1999.

OLIVEIRA, Gleydson Kleber de Oliveira. *Apelação no direito processual civil brasileiro*, itens 3.1-3.7, p. 92-169. São Paulo: Ed. RT, 2009.

OLIVEIRA JUNIOR, Zulmar Duarte de; STRECK, Lenio Luiz; NUNES, Dierle; CUNHA, Leonardo (org.). *Comentários do Código de Processo Civil (de acordo com a Lei 13.256/2016)*. São Paulo: Saraiva, 2016.

ORIONE NETO, Luiz. Teoria geral dos procedimentos especiais. In: FARIAS, Cristiano Chaves de; DIDIER JR., Fredie. (coord.). *Procedimentos especiais cíveis, legislação extravagante*. São Paulo: Ed. RT, 2002.

PÁDUA, Thiago Aguiar. A expressão “ativismo judicial”, como um “cliché constitucional”, deve ser abandonada: uma análise crítica. *Revista Brasileira de Políticas Públicas*, vol. 5, número especial, p. 135-168, 2015.

PAES, José Eduardo Sabo. *Fundações, associações e entidades de interesse social*. 7. ed. São Paulo: Forense, 2010.

PASSOS, J. J. Calmon de. *Da jurisdição*. Salvador: Livraria Progresso, 1957.

PELUSO, Cezar; GODOY, Claudio Luiz Bueno de; LOUREIRO, Francisco Eduardo; BDINE JR., Hamid Charaf; AMORIM, José Roberto Neves; BARBOSA FILHO, Marcelo Fortes; ANTONINI, Mauro; CARVALHO FILHO, Milton Paulo de; ROSENVALD, Nelson; DUARTE, Nestor. *Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência* (Cezar Peluso (coord.)). 4. ed. São Paulo: Manole, 2010.

PENTEADO, Luciano de Camargo. *Direito das coisas*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012.

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. *Divórcio: teoria e prática*. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora GZ, 2010.

PFANDER, James E.; BIRK, Daniel. Article III Judicial Power, the Adverse-Party requirement, and Non-Contentious Jurisdiction. *The Yale Law Journal, Forthcoming: Northwestern Public Law Research Paper*, n. 14-13. (Abril 13, 2014). Disponível em: [http://ssrn.com/abstract="2424511"]. Acesso em: 19 set. 2016.

PICARDI, Nicola. *Manuale del Processo Civile*. Milano: Giuffrè, 2006.

PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. *Direito processual civil contemporâneo: processo de conhecimento, cautelar, execução e procedimentos especiais*. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. vol. II.

_____. *Direito processual civil contemporâneo: processo de conhecimento, cautelar, execução e procedimentos especiais*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. vol. II.

PIZZOL, Patricia Miranda. *A competência no processo civil*. São Paulo: Ed. RT, 2003.

_____. *A competência no processo civil*. São Paulo: Ed. RT, 2003.

PODETTI, J. Ramiro. *Teoría estructural da ciencia del proceso civil, teoría y técnica del proceso civil y teoría estructural de la ciencia del proceso civil*. Buenos Aires: EDIAR, 1963.

PONTES DE MIRANDA, F. C. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1959 e 1977. t. IX e XVI.

_____. *Tratado da ação rescisória das sentenças e de outras decisões*. 1. ed. atualizada. Campinas: Bookseller, 1998.

_____; HIRONACA, Giselda; LÔBO, Paulo. *Tratado de Direito Privado. Direito das Sucessões. Sucessão Testamentária*. São Paulo: Ed. RT, 2012. t. LVI.

_____; _____. *Tratado de Direito Privado. Direito das Sucessões. Herança e Legados*. São Paulo: Ed. RT, 2012. t. LVII.

_____; _____. *Tratado de Direito Privado. Direito das Sucessões. Disposições Testamentárias*. São Paulo: Ed. RT, 2012. t. LVIII.

_____; _____. *Tratado de Direito Privado. Direito das Sucessões. Testamentos*. São Paulo: Ed. RT, 2012. t. LIX.

_____; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz; GUEDES, Jefferson Carús; QUARCH, Tilman. *Tratado de Direito Privado. Exceções. Exercício dos Direitos. Prescrição*. São Paulo: Ed. RT, 2012. t. VI.

- PORTO, Sergio Gilberto. *Doutrina e prática dos alimentos*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2004.
- _____. Jurisdição voluntária: atividade administrativa ou jurisdicional. *Revista de Estudos Jurídicos*. São Leopoldo: UniSinos, 1983.
- PRATA, Ana. *A tutela constitucional da autonomia privada*. Coimbra: Almedina, 1982.
- PRATA, Edson. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 1978. vol. 7, arts. 1.103-1.220.
- _____. *Jurisdição voluntária*. São Paulo: LEUD, 1979.
- RAMOS, Glauco Gumerato. Ativismo e garantismo no processo civil: apresentação de debate. *Revista Brasileira de Direito Processual*, n. 70. Belo Horizonte: Fórum, 2010.
- _____. Realidade e perspectivas da assistência judiciária aos necessitados no Brasil. *Cadernos Adenauer 3: Acesso à Justiça e cidadania*. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 2000.
- RIZZI, Sérgio. *Ação rescisória*. São Paulo: Ed. RT, 1979.
- ROCHA, Eliana Pires. *Conciliação do direito processual civil*. Dissertação (mimeografada), São Paulo, PUC-SP, 2007.
- RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. A influência do BGB e da doutrina alemã no direito civil brasileiro do século XX. *Revista dos Tribunais*, vol. 938, p. 79-155. São Paulo: Ed. RT, dez. 2013.
- RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski. *Famílias simultâneas: da unidade codificada à pluralidade constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.
- SALES, José Roberto da Cunha. *Tratado da praxe conciliatoria: Theoria e pratica das conciliações e da pequena demanda*. Rio de Janeiro: Nicoláo d'Oliveira & C., 1879.
- SANTOS, Moacyr Amaral. *Primeiras linhas do direito processual civil*. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 1984. vol. 2.
- SANTOS, Uziel Santana dos. *Litígio e lide: uma construção, analítico-distintiva, terminológico-conceptual e empírico-crítica*. Dissertação (mimeografada), Recife, UFPE, 2007.
- SARMENTO, Eduardo Sócrates Castanheira. *A interdição no direito brasileiro*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.
- SCIALOJA, Vittorio. *Procedimento civil romano: ejercicio y defensa de los derechos*. Trad. Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra Redin. Buenos Aires: EJEA, 1954.
- SILVA FILHO, Nelson Cavalcante e. O projeto do Novo Código de Processo Civil e o Direito Marítimo. *Revista de Processo*, n. 203, p. 181-205. São Paulo: Ed. RT, jan. 2012.
- SILVA, Jorge Araken Faria da. *Natureza jurídica da jurisdição voluntária*. Dissertação (mimeografada), São Paulo, USP/Faculdade de Direito, 1989.
- SOARES, Fernando Luso. *O processo penal como jurisdição voluntária: uma introdução crítica ao processo penal*. Coimbra: Almedina, 1981.
- SOUZA, Caroline Angélica Rabêlo de. Simplificação dos procedimentos de jurisdição voluntária: Inexigibilidade de advogado. *Revista do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região*. vol. 19, n. 8. Brasília: TRF 1.ª Região, 2007.
- STRECK, Lenio Luiz. O ativismo, o justo, o legal e a Lesão por Esforço Epistêmico Repetitivo. *Consultor Jurídico* (31 de julho de 2014). Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2014-jul-31/senso-incomum-ativismo-justo-legal-lesao-esforco-epistemico-repetitivo>. Acesso em: 13 ago.

2016.

STRECK, Lenio Luiz; NUNES, Dierle; CUNHA, Leonardo (org.). *Comentários do Código de Processo Civil (de acordo com a Lei 13.256/2016)*. São Paulo: Saraiva, 2016.

TAGLIALEGNA, Aldon. Comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas pelo empregador rural (art. 233 da CF/1988 e art. 10, § 3.º das disposições constitucionais transitórias). *LTr*, vol. 53, n. 6, jun.1989.

TARTUCE, Fernanda. *Processo civil aplicado ao direito de família*. Rio de Janeiro/São Paulo: GEN/Método, 2012.

TESHEINER, José Maria Rosa. *Elementos para uma teoria geral do processo*. São Paulo: Saraiva, 1993.

_____. *Jurisdição voluntária*. Rio de Janeiro: Aide, 1992.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. *Curso de direito processual civil*. 57. ed. São Paulo, Saraiva, 2016. vol. I.

_____. Ainda a polêmica sobre a distinção entre a “jurisdição contenciosa” e a “jurisdição voluntária” espécies de um mesmo gênero ou entidades substancialmente distintas?. *Revista de Processo*, vol. 198/2011, p. 13 – 50, Ago/2011, *Doutrinas Essenciais de Processo Civil*, vol. 2, p. 543 – 579, Out/2011.

_____. *Curso de Direito Processual Civil*, 52. ed. v. II. Rio de Janeiro: forense, 2018.

TUCCI, José Rogério Cruz e; FERREIRA FILHO, Manoel Caetano; APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho; DOTTI, Rogéria Fagundes; MARTINS, Sandro Gilbert. *Código de Processo Civil anotado*. São Paulo/Curitiba: AASP-OAB-PR, 2015.

VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. Famílias paralelas e poliafetivas devem ser reconhecidas pelo Judiciário. *Consultor Jurídico* (5 ago. 2014). Disponível em: [www.conjur.com.br/2014-ago-05/paulo-iotti-familias-paralelas-poliafetivas-reconhecidas#_ftn1_6588]. Acesso em: 13 ago. 2016.

VELOSO, Zeno. *Código Civil comentado. Direito de Família. Alimentos. Bem de Família. União Estável. Tutela e Curatela* (arts 1.694-1.783). São Paulo: Atlas, 2003. vol. XVII.

_____. *Código Civil comentado*. vol. XVII. Álvaro Villaça Azevedo (coord.). São Paulo: Atlas, 2003.

VENOSA, Sílvio de Salvo. *Direito civil. Direito das sucessões*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006. vol. VII.

_____. *Direito civil. Parte Geral*. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2004. vol. I.

VENTURINI VILLAROEL, Ali Jose. Apunte sobre la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en materia de autocomposición procesal y ejecución en sede de jurisdicción voluntaria. *Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales / Academia de Ciencias Políticas y Sociales*. Caracas. Vol. 70, n. 141 (2003). Disponível em: [http://acienpol.msinfo.info]. Acesso em 13. Ago. 2016

VINCENZI, Brunela Vieira de. *A boa-fé no processo civil*. São Paulo: Atlas, 2003.

WAMBIER, Tereza Arruda Alvim. CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. *Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil - Artigo por Artigo*. São Paulo: Ed. RT, 2015.

WAQUIM, Bruna Barbieri. *Alienação Familiar Induzida: aprofundando o estudo da alienação parental*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015.

_____. *Relações simultâneas conjugais: o lugar da outra no direito de família*. São Luís: Café & Lápis, 2010.

_____. Universos paralelos e danos de amor. *Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões*, vol. 13, n. 23, p. 65-83. Belo Horizonte: Magister, ago.-set.2011.

XAVIER, José Tadeu Neves. Questões relevantes sobre a mutabilidade do regime de casamento. *Revista de Direito Privado* (online), vol. 52, p. 193-228. São Paulo: Ed. RT, out-dez 2012.

YARSHEL, Flávio Luiz. *Ação rescisória: juízos rescindente e rescisório*. São Paulo: Malheiros, 2005.

_____. *Tutela jurisdicional*. São Paulo: Atlas, 1999.

ZACCARDI, Piero. Doppio grado o doppia fase del giudizio di merito? Una scelta politica. *Studi in onore di Enrico Tullio Liebman*, vol. III. Milano: Giuffrè, 1979.

ZANETI JUNIOR, Hermes. *Processo constitucional: o modelo constitucional do processo civil brasileiro*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.

ZANOBINI, Guido. Sull'amministrazione pubblica di diritto privato. *Rivista di Diritto Pubblico*, n. 3, p. 170-230. Milano: Società Editrice Libreria, [1918?].

ZENKNER, Marcelo. *Ministério Público e efetividade do processo civil*. São Paulo: Ed. RT, 2006.

© desta edição [2018]

Índice Alfabético-remissivo

A

- Abalroação, **Seç. XII**, 1; **Seç. XII**, 2.3
- Abandono de; da
- Bens vacantes, **742**, 2
- Bens, **744**, 2
- Coisa, **746**, 3.4.2
- Incidentes em embarcações, **Seç. XII**, 2.3
- Abuso do processo e má-fé, **726**, 3.6
- Ação de divórcio consensual (ver Divórcio Consensual)
- Ação de separação consensual (ver Separação Consensual)
- Ação dissolutória, **Seç. IV**, 2.1
- Ação penal, **BEI**, 3.1, 9.5; **746**, 5.
- Adaptabilidade, **BEI**, 1.2.1.1, 1.2.1.2, 6.2; **747**, 3.3
- Administração
- De bens e valores alheios, remanescentes, coisa, herança, **BEI**, 4.2, 7.2.4; **720**, 3.2; **735**, 3.4.4; **759**, 1; **Seç. IX**, 3; **762**, 2; **730**, 3.8
- Da coisa comum, **725**, 3.4, 3.4.2.1, 3.4.2.4; **730**, 3.2
- Da Justiça; judicial, **BEI**, 8.4, 9, 9; **Seç. I**, 2
- E deveres, **730**, 3.7.1; **735**, 3.4.4; **739**, 3.2
- Imóvel de incapaz, **BEI**, 7.2.4; **730**, 3.5.2; **762**, 3
- Administração Direta, **BEI**, 8.3; **722**, 3.1
- Administração Indireta, **BEI**, 8.3; **730**, 2; **766**, 4
- Administração Pública, **BEI**, 8.1; **720**, 2; **Seç. XI**, 2.1.1; **720**, 2
- Bens e valores alheios, remanescentes, **BEI**, 4.2, 7.2.4
- Prestação de contas, **744**, 3.4.6

Transigibilidade, disponibilidade, **BEI**, 4.3.3; **725**, 1; **725**, 3.8.1.3

Administração Pública de interesses privados; de direito privado, **BEI**, 2.1, 4.2, 4.3.2; **725**, 3.8.1.2

Advocacia Pública

Instituição, **BEI**, 8.2.1, 8.3, 8.3.1, 8.4; **720**, 3.1.3; **740**, 3; **741**, 3.4; **742**, 3.1, 3.5; **745**, 3.7

Legitimidade ativa do Estado, **738**, 3.2; **739**, 3.6; **740**, 3.9; **741**, 3.4; **742**, 3.1, 3.5, 3.7

Representação da Fazenda Pública, **722**, 3.1

Advocacia; advogado, **BEI**, 2.2.1, 5.3.1.1, 5.3.1.3, 8, 8.1, 8.4; **720**, 3.4; **731**, 3.3; **735**, 3.1; **737**, 3.3; **739**, 3.2; **741**, 3.3

Honorários de (...), **BEI**, 6.4; **720**, 3.4; **729**, 3.1; **752**, 1; **770**, 3.3

Inicial, subscrição por, **Seç. IV**, 2; **731**, 4.3, 4.6, 5.3; **733**, 2.1.5; **734**, 3.3; **760**, 3.1; **766**, 4.1; **767**, 3.1

Representação por; acompanhamento de; curadoria de, **720**, 3.4; **721**, 3.1, 3.4; **725**, 3.1.3.2, 3.2.5.3, 3.3.2.2, 3.8.2; **726**, 3.3, 3.5; **730**, 3.1.4, 3.7.1; **732**, 3.3, 3.5; **733**, 2.1.7; **742**, 3.5; **744**, 3.4; **Seç. IX**, 2, 4; **751**, 3.1; **752**, 1, 2, 3.2, 3.2.2; **768**, 4; **769**, 4; **770**, 3.3

Alienação(ções) judicial(is); **720**, 3.1; **721**, 3.1.2.1, **724**, 3.1; **725**, 3.2.5.3, 3.6.1.1, **Seç. III**, 1, 2; **730**, 1, 2.1; **730**, 2.2, 3; **742**, 2

Aspectos materiais da, **Seç. III**, 2; **725**, 3.6; **726**, 2.1.2; **726**, 3.1; **728**, 2, **Seç. III**, 1, 2; **730**, 2; **742**, 2.1

Avaliação na; oferta na; lance na, **730**, 3.5, 3.7, 3.7.1, 3.7.2, 3.8, 3.9

Bem alienado, **725**, 3.2.5.3; **730**, 3.1.2, 3.7, 3.8

De bem(ns); de coisa(s), **BEI**, 8.3.1; **720**, 3.1, 3.1.1, 3.2, 3.5; **725**, 3.3, 3.3.1; **726**, 3.1; **730**, 2.1.2, 2.2, 3.2, 3.5; **742**, 2.1

De bens de incapazes, **730**, 2.1.1; **725**, 3.3; **725**, 3.3, 3.3.2; **730**, 2.1.1, 3.5

De bens de crianças ou adolescentes, **725**, 1; **725**, 3.3, 3.3.1; **730**, 2.1.1, 2.2

De bens de órfãos, **725**, 1; **725**, 3.3, 3.3.2; **730**, 2.1.1

De bens vacantes, **742**, 2, 3, 3.1, 4, 4.1

De coisa comum, e quinhão em coisa comum, **725**, 3.4, 3.4.1, 3.4.2.1, 3.4.2.3, 3.4.2.4, 3.5, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.6; **730**, 2.2

De bens de interditos, **725**, 3.3; **725**, 3.3, 3.3.1, 3.3.2

Finalidade; justa causa, **725**, 3.2.1; 3.2.2; **730**, 2.1; **Seç. III**, 1; **730**, 2.1, 3.1.1, 3.1.2

Espécies e formas de, **730**, 2.1, 2.2, 3.1, 3.1.1, 3.2, 3.7

Procedimento(s), **725**, 3.3, 3.3.2.1; **730**, 2.2, 3, 3.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.5, 3.7, , 3.7.1, 3.7.1, 3.7.2; 3.8, 3.9, **742**, 3, 3.1

Protesto contra a, **726**, 3.1; **729**, 3.4; **Seç. III**, 1; **730**, 3.3

Alienação parental, **731**, 4.4.3

Alijamento, **Seç. XII**, 2.3; **767**, 2.2

Alteração do regime de bens do casamento, **BEI**, 8.1.1; **719**, 1.1; **Seç. IV**, 1, 2, 2.2, 2.4

Aspectos materiais, **Seç. IV**, 2.4; **730**, 2.4; **734**, 2

Legitimidade, **734**, 3.1

Procedimento, **734**, 3.3

Âmbito da impugnação, **752**, 3.2

Anomalia psíquica, **747**, 3.1.5; **748**, 1, 2; **749**, 1

Apelação, **BEI**, 5.3.1.1, 5.3.1.6; **725**, 3.1.3.8, 3.3.2.3, 3.5.2.7, 3.6.2.4, 3.6.2.8, 3.7.3.6; **Seç. II**, 3.5; **731**, 4.7, 5.7; **732**, 3.9; **734**, 3.7; **743**, 3.6; **745**, 3.8; **746**, 3.4.7; **751**, 3.2; **764**, 3.1; **767**, 3.1; **770**, 3.3

Recurso da sentença, **BEI**, 5.3.1.6, 5.3.6; **724**, 1, 2, 3.1, 3.2

Cabimento; **BEI**, 7.2.3; **724**, 1, 3, 3.1; **725**, 3.3.2.3; 3.8.2; **Seç. II**, 3.4, 3.5; **726**, 3.6; **731**, 4.7, 5.7; **732**, 3.9; **734**, 3.7; **743**, 3.6; **745**, 3.8; **746**, 3.4.7; **750**, 3.2; **764**, 3.1; **765**, 3.7

Efeitos, **724**, 3.2 1; **751**, 3.2; **760**, 3.2

Interdição, **751**, 1, 3.2; **761**, 3.3; **762**, 3.2; **763**, 3, 3.2

Legitimidade, **724**, 3.

Procedimento, **724**, 3.3; **725**, 3.4.2.4, 3.4.2.6, 3.5.2.3, 3.5.2.7; **735**, 3.3, 3.3.9.

Apresentante, **725**, 4

Testamentos, **Seç. V**, 2.4; **735**, 3.1, 3.1.1; **736**, 3, 3.1, 3.2

Legitimidade, **736**, 3.1, 3.3.4

Arrematação e paralisação do procedimento, **730**, 3.9

Arribada(s), **Seç. XII**, 2.2, 2.3

Arribada Forçada, **Seç. XII**, 2.3; **766**, 2.2

Arribada Voluntária, **Seç. XII**, 2.3

Arrolamento e arrecadação, **725**, 3.7.3.1; **740**, 3.3, 3.6

Ato circunstanciado, **740**, 3.1

Ausência curador, **740**, 3.3; **744**, 3.4

De bens dos ausentes, **744**, 2.2, 3.4.3

Curador, **739**, 3.3

Herança jacente, **BEI**, 7.2.4; **738**, 2, 3.1, 3.6; **739**, 3, 3.1.1, 3.3, 3.3.9; **740**, 2, 3, 3.1, 3.2

Inventário ou (...), **725**, 3.7.3.4; **741**, 3.4

Suspensão, **740**, 3.7

Atividade do juiz, **BEI**, 4.1; **721**, 3.1.2.1; **Seç. II**, 2; **735**, 3.3.3; **737**, 4.1

Atividade substitutiva, **BEI**, 3.5

Atraso no levantamento, **730**, 3.8

Autonomia privada, autonomia da vontade, **BEI**, 4.2; **725**, 2

Auto de inquirição, **740**, 3, 3.4

Audiência (s), **BEI**, 5.3.1.1, 7.2.4, 3.5.3.2; **737**, 3.3, 3.3.1; **761**, 3.2; **767**, 3.1

De conciliação e mediação, **BEI**, 5.3.1.1, 2; **726**, 2, 3.2; **730**, 3.1.3; **Seç. IV**, 1; **731**, 3, 4, 4.1, 5; **767**, 3.1; **768**, 3.3.2

De instrução e julgamento, **BEI**, 5.3.1.1, 5.3.1.4; **726**, 3.5; **753**, 1, 3; **754**, 2, 3; **756**, 3.3, 3.4; **760**, 3.2; **761**, 3.3; **769**, 1, 2, 3, 3.2, 3.3, 4; **770**, 33.1, 3.2

De menor, incapaz, **725**, 3.1.3.5, 3.3.2

De saneamento e de organização, **725**, 3.2.4.3

E entrevista do interditando, **721**, 3.1; **751**, 1, 3.1, 3.2; **752**, 1; **753**, 3; **754**, 3, 3.4

Auto circunstanciado, **BEI**, 7.2.4; **740**, 3.1, 3.2, 3.4

Autointerdição, **747**, 3.2, 3.3; **752**, 3.2, 3.2.1

Autonomia

Processual; procedimental, **730**, 3.1; **747**, 3.1; **756**, 3.3, 3.5; **757**, 3; **759**, 3.1; **761**, 3.1

Autoridade consular, **741**, 2; **741**, 3.5

Autoridade policial, **740**, 2, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6; **Seç. VIII**, 3; **746**, 2, 3, 3.1, 3.3, 5

Autorização para venda, **725**, 3.2.5.2, 3.2.5.4

Auxiliares da Justiça, **BEI**, 7.2.4; **730**, 3.1.2, 3.7.1; **744**, 3.4

Avaliação, **BEI**, 7.2.4; **725**, 3.3.2; **730**, 3.1.2, 3.5, 3.5.1, 3.7.3; **741**, 3.4

De bem(ns); do quinhão **725**, 3.2.4.1, 3.2.4.2, 3.2.4.5, 3.5.2.3, 3.6.2.4, 3.5.2, **742**, 2.1; 3.4

Oferta na; lance na, **730**, 2.1.1, 3.5, 3.7, 3.7.1, 3.7.2, 3.8, 3.9

Preço; valor, **725**, 3.4.2.2, 3.5.2.4, 4; **730**, 2, 3.1.2, 3.7, 3.7.2, 3.7.3, 3.9, **746**, 3.4.3

Procedimento, **730**, 3, 3.1.2, 3.5, 3.5.1, 3.9, **741**, 3.4

Avaria Grossa, **Seç. XII**, 1, 2.3

Avaria Simples, **Seç. XII**, 2.3

Avaria(s), **BEI**, 7.2.4; **Seç. XII**, 2.1, 2.3; **766**, 1, 2, 2.1, 2.2, 4; **767**, 2, 2.1, 2.2, 3.1.2; **769**, 3.2; **770**, 2, 3.4

Averbação, **726**, 3.5; **728**, 1, 2, 3.1.4; **731**, 4.7, 4.8, 4.9; **734**, 3.5, 3.6

Assento de nascimento, **725**, 3.1.3.7; **731**, 4.7, 4.9; **733**, 4

Protesto, **729**, 1

Registro de imóveis, **725**, 3.1.3, 3.6, 3.6.2.1; **731**, 4.9; **733**, 2

Registro Público, **726**, 1, 3.5; **728**, 1, 2, 3.1.4; **731**, 4.7, 5.7; **733**, 2.1

B

Bens arrecadados, **Seç. VI**, 3; **739**, 2, 3.3.2; **744**, 3.4.2; **745**, 3.2, 3.3, 3.5

Bens dos ausentes, **Seç. VII**, 2; **744**, 2.2, 3.3, 3.7; **745**, 3.2; **Seç. VIII**, 2

Bens imóveis, **BEI**, 8.3.1; **730**, 2.1.1; **731**, 4.6, 4.9, 5.6; **733**, 2.1.3, 2.1.7; **738**, 3.5; **739**, 2.1, 3.1; **742**, 2.1; **744**, 2.2; **745**, 3.2.4

Bens móveis, **730**, 3.7.3; **Seç. IV**, 2.2; **731**, 4.6, 5.6; **732**, 3.1; **730**, 3.7.3; **733**, 2.1.7; **738**, 3.5; **739**, 2.1; **742**, 2.1; **743**, 3.5.3; **745**, 3.2, 3.2.4; **746**, 3.2; **746**, 2.1

Bens passíveis de alienações, **730**, 2.2

Borrascas, **Seç. XII**, 2.3; **769**, 3.2

C

Capacidade de testar, **Seç. V**, 2.1.1, 2.1.2

Capacidade para estar em juízo, **738**, 3.4

Capacidade postulatória, **BEI**, 8.4; **720**, 3.4; **721**, 3.1; **726**, 3.3; **735**, 3.1

Capacidade processual do menor, **725**, 3.1.3.2

Cargas sinistradas, **767**, 2.1, 3.1

Causa transitória, **730**, 2.1.1; **733**, 2.1.2; **747**, 3.1, 3.1.3, 3.1.4, 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4; **752**, 3.2.1; **Seç. X**, 2

Chamamento, chamar, **734**, 3.4. **725**, 3.5.2.5

Do réu, **726**, 3.5; **Seç. IV**, 1

De interessados; dos herdeiros, **Seç. II**, 3.2.2; **734**, 3.4, 3.5; **738**, 3; **741**, 2, 3.1, 3.5; **743**, 3.1; **745**, 3.1

Do testamentário, **735**, 3.4; **736**, 3.5; **737**, 3.4

Dos consignatários, **769**, 3.2

Citação do interditando, **751**, 3.1

Civil (Direito Civil), **BEI**, 9.1; **731**, 4.4.2; **734**, 2; **Seç. V**, 2; **758**, 2; **Seç. XI**, 2.1.1; **Seç. XII**, 2.3

Codicilo(s), **BEI**, 7.2.3; **Seç. V**, 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3; **735**, 3.3; **737**, 2, 4.1

Código Comercial, **BEI**, 9.2, **Seç. XII**, 1, 2.1, 2.3; **768**, 2

Coisa julgada, **BEI**, 2.2.2, 3.1; **721**, 3.1; **724**, 3.1, 3.3

Formal, **BEI**, 3.7; **724**, 3.3, 3.4

Material, **BEI**, 5.4.2; 5.4.3; **724**, 3.3, 3.4; **725**, 3.8.2; **Seç. II**, 3.5

E ações impugnativas (anulatória e rescisória), **BEI**, 1.2.1.5, 1.2.1.6, 3.7, 5.4.2, 5.4.3; **724**, 3.4; **725**, 3.8.2; **729**, 3.2, 3.3; **730**, 3.7.2; **739**, 3.1.2; **744**, 2.2; **770**, 3.3

Coisas Vagas, **BEI**, 3.6, 4.2; **741**, 1; **Seç. VIII**, 2; **746**, 2, 3.4.4, 4

Colheita de informações, **740**, 3, 3.4

Comandante, **Seç. XII**, 2.1, 2.2, 2.3; **766**, 1, 2, 2.1, 4; **767**, 1, 3.1; **768**, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.3.2; **769**, 3, 3.4; **770**, 3.2

Companheiro(a)(s), **BEI**, 8.1.1; **Seç. IV**, 2.3; **747**, 3.1.1

Direito dos (...), **731**, 4.4.1, 4.4.5; **732**, 2, 3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 3.6.2; **735**, 3.1; **740**, 3.7, 3.8; **741**, 1; **745**, 3.2.4; **Seç. IX**, 4; **747**, 2, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4; **748**, 3, 3.1, 3.2.1, 3.2.2; **752**, 1, 2; **756**, 3.1

Legitimidade dos (...) **730**, 3.7.3; **Seç. IV**, 2.3; **732**, 2, 3.1, 3.3; **737**, 3.1; **741**, 1; **743**, 1; **745**, 1, 3.2.1; **Seç. IX**, 4

Reunião dos (...), **BEI**, 5.4.3

Compromisso(s), **729**, 3.5, **768**, 3.3.1

Dos apoiadores, **Seç. IX**, 3

Do tutor; do curador, **739**, 3.2, 3.5; **744**, 3.3, 3.7; **759**, 1, 3, 3.1, 3.2; **761**, 2, 3; **763**, 1

Do testamenteiro, **735**, 3.4

Do depositário, **740**, 3.3

Do(s) pais, **731**, 4.4.3

Comunicação dupla, **741**, 3.1; **745**, 3.1

Ciência aos herdeiros, **741**, 3.1; **745**, 3.1

Comunicação (processual), **725**, 3.5.2.4, 7.2.4; **Seç. II**, 3.1; **741**, 2.1

Às partes; aos interessados, **BEI**, 5.3.1.1; **721**, 1, 3.1.1; **724**, 4; **744**, 3; **767**, 3.1; **768**, 3.3

À autoridade consular, **741**, 3.5

Do interessado; do adquirente; do comunicante, **725**, 3.5.2.4; **Seç. II**, 2, 3.1, 3.2, 3.4; **726**, 2, 2.1, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5; **727**, 2; **729**, 3.4, 3.5; **740**, 3.6; **751**, 1

Dupla, **741**, 3.1; **745**, 3.1

Contra a Administração Pública, **729**, 3.5; **730**, 3; **741**, 3

Eletrônica, **730**, 3; **Seç. VI**, 1; **741**, 2; **745**, 3.1

E editais, **726**, 3.7; **741**, 3, 3.2; **745**, 3.1; **Seç. VIII**, 3; **746**, 3.3

Condição resolutória, **725**, 1, 3.6, 3.6.1.2, 3.6.2.1, 3.6.2.5

Conexão (de causas), **BEI**, 7.2.1; **721**, 3.4; **725**, 3.2, 3.6.2.3; **746**, 4; **Seç. IX**, 3; **756**, 3.5

Conflito(s), **BEI**, 2.1, 3.1; **731**, 4.5, 4.3.1, 6.2, 7.1, 9.3; **721**, 3.1.2; **725**, 3.8.8.1; **725**, 3.8.1.2; **725**, 3.8.2; **731**, 4.5

Da Administração, **BEI**, 4.3.3; **725**, 1; **725**, 1; **725**, 3.8.1.3

De competência, **725**, 3.7.3.4; **741**, 3.6; **744**, 3.2; **747**, 3.1.4

De interesses, **725**, 1; **Seç. II**, 3.2.1; **728**, 3.1; **730**, 2; **730**, 2.2; **730**, 3; **730**, 3.4; **730**, 3.7.1; **730**, 3.7.3; **752**, 2

Entre partes, **BEI**, 2.1, 7.2.4

Inexistência de (...), **BEI**, 3.1, 3.7

Solução (consensual) de (...), **BEI**, 2.1, 4.1, 4.3.3, 5.1, 5.3, 9.3; **725**, 3.8.1

Conflituosidade, **BEI**, 2.2, 3.1, 7.2.3, 7.2.4; **742**, 2.1; **743**, 3.5.3; **Seç. IX**, 2

Cônjuge(s), **BEI**, 8.1.1; **722**, 3.2; **725**, 3.2.1, 3.4.2.3, **Seç. IV**, 2.3; **747**, 3.1.1; **Seç. IV**, 2.4; **731**, 1, 2

Anuência do (...), **725**, 3.4.2, 3.5.2.2

Comunicação ao (...), **730**, 3.3, 3.7.3; **Seç. IV**, 2.1; **740**, 3.7; **741**, 3.2; **745**, 3.2

Legitimidade do(s) (...); legitimidade para, **Seç. IV**, 2.3, 2.4; **731**, 4, 5.1; **732**, 2.1.2; **734**, 3.1; **737**, 3.1; **744**, 3.1; **745**, 3.2, 3.2.4; **747**, 3.1; **748**, 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2; **750**, 3.1

Suprimento de outorga do (...), **725**, 4

Assinatura conjunta do (...), **Seç. IV**, 2.2; **731**, 4.4, 4.4.1, 5.3; **732**, 2.1.5; **734**, 3.3

Direito(s) do(s) (...), **731**, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.5, 5.7, 5.8, 5.9; **732**, 2, 2.1.7, 6.2; **733**, 2, 6.2, 6.3; **734**, 2; **735**, 3.1, 3.5; **741**, 3.5; **743**, 3.1; **745**, 1, 3.2.4; **Seç. IX**, 1; **747**, 1; **748**, 1; **752**, 1

Conservação, **739**, 3.1.3

Contrapedido, **752**, 3.2.1

Contraditório, **BEI**, 3.1, 3.3, 3.7, 5.3, 5.3.1.1, 6.2, 7.1; **721**, 1, 3.1, 3.5; **725**, 3.7.2; **Seç. II**, 3.2.2, 3.3; **726**, 2, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7. **728**, 3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2; **729**, 3.5; **730**, 3, 3.1.2, 3.2; **742**, 3.3; **743**, 3.3; **752**, 3.1; **765**, 3.4; **769**, 3.4; **770**, 3.3

Ausência de; falta de (...), **BEI**, 3.1, 3.3; **726**, 3.7.2; **726**, 3.6; **769**, 3.4

Contraditório antecipado, **728**, 3.1.1

Constitucional (Direito), **BEI**, 7.1; **731**, 4.4.2

Consolidação, **725**, 1, 3.6, 3.6.1.1

Controvérsia(s), **BEI**, 3.1, 4.3.2; **725**, 3.8, 3.8.7, 4; **730**, 3.4.1; **734**, 2; **741**, 3.1; **745**, 3.1; **Seç. IX**, 4; **752**, 3.2.2; **Seç. XI**, 2

Conciliação de (...), **725**, 3.8, 3.8.1.2, 3.8.1.3

Deformalização e desformalização (...), **BEI**, 2.1, 6.1; **Seç. II**, 2; **732**, 2

Expressa, **BEI**, 4.1

Solução de, **BEI**, 2.1, 3.1, 4.1, 4.3; **725**, 3.8, 3.8.1; **Seç. XI**, 2

Conversão da arrecadação, **741**, 3.4; **743**, 3.2; **745**, 3

Conversão de ação, **731**, 4.5; **731**, 5.5; **732**, 3.7

Criação das fundações, **764**, 2.1, 2.2

Cuidados materiais, **744**, 2.2

Cumprimento, **725**, 3.5.2.4; **727**, 2; **765**, 3.6

De mandado, **BEI**, 7.2.4; **729**, 3.5

De obrigação; deveres, **729**, 3.5; **735**, 3.3.2

De sentença; de decisão; de ordem, **BEI**, 6.2, 7.1; **729**, 3.5; **Seç. III**, 2; **730**, 3.1, 3.1.2, 3.6.

De testamento, **722**, 3; **Seç. V**, 2.4, 3; **735**, 3.3

Fase de (...), **BEI**, 1.2.1.1, 5.3.1.1, 5.3.1.5; **725**, 3.2.4.1, 3.2.4.4

Curador(es), **BEI** 5.3.1.1; **BEI**, 8.1.1; **720**, 3.1, 3.1.2; **725**, 3.1.3.2, 3.3.2.2; **730**, 3.7.1; **Seç. IV**, 2.3; **731**, 4.1; **733**, 2.1.2; **734**, 2.3.1; **735**, 3.4.4; **Seç. VI**, 4; **738**, 3.2, 3.3, 3.4; **Seç. VII**, 3.3; **739**, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5; **740**, 3.3; **744**, 3.3, 3.4, 3.4.7, 3.7; **749**, 3.3; **759**, 3.1, 3.3; **762**, 3.3; **769**, 3.3

De ausentes, **744**, 3.3, 3.4, 3.7; **745**, 3.2.2; **769**, 1, 3.3

De bens, **BEI**, 7.1; **744**, 1

Especial, **720**, 3.1.2; **721**, 3.4; **725**, 3.1.3.2, 3.1.3.2, 3.3.2, 3.3.2.2

Nomeação do (...), **720**, 3.2.1; **725**, 3.1.3.2; **744**, 2.1; **Seç. IX**, 2, 3, 4; **747**, 3.1.1; **749**, 1, 3.2, 3.3; **755**, 1,2, 3.1; **757**, 2; **759**, 2, 3.2, 3.3; **762**, 3.3

Provisório, **BEI**, 7.1; **Seç. IX**, 4; **747**, 3.1.1; **749**, 1, 3.2, 3.3; **752**, 3.2

Remoção do (...), **BEI**, 5.3.1.1, 8.1.1; **720**, 3.2.1; **739**, 3.5; **744**, 3.7; **747**, 3.1.4; **Seç. X**, 2; **761**, 1, 3.3

Curatela, **747**, 3.3.1; **752**, 3.2.1

Custas processuais, **Seç. II**, 3.5; **729**, 3.1, 3.2

Custas, **BEI**, 6.4; **720**, 3.4.1; **725**, 3.2.5.3, 3.5.3; **Seç. II**, 3.5; **729**, 3.1, 3.2; **730**, 3.7.3; **735**, 3.1.1.2; **770**, 3.3

D

Decisão de ratificação, **770**, 3.2

Declaração da ausência, **744**, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 3.1, 3.3, 3.5; **745**, 3.2; **753**, 3

Declaração de vacância, **738**, 3; **740**, 3.4, 3.9; **741**, 3.4, 3.7; **743**, 3.1, 3.2, 3.3

Decretação de interdição, **724**, 3.2; **755**, 1, 3.1

Defensoria Pública, **BEI**, 8.2

Intervenção, **720**, 3.1.3

Legitimidade (de representação), **720**, 1, 3.1, 3.1.1; **721**, 3.1; **730**, 3.7.1; **735**, 3.1; **737**, 3.3; **738**, 3.3; **739**, 1; **752**, 1; **760**, 3.1; **769**, 3.3

Parte hipossuficiente, **BEI**, 8, 8.2, 8.2.1; **720**, 3; **721**, 2

Depoimentos do comandante, **768**, 3.3; **770**, 3.2

Depositário provisório, **740**, 3, 3.3

Depósito

Ação(ões) de (...), **725**, 3.2.5.3; **739**, 3.4

Preço, valor, **725**, 3.5, 3.5.2.3, 3.5.2.4, 3.5.2.5, 3.5.2.7, **730**, 3.1.2, 3.7.3, 3.9; **746**, 3.4.3, 3.4.6

Do bem, coisa, **730**, 3.1.2, 3.5.2; **741**, 1; **745**, 1; **749**, 3.2

Levantamento do (...), **730**, 3.8

Desaparecimento, **725**, 3.6.2.5, 4; **744**, 2.1

Desapropriação, **725**, 3.2.5.4; **742**, 2

Desinteresse, **BEI**, 7.2.3; **Seç. VI**, 3; **740**, 3.7; **745**, 3.8; **Seç. VIII**, 3; **746**, 3.4.2, 3.4.7

Despesas processuais, **BEI**, 6.4; **720**, 3.4.1; **729**, 3.1

Destinação do patrimônio, **764**, 2.3; **765**, 3.6

Detentor(es), **BEI**, 8.1.1; **721**, 3.1; **725**, 3.1.1, 3.1.3.1; **Seç. II**, 3.3; **729**, 3.4; **730**, 2.1.2; **735**, 3.1.1, 3.1.1.2, 3.4.3; **736**, 1; **737**, 3.1, 3

Deveres do tutor, **759**, 3.3, 3.4

Deveres e obrigações, **735**, 3.4.3; **739**, 3.4; **744**, 3.4

Diário da Navegação, **Seç. XII**, 2.1; **766**, 1, 2, 2.1, 2.2, 3.1; **767**, 2.2, 3.1, 3.1.1, 3.1.2; **768**, 3.3; **769**, 2; **770**, 2, 3.1, 3.2

Diligências iniciais, **734**, 3.4

Direito

Fiscal, **725**, 3.6.2.4

Fundamental(is), **BEI**, 1.2.1.1; **731**, 4.4.3; **Seç. XI**, 2.1

De ação, **BEI**, 8.1; **720**, 2, 3.1; **725**, 3.6.2.5

De preempção, **725**, 3.5.2, 3.5.2.3, 3.5.2.4

Indisponível(is), **BEI**, 4.1; **720**, 3.4.2; **721**, 3.1.2.1, 3.4

Estado Democrático de, **BEI**, 5, 8.2, **720**, 3.1.3

Teoria Geral do, **719**, 3

Reais de garantia, **720**, 3.1.1

Real, **721**, 2; **725**, 3.2.3, 3.2.5.2, 3.6.1.1, 3.6.1.2, 3.6.2.7; **730**, 3.1.4, 3.3; **732**, 3.8; **744**, 3.1

Humanos, **720**, 3.1.3; **Seç. XI**, 2.1.1

Individuais e coletivos, **720**, 3.1.3

Direito(s) material(is), **BEI**, 1.2.1.2, 5.4.2, 5.4.3, 9; **719**, 2; **720**, 3.1.1; **721**, 3.5; **725**, 3.1.3.2, 3.3, 3.3.2, 3.4.2.4, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.2.4, 3.6.2.7, 3.8.2; **Seç. II**, 2, 3.1, 3.2.1; **726**, 2, 2.1.1, 2.1.3, 3.2, 3.1.2, 3.4.3; **Seç. IV**, 2; **736**, 1; **Seç. VI**, 3; **744**, 1; **745**, 3.2.4; **Seç. IX**, 2; **747**, 3.1.3; **Seç. X**, 2; **759**, 3.3; **763**, 3; **Seç. XI**, 2, 3; **764**, 1; **765**, 2; **Seç. XII**, 2.1; **768**, 3

Direito processual, **BEI**, 1, 3.1, 3.3, 6.1, 7.1; **726**, 3.6; **727**, 2; **732**, 1; **758**, 2; **Seç. XI**, 2; **Seç. XII**, 2.3

Dispensa da homologação, **733**, 5

Distribuição, **BEI**, 3.3, 5.3.1.2, 5.3.1.3; **720**, 3.2; **725**, 3.2.4.3, 3.3.2; **729**, 3.4; **731**, 4.4.3; **740**, 3.5; **746**, 3.3; **767**, 1, 3.1; **768**, 3.2; **769**, 3.1

Distrito Federal, **BEI**, 8.3; **722**, 3.1; **725**, 3.2, 3.7.3.1; **729**, 3.4; **730**, 3.1.4, 3.7.3; **Seç. VI**, 2, 3; **739**, 1; **740**, 3.9; **741**, 3.1, 3.3; **742**, 3.5; **743**, 3, 3.1; **745**, 3.1, 3.5, 3.8; **746**, 3, 3.4.1, 3.4.6, 3.4.7

Divórcio consensual, **719**, 1.1; **Seç. IV**, 1, 2.1; **731**, 1, 2; **731**, 4; 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.2, 4.5, 4.8, 4.9, 5.2, 5.8; **732**, 3.3; **733**, 2, 6, 6.3

Documentos essenciais, **731**, 5.3; **732**, 3.5; **748**, 3, 3.4

Documentos indispensáveis, **BEI**, 5.3.1.1, **725**, 3.7.3.3, 3.8.2, 3.7.4; **767**, 3, 3.1

Duração

Do encargo de tutor; de curador, **739**, 3.2, 3.5; **744**, 3.3, 3.7; **759**, 3.4

E

Ébrios habituais, **730**, 2.1.1; **747**, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4

Editais, **Seç. II**, 3.4, **726**, 2, 3.1, 3.5, 3.7; **729**, 3.4; **730**, 3, 3.6; **741**, 3.1, 3.2, 3.5; **743**, 3; **Seç. VII**, 3; **745**, 3.1, 3.2, 3.3; **Seç. VIII**, 3; **746**, 3.3, 3.4; **755**, 1, 3.3

Eleitoral (Direito), **BEI**, 1.1

Empresarial, **BEI**, 9.2

Entrega dos autos, **729**, I, 2, 3.2, 3.4; **770**, 3.3

Entrega efetiva dos autos, **729**, 3.2

Entrevista pessoal, **751**, 3.2

Esferas normativas, **BEI**, 1.2.1

Espécies fundacionais, **Seç. XI**, 2.2

Estado(s), **BEI**, 7.2.4, 8.3; **722**, 3.1, 3.7.3.1; **729**, 3.4, 3.7.3; **730**, 3.8; **739**, 1; **742**, 3.5, 3.8

Estado Constitucional, **BEI**, 1.2.1.1

Estado Democrático de Direito, **BEI**, 5, 8.2; **720**, 3.1.3

Estatuto fundacional, **764**, 2.2.1

Estrutura fundacional, **764**, 2.2.1.1

Excludentes de citação, **751**, 3.1.1

Execução do testamento, **735**, 3.3.7, 3.4, 3.4.3

Execução por dívida, **725**, 3.2.5.6

Eximção, **739**, 3.5; **744**, 3.7; **760**, 3.1, 3.2

Existência de herdeiros, **740**, 3.6; **741**, 3.2

Exprimir sua vontade, **730**, 2.1.1; **733**, 2.1.2; **737**, 3.3; **747**, 3.1, 3.1.3, 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4; **752**, 3.2.1; **Seç. X**, 2

Extinção consensual de união estável, **Seç. IV**, 1, 2, 2.3; **731**, 4; **732**, 1, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.6.1, 3.11; **733**, 2, 6.3

Extinção da fundação, **BEI**, 8.1.1; **765**, 2.1, 3, 3.1, 3.3

Extinção de usufruto, **725**, 1, 3.6, 3.6.2.1

F

Fase decisória, **BEI**, 5.3.1, 5.3.1.4; **725**, 3.2.4, 3.2.4.4

Fase instrutória, **BEI**, 5.3.1.1, 5.3.1.3, 5.3.1.4; **725**, 3.2.4.2, 3.2.4.4

Fase organizatória e de saneamento, **BEI**, 5.3.1, 5.3.1.2; **725**, 3.2.4

Fase postulatória, **BEI**, 5.3.1, 5.3.1.1; **725**, 3.2.4, 3.2.4.1

Fase recursal, **BEI**, 5.3.6, 5.3.1.4, 5.3.1.6; **725**, 3.2.4, 3.2.4.4

Fazenda Pública como, **722**, 3

Fiduciariiedade, **725**, 3.6.2.5

Fiduciário, **725**, 3.6, 3.6.1.2, 3.6.2.1, 3.6.2.4, 3.6.2.5, 3.6.2.7; **730**, 3.1.4, 3.3

Fideicomissário, **725**, 3.6, 3.6.1.2, 3.6.2.1, 3.6.2.4, 3.6.2.5, 3.6.2.6.2, 3.6.2.7

Fideicomisso, **725**, 1, 3.6, 3.6.1, 3.6.1.2, 3.6.1.2.2, 3.6.2.1, 3.6.2.3, 3.6.2.4, 3.6.2.5, 3.6.2.6, 3.6.2.6.2, 3.6.2.7; **745**, 3.2.1

Fim da arrecadação e credor legitimado, **738**, 3.5

Finalidade das alienações judiciais, **730**, 2.1

Fiscal, **725**, 3.2.5.3, 3.2.5.4

Flexibilização procedimental, **BEI**, 6.2; **734**, 3.4

Formas de alienação, **730**, 3.1

Função homologatória e solução consensual ou conciliação, **BEI**, 4.3

Funções Essenciais à Justiça, **BEI**, 8, 8.1; **720**, 2

Fundação, **BEI**, 8.1.1; **Seç. II**, 3.3; **Seç. XI**, 2.1, 2.1.1, 2.2; **764**, 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1; **764**, 2.3, 3.1, 3.2, 3.5; **765**, 2, 2.1, 3, 3.1, 3.3, 3.6, 3.7

Fundações, **BEI**, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 8.1.1, 8.3; **719**, 1.1; **720**, 3.1.2; **722**, 3.1; **Seç. II**, 3.3; **729**, 3.4; **Seç. XI**, 1, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 3; **764**, 1, 2, 2.2.1, 2.3, 3.2; **765**, 3.2, 3.7

Públicas, **729**, 3.4; **Seç. XI**, 2.1.1

Privadas, **Seç. XI**, 2.1.1, 2.2, 3; **764**, 2.1, 2.2

Instituídas por pessoas físicas e jurídicas, **Seç. XI**, 2.2

Instituída por empresa, **Seç. XI**, 2.2

Instituída por partido político, **Seç. XI**, 2.2

De apoio à instituição de ensino superior, **Seç. XI**, 2.2

De previdência privada ou complementar fechada, **Seç. XI**, 2.2

Organização e Fiscalização das, **Seç. XI**, 2, 3; **764**, 1, 2.3

G

Gestão, **BEI**, 4.1; **725**, 3.1.3.6, **739**, 2, 3.1, 3.1.4, 3.2, 3.3.6, 3.5; **744**, 2.2, 3.3, 3.4.6, 3.7; **745**, 3.3; **751**, 3.1.1; **759**, 3.4; **763**, 1; **Seç. XI**, 2.1.1

Gratuidade de justiça, **BEI**, 5.6.4; **720**, 3.4.1; **724**, 3.1; **729**, 3.1

Das escrituras, **733**, 2.1.4

Guarda, **BEI**, 7.2.4; **720**, 3.1; **725**, 3.1.3.3, 3.6.1.2; **Seç. II**, 2; **729**, 3.3, **730**, 2, 2.2, 3.1.1, 3.5.2, 3.7.1; **733**, 6.3; **735**, 3.1, 3.3.2, 3.3.6, 3.4.4; **739**, 2, 3, 3.1, 3.1.2, 3.2, 3.3, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.5, 3.4; **740**, 3, 3.3, 3.5; **744**, 2, 2.2, 3.4, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.5, 3.4.5.3; **745**, 3.3; **746**, 3.3, 3.4.6; **Seç. IX**, 3; **747**, 3.1.4; **755**, 1; **757**, 3

Dos filhos incapazes, **731**, 2, 4.4, 4.4.3, 5.4, 5.4.3; **732**, 3.3, 3.5, 3.6, 3.6.3; **733**, 2

H

Habilitação, **719**, 2; **Seç. VI**, 2, 2.1; **738**, 3, 3.2; **740**, 3.9; **741**, 1, 2, 3, 3.1, 3.4, 3.5; **743**, 3.3, 3.5; **744**, 1, 3.3; **745**, 3, 3.1, 3.2.2, 3.2.3; **746**, 4; **758**, 1, 2

De herdeiros, **741**, 3.3

Pendente, **742**, 3.4; **743**, 3, 3.2; **745**, 3.1

Dos credores, **741**, 3.6

Herança jacente, **BEI**, 3.6, 4.2, 7.2.3, 7.2.4, 8.1.1, 8.3.1; **724**, 3.1; **725**, 3.2; **730**, 2.2; **Seç. VI**, 1.2, 2.1, 3; **738**, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6; **739**, 2, 3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.3.3, 3.4, 3.5; **740**, 2, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7; **741**, 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7; **742**, 2, 3.3; **743**, 3.5.1; **744**, 2.2, 3.3; **745**, 3.2.4, 3.7; **Seç. VIII**, 2; **746**, 2

Arrecadação de, **730**, 2.2; **738**, 3.6; **739**, 3.1.1; **740**, 2, 3.2, 3.3; **741**, 3.6; **743**, 3.2; **744**, 3.6

Curador da, **735**, 3.4.4; **738**, 3.4; **739**, 3.1.4, 3.2, 3.3, 3.3.5, 3.4, 3.5; **744**, 1, 3.4; **769**, 3.3

Natureza jurídica da, **Seç. VI**, 4

Juízo competente para a, **738**, 3.5; **741**, 3.6

Vacância da, **742**, 3.3; **743**, 2

Herdeiros, **BEI**, 8.1.1; **725**, 3.6.1.2, 3.7; **735**, 3.4, 3.4.1, 3.4.5; **737**, 3.1, 3.3; **Seç. VI**, 2, 2.1, 3; **738**, 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3; **739**, 2, 3.1.1; **740**, 3.5, 3.6, 3.7; **741**, 2, 3, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5; **742**, 2, 3.4; **743**, 3, 3.1, 3.2, 3.5, 3.5.2; **Seç. VIII**, 3; **744**, 3.4; **745**, 3, 3.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.4, 3.7

Em expectativa, **725**, 3.6.2.4

Habilitação de, **741**, 3.3

Legítimos, **Seç. VI**, 2.1; **738**, 3.3; **740**, 3.4, 3.7; **744**, 3.1; **745**, 3.2.1

Necessários, **735**, 3.4.2

Presumidos, **744**, 3.1; **745**, 3.2.1

Retardatários, **Seç. VI**, 2; **743**, 3.3

Testamentários, **Seç. VI**, 2.2; **738**, 3.3; **740**, 3.4, 3.7; **744**, 3.1; **745**, 3.2.1

Hipoteca, **720**, 3.1.1; **721**, 3.5; **725**, 3.3.1, 3.6.2.5; **730**, 3.3, 3.7.3, 3.9; **742**, 2; **745**, 3.2.4; **747**, 3.3.4; **755**, 2

De bem fideicomitido, **725**, 3.6.2.5

Especificação de, **759**, 3.3.1

Judiciária, **730**, 3

Legal, **759**, 3.3.1; **762**, 2

Homologação, **BEI**, 1.2.1.5, 4, 4.3.3, 7.2.4, 8.1.3, 9; **Seç. I**, 1; **719**, 2; **724**, 3.4; **725**, 1, 3.1, 3.1.3.1, 3.8.1, 3.8.3, 3.8.4, 4; **729**, 3.4; **Seç. IV**, 2.2; **731**, 3, 4.1, 4.9, 5.9; **734**, 3.3, 3.7; **766**, 2.1; **767**, 1

Atos judiciais de, **BEI**, 9; **Seç. I**, 2

Da extinção consensual de união estável, **732**, 1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.6.1, 3.6.2, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11

De autocomposição extrajudicial, **BEI**, 1, 1.2.1.5, 2.1, 4.3.3, 8.4, 9.3; **719**, 1; **725**, 1, 3.1, 3.8, 3.8.1, 3.8.1.3, 3.8.2, 3.8.3

De sentença estrangeira, **725**, 4

Do divórcio, **731**, 3, 4.1, 4.3, 4.4.1, 4.4.4, 4.6, 4.9, 5.3, 5.9

Judicial, **BEI**, 3.7; **725**, 3.1.2, 3.1.3.1, 3.8.2; **Seç. IV**, 2.2; **732**, 3.11; **733**, 2.1.5, 5

Honorários advocatícios, **BEI**, 6.4; **720**, 3.4.1; **729**, 3.1; **752**, 1; **770**, 3.3

I

Impedimento(s), **BEI**, 7.2.4; **Seç. IV**, 2.3; **721**, 3.4; **725**, 3.1; **726**, 3.1; **731**, 4.4.5; **735**, 3.4.1

Imposto(s), **BEI**, 9; **Seç. I**, 2; **725**, 3.6.2.4, 3.6.2.5, 3.6.2.6, 3.6.2.6.1, 3.6.2.6.2, 3.7.3.1, 3.7.3.2.3; **730**, 2.1, 3.9; **733**, 2.1.7; **734**, 2; **735**, 3.1; **764**, 3.5; **Seç. XII**, 2.1

Impugnação, **BEI**, 1.2.1.2, 5.3.1.1, 6.3; **721**, 3.4; **725**, 3.1.3.5, 3.8.2; **Seç. II**, 3.1, 3.4; **730**, 3.3, 3.9; **738**, 3.5; **745**, 3.2.3; **Seç. IX**, 4; **752**, 1, 3.1, 3.2, 3.2.2; **753**, 1, 2

Autônoma, **729**, 3.2

Do interditando, **BEI**, 5.3.1.1; **Seç. IX**, 4

Imparcialidade(s) do juiz, **BEI**, 2.1, 3.6; **723**, 3; **730**, 3.1.2

Incapacidade, **BEI**, 2.1, 6.1; **721**, 3.4; **725**, 3.1.3.7; **730**, 2.1.1; **733**, 2.1.2; **Seç. V**, 2.1.1; **747**, 3.3.1; **748**, 1, 3.2, 3.2.2; **749**, 1, 2; **751**, 1, 3.1.1, 3.2; **752**, 3.2.1; **753**, 2; **754**, 3; **755**, 2, 3.1, 3.3; **757**, 3

Absoluta, **730**, 2.1.1; **Seç. V**, 2.1.1; **747**, 3.3.1; **752**, 3.2.1

Acidental, **Seç. V**, 2.1.2

Da parte, **721**, 3.4; **749**, 1

De cônjuge, **748**, 3, 3.2.2

De exprimir vontade, **Seç. IX**, 3

De ser tutor, **747**, 3.1.3; **Seç. X**, 2

Do interditando, **749**, 1; **750**, 3; **751**, 1, 3.1.1, 3.2; **753**, 2, 3; **755**, 1; **757**, 3

Física, **Seç. IX**, 2

Por idade, **725**, 3.1.2, 3.1.3.7

Transitória, **758**, 1

Incapaz(es), **BEI**, 1.2.1.2, 5.3.1.1, 6.1, 7.1, 7.2.4, 8.1, 9; **Seç. I**, 2; **720**, 3.1; **721**, 3.1, 3.1.2.1; **725**, 3.1.2, 3.3, 3.7.3.2.2; **Seç. III**, 3; **730**, 2.1.2, 3, 3.1.4, 3.2, 3.5.2; **Seç. IV**, 2.1, 2.2, 2.3; **731**, 2, 4.1, 4.2, 4.4, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 5.4, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4; **732**, 3.4, 3.6, 3.6.3, 3.6.4; **733**, 2, 2.1.2, 2.1.7, 6, 6.3; **734**, 3.1; **Seç. V**, 2.1.1; **741**, 3.6; **Seç. IX**, 2, 4; **747**, 3.1.3; **748**, 3.1, 3.2.2; **751**, 3.1.1; **755**, 1, 3.1; **757**, 1, 2, 3; **Seç. X**, 2; **760**, 2; **761**, 2; **762**, 3

Absolutamente, **725**, 2; **730**, 2.1.1; **748**, 1

Administração imóvel de, **BEI**, 7.2.4

Relativamente, **725**, 2, 3.3.2; **730**, 2.1.1; **733**, 2.1.2; **Seç. V**, 2.1.1; **747**, 3.1.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4; **752**, 3.2.1; **Seç. X**, 2

Incumbência(s), **BEI**, 8.1; **720**, 2; **748**, 2; **759**, 3.3.1

Do curador, **739**, 1, 2, 3, 3.3; **744**, 3.4

Iniciais, **Seç. VII**, 3.4; **739**, 3, 3.3; **744**, 3.4

Indeferimento, **BEI**, 5.3.1.1, **724**, 3.3; **Seç. II**, 2, 3.5; **726**, 3.4, 3.6; **769**, 3.2

Da inicial, **720**, 3.1, 3.2; **Seç. II**, 3.4, 3.5; **750**, 3, 3.2; **767**, 3.1

Da medida, **728**, 3

Do pedido, **727**, 3; **760**, 3.2; **766**, 1

Do protesto, **726**, 3.6

Liminar, **766**, 1

Inércia, **722**, 3

Da jurisdição ou do órgão jurisdicional, **Seç. II**, 2; **730**, 3.1.1

De cônjuge, **748**, 3, 3.2.1

Dos interessados, **747**, 3.1.5

Dos legitimados ativos, **748**, 1, 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2; **752**, 3.2.2

Inexistência de herdeiros, **Seç. VI**, 2.1, 2.2; **738**, 3.1, 3.3; **743**, 3.1

Informação de autoridade, **740**, 3.4

Inicial (ver Petição Inicial)

Iniciativa, **720**, 1, 3.1, 3.4; **730**, 3.1; **Seç. VI**, 3; **738**, 3.2, 3.5; **739**, 3.3.4; **740**, 3.6; **744**, 2.2; **744**, 3.4.4; **765**, 3.4; **769**, 2

Da alienação, **730**, 3, 3.1

Da Fazenda Pública, **739**, 3.3.3; **742**, 3.1; **744**, 3.4.3

De abertura, **738**, 3.2

De arrecadação, **739**, 2

Do deficiente, **Seç. IX**, 3

Do(s) interessado(s), **720**, 3.1.1; **742**, 3.1; **744**, 3.4.3

Do juiz, **BEI**, 7.1; **720**, 3; **735**, 3.4.5; **738**, 3.2, 3.3; **742**, 3.1

Do menor, **725**, 3.1.3.2

Do Ministério Público, **720**, 3, 3.1.2; **739**, 3.3.3, **742**, 3.1; **744**, 3.4.3; **747**, 3.1.4

Do(s) legitimado(s), **735**, 3.4.4; **738**, 3.1, 3.2; **739**, 3.4; **745**, 3.2.1

Particular, **720**, 3.4, **Seç. III**, 3; **730**, 2, 2.1.1, 2.1.2, 3, 3.1.2

Judicial, **739**, 3.3.3; **744**, 3.4.3

Inocorrência

De revelia, **721**, 3.4

De preclusão, **724**, 3.1

De prevenção, **Seç. II**, 3.3

Inspeção, **735**, 3.3.3; **740**, 3.5

Do testamento, **735**, 3.3.3

De documentos, **739**, 3.5; **740**, 3, 3.5

Judicial, **Seç. IX**, 4; **751**, 3.3

Instauração, **720**, 1, 2.1.1; **721**, 2, 3.5; **729**, 3.4; **730**, 2.1, 3.1.1; **738**, 3.1, 3.3; **741**, 3.3; **746**, 3.1, 3.3, 5

De processo criminal, **725**, 3.7.3.3

Do procedimento, autoridade policial, **746**, 3.1

Interdição, **BEI**, 3.6, 5.3.1.1, 5.4.3, 7.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 8.1, 8.1.1; **720**, 3.1.2; **721**, 3.1; **724**, 3.2, 3.4; **730**, 2.1.1; **734**, 2; **Seç. V**, 2.1.2; **Seç. IX**, 1, 2, 3, 4; **747**, 2, 3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.2, 3.3, 3.3.2; **748**, 3, 3.1, 3.4; **749**, 1, 3; **750**, 3.1, 3.2; **751**, 2, 3.1.1; **754**, 2; **755**, 1, 3.1, 3.2; **756**, 1; **758**, 1; **759**, 3.1.

Ação de, **747**, 3.1.2, 3.1.4, 3.2, 3.3; **752**, 3.1; **755**, 2; **761**, 3.3

Auto, **747**, 3.2, 3.3.1; **749**, 3; **752**, 3.2.1

Causa de, **748**, 3.1

De menor ou adolescente, **747**, 3.1.4

Levantamento da, **747**, 3.2, 3.3.2; **756**, 3.3

Levantamento parcial da, **747**, 3.2; **756**, 2

Parâmetros da, **Seç. IX**, 3

Pedido de, **Seç. IX**, 2, 3, 4; **747**, 1, 2, 3.1, 3.1.1, 3.2, 3.3.5; **748**, 3.2.2; **749**, 3.1; **750**, 3; **752**, 2, 3.2.2;

756, 3.1; **Seç. X**, 2

Procedimento de, **Seç. IX**, 3, 4; 747, 3.1, 3.1.1, 3.1.5, 3.3, 3.4; 748, 1, 3.2, 3.3; 749, 1, 3.2; 750, 1, 2, 3, 3.1.1, 3.3; 750, 3.2; 752, 3.2.1, 3.2.2; 753, 1, 2, 3, 3.1, 3.2; 754, 3; 756, 3.4, 3.5, 3.5.1; 757, 2, 3; 758, 3; 761, 3.1

Sentença de, 741, 1; 745, 1; **Seç. IX**, 1, 4; 749, 3.1; 753, 2; 755, 1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4; 756, 2, 3.2; 758, 1, 2; 759, 3.2

Terceiro na, 747, 2

Interessado(s), **BEI**, 2.2.2, 3.4, 4.3.3, 5.3.1.2, 5.3.1.3, 5.3.1.5, 6.4, 7.2, 7.2.1, 7.2.2; 720, 3.1, 3.4.1; 721, 3.1, 3.1.2.1; 725, 3.1.3.7, 3.2.4.3, 3.2.5.3, 3.3.2.2, 3.5.2.4, 3.7.3.2; **Seç. II**, 3.2, 3.2.1, 3.3; 726, 3.1; 729, 3.4; 730, 2, 2.1.1, 2.2, 3, 3.4, 3.5.1; **Seç. IV**, 2.1; 731, 3, 4.6; 734, 3.6; **Seç. VI**, 2.1; 738, 3; 740, 3.5; 741, 2, 3.5; 743, 3.2; **Seç. VII**, 3; 745, 2, 3.3; 751, 3.3; 753, 3.2; 765, 3.5; 768, 3.3; 769, 2; 770, 2

Atuação do(s), **BEI**, 8.1, 720, 2; 722, 2; 725, 3.7.3, 3.8.2; 730, 2.1.2, 3.1.2, 3.1.3, 3.7.3; 731, 4.1, 5, 5.1; 732, 3.3; 734, 3.4, 3.5; 737, 3.1; 738, 3.3; 739, 3.2; 742, 3.1, 3.5; 744, 3.1; 745, 3.2.1; 747, 2; 747, 3.1.5; 752, 3.2.1, 3.2.3; 761, 3.1; 764, 3.3; 765, 3.1; **Seç. XII**, 2.2; 769, 3.1, 3.4

Citação do(s), **BEI**, 7.2.4; 720, 3.2; 721, 1, 3, 3.1.1; 722, 3; 725, 3.2.4.1, 3.3.2, 3.4.2.4, 3.5.2.3, 3.6.2.4, 4; 726, 3.5; 730, 3.1.4; 735, 3.3.1, 3.3.2; 741, 3.2; 769, 3.2

Dever(es) do(s), **BEI**, 1.2.1.1, 3.1; 725, 3.4.2.3, 3.7.3.3, 3.8.2; 729, 3.1; 730, 2.2; 733, 2.1.4; 753, 3.2; 756, 3.4; 768, 3.2

Efeitos entre os, 725, 3.1.3.7; 731, 4.7; 743, 3.6; 745, 3.2.4; 764, 3.1

Manifestação de(o), **BEI**, 5.3.1.1, 5.3.1.2; 721, 1, 3.3, 3.4; 725, 3.6.2.4; 730, 3.2; 737, 3.3.2; 745, 3.2.3; 756, 3.3; 765, 3.6

Prejuízos aos, 730, 3.6; 742, 3.3; 745, 3.4; 763, 3.3; **Seç. XII**, 2.3

Requerimento do(s), **BEI**, 7.1; 730, 2.1, 3.1.3, 3.9; 731, 4.2, 4.3, 5.2, 5.3, 5.6; 732, 3.4, 3.5; 733, 2.1.5; 733, 2.1.6; 734, 3.3; 735, 3.3, 3.3.3; 738, 3.2; 740, 3.7; 741, 3.6; 744, 3.3; 745, 3.2, 3.3; 749, 3.3; 755, 3.1

Terceiro, **BEI**, 7.2.3; 734, 3.7; **Seç. IX**, 3

Vedado ao(s), 721, 3.1.1; 730, 2.2, 3.7.1

Interesse de incapaz(es), **BEI**, 1.2.1.2, 8.1, 8.1.1; 720, 2, 3.1.2; 721, 3.1.2.1; 730, 2.2, 3.5.2, 3.8; 733, 2.1.2; 740, 3.9; 747, 3.1.1; 748, 2; 759, 3.1; 760, 2; 761, 2, 3.3

Público(s), **BEI**, 8.1, 8.1.1; 720, 2, 3.1.2, 3.4.2; 721, 3.1.2, 3.1.2.1; 722, 2; 725, 3.8.1; **Seç. II**, 3.2.1; 729, 3.4; 731, 4.4.5; 740, 3.9; 742, 2; 744, 3.4

Recursal, **BEI**, 5.3.1.6; 724, 3, 3.1; **Seç. II**, 3.4, 3.5; 731, 4.7, 5.7; 732, 3.9; 734, 3.7; 743, 3.6; 745, 3.8; 746, 3.4.7; 752, 3.2.3; 763, 3.3; 770, 3.3

Intervenção, **BEI**, 1, 3.6, 4.2, 5.3.1.1; 725, 3.1.3.1, 3.5.2.4, 3.6, 3.6.2.1; **Seç. II**, 1; 726, 3.2; 730, 2.2, 3.8; **Seç. IV**, 2.4; 731, 4.6, 5.6; 769, 3.4

Da Advocacia Pública, 742, 3.5; 740, 3; 742, 3.5, 3.7

Da Fazenda Pública, 725, 3.7.3.2.3, 3.8.3.5

Do curador, **Seç. IX**, 3; 747, 3.3.2; 755, 2

Do INSS, 725, 4

Do Ministério Público, **BEI**, 8.1, 8.1.1; **720**, 2, 3.1.2, 3.1.3; **721**, 2, 3, 3.1.2, 3.1.2.1; **725**, 3.8.3.5; **733**, 2, 2.1.2; **734**, 3.1, 3.6; **735**, 3.3.5; **736**, 3.4; **737**, 3.3.3; **739**, 3.6; **740**, 3, 3.9; **742**, 3.6; **748**, 1, 3.2, 3.2.1; **752**, 3.2.2; **756**, 3.5.1; **764**, 3.2

De terceiros, **BEI**, 7.2.3, **721**, 3, 3.5; **Seç. II**, 3.2.2; **730**, 3.4; **747**, 3.3.1; **769**, 3.2

Intimação, **721**, 1, 3.1.2; **726**, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7; **727**, 3; **728**, 3; **729**, 1, 2, 3.4; **730**, 3.1.4; **735**, 3.1.1; **737**, 3.1, 3.3

Da Fazenda Pública, **BEI**, 8.3.1, **722**, 3; **725**, 3.4.2.4

Do despacho, **759**, 3.2

Do Ministério Público, **BEI**, 8.1; **720**, 3.1.2, 3.2; **721**, 3; **725**, 3.2.4; **734**, 3.6

Dos interessados, **721**, 3; **725**, 4; **729**, 3.2, 3.3

Pessoal, **726**, 2; **729**, 3.4; **764**, 3.2; **765**, 3.2

Investigação de paternidade, **743**, 3.4, 3.5.1

J

Juiz, **BEI**, 7.1.

Atividade do (...), **BEI**, 4.1; **721**, 3.1.2.1; **Seç. II**, 2; **735**, 3.3.3; **737**, 4.1

Competente, **725**, 4; **735**, 3.2, 3.3.7; **747**, 3.1.3; **751**, 3.1.1, 3.2; **755**, 1; **Seç. X**, 2

Da jurisdição voluntária, **BEI**, 2.1, 2.2.2, 3.6, 4.1, 4.3.3, 5.3.1.1, 7.1

Deveres do (...), **BEI**, 1.2.1.1, 3.1, 3.3, 3.6, 4.1, 4.3, 4.3.1, 5.3.1.3, 7.1; **731**, 4.5, 5.5; **732**, 3.7

Imparcial, **BEI**, 2.1, 3.6, 5.1, 7.1, 8; **730**, 3.1

Poderes do (...), **BEI**, 1.2.1.1, 3.1, 3.6, 5.3.1.1, 5.3.1.3, 7.1, 9.4, **723**, 1; **Seç. I**, 2; **726**, 3.4; **731**, 4.4.4, 5.4.4; **732**, 3.6.4; **Seç. IX**, 4; **751**, 1; **765**, 3.5; **768**, 3.3.1

Juizados Especiais, **BEI**, 4.3.3, 8.1.3, 8.4, 9.4; **720**, 3.4; **724**, 2; **725**, 3.2, 3.8, 3.8.2, 3.8.3; **726**, 3.2; **729**, 3.1; **770**, 3.3

Juizados Especiais Federais, **BEI**, 4.3.3, 8.1.3; **725**, 3.2, 3.8.3

Juizados Especiais da Fazenda Pública, **BEI**, 4.3.3, 8.1.3, **725**, 3.8.3

Jurisdição Voluntária, **BEI**, 1.1

Características da (...), **BEI**, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7

Conceito de (...), **BEI**, 2.1, **719**, 1

E ação, **BEI**, 5, 5.2

E jurisdição, **BEI**, 3.5, 5, 5.1

E processo e procedimento; e fases procedimentais, **BEI**, 5, 5.3, 5.3.1, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.1.3, 5.3.1.4, 5.3.1.5, 5.3.1.6; **720**, 3.3; **726**, 3.2; **730**, 3.1.3; **756**, 3.3

Funções da (...), **BEI**, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3

Natureza jurídica da (...), **BEI**, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3

Premissas decorrentes da (...), **BEI**, 1.2.1, 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.4, 1.2.1.5, 1.2.1.6, 1.2.1.7

Jurisdição contenciosa, **BEI**, 1.2.1.2, 2.1, 2.2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 5.3.1.1, 5.3.1.5, 7.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4; **719**, 1; **720**, 1, 3.3, 3.4, 3.4.1; **721**, 3.1.1; **724**, 3, 3.3; **725**, 3.2; **Seç. II**, 3.3; **Seç. III**, 2; **730**, 3.3, 3.7; **Seç. IV**, 1; **735**, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.8; **Seç. IX**, 4, **Seç. XI**, 2

Conversão em (...), **BEI**, 3.1, 4.1; 7.2.3; **720**, 3.2; **728**, 3; **Seç. IV**, 1; **731**, 4.5, 5.5; **732**, 3.7; **746**, 3.4.1

E jurisdição voluntária, **BEI**, 1.2.1.2, 2.1, 2.2.1, 2.2.3, 5.4.1, **Seç. II**, 3.3

Justa causa, **725**, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4.1, 3.2.4.2

Justiça do Trabalho, **725**, 3.8.3; **Seç. II**, 3.3

Justiça Eleitoral, **BEI**, 8.5; **725**, 3.8.3

Justiça (Comum) Federal, **725**, 3.2; **Seç. II**, 3.3; **729**, 3.5; **743**, 3.5; **744**, 3.2; **766**, 4

Justiça (Comum) Estadual, **734**, 3.2, 3.7.2.5; **744**, 3.2; **764**, 3.4

L

Lance vil, **730**, 3.7

Legitimação processual, (ver Legitimidade processual)

Legitimação ativa, (ver Legitimidade ativa)

Legitimação processual, (ver Legitimidade passiva)

Legitimidade ativa, **720**, 3, 3.1, 3.4

Abertura do testamento, **737**, 3.1

Autointerdição, **752**, 3.2, 3.2.1

Curatela, **756**, 3.1

Defensoria Pública, **720**, 1, 3.1.3

Divórcio, **731**, 4.1

Extinção união estável, **Seç. IV**, 2.3

Extinção de Fundação, **BEI**, 8.1.1

Interdição, **747**, 3.1.1; **747**, 3.1.4, 3.2

Levantamento da interdição, **756**, 3, 3.1

Ministério Público, **734**, 3.1; **747**, 3.2; **748**, 3.2; **756**, 3.2

Separação, **731**, 5.1

Legitimidade ativa concorrente e subsidiária, **748**, 3, 3.1

Legitimidade passiva, **721**, 3.1; **730**, 3.4; **747**, 3.3

Alienação, **730**, 3.4

Abertura do testamento, **735**, 3.4.4

Interdição, **747**, 3.3

Legitimidade e interesse recursal, **BEI**, 5.3.16, 7.2.3; **731**, 7.4, 7.7; **732**, 3.9; **734**, 3.7; **743**, 3.6; **745**, 3.8; **746**, 3.4.7; **763**, 3.3

Legitimidade processual do

Cônjuge ou companheiro, **747**, 3.1.1

Herança jacente, **738**, 3.4, 3.5

Tutor, **747**, 3.1.3; **Seç. X**, 2

Legitimidade subsidiária, **748**, 3.2

Levantamento da curatela, **BEI**, 7.2.4; **Seç. IX**, 4; **752**, 3.2.1; **756**, 1,2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5.1; **758**, 2

Lide, **BEI**, 3.1, 4.3, 5.2, 5.4.2, 5.4.3, 7.2.2; **721**, 3.4; **725**, 3.8.5; **725**, 3.8; **731**, 4.5; **731**, 4.5

Inexistência de (...), **BEI**, 2.2.2, 3.1, 3.7, 5.4.3; **721**, 3.4; **724**, 3.4; **Seç. II**, 3.2.1; **726**, 3.2, 3.4; **730**, 3, 3.1.3; 3.4

Composição da (...), **BEI**, 4.1; 4.3

Prevenção de (...), **BEI**, 4.2

Língua Portuguesa, **BEI**, 7.2.4; **767**, 3.1, 3.1.1; **768**, 3.3, 3.3.2

Litígio, **BEI**, 3, 4.1, 5.3.1.5, 7.2.3; **721**, 3.1.1; 3.4, 3.5; **724**, 3.1; **725**, 3.8.5; **728**, 3.1; **729**, 3.1; **730**, 2.1; **731**, 4.5

Locação e administração da coisa comum, **725**, 3.4; **730**, 2.2

Local da ausência, **744**, 2.1

Loucos, **747**, 3.3.1

M

Manifestação de interesse, **740**, 3.9; **741**, 3.1; **743**, 3, 3.1; **745**, 3.1; **746**, 3.4.1

Meios de comunicação, **726**, 3.7; **730**, 3.5.1

Morte presumida, **725**, 4; **Seç. VII**, 3; **744**, 2.1.1

Manifestação de vontade, **725**, 3.1.3.1; **Seç. II**, 1; 3.1; **726**, 2, 2.1.3, 3.4; **728**, 2, 3.1.2; **733**, 2.1.7; **Seç. V**, 2; **739**, 3.3.1; **744**, 3.4.1; **751**, 1

Município(s), **BEI**, 8.3; **722**, 3.1; **725**, 3.2, 3.7.3.1; **729**, 3.4; **730**, 3.1.4, 3.7.3; **Seç. VI**, 2, 3; **738**, 3.5; **739**, 1; **740**, 3.9; **741**, 3.1, 3.3; **742**, 3.5; **743**, 3, 3.1; **745**, 3.1, 3.5; **746**, 3, 3.4.1, 3.4.6, 3.4.7

Mérito, **BEI**, 3.7, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.1.6, 5.4.1, 5.4.2; **721**, 3.4

Sentença de, decisão de, **BEI**, 3.7, 5.3.1.6, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 7.1; **724**, 3.4; **725**, 3.8; **725**, 3.8.7

Julgamento de, resolução de, **BEI**, 2.1, 5.3.1.1, 5.3.1.4, 5.4.1, 7.1; **724**, 1, 3.1; **Seç. II**, 3.5; **750**, 3.2; **767**, 3.1

Modalidade extrajudicial (meios), **733**, 2, 2.1, 2.1.2, 2.1.4

Modalidade judicial (meios), **731**, 4; **734**, 3.6

Ministério Público, **BEI**, 2.1, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.1.3, 7.2.3, 8, 8.1, 8.2; **747**, 3.1.5

Atuação, participação, intervenção do (...), **BEI**, 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4; **720**, 3.4.1; **721**, 1, 3.3; **725**, 3.3.2, 3.8.2, 4; **730**, 3.7.1; **Seç. IV**, 2.2; **733**, 2; **735**, 3.3.6; **739**, 1, 3.5, 3.6; **740**, 3, 3.4; **741**, 3.4; **745**, 3.6; **Seç. IX**, 4; **748**, 1, 2, 3; **748**, 3.3; **752**, 1, 3, 3.2.2; **756**, 3.5.1; **760**, 3.1; **762**, 3; **Seç. XI**, 3; **764**, 2.2.1; **764**, 2.3; **764**, 3.1, 3.2; **764**, 3.5; **765**, 2.1, 3.4, 3.5, 3.6; **769**, 4

Ausência do (...), **744**, 2.1; **744**, 3.1; **744**, 3.7; **746**, 3.4.1; **747**, 3.3.4

Citação e intimação do (...), **720**, 3.2; **721**, 1, 3, 3.1.2, 3.1.2.1, 3.2; **725**, 3.1.3.5, 3.2.4.1; **730**, 3.1.4; **734**, 3.6; **735**, 3.3.5; **740**, 3.9; **745**, 3.2.2

E Fazenda Pública, **725**, 3.2.4.3, 3.7.3, 3.8.3.5; **737**, 3.3.2; **738**, 3.3; **739**, 3.1, 3.3.3; **740**, 3.2, 3.7; **741**, 3.6; **744**, 2.2; **744**, 3.4.3

Legitimidade do (...), **BEI**, 8.1.3; **720**, 3.1, 3.1.1, 3.1.2; **733**, 2.1.2; **737**, 3.1; **742**, 3.1; **745**, 3.2, 3.2.1; **Seç. IX**, 3; **747**, 2; **747**, 3.1, 3.1.4, 3.2; **748**, 3.1, 3.2; **752**, 3.2.3; **755**, 3.2; **756**, 1, 3.1; **761**, 3.1; **765**, 3, 3.2

Presença, participação, oitiva do (...), **721**, 3.4; **722**, 3; **725**, 3.7.3.3, 3.7.3.5; **730**, 3; **736**, 3.4.3; **737**, 3.3.3; **748**, 3.2.1, 3.2.2; **762**, 3.2; **763**, 3

Fiscal da ordem jurídica, **720**, 2, 3; **725**, 3.2.5.3; **730**, 2.1.1, 3.1.2, 3.8; **733**, 6.3; **734**, 3, 3.1; **739**, 3.1.4; **741**, 3.2; **751**, 3.3; **752**, 2, 3.2; **759**, 2; **763**, 3; **764**, 2.2.1.1

Melhor oferta, **730**, 3.7

N

Natureza homologatória, **BEI**, 9.4; **731**, 4.9, 5.9; **732**, 3.1.1

Natureza jurídica administrativa, **BEI**, 2.2.1

Natureza jurídica jurisdicional, **BEI**, 2.2.2

Natureza jurídica do(a), **BEI**, 2, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 3.1; **721**, 3.1.1

Alvará judicial, **725**, 3.7.2

Decisão, **725**, 3.5.2.6

Herança jacente, **Seç. VI**, 4

Material e processual, **Seç. IX**, 2, 3

Sentença, **725**, 3.6.2.7

Sentença de interdição, **755**, 3.1

Naufrágio e salvados, **Seç. XII**, 2.3

Negócios processuais, **BEI**, 1.2.1.1, 9.4

Atos e, **719**, 3.1; **739**, 3.3.1; **744**, 3.4.1

Competência de foro, **725**, 3.8.3

Definição, **719**, 3

Custas processuais, **729**, 3.1

Neuróticos, **747**, 3.3.1

Nome, **BEI**, 2.2.2, 4.2, 5.3.1.1, 8, 8.3; **720**, 2, 3.1; **722**, 3.1; **725**, 3.4.2.4, 3.7, 3.7.3.3, 4; **731**, 4.4.5, 4.7; **Seç. II**, 2, 3.2.1; **735**, 3.3.4; **736**, 3; **737**, 3.3; **738**, 3.4; **739**, 3.3.1, 3.3.5; **743**, 3.5.1; **744**, 3.4.1, 3.4.5; **745**, 3.2.4; **Seç. IX**, 2; **750**, 3.1; **756**, 3.4; **762**, 3.3; **770**, 3.3

Divórcio consensual e (...), **Seç. IV**, 2.1; **731**, 2

Empresarial, **739**, 2.2

Extinção consensual da união estável e (...), **732**, 3

Interessados, **BEI**, 3.4, 7.2.1, 7.2.2; **724**, 3.1

Manutenção do (...), **733**, 2, 2.1.7

Próprio, **738**, 3.3, 3.4

Petição inicial e (...), **726**, 3.2; **730**, 3.1.3

Registro de pessoa natural, **755**, 3.4

Nomeação do tutor, **759**, 2, 3.1; **762**, 3.3

Nomeação do curador, **749**, 3.1.1, 3.3; **755**, 2; **759**, 2, 3.1; **762**, 3.3

Notificação(ões), **BEI**, 3.6, 5.3.1.5, 6.1 7.1; **721**, 3.1.1, 2; **724**, 3; **Seç. II**, 1, 2, 3.1, 3.4; **726**, 1, 2, 2.1.1, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7; **727**, 3; **728**, 1, 2, 3, 3.1.1; **729**, 3.3, 3.4; **735**, 3.1.1; **737**, 4.1

Averbação da (...), **728**, 4

Deferida a (...), **729**, 3.2

Interpelação(ões) e , **BEI**, 3.6, 5.3.1.5, 6.1 7.1; **Seç. I**, 2; **721**, 3.1; **Seç. II**, 1, 2, 3, 3.2.1, 3.2.2, 3.3; **726**, 2, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7; **727**, 1, 2; **728**, 3.1; **729**, 1, 2, 3.3, 3.4; **Seç. XII**, 2; **769**, 3.4; **770**, 3.3

Interesses de terceiros, **730**, 3.2, 3.3; **734**, 2

Nulidade(s), **BEI**, 5.3.1.4, 8.1; **720**, 3.1.2, 3.2; **721**, 1, 3, 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.4; **722**, 3; **724**, 1, 3.1; **730**, 3.1.2, 3.6, 3.7.2; **731**, 5.7; **735**, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.5; **741**, 3.2; **764**, 3.2; **765**, 3.2

Absoluta, **756**, 3.4

De negócios jurídicos, **755**, 3.1

Do procedimento, **725**, 3.7.3.3, 3.8.2

E Ministério Público, **721**, 3.2, 3.4

Relativa, **733**, 2.1.2

O

Objeto, **BEI**, 5.3.1.2, 5.3.1.3, 5.4.3, 7.2.2, 7.2.3; **724**, 3.4; **725**, 3.7; **730**, 3; **733**, 2.1.1, 6; **748**, 3.1; **749**, 3.2; **751**, 3.1.1; **756**, 3.1; **Seç. XI**, 2.1; **764**, 2.1, 3.2; **765**, 3.1, 3.6; **766**, 2.1

Adjudicar o (...), **730**, 3.1.2

Conhecimento do (...), **730**, 2.1

Da arrecadação, **738**, 3.6; **739**, 2, 3.1.1; **744**, 2.2

Da oposição, **740**, 3.9

Da prova, **753**, 3.1; **Seç. XII**, 2.3; **769**, 3.1

De ação impugnativa autônoma, **725**, 3.8.2

De alienação judicial, **720**, 2.2; **730**, 3.1.2, 3.3, 3.5, 3.7.1, 3.7.3

De testamento, **Seç. VI**, 2.2

Do fideicomisso, **725**, 3.6, 3.6.2.6

Do processo, **BEI**, 3.6, 7.2.3, **731**, 4.4, 5.4; **732**, 3.6, 3.6.2; **741**, 3.3; **769**, 3.2; **770**, 3.2; **725**, 2, 3.2.4.3, 3.4, 3.6; **Seç. II**, 1, 3.1; **730**, 2.2; **738**, 3.4; **741**, 3.3; **746**, 2; **766**, 2.1, 2.2, 3, 3.1; **769**, 3.2; **770**, 3, 3.2

Oferecimento

De lance, **730**, 3.7.1

De resposta, **726**, 3.5, **728**, 3.1; **752**, 3.1

De denúncia, **746**, 5

Oportunidade, **BEI**, 2.2.2, 3.3, 5.3.1.4; **721**, 1, 3.3; **725**, 3.2.5.1, 3.2.5.3; **730**, 2; **735**, 2; **739**, 3.4; **744**, 3.4; **746**, 3.1, 3.3; **Seç. IX**, 3; **750**, 3.1, 3.2; **751**, 3.1; **755**, 1; **756**, 3.3; **765**, 3.3

De se manifestar, **728**, 3.1; **730**, 3.1.2, 3.1.4; **737**, 3.3.2; **760**, 3.1

E conveniência, **BEI**, 8.1; **720**, 2; **723**, 3; **724**, 3.2; **730**, 3, 3.1.1, 3.2; **764**, 3.5

Para requerimento de adjudicação, **730**, 3.1.2

Oposição, **BEI**, 8.1.1, 9; **725**, 3.3.2, **739**, 3.9; **740**, 3.7, 3.9

Ação de, **BEI**, 7.2.3; **725**, 3.8.2; **739**, 3.1.2; **741**, 3.7; **744**, 2.2

Dos embargos, **730**, 3.3

Organização e da Fiscalização das Fundações, **Seç. XI**, 2

P

Pagamento(s), **BEI**, 8.3.1; **725**, 3.2.5.3; **726**, 2.1.1, 3.6; **730**, 3, 3.1.2, 3.6, 3.7; **742**, 2.1

Das despesas, custas e impostos, **720**, 3.4.1; **725**, 3.6.2.4, 3.6.2.6.1; **729**, 3.1; **730**, 3.7.3, 3.9; **733**, 2.1.7; **735**, 3.1.1.2; **739**, 2, 3.4; **742**, 3.3, 3.4; **745**, 3.8; **746**, 3, 3.4.6, 3.4.7

Do descobridor, **746**, 3.4.3

Remanescente, **746**, 3.4.6

Do(s) preço(s); valor(es); **722**, 3; **725**, 1, 3.5; **730**, 2.2, 3.5.2, 3.7.3; **731**, 4.4.1, 4.4.2, 5.4.2; **738**, 3.6; **741**, 3.6; **746**, 3.4.6; **761**, 2

Parentes, **725**, 3.1, 3.7.3.3, 3.8.2; **731**, 4.4.2, 4.4.4; **Seç. V**, 2.1.1; **743**, 3; **748**, 3.4; **Seç. X**, 2, **751**, 1; **759**, 3.2

Legitimidade dos (...), **725**, 4; **746**, 3.1; **Seç. IX**, 3, 4; **747**, 1, 3.1, 3.1.2, 3.1.4; **756**, 3.1

Pai(s), **725**, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3.1, 3.1.3.2, 3.3.2.2, 3.7.1.1; **730**, 2.1.1; **731**, 4.4.3, 5.4.3, **Seç. IX**, 2, 3, 4; **747**, 3.1.2, 3.1.3; **748**, 3.2.2; **759**, 3.1, 3.2

Direitos e deveres dos (...), **731**, 4.4.4, 5.4.4; **732**, 3.6.3, 3.6.4; **744**, 3.3; **748**, 3, 3.2.1

Patrimônio, **720**, 3.1.1, 3.2.1, 3.2.4.1; **725**, 3.6.1.1; **730**, 2.1.1, 2.1.2, 3.7.3; **731**, 1, 4.4.1; **732**, 3.8; **Seç. V**, 2.1, 2.2; **738**, 3.4; **740**, 3.3; **741**, 3.4, 3.7; **Seç. IX**, 2; **747**, 3.3.4; **Seç. X**, 2; **759**, 2, 3.3.1; **Seç. XI**, 2.1.1, 3; **764**, 2.1, 2.2.1, 2.2.1.1, 3.3; **765**, 2, 2.1, 3.1, 3.6

Do requerente, do proprietário ou do ausente, **725**, 3.2.5.3, 3.2.5.5, 3.2.5.7; **744**, 3.6; **762**, 2, 3, 3.1

Público, **739**, 3.1.4; **745**, 3.5; **764**, 2.3

Penal (Direito), **BEI**, 3.1, 4.3.3, 9.4; **724**, 2; **Seç. II**, 3.3; **735**, 3.1.1.2, 3.4.4; **739**, 3.4; **744**, 3.4; **746**, 5

Pensão alimentícia, **731**, 2, 4.3, 4.4.2, 4.8, 5.3, 5.4.2; **732**, 3.5, 3.6.2; **733**, 2, 2.1.7, 6.2

Perturbações mentais, **747**, 3.3.1

Petição inicial, **BEI**, 5.3.1.1; **720**, 1, 3, 3.2; **721**, 3.4; **725**, 3.2.4.1, 3.3.2, 3.3.2.1, 3.4.2, 3.4.2.3, 3.4.2.4, 3.5.2.1, 3.5.2.3, 3.6.2, 3.7.3, 3.7.3.3, 3.8.2, 3.8.3.5; **Seç. II**, 3.2.1; **726**, 3.5; **727**, 3; **730**, 3.1.3, 3.1.4; **Seç. IV**, 1; **731**, 4.4.1, 5.4.1; **734**, 3, 3.4, 3.6; **748**, 3, 3.4; **761**, 3.3; **764**, 3.5; **765**, 3.3; **766**, 2.2, 4.1; **767**, 3, 3.1, 3.1.2; **768**, 3; **769**, 3

Pedido inicial, **Seç. II**, 3.1; **733**, 2.1, 2.1.5; **Seç. II**, 3.4, 3.5; **726**, 2, 3.2, 3.4, 3.5; **727**, 3; **730**, 3.1.3; **Seç. IV**, 2.1; **736**, 3.2; **737**, 3.3; **749**, 3.2; **750**, 3.2; **753**, 1; **764**, 3.1

Documentos, **720**, 3.2; **725**, 3.7.3.3, 3.8.2; **726**, 3.2; **731**, 4.6; **748**, 3, 3.4; **749**, 3, 3.1, 3.2; **750**, 3, 3.1; **767**, 3.1

Assinada pelos interessados e advogado, **731**, 4.1, 4.3, 4.6, 5.1, 5.3, 5.6; **732**, 3.5; **734**, 2, 3.3

Portadores de deficiência, **Seç. V**, 2.1.1

Prazo, **BEI**, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 7.2.4; **724**, 3.3, 3.4; **725**, 3.5.2.1, 3.5.2.2, 3.6, 3.6.1.1, 3.6.1.2.1; **726**, 2.1, 2.1.3; **727**, 2; **728**, 3.1.2, 3.1.3; **729**, 3.2; **730**, 3.5.1, 3.9; **721**, 4.6, 5.6; **735**, 3.4.3; **Seç. VI**, 3; **738**, 3; **740**, 3.6; **743**, 3.3, 3.5.2; **744**, 3.5; **745**, 3.2.4, 3.4, 3.5; **Seç. XI**, 3; **765**, 2.1, 3, 3.1, 3.3; **767**, 3.1; **768**, 3.2; **769**, 3; **770**, 2, 3.4

Do adiamento ou para a suspensão, **730**, 3.5.1, 3.5.2; **733**, 2.1.6

Início ou contagem do (...), **741**, 3.1; **745**, 3.1; **759**, 3.2; **766**, 4.1

Para abertura, manifestação ou para requerimento, **BEI**, 7.2.3; **720**, 3.2; **721**, 1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4; **722**, 3; **725**, 3.1.3.5, 3.5.2.4, 3.8.3.5; **728**, 3; **730**, 3.1.4; **734**, 3.4; **738**, 3, 3.1; **744**, 3.5; **745**, 3.2, 3.2.1, 3.3; **746**, 3.4.2; **Seç. IX**, 4; **750**, 3.2; **752**, 1, 3.1; **760**, 3.1; **761**, 3.2; **763**, 1, 2, 3, 3.1; **764**, 3.2; **765**, 3.2

Para decisão (em sentido amplo), **723**, 1, 3; **Seç. II**, 1; **Seç. XI**, 3; **764**, 2.2.1; **770**, 3.2

Para depósito, pagamento ou levantamento, **725**, 3.5.2.5; **730**, 3.7.3, 3.8

Para habilitação, apresentação ou compromisso, **739**, 3.2; **741**, 3.1, 3.3; **743**, 2, 3, 3.1; **743**, 3.5; **744**, 3.3; **745**, 3.1; **745**, 3.2.3; **753**, 1; **759**, 3, 3.1, 3.3.2; **766**, 1, 3

Para indicação de testemunha, **725**, 3.2.4.3; **769**, 3.1

Para realização da venda, **730**, 3.1.2; **742**, 3.4

Para recurso, **724**, 3.1; **725**, 3.5.2.7; **726**, 3.5

Preclusão, **724**, 3.1, 3.3; **743**, 3.1; **760**, 3.1; **763**, 3

Consequência da (...), **724**, 3.4

Preferência, **BEI**, 3.4; **725**, 3.3; **740**, 3.6; **746**, 1; **Seç. IX**, 4; **751**, 3.1; **755**, 1; **757**, 2

Direito de (...), **725**, 3.4.2, 3.4.2.4, 3.4.2.5, 3.5, 3.5.2.3, 3.5.2.5, 3.5.2.6, 3.6.2; **730**, 3.1.2, 3.1.4, 3.3, 3.7.3; **735**, 3.4

Prejudicial ou prejudicialidade, **721**, 3.1.2; **Seç. II**, 3.2.1; **730**, 3.5.2; **741**, 3.7; **744**, 3.2

Prescrição:

Das pretensões; das ações, **BEI**, 5.3.1.1; **743**, 3.5.1; **770**, 3.4

Interrupção da (...), **726**, 2.1.3; **739**, 3.3.4, **744**, 3.4.4

Processo(s)

De alienação judicial, **730**, 3.5

De conhecimento, **BEI**, 1.2.1.2; **719**, 1, 1.2

De execução, **719**, 1, 1.2; **Seç. III**, 2; **730**, 1, 2, 2.2, 3, 3.1.1, 3.1.2, 3.9; **742**, 3

Devido (...) legal, **728**, 3.1; **759**, 3.1

Incidentais, suspensão da vacância, **743**, 3.2; **759**, 3.1

Testemunháveis formados a bordo, **BEI**, 7.2.4; **729**, 2; **744**, 1; **Seç. XII**, 1, 2, 2.1, 2.3; **766**, 2, 2.1, 2.2; **767**, 1, 3.1.1; **768**, 2, 3.3, 3.3.2; **769**, 2, 3.3; **770**, 2

Procedimento(s)

Jurisdicional(is), **BEI**, 3.2

Extrajudicial(is); notarial(is), **BEI**, 6.1; **731**, 4.8, 5.8; **732**, 3.10; **734**, 3

Especiais, **BEI**, 1.2, 1.2.1.3, 9; **719**, 1.2, 3; **725**, 3, 3.2.3, 3.8.2, 4; **728**, 3.1.2; **730**, 2.2; **731**, 4, 4.4.4; **732**, 3.1, 3.6.4; **733**, 2.1.5; **735**, 3.4.4; **Seç. VI**, 2; **738**, 3.3, 3.4; **739**, 2; **740**, 3.7; **746**, 4; **747**, 3.1; **Seç. XII**, 1, 2.1; **768**, 3.3, 3.3.2

Pródigo(s), **730**, 3.1.1; **747**, 3.1, 3.1.4, 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4; **755**, 2

Exclusão do (...), **747**, 3.1.4

Protesto, **BEI**, 5.3.1.5, 6.1, 9; **Seç. I**, 2; **721**, 3.1.1; **Seç. II**, 1, 2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3, 3.4, 3.5, **726**, 2, 2.1.3, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7; **727**, 2, 3; **728**, 2, 3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4; **729**, 1, 3.2, 3.3

Contra (...), **728**, 3.1.3

Na justiça do trabalho, **Seç. II**, 3.3

Judicial, **Seç. II**, 3.1; **726**, 1, 2.1.3; **729**, 3.4

Extrajudicial, **Seç. II**, 2

Protestos marítimos, **BEI**, 7.2.2, 7.2.4; **729**, 2; **744**, 1; **Seç. XII**, 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3; **766**, 1, 2, 2.1, 2.2, 3.1, 4, 4.1; **767**, 1, 3.1, 3.1.1, 3.1.2; **768**, 2, 3.2, 3.3; 3.3.2; **769**, 2, 3.2, 3.3, 3.4; **770**, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

Protestos contra alienação de bens, **726**, 3.1

Prova(s), **BEI**, 1.2.1.1, **725**, 3.5.2.2

Pericial e assistência técnica, **BEI**, 5.3.1.2; **725**, 3.1.3.4, 3.2.4.3; **Seç. IX**, 4; **749**, 1; **750**, 3; **753**, 1, 2,

3.2; 754, 2, 3; 756, 3.2; 769, 3.1

Testemunhal, **BEI**, 5.3.1.2, 5.3.1.3, 7.2.4; 725, 3.1.3.1, 3.1.3.4, 3.2.4.2, 3.2.4.3; 730, 3, 3.2, 3.5.1; 734, 3.5; 737, 3.3.1, 3.3.3; 746, 3.4.1; 751, 3.2; 753, 3.1; 767, 3, 3.1; 768, 3.3; 769, 3.1, 4; 770, 3.2

Psicóticos, 747, 3.3.1

Publicidade, 725, 7.6.2.7; 725, 7.6.2.7; 730, 3.6; **Cap. XV, Seq. II**, 3.4

Do Estado, **Seq. I**, 2

Edital, 741, 3.1

Medidas de, **BEI**, 9; **Seq. I**, 2

Registrária, 726, 2

Q

Quinhão em coisa comum, 725, 3.5, 3.5.2; 730, 2.2

R

Rateio, 729, 3.1

Razões da extinção, 765, 3.4

Reclamação, 746, 3.4.2; 767, 1, 2.2

Recompensa(s), 745, 3.8; 746, 2, 3, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.6, 3.4.7, 5; 767, 2.2

Reconstituição física, 729, 3.3

Recorribilidade, **BEI**, 1.2.1.5; 724, 1, 2, 3, 3.1; 725, 3.1.3, 3.4.2, 3.6.2; **Seq. II**, 3.4, 3.5, 764, 3.6; 765, 3.7; 770, 3

Registro de pessoa natural, 755, 3.4

Regresso do ausente, 745, 3.4

Remoção do curador, 739, 3.5; 744, 3.7; 761, 3.3

Representante de entidade de abrigo, **Seq. IX**, 4; 747, 3.1.4; 748, 3.2.1

Representar, **Seq. VII**, 3.4.1

Responsabilidade criminal, 746, 5

Revelia, **BEI**, 3.3, 5.3.1.1; 721, 3.1.1, 3.4; 724, 3.3; 752, 3, 3.1

Risco, 762, 3.1

Renúncia, **BEI**, 4.3.1; 724, 3.4; 725, 1, 3.6, 3.6.2.1, 3.6.2.1.2; 725, 3.8.1.1; 726, 3.1; 731, 4.4.2, 5.4.2; 732, 3.6.2; 733, 2.1.7; 733, 6.2; **Seq. VI**, 2, 2.1; 742, 2.

S

Sentença, **BEI**, 1.2.1.2, 4.3, 4.3.3, 5.3.1.3; 723, 3; 725, 3.1.3.7, 3.2.4.4, 3.6.2.7, 3.7.1.1; 731, 4.7, 5.7; 732, 3.9; 734, 3.6; 743, 3.1; 744, 3; 745, 3.2.4; **Seq. IX**, 1; 755, 3.1

De mérito, **BEI**, 3.7; 724, 3.4; 725, 3.8, 3.8.2

Final, **BEI**, 5.3.1.4, 5.4, 5.4.1, 5.4.2; **743**, 3.3

Parcial, **BEI**, 5.3.1.5

Recurso da (...); recorribilidade da (...), **BEI**, 5.3.1.6, 5.4.3; **724**, 1, 3, 3.1; **725**, 3.1.3.8, 3.7.3.6; **Seç. II**, 3.4; **729**; **734**, 3.7; **743**, 3.6; **745**, 3.8; **746**, 3.4.7; **755**, 3.2; **761**, 3.3; **763**, 3.3; **764**, 3.6; **765**, 3.7; **770**, 3.3

Sentença de vacância, **743**, 3.3

Separação consensual, **719**, 1.1; **Seç. IV**, 1, 2.1, 2.2; **731**, 1, 2, 4, 4.4.1, 4.4.5, 5, 5.1, 5.3, 5.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3; **732**, 3.3; **733**, 2, 2.1.7, 6, 6.3

Sinistro(s), **725**, 3.2.5.5; **766**, 2, 2.2; **767**, 2, 2.1; **769**, 3.2

Ratificáveis, **Seç. XII**, 2.3, **766**, 1; **770**, 2

Solução consensual, **BEI**, 2.1, 4.3, 4.3.2, 4.3.3; **725**, 1, 3.8.1.2, 3.8.1.3

Sub-rogação, **725**, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4.1, 3.2.4.2, 3.2.4.4, 3.2.5, 3.2.5.1, 3.2.5.2, 3.2.5.4, 3.2.5.7, 3.3.2, 3.6.2.5; **730**, 3.8

Sucessão

Abertura (...), **725**, 3.6.1.2, 3.6.2.6.2; **735**, 3.3.1; **Seç. VI**, 2; 3; **738**, 3, 3.1; **739**, 3.1.2, 3.3.2; **740**, 3.6; **741**, 3.1, 3.2; **743**, 3, 3.1, 3.5.1; **Seç. VII**, 3; **744**, 2.2; **745**, 3.1

Abertura de ofício da (...), **738**, 3.3

Abertura definitiva da (...), **744**, 2.1

Abertura provisória da (...), **744**, 2.1; **744**, 3.1; **744**, 3.5; **745**, 3.2; **745**, 3.2.4; **745**, 3.3

Competência para a (...), **738**, 3.5

Conversão da (...), **744**, 3.1; **744**, 3.5, **745**, 3; **745**, 3.2; **745**, 3.3

De cujus, **744**, 3.6

Definitiva (...), **745**, 3.3, 3.4, 3.5

Definitiva, bens dos ausentes, 3

Do falecido, **743**, 3.5.3

Estatal, **738**, 3.5

Na pensão por morte, **744**, 3.2

Ordem de sucessão na (...), **725**, 3.7.3.2

Processual, **730**, 3.4

Provisória ou permanente, **BEI**, 8.3.1; **735**, 3.3.1; **Seç. VII**, 2

Provisória, **745**, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3; **745**, 3.2.4; **745**, 3.3

Sujeito(s) processual(is), **BEI**, 5.3.1.1, 7; **Seç. II**, 3.2

Suspensão, **BEI**, 1.2.1.1; **725**, 4; **730**, 3.1.2; **730**, 3.5.2; **733**, 2.1.6, 2.1.7; **743**, 3.2

Do Arrolamento, **740**, 3, 3.7

Do curador; do tutor, **739**, 3.5; **744**, 3.7; **758**, 3; **759**, 3; **759**, 3.4; **762**, 2, 3, 3.1, 3.3

Do processo, **720**, 3.4.2; **721**, 3.3; **725**, 1; **762**, 3.1

T

Tecnologias, tecnológicas

Inovações, **Seç. VI**, 1; **Seç. VIII**, 3; **Seç. IX**, 4; **751**, 1

Testamento

Cerrado, **BEI**, 7.2.4, 8.1.1; **719**, 2.1; **Seç.V**, 2.1.2, 2.2; **735**, 2; **737**, 3.3

De ausente, **735**, 3.3.1

Marítimo, **Seç. V**, 1, 2, 3.3

Militar, **Seç. V**, 1, 2, 3.3

Nuncupativo, **Seç. V**, 1, 2, 3.3

Particular, **BEI**, 8.1.1; **Seç. V**, 2.2, 3; **737**, 2, 3, 3.3

Termo de abertura do (...), **735**, 3.1, 3.3.4

Testamentos e codicilos, **BEI**, 7.2.3; **735**, 3.3; **743**, 3.2

Testamenteiro, **BEI**, 8.1.1; **740**, 3.7

Direitos, deveres, obrigações, contas (...), **735**, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4; **736**, 3.5; **739**, 3.3.3

Legitimidade (...), **721**, 3.1; **722**, 3; **725**, 3.2.4.1

Manifestação; participação (...); **730**, 3.7.1; **735**, 3.1; **736**, 3.5; **737**, 1, 3.4

Substituição do; remoção do, **735**, 3.4, 3.4.5

Terceiros, **BEI**, 1.2.1.1, 7, 7.2, 7.2.3; **721**, 3, 3.5; **725**, 3.2.4.3, 3.8.2; **Seç. II**, 3.2, 3.2.1, 3.2.3; **726**, 3.3; **729**, 3.4; **730**, 3.1, 3.2, 3.3; **Seç. IV**, 2.3, 2.4; **731**, 4.9, 5.9; **732**, 2; **734**, 2, 3.1, 3.4, 3.6; **736**, 3; **739**, 3.1.2, 3.3.3, **744**, 3.1, 3.4.3; **745**, 3.2.4; **Seç. IX**, 3; **747**, 3.3; **763**, 1; **Seç. XII**, 2.3; **769**, 2, 3.1, 3.4

Intervenientes, **BEI**, 1.2.1.1, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 7.2.3, **725**, 3.2.4.3, 3.8.2; **769**, 3.1

Interessados, **BEI**, 7.2.3, **Seç. IX**, 3

Tomada de decisão apoiada, **BEI**, 7.2.4; **725**, 4; **Seç. V**, 2.1.1; **Seç. IX**, 2, 3, 4, **747**, 3.2, 3.3; **757**, 2

Trabalhista (Direito), **BEI**, 1.1, 9.3; **725**, 3.7.1, 3.8.2; **Seç. XII**, 2

Tradutor, **BEI**, 7.2.4; **Seç. I**, 2; **735**, 2; **767**, 3.1.3; **768**, 3.3.2. **769**, 3

Trânsito em julgado, **BEI**, 5.4; **724**, 3.4; **725**, 3.2, 3.1.3.7, **731**, 4; **731**, 5.9; **734**, 3.6; **743**, 3.3, 3.5.1; **744**, 2.1; **745**, 3.2.4, 3.3; **760**, 3.2; **770**, 3.3

Tutela antecipada, **BEI**, 1.2.1.1

Tutela(s) cautelar(es); medidas provimento; procedimento, **BEI**, 1.2.1.1, 9; **Seç. I**, 2; **725**, 4; **738**, 3.3; **Seç. II**, 1, 2, 3.2, 3.2.1, 3.3; **728**, 1, 3.1.4; **730**, 2.2, 3.8; **738**, 3.1, 3.3; 3.4; **739**, 3.4; **742**, 3.3; **744**, 2.2; **747**, 3.1.1; **762**, 3.1; **770**, 2

Tutela da evidência, **736**, 1; **738**, 3.3; **762**, 3.1

Tutela de direitos, **BEI**, 1.2.1.1

Tutela de urgência, **749**, 1, 3.2; **762**, 3.1

Tutela provisória, **BEI**, 1.2.1.1; **Seç. II**, 1, **728**, 3.1, **736**, 1, **738**, 3.3, **749**, 1, 3.2; **762**, 2, 3.1

Tutor(es), **BEI**, 5.3.1.1; **Seç. IX**, 4; **747**, 3.1.3; **748**, 3; **Seç. X**, 2, 3, **759**, 2, 3.3; **760**, 2

Contestação do (...), **BEI**, 5.3.1.1; **761**, 3.2

Nomeação do (...), **759**, 2, 3.1; **762**, 3.3; **Seç. V**, 2.1; **744**, 3.4; **759**, 3

Remoção do (...), **BEI**, 8.1.1; **720**, 3.2.1; **739**, 3.5; **744**, 3.7, 3.1.3, **Seç. X**, 2; **759**, 3.1; **761**, 3.1, 3.1.3; **762**, 2

Participação do (...); manifestação, **725**, 3.1.2, 3.1.3.1, 3.1.3.2, 3.1.3.5, 3.3.2.2, 3; **747**, 3.1.3, **759**, 3.2, 3.3

Venda; alienação, contas do (...), **730**, 2.1.1, 3.7.1; **759**, 3.3.2; **760**, 3.1

U

União, **BEI**, 7.2.4, 8.3; **722**, 3.1; **725**, 3.2, 3.7.2.4, 3.7.3.1, 3.8.3, 4; **Seç. II**, 3.3; **729**, 3.4; **730**, 3.1.4, 3.7.3, 3.8; **Seç. VI**, 2, 3; **739**, 1, 2; **742**, 3.5; **740**, 3.2; **745**, 3.5; **766**, 4

Usucapião, **Seç. VI**, 4; **739**, 3.1.2; **741**, 3.7; **743**, 3.4, 3.5.2; **744**, 2.2, 3.1

Uso, **725**, 3.3.1, 3.6.1.1, 3.6.1.2, 3.6.2.6.1; **730**, 3.3

Especial, **730**, 3.1.4; 3.4

Pessoal, **Seç. V**, 2.1, 2.2; **742**, 2.4

Gozo, **725**, 3.3.1, 3.6.1.1, 3.6.1.2, 3.6.2.6.1; **730**, 3.1.4; **741**, 3.7

Usufruto, **725**, 1, 3.6, 3.6.1, 3.6.1.1, 3.6.1.2, 3.6.2.1, 3.6.2.3, 3.6.2.1, 3.6.2.6, 3.6.2.6.1, 3.6.2.6.2, 3.6.2.7; **730**, 3.1.4, 3.3; **744**, 3.1

Usufrutuário, **725**, 1, 3.6, 3.6.1, 3.6.1.1, 3.6.2.1, 3.6.2.4, 3.6.2.7

V

Vacância, **Seç. IV**, 2, 2.1, 2.2; **Seç. VI**, 3, 4; **738**, 3, 3.1, 3.2, 3.3; 3.5; **739**, 2, 3.1, 3.1.4, 3.4, 3.5, 3.6; **740**, 3.9; **741**, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7; **742**, 2.1, 3.3, 3.4; **743**, 2, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5.1, 3.5.2, 3.6; **746**, 3.4.2

Venda, **730**, 2.2, 3.1.2, 3.3, 3.6, 3.7

Autorização para (...), **725**, 3.2.5.2, 3.7.2

Avaliação e (...), **725**, 3.3.2; **730**, 3.5, 3.5.1

Compra e (...), **725**, 3.2.5.2, 3.3.1, 3.1.4; **730**, 3.3, 3.7

De bem sub-rogado, **725**, 3.2.5.1

De coisa comum; imóvel, **725**, 3.4.1, 3.4.2.2, 3.5, 3.7.1; **Seç. II**, 3.3

De menores; incapazes, **730**, 2.1.2; 3.1.4, 3.7.2

De quinhão, **721**, 3.1.2.1, 3.5, 3.5.2
Desapropriação e (...), **725**, 3.2.5.4
Fiscal da (...), **725**, 3.2.5.3
Melhor oferta, **730**, 3.7
Preço; valor da (...), **725**, 3.4.2.2, 3.5.2, 3.5.2.4; **730**, 3.5.1, 3.5.2
Produto da (...), **725**, 3.2.5.6
Publicidade e (...), **730**, 3.6
Via extrajudicial, **733**, 2, 2.1.6, 5; **733**, 6; **734**, 2
Via judicial, **733**, 2, 2.1.6, 5, 6.2; **765**, 2
Viciado(s) em tóxico, **730**, 2.1.1; **747**, 3.1, 3.1.4, 3.3, 3.3.2, 3.3.4

© desta edição [2018]